T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

100 SORUDA DOĞRUDAN TEMİN

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Cevdet BOZKURT
Bakanlık İç Denetçisi

Serdar ÖZEN
Bakanlık İç Denetçisi

ARALIK-2022

İÇİNDEKİLER

S U N U Ş 7
KISALTMALAR 9
1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına hangi idareler ve ne tür alımlar girmektedir? 11
2. Doğrudan temin yöntemi nedir ve hangi nitelikteki ihtiyaçlar 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesi kapsamında bu yöntemle karşılanabilir? 18
2.1. Doğrudan temin kapsamı alımlardan hangileri Yasa'nın 22/d maddesine girer? 20
3. Doğrudan temin yönteminin sağladığı kolaylıklar ile bu alım yönteminde karşılaşılan zorluklar nelerdir? 25
3.1. Getirilen kolaylıklar 26
3.2. Karşılaşılan zorluklar/zorunluluklar 28
4. Doğrudan temin kapsamı alımlarda 4734 sayılı Kanun'un "Temel ilkelerinin" dikkate alınması zorunlu mudur? 30
5. Doğrudan temin kapsamı alımlarda yapılan iş ve işlemler nelerdir, işlem akış sırası nasıldır? 37
5.1. İhtiyacın ortaya çıkması/ihtiyacın bildirilmesi 38
5.2. Teknik şartnamenin/projenin hazırlanması 39
5.3. Yaklaşık maliyetin hazırlanması 40
5.4. Onay belgesinin düzenlenmesi 41
5.5. Piyasa fiyat araştırması yapacak kişilerin görevlendirilmesi 42
5.6. Piyasa fiyat araştırması yapılması 42
5.7. Teklif mektuplarının/Tekliflerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi 43
5.8. Sözleşme yapılması 44
5.9. Teslim ve kabul süreci 45
5.10. Ön mali kontrol 45
5.11. Ödeme belgesinin düzenlenmesi 46
5.12. Taşınır İşlem Fişinin (TİF) düzenlenmesi 47
5.13. Ödemenin kontrolü ve yapılması 47
5.14. Doğrudan Temin Kayıt Formunun KİK'e elektronik ortamda gönderilmesi 48
6. Doğrudan temin kapsamı alımlarda Onay Belgesi ve Harcama Talimatının kapsamı ve düzenleniş şekli nasıldır? 50
6.1. Doğrudan temin yöntemi kullanılarak 22/d maddesi kapsamında yapılacak alımlar için hazırlanacak Onay belgesinin şekli nasıl olacak ve hangi bilgileri içerecektir? 52
7. 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak her alım için ayrı bir Onay Belgesi düzenlenmesi zorunlu mudur? 55
8. Doğrudan temin kapsamı alımlarda teknik şartname düzenlenmesi zorunlu mudur? 58
9. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda idari şartname zorunlu mudur? 62
10. Doğrudan temin yönteminde yaklaşık maliyet hesaplanması gerekmekte midir? 67
10.1. 4734 sayılı Kanun'un 22/d maddesi kapsamı alımlarda ödeme belgesine yaklaşık maliyet hesap cetveli eklenmeli midir? 73
11. Doğrudan temin kapsamı alımlarda hesaplanan yaklaşık maliyetin üzerinde teklifin bulunması durumunda idare ne yapmalıdır? 76

12. Doğrudan temin kapsamında belirlenen yaklaşık maliyetin gizlenmesi gerekmekte midir? 81
13. Doğrudan temin yönteminde ihale komisyonu kurulması gerekir mi? 86
13.1. Bir personelin resmi görevlendirmeye rağmen ihale (alım) komisyonu üyesi olmak istememesi mümkün müdür?..... 91
14. Doğrudan temin kapsamında ilan yapılması gerekli midir?..... 93
15. Doğrudan temin yönteminde teminat alınması zorunlu mudur? 100
16. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesindeki yeterlik şartlarına uyulur mu?..... 106
17. Doğrudan temin kapsamı alımlarda 4734 sayılı Kanun'da yer alan eşik değer ve parasal sınırlar hangi anlama gelmektedir?..... 113
18. Doğrudan temin kapsamı alımlarda piyasa fiyat araştırması yapacak kişiler nasıl belirlenir?..... 120
19. Doğrudan temin yöntemi alımlarda piyasa fiyat araştırma sürecinde yazılı teklif alınması zorunlu mudur?..... 125
20. Doğrudan temin yönteminde internet üzerinden (elektronik ortamda) alım yapılabilir mi?..... 130
20.1. Türk Borçlar Kanunu ve ihale mevzuatı açısından elektronik ortamda alım süreci nasıl değerlendirilmelidir? 134
21. Doğrudan temin kapsamında ticaret odaları ve meslek odaları nezdinde araştırma yapılması zorunlu mudur?..... 140
22. Doğrudan temin kapsamı alımlarda piyasa fiyat araştırması ihale yetkilisince onaylanmalı mıdır? 146
23. Doğrudan temin yönteminde teklif alınacak kişi ya da firma sayısı kaç olmalıdır? 151
24. Doğrudan temin kapsamında yer alan ve istisna durumuna girmeyen alımlarda marka belirtilebilecek midir?..... 157
25. Doğrudan temin yönteminde ihtiyacın gerçek veya tüzel tek kişiden temini (22/a) nasıl olmalıdır? 162
26. İhtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden temini (22/b) nasıl gerçekleşmektedir? 170
27. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlara ait dokümanlarda bakım onarım kapsamında garanti ve yedek parçaya yönelik düzenlemeler nasıl olmalıdır? 178
28. Doğrudan temin kapsamı alımlarda kısmi teklif ve dolayısıyla kısmi alım mümkün müdür?..... 186
29. İhtiyacın kısımlara bölünerek doğrudan temin limitinin altına çekilmesi mümkün müdür?..... 193
30. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda sözleşme düzenlenmesi zorunlu mudur? 202
31. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda muayene ve kabul işlemleri nasıl yapılır?..... 208
32. Doğrudan temin yönteminde fiyat farkı ödenebilir mi? 215
33. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda damga vergisi kesilir mi? 224
34. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda ihale karar pulu (vergisi) alınır mı? 230
35. Doğrudan temin kapsamı alımlarda süre uzatımı verilebilir mi? 235
36. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?..... 243
37. Doğrudan temin yönteminde alım sürecinde pazarlık yapılması gerekli midir?..... 248
38. Doğrudan temin kapsamı alımlarda tekliflerin eşit olması durumunda ne yapılması gerekmektedir? 254
39. Doğrudan temin yönteminde iş artışı yapılabilir mi? 260
40. Doğrudan temin kapsamı alımlarda tekliflerde aritmetik hatanın bulunması durumunda ne

yapılmalıdır? 266
41. Doğrudan temin kapsamı alımlar Kamu İhale Kurumu'na (KİK) bildirilir mi? 272
42. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yükümlülüğünün kapsamı nedir? 277
43. Doğrudan temin kapsamı alımlarda gecikme cezası uygulanması mümkün müdür? 284
44. Doğrudan temin yönteminde hakediş ödemelerinde SGK'dan ilişiksizlik belgesi istenir mi? 296
45. Doğrudan temin kapsamı alımlarda hakediş raporu hazırlanmalı mıdır? 302
46. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlara ilişkin ödemelerde vergi borcu sorulur mu? 310
47. Doğrudan temin kapsamı alımlarda ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilir mi? 316
48. Doğrudan temin kapsamı alımlarda ihalelerde katılmaktan yasaklama teyidi yapılır mı? 322
49. Kamu kuruluşları birbirlerinden doğrudan temin kapsamında alımlar yapılabilir mi? 327
50. Doğrudan temin yönteminde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması mümkün müdür? 333
51. 4734 sayılı Yasa'nın 22/c maddesi kapsamında idare ihtiyaçlarının ihalesiz olarak ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden karşılanması mümkün müdür? 339
51.1. Düzenlenecek sözleşmelerin niteliği nasıl olmalıdır? 342
52. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilebilir mi? 346
53. Doğrudan temin kapsamı alımlarda ödeme süreci nasıl işlemektedir? 354
54. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda kurum bütçesinin %10 sınırı nasıl uygulanır? 363
55. İhale usulü olmayan doğrudan temin yönteminde ödeneksiz alım yapılabilir mi? 368
56. Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan temini için doğrudan temin yöntemi kullanılabilir mi? 375
57. Doğrudan temin kapsamında kullanılmış makine, taşıt veya demirbaş alımı yapılabilir mi? 379
58. Doğrudan temin kapsamı alıma ait ödeme sürecinde Bütçe tertibi yönünden "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" açısından parasal sınır var mıdır? 385
59. Doğrudan temin kapsamında (22/d) yapılan temsil ve ağırlama giderleri parasal sınırlamaya tabi midir? 393
60. Doğrudan temin kapsamı alımlarda yerli malı/yerli istekliye sağlanan avantajlar nelerdir? 400
61. Doğrudan temin kapsamı alımlarda ön mali kontrol yapılır mı? 406
62. Danışmanlık hizmetleri doğrudan temin yöntemiyle alınabilir mi? 413
63. 4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesi kapsamı doğrudan temin yönteminde yakın akrabadan alım yapılabilir mi? 419
64. Doğrudan temin kapsamı alımlarda sözleşmenin feshi söz konusu olabilir mi? 427
65. Doğrudan temin kapsamı alımlarda düzenlenmiş ise sözleşmenin devri mümkün müdür? 433
66. Piyasa fiyat araştırması kapsamında yurtdışından alım yapılabilir mi? 442
67. Doğrudan temin yöntemindeki parasal limit ve alımlardaki hesaplamaya KDV dahil midir? 450
68. İhalelerden katılmaktan yasaklananlar doğrudan temine teklif verebilir mi? 457
69. Doğrudan temin kapsamında taşıt kiralanması mümkün müdür? 463
70. Avans kullanmak suretiyle doğrudan temin kapsamında alım yapılabilir mi? 469
71. Farklı kamu idareleri adına tek idare veya aynı kurumun harcama birimleri adına tek birim ortak alım yapabilir mi? 478
72. 4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesi kapsamı alımlara ait ödeme süreci ve ödeme sürecinde maddi hatanın varlığında ne yapılır? 486

73. Doğrudan temin kapsamı alım sürecinde fatura ve fatura yerine geçen belgeler kıyas yoluyla sözleşme kabul edilip damga vergisi kesintisine tabi tutulur mu? 494
74. Doğrudan temin yöntemiyle milletlerarası alanda avukatlık hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet hakkı tescil sürecine ilişkin hizmet alımlarının kapsamı nedir? 501
75. Doğrudan temin kapsamında idareler taşınmaz alımı veya kiralaması yapılabilir mi? 508
76. Doğrudan temin kapsamında yapım işi gerçekleştirilebilir mi? 515
77. Doğrudan temin kapsamı alımlarda KDV tevkifatı yapılır mı? 522
78. Gelir vergisi stopajı (tevkifatı) doğrudan temin kapsamı alımlarda uygulanır mı? 529
79. Doğrudan temin kapsamı alımlarda alacağın temliki (alacağın devri) mümkün müdür? 535
80. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen hangi ödemelerde Taşınır İşlem Fişi (TİF) aranmaktadır? 542
81. Doğrudan temin kapsamı alımlarda ihaleye fesat karıştırma suçu oluşur mu? 550
82. Doğrudan temin kapsamı alımlarda edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenebilir mi? 558
83. Doğrudan temin kapsamında firmadan alınan "yazılı teklif" teklif sahibini bağlar mı? 565
84. Doğrudan temin kapsamı alımlar açısından harcama yetkilisi/ihale yetkilisi nedir ve harcama yetkisinin devri mümkün müdür? 575
85. Doğrudan temin kapsamı alımlarda düzenlenecek sözleşmeler birim fiyat şeklinde mi yoksa götürü bedel olarak mı sözleşmeye bağlanmaktadır? 582
86. Doğrudan temin yönteminde iş artışı, fiyat farkında damga vergisi alınır mı? 590
87. Doğrudan temin yönteminde KİK'e şikâyet başvurusu yapılabilir mi? 599
88. Mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi doğrudan temin kapsamı alımlara engel midir? 605
89. İdareler doğrudan temin yöntemini kullanarak piyasadan güvenlik veya temizlik elemanı (taşeron) alımı yaparak bunları çalıştırılabilir mi? 613
90. Doğrudan temin yöntemi alımlara ilişkin olarak KİK'in resen inceleme yetkisi var mıdır? 621
91. Doğrudan temin kapsamı alımlarda taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda ne yapılır? 627
92. Çeşitli hukuki düzenlemelerde birlikte ifade edilen 4734 sayılı Yasa'nın 22/d ve 21/f maddeleri kapsamı alımlar arasında bir bağlantı var mıdır? 637
93. Doğrudan temin kapsamı alımlarda tebligat usul ve esasları nasıldır? 644
94. İdarenin doğrudan temin kapsamı alımlarda takdir hakkı bulunmakta mıdır? 653
95. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda kontrol teşkilatı kurulur mu? 659
96. Doğrudan temin yönteminde sigorta uygulaması mümkün müdür? 668
97. Doğrudan temin yönteminde sulh anlaşması yoluyla kamu idareleri alımlara ilişkin uyuşmazlıklarda yüklenici ile anlaşabilir mi? 677
98. Doğrudan temin yönteminde dava ne zaman açılabilir? 686
99. KBS boyutuyla taşınır ve bağlantılı harcama kapsamı işlemler örnek uygulamalar çerçevesinde nasıl gerçekleştirilmektedir? 691
100. Doğrudan temin yönteminde EKAP üzerinden işlem yapılmakta mıdır? 713
MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 726
MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ 756
KAYNAKÇA 763

SUNUŞ

Uluslararası ihale uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin olmak üzere dört ihale usulü belirlenmekle birlikte, 30.07.2003 tarihinde 4964 sayılı Kanun ile yapılan yasal değişiklikle doğrudan temin, ihale usulleri arasından çıkartılmıştır.

Doğrudan temin yönteminin sadece 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen durumlarda kullanılması mümkün olup, bu yönteme ilişkin temel ilkeler ise aynı maddede düzenlenmiştir. Kanun'un "Tanımlara" ilişkin maddesinde ise "Doğrudan temin"; "Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" şeklinde ifade edilmiştir.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yayımlanan 2021 yılı Kamu Alımları İzleme Raporuna göre; bir yıllık dönem için doğrudan temin yolu ile yapılan kamu alımlarının sayısı 544.913 adet iken, aynı dönem için bu kapsamdaki toplam alım bedeli ise 13.193.476.000.- TL'dir.

Kamu harcamaları içerisinde büyük bir yer tutan söz konusu alım yönteminin, ihale mevzuatı dışındaki hukuki düzenlemelerden de etkilendiği dikkate alınarak, bu hususta herhangi bir işlem tesis edilirken bağlantılı mevzuatın da dikkate alınması uygun olacaktır.

Bu çalışma ise 19.12.2022 tarihindeki cari mevzuat dikkate alınarak hazırlanmış olup, ilgili mevzuatın değişen yapısının (ve güncellenen rakamsal tutarların) süreçte göz önünde bulundurulması büyük önem arz etmektedir.

Bakanlıktaki satın alma süreçlerine katkı yapmak ve aynı zamanda kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yarar sağlayacağına inandığım "100 Soruda Doğrudan Temin" isimli bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen başta İç Denetçi Cevdet BOZKURT olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı tebrik eder ve Bakanlığımız için faydalı olmasını temenni ederim.

Serdar ÖZEN
İç Denetim Birimi Başkanı

KISALTMALAR

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	KMYKK
Kamu İhale Kurumu	KİK
Elektronik Kamu Alımları Platformu	EKAP
Çevresel Etki Değerlendirme	ÇED
Türk Ceza Kanunu	TCK
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi	KBS
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği	MYHBY
Taşınır İşlem Fişi	TİF
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	EPDK
Devlet Malzeme Ofisi	DMO
Sosyal Güvenlik Kurumu	SGK
Türk Borçlar Kanunu	TBK
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi	TKYS
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi	BKMYBS
Mali Yönetim Sistemi	MYS
Varlık İşlem Fişi	VİF
İdari Yargılama Usulü Kanunu	İYUK
Katma Değer Vergisi	KDV
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu	TÜBİTAK
Ceza Muhakemesi Kanunu	CMK

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına hangi idareler ve ne tür alımlar girmektedir?

Özet: *Bir idarenin 4734 sayılı Kanun'a tabi olması için gerekli şartları; kamu hukukuna tabi olması, kamunun denetimi altında bulunması ve kamu kaynağı kullanması şeklinde sıralayabiliriz. Dolayısıyla, bu şartlardan en az birini sağlayan bir idarenin bulunması veya ileride kurulması durumunda bu idare 4734 sayılı Kanun'a tabi olacaktır. Kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan ve sadece talep edenlerin faydalandığı hizmet ve alımları, gerek kamu idaresi olarak kabul edilmemesi ve gerekse kullanmış olduğu kaynakların kamu kaynağı kapsamına girmemesi sebebiyle, bu nitelikteki alımlar 4734 sayılı Kanun kapsamına girmemektedir. Kamu alımları çerçevesinde gerek ihale kapsamı alımlar ve gerekse doğrudan temin kapsamı alımlara ait temel düzenlemeler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yer almaktadır. Ayrıca, İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği'nde de satın alma süreçlerine ait ilave düzenlemeler bulunmaktadır. Bu itibarla, ihale türlerine göre farklı yöntemlere tabi olsa/olmasa da doğrudan temin kapsamı alımlara ait temel hususlarda, anılan Kanun hükümlerinin esas alınarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade edebiliriz.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun amacı Kanun'un 1'inci maddesi ile belirlenmiş olup, söz konusu maddeye göre; Kanun'un amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek şeklinde sıralanmıştır.

Bu maddeye göre bir idarenin 4734 sayılı Kanun'a tabi olması için;

- Kamu hukukuna tabi olması,
- Kamunun denetimi altında bulunması,
- Kamu kaynağı kullanması,

Şartlarından birinin olması yeterlidir.

Dolayısıyla, kapsam maddesinde sayılmayan ancak yukarıdaki şartlardan en az birini sağlayan bir idarenin kurulması durumunda bu idare de Kanun'a tabi olacaktır.

Kanun'un söz konusu amacı göz önünde bulundurulmakla birlikte, 4734 sayılı Kanun

kapsamına hangi idarelerinde girdiği hususu da değerlendirmenin en önemli kriterlerinden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Kamu İhale Kanunu'nun kapsam başlıklı 2'nci maddesine baktığımızda ise;

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişilerin,

- Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüslerin,

- Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşların,

- Bahse konu 2'nci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin,

- 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri,

Kanun kapsamına girdiğini görmekteyiz. Farklı bir anlatımla, belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir.

Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler (2'nci maddenin e bendi kapsamındaki yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındadır.

Aynı şekilde, kamu kurumu niteliğindeki meslek Kuruluşları, köy tüzel kişilikleri, vakıf yükseköğretim kurumları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu fonun hisselerine sahip olduğu bankalar, enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin de kapsam dışında olduğunu ifade edebiliriz.

4734 sayılı Yasa'ya ait madde gerekçesinden de yer aldığı üzere, idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları harcamalara ilişkin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyelerin yanı sıra;

-Bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler,
-Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan bütün kamu iktisadi teşebbüsleri,
-Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar,
-Yukarıda belirtilen daire, idare, kuruluş ve teşebbüslerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler,

Kanun kapsamına alınmıştır. Ancak, 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Yasa kapsamındaki bankalar, 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

Buna göre bütçeden yani kamu kaynağı kullanılarak harcama yapılmasına ilişkin ihaleler 4734 sayılı Kanun kapsamında olup, kapsamda olmayan işler hakkında geniş açıklamalar Kamu İhale Genel Tebliği'nde bulunmaktadır.

Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği'ne göre; idarelerin, kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan ve sadece talep edenlerin faydalandığı hizmet ve alımları, 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır.

Ayrıca, belli maddeleri itibarıyla ihale mevzuatına (ve dolayısıyla anılan Kanun'lara) atıf yapan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda (KMYKK) da bu yönde tanımlamaların yer aldığını görmekteyiz. Temel bir Kanun olması ve mali sistemimizi yeniden

yapılandıran söz konusu Kanun'daki tanımlamaların, ihale mevzuatı için de geçerli olacağını belirtebiliriz.

Bu çerçevede, kamu idaresi ibaresinin hangi anlama geldiğini de yine aynı Kanun hükümleri çerçevesinde ortaya koyabiliriz. Buna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerin bütününden genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin oluştuduğunu ifade edebiliriz.

4734 sayılı Kanun'la, ihaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketlerin, bu idarelerin ihalelerine katılamayacakları hususunun hüküm altına alındığının bilinmesi gerekir.

Bu nedenle, kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan ve sadece talep edenlerin faydalandığı hizmet ve alımların, 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almaması nedeniyle; gerek kamu idaresi olarak kabul edilmemesi ve gerekse kullanmış olduğu kaynakların kamu kaynağı kapsamına girmemesi sebebiyle, yaptıkları alımların 4734 sayılı Kanun kapsamına girmediğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

4734 sayılı Yasa'da istisna kapsamına giren alımlara da yer verilmiş olup, Yasa'nın 3'üncü maddesinde yer alan bu nitelikteki bazı alımlara örnek olarak;

"..b) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

..e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel

Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar,

..h) Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbî malzemelerin kişilerce alımları, sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları,

..t) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının kurduğu veya iştirak ettiği şirketten (ÖSYM'nin yapacağı mal ve hizmet alımlarında Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü alınmak kaydıyla) sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımları…",

Gösterilebilir.

4734 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde düzenlenen ve yukarıda örnek verilen istisna sayılan alımların ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun'a tabi olmadığı hükme bağlanmıştır. Bu istisnalar, Kanun'a tabi idarelere Kanun hükümlerini uygulamadan, maddede bentler halinde sayılan ihtiyaçlarını karşılama imkânı vermektedir.

Kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan kat ve/veya arsa karşılığı yapım işleri de 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır. Kamu kaynağı kullanılmayan, bedeli okul idaresi tarafından ödenmeyen ve sadece talep edenlerin faydalandığı öğrenci taşıma hizmeti ve yemek hizmeti alımları, 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır. İdarelere, Kanun kapsamı dışındaki kişilerin tasarrufunda bulunan kaynaklardan yapılacak şartlı bağışlarda, bağış şartlarının 4734 sayılı Kanun'un

uygulanmasını olanaksız hale getirmesi halinde, söz konusu bağış miktarı ile sınırlı olarak yapılacak alımlar, Kanun kapsamında bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kanun'un 2'nci maddesine göre, Yasa kapsamındaki idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bu Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilmesi söz konusu olmakla birlikte, Kanun kapsamındaki bir idare tarafından yine Kanun kapsamındaki başka bir idareye aktarılacak kaynaklar da 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanılacaktır.

İdareler kendi bünyelerinde kurulmuş birimleri niteliğinde bulunan ve ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olmayan döner sermaye işletmelerinden, bu işletmelerin faaliyet konuları ile sınırlı olmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetleri 4734 sayılı Kanun'la öngörülen ihale usullerine tabi olmadan temin etmeleri mümkündür. İdarelerin kendilerine bağlı olan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunan döner sermaye işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri ise ancak anılan Kanun'da belirtilen hükümlere uygun olarak temin etmeleri mümkün bulunmaktadır.

İlgili mevzuatı ile belirlenen esaslar uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan mal ve hizmetlere karşılık düzenlenen faturaların bankalar aracılığıyla tahsil edilmesinde, idare bütçesinden harcama yapılmasını gerektirmeyen hallerde, bu aracılık hizmetinin 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla; mevzuatları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan elektrik, su, doğalgaz, telefon ve benzeri hizmetler karşılığında aboneler adına düzenlenen faturaların idare adına bankalar tarafından tahsil edilmesi işi, kamu yararı ve menfaatleri korunmak ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde protokol/sözleşme düzenlenmek suretiyle 4734 sayılı Kanun hükümleri dışında gerçekleştirilebilecektir.

Bu bağlamda, doğrudan temin kapsamı alımların konumunu değerlendirecek olursak, 4734 sayılı Yasa uyarınca "Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" olarak tanımlanmıştır.

Anılan Yasa'nın 22'nci maddesi uyarınca doğrudan temin kapsamı alımların hangi durumlarda yapılabileceği tek tek belirlenmiştir ve bu süreçte farklı bir yöntem öngörülmüştür. Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Söz konusu Yasa'nın

ilk halinde doğrudan temin, ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır.

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur. Bunların dışında, satın alma sürecinde ihale usulleri için öngörülen diğer düzenlemelerin uygulanmamasına ilişkin Kanun'da aksi yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Doğrudan temin kapsamı ihtiyaçlar, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar olup, doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir satın alma yöntemidir.

Ancak gerek ihale kapsamı alımlar ve gerekse doğrudan temin kapsamı alımlar, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, doğrudan temin kapsamı alımlar da ihale mevzuatı ile belirlenen hükümlerine tabidir ve birçok açıdan Kanun kapsamına girmektedir. İhale usulleri ile doğrudan temin arasında uygulanan mevzuat açısından farklılar olması, doğrudan temin kapsamı alımların Kanun kapsamına girmediği anlamına gelmemektedir.

2. Doğrudan temin yöntemi nedir ve hangi nitelikteki ihtiyaçlar 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesi kapsamında bu yöntemle karşılanabilir?

Özet: *4734 sayılı Yasa'nın "Tanımlara" ilişkin 4'üncü maddesinde "Doğrudan temin"; Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak ifade edilmiştir. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlara, 4734 sayılı Kanun'un 22'inci maddesinde belirtilen durumların varlığı halinde istisnai olarak başvurulmaktadır. Yani ihale türlerinden farklı esaslara ve/veya belli rakamsal tutara bağlanılan bir alım yöntemidir. Ayrıca, anılan Yasa'nın 22'inci maddesinde kapsama giren alımlar sayma yöntemiyle tek tek belirlendiği için kıyas veya yorum yoluyla doğrudan temin yöntemine giren alımların kapsamının genişletilmesi mümkün değildir.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu Yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanması ve sonraki süreç ise bu Yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

4734 sayılı Kanun'un amaca ilişkin maddesi hükmü uyarınca, "kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan" kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerin anılan Kanun'a göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Yasa'nın "Tanımlara" ilişkin maddesi uyarınca; İhale; "Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri" ifade etmektedir.

Anılan Yasa'nın "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesi ise, "İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Pazarlık usulü.
d) (Mülga: 30/7/2003-4964/12 md.)" şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddede geçen ihale usullerinin hangi anlama geldiği ise, aynı şekilde Yasa'nın tanımlara ilişkin bahse konu maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca;

Açık ihale usulü; Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü; Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü; Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

İfade etmektedir.

Doğrudan temin usulü bağlamında ilk esaslı değişiklik 4964 sayılı Kanun ile yapılmış olup, söz konusu düzenleme ile daha önce ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin, ihale usulleri arasından çıkartılmıştır. Bu düzenleme ile Kanun kapsamındaki kamu idarelerinin herhangi bir ihale usulüne bağlı kalmaksızın ihtiyaçlarını "Doğrudan temin" adı verilen bir yöntemle karşılamalarına yasal anlamda izin verilmektedir.

Yasa'nın "Tanımlar" maddesinde ise "Doğrudan temin"; Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü ifade ettiği görülmektedir.

Bütçe Kanunu'yla kendilerine ödenek tahsis edilen kamu idarelerinin, doğrudan temin yoluyla gereksinim duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için harcama yapması ancak mevzuatta öngörülen belirli yükümlülükleri yerine getirmeleri ile gerçekleşebilecektir.

Kamu idarelerinin doğrudan temin alımlarının nasıl gerçekleştirileceğini düzenleyen ve hukuki dayanak teşkil eden mevzuat çeşitlilik göstermekte olup, bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Muayene ve Kabul Yönetmelikleri, Harcama

Yetkilileri Hakkında Tebliğ, Kamu İhale Genel Tebliği ve Kamu İhale Tebliğleri ile başta Kamu İhale Kurumu olmak üzere, görev alanıyla bağlantılı hususlarda kamu idarelerince belirlenen düzenlemelere göre alım süreçlerinin şekillendiğini söyleyebiliriz.

Söz konusu mevzuat ile süreçte yapılacak iş ve işlemler, ilgili harcama belgeleri ışığında açıklanmıştır.

Doğrudan temin kapsamı alımlara ilişkin akış süreci ise şu şekilde ana hatlarıyla sıralanabilir;

1- Ödenek Kontrolü ve Temini
2- Yaklaşık Maliyet Tespiti (yapım işleri alımları hariç zorunlu değil)
3- Şartname/Sözleşme Tasarısının Hazırlanması (zorunlu değil)
4- Onay Alınması (Doğrudan Temin Onay Belgesi/Harcama Talimatı)
5- Piyasa Fiyat Araştırması Yapılması (Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı)
6- Sözleşme Yapılması (zorunlu değil)
7- Muayene ve Kabul İşlemleri (Kabul Tutanağı/Muayene ve Kabul Tutanağı)
8- Hakediş İşlemleri (Hakediş Raporu)
9- Ödeme Evrakının Düzenlenmesi (Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri)
10- Kamu İhale Kurumuna Bildirim (Doğrudan Temin Kayıt Formu)

Yukarıda ifade edilen adımlar ortalama bir doğrudan temin kapsamı alım için geçerli olup, idarenin yapısı, alımın miktar ve niteliğine gibi süreçte değişkenlere bağlı olarak bazı işlem adımlarında farklılıklar söz konusu olabilir.

4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesi kapsamında doğrudan temin konusuna giren alımların son şekline ve dolayısıyla "d" bendi kapsamına giren alımlara aşağıda yer verilmektedir.

2.1. Doğrudan temin kapsamı alımlardan hangileri Yasa'nın 22/d maddesine girer?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde, hangi hallerde doğrudan temin yöntemine başvurulabileceği belirtilmiş olup söz konusu maddenin en güncel haline göre; "Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (İkiyüzonsekizbinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası)*, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (Yetmişikibinyediyüzelliiki Türk Lirasını)* aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

ı) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin

* 20/01/2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01/02/2022 – 31/01/2023 dönemini kapsamaktadır.

hizmet alımları,

i) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

Şeklinde doğrudan temin yöntemine başvurulabilecek hususlar hükme bağlanmıştır.

Görüldüğü üzere; yasa hangi hallerde alım yapılabileceğini açık bir şekilde ortaya koyduğu için bunlar dışında alım yapılması mümkün değildir. Ancak bu hususlarla bağlantılı olarak ilgili mevzuatta öngörülen istisnai durumlarda alım yapılabilmesi mümkündür. Örneğin; Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer aldığı üzere, ihalenin iptali durumunda süreklilik arz eden ihtiyaçların doğrudan temin kapsamında karşılanması mümkündür.

Dolayısıyla, doğrudan temin ihale usulleri arasından çıkarılmış olmakla birlikte, bunun bütünüyle bir serbestlik şeklinde yorumlanmaması ve bazı kurallara uyma yükümlülüğünün de bulunduğunun bilinmesi gerekir.

Bu bağlamda, açık ihale yöntemiyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırlar altında kalması için söz konusu ihtiyacın kalemlere bölünmek suretiyle temin edilmesi durumunda, hukuki sorumluluk doğuracağının bilinmesi gerekir. Keza yasal koşullar oluşması durumunda ihaleye fesat karıştırma suçu söz konusu olabilir.

Yapılan düzenlemeler uyarınca doğrudan teminde, Kanun'un temel amacına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurulmadan,

Kanun'da sayılan yeterlik kriterlerini dikkate almadan, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi esastır.

Genel kural bu olmakla beraber, ihtiyaçların niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerden belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarenin takdirindedir. Ancak, Kanun'un 22/d maddesi kapsamında gerçekleştirilecek olan yapım ihalelerinde piyasa fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunluluk arz etmektedir.

Bu bağlamda, 22'nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir.

İdarelerin doğrudan temin kapsamında en çok kullandığı alım türünü Kanun'un 22/d maddesi kapsamında yer verilen ve her yıl Kamu İhale Tebliği ile güncellenen *"parasal tutarlar kapsamında aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar"* oluşturmaktadır. Bahse konu parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

İşin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilirler. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir. Ancak bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre doğrudan temin yöntemi, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar için öngörülmüş

olup, bu alım yöntemi için getirilen kolaylıklardan, alımların herhangi bir kriterlere bağlı kalınmadan keyfi yöntemlerle gerçekleştirilebileceği sonucu çıkarılmaması gerekmektedir.

Bunlarla birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesine göre idareler; bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu şekilde öngörülen yasal bir düzenlemenin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun amacının açıklandığı 1'inci maddesinde yer alan, kamu kaynaklarının, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasına yönelik hedeflerle de uyumlu olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir.

3. Doğrudan temin yönteminin sağladığı kolaylıklar ile bu alım yönteminde karşılaşılan zorluklar nelerdir?

Özet: *Doğrudan temin yöntemi, ihale usulleri için belirlenmiş olan ilan yapma, teminat alınma, ihale komisyonu kurma ve Kanun'da belirtilen yeterlik kriterleri gibi zorunluluklar aranmaksızın, ihale yetkililerince görevlendirilen kişi ya da kişilerce piyasada fiyat araştırması yapılarak kamu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir satın alma yöntemidir. Ancak bu kolaylıkların varlığı, idarenin keyfi hareket edeceği anlamına gelmemektedir. Ayrıca, duruma göre sözleşme yapılması ve yaklaşık maliyet hazırlanması gibi zorunluluklar bu alım yönteminde de söz konusu olabilmektedir.*

30.07.2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun belli maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Kanun'un ilk halinde ihale usulleri olarak; "Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü, Pazarlık Usulü ve Doğrudan temin usulü" şeklinde dört usul sayılmasına rağmen, 4734 sayılı Kanun'da değişiklik yapan 4964 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, doğrudan temin ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idarenin ihtiyaçları temin edilmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde doğrudan temin yöntemi ile karşılanabilecek ihtiyaçlar tek tek sayılmış olup, bunların yorum veya kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. Zira madde metni bu şekilde yorumlamaya izin vermemektedir.

Doğrudan teminde, 4734 sayılı Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların uygulanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ihale kapsamı alımlar için geçerliliği söz konusu olan bazı kuralların (temel ilkeler, idarelerce uyulması gereken diğer kurallar gibi) bu alım yönteminde de dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü bahse konu düzenlemeler alım yöntemlerinden bağımsız çerçeve hükümler içeren, genel kurallar niteliğindedir.

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4'üncü maddesinde; *"Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve*

fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu alımlara ilişkin Kanun gerekçesinde ise; "özellikle kağıt, kırtasiye, elektrik malzemeleri gibi küçük ölçekli günlük ihtiyaçların karşılanması ile küçük bakım onarım işlerinin yaptırılmasında kolaylık sağlamak üzere ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin yöntemi benimsenmiştir" denilmek suretiyle maddenin düzenleniş nedeni ve hukuki altyapısı ortaya konulmuştur.

Doğrudan temin kapsamı ihtiyaçlar, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar olup, doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir satın alma yöntemidir. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın doğrudan temin kapsamında karşılanması mümkün değildir.

Doğrudan temin yöntemi, ihale yöntemi için belirlenmiş olan ilan yapma, teminat alınması, ihale komisyonu kurma ve Kanun'da belirtilen yeterlik kriterleri gibi zorunluluklar aranmaksızın, ihale yetkililerince görevlendirilen kişi ya da kişilerce piyasada fiyat araştırması yapılarak kamu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik mal ya da hizmetin satın alınması ile ilgili bir yöntemdir.

Bu alım yöntemi kullanılırken, 22'nci maddenin bazı bentleri için parasal sınır söz konusu değilken, "d bendi" kapsamı alımlar için parasal sınır söz konusudur. Tespit edilen parasal sınırlar, 4734 sayılı Kanun çerçevesinde Kamu İhale Kurumuna (KİK) verilen yetkiye istinaden büyükşehir sınırları esas alınarak belirlenmekte ve Kamu İhale Tebliği ile Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yıllık olarak güncellenmektedir.

Belli esnekliklere rağmen, bu alım yönteminde de kamu kaynağı kullanıldığı dikkate alınarak, kamu idarelerinin, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için harcama yapması ancak mevzuatta öngörülen bazı yükümlülükleri yerine getirmeleri ile mümkün olabilmektedir.

3.1. Getirilen kolaylıklar

Doğrudan teminde; ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale

yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilebilmesi öngörülmüştür. Ancak alımın niteliği ve rakamsal büyüklüğü dikkate alınarak, idarelerce bu kapsamda bazı kriterler belirlenmesini engelleyen bir hüküm de bulunmamaktadır.

Zira doğrudan teminde, Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların uygulanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ihale kapsamı alımlar için geçerliliği söz konusu olan bazı kuralların (temel ilkeler, idarelerce uyulması gereken diğer kurallar gibi) bu alım yönteminde de uygulanması gerekmektedir. Çünkü bahse konu düzenlemeler alım yöntemlerinden bağımsız çerçeve düzenlemeler içeren, genel kurallar niteliğindedir.

Doğrudan temin konusu yapılabilecek ihtiyaçlar Kanun'un 22'nci maddesinde tek tek sayılmış olup, bunların kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

İhale kapsamı alımlar için 4734 sayılı Kanun ve alt düzey mevzuatta, idarelerce uygulanabilecek tip şartname, tip sözleşme, standart form gibi dokümanlar öngörülmüştür. Bu dokümanların doğrudan temin yönteminde kullanılması zorunlu değildir. Ancak idareler Kanun'un 22'nci maddesi çerçevesinde, diğer ihale usulleri için öngörülmüş bulunan bahse konu şartname ve sözleşme içeriklerinden yararlanarak kendi tercihleri doğrultusunda uygun dokümanlar hazırlayıp kullanması mümkündür. Hatta bahse konu dokümanları alım yöntemine uyarlayarak aynı şekilde kullanmaları olanak dahilindedir.

Doğrudan temin bir alım yöntemi olması nedeniyle, Kanun'un 4'üncü maddesindeki "ihale" tanımına uygun değildir. Söz konusu alımlar için geçerli olmak üzere (kolaylıklar);

- Doğrudan temin Kanun'da bir ihale usulü olarak düzenlenmediği için, Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kurallara uymak mecburiyeti yoktur.
- Bu usulde teminat (geçici/kesin) alınması ve ilan yapılması zorunlu değildir.
- İhale komisyonu kurulması ve ihale kararı alınması zorunlu değildir.
- İhale dokümanı hazırlanması ve yaklaşık maliyet tespiti (yapım işi hariç) zorunlu değildir.

- Şartname hazırlanması ve sözleşme yapılması (istisnai durumlar hariç) zorunlu değildir.

- 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin aranılması (isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerin belirlenmesine ilişkin) zorunlu değildir.

- İhalelere katılmaktan yasaklamanın bulunup bulunmadığının teyidi (Yasa'nın 22/d kapsamında yapılan alımlar hariç olmak üzere) zorunlu değildir.

- Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde işlemlerin yürütülmesi (sonuç bildirimi hariç) zorunlu değildir.

3.2. Karşılaşılan zorluklar/zorunluluklar

Bu alım yönteminde;

- Piyasa fiyat araştırması zorunlu olup, piyasa fiyat araştırması için yazılı olarak "en az bir kişi" görevlendirilmelidir.

- Görevlendirilen kişi/kişiler piyasada fiyat araştırması yapmalıdır.

- Uygun olan kişiden alım yapılmadan önce, harcama yetkilisinden onay alınmalıdır.

- Belli bir süreyi gerektiren işlerde, sözleşme düzenlenmesi zorunludur.

- Yasa'nın 22/c maddesi kapsamı alımlar için sözleşme yapılması zorunludur.

- Yasa'nın 22/a-b-c maddeleri kapsamı alımlar için "Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form" düzenlenmesi gerekmektedir.

- Aynı şekilde Yasa'nın 22/a-b-c maddeleri kapsamı alımlar için "Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli" hazırlanması zorunludur.

- Yasa'nın 22/d maddesi kapsamı yapım işleri için piyasa fiyat araştırmasının, ilgili ihale uygulama yönetmeliğindeki yaklaşık maliyet hazırlanmasına ilişkin esaslara göre yapılması gerekmektedir.

Bunlarla birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesine göre idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Bu şekildeki yasal bir düzenlemenin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun amacının açıklandığı 1'inci maddesinde yer alan, kamu kaynaklarının, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasına yönelik hedeflerle de uyumlu olduğunun göz önünde bulundurulması gerekir.

4. Doğrudan temin kapsamı alımlarda 4734 sayılı Kanun'un "Temel ilkelerinin" dikkate alınması zorunlu mudur?

Özet: *Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da kamu kaynağı kullanıldığı hususu dikkate alındığında, 4734 sayılı Yasa'nın 5'inci maddesinde yer verilen aslında ihale kapsamı alımlar içim öngörülen "Temel ilkelerin" ağırlıklı olarak bu alım yöntemi için de geçerli olduğunu, çünkü bahse konu düzenlemelerin alım yöntemlerinden bağımsız hükümler içeren, genel kurallar niteliğinde olduğunu görmekteyiz. Söz konusu ilkelere aykırı hareketin ise, idari sorumluğunun yanında, söz konusu fiilin niteliğine bağlı olarak adli nitelikte işlem tesisini de gündeme getirebileceğine dikkat edilmesi gerekir.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun kabulünden kısa bir süre sonra, anılan Kanun'un belli maddelerinde kapsamlı değişiklikler yapıldığını, yapılan değişiklikler ile Kanun'un ilk halinde ihale usulleri arasında sayılan "Doğrudan temin usulü"nün, ihale türleri arasından çıkarıldığını görmekteyiz. Bu çerçevede, doğrudan temin yöntemini, ihale mevzuatında öngörülen usul ve esasların, birçoğunun uygulanmasına gerek duyulmadan ihtiyaçların kısa sürede karşılandığı alım yöntemi şeklinde tanımlayabiliriz.

Doğrudan temin kapsamındaki alımlar çeşitlilik göstermektedir. Zira 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde yer verildiği üzere, bu kapsamda yapılan alımlara; ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesinin zorunluluk arz ettiği alımlar başta olmak üzere, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması, idarenin uluslararası alandaki avukatlık hizmetleri gibi normal ihale usulleri ile karşılanması pek mümkün (ve pratik olmayan) alımlar örnek olarak gösterilebilir.

Yasa'da yapılan çeşitli değişikliklere rağmen, doğrudan temin yönteminin mevcut durum itibarıyla 4734 sayılı Kanun'da yer aldığını görmekteyiz. Doğrudan teminin bir ihale çeşidi olarak düzenlenmemesi nedeniyle diğer ihale usulleri için uygulanan bazı düzenlemeler, doğrudan temin için uygulanmamaktadır. Ayrıca, doğrudan temin şekli alımlarda, Kamu İhale Kurumu tarafından herhangi bir inceleme ve uygulamanın doğruluğunun kontrolü yapılmaz.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun amacı 1'inci maddesinde yer aldığı üzere,

kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri anılan Kanun belirlemektir. Bu kapsamda Kanun'un temel ilkelerine baktığımız zaman;

Kanun'un "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesinin; *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.*

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartlarına uygun şekilde yerine getirilme zorunluluğu nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılabilir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz."

Hükmüne amir olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki madde metni ışığında, "Temel ilkeler" açısından önem arz eden ve ön plana çıkan bazı ilkelere kısaca değinecek olursak;

Saydamlık İlkesi: *Alım sürecinde gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin, açık bir şekilde*

gerçekleştirilmesi ve bu sayede, tüm işlemlerin alım sürecinde görev alan ilgililer dışında kamuoyu boyutuyla da anlaşılır kılınmasını,

Rekabet İlkesi: *İdare tarafından gerçekleştirilen ihalelere olabildiğince fazla isteklinin katılımının sağlanmasının yanında, tüm isteklilerin her türlü baskıdan uzak bir şekilde tekliflerini sunabilmeleri ve böylelikle en kaliteli mal ve hizmeti en uygun bedel ve en uygun şartlarda alınabilmesini,*

Güvenirlik İlkesi: *İhaleyle ilgili tarafların ihale sürecine güven duyması ve ihale sürecinin istekliler açısından öngörülebilir olmasını ve ayrıca, herhangi bir endişe duyulmadan isteyen ve şartları taşıyan herkesin ihalelere katılımının sağlanmasını,*

Eşit Muamele İlkesi: *Bütün isteklilerin ihale sürecinde eşit hak ve muameleye sahip olması ve bu kapsamda, ilgili idare (kamu görevlisi)nin, dürüstlük, tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde hareket ederek, aynı durumda olan isteklilere farklı muamele etmemesini,*

Kamuoyu Denetimi İlkesi: *Vatandaşların kamu ihalelerinden haberdar olması ve bu kapsamda, gizlilik durumları hariç olmak üzere yapılan ihaleler hakkında ilgili idareden bilgi alabilmesi ve ihale sonuçlarının gerek elektronik ortamda ve gerekse yazılı olarak ilan edilmesi zorunluluğunun bulunmasını,*

İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması İlkesi: *İhale dokümanlarında ve dolayısıyla teknik şartname, idari şartname ve diğer belgelerde ihtiyaç konusunun çok iyi bir şekilde tanımlanasını, fiyatları ve arzı mevsimsel koşullar dikkate alınarak ihtiyaçların uygun oldukları zamanlarda ihale edilmesi, muayene kabul sürecinin zamanında ehil kişilerce yapılmasını ve olası gecikmelere karşı yaptırımlar öngörülmesini,*

Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi: *İdarelerin, yapacakları ihalelerde kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olması, bu çerçevede, ihalenin gerekli şartları sağlamaları koşulu ile en düşük teklif fiyatı sunan üzerinde bırakılması, ödenek programlamasının doğru yapılması gibi düzenleme ve uygulamaların hayata geçirilmesini,*

Gizlilik İlkesi: *Yaklaşık maliyet tutarı gibi ihale sürecindeki bazı bilgilerin belli aşamalardan önce paylaşılmamasını ve idare ile muhatap olanlara ait gizli bilgilerin de aynı şekilde*

korunmasını,

İfade ettiğini söyleyebiliriz.

Bu madde kapsamı ilkelere, *"Aralarında Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı Olmadığı Sürece Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerinin Birarada İhale Edilememesi İlkesi"ni* de ekleyebiliriz. Böylelikle, her bir alımın farklı uzmanlaşma gerektirdiği hususu dikkate alınarak, hizmet işinin hizmet sunucusu, yapım işinin yapım müteahhidi ve mal alımının mal tedarikçisi tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu durumun istisnası, aralarında kabul edilebilir bir doğal bağlantı olan ihtiyaçların bir arada ihale edilmesidir. Ancak nitelikleri birbirinden farklılık taşıdığı için mal alımı, hizmet alımı ve yapım işinin bir arada ihale edilmemesi gerektiğini tekrar vurgulayabiliriz.

Benzer şekilde, *"Eşik Değerlerin Altında Kalmak Amacıyla Mal ve Hizmet Alımlarıyla Yapım İşlerinin Kısımlara Bölünememesi"* gerekmektedir. Kanun'un uygulanmasında esas alınacak eşik değerler anılan Kanun'un 8'inci maddesinde belirtilmiş olup, idarelerin yaklaşık maliyetlerini dikkate alarak öncelikle ihale edilecek işin eşik değerin altında mı üstünde mi olduğunu belirlemeleri gerekmektedir. Zira ihale edilecek işin eşik değerin altında olması halinde uygulanacak hükümler farklı, üstünde olması halinde uygulanacak hükümler farklıdır. Bu nedenle gerekli işlemlerden kaçınmak amacıyla böyle bir rakamsal parçalanma yapılmaması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde; *"Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir."* hükmüne yer verilmiş olup, anılan düzenleme uyarınca, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün esas olduğu, pazarlık usulüyle ihale yapılmasının ve bir ihale usulü olmayan doğrudan temin yönteminin kullanılmasının ise, sadece Kanun'da belirtilen özel hallerde mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, Kanun'un 21'inci maddesinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilecek haller, 22'nci maddesinde de doğrudan temin yöntemiyle alım yapılabilecek durumlar madde metinlerinde sayılmış olup, ancak bunların varlığı halinde bu kapsamda alım yapılabileceğini, kıyas yoluyla bu alımların içeriğinin genişletilemeyeceğini ifade edebiliriz.

Aynı şekilde, *"Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılması mümkün değildir."* ilkesi

ile de ihtiyaçların karşılanması noktasında sürecin uzamasının engellenmesi, yatırımların mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

"İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz." hükmü ve ilkesi uyarınca; kamu alımlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" hükümlerine uygun hareket edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar Kanun'un 62'nci maddesinde düzenlenmiş olup, bahse konu hususlara da süreçte uyulması zorunluluk arz etmektedir.

Bu bağlamda, yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması gerekmektedir. İlk yıl için öngörülen ödenek, yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmak üzere, proje maliyetinin %10'undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkân verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

Diğer taraftan, yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur.

4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde sayılan "Temel ilkelerin" idarelerce tamamına uyulması zorunludur. Söz konusu ilkelere uyulmamış olması ihale sürecinin geçerliliğini etkileyecektir. Ayrıca, bahse konu ilkelerin ihlali Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümlerinin uygulanmasına da neden olabilecektir.

Benzer şekilde, 4735 sayılı Yasa ile de ilkeler belirlenmiş olup, ilgili maddeye göre, anılan Kanun'a göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceği gibi, Kanun'da belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması ve ek sözleşme düzenlenmesi de mümkün değildir.

Ayrıca, anılan Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği gibi Kanun'un yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun'da olduğun gibi 4735 sayılı Kanun'a ait ilkelerin de alım sürecinde dikkate alınması gerekmekte olup, aksi yöndeki eylemlerin adli ve idari sorumluluğu gündeme getirdiğinin bilinmesi gerekir.

Netice itibarıyla;

Yukarıda yer verilen temel ilkeler ağırlıklı olarak Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihaleler için geçerlidir. Keza madde metnini de bu şekilde ifade edilmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman bu ilkelerin doğrudan temin alımlarıyla bir ilgilisi olmadığı düşünülebilir. Ancak tüm ilkelerin doğrudan temin kapsamı alımlarla da ilişkilendirilmemesi hatalı bir yaklaşım olacaktır.

Zira bahse konu ilkelerin içeriği eğer bir ihale yöntemine özgü ise şüphesiz o ilkenin ihale türleri için dikkate alınması gerekir. Ancak ilke, bir ihale yöntemiyle ilgisi olmayan kamu kaynağının kullanımı ile ilgili ise, bu durumda söz konusu ilkenin doğrudan temin yöntemi için de uygulanması gerekmektedir. Örneğin eşit muamele ilkesi, idarenin herkese (isteklilere) eşit davranması anlamına gelmekte olup, bu ilkenin doğrudan temin yönteminde de dikkate alınmaması düşünülemez.

Buna karşın aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet

alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez kuralının ise, söz konusu alımlarda açıkça ihale kapsamı alımlar için öngörüldüğü dikkate alınarak, bunların doğrudan temin yöntemiyle ilgili olmadığı söylenebilir.

Kaldı ki her ne kadar Yasa'nın 22'nci maddesinde bu yöntemle alınabilecekler ihtiyaçlar tek tek sayılmış olsa da, Yasa'nın temel ilkelerinin bu alım yöntemiyle uygulanmamasını söylemek hatalı bir yaklaşım olacaktır.

Bu itibarla, doğrudan temin yöntemiyle de olsa Yasa'nın açıkça ihale türleri için öngördüğü alımlar hariç olmak üzere, temel ilkelerin doğrudan temin kapsamı alımlar için de uygulanması gerektiğini ifade edebiliriz.

5. Doğrudan temin kapsamı alımlarda yapılan iş ve işlemler nelerdir, işlem akış sırası nasıldır?

Özet: *4734 sayılı Yasa'nın "Temel ilkelere" ilişkin 5'inci maddesinde yer verildiği üzere, anılan Kanun'a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuller olup, gerek pazarlık usulü (ihale usulü) kapsamındaki alımlar ve gerekse doğrudan yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar istisnai durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Doğrudan temin bir ihale değil alım yöntemi olması nedeniyle uygulanacak işlemler farklılık arz etmektedir. Bu yöntemde, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların karşılanması söz konusudur. Ayrıca, 4734 sayılı Yasa'nın doğrudan temin yöntemi (22-d) kapsamı alımları için 2022 yılı için öngördüğü ve güncellenen parasal sınırı Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için 218.395.- Türk Lirası, diğer idareler için 72.752 Türk Lirası olup, idare ihtiyaçlarının bu parasal sınırlara uymak şartıyla öngörülen yöntemle alınabileceğini ifade edebiliriz.*

Doğrudan temin yöntemi, ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'da belirtilen yeterlik kriterlerini taşıma zorunluluğu aranmaksızın, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların karşılandığı bir yöntem olup, bu yöntemde, birçok uygulama ihale türlerinden farklılık göstermektedir.

Ayrıca, doğrudan temin kapsamı alımın niteliğine veya alımın yapan idarenin yapısına bağlı olarak alım kapsamı süreçler idareler bazında da farklılıklar gösterebilmektedir.

Keza idare tarafından kırtasiye malzemesi alırken yaklaşık maliyet hazırlanması zorunluluk olmazken, parasal limitlere dahil doğrudan temin kapsamında da (22-d) olsa yapım işleri için ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğinde yer alan yaklaşık maliyet hesaplama yönteminin, piyasa fiyat araştırması sürecinde dikkate alınması hukuki bir gerekliliktir. Aynı şekilde, bir Bakanlığın destek birimi birçok birim için demirbaş alımında talep yazılarını dikkate alırken, farklı bir müdürlükte süreç sözlü bir talimatla da başlayabilir. Tekrar ifade etmek gerekirse

alımın niteliği işlem adımlarında farklılıklara neden olabilmektedir.

Bu bağlamda süreçte zorunluluk arz etmeyen adımlar dahil olmak üzere genel olarak doğrudan temin yöntemindeki süreçleri sıra dahilinde şu şekilde sıralayabiliriz;

a-İhtiyacın ortaya çıkması/belirlenmesi/bildirilmesi (yazılı talep/mal alımlarında taşınır istek belgesi)
-Ödenek kontrolü
-Teknik şartname veya projenin hazırlanması
-Yaklaşık maliyetin hazırlanması
b-Onay belgesinin düzenlenmesi (Doğrudan Temin Onay Belgesi/Harcama Talimatı)
-Piyasa fiyat araştırması yapacak kişilerin belirlenmesi ve görevlendirilmesi
c-Piyasa fiyat araştırması yapılması (ve Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı tanzimi)
- Fiyatın harcama yetkilisi tarafından onaylanması
d- Gereklilik arz ediyorsa sözleşme yapılması
e- Taahhüdün yerine getirilmesi
f- Teslim ve kabul (Kabul Tutanağı/Muayene ve Kabul Tutanağı)
g-Taşınır işlem fişinin düzenlenmesi (mal ve malzeme alımları için)
h-Ödeme belgesinin düzenlenmesi ve imzalanması (ödeme belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler)
i-Ön mali kontrol yapılması (zorunluluk arz ediyorsa ön mali kontrol için Mali Hizmetler Birimine/SGB'ye ödeme emri ve eki harcama belgelerinin gönderilmesi)
j-Ödeme
k-Alımların KİK'e elektronik ortamda bildirilmesi (Doğrudan Temin Kayıt Formu)

5.1. İhtiyacın ortaya çıkması/ihtiyacın bildirilmesi

Kamu alımları süreci ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlamakta olup, ilk olarak ihtiyacın doğru tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. İdarece, ihtiyaç doğrultusunda alım yapılabilmesi için gerek ihale kapsamı ve gerekse doğrudan emin yöntemiyle alım olsun yeterli ödeneğin bulunması zorunludur. 4734 sayılı Kanun'da da ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Gerek görüldüğü takdirde, ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanması da mümkündür. İhtiyacın ilgili birimlere bildirilmesi

noktasında standart form olmayıp, idareler kendileri belirler. Bu süreç resmi veya iç yazışma yoluyla da gerçekleşebilmektedir. Bu bağlamda harcama talimatı düzenlenmesi söz konusu ise, bu formdaki bilgilerin eksiksiz ve açık olarak yazılması gerekmektedir.

İlgili birimce, parasal limitler ve diğer şartlar dikkate alınarak, alımın doğrudan temin yöntemiyle karşılanıp karşılanmayacağı değerlendirilir.

Alıma ilişkin olarak birimce değerlendirilen harcama talebi, harcama yetkilisi/ihale yetkilisi onayına sunulur. Harcama yetkilisi, talep çerçevesinde gerekli değerlendirmeyi yaparak, alımın gerçekleşmesine karar verebileceği gibi alımdan vazgeçmesine de karar verebilir. Alımın gerçekleştirilmesine karar verilen talepler için Onay Belgesi (doğrudan temin onay belgesi/harcama talimatı) düzenlenmesi ve satın alma görevlilerinin belirlenmesi söz konusudur.

5.2. Teknik şartnamenin/projenin hazırlanması

Ortaya çıkan ihtiyacın giderilmesi için gerek duyulan mal veya hizmet ya da yapım işlerinin satın alınabilmesi için gerekli olan sonraki adım ise, bunların niteliklerinin detaylı olarak tespit edilmesidir. Tespit edilen bu özelliklere ve teknik kriterlere teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik şartnameler, alım dokümanının bir parçasıdır.

Doğrudan temin uygulamasında şartname ve sözleşme düzenlenmesi idarenin takdirinde bir husus olmakla birlikte özellikle süreli alımlarda, bir başka ifadeyle işin gerçekleştirilmesinin belli bir süreye bağlı olduğu mal, hizmet veya yapım işlerinde sözleşme düzenlenmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Doğrudan temin kapsamı alımlarda idarece şartname ve sözleşme düzenlenmesi söz konusu ise bu gibi durumlarda; ilgili ihale uygulama yönetmeliği ekinde yer alan tip dokümanların (sözleşme/şartname) kullanılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde, kamu ihale sözleşmelerinde bulunması zorunlu hususlara uyulması zorunlu değildir. Bu gibi durumlarda, işin niteliğine göre; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşme metni kullanılması mümkündür.

Teknik şartnamelerde idarenin isteğinin açık, net ve tereddüte yer vermeyecek şekilde

belirtilmesi gerekli olup, şartnamede yer verilen hususların, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi gerekmektedir.

5.3. Yaklaşık maliyetin hazırlanması

İhale kapsamı alımlar için ihalesi yapılmadan önce idarece, ilgili uygulama yönetmeliklerinde belirlenen esas ve usuller uyarınca, ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Ödenek miktarı belirlenirken yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisi (KDV) de dahil edilir.

İhale onay belgesi düzenlenirken ekinde yaklaşık maliyet hesap cetveli de yer alır. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesine göre ihtiyaçlar temin edilirken, bir ihale usulü olmadığından doğrudan temin yönteminde yaklaşık maliyetin tespiti zorunlu olmamakla birlikte, alım tutarı dikkate alınarak ihtiyacın parasal sınıra tabi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yaklaşık maliyet hazırlanabilir.

Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların doğrudan temin sürecinde uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi irdelendiğinde, yaklaşık maliyet hazırlama zorunluluğunun ihale usulleri kullanılarak yapılacak alımlar için getirildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin yönteminde anılan madde çerçevesinde, yaklaşık maliyet hesaplamanın zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, ihale uygulama yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliği'nde de bu tür bir zorunluluk öngörülmemiştir. Ancak idare gerekli görmesi durumunda yaklaşık maliyet hesaplayabilecektir.

Bunlarla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği'nde, Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde piyasa fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

5.4. Onay belgesinin düzenlenmesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 32'nci maddesi hükmüne göre, kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.

Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Kamu İhale Mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır.

Bu alım yönteminde de ihtiyacın karşılanmasının gerekliliği, karşılanma yöntemi, ödenek durumu, avans ve/veya fiyat farkı verilip, verilmeyeceği gibi hususlarda ihale yetkilisinden onay alınması zorunludur.

İhale yetkilisi onay belgesiyle ihtiyacın karşılanmasına ve bütçede bu ihtiyaç için ayrılan kaynağın kullanılabilmesine izin verilmesinin yanında, Kamu İhale Genel Tebliği'nde de onay belgesi zorunlu tutulmuştur.

Bahse konu Onay belgesi, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinde tanımlanmıştır. Yapılan bu tanıma göre "Onay belgesi"; alım konusu işin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgedir. Onay belgesinde, piyasa fiyat araştırmasını yapacak kişi ya da kişilerin belirtilmesi gerekmektedir.

Ancak uygulama sürecinde birçok işlemler KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)-Harcama Modülü üzerinden yürütüldüğünden birçok otokontrol sistem üzerinden sağlanmaktadır. Örneğin; ödeneği olmayan bir bütçe tertibi için harcama talimatı düzenlenmesine sistem izin vermemektedir. Ayrıca, ödeme aşamasında da bu kapsamda sorunlar çıkabilmektedir.

5.5. Piyasa fiyat araştırması yapacak kişilerin görevlendirilmesi

Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi; "Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir." şeklinde hükme bağlanmıştır.

Görevlendirme bizzat ihale yetkilisi/harcama yetkilisi tarafından ve yazılı olarak yapılmalıdır. İhale yetkilisi anılan Kanun'da tanımlanmıştır. Görevlendirme ayrıca yazılı biçimde yapılabileceği gibi, ihale yetkilisince onay belgesine düşülecek bir kayıtla da yapılabilir.

Kanun'da görevlendirmenin şekliyle ilgili bir zorunluluk hükmü öngörülmemekle birlikte, doğrudan temin konusu ihtiyacın niteliğine uygun biçimde alımın kapsamı dikkate alınarak, sorumlu olacak bu kişilerin alım konusunda bilgi sahibi olmalarında yarar vardır. Bu hususa uyulması durumunda, uygun koşullarda idarenin alım yapmasına ortam sağlanmış olur.

5.6. Piyasa fiyat araştırması yapılması

4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesinde, doğrudan temini gerçekleştirecek kişi veya kişilerin görevlendirilme şekliyle ilgili herhangi bir belirleme yapılmamış olmakla birlikte, görevlendirmeyi ihale yetkilisinin bizzat yapması gerekmektedir.

Kanun'da fiyat araştırmasının şekil, yöntem ve esaslarıyla ilgili de herhangi bir belirleme yapılmamakla birlikte, konuya ilişkin olarak Yasa'nın 22'nci maddesinin son fıkrasında, maddenin farklı durumları düzenleyen bütün bentleri için geçerli olmak üzere;"....ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir." ifadesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendine göre yapılan satın almalarda Onay belgesinde yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılır ve "Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı" düzenlenir. Piyasa fiyat araştırması tutanağı; doğrudan temin yöntemiyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri,

uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin (MYHBY) ekindeki 2 örnek numaralı tutanaktır.

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağında; kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı da gösterilir. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili uygulama yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir. Ancak yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılan alımlarda: alım şekli dikkate alınarak Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form hazırlanır ve ihale yetkilisince imzalanır.

Piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmaların, alımın niteliği ile bahse konu mal veya hizmetin arzı da dikkate alınarak kapsayıcı ve dayanaklarıyla birlikte ispat edilebilir olması gereklilik arz etmektedir.

Görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından düzenlenen piyasa fiyat araştırması tutanağının altına ihale yetkilisi tarafından uygundur şerhi konulması zorunlu olmamakla birlikte, konulması harcama yetkilisini yapılan araştırmayı uygun bulduğunun belirtilmesi bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir.

5.7. Teklif mektuplarının/Tekliflerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi

İdare, satın alınacak mal veya hizmet ile yapım işinin bütün özelliklerini, teklif mektubu üzerinde veya ekinde yer alan teknik şartnamede göstermesi gerekmektedir. Aynı şekilde, alıma konu ihtiyacın teslim süresi ve şartlarını da belirtmelidir. Alımla ilgili teknik ve idari şartname düzenlenmişse, verilen teklifler değerlendirmeye alınmadan önce, teklif edilen malın düzenlenmiş şartnameye uygunluğu tespit edilmesi de gerekmektedir. Zira yüklenicinin sunduğu malın, ihtiyaç konusu ile uyumluluk arz edip etmediği belirlenmelidir.

Doğrudan temin yolu ile yapılan alımlarda, teklifler idareye geldikten sonra, gerekli inceleme yapıldıktan sonra teklifler değerlendirilir. İdarece yapılan değerlendirmelerde, sadece fiyata

bakılmaması gerekmektedir. Keza fiyatı uygun olmakla birlikte, ihtiyaç karşılamaktan uzak malın tercih edilmemesi gerekmekte olup, bu hususa ait gerekçenin de mutlaka piyasa fiyat araştırması tutanağında belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, alımın niteliği dikkate alınarak teknik şartnamenin düzenlendiği alımlarda, teknik şartname sürecinde görev alanların, piyasa fiyat araştırma sürecinde veya muayene kabul sürecinde görev alması uygun olacaktır. Böyle bir tercihin kullanıldığı durumlarda, gerekli şartları taşımayan ürünün, idare tarafından alımının engellenmesi söz konusu olabilecektir.

5.8. Sözleşme yapılması

Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların karşılanması söz konusudur.

Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir.

Sözleşme serbestisinin iki istisnası bulunmakta olup, bahse konu hususlar, Kamu İhale Genel Tebliği ile ortaya konulmuştur. Bunlar, alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanmış zorunlu olup, bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Ayrıca, 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunluluk arz etmektedir.

Belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda, yükleniciden teminat alınması, cezai yaptırımlar ön görülmesi gibi ilave koşulların varlığı halinde de yazılı sözleşme düzenlenmesi olası hukuki belirsizliklerin aşılması anlamında yararlı olacaktır. Ancak tip dokümanların kullanılması zorunlu değildir. İdare isterse referans amaçlı kullanabilir.

5.9. Teslim ve kabul süreci

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yine bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin muayene ve kabul işlemlerinin de yapılması gerekmektedir. Bu işlemlere ait esaslar ise 4735 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir.

Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmadığından muayene ve kabul yönetmelikleri kapsamında kabul işlemi yapılması ve dolayısıyla bu kapsamda bir komisyon kurulması zorunlu değildir.

Ancak doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılan alımlarda muayene ve kabul komisyonu kurulacağına ilişkin mevzuatta açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, belirli süreli olarak alınan hizmetlerde işin niteliğine göre kontrol teşkilatı ile muayene ve kabul komisyonunun oluşturulması yararlı olacaktır.

5.10. Ön mali kontrol

Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'da düzenlenmiştir. İdarelerce, usul ve esaslarda belirlenen karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de mali hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde, yapılan alım ön mali kontrole tabi tutulmuş ise, ödeme belgesinin harcama yetkilisi tarafından imzalanmasından sonra ön mali kontrolünün yapılması için Mali Hizmetler Birimine (Strateji Geliştirme Başkanlığına) gönderilir.

Mevcut durum itibarıyla Mali Hizmetler Biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'da düzenlenmiştir. İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için beş milyon Türk Lirasını, yapım işleri için on beş milyon Türk Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbidir. Yani, doğrudan temin kapsamında alım olsa dahi söz konusu Usul ve Esaslara ait limit kapsamında olanların ön mali kontrole tabi tutulması zorunlu olmakla birlikte, bunun altındaki rakamlar ise idarenin düzenlemelerine göre şekillenecektir.

Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi danışma ve önleyici niteliği haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanması noktasında bağlayıcı değildir. Yapılan kontrol sonucunda mali karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, ödeme emri belgesinin üzerine "kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülür. Mali karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde, nedenleri açıkça belirtilen bir yazı yazılarak, ödeme emri belgesi ve ekleri ilgili harcama birimine gönderilir.

Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen alımların ödenmesinde, uygun görülmediğine ilişkin görüş yazısının ödeme belgesine bağlanması gerekir. Ayrıca, ön mali kontrol merkez teşkilatları için geçerli olup, taşra teşkilatları için bu yönde bir düzenleme bulunmadığını ifade edebiliriz.

5.11. Ödeme belgesinin düzenlenmesi

Ödeme belgesi, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde tanımlanmış olup, bütçeden yapılacak kesin ödemelerde Ödeme Emri Belgesini; ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise Muhasebe İşlem Fişini ifade etmektedir. Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. İlk iki nüshası, kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının bağlanması esastır. Ödeme belgeleri harcama yetkilisi tarafından belirlenen gerçekleştirme görevlisi tarafından düzenlenir ve ekine Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenmiş olan kanıtlayıcı belgeler bağlanır.

Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda ödeme emri ekinde yer alması gereken kanıtlayıcı belgeler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile belirlenmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin "Taahhüt dosyası" başlıklı 6'ncı maddesinde; "Hakediş raporu" başlıklı 7'nci maddesinde; "Çeşitli hizmet alımları" başlıklı 46'ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "22'nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar" başlıklı 63'üncü maddesinde ibrazı gereken belgeler genel olarak açıklanmıştır.

Ayrıca, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ'de de bu hususta tamamlayıcı nitelikte açıklamaların bulunduğunu söyleyebiliriz.

5.12. Taşınır İşlem Fişinin (TİF) düzenlenmesi

Taşınır mevzuatı uyarınca, 4734 sayılı Kanun çerçevesinde gerek ihale suretiyle ve gerekse doğrudan temin yöntemiyle alımı gerçekleştirilen taşınırların, kaydının yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Taşınır Mal Yönetmeliği eki Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenir. Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağının tarihi ve sayısı, fatura veya fatura yerine geçen belgenin tarihi ve sayısı ile satıcı firmaya ait bilgilerin de TİF'e yazılması gerekir.

Taşınır Mal Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca taşınır işlem fişinin düzenlenmeyeceği belirtilen taşınır alımlarında ödeme emri belgesine taşınır işlem fişi bağlanmayacaktır.

Yapılan bu düzenlemelere göre aşağıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine bağlanmaz.

1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri madde alımları,

2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz ve yağ alımları,

3) Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları.

Ancak bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan bakım-onarım yedek parçaları ile likit gaz, akaryakıt ve yağlar için taşınır işlem fişi düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, dergi ve gazete gibi süreli yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

5.13. Ödemenin kontrolü ve yapılması

Alım sürecine ait gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra, giderlerin hak sahiplerine

ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemler muhasebe birimince yerine getirilmektedir. Bu bağlamda, muhasebe yetkilisinin temel yetki ve sorumluluklarının, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 61'inci maddesinde düzenlendiğini görmekteyiz.

Söz konusu Yasa hükmüne göre, muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

Kontrol etmekle yükümlüdür.

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Ayrıca, bu hususlardaki hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

5.14. Doğrudan Temin Kayıt Formunun KİK'e elektronik ortamda gönderilmesi

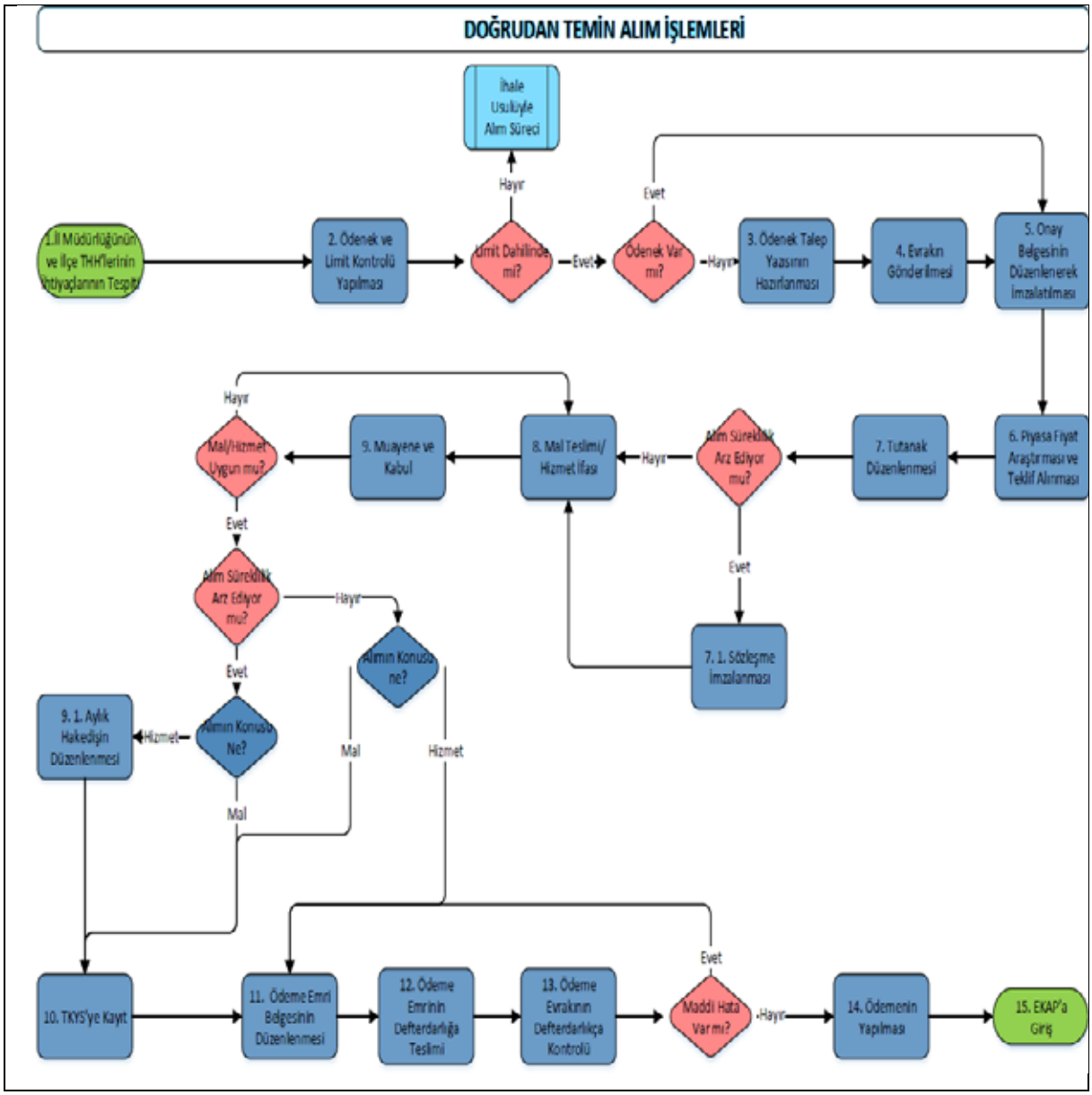
Kamu İhale Genel Tebliği'nin 30.9. maddesinin "Doğrudan Temin Kayıt Formu" başlıklı bölümünde; "Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar 'Doğrudan Temin Kayıt Formu' doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınır. " denilmektedir.

Bu çerçevede, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için "Doğrudan Temin Kayıt Formu" elektronik ortamdan gönderildikten sonra, gönderilen söz konusu formlar ayrıca posta ile gönderilmez.

Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından Ticaret İl Müdürlüklerinin iş akışlarının çıkarılmasına yönelik taşra teşkilatı özelinde daha önce yapılan çalışma sürecinde doğrudan temin kapsamı alımlara ilişkin iş akışları da çıkarılmış olup, elde edilen sonuca

aşağıda yer verilmektedir. Kuşkusuz alımın niteliği ve idarenin yapısına bağlı olarak bahse konu işlem adımlarında değişkenliklerin söz konusu olabileceğini ifade edebiliriz.

Doğrudan temin yönteminde iş akışına ilişkin örnek Tablo



6. Doğrudan temin kapsamı alımlarda Onay Belgesi ve Harcama Talimatının kapsamı ve düzenleniş şekli nasıldır?

Özet: *5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi hükmüne göre, kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu İhale Mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır. Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı Kanun'a göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi nitelikleri itibariyle aynı mahiyette belgelerdir. Ve ihale yetkilisi tarafından imzalanmaktadır. Onay belgesi KBS harcama modülü üzerinden de hazırlanabilmektedir.*

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

İdare ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına bağlı olarak, bu işlemlerin hukuki bir zeminde yürütülmesi gerekmektedir. Bu açıdan hazırlanacak onay büyük önem arz etmektedir. Zira harcama yetkilisi, harcama talebini değerlendirerek, gerçekleştirilmesine karar verebileceği gibi alımdan vazgeçilmesini de isteyebilir. Gerçekleştirilmesine karar verilen talepler için onay belgesi düzenlenir. İhale kapsamı alımlar için ihale onay belgesi düzenlenirken, doğrudan temin yönteminde sadece onay belgesi veya doğrudan temin onay belgesi adı altında bu belgenin düzenlenmesi mümkündür. Onay belgesinin düzenlenmesiyle birlikte birçok işlemin hukuki altyapısı da hazırlanmaktadır.

Kamu alımlarına ilişkin temel hukuki düzenlemeler incelendiğinde, herhangi bir harcama veya satın alma işlemi için, harcama yetkilisinden alımın veya harcamanın yapılmasına ilişkin bir onay alınmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu yöntem kapsamı alımlarda, görevlendirme yazılı olarak yapılabileceği gibi onay belgesi üzerine kayıt düşülerek de yapılabilir. Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir.

Bahse konu Onay belgesi, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinde tanımlanmış olup, yapılan bu tanıma göre "Onay belgesi": alım konusu işin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgedir.

Bu bağlamda, doğrudan temin yöntemiyle ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihaleler için İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde İhale Onay Belgesi standart formu mevcuttur. Ancak bir ihale türü olmayan doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlar için standart bir onay belgesi anılan mevzuatta bulunmamaktadır. Sadece, doğrudan temin yöntemlerinden birisi olan tek kaynaktan yapılacak alımlara ilişkin standart bir form düzenlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde, Yasa'nın 22/d bendine ilişkin olarak "*İşin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilirler*" şeklinde bir açıklamanın yer aldığını görmekteyiz.

Bu kapsamda düzenlenen onay belgesi ile bütçede bu ihtiyaç için ayrılan ödeneğin kullanılabilmesine izin verilmesinin yanında, bu ihtiyacın Kanun'un 22'nci maddesi kapsamında doğrudan teminle karşılanabileceği hususuna da olur vermektedir.

Bütün bu nedenlerle doğrudan temin uygulamasında da ihale yetkilisinden mutlaka bir onay belgesi alınması gerekmektedir. Bu husus Kamu İhale Genel Tebliği'nde de zorunluluk olarak

vurgulanmıştır. Zira bu alım yönteminde ödenek durumu, avans veya fiyat farkı verilip verilmeyeceği gibi hususlarda ihale yetkilisinden onay alınması zorunludur ve bu hususlar onay belgesiyle somutlaşmaktadır.

Doğrudan temin yönteminde kullanılacak olan onay belgesi Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır. MYHBY'de yapılan onay belgesi tanımında açık bir şekilde, onay belgesinde diğer bilgilerle birlikte alım konusu isin nev'i, niteliği, miktarı, kullanılabilir ödeneği ve tertibi bilgilerinin olması gerektiği belirtilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 32'nci maddesi hükmüne göre, kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.

Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu İhale Mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır.

6.1. Doğrudan temin yöntemi kullanılarak 22/d maddesi kapsamında yapılacak alımlar için hazırlanacak Onay belgesinin şekli nasıl olacak ve hangi bilgileri içerecektir?

5018 sayılı Kanun'un, "Harcama talimatı ve sorumluluk" başlıklı 32'nci maddesinde; "*...Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.*" hükmüne yer verilmiş olup, madde metninde geçen harcama talimatının, Kamu İhale Mevzuatındaki satın alma işlemlerine ilişkin onay belgelerini de kapsadığı anlaşılmaktadır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesine göre Harcama talimatı; Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak is veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını

taşıyan belgeyi ifade etmektedir.

Buna karşın Onay belgesi; İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım konusu isin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi ifade ettiği görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde ise "*22.1.1.4. (Değişik: 28/11/2013- 28835 R.G./ 1. md.) Diğer taraftan 22 nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur..."* düzenlemesine yer verilmiştir.

Yine söz konusu Tebliğde;*"22.5. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihtiyaçların temini*

"22.5.1. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve Kurum tarafından güncellenen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ve yapım işleri ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmetlerin idarelerce temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. İşin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilirler. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir. Ancak bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur." düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer aldığı üzere, Yasa'nın 22'nci maddesine göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmadığı için hazırlanan onaya İhale Onay Belgesi demek hatalı olacaktır. Onay Belgesi veya Doğrudan Temin Onay Belgesi demek daha doğrudur. Harcama talimatı demek ise Yasa'ya uygundur. EKAP üzerinden de doğrudan temin kapsamı alımlara ait onay belgesi hazır formlar arasında yer almaktadır.

7. 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak her alım için ayrı bir Onay Belgesi düzenlenmesi zorunlu mudur?

Özet: *Doğrudan temin kapsamı alımlara ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer aldığı üzere, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen alımlara ilişkin olarak işin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilirler. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgelerinin de onay belgesine eklenmesi gerekmektedir. Doğrudan temin kapsamı alımlarda KBS harcama modülü üzerinden de harcama talimatı hazırlanması mümkündür. Söz konusu belge de onay belgesi niteliğindedir. Çünkü bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir.*

5018 sayılı Kanun uyarınca, bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Bu kapsamda bütçeden harcama yapılmasını gerektiren doğrudan teminle yapılan alımlar için de bir onay belgesi düzenlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde de onay belgesinin ne anlama geldiği ortaya konulmuştur.

Söz konusu Yönetmeliğe göre Onay belgesi; İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım konusu isin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi ifade etmektedir.

İhtiyacın oluşmasına bağlı olarak, onay belgesi hazırlanması ve ihale yetkilisi tarafından piyasa fiyat araştırmasını yapacak personel belirlendikten sonra onay belgesinin imzalanarak alım sürecinin başlatılması gerekmektedir. Sonraki aşamada ise, doğrudan temin işlem akışına uygun olarak piyasa fiyat araştırmasının yapılması gerekir.

Bu hususta Kamu İhale Genel Tebliği'nde; *"4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ....işin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük*

ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilirler. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir…" düzenlemesi yer almaktadır.

Böylelikle her alım için onay belgesi düzenlenmesi zorunluluğunun bazı durumlar için geçerli olmadığı ortaya konulmuştur. Yani küçük ölçekli ve günlük alımlar için genel onay belgesi düzenlenebilmektedir.

Ancak doğrudan temin kapsamı alımlarda onay belgesi düzenlenmesi gerekliliğine rağmen, doğrudan temin kapsamı alımlar için düzenlenmiş standart bir onay belgesi olmaması nedeniyle, ihale uygulama yönetmelikleri ekinde yer alan standart onay belgesinin doğrudan temin kapsamı alımlar için uyarlanıp uygulanması mümkündür. Ayrıca, EKAP üzerinden de doğrudan temin kapsamı alımlara ait onay belgesi hazır formlar arasında yer almakta olup, bu formun da kullanılması mümkündür.

5018 sayılı Kanun'a göre kamu idareleri tarafından kurum bütçesinden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle ya da Kamu İhale Kanunu'na göre ihale yetkilisinin onay belgesini vermesiyle mümkündür.

Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı Kanun'a göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi nitelikleri itibariyle aynı mahiyette belgelerdir.

Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan alımlar için standart form şeklinde düzenlenmiş ihale onay belgesi mevcuttur. Buna karşılık, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlar için KİK tarafından tasarlanan ve ihale türleri için kullanılan onay belgesine benzeyen standart bir onay belgesi mevcut değildir.

Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmadığı için hazırlanan onaya, İhale Onay Belgesi demek hatalı olacaktır. Onay belgesi veya Doğrudan Temin Onay belgesi demek daha doğrudur. Harcama talimatı demek ise Yasa'ya uygundur. EKAP üzerinden de doğrudan temin kapsamı alımlara ait onay belgesi hazır formlar arasında yer almaktadır.

KBS kullanılarak da harcama talimatı onay belgesi düzenlenebilmektedir. Doğrudan temin kapsamı alımlarda KBS harcama modülü üzerinden belgenin hazırlanması durumunda, yeterli ödeneğin bulunmaması durumunda onay işlemi tamamlanamamaktadır ve işlem sonraki aşamaya geçememektedir. Ayrıca, ödeneksiz alım işlemine muhasebe birimleri de engel olmakta ve böyle bir durumda ödeme işlemi gerçekleştirilmemektedir.

8. Doğrudan temin kapsamı alımlarda teknik şartname düzenlenmesi zorunlu mudur?

Özet: *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliği'ndeki açıklamalar uyarınca, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda şartname düzenlenmesi idarelerin takdirinde bulunsa da gerek teklif fiyatının oluşturulması gerekse kabul işlemlerinin yapılması açısından bu yöntemle yapılan alımlarda da teknik şartnamelerin (günlük ve küçük ölçekli alımlar hariç olmak üzere) hazırlanmasının yararlı olduğu düşünülmektedir. Doğrudan temin yönteminde alım konusu işin teknik özellikleri, teklif vermeye davet yazısında ya da ayrı bir teknik şartnamede gösterilebilir. İhale yetkilisi tarafından teknik şartnameyi hazırlayacak personelin yazılı görevlendirilmesi uygun olacaktır. 4734 saylı Kanun'un 22'nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda marka veya model belirtilmesi alımın özelliğinden dolayı mümkündür. Çünkü söz konusu alımlar belli bir marka, model veya kişiye yönelik alımlardır. Aynı şekilde Yasa'nın 22'nci maddenin (d) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise alımın niteliğine bağlı olarak belli durumlarda marka belirtilmesi söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, tercihe bağlı olarak hazırlanması durumunda teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.*

Gerek ihale kapsamı alımlar ve gerekse doğrudan temin kapsamı alımlar için teknik şartname düzenlenmesi çoğu zaman gereklilik arz edebilir. Çünkü ihtiyaç duyulan mal veya hizmet ya da yapım işlerine ait niteliklerin ayrıntılı ve tereddütleri giderecek şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bahse konu teknik kriterlere, ihale (alım) dokümanın bir parçası konumundaki teknik şartnamelerde yer verildiğini görmekteyiz.

İhale kapsamı alımlar için teknik şartname 4734 sayılı Kanun'un "Şartnameler" başlıklı 12'nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun maddesinde;

"İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve ***teknik şartnamelerin*** *idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.*

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının

bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.
Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir."

Hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere; ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine teknik şartnamelerde yer verileceği Yasa maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Bu maddeye göre, ihale ile yapılan tüm alımlar için teknik şartname düzenlenmesi zorunludur. Çünkü alınacak mal ve hizmetler ile yapım işlerinin teknik özellikleri bilinmeden işin yaklaşık maliyetinin gerçekçi bir şekilde tespiti mümkün değildir.

Bu bağlamda, alım konusu malın niteliği ve ilgili ihale uygulama yönetmeliğinde öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliğinin de teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilmesi gerekir. Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenlemeler de yapılması mümkündür.

Teknik şartnamenin hazırlanmaması durumunda, yüklenici tarafından işin ihale dokümanına uygun olarak idareye teslim edilip edilmediğinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi de mümkün olamayabilecektir.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda da gerek fiyat araştırması sırasında gerekse alımın idarece kabul aşamasında, bir teknik şartnamenin hazırlanmasının çoğu zaman yasal olmasa da fiili bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz.

Dolayısıyla, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda teknik şartname hazırlanması gereklidir. Bu husus ayrı bir teknik şartname düzenlenmesi şeklinde olabileceği gibi teklif alma yazısında alıma konu ihtiyacın niteliklerinin belirtilmesi şeklinde de olabilir.

4734 sayılı Yasa'nın teknik şartnameye ilişkin 12'nci maddesi gereği; teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Bu durumunun istisnası ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilmesi durumudur.

Yine yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür. Söz konusu durumlar dışında ihalelerde marka veya model belirtme imkânı yoktur.

Uygulamada tereddüt yaratan hususlardan biri de 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi kapsamında yapılan alımlarda marka ve model belirtilip belirtilemeyeceği hususudur. Bu hususu söz konusu maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda ayrı, (d) bendi kapsamında yapılan alımlarda ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda marka veya model belirtilmesi işin doğası gereğidir. Bu hususa ilişkin olarak KİK 01.04.2003 tarih ve 2003/DK-D.94 sayılı Kararı'nda da *"Bir taahhüt kapsamında, taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır."* değerlendirilmesine yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.2. maddesinde de "*İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet alımlarında, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir. Ayrıca, bir taahhüt*

kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır." açıklaması yer almaktadır.

Söz konusu alımlar (22/a-b-c) belli bir marka, model veya kişiye yönelik alımlardır. Ancak 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamındaki alımlarda marka belirtilmesi hususu alıma göre değişkenlik göstermektedir. Kamu İhale Genel Tebliği'nde ise, "*İdarelerce işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, ordu evi, askeri gazino, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler tarafından, bu tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hallerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilir."* hususuna yer verilmiştir.

Bu çerçevede idarelerce işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, ordu evi, askeri gazino, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler tarafından, bu tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hâllerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilecektir.

Öte yandan, hazırlanacak teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir. Aynı gerekçe doğrudan temin kapsamı alımlar için de geçerlidir. Örneğin, idarenin bir klima veya buzdolabı ya da fotokopi makinesi aldığını düşünürsek, bu alımlara ilişkin teknik tanım ve bilgilerin belirsiz olması idare ihtiyaçlarının en uygun şekilde karşılanmasını engelleyecektir. Bu durum ise kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasının yanında 4734 sayılı Yasa'nın temel ilkelerine aykırılığı da gündeme getirecektir.

Dolayısıyla, idarenin günlük ve küçük ölçekli ihtiyaçları hariç olmak üzere, idarece gerekli görülmesi durumunda, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda da yasal zorunluluk olmasa bile teknik şartname hazırlanmasının yararlı olacağını, bu hususun ayrı bir teknik şartname düzenlenmesi şeklinde olabileceği gibi teklif alma yazısında alıma konu ihtiyacın niteliklerinin belirtilmesi şeklinde de hazırlanmasının mümkün olacağını ifade edebiliriz.

9. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda idari şartname zorunlu mudur?

Özet: *İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterleri idari şartnamelerde yer almaktadır. İdarelerin, mevzuata aykırı olmamak ve alımın niteliğine bağlı olarak, kendi öngördüğü bilgileri içeren idari şartname düzenlemesi gerekmektedir. Yani ihale kapsamı alımlar için zorunluluktur. Buna karşın bir ihale yöntemi olmayan doğrudan temin kapsamı alımlarda, idare alımın niteliğine bağlı olarak isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin isteğe bağlı düzenlemeler yapılabilir. Doğrudan temin kapsamı alımlarda idari şartname düzenlenmesine karar verilen hallerde, söz konusu idari şartnamelerin Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tip idari şartnamelerle aynı olmasına gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla, idare mevzuata aykırı olmamak ve alımın niteliğine bağlı olarak, kendi öngördüğü bilgileri içeren idari şartname düzenleyebilir. Hazırlanacak söz konusu dokümanın, piyasa fiyat araştırması esnasında istekli konumunda bulunan kişilere/firmalara verilmesi ise sağlıklı fiyat araştırması açısından yararlı olacaktır.*

Doğrudan temin yöntemi, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen durumların varlığı halinde istisnai olarak başvurulan bir alım şeklidir. Yani burada ihale türlerinden farklı esaslara bağlanılan bir satın alma yönteminin varlığı söz konusudur.

Konuyla bağlantılı 4734 sayılı Yasa'nın "Şartnameler" başlıklı 12'nci maddesi;

*"İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten **idari** ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.*

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve

tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir."

Hükmüne amirdir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterleri bölümünde idari şartnamede yer almaktadır. Dolayısıyla, idari şartnameler, idare ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması açısından önem arz etmektedir. Bu şekilde belirlenecek kriterler ihaleye katılım sayısını etkileyecektir.

Doğrudan temin kapsamında yapılacak alımlarda ise, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur.

Belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Söz konusu alım yöntemi farklı esaslara bağlandığı için, doğrudan teminde sözleşme yapılması zorunlu olmadığı gibi aynı zamanda ihale usullerinde olduğu gibi tip sözleşme de söz konusu değildir. Dolayısıyla, ihale kapsamı alımlar için öngörülen kriter ve kurallara bu yöntemde bağlı olunması söz konusu değildir.

Ancak, ihale türleri alımlar için geçerli olmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı 10'uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden ihaleye katılımda istenebilecek ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek belge ve bilgiler belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar" başlıklı 27'nci maddesinde;

"İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir." şeklinde düzenlenmiştir.

İhale kapsamı alımlarda, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

İstekliler tarafından, üst kısımdaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'ne uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

04.01.2002 tarihinde kabul edilen ve 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, kamu idarelerinin kamu kaynaklarını kullanarak yapacakları alımlara ilişkin hususları düzenlemektedir. Kanun'un, kamu satın alma işlemleriyle ilgili getirdiği birçok yeni kavram ve süreçten birisi de "Doğrudan temin" olmuştur.

Başlangıçta, Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri arasında yer alan doğrudan temin, 30.07.2003 tarihinde kabul edilen 4964 sayılı Kanun'la, Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik yapılarak bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

Kamu idarelerinin, Kanun'da belirtilen özel durumlarda ihtiyaçlarını, ihale sürecinde öngörülen prosedürleri atlayarak daha kolay ve hızlı bir şekilde karşılamalarına imkân vermek amacıyla geliştirilen ve düzenlenen doğrudan temin yöntemi, Kanun'un 4'üncü maddesinde; "*Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul*" şeklinde tanımlanmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10'uncu maddesi uyarınca isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla bazı belgeler istenilmektedir. Söz konusu belgeler ihale usulleri kullanılarak yapılacak alımlarda istenilmekte olup, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda bahse konu yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Buna karşın, bir ihale yöntemi olmayan doğrudan temin kapsamı alımlarda, idare alımın niteliğine bağlı olarak isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin düzenlemeler yapılabilir. Dolayısıyla, bu şekilde yapılacak bir düzenlemenin varlığı halinde, yani doğrudan temin ile yapılacak alımlar kapsamı şartnamelerde, bilanço, gelir tablosu ve iş deneyim belgesi gibi hususlara yer verilebilir.

Doğrudan temin kapsamı alımlarda idari şartname düzenlenmesine karar verilen hallerde, söz konusu idari şartnamelerin Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tip idari şartnamelerden olmasına gerek bulunmamaktadır.

İdare mevzuata aykırı olmamak ve alımın niteliğine bağlı olarak, kendi öngördüğü bilgileri içeren idari şartname düzenleyebilir.

Her ne kadar ihale usulü olmaktan çıkarılsa da ihale kapsamı alımlarda olduğu gibi, doğrudan temin yönteminde de ihtiyaçların en uygun şartlarla karşılanması, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması gibi Kanun'da yer verilen temel ilkelerin gözetilmesinin esas olduğu bilinmelidir. Çünkü doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlarda da kamu kaynağı kullanılmaktadır.

Doğrudan temin uygulamasında şartname ve sözleşme düzenlenmesi idarenin takdirinde bir husus olmakla birlikte özellikle süreli alımlarda, bir başka ifadeyle işin gerçekleştirilmesinin belli bir süreye bağlı olduğu mal, hizmet veya yapım işlerinde sözleşme düzenlenmesi gerekir.

Bu husus, Kamu İhale Genel Tebliği'nde; "Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur." şeklinde öngörülmüştür.

Yine bu tür alımlarda idare sadece sözleşme düzenleyebileceği gibi idari ve teknik şartnameler de hazırlayabilecek ve bunları sözleşmenin bir parçası olarak kullanabilecektir. İdari şartname düzenlenecek hallerde;

a) Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan Tip Şartnamelerin kullanılma zorunluluğu,

b) 4734 sayılı Kanun'un 27'inci maddesinde düzenlenen idari şartnamede bulunması zorunlu hususlara uyma zorunluluğu,

olmaksızın işin niteliğine göre belirleyeceği idari şartnameyi kullanılabilecektir.

Bununla birlikte, söz konusu tip dokümanların bir kısmının kullanılması da mümkündür. İdare isterse, hazırlayacakları doğrudan temine ait alım belgelerde bu tip dokümanlara yer vermek suretiyle de bu belgeleri referans olarak kullanabilecektir.

10. Doğrudan temin yönteminde yaklaşık maliyet hesaplanması gerekmekte midir?

Özet: *Doğrudan temin bir ihale usulü değildir ve Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların doğrudan temin sürecinde uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede, yaklaşık maliyet hazırlama zorunluluğunun ihale usulleri kullanılarak yapılacak alımlar için getirildiğini, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin yönteminde Kanun'un 9'uncu maddesine ve ihale uygulama yönetmeliklerinin konuyu düzenleyen hükümlerine göre yaklaşık maliyet hesaplama zorunluluğunun olmadığını söyleyebiliriz. Kamu İhale Genel Tebliği'nde de bu yönde bir zorunluluk öngörülmemiştir. Ancak 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde piyasa fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yapılması zorunludur. 4734 sayılı Kanun'a göre doğrudan temin için zorunlu olmayan bu uygulama ile ilgili olarak, yapılacak alımdan önce yaklaşık maliyet hazırlamanın alım süreci bakımından bir fayda sağlayıp sağlamayacağı çerçevesinde konunun değerlendirilerek karar verilmesi gerekmektedir. Şayet yapılmasına karar verilmişse, idare yaklaşık maliyetin hesaplanmasında; alım konusu malın niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç istekliden fiyat bildirilmesini ister. Ancak idarenin, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini değerlendirmeye almaması icap eder.*

Yaklaşık maliyete ilişkin temel hukuki doküman olarak gözüken 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere, İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği'nde bu hususa ait düzenlemelerin yapıldığını görmekteyiz.

Öncelikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Yaklaşık maliyet"e ilişkin 9'uncu maddesine baktığımız zaman söz konusu maddenin; *"Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz."* hükmüne amir olduğu görülmektedir.

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, ilgili uygulama yönetmeliklerinde belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması

yapılarak Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Ödenek miktarı belirlenirken yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisi de dahil edilir.

Yasa'nın 22/d maddesi kapsamı alımlarda, yaklaşık maliyetin tespiti zorunlu olmamakla birlikte, yaklaşık maliyet tespit edilmeden karşılanacak ihtiyacın belirlenen parasal tutarın altında kalıp kalmadığı bilinemez. Bu nedenle, anılan Yasa maddesine göre yapılacak alımlar için öncelikle yaklaşık maliyet hesap cetvelinin idarece hazırlanması ve hesap cetvelinin ihale yetkilisine onaylattırılması uygun olacaktır. Ancak zorunluluk değildir.

Bilindiği üzere, doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü değildir ve Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların doğrudan temin sürecinde uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, Kanun'un mezkûr maddesinde yer alan düzenlemelerin ihale usulleri kullanılarak yapılacak alımlar için getirildiğini, bir ihale usulü olmayan doğrudan teminde ihale uygulama yönetmeliklerinin konuyu düzenleyen hükümlerine uygun bir yaklaşık maliyet hesabı çıkarmanın zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği'nde de bu tür bir zorunluluk öngörülmemiştir.

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliği'nde, *"Ancak bu bent 22-d kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur."* düzenlemesi bulunmakta olup, bu özel durumun süreçte dikkate alınması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun'a göre zorunlu olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak ise bu yöntemle yapılacak alımdan önce yaklaşık maliyet hazırlamanın alım süreci bakımından teknik veya hukuki bir fayda sağlayıp sağlamayacağı ile bu konuda idarelere zorunluluk getiren başka bir mevzuat hükmünün bulunup bulunmadığı noktasından değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Kanun'un 22'nci maddesinde, doğrudan temin suretiyle yapılacak alımın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer aldığı üzere, 22'nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılması mümkündür.

Aynı Genel Tebliğe göre; 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

Söz konusu Yönetmelikte yer alan düzenlemelere baktığımızda ise;

"Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler" başlıklı 8'inci maddesi;

"(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
(2) Ön ilan yayımlanmadan önce yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktar veya kapsam esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yeniden hesaplanır.
(3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.
(4) İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.
(5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır.

(6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir."

"Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti" başlıklı 9'uncu maddesi;

"(1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir:
a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.
b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.
c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.
ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.
d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar.
e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir."

"Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti" başlıklı 10'uncu maddesi;

"(1) İdarelerce, ihale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;
a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,
c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,
ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,
d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri,
esas alınır.
(2) İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.
(3) İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir.
(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz."

"Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi" başlıklı 11'inci maddesi;

"(1) İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara %25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.
(2) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onay belgesine eklenir.

(3) Yaklaşık maliyet, güncelliğini kaybetmesi halinde, ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenir."

Şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

İlave olarak, tek kaynaktan temin edilecek alımlarda kullanılacak standart formlarda (KİK021.0/H ve KİK022.0/M) yaklaşık bedel hazırlanmasına ilişkin açıklamalara yer verildiğinden dolayı, 22'nci maddenin a, b ve c bentlerine göre yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet hazırlanmasının zorunlu olduğunu, diğer bentleri için ise zorunlu olmadığını, bu bağlamda, mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak tek yükleniciden alım yapılabilir olmasının piyasa fiyat araştırması yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını ifade edebiliriz.

Ayrıca, özellikle Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında yapılan ve küçük ölçekli olmayan alımlar için, alıma konu tutarın doğrudan temin kapsamında kalıp kalmadığının belirlenmesi için yaklaşık maliyetin belirlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bu hususa ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunun 10.07.2014 tarihli, 580-12281 sayılı yazısının da dikkate alınması gerekmektedir.

Nitekim bahse konu yazıda; "Doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle Kanundaki değişik usul ve kurallardan bağışık tutulduğu, bu nedenle idarelerin doğrudan temin yönteminde daha esnek hareket edebilecekleri, bu anlamda yaklaşık maliyet tespiti yaparak alım yapmanın da ihale usulleri kapsamında zorunlu tutulduğu, bu nedenle de doğrudan temin yönteminde böyle bir zorunluluktan söz edilemeyeceği" hususları yer almaktadır.

Doğrudan temin yönteminin tek kaynaktan temine ilişkin uygulamaları için hazırlanan standart formda "Yaklaşık Bedel" bölümü bulunmaktadır. Ayrıca, aynı formun "Fiyat Araştırması" bölümünde, "*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 'Doğrudan Temin' Başlıklı 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre bu maddeye göre yapılacak alımlarda ihale yetkilisince*

görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilecektir." açıklaması yer almaktadır.

Ancak Kamu İhale Genel Tebliği (22.5.1.1.)'nin; "*Bu bentte (22/d) belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.*" şeklindeki açıklamasından, yaklaşık maliyet belirlenmeden onay alınarak işlemlerin başlatılacağı ve piyasa fiyat araştırması sonucunda limit aşılırsa alımın doğrudan teminle yapılmaması ve diğer ihale usullerine başvurulması gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Diğer bir ifadeyle, 22/d kapsamında, belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, MYHBY'deki onay belgesi tanımında;"… doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım konusu işin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi" ifadesi yer almaktadır.

Doğrudan temin kapsamı alımlar için geçerli olan "piyasa fiyat araştırması" ifadesi, 4734 sayılı Kanun'da yaklaşık maliyetin hazırlanmasıyla ilgili olarak yer verilen "her türlü fiyat araştırması" ifadesi ile benzer anlamlara sahip olup, böylece doğrudan teminde, alım yapacak kişiler dışında fiyat araştırması yapacak başka bir komisyon kurulmasına gerek olmadığı gibi, alım yapacak kişilerce yapılacak piyasa fiyat araştırması dışında fiyat tespiti için başka bir araştırma yapılmasına da gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

10.1. 4734 sayılı Kanun'un 22/d maddesi kapsamı alımlarda ödeme belgesine yaklaşık maliyet hesap cetveli eklenmeli midir?

Doğrudan temin yönteminde ihtiyaçlar ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilir. Piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. Gerekli

görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilecektir. Ancak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.5.1'inci maddesi uyarınca 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yapılması zorunludur.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde piyasa fiyat araştırması tutanağı; "*doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanak*" olarak tanımlanmıştır. Piyasa fiyat araştırması tutanağı, piyasa fiyat araştırmasını yapan görevli/görevliler tarafından imzalanmalıdır. Bunun dışında söz konusu tutanağın ayrıca ihale yetkilisi tarafından imzalanması zorunluluk arz etmemektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde; "*Diğer taraftan 22 nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir. Ancak doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, piyasa araştırması yapılması aşamasında bu hususun belirtilerek fiyat tekliflerinin alınması gerekmektedir."* açıklaması yer almaktadır.

Aynı Genel Tebliğde ayrıca; *"İdareler ihtiyaçlarının temin edilmesinde saydamlığı, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu zorunlulukların idarece saptanması durumunda, yapılacak alımlarda; ihale komisyonu kurma ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilecektir… "* şeklinde düzenlemeye de yer verilmiştir.

Bunlarla birlikte, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ'de; "…sınai, teknolojik, malî ve benzeri zorunluluklar nedeniyle yaklaşık maliyetin tespit edilemediği haller

dışında, yaklaşık maliyet hesap cetveli veya yaklaşık bedelin tespitine ilişkin belgeler de yukarıda belirtilen ihale onay belgesi veya onay belgesi ile birlikte ödeme belgesine bağlanacaktır.” yönündeki düzenlemeyle bağlantılı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı (mülga Maliye Bakanlığı) Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2014 yılında yayınladığı bir yazı ile Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli ekleme zorunluluğunu kaldırdığını bildirmiştir.

11. Doğrudan temin kapsamı alımlarda hesaplanan yaklaşık maliyetin üzerinde teklifin bulunması durumunda idare ne yapmalıdır?

Özet: *4734 sayılı Yasa'nın temel ilkelerinden birisi de ihtiyaçların uygun koşullarda ve zamanında karşılanmasıdır. Söz konusu ilke sadece ihale kapsamı için değil, doğrudan temin dahil diğer alım yöntemleri için de geçerlidir. Bu süreçte esas olan harcama yapılması değil, yapılan harcama neticesinde en yüksek kamusal faydayı mevzuata uygun olarak elde etmektir. Dolayısıyla, yapılacak değerlendirmede, idarelerce ihtiyaç duyulan malların en uygun fiyatla temin edildiği yönünde kanaat oluşması ve hizmetin gerekleri de dikkate alınarak doğrudan temin kapsamı alım da olsa yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin idarece kabul edilmesi mümkündür. Kuşkusuz bu süreçte gerçekçi olmayan fiyatların değerlendirmeye alınmaması gerekmektedir. Doğrudan temin kapsamında çoğu alım için geçerli olduğu üzere, yaklaşık maliyetin tespit edilmesine gerek duyulmamaktadır. Ayrıca, yapılan piyasa fiyat araştırması neticesinde, alınan tekliflerden uygun olan üzerinde alım süreci gerçekleştiği için böyle bir durum, yaklaşık maliyetin hazırlanmadığı durumlarda pratikte söz konusu olmayacaktır.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Söz konusu Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır.

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur. Bunların dışında, satın alma sürecinde ihale usulleri için öngörülen diğer genel düzenlemelerin bu yöntem için uygulanmamasına ilişkin Kanun'da açık bir hüküm bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kanun'un "Yaklaşık maliyet"e ilişkin 9'uncu maddesi uyarınca, ihale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan ihale konusu alımın, hizmet işinin öngörülen bedelini ifade etmektedir.

Bu bağlamda, bütçeye ödenek konulmasından, ihale ilân sürelerinin, ihaleye katılımda yeterlik kurallarının, ihalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığının belirlenmesinde, fiyat avantajı uygulanmasında, verilen tekliflerin değerlendirilmesinde, diğer bir ifade ile ihale sürecinin sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesinde yaklaşık maliyetin gerçekçi olarak tespitinin önemi büyüktür.

4734 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinde yer verilen, yaklaşık maliyet hazırlanması ile ilgili zorunluluğunun ihale usulleri kullanılarak yapılacak alımlar için getirildiği, Yasa kapsamında bir ihale usulü olmayan doğrudan teminde yönteminde yaklaşık maliyet hesaplama zorunluluğu olmadığını söyleyebiliriz.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde esas olarak bir zorunluluk öngörmemekle birlikte, Yasa'nın 22/d maddesi kapsamı yapım işi için istisnai bir durum öngörülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği'ne göre; 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

Ancak belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Kanun'un 22'nci maddesinde, doğrudan temin suretiyle yapılacak alımın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bahse konu "piyasa fiyat araştırması" tabiri, Kanun'un 9'uncu maddesinde yaklaşık maliyetin hazırlanmasıyla ilgili olarak geçen "her türlü fiyat araştırması" tabiriyle benzer içeriğe sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Doğrudan temin kapsamı alımlara ilişkin olarak yaklaşık maliyet hazırlanmasına gerek bulunmamakla birlikte, 4734 sayılı Yasa'nın doğrudan temine ilişkin düzenlemelerinin yer

aldığı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının "a, b ve c bentleri" kapsamında yapılan alımlar ile aynı maddenin "d" bendi kapsamında olsa bile yapım işlerine ait alımlarda yaklaşık maliyetin belirlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, özellikle 22/d maddesi kapsamında yapılan ve küçük ölçekli olmayan alımlar için, alıma konu tutarın doğrudan temin kapsamında kalıp kalmadığının belirlenmesi için de yaklaşık maliyetin belirlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Konuyla bağlantılı olarak Kamu İhale Kurumu bir açıklamasında da; "… Doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle Kanundaki değişik usul ve kurallardan bağışık tutulduğu, bu nedenle idarelerin doğrudan temin yönteminde daha esnek hareket edebilecekleri, bu anlamda yaklaşık maliyet tespiti yaparak alım yapmanın da ihale usulleri kapsamında zorunlu tutulduğu, bu nedenle de doğrudan temin yönteminde böyle bir zorunluluktan söz edilemeyeceği" hususlarına yer vermiştir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemelere göre ise Onay belgesi; Doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım konusu işin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi ifade ettiği vurgulanmıştır. Yani onay belgesinde yaklaşık maliyete ilişkin bilgiye de yer verilmesi gerektiği öngörülmüştür.

Yaklaşık maliyetin hesaplanması, alımın yönteminin belirlenmesi ve alım için yeterli kaynağın var olup olmadığının tespit edilmesinin ortaya konulması açısından önem arz etmektedir. Kamu İhale Mevzuatı gereğince, ihale onay belgesinin ihale yetkilisince onaylanmasından önce yaklaşık maliyetin usulüne uygun şekilde belirlenerek ihale onay belgesi ekinde ihale yetkilisinin onayına sunulması gerekmektedir.

Görüldüğü üzere; ihale kapsamı alımlar için zorunluluk arz eden yaklaşık maliyet hesaplama gerekliliği genel olarak doğrudan temin kapsamı alımlar için söz konusu değildir. Ancak 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesinin ilk fıkrasının "a, b ve c bentleri" kapsamında yapılan alımlar ile 22/d kapsamı olsa bile yapım işlerine ait alımlarda yaklaşık maliyetin hesaplanması gerekmektedir.

Bu bağlamda, gerek zorunluk arz eden durumlar için ve gerekse faydası olacağı düşüncesiyle yapılan yaklaşık maliyet fiyat araştırması neticesinde elde edilen tutarlara oranla, piyasa fiyat araştırmasında daha yüksek tutarlarda fiyat tekliflerinin gelmesi durumunda idare nasıl hareket etmesi gerektiğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Doğrudan temin kapsamı alım bile olsa, idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin üzerinde bir teklif gelmesi durumunda, söz konusu ve idarece kabul edilen tutarın ihale alım limitleri içinde olmaması koşuluyla, belli durumlarda bu teklifin kabul edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Bu hususta Kamu İhale Genel Tebliği'nde açıklama bulunmaktadır. Her ne kadar bu düzenleme ihale kapsamı alımlar için söz konusu olsa da bunun doğrudan temin kapsamı alımlar için de referans olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler" başlıklı maddesi söz konusu maddesine (16.3) baktığımız zaman;

"16.3. Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler

16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir."

Şeklinde bir düzenleme ile karşılaşmaktayız.

Söz konusu düzenleme çerçevesinde, piyasa fiyat araştırması neticesinde elde edilen tutarların, yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.

Tekrar altını çizmek gerekirse, idarelerin bu yöndeki teklifleri kabul etmesi için bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece hizmetin gerekleri çerçevesinde, idarenin sorumluluğu almak şartıyla bu şekilde hareket edebilmesi mümkündür.

Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabulünde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 16.3. maddesinde de belirtildiği üzere, yaklaşık maliyette hata yok ise idare yaklaşık maliyet üzerindeki teklifi kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alarak kabul edebilir. Buradaki teklifin yaklaşık maliyetin ne kadar üzerinde olduğunda kabul edilebileceğine ilişkin mevzuatımızda bir üst sınır bulunmamaktadır.

Alımı gerçekleştiren idarenin sorumluluğunun söz konusu olması nedeniyle, bu konumdaki idarenin hizmet gerekleri ve kamu yararı gözeterek karar vermesi gerekmektedir. Yani seçimlik bir hareket tarzı idare için söz konusu olup, idare yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri kabul edebileceği gibi Yasa'nın temel ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu yöndeki tekliflerin kabul edilmemesi yönünde de tavrını koyabilir.

12. Doğrudan temin kapsamında belirlenen yaklaşık maliyetin gizlenmesi gerekmekte midir?

Özet: *Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda istisnai durumlar hariç olmak üzere, yaklaşık maliyet hesaplama zorunluluğu bulunmamakla birlikte, hesaplamanın gereklilik arz ettiği durumlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine ve dolayısıyla gizlilik ilkesine riayet edilmesi gerekmektedir. Doğrudan temin için gizlilik ilkesinin sadece yaklaşık maliyet için geçerli olmadığını, bu kısıtlamanın doğrudan temin yönteminde yakın fonksiyonları bulunan piyasa fiyat araştırma süreci ve diğer alım dokümanları için de geçerli olduğunu, çünkü bu kapsamdaki bilgilerin aynı zamanda gizli kalması kaydıyla verilen ticari bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla mevzuatı ile belirlenen durum ve koşullar oluşmadığı sürece gizlilik ilkesine aykırılıklar için yaptırım uygulanmasının söz konusu olabileceğini ifade edebiliriz.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesinde; " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu ilkelerden gizlilik ilkesi; yalnızca idare tarafından bilinmesi gereken, katılımcılarla ve diğer gerçek ve tüzel kişilere açıklanmayan ticarî ve malî hususların açıklanması yasağına ilişkindir. Aksi nitelikteki saydamlık ilkesi ise ihale sürecinin hukuka uygunluğunu sağlamak amacıyla bilgilerin paylaşılabilirliğini hedeflemektedir. Bu yönüyle her iki ilke de ihale sürecine hâkim olması gereken temel ilkeler arasında bulunmakta ve idareler tarafından dikkate alınmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu incelendiği zaman, anılan Yasa'nın "9, 61 ve 62'nci maddenin (d) bendinin" bu ilkeyle bağlantısı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, yaklaşık maliyet, ihalenin yapılma yöntemini ve sonucunu etkileyen en önemli etken olduğu için gizli tutulması büyük önem arz etmektedir. 4734 sayılı Kanun'un temel ilkelerinin belirlendiği 5'inci maddesinde yer alan "gizlilik" ilkesinin bir sonucu olarak yaklaşık maliyet bilgisinin gizliliği, mevzuat ile belirlenen sürece kadar bu bilginin açıklanmasının yasaklanmasını öngörmektedir.

Kamu İhale Mevzuatı, yaklaşık maliyetin idarelerce belirlenmesini öngörmektedir. Ancak, teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyetin belirlenmesi işlemi de danışmanlık hizmet sunucusuna yaptırılabilir. Fakat mevzuat sadece yaklaşık maliyeti belirlemek için danışmanlık hizmeti alınmasına izin vermemektedir.

Anılan Kanun'un "Yaklaşık maliyet" başlıklı 9'uncu maddesinde ise; "Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz." hükmü öngörülmüştür.

4734 sayılı Kanun'un "Temel ilkelerine" bakıldığında, idarelerin ihalelerde saydamlığı sağlamakla yükümlü olduğu gibi, aynı şekilde gizlilik ilkesinin gereklerini de yerine getirmekle yükümlü olduğu görülmektedir.

Kanun'un "Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı" başlıklı 61'inci maddesi ile de görevlilerin ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere o isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemeyecekleri, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacaklarını hükme bağlamaktadır. Şüphesiz aksi yöndeki davrananlar hakkında 58 ve 60'ıncı maddelerde belirtilen müeyyidelerin uygulanması söz konusudur.

4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen mal veya hizmet alımı veya yapım işleri için ihale yapılmadan önce idare tarafından yaklaşık maliyet belirlenmektedir. Gizlilik ilkesinin gereği olarak, idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyetin gizli tutulması ve herhangi bir şekilde isteklilerle paylaşılmaması zorunludur. Zira mevzuat, yaklaşık maliyetin, ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilerle paylaşılmasını yasaklamaktadır. İstekliler, piyasa şartlarına uygun olarak teklif vermekte ve yaklaşık maliyeti bu aşamada bilmemektedir. Bu ise gerçekçi fiyat oluşumlarına katkı sağlamaktadır.

Yaklaşık maliyetin gizli tutulması, ihale sürecinde eşitliği ve rekabeti sağlamaktadır. Kamu İhale Kurulu Kararlarında gizlilik ilkesinin ihlal edilmesi eşit muamele ilkesi ile

ilişkilendirilmektedir. Nitekim gizlilik ilkesinin ihlali, ihale katılımcıları arasında belli gerçek veya tüzel kişiler lehine avantaj sağlanmasına gerekçe oluşturabilecektir. Bu durum ise kamu kaynağının en uygun şekilde kullanılmasını engellemektedir.

Bu itibarla, yaklaşık maliyetin gizli tutulmasının gereği olarak, ihale ilanlarında ve isteklilere verilen ihale dokümanlarında hiçbir surette yaklaşık maliyet bilgisine yer verilemez ve herhangi bir suretle açıklanamaz. Yaklaşık maliyetin gizliliği, ihale sonuçlanıncaya kadar korunur.

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin ilke ve esaslar ise, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihale uygulama yönetmeliklerinde, bu alımların özellikleri de dikkate alınarak detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.

İhale kapsamı alımlar için zorunluluk arz eden yaklaşık maliyet hesaplama zorunluluğu, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar için esas olarak geçerli değildir. Yani doğrudan temin kapsamı alımlara ilişkin olarak yaklaşık maliyet hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere, 4964 sayılı Yasa ile 4734 sayılı Yasa'da yapılan değişiklikten sonra doğrudan temin ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Dolayısıyla, doğrudan temin bir ihale usulü değildir ve Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların doğrudan temin sürecinde uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde ise bu hususta, 22/d kapsamı yapım işleri için bir istisna getirilerek, söz konusu alıma ilişkin piyasa fiyat araştırmasının ilgili ihale uygulama yönetmeliğinde yer alan esaslara göre yaklaşık maliyetin belirlenmesi gerektiği öngörülmüştür.

4734 sayılı Kanun'a göre zorunlu olmayan bu uygulama ile ilgili olarak ise, doğrudan teminle yapılacak alımdan önce yaklaşık maliyet hazırlamanın alım süreci bakımından bir fayda sağlayıp sağlamayacağı ile bu konuda idarelere zorunluluk getiren başka bir mevzuat hükmünün bulunup bulunmadığı noktasında idarece değerlendirme yapılıp karar verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Kanun'un 22'nci maddesinde, doğrudan temin suretiyle yapılacak alımın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak

gerçekleşeceği belirtilmek suretiyle, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlar için yaklaşık maliyet hesaplama zorunluluğunun esas olarak olmadığı ortaya konulmuştur.

Ancak Yasa'nın 22/a-b-c maddeleri kapsamında yapılan alımlar ile 22/d maddesi kapsamı yapım işlerine ait alım sürecinde yaklaşık maliyet hesaplamasının yapılması gerekmektedir. Ayrıca, özellikle 22/d kapsamında yapılan ve küçük ölçekli olmayan alımlar için, alıma konu tutarın doğrudan temin limiti içinde kalıp kalmadığının belirlenmesi için yaklaşık maliyetin belirlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Diğer bu hususa ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu bir yazısında;"… Doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle Kanundaki değişik usul ve kurallardan bağışık tutulduğu, bu nedenle idarelerin doğrudan temin yönteminde daha esnek hareket edebilecekleri, bu anlamda yaklaşık maliyet tespiti yaparak alım yapmanın da ihale usulleri kapsamında zorunlu tutulduğu, bu nedenle de doğrudan temin yönteminde böyle bir zorunluluktan söz edilemeyeceği" hususlarına dikkat çekmiştir.

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.5.1.1. maddesinde yer alan; "*Bu bentte (22/d) belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.*" şeklindeki düzenleme uyarınca, yaklaşık maliyet belirlenmeden alım onayının alınarak işlemlerin başlatılacağı ve piyasa fiyat araştırması sonucunda limit aşılırsa alımın doğrudan teminle yapılmaması ve diğer ihale usullerine başvurulması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Görüldüğü üzere; doğrudan temin kapsamı alımlarda, yaklaşık maliyetin hazırlanması zorunluluk olmamakla beraber, belli alımlar için yaklaşık maliyet hazırlanması gerekebilir.

İsteklilerin tekliflerini kendi iradeleriyle serbestçe ve gerçekçi vermelerini sağlamak, isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere için yaklaşık maliyet isteklilere açıklanamaz. Bu boyutuyla gizli tutulması gerektiğini söyleyebiliriz.

Anlatılanlar çerçevesinde netice itibarıyla;

- 4734 sayılı Kanun'da yer alan yaklaşık maliyet hesaplanmasına ilişkin kurallar ve bu kapsamdaki yaptırımların esas olarak ihale kapsamı alımlar için geçerli olduğunu,

- Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda esas olarak yaklaşık maliyet düzenlenmemekle birlikte, düzenlenmesinin gerekli olduğu durumlarda aynı şekilde gizlilik ilkesine dikkat edilmesi gerektiğini,

- Doğrudan temin için gizlilik ilkesinin sadece yaklaşık maliyetin geçerli olmadığını, doğrudan temin yönteminde yakın fonksiyonları bulunan piyasa fiyat araştırma süreci ve diğer alım dokümanları için de gizlilik ilkesinin geçerli olduğunu,

- Yasa'nın "Gizlilik ilkesi" ile birlikte 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin de süreçte göz önünde bulundurulması gerektiğini,

- Bunlarla birlikte, 4734 sayılı Yasa'nın "Temel ilkelerinin" bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, gizlilik ilkesi ile birlikte saydamlık, ihtiyaçların uygun koşullarda karşılanması ve kamuoyu denetimi gibi diğer ilkelerin de göz ardı edilmesi gerektiğini, gizlilik ilkesinin ölçüsüz kullanılmasının aynı zamanda rekabet ilkesine de zarar verebileceğini,

İfade edebiliriz.

13. Doğrudan temin yönteminde ihale komisyonu kurulması gerekir mi?

Özet: *Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale komisyonu kurulması zorunlu değildir. Komisyon kurulması durumunda 4734 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinde yer alan komisyonların kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların uygulanması zorunluluğu da bulunmamaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği'nde, idare ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususların idarelerin takdirinde olduğunun belirtilmesi nedeniyle, ihale yetkilisi isterse bir alım komisyonu kurabilir, istemezse kurmaz. İhale komisyonunun kurulması durumunda ise başkan ve üyelerin oy ve kararlarından sorumlu olduğunun bilinmesi gerekir.*

4734 sayılı Yasa'nın "İhale Komisyonu" başlıklı 6'ncı maddesi;

"İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır."

Hükmüne amirdir.

4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, sürecin önemli aşamalarından bir tanesini de ihale komisyonun kurulması hususu oluşturmaktadır. Keza ihale süreci ile ilgili tüm kararlar bu komisyon tarafından alınmakta olup, anılan komisyon yerine geçecek ve başka adlar

altında komisyon ya da komisyonlar kurulması mümkün değildir.

Ancak doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlarda ihale komisyonu konusundaki düzenlemeler farklı esaslara bağlanmıştır. Bu bağlamda, ihale kapsamı alımlar için genel bir bilgi verdikten sonra doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlarda ihale komisyonu kurulmasının gerekli olup olmadığı hususu açıklığa kavuşturulacaktır.

İhale komisyonları, ihale yetkilisinin onayıyla kurulmaktadır. 4734 sayılı Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde ise "İhale yetkilisi"; idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda harcama yetkilisi olarak da adlandırılan bu kişilere, örnek olarak bakanlıklardaki genel müdürler gösterilebilir.

İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.

İhale komisyonu başkan ve üyeleri çekimser oy kullanamazlar ve verdikleri oy ve kararlardan sorumludurlar. Bu nedenle, çoğunluk görüşüne katılmayanların karşı oylarını ve gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalamaları gerekmektedir. İhale komisyonunun eksiksiz toplanıp karar vermesi gerektiğinden, eksik üye ile ihale komisyon kararı alınamaz.

İhale yetkilisince, ihale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacaklarının da belirtilmesi gerekmektedir.

Belirtilen komisyonların üye sayısının ise, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az 5 (yani, 7 veya 9 kişilik de ihale komisyonları kurulabilir) kişiden oluşması gerekmekle birlikte, bahse konu beş kişiden en az dördünün idare personeli olması bir zorunluluktur.

Ancak ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması durumunda, Kanun kapsamdaki diğer idarelerden üye alınabilir. Tekrar altını çizmek gerekirse, ihale komisyonun üye sayısı ile kriter, asgari 5 kişi ve tek sayıda olmak kaydıyla, ihalenin niteliği göz önünde bulundurulmak şartıyla daha fazla sayıda kişinin de ihale yetkilisince komisyonda görevlendirilmesi mümkündür.

Bu süreçte önem arz eden diğer bir husus, ihale yetkilisinin ihale komisyonunda görev almaması gerektiği kuralıdır. Aynı paralelde, kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri, ihale komisyonlarına üye olamaz. Seçimle iş başına gelmiş kişiler de ihale komisyonuna üye olamaz.

İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacaklarının da belirtilmesi gerekmektedir.

Yani, ihale komisyonlarında, asil üyelerle birlikte, yedek üyelerin de başlangıçta, yani görevlendirme aşamasında belirlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, komisyon başkan ve üyelerinin her biri için yedek üye görevlendirilir. Yedek üyelerin, asıl üyelerin taşıması gereken özelliklere sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi bir zorunluluktur.

Öte yandan, söz konusu komisyonların eksiksiz toplanması gerekmekte olup, alınan kararların da çoğunlukla alınması gerekir. Karar sürecinde üyeler, çekimser kalamaz. Tüm üyelerin alınan kararı imzalaması gerekir. Herhangi bir nedenle, alınan karara katılmayan ve karşı oy kullanan üyenin, gerekçesini karara yazması ve altını imzalaması gerekmektedir.

Bu itibarla, ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

İhale komisyonunda çalışacak personelin en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması gerekmektedir. Bu uzmanlığın bir diploma veyahut bir unvana dayanmasına gerek yoktur. Muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel ihaleye çıkan idarenin bu biriminde çalışan veya bu görevleri yerine getiren bir personeli göstermektedir.

Örnek nitelikteki Kamu İhale Kurulu'na ait bir kararda da mikrobiyoloji uzmanının mali üye olarak komisyonda görev almasının mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekilmiştir.

İhale kapsamı alımlara ilişkin olarak yukarıdaki usul ve esaslara uyulması zorunluluk arz etmekle birlikte, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar için söz konusu düzenlemeler esas olarak bağlayıcılık içermemektedir.

Dolayısıyla, doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale komisyonu kurulması zorunlu değildir. Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.1. maddesinde bu hususa ilişkin olarak, "*Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca 4734 sayılı Kanun'un 22. maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır."* açıklaması yer almaktadır.

Ancak anılan Tebliğ'in 22.1.1.2. maddesinde ise, *"Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir."* açıklaması yer almakta olup, ihale yetkilisi isterse bir alım komisyonu kurabilmesi mümkündür.

Şayet alıma ilişkin olarak komisyon kurulması durumunda 4734 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinde yer alan komisyonların kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların uygulanması zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Ancak doğrudan temin yöntemiyle de olsa, komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Bu sorumluluğa aykırı fiillerin varlığı ise çeşitli yaptırımların uygulanmasını gündeme getirmektedir.

Kuşkusuz, ihale sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla, ihale komisyonları, teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri ilgililerden isteyebilir. İlgili kişi ve kurumların bu talepleri zaman kaybetmeden (ivedilikle) karşılaması gerekmektedir.

Doğrudan temin yöntemi farklı esaslara da bağlanmış olsa sağlıklı bir karar alma ve uygulama süreci açısından, söz konusu komisyonların eksiksiz toplanması gerekmektedir. Alınan kararların da çoğunlukla alınması gerekir. Karar sürecinde üyeler, çekimser kalamaz. Tüm üyelerin alınan kararı imzalaması gerekir. Herhangi bir nedenle, alınan karara katılmayan ve karşı oy kullanan üyenin, gerekçesini karara yazması ve altını imzalaması gerekmektedir.

Bu itibarla, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen bir alıma ilişkin olarak ihale yetkili tarafından kurulan adı ister alım komisyonu ister farklı bir adla olsun, alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanması gerekmektedir.

Yine bağlayıcı olmamakla birlikte, komisyonunda çalışacak personelin en az ikisinin alım konusu işin uzmanı olması yararlı olacaktır. Bahse konu uzmanlığın ise bir diploma veyahut bir unvana dayanmasına gerek bulunmamaktadır. Yani alım konusu hakkında diğer çalışanlara oranla daha fazla bilgi ve tecrübesi bulunan personele öncelik verilmesi uygun olacaktır.

Benzer şekilde, muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel ihaleye çıkan idarenin bu biriminde çalışan veya bu görevleri yerine getiren bir personeli olması süreçte yeterlidir.

Diğer yandan, ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz; keza ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

Görüldüğü üzere; doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlara ilişkin olarak ihale yetkilisinin geniş bir takdir ve yetki alanı bulunmaktadır. Bu çerçeve alım sürecine ilişkin olarak ihale komisyonu benzeri bir komisyon kurabileceği gibi hiç de kurmayabilir. Ancak işin niteliğine ve rakamsal tutar göz önüne alınarak komisyon kurulmasının bazı alımlar için yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Doğrudan temin yöntemi alımlar için ihale komisyonu kurulması noktasında ihale yetkilisinin takdir hakkının bulunması, komisyon üyelerinin serbest hareket edecekleri anlamına gelmemektedir. Diğer ihale türleri alımlar gibi uyulması gereken temel düzenlemelere aykırı davranılması, çeşitli yaptırımların uygulanmasına da neden olabilecektir.

Benzer şekilde, ihale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden

sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

Yine, aynı maddeye göre, Kanun'un 5'inci maddede belirtilen "Temel ilkelere" ve 62'nci (İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı) maddesinde belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yaptırım uygulanmaktadır.

13.1. Bir personelin resmi görevlendirmeye rağmen ihale (alım) komisyonu üyesi olmak istememesi mümkün müdür?

657 sayılı Yasa'nın istihdam şekillerine ilişkin 4'üncü maddesinde memur; *"Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır."* şeklinde tanımlamaya tabi tutulmuştur.

Aynı Yasa'nın "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11'nci maddesi ise;

"Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır."

Hükmüne amirdir.

Bu itibarla, 657 sayılı Yasa'nın yukarıdaki hükmü ışığında, kamu hukukunda yazılı olan kurallar gereğince, yazılı olarak yapılan bir görevlendirmeye rağmen, ilgili kamu personeli yasal bir gerekçe göstermeden ben bu görevi yapmıyorum diyerek görevden kaçınması mümkün değildir.

Dolayısıyla, konusu suç teşkil etmeyen görevleri 657 sayılı Yasa uyarınca ilgili personelin yerine getirmesi gerekir. Ancak ihale konusu işin teknik uzmanlık gerektirmesi gibi hukuki gerekçelere dayanılarak söz konusu yazılı görevlendirmeye gerekçeleri belirtilmek suretiyle itiraz edilebilir.

İtiraz kabul edilmediği veya bu görevlendirme iptal edilmediği müddetçe ihale komisyonunda görevlendirilen üyenin geçerli bir mazereti bulunmuyorsa çalışmalara katılması gerekmektedir. İhale üyesinin mazereti olmaksızın ihaleye katılmaması durumunda ilgili personel hakkında disiplin soruşturması açılma ihtimali de bulunmaktadır.

Ancak bu sorumluluk sadece ihaleye katılım sağlanıp sağlanmaması hususuyla sınırlı olmayıp, doğrudan temin yöntemiyle de olsa konusu suç teşkil eden fiil ve davranışların, ceza mevzuatı kapsamında soruşturulması her zaman söz konusu olabilmektedir.

Bunlarla birlikte, ihale komisyonunun eksiksiz olarak alım sürecini sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin de belirlenmesi gerekmektedir. Yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyelerin de mutlaka belirlenmesi gerekmektedir.

14. Doğrudan temin kapsamında ilan yapılması gerekli midir?

Özet: *İhale kapsamı alımlar açısından ilan yapılması istisnai durumlar hariç (pazarlık usulü 21-f) olmak üzere zorunluluk arz etmektedir. Kamu ihalelerinin ilan sürelerinin belirlendiği 4734 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesi dikkate alındığında, ihale ilan süreleri, her bir ihale türü için belirlenen yaklaşık maliyetin eşik değerler karşısındaki durumuna göre değişiklik göstermektedir. Buna karşın doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlarda ilan zorunluluğu bulunmamaktadır. Nitekim 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi, çok açık bir şekilde, doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda, ilan yapıp yapmama ve teminat alıp almama konusunu tamamen idarelerin takdirine bırakmış olup, idare isterse ilan verebilecek, ilanın yaralı olmadığına ve zaman kaybına neden olacağı düşünülüyorsa ilan vermeyecektir. Özel bir durum söz konusu olmadığı sürece, küçük tutarlı alımlar hariç olmak üzere alım kapsamında rekabet koşullarının oluşması adına ilan verilmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanmasındaki süreç ise bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir.

Anılan Yasa'nın "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinin ilk halinde, doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır.

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur. Bunların dışında, satın alma sürecinde ihale usulleri için öngörülen diğer kuralların uygulanmamasına ilişkin bir hüküm halen yürürlükte olan Kanun'da bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu nitelikteki genel kuralların dikkate alınması gerekmektedir.

Doğrudan temin kapsamı söz konusu ihtiyaçlar, doğaları gereği ihale açılarak temini mümkün

olmayan, işin doğası, piyasa koşulları ve çeşitli yasal düzenlemelerle idarelerin tercih hakkının ortadan kalktığı ihtiyaçlardır. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın doğrudan temin yöntemiyle karşılanması söz konusu değildir.

Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, doğrudan teminle yapılan alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir. Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.1. maddesinde bu hususa ilişkin olarak; "… *4734 sayılı Kanun'un 22. maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır."* açıklaması yer almaktadır.

İhale sürecinde yapılacak işlemler konusunda herhangi bir tereddüte yer verilmemesi bakımından, ihale ilanları standart formlar kullanılmak suretiyle yapılmaktadır. Bu standart formlarda, istekli olabileceklerin yapılacak ihalenin içeriği ile katılma şartları konusunda yeterli ve açık şekilde bilgilenmelerini sağlayacak hususlara yer verilmektedir.

İhalenin ilanı, ihale sürecinde istekliler ile idare arasındaki işlemleri resmi olarak başlatan ve ihalenin duyurulmasını sağlayan, ihale sürecinin temel aşamalarından birisi olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden ihale sürecinin daha sonraki aşamalarında herhangi bir aksaklığın önüne geçilebilmesi açısından ihalenin ilanı aşamasında mevzuatta öngörülen şekil, içerik ve yöntem kurallarına uymak büyük önem arz etmektedir.

4734 sayılı Yasa'nın "İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan" başlıklı 13'üncü maddesinde;

"Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;
1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,
2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,
3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,

Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar Türk Lirasına (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirasına) kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar Türk Lirasına (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirasına)* kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,*

2) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası) ile altmışmilyar Türk Lirası (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası)* arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası)* ile beşyüzmilyar Türk Lirası (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası)* arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,*

3) Yaklaşık maliyeti altmışmilyar Türk Lirasının (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirasının) üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüzmilyar Türk Lirasının (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,*

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin

* 20/01/2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01/02/2022 – 31/01/2023 dönemini kapsamaktadır.

* 20/01/2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01/02/2022 – 31/01/2023 dönemini kapsamaktadır.

edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir.
İdareler, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir.
....İlân edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.
İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.
İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine oniki gün eklenir."

Hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere; 4734 sayılı Kanun'un ihale ilanına ilişkin 13'üncü maddesinde süreçle ile ilgili iki önemli kavram yer almaktadır. Bunlardan ilki "yaklaşık maliyet" kavramı, diğeri ise "eşik değer" kavramıdır. İlan süreleri bu iki kavrama ve ihalenin türüne göre (mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri) değişmektedir.

İlan açısından önem arz eden kavramlardan ilki olan yaklaşık maliyet, 4734 sayılı Yasa'nın 9'uncu maddesi çerçevesinde ihale uygulama yönetmeliklerinde belirlenen esas ve usullere göre belirlenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Yasa'nın "Eşik değerler" başlıklı 8'inci maddesi ise;

"Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında

*üçyüzmilyar Türk Lirası. (İkimilyonikiyüzyirmibeşbinsekizyüzyirmidört Türk Lirası)**

*b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası. (Üçmilyonyediyüzdokuzbinyediyüzonyedi Türk Lirası)**

*c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası. (Seksenbirmilyonaltıyüzondörtbinüçyüzüç Türk Lirası)**

(Mülga son fıkra: 12/6/2002-4761/12 md.)"

Hükmüne amirdir.

Açıklandığı üzere, eşik değerler temel olarak Yasa'nın 8'inci maddesinde yer almaktadır. Ancak bu tutar her yıl değişkenlik göstermektedir. Şöyle ki; Yasa'nın 67'nci maddesi gereğince, ihale süreçleri için geçerli olan parasal limit ve eşik değerlerin Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından belirlenmektedir.

Zira anılan Kanun'un eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin bahse konu maddesi çerçevesinde, 2022 yılı için Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenmiş ve 20.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. İlan edilen bu parasal tutarlar (1 Şubat 2022-31 Ocak 2023) tarihleri arasında bir yıl süre ile geçerli olup, bu tutarların, 1 Şubattan sonra yapılan ihalelerde dikkate alınması gerekmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanması bağlamında, anılan Kanun'un 8'inci maddesi ile düzenlenen mezkûr değerler, ihale ilan süreleri ve kuralları gibi hususlarda yaklaşık maliyet esas alınarak kullanılan parasal limitleri temsil etmektedir.

Eşik değer dışında kalan ve Kanun'da yer alan diğer parasal limitler ise, ihalenin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için göz önünde bulundurulması gereken tutarları ifade etmektedir. Bu parasal limitler, belirli unsurlar esas alınarak hesaplanan bir değer olmayıp, uluslararası düzenlemeler çerçevesinde esasları Kanun'la belirlenen bir niteliğe sahiptir.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendine göre parasal sınırlar kapsamında harcama

* 26/01/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2021/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01/02/2021 – 31/01/2022 dönemini kapsamaktadır.

yapılması mümkündür. Diğer bentler için parasal sınır yoktur. Hatta Yasa'nın 22/d maddesi kapsamı temsil ve ağırlama giderleri için parasal sınır geçerli değildir.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda, Büyükşehir sınırları dahilinde geçerli olan parasal limit 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 218.395 TL olarak belirlenmiş olup, bu tutarın üzerindeki ihtiyaçların bahse konu madde kapsamda karşılanması mümkün değildir.

4734 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen eşik değerler, birçok ihale hükmünün ve ihalenin ilanı konusunda göz önünde bulundurulması gereken temel değerdir. Çünkü ihale ilanları eşik değerlerin altında veya üzerinde olması durumlarına göre ilan süreleri açısından değişkenlik gösterecektir. Söz konusu Tablonun;

4734 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca 2022 yılı Eşik Değerlere ait Tablo

Kanun Kapsamına Giren İdare Türleri	Alımın Türü	31.01.2022 tarihine kadar uygulanan eşik değerler (TL)	01.02.2022-31.01.2023 döneminde uygulanacak eşik değerler (TL)
Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler	Mal ve Hizmet alımlarında	2.225.824	4.004.034
Kanun kapsamındaki diğer idarelerin (genel ve katma bütçe dışındaki idarelerin)	Mal ve Hizmet alımlarında	3.709.717	6.673.409
Kanun kapsamındaki bütün idarelerin	Yapım İşlerinde	81.614.303	146.815.969

Şeklinde olduğunu görürüz.

Kamu ihalelerinin ilan sürelerinin belirlendiği 4734 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesi dikkate alındığında, ihale ilan süreleri, her bir ihale türü için belirlenen yaklaşık maliyetin eşik değerler karşısındaki durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Yukarıda yer aldığı üzere, ihale kapsamı alımlar için Kamu İhale Kanunu'nda ilan süreleri birçok değişkene bağlı olarak belirlenmiş olup, söz konusu ilanlar elektronik ortamda Kamu

İhale Bülteni'nde de yayınlanmaktadır.

Buna karşın, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlarda ilan zorunluluğu bulunmamaktadır. Nitekim 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi çok açık bir şekilde, doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda, ilan yapıp yapmama ve teminat alıp almama konusunu tamamen idarelerin takdirine bırakılmış olup, idare isterse ilan verebilecek, ilanın yararlı olmadığına ve zaman kaybına neden olacağı düşünülüyorsa ilan vermeyecektir.

İlan yapılan hallerde 4734 sayılı Kanun'un ilanın süresi, şekli ve içeriği konusunda getirdiği zorunluluk hükümlerine uyulmaksızın idarenin takdiri doğrultusunda işlem yapılması mümkündür.

Tekrar vurgulamak gerekirse, doğrudan temin kapsamında da olsa, ihale yetkilisince gerek görülmesi durumunda, idare, isteklinin alım sürecine hazırlık yapmak ve buna uygun davranmasını sağlamak amacıyla zorunlu olmasa bile ilan yapabilir.

Zira ilan, kamu ihalelerinde saydamlığın, eşit muamelenin, güvenirliğin, kamuoyu denetiminin sağlanması, kamu çıkarının gözetilmesi ve ihaleye katılacak olanların rekabetine olanak sağlanması açısından alım sürecine katkı sağlamaktadır. Böylelikle kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması söz konusu olabilmektedir.

Ayrıca, idare, ilan konusunda sadece ilanı basın yayın araçlarıyla değil, kurumun web sayfasına koymak ya da kurum bina girişine aşmak suretiyle de ilanın daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Bütün bu seçenekler ilanın daha çok kişi ulaşmasına ve dolayısıyla daha fazla katılımın sağlanmasına bağlı olarak daha üst düzeyde rekabetin sağlanmasına ortam hazırlayacaktır.

Son olarak gerek ihale kapsamı alımlarda gerekse doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlar da ilan yapılması durumunda alım dokümanlarına aykırı hususlara yer verilmeyeceğine dikkat edilmesi gerekir. Aksi yöndeki uygulamalarda ise çeşitli hukuki sorunların yaşanacağı açıktır.

15. Doğrudan temin yönteminde teminat alınması zorunlu mudur?

Özet: *Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, doğrudan teminle yapılan alımlarda teminat alınmasının zorunlu olmadığını ifade edebiliriz. Bu çerçevede, ilan yapılan hallerde 4734 sayılı Kanun'un ilanın süresi, şekli ve içeriği konusunda getirdiği zorunluluk hükümlerine uyulmaksızın idarenin takdiri doğrultusunda işlem yapılması mümkündür. Ancak işin ifasının belli bir süreye ihtiyaç gösterdiği ve bu nedenle de tarafların hak ve yükümlülüklerinin bir sözleşme kapsamında kayıt altına alındığı durumlarda, idarenin, yüklenicinin sözleşmeye uygun davranmasını sağlamak ve sözleşme hükümlerini belli ölçüde güvence altına almak amacıyla teminat almasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.*

4734 sayılı Kanun'un "Teminat olarak kabul edilecek değerler" başlıklı 34'üncü maddesi;

" Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz."

Hükmüne amirdir.

Yukarıda yer aldığı üzere, teminat olarak kabul edilebilecek değerler ekonomik ve mali gelişmeler dikkate alınarak belirlenmiş ve maddede teminatların teslim ve iade şartları düzenlenmiştir. Ayrıca, teminatlar taahhüdün ihale dokümanında yer alan hükümlere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere alındığından, bu konuda bir sorun yaşandığında teminatların gelir kaydedilebilmesi için haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 4734 sayılı Yasa'nın "Teminat mektupları" başlıklı 35'inci maddesi ise;

" Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez."

Şeklinde düzenlenmiştir.

Açıklandığı üzere, yasa maddesinde, teminat olarak kabul edilecek değerler arasında sayılan teminat mektuplarının farklı düzenlenmesini önlemek amacıyla; kapsam, şekil, limit ve sürelerin belirlenmesi konusunda esaslar öngörülmüştür.

Öncelikli olarak, doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, doğrudan teminle yapılan alımlarda teminat alınmasının zorunlu olmadığını ifade edebiliriz.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan

yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilebilmektedir.

Bahse konu hükümler uyarınca belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

İdarece doğrudan temin yöntemiyle karşılanacak ihtiyaçlara ilişkin olarak, belli bir süreyi kapsayan alımlarda şartname hazırlanması öngörülmüşse şartnamede, sözleşme imzalanması öngörülmüşse sözleşme tasarısında belirtilmek koşuluyla teminat alınması mümkündür.

Doğrudan temin yöntemi kapsamı alımlarda, alımın niteliği göz önünde bulundurularak belli bir süreyi kapsayan ve garantisi söz konusu olan mal alımlarında, aynı şekilde belli bir süreyi gerektiren hizmet alımlarında, yapım işlerinde teminat alınması idarenin takdirinde olmakla beraber, sözleşme konusu alıma ilişkin olarak ileride yaşanacak belirsizliklerin aşılması ve olası yaptırımların uygulanabilirliği açısından, sözleşme düzenlenerek teminat alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesinde, Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, teminat olarak kabul edilecek değerler üç bent hâlinde sayılmış olup, söz konusu değerleri;

"Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler" olarak sıralayabiliriz.

Teminatın hangi tutarda alınacağı ise, 4734 sayılı Kanun'un ilgili maddelerinde açıklanmıştır. Teminat alınmasının zorunlu olduğu söz konusu ihalelerin ihale kapsamı alımlar için geçerli olduğunu ifade edebiliriz.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi gereğince ihalelerde, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminatı alınması gerektiği öngörülmüştür. Belirlenen %3 oranı asgari oran olup, bu oranın üzerinde bir oran belirlenmesi de mümkündür.

Yine aynı Kanun'a göre kesin teminat alınması da söz konusu olabilmektedir. Zira Yasa'nın 43'üncü maddesi hükmü gereğince de sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında (belli hallerde yaklaşık maliyetin %9'u oranında) kesin teminat alınması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hususlar esas olarak ihale kapsamı alımlar için geçerli olan ve idarelerin uymak zorunlu olduğu temel ilkelerdir. Bu hususlar doğrudan temin kapsamı alımlar için geçerli değildir.

Doğrudan temin kapsamı ihtiyaçlar, doğaları gereği ihale açılarak temini mümkün olmayan, işin doğası, piyasa koşulları ve çeşitli yasal düzenlemelerle idarelerin tercih hakkının ortadan kalktığı ihtiyaçlardır. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın bu kapsamda karşılanması söz konusu değildir; doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir yöntemdir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde (22.1.1.1.);"… *4734 sayılı Kanun'un 22. maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır."* açıklaması yer almaktadır.

Anılan Tebliğde ayrıca; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenleme ile de sözleşme yapma konusunda idareler serbest bırakılmıştır.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinde belirtilen hususlara (sözleşmelerde bulunması zorunlu hususlar) uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması

mümkündür.

Ancak 4734 sayılı Yasa'nın 22/c maddesine göre yapılan alımlar ile alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin veyahut yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın yazılı bir sözleşmeye bağlanması zorunluluk arz etmektedir. Bu iki durum dışında doğrudan temin ile yapılacak alımlarda yazılı sözleşme düzenlenip düzenlenmemesi idarelerin takdirindedir.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda yazılı sözleşme düzenlendiği durumlarda Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılması zorunlu değildir. Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda düzenlenecek sözleşmeler Borçlar Kanunu ile belirlendiği üzere, emredici hukuk kurallarına, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ve konusunun objektif olarak imkânsız olmaması şartı ile idare tarafından istenildiği şekilde yapılabilir.

Anlatılanlar ışığında, doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, bu yöntemle yapılan alımlarda geçici ve kesin teminat alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak idare alımın niteliğini dikkate alarak teminata yönelik düzenleme yapabilir.

Alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi nedeniyle yazılı sözleşme yapılan durumlarda teminat alınması uygun olacaktır. Alınacak bu teminatın oranına da yine idare, karşılaşabileceği belirsizlik ve riskleri dikkate alarak kendisi karar verecektir.

Bu bağlamda, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, alımın yapıldığı yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için teminat alınabilir. Kesin teminat alınması halinde sözleşme düzenlemesi uygun olacaktır. Bu sözleşmede hangi durumlarda teminatın gelir kaydedileceğine yönelik düzenleme yapılması da ileride yaşanacak sorunların önlenmesi adına yararlı olacaktır.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi çok açık bir şekilde, doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda, ilan yapıp yapmama ve teminat alıp almama konusunu tamamen idarelerin takdirine bırakmıştır. İdareler, yaptıkları alımın özelliğine göre nasıl bir uygulama yapacaklarına kendileri karar vereceklerdir.

Bu çerçevede, ilan yapılan hallerde 4734 sayılı Kanun'un ilanın süresi, şekli ve içeriği konusunda getirdiği zorunluluk hükümlerine uyulmaksızın idarenin takdiri doğrultusunda işlem yapılması mümkündür.

İşin ifasının belli bir süreye ihtiyaç gösterdiği ve bu nedenle de tarafların hak ve yükümlülüklerinin bir sözleşme kapsamında hüküm altına alındığı durumlarda, idarenin, yüklenicinin sözleşmeye uygun davranmasını sağlamak ve sözleşme hükümlerini belli ölçüde güvence altına almak amacıyla teminat almasında yararlı olacağını tekrar belirtebiliriz.

Netice itibarıyla; doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlarda da temel amacın kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi olduğu dikkate alınarak, sağlıklı bir alım süreci ve buna bağlı olarak idare ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasını sağlamak ve aynı zamanda kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması amacı çerçevesinde, küçük tutarlı alımlar hariç olmak üzere, sözleşme yapılması ve teminat alınmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Bunlara birlikte, doğrudan temin kapsamı alımların niteliği dikkate alınarak, çok küçük tutarlı alımlar için teminat ve benzeri yükümlülüklerin çok katı belirlenmesinin, isteklilerin teklif vermek noktasında ilgisiz davranmasına neden olabileceği de süreçte göz önünde bulundurulmalıdır. Yani uygulamada teminat belirleme/belirlememe hususunda fayda maliyet hesaplamasının idarece iyi yapılması gerekmektedir.

16. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesindeki yeterlik şartlarına uyulur mu?

Özet: *Doğrudan temin bir ihale usulü değildir ve Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların, doğrudan temin sürecinde uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Kanun'un 10'uncu maddedeki yeterlik şartlarının aranılması esas itibarıyla zorunlu değildir. Dolayısıyla, doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılacak bir alımda, bahse konu yeterlik koşullarının alım süreci bakımından bir fayda sağlayıp sağlamayacağı ile bu konudaki mevzuat gereklilikleri dikkate alınarak idarece bir tercihte bulunulması gerekmektedir. İdarece gerekli görülmesi durumunda, yeterlik kriterleri konusunda farklı bir düzenleme yapılabilecektir. Ayrıca, ihale kapsamı alımlar için birçok yeterlik kriterine ilişkin belgeler EKAP'ta yer almaktadır. Buna karşın, mevcut durum itibarıyla, doğrudan temin yönteminde işlemler esas olarak EKAP üzerinden yürütülmemektedir ve EKAP kullanılması isteğe bağlıdır.*

4734 sayılı Kanun'un amaca ilişkin ilgili maddesi hükmü uyarınca, "kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerin" anılan Kanun kapsamına girdiği anlaşılmaktadır.

İdarenin kamu kaynağı kullanarak gerçekleştirdiği alımlar değişkenlik gösterebilir. Bir fotokopi makinası alınabileceği gibi, bir baraj yapımı da söz konusu olabilir. Her iki alıma da teklif verecek firmaların aynı düzeyde olmasa beklenemez. Baraj veya okul yapımı veya bir kampüsün yemek ihalesi gibi büyük ölçekli alımlar için kuşkusuz firmaların belli bir yetkinlikte olması gerekir. Sadece isteklinin bu yöndeki iradesi değil, aynı zamanda idarenin de hizmette aksaklık yaşanmaması için öngörülen alımın belirlenen koşullarda gerçekleşmesi için firmaların belli yeterlik düzeyine sahip olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede kamu idarelerinin gerçekleştirdiği alımlara ilişkin ihalelere katılabilmek için, ihale dokümanlarında belirtilen diğer şartların yanı sıra, 4734 sayılı Kanun'un ilgili maddesi ve ihale uygulama yönetmeliklerinde belirlenen ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanmasına yönelik birtakım belgelerin teklif aşamasında sunulması gerekebilir. Bu aşamada, alım türü ve ihale yöntemine bağlı olarak, yaklaşık maliyete göre, istenecek yeterlik belgeleri konusunda değişik uygulamalar olabilmektedir.

Bu hususlar genel olarak ihaleye katılımda yeterlik kuralları şeklinde ifade edilebilir. Söz konusu kural ve kriterler 4734 sayılı Yasa'nın "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı maddesinde düzenlenmekte olup, aşağıda söz konusu maddeye yer verilmektedir.

4734 sayılı Yasa'nın "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı 10'uncu maddesi;

" İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2)İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az %80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80'inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

f) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler.

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin

kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate alınır. Ancak, yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaz. Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirmeye Kurum yetkilidir. Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme belgeleri, belge sahipleri tarafından ve bunların bünyesinde bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılabilir. Bu belgelerin, şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi hâlinde yurt dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belge sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat vermesi zorunludur.

...

Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir."

Hükmüne amirdir.

Maddenin içeriğinde ayrıca ihale kapsamında gerçekleştirilen alımlara ilişkin olarak isteklilerin hangi durumlarda ihale dışı bırakılması gerektiğine yönelik hususlar da hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen yasa hükmünde açık bir şekilde görüldüğü üzere; söz konusu kriterler ihale kapsamı alımlar için öngörülmüştür. Dolayısıyla, kapsama giren alım türleri için bazı belgelerin

istekliler tarafından idarelere sunulması gerekmektedir. Bu bağlamda istenecek belgeleri, öncelikli olarak zorunlu olarak istenen belgeler ile yaklaşık maliyet ve eşik değer oranına göre istenmesi gereken belgeler şeklinde kategorik bir ayrıma tabi tutabiliriz.

Bu kapsamda alım şekline bağlı olarak, "Mesleki faaliyet belgesi" ile "Teklif vermeye yetkisine gösteren belgeleri" zorunlu olarak istenen belgeler kapsamında sayabiliriz. Buna karşın, alımın büyüklüğü dikkate alınarak, yaklaşık maliyet ve eşik değer oranına göre "İş deneyim belgesi, Mesleki ve teknik yeterlik belgeleri vb." belgeler de istenebilir.

Ancak yukarıda ifade edilen kriter ve şartlar ihale kapsamı alımlar için geçerli olup, doğrudan temin için söz konusu belge ve değerler esas olarak söz konusu değildir.

İhale kapsamı alımlar açısından özellikle teknik şartname önem arz etmekte olup, alınacak malın teknik kriterleri ve özelliklerinin, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, Kanun'un ilk halinde ihale usulleri olarak; "Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü, Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü" şeklinde dört ihale usulü sayılmasına rağmen, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik yapan 4964 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, doğrudan temin ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

"Doğrudan temin" adı verilen bu yöntemle yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 4734 sayılı Kanun'un 10'ncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Doğrudan teminde 4734 sayılı Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların uygulanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, doğrudan teminin dahil tüm alımlar için geçerli olan temel ilkeler ve idarelerce uyulması gereken diğer kuralların uygulanması gerekmektedir.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren alımlarda da idarelerin, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu

denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğunu yönelik Yasa'nın 5'inci maddesinde sayılan "Temel ilkelerin" referans alması gerekmektedir. Zira saydamlık, eşit muamele, güvenirlik gibi ilkesinin sadece ihale kapsamı alımlar için olduğunu söylemek hatalı bir bakış açısı olacaktır.

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4'üncü maddesinde, "Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" şeklinde tanımlanmıştır.

Bahse konu ihtiyaçlar, doğaları gereği hızlı bir şekilde karşılanması gereken, ihale kapsamı alım türleri gibi karmaşık düzenlemelerin uygulanmasına gerek olmayan ihtiyaçlardır. Örneğin, idarenin birkaç top kağıt ihtiyacı için ilan, iş deneyim belgesi gibi prosedürleri hayata geçirmek istemesi hem idareyi hem de istekliyi zora sokacaktır. Dolayısıyla bu tür alımların ihale türleri kapsamında karşılanmasını beklemek çok rasyonel bir yaklaşım olmayacaktır. Bu çerçevede, doğrudan teminin istisnai bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü doğrudan teminde gerçek anlamda rekabet sağlanmamaktadır.

İhale türleri kapsamında alımın karşılanmasının söz konusu olabileceği alımlar için doğrudan temine başvurulmaması gerekmektedir.

Ancak alım sürecinde doğrudan temin yöntemi de tercih edilse, idare alımın büyüklüğü ve niteliğini dikkate alarak bazı belge ve kriterler isteyebilir.

Bu çerçevede, doğrudan temin, ihtiyaçların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen hallerde idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek temin edilebildiği alım yöntemidir. Doğrudan temin yöntemi ile yapılacak alımlar Yasa'nın 22'nci maddesinde sayılmakta olup, bu alımların kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

Doğrudan temin yöntemi, ihale yöntemi için belirlenmiş olan ilan yapma, teminat alınması, ihale komisyonu kurma ve Kanun'da belirtilen yeterlik kriterleri gibi zorunluluklar aranmaksızın, ihale yetkililerince görevlendirilen kişi ya da kişilerce piyasada fiyat araştırması yapılarak kamu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir satın alma yöntemidir.

Doğrudan temin kapsamı ihtiyaçlar, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar olup, doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir alım yöntemidir.

Bütçe Kanunu'yla kendilerine ödenek tahsis edilen kamu idarelerinin, doğrudan temin yoluyla gereksinim duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için harcama yapması ancak mevzuatta öngörülen belirli yükümlülükleri yerine getirmeleri ile gerçekleşebilecektir.

Yukarıda ifade edildiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10'uncu maddesi; ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenlemekte olup, madde metninde yer aldığı üzere, söz konusu madde isteklilerde aranacak şartlara ilişkindir.

Ancak doğrudan temin de olsa ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve genel olarak sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Dolayısıyla, idarelerce yaygın olarak kullanılan Yasa'nın 22/d maddesi kapsamı alımlarda, isteklilerden teklif almak suretiyle değil, piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyacın karşılanması nedeniyle gerçek bir rekabetten söz edilemediğinden, Yasa'nın 10'uncu maddedeki yeterlik şartların aranılmasının zorunlu olmamasının alımın niteliğine uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Netice itibarıyla; bir ihale türü olmayan doğrudan temin yöntemiyle, idare ihtiyaçlarının karşılanmasının ancak mevzuatta öngörülen yükümlüklerin yerine getirilmesi ile mümkün olabileceğini, ancak çoğunda idarenin tercihlerinin belirleyici olduğunu, bu bağlamda, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen kamu alımlarında ilan yapılmaksızın, teminat istenmeksizin, sözleşme yapılması ve ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik şartlarının istenmesi zorunluluğu olmadan alımların gerçekleştirilebileceğini söyleyebiliriz.

17. Doğrudan temin kapsamı alımlarda 4734 sayılı Kanun'da yer alan eşik değer ve parasal sınırlar hangi anlama gelmektedir?

Özet: *Kamu İhale Mevzuatı kapsamındaki alımlar belli esaslara bağlanmış olup, bu kuralların hayata geçirilmesinde alımın niteliği ve büyüklüğü önem arz etmektedir. Zira parasal sınırlar altında kalan bir alım için daha az prosedür uygulanırken, yüksek tutarlı bir alım için daha karmaşık süreçler söz konusu olabilmektedir. Bu süreçte referans alınan (alınmak zorunda kalınan) eşik değer ve parasal sınırlar her yıl Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından belirlenmektedir. Doğrudan temin kapsamı alımlarda da (22-d) belirlenen bu rakamsal sınırlar esas alınmaktadır. Örneğin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda, Büyükşehir sınırları dahilinde geçerli olan parasal limit 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 218.395 TL olarak belirlenmiş olup, bu tutarın üzerindeki ihtiyaçların bahse konu madde kapsamda karşılanması mümkün değildir. Gerek görülmesi durumunda yapılan yaklaşık maliyet araştırma sonucuna göre ya da yapılacak piyasa fiyat araştırması neticesinde, bahse konu parasal limitlerin aşıldığının belirlenmesi durumunda, alımın doğrudan teminle yapılmaması ve ihale usulleri kapsamında ihtiyacın karşılanması gerekmektedir.*

Kamu alımları açısından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu temel düzenlemelerin başında gelmekte olup, söz konusu Kanun'a aykırılıklar ise ihalenin iptaline kadar varan hukuki sonuçlara neden olabilmektedir. Bu itibarla, bütçe kaynağını kullanılarak gerçekleştirilen alımlarda, bilinmesi gereken ve özellik arz eden teknik düzenlemeler bulunmaktadır.

Bahse konu düzenlemelerden bir tanesi de anılan Yasa'nın 67'nci maddesi gereğince, ihale süreçleri için geçerli olan parasal limit ve eşik değerlerin Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından belirlenmesidir. Zira anılan Kanun'un eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin bahse konu maddesi çerçevesinde, 2022 yılı için Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenmiş ve 20.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.

İlan edilen bu parasal tutarlar (1 Şubat 2022-31 Ocak 2023) tarihleri arasında bir yıl süre ile geçerli olup, bu tutarların, 1 Şubattan sonra yapılan ihalelerde yeni bir güncellemeye kadar dikkate alınması gerekmektedir.

Uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 67'nci maddesi ile 1/3/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 14'üncü maddesiyle 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 58'inci maddesine eklenen fıkra çerçevesinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı esas alınarak güncellenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanması bağlamında, anılan Kanun'un 8'inci maddesi ile düzenlenen mezkûr değerler, ihale ilan süreleri ve kuralları gibi hususlarda yaklaşık maliyet esas alınarak kullanılan parasal limitleri temsil etmektedir.

Eşik değer dışında kalan ve Kanun'da yer alan diğer parasal limitler ise ihalenin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için göz önünde bulundurulması gereken tutarları ifade etmektedir. Bu parasal limitler, belirli unsurlar esas alınarak hesaplanan bir değer olmayıp, uluslararası düzenlemeler çerçevesinde esasları Kanun'la belirlenen bir niteliğe sahiptir.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendine göre parasal sınırlar kapsamında harcama yapılması mümkündür. Diğer bentler için parasal sınır yoktur. Hatta 22/d maddesi kapsamı temsil ve ağırlama giderleri için parasal sınır geçerli değildir.

Yasa'nın 22'nci maddesinin "d bendi" kapsamına giren ihtiyaçlar yalnız mal alımlarından ibaret olmayıp, yapım işleri ve hizmet alımlarının da yöntemle gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak doğrudan temin kapsamında olsa bile alım türleri itibarıyla bazı prosedürlerde farklılıklar bulunmaktadır. Yaklaşık maliyet hesaplama ve hakediş ödemesi süreci gibi.

Örnek vermek gerekirse; Bir bakanlığa ait destek hizmetleri biriminin kendi birimi için yazıcı alması durumunda Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında bu alımın yapılması mümkün iken, bakanlığın tüm birimleri için çok sayıda yazıcı alması durumunda belirlenen parasal limitlerin aşılması halinde söz konusu ihtiyacın ihale usulleri kapsamında karşılanması zorunluluk arz etmektedir.

Ancak söz konusu ihtiyacın ihale usullerinden kaçınmak maksadıyla kısımlara bölünerek doğrudan temin kapsamında karşılanması halinde, Kanun'un 5'inci maddesinde belirtilen açıklık ve şeffaflık gibi temel ilkelere aykırılık söz konusu olacaktır. Buna karşın, idarelere ait

bilgisayar, fotokopi makinesi, asansör gibi kayıtlı demirbaşlar için periyodik bakımları için, 22/d bendindeki tutarı geçmemek şartıyla yıllık sözleşme yapılması da yasanın temel ilkelerine aykırılık anlamına gelmemektedir.

Söz konusu parasal tutarlar (Kanundaki diğer tutarlar gibi), Kanun'un 67'nci maddesi gereğince Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmektedir.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda, Büyükşehir sınırları dahilinde geçerli olan parasal limit 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 218.395 TL olarak belirlenmiş olup, bu tutarın üzerindeki ihtiyaçların bahse konu madde kapsamda karşılanması mümkün değildir.

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kanun'un 67'nci maddesi gereğince Kanun'da belirtilen eşik değerler ve parasal limitler her yıl 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenmesi gerekliliği nedeniyle, söz konusu tutarlar 2022 yılı için geçerli olmak üzere Kamu İhale Kurumunun 2022/1 sayılı Tebliği ile belirlenmiş ve 20.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4734 sayılı Kanun'un "Eşik değerler"e ilişkin 8'inci maddesine baktığımız zaman, söz konusu maddenin; *"Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:*

a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası. (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası)[*]

b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası. (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz Türk Lirası) [*]

c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası. (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası)[*]

(Mülga son fıkra: 12/6/2002-4761/12 md.)"

[*] Kamu İhale Kurumunun 2022/1 sayılı Tebliği ile 20/01/2012 tarihli ve 31725 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup 01.02.2022 – 31.01.2023 dönemini kapsamaktadır.

Hükmüne amir olduğu görülmektedir.

Bu çerçevede, (2022/1) sayılı Kamu İhale Tebliği ile belirlenen eşik değerleri tablo yardımıyla gösterecek olursak, bu rakamların;

4734 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca 2022 yılı Eşik Değerlere ait Tablo

Kanun Kapsamına Giren İdare Türleri	Alımın Türü	31.01.2022 tarihine kadar uygulanan eşik değerler (TL)	01.02.2022-31.01.2023 döneminde uygulanacak eşik değerler (TL)
Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler	Mal ve Hizmet alımlarında	2.225.824	4.004.034
Kanun kapsamındaki diğer idarelerin (genel ve katma bütçe dışındaki idarelerin)	Mal ve Hizmet alımlarında	3.709.717	6.673.409
Kanun kapsamındaki bütün idarelerin	Yapım İşlerinde	81.614.303	146.815.969

Şeklinde olduğunu görürüz.

Öte yandan, eşik değerlere benzer şekilde 2022 yılı için yine parasal değerlere ilişkin 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile belirlenen parasal limitleri, ilgili Kanun maddelerini de ortaya koyacak şekilde tablo halinde gösterecek olursak;

4734 sayılı Kanun'da yer alan 2022 yılı Parasal Değerlere ilişkin Tablo

İlgili Kanun Maddesi ve Açıklaması	**Önceki Parasal Limit (TL)** 31.01.2022 tarihine kadar uygulanan parasal limitler	**2022 için Parasal Limit (TL)** 01.02.2022-31.01.2023 döneminde uygulanacak parasal limitler
• İstisna maddesi (3-g)	18.619.202	33.494.082
• "İhale İlan Süreleri ve Kuralları" başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;		
-1 no.lu alt bendi	242.832	436.830
-2 no.lu alt bendi	485.689	873.705

-3 no.lu alt bendi	4.047.628	7.281.278
• "Pazarlık Usulü" başlıklı 21 inci maddenin; (f) bendinde	404.732	728.072
• "Doğrudan Temin" başlıklı 22 nci maddenin; (d) bendinde		
-Büyükşehir belediye sınırları dahilinde	121.405	218.395
-Diğer idareler için	40.443	72.752
• "Kamu İhale Kurumu" başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının (KİK Gelirleri)		
-1 no.lu bendi için (ihale sözleşme bedeli sınırı)	809.496	1.456.202
-2 no.lu alt bendi için (KİK'e yönelik itirazen şikâyet bedeline ilişkin yaklaşık maliyet aralıkları ve şikâyet bedelleri tutarları)	1.281.438	2.305.178
	7.682	13.819
	5.125.768	9.220.744
	15.373	27.654
	38.443.271	69.155.600
	23.060	41.482
	30.750	55.316
• "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62 nci maddenin (h) bendi için (iş deneyimi bulunmayan mimar ve mühendisler için dikkate alınacak iş deneyim tutarı)	449.259	808.172

Şeklinde olduğunu görmekteyiz.

Eşik değer ve parasal limitlerin ihale sürecine olan ilişkisini bir örnek yardımıyla ortaya konulabiliriz. Şöyle ki; bir hizmet alımına ilişkin ihale sürecinde, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan ihalelerde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenebilmesi zorunluluk değilken; yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, aynı belgenin istenilmesinin zorunlu olması eşik değer ve parasal limitlerin sürece etkisini ortaya koymaktadır.

Aynı şekilde, bir mal alımı veya yapım işinde de eşik değer ve parasal limitlere bağlı olarak

talep edilen belgeler ve bu belgelerin niteliği değişebilmektedir. Bu nedenle, ihale sürecinin doğru bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için ihale işlem ve süreçlerinin söz konusu eşik değer ve parasal limitlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, ihale sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yapılacak işlemlerde, eşik değer ve parasal limitlerin mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Keza söz konusu tutarlar, 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi ile 13 (ilan süreleri) ve 63'üncü maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanmasını doğrudan etkilemektedir.

Yukarıda yer verilen eşik değer ve parasal değerler gerek ihale kapsamı alımlar ve gerekse doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlarda mutlaka dikkate alınması gereken parasal tutarlardır. Söz konusu değerlerin dikkate alınmaması hatalı ve geçersiz noktasına varacak olumsuzluklara sebebiyet verebilir.

Bu itibarla, Yasa'nın 22/d maddesi kapsamı doğrudan teminler için büyükşehir sınırları için öngördüğü limit olan 218.395 .-TL tutarının aşılması durumunda bu bent kapsamında alım yapılması mümkün değildir. Yapılması durumunda bu davranış yaptırımı gerektirmektedir. Aynı şekilde 21/f kapsamı limit 2022 yılı için 728.072.-TL'dir. Bu tutarı aşan alımların da bu bent kapsamında yapılması mümkün değildir.

Söz konusu tutarlar, sadece alım türü açısından değil, ilan ve yeterlik gibi temel işlem adımları açısından da önemlilik arz etmektedir.

Doğrudan temin boyutuyla konuya baktığımızda, bilindiği gibi, doğrudan temin bir ihale usulü değildir ve Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların doğrudan temin sürecinde uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.5.1.1. bendinde "Bu bentte (22/d) belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir." şeklindeki düzenleme uyarınca, gerek görülmesi durumunda yapılan yaklaşık maliyet araştırma sonucuna göre ya da yapılacak piyasa fiyat araştırması sonucunda limit aşılırsa alımın doğrudan teminle yapılmaması ve diğer ihale usullerine başvurulması gerekmektedir.

Bu itibarla, idarelerce, Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında gerçekleştirilen alımlarda söz konusu parasal limitin göz önünde bulundurulmak koşuluyla, Kamu İhale Genel Tebliği'nin (22.1.1.2.); "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenlemesi çerçevesinde hareket edilmesi uygun olacaktır. Ancak sözleşme düzenlenmesini gerektiren istisnai durumların bulunduğunun da unutulmaması gerekir.

18. Doğrudan temin kapsamı alımlarda piyasa fiyat araştırması yapacak kişiler nasıl belirlenir?

Özet: *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde;"...ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından..." ifadesi yer almakta olup, bu ifadede görevlendirmenin şekli ile ilgili her hangi bir açıklama yer almamaktadır. Ancak, görevlendirilecek kişilerin alımdan sorumlu tutulabilmeleri için, görevlendirmenin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Görevlendirme ihale yetkilisince yapılmalıdır. Yazılı olur verme biçiminde yapılabileceği gibi, onay belgesinde belirtilmek sureti ile de yapılabilir. Her doğrudan temin için ayrı bir görevlendirme yapılabileceği gibi, ihtiyacın niteliği farklı görevlendirmeleri gerektirmiyorsa, sürekli olarak aynı kişiler de görevlendirilebilir. Dolayısıyla, ihtiyacın niteliği uzmanlık gerektiriyorsa, görevlendirilen kişilerde buna uygun nitelik aranmalıdır. Birden fazla kişi görevlendirildi ise, bu kişilerin koordineli çalışmalarını sağlamak amacıyla, içlerinden birinin başkan ya da koordinatör olarak görevlendirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak yapılacak görevlendirmelerde, görevlendirilen kişilerin alım konusunda bilgi sahibi olmasına özen gösterilmesi uygun olacaktır.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlara" ilişkin 4'üncü maddesi uyarınca *"Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul"* olarak ifade edilmiştir.

Aynı Kanun'un 22'nci maddesinin son fıkrasında ise; *"Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir"* denilmektedir.

Söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nin ilgili kısmında ise;

"22.1.1.1. Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu

bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

22.1.1.2. Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

22.1.1.3. Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

22.1.1.4. Diğer taraftan 22 nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir. Ancak doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, piyasa araştırması yapılması aşamasında bu hususun belirtilerek fiyat tekliflerinin alınması gerekmektedir."

Hususları yer almaktadır.

Yukarıda yer aldığı üzere, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

Bunların dışında, satın alma sürecinde ihale usulleri için öngörülen diğer düzenlemelerin uygulanmamasına ilişkin Kanun'da aksi yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yine Yasa'nın 22'nci maddesinin son fıkrası çerçevesinde, doğrudan temin yöntemi idareler için bir tercih olmakla birlikte maddenin piyasa fiyat araştırmasını içeren hükmü bir tercih değil

zorunluluktur.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin son bendinde ise; Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı; "Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda, alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı ifade eder." şeklinde tanımlara yer verilerek, harcama talimatı, onay belgesi ve piyasa fiyat araştırması tutanağının içeriği düzenlenmiştir.

Diğer bir ifadeyle, 22/d maddesi kapsamında, belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir. Piyasa fiyat araştırması tutanağının aslında harcama yetkilisinin onayı ile geçerlilik kazanacak bir tür alım kararı tutanağı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz.

Dolayısıyla bu şekilde temin edilecek ihtiyaçların, fiyatının gerçekçi ve hatta uygun olması gerekli olup, Yasa'nın 5'inci maddesi yer alan temel ilkeler çerçevesinde her türlü piyasa fiyat araştırmasının yapılması gerekmektedir. Çünkü doğrudan temin yönteminde, ihale usullerinde olduğu gibi yoğun bir katılımın varlığından söz edemeyiz.

Bu yöntemde rekabete ve katılıma açık bir alım süreci bulunmadığından, sağlıklı piyasa araştırması yapılmak suretiyle, idare ihtiyaçlarının en uygun şekilde karşılanması hedeflenmelidir. Bu şekildeki bir hareket tarzı ise, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına ortam hazırlayacaktır.

Doğrudan temin yönteminde ihtiyaçlar ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilir. Kamu İhale Mevzuatında piyasa araştırması yapacak kişi ya da kişilerin yazılı olarak görevlendirilmesine yönelik bir standart form bulunmamaktadır. Ancak görevlendirmenin yazılı olarak yapılması hukuki açıdan uygun olacaktır. Bu görevlendirme onay belgesine bir kayıt düşülmek suretiyle de yapılabilir.

Görevlendirme bizzat ihale yetkilisi/harcama yetkilisi tarafından ve yazılı olarak yapılmalıdır. Örneğin; ihale yetkilisi onay belgesinin imzalanması aşamasında yine onay belgesine söz konusu alımda görevlendirilen kişi veya kişileri belirleyerek yazabilecektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4'üncü maddesinde yazıldığı şekilde, *"İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini "* ifade etmektedir.

Kanun'da görevlendirmenin şekliyle ilgili bir zorunluluk hükmü öngörülmemekle birlikte, görevlendirilen kişilerin piyasa fiyat araştırması sürecinden doğrudan sorumlu oldukları dikkate alınarak görevlendirmenin yazılı olarak yapılması uygun olacaktır.

Kaldı ki 5018 sayılı Yasa uyarınca, idarelerin iç kontrole ilişkin görev ve sorumlulukları da dikkate alındığında, görevlendirmenin yazılı yapılması aslında bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz.

Genel bir görevlendirme yerine doğrudan temin konusu ihtiyacın niteliğine uygun biçimde bir görevlendirme yapılması daha uygun olacaktır. Dolayısıyla özellik arz eden alımlarda, görevlendirilecek kişi ya da kişilerin alım konusunda bilgi sahibi olmasına hatta varsa işin uzmanı olmasına özen gösterilmelidir.

Birden fazla kişinin görevlendirildiği durumlarda, bu kişilerin alım sürecinde belli tercihlerde bulunmaları ve belli kararları almaları zaman zaman söz konusu olduğundan, aralarında birinin başkan (ya da koordinatör vb.) olarak görevlendirilmesinin Kanun'un amacının gerçekleşmesi açısından daha uygun bir hareket tarzı olacağını düşünmekteyiz.

Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alım süreçlerinin, genel olarak rekabete açık bir süreç olmadığı hususu dikkate alındığında, görevlendirilen kişi veya kişilerin yapacakları piyasa araştırmasını gerçekçi verilere dayanarak yapması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından önem arz etmektedir.

Kamu alımları sisteminde idarenin sağlamaya çalıştığı en önemli sonuç uygun malın uygun zamanda ve uygun fiyatla alınmasıdır. Bu sonucun sağlanmasına ilişkin sorumluluk ise, tümüyle idare adına bu sürece katılan kamu görevlilerine aittir. Bu nedenle piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmaların belgeye dayalı olması gerekmektedir.

Yasa'nın 22/d maddesinde, doğrudan temini gerçekleştirecek kişi veya kişilerin

görevlendirilme şekliyle ilgili herhangi bir belirleme yapılmamasına rağmen, görevlendirmeyi ihale yetkilisinin bizzat yapması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

İhale yetkilisi (harcama yetkilisi), bir veya birden fazla kişiyi piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirebilir. Bu kapsamda sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler de piyasa fiyat araştırmasında görevlendirilebilir. Piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmalar somut ve dayanaklarıyla birlikte ispat edilebilir olmasına özen gösterilmelidir.

Ayrıca, piyasa fiyat araştırması sürecinde görev alanların, muayene kabul sürecinde veya ödeme emrine ilişkin işlemlerde görev almasına engel bir durum olmamakla birlikte, yeterli insan kaynağının bulunması durumunda görevler ayrılığı ilkesine de dikkat edilmelidir.

19. Doğrudan temin yöntemi alımlarda piyasa fiyat araştırma sürecinde yazılı teklif alınması zorunlu mudur?

Özet: *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde, piyasa fiyat araştırması yapılması öngörülmüş fakat piyasa fiyat araştırmasının nasıl yapılması gerektiğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Piyasa fiyatını araştırırken, belli sayıda ve belli yerlerden fiyat alınmasına yönelik ihale mevzuatımızda bir düzenleme yoktur. Bu tamamen sorumluluk altına giren görevlilerin seçimine bağlıdır. Doğrudan temin yönteminde idare, satıcılardan ıslak imzalı teklif alabilir. Bunun dışında, faks veya e-posta yoluyla ya da mağazaların fiyat kataloglarını dikkate alarak da fiyat araştırması yapabilir. Ayrıca, çeşitli on-line alışveriş sitelerinden de fiyat araştırması yapılması mümkündür. Ancak alım bedelini tespit için yapılan fiyat araştırmasının her ne şekilde yapılırsa yapılsın belgelendirilmesi şarttır. Bu nedenle piyasa fiyat araştırması kapsamında sözlü veya telefonla teklif alınmasının, cari hukuk sistemimiz açısından bazı riskleri bulunduğunu ifade edebiliriz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanması ve sonraki süreç ise bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4'üncü maddesinde, "Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" şeklinde tanımlanmıştır. Kanun tasarısında yer alan gerekçede ise, "…küçük ölçekli günlük ihtiyaçların karşılanması ile küçük bakım onarım işlerinin yaptırılmasında kolaylık sağlamak üzere ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin yöntemi

benimsenmiştir.” ifadesi yer almaktadır.

Doğrudan temin yönteminde ihtiyaçlar ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilir. Kamu ihale mevzuatında piyasa araştırması yapacak kişi ya da kişilerin yazılı olarak görevlendirilmesine yönelik bir standart form bulunmamaktadır. Ancak görevlendirmenin yazılı olarak yapılması idare hukukuna uygun olacağı gibi uygulamada ihtilafların önlenmesinde de fayda sağlayacaktır. Bu görevlendirme onay belgesine kayıt düşülmek suretiyle de yapılabilir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde piyasa fiyat araştırması tutanağı; “doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanak” olarak tanımlanmıştır. Piyasa fiyat araştırması tutanağı, piyasa fiyat araştırmasını yapan görevli/görevliler tarafından imzalanmalıdır.

İhale yetkilisi, bir veya birden fazla kişiyi piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirebilir. Bu kapsamda sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler de piyasa fiyat araştırmasında görevlendirilebilir. Piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmalar somut ve ispat edilebilir olmalıdır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinde, piyasa fiyat araştırması yapılmasını öngörmüş fakat piyasa fiyat araştırmasının nasıl yapılması gerektiğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Piyasa fiyat araştırmasında kaç kişiden teklif alınacağına ve bunların nasıl belgelendirileceğine ilişkin mevzuatta açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin eki piyasa fiyat araştırması tutanağının dipnotunda piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi/firma, yer sayısına harcama yetkilisinin karar vereceği ifade edilmiştir. Alınacak mal ve hizmet alımı ile yapım işinin özelliğine göre makul sayıda kaynaktan araştırma yapılması gerekmektedir. Uygulamada alım konusu işe bağlı olarak mümkün olması durumunda en az üç kişiden fiyat sorulması gerektiği noktasında yaygın bir teamülün oluştuğu görülmektedir.

Satıcılar tarafından fiyat tekliflerinin idareye kapalı zarf içerisinde verilmesi zorunlu değildir. Zira Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde, Teklif (öneri) tek taraflı bir hukuki işlemdir ve genel bir ifadeyle sözleşme yapma çağrısıdır. Teklifin kabulü ile sözleşmenin tamam olduğunu söyleyebiliriz.

Bu nedenle idare satıcılardan ıslak imzalı teklif almak dışında faks veya e-posta yoluyla fiyat alabileceği gibi mağazaların fiyat katalogları ile de fiyat araştırması yapabilecektir. Ayrıca on-line alışveriş sitelerinden de fiyat araştırması yapılabilecektir. Ancak alım bedelini tespit için yapılan fiyat araştırması, her ne surette yapılırsa yapılsın belgelendirilmesi şarttır. Bu nedenle piyasa fiyat araştırması kapsamında sözlü veya telefonla teklif alınmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Buna göre, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiler piyasada fiyat araştırması yapmak zorundadır. Ancak araştırması sırasında tespit edilen fiyatların mutlaka kapalı zarflar içinde yazılı teklif alınmak suretiyle tespit edilmesi gibi bir zorunluluk yoktur.

Yani fiyat araştırması yaparken Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan standart teklif mektuplarının kullanılması gibi bir zorunluluk yoktur.

Diğer taraftan, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin fiyatının resmî olarak belirlendiği durumlarda bahse konu rakamların, referans alınması mümkündür. Örneğin akaryakıt alımında belirlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ve ilan edilen akaryakıt fiyat listesi yeterli olacaktır. Benzer şekilde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen fiyatlar, ya da DMO tarafından sanal katalogdan ilan edilen fiyatların referans alınarak fiyat araştırması yapılması mümkündür.

On-line alışveriş sitelerinden doğrudan teminle alım yapılması hususunda yasal bir engel bulunmamakla birlikte, bu sitelerden doğrudan teminle alım yapılması pratikte mümkün olmayabilir. Zira bu sitelerden alım yapılması durumunda sözleşme yapılacağı için sözleşme bedeli üzerinden sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerekecek olup, bu verginin tahsil edilmesinde sıkıntılar yaşanabilecektir. Ayrıca bu şekilde yapılan bir alımda, ödeme sürecinde de çeşitli hukuki problemler yaşanabilir. Olayın mali mevzuatı hatta kambiyo mevzuatını ilgilendiren boyutu da bulunmaktadır.

5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuat kaynaklarında kamu görevlilerinin mali sorumlulukları ile

ilgili hükümler mevcut olduğundan piyasa fiyatının tespitine yönelik çalışmaların somut ve dayanakları ile birlikte kanıtlanabilir olması gerekir.

Piyasa fiyatını araştırırken, belli sayıda ve belli yerlerden fiyat alınmasına yönelik ihale mevzuatımızda bir düzenleme yoktur. Bu tamamen sorumluluk altına giren görevlilerin takdirindedir.

İç kontrol bağlamında da süreçlerin belgelendirilmesi gerekir. Harcama süreci açısından da sorumlulukların belirlenmesi anlamında belgelendirme esastır.

Doğrudan temin yönteminde, piyasa fiyat araştırmasında teklifler yazılı alınabileceği gibi, internet üzerinden fiyat araştırması yapılabilir veya sözlü olarak da alınabilir. Ancak yazılı olarak alınması cari hukuk sistemi açısından daha uygundur.

Bu bağlamda, fiyat araştırması kapsamında, tespit edilen fiyatlar görevlendirilen kişilerce kayıt altına alınmalıdır. Fiyat araştırması sırasında teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmasında da bir engel bulunmamaktadır. Aksine Kanun'da yer alan doğrudan temin tanımına daha uygundur.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde yer alan tanımdan, tutanağın sadece görevlilerce imzalanmasının yeterli olduğu anlaşılabilirse de, bu hükmün ihale (harcama) yetkililerinin 5018 sayılı Kanun kapsamındaki sorumlulukları ile birlikte değerlendirildiğinde bu bakış açısının doğru olmadığı düşünülmektedir.

Ancak görevlendirilecek kişilerin alımdan doğrudan sorumlu tutulabilmeleri için, görevlendirmenin yazılı olarak yapılması uygundur. Görevlendirme ihale yetkilisince yapılmalıdır. Yazılı olur verme biçiminde yapılabileceği gibi, onay belgesinde belirtilmek sureti ile de yapılabilir. Her doğrudan temin için ayrı görevlendirme yapılabileceği gibi, ihtiyacın niteliği farklı görevlendirmeleri gerektirmiyorsa, sürekli olarak aynı kişiler de görevlendirilebilir. İhtiyacın niteliği uzmanlık gerektiriyorsa, görevlendirilen kişilerde buna uygun nitelikler aranmalıdır.

5018 sayılı Yasa uyarınca, kamu kaynağı kullanılarak gerçekleştirilen alım sürecinde, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hedeflenmelidir. Bu

kapsamda idarelerce ihtiyaç duyulan malların en uygun fiyatla temin edilebilmesindeki başarı, sağlıklı piyasa fiyat araştırması ile doğru orantılıdır.

Piyasa fiyat araştırmasında belli sayıda veya belli yerlerden (Esnaf Odası gibi) yazılı fiyat sorulması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu husus fiyat araştırması yapan görevlilerinin takdirindedir. Ancak ticari hayatın gereklerine de uygun olarak, alımı yapılacak malın varsa yetkili satıcı veya bayilerine ait fiyatların da dikkat alınması uygun olacaktır. Bu kapsamda başvurulan ve fiyat alınan yerlere ait gerekli belgelendirmeler de yapılmalıdır.

Doğrudan temin kapsamında gerçekleşecek alım süreci rekabete açık bir süreç değildir. Bu nedenle görevli kişi veya kişilerce yapılacak piyasa araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi tespitlere dayanması kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından önem arz etmektedir.

4734 sayılı Kanun'un "piyasa fiyat araştırması yapılmasına" vurgu yapan düzenlemesinden, bu şekilde temin edilecek ihtiyacın gerçek piyasa rayiçlerine uygunluğunun sağlanmasının zorunlu olduğu, bunu sağlamaya yönelik olarak görevli kişi veya kişilerce gerekli her türlü piyasa fiyat araştırmasının çeşitli kaynaklardan yapılması gerektiği sonucunu çıkartmak mümkündür.

Kamu alımları sisteminde idarenin sağlamaya çalıştığı en önemli sonuç uygun malın uygun zamanda ve uygun fiyatla alınmasıdır. Bu nedenle piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmaların bu bakış açısına uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

Bunlarla birlikte, her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlarda, kabul sonrası sorumluluklar getirilmesi gibi uygulamaların tercih edildiği durumlarda da yazılı teklif alınması yararlı olduğu düşünülmektedir. Keza bahse konu hususların ispatı yazılı olması durumunda ancak netlik kazanabilecektir.

Dolayısıyla, geçerliliği yazılı kurala ihtiyaç gösteren uygulamaların tercih edildiği durumlarda, daha sonra doğabilecek ihtilafların önlenmesi açısından yazılı teklif alınması uygun olacaktır.

20. Doğrudan temin yönteminde internet üzerinden (elektronik ortamda) alım yapılabilir mi?

Özet: *Doğrudan temin yönteminde, güvenli elektronik imza ya da yazılı şekilde sunulan tekliflerin idarece koşulsuz kabul edilmesi gerekmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca da yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunmasının zorunlu olduğu, Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinlerin de yazılı şekil yerine geçeceği hususunun dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Bu itibarla, on-line alışveriş sitelerinden doğrudan teminle alım yapılması hususunda net bir engel bulunmamakla birlikte, bu sitelerden doğrudan teminle alım yapılması pratikte mümkün olmayabilir. Zira bu sitelerden alım yapılması durumunda sözleşmenin varlığı halinde sözleşme bedeli üzerinden damga vergisi tahsil edilmesi gerekecek olup, bu verginin tahsil edilmesinde sıkıntılar yaşanabilecektir. Ayrıca, mali mevzuat dikkate alındığında, bu şekilde yapılan bir alımda, tedarikçiye yapılacak ödemelerde de sıkıntılar yaşanabilmesi olanak dahilindedir. Aynı şekilde garanti sürecinde de sorunlar yaşanılabilir.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; "Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" şeklinde tanımlanmıştır.

Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin yönteminde, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu usulde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Doğrudan temin yönteminde ihtiyaçlar ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilir. Kamu İhale Mevzuatında piyasa

araştırması yapacak kişi ya da kişilerin yazılı olarak görevlendirilmesine yönelik bir standart form bulunmamaktadır. Ancak görevlendirmenin yazılı olarak yapılması idare hukukuna uygun olacağı gibi uygulamada ihtilafların önlenmesinde de fayda sağlayacaktır. Bu görevlendirme, onay belgesine bir kayıt düşülmek suretiyle de yapılabilir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde piyasa fiyat araştırması tutanağı; "*doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanak*" olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tanım ile harcama talimatı, onay belgesi ve piyasa fiyat araştırması tutanağının içeriği düzenlenmiştir. Piyasa fiyat araştırması tutanağı, piyasa fiyat araştırmasını yapan görevli/görevliler tarafından da imzalanmalıdır.

Piyasa fiyat araştırmasında kaç kişiden teklif alınacağına ve bunların nasıl belgelendirileceğine ilişkin mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin eki piyasa fiyat araştırması tutanağının dipnotunda piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi/firma ve yer sayısına harcama yetkilisinin karar vereceği ifade edilmiştir.

Satıcılar tarafından fiyat tekliflerinin idareye kapalı zarf içerisinde verilmesi zorunlu değildir. Teklif (öneri) tek taraflı bir hukuki işlemdir ve genel bir ifadeyle sözleşme yapma çağrısıdır. Teklifin kabulü ile sözleşme tamam olur.

Bu nedenle idare, satıcılardan ıslak imzalı teklif almak dışında faks veya e-posta yoluyla fiyat alabileceği gibi mağazaların fiyat katalogları ile de fiyat araştırması yapabilecektir. Ayrıca on-line alışveriş sitelerinden de fiyat araştırması yapılabilecektir. Ancak alım bedelini tespit için yapılan fiyat araştırması her ne surette yapılırsa yapılsın belgelendirilmesi şarttır. Bu nedenle piyasa fiyat araştırması kapsamında sözlü veya telefonla teklif alınmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

On-line alışveriş sitelerinden doğrudan teminle alım yapılması hususunda yasal bir engel bulunmamakla birlikte, bu sitelerden doğrudan teminle alım yapılması pratikte mümkün olmayabilir. Zira bu sitelerden alım yapılması ve sözleşme düzenlenmesi durumunda sözleşme bedeli üzerinden sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerekmekte olup, bu verginin tahsil

edilmesinde sıkıntılar yaşanabilecektir. Ayrıca idarenin bu şekilde yapılan bir alımda, tabi olduğu mali mevzuat dikkate alındığında, tedarikçiye ödeme yapmasında da prosedüre bağlı sıkıntılar yaşanabilecektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde, piyasa fiyat araştırması yapılması öngörülmüş fakat piyasa fiyat araştırmasının nasıl yapılması gerektiğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Buna göre, yazılı tekliflerin şekli belirlenmemiş olduğundan, bu kapsamda e-posta (e-mail) yoluyla da fiyat araştırması yapılabilir. Hatta mağazaların fiyat kataloglarından da fiyat araştırması yapılabilir. Ancak yazılı olarak alınması Türk Hukuk Sistemi açısından daha uygundur. Yani nihai alım sürecinde yazılı teklif ön plana çıkmalıdır.

Öte yandan, fiyat araştırması kapsamında, görevlendirilen kişiler Devlet Malzeme Ofisi (DMO) veya Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar tarafından belirlenen idari veri tabanları kullanılabileceği gibi, on-line sanal marketler, katalog, broşür gibi materyaller, faks ve e-posta kullanmak suretiyle de fiyat araştırması yapılabilir. Kanun bir sınır ve şekil öngörmemiştir. İhale usulü kapsamındaki araştırmalardan dahi yararlanabilir.

Ancak fiyat araştırması suretiyle tespit edilen fiyatlar görevlendirilen kişilerce mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, yasada yer alan tanım da dikkate alınarak fiyat araştırması sırasında teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmalıdır. Hatta bu yönde hareket tarzı alım yöntemin amacına da uygun olacaktır.

Görevlendirilen kişilerce gerekli olan her türlü piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı, gerçekçi ve kanıtlanabilir şekilde yapılması zorunludur. Dolayısıyla idare, sağlıklı ve gerçekçi piyasa fiyat araştırması yaparak, belli ölçüde rekabet ortamının sağlamak suretiyle en uygun koşullarda idare ihtiyaçları karşılanmasına ortam hazırlamalıdır.

Doğrudan temin yolu ile yapılan alımlarda, teklifler idareye geldikten sonra, teklifler bu kişilerin huzurunda açılır ve öncelikle teklif edilen malın uygunluğu, belgeler çerçevesinde incelenir. Söz konusu inceleme yapıldıktan sonra teklifler değerlendirilir.

Bu değerlendirme sırasında, ucuz olmakla birlikte tercih edilmeyen malın tercih edilmeme gerekçesi mutlaka piyasa fiyat araştırması tutanağında belirtilmelidir. Teknik şartname düzenlenmiş alımlarda teknik kişilerin piyasa fiyat araştırma sürecinde yer alması esastır. İdare

teklif mektubunda, yapmışsa ilanında, düzenlemişse şartnamesinde yer verilmesi şartı ile yazılı tekliflerden sonra gerek duyulması halinde hazırda bulunanlardan sözlü teklif verilmesini isteyebilir ve bu çerçevede satın alma süreci yazılı olarak karara bağlanabilir. Sözlü teklif verilmemesi durumunda yazılı tekliflerin nihai teklif olduğu açıktır.

Piyasa fiyatını araştırırken, belli yerlerden fiyat alınmasına yönelik ihale mevzuatımızda bir düzenleme yoktur. Bu tamamen sorumluluk altına giren görevlilerin takdirindedir. Uygulamada, piyasa fiyat araştırması kapsamında en az 3 istekliden fiyat alınması ve bu hususun belgelendirilmesi şeklindeki yerleşik anlayış mevcuttur.

Ancak ihale mevzuatımızda bu uygulamayı doğrular herhangi bir düzenlemede bulunmamaktadır. Ayrıca 3 sayısını asgari olarak kabul etmek gerekir, 5 veya 7 kişiden teklif alınmasına engel bir durum yoktur. Hatta daha çok rekabet sağlanmış olur.

Eğer arz piyasasında yeteri kadar satıcı varsa, mümkün olan en fazla sayıda satıcıdan teklif almak, buna karşılık arz piyasasında yeteri kadar satıcı olmayan ürünlerde mümkün olan sayıda satıcıdan teklif almak, daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bütün bu yaklaşımların yanında, mümkün olan hallerde, oluşacak fiyatın gerçek piyasa rayicini yansıtıp yansıtmadığına yönelik bir değerlendirme de yapılmalıdır.

Örneğin; akaryakıt alımında EPDK'nın ilan ettiği fiyatların ile yapım işi alımlarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen fiyatların, ilgili Esnaf Odaları tarafından belirlenen fiyatların araştırma sürecinde göz önünde bulundurulması ve bu fiyatlar ile teklif fiyatları arasındaki olası sapmaların nedeni irdelenmelidir. Kabul edilebilir bir açıklamanın olmadığı durumlarda, alım yapmaktan kaçınılmalıdır.

Kamu alımları sisteminde idarenin sağlamaya çalıştığı en önemli sonuç uygun malın uygun zamanda ve uygun fiyatla alınmasıdır. Bu sonucun sağlanmasına ilişkin sorumluluk ise, tümüyle, idare adına bu sürece katılan kamu görevlilerine aittir. Bu nedenle piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmaların dayanaklarıyla birlikte kanıtlanabilir olması gerekmektedir.

20.1. Türk Borçlar Kanunu ve ihale mevzuatı açısından elektronik ortamda alım süreci nasıl değerlendirilmelidir?

Elektronik ortamda alım ve alıma ilişkin teklif süreci 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Sözleşmenin kurulması"na yönelik düzenlemeleri dikkate alındığında, anılan Kanun'da;

1 nci maddesinde; Sözleşmenin, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacağı, irade açıklamasının, açık veya örtülü olabileceği,

2 nci maddesinde; Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla, taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılacağı,

4 üncü maddesinde; kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye yapılan öneri hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulacağı, telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılacağı,

5 inci maddesinde; kabul için süre belirlenmeksizin hazır olmayan bir kişiye yapılan öneri, zamanında ve usulüne uygun olarak gönderilmiş bir yanıtın ulaşmasının beklenebileceği ana kadar, önereni bağlayacağı,

6 ncı maddesinde; öneren, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek zorunda değilse, öneri uygun bir sürede reddedilmediği takdirde, sözleşmenin kurulmuş sayılacağı,

8 inci maddesinde; öneren, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse veya işin özelliğinden ya da durumun gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisinin kendisini bağlamayacağı, fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılacağı,

11 nci maddesinde; hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmelerin, kabulün gönderildiği andan başlayarak hüküm doğuracağı, açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşmenin, önerinin ulaşma anında başlayarak hüküm doğuracağı,

12 nci maddesinde; sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı olmadığı, Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şekli olduğu, öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmelerin hüküm doğurmayacağı,

13 üncü maddesinde; Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulmasının zorunlu olduğu, ancak, sözleşme metniyle

çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümlerin bu kuralın dışında olduğu, bu kuralın, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanacağı,

14 üncü maddesinde; yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunmasının zorunlu olduğu, kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçeceği,

17 nci maddesinde; Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşmenin tarafları bağlamayacağı, herhangi bir belirleme olmaksızın yazılı şekil kararlaştırılmışsa, yasal yazılı şekle ilişkin hükümlerin uygulanacağı,

20 nci maddesinde; genel işlem koşullarının, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri olduğu, bu koşulların, sözleşme metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şeklinin, nitelendirmede önem taşımadığı, aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmamasının, bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemeyeceği, genel işlem koşullarıyla ilgili hükümlerin, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanacağı,

27 nci maddesinde; Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüz olduğu, sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemeyeceği, ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamının kesin olarak hükümsüz olacağı,

Hususları yer almaktadır.

Bu bağlamda, 4734 ve 4735 sayılı Yasalar çerçevesinde, ihale süreçlerini genel olarak iki kategoriye ayırabileceğimizi, bu evrelerin sözleşme öncesi ve sonrası dönemler olduğunu, bu dönemlerden sözleşme öncesi dönemin 4734 sayılı Kanun kapsamına girdiği ve bu sürecin ihale onayının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar sürdüğünü, buna karşın sözleşme sonrası dönemin ise, 4735 sayılı Kanun kapsamı çerçevesinde, sözleşmenin imzalanmasından sonra başladığını ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin dönemi kapsadığını söyleyebiliriz. Söz

konusu dönem farklılıkları aynı zamanda, uygulanan mevzuat açısından da farklılık arz etmektedir.

4735 sayılı Kanun'un amacı, Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek olup, anılan Kanun, Kamu İhale Kanunu'na tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsamaktadır.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile de hükme bağlandığı üzere, Kanun kapsamında yapılan sözleşmelerin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği gibi, Kanun'un yorum ve uygulanmasında bu prensibin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bundan dolayıdır ki yine aynı Kanun hükmü gereğince, 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağının hükme bağlanması ve söz konusu Kanun'la da tarafların eşitliğinin ilke edinilmesi ve sözleşme hükümlerine aykırılığın da yaptırıma bağlanmasını, yapılan işlemlerde dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak ayrıca vurgulayabiliriz.

Bu çerçevede, idareye elektronik ortamda teklif sunun bir kişinin durumu anılan bilgiler çerçevesinde Borçlar Kanunu kapsamında ortaya koyup, sonrasında ise bahse konu durumun Borçlar Kanunu ve ihale mevzuatı açısından bağlantılarını açıklayabiliriz.

Yukarıda yer verilen Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olmadığı sürece sözleşmeler geçerli olup, sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulabilmektedir. Ancak ilgili kişi teklifinde teklifinin belli bir süre için geçerli olduğunu söylerse, bu sürenin sonunda teklifi geçerliliğini yitireceği için sorumluluktan kurtulacaktır. Yoksa önerisiyle bağlıdır. Dolayısıyla isteklinin piyasa fiyat araştırmasında vermiş olduğu teklif Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde kendini bağlamaktadır.

Hatta piyasa fiyat araştırması kapsamında idarenin, telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan önerinin, hazır olanlar arasında yapılmış

sayılmakta olup, aynı şekilde firma kataloglarında yer alan fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılacağının bilinmesi gerekir. Bu boyutuyla da yasada sayılan iletişim araçlarıyla verilen teklifler de geçerli sayılmaktadır.

Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmelerin, kabulün gönderildiği andan başlayarak hüküm doğuracağı, açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hüküm doğuracağının bilinmesi gerekir. Bu ise, posta yoluyla istekli tarafından verilen imzalı tekliflerin geçerli olacağı anlamına gelmektedir.

Sözleşmelerin geçerliliğinin, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı olmadığı, kanunda sözleşmeler için öngörülen şeklin, kural olarak geçerlilik şekli olduğu, öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmelerin hüküm doğurmayacağı hususu dikkate alındığında, bu kapsamda idarelerin tip sözleşmelere bağlı kalmadan serbestçe sözleşme düzenleyebileceğini söyleyebiliriz.

Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunmasının zorunlu olduğu, kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçeceğinden, istekli tarafından sunulan fiyat teklifinin bu bağlamda geçerli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, imzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunlu olup bu yönüyle de imzalı teklif, sunan kişiyi teklif bağlamaktadır.

Anlatılanlar ışığında, 4735 sayılı Kanun'un; bu Kanun'da hüküm bulunmayan durumlarda Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği yönündeki hükmü uyarınca, her ne kadar 4735 sayılı Kanun kapsamına ihale kapsamı sözleşmeler kapsamına girse de, doğrudan temin mevzuatı alımların da ihale mevzuatında düzenlenmesi ve ayrıca burada Borçlar Kanunu anlamında bir borç alacak ilişkisinin varlığından hareketle anılan Kanun hükmünün uygulanabileceği düşünülmektedir.

Diğer bir anlatımla, Borçlar Kanunu bağlamında, piyasa fiyat araştırması boyutuyla teklif alma sürecinde, bir anlamda öneri ve kabul gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Kanun'da yer aldığı şekliyle öneri ve kabul süreci tamamlanmakta ve sözleşme gerçekleşmektedir. Çünkü Kanun'a

göre, sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Kanun'da, sözlü şekil mevcut değildir; yazılı şekil esastır, ancak yazılı sözleşmelerin şekil şartı yoktur.

Dolayısıyla, isteklinin vermiş olduğu teklifin Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde kendisini bağladığı ve yasal süresi içerisinde teklifinden vazgeçtiğini idareye bildirmediği durumda teklifin geçerli olduğunu, teklif kapsamında geçerli olan taahhüdünü istekli yerine getirmezse anılan Kanun çerçevesinde idarenin zararını karşılamak zorunda olduğunu söyleyebiliriz.

Bunlarla birlikte, konunun sadece ihale mevzuatı ile sınırlı olmaması nedeniyle diğer mevzuat hükümleri de dikkate alındığında; Kamu İhale Mevzuatı, 5018 sayılı Kanun ve 6098 sayılı Kanun hükümleri ışığında;K

Elektronik ortamdaki fiyat tekliflerinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde isteklileri bağladığı, ancak Kamu İhale Mevzuatı ve 5018 sayılı Kanun olmak üzere diğer mevzuat hükümleri açısından ispat yükümlülüğü ve geçerliliği yazılı şekle bağlı olmasından dolayı tekliflerin imzalı olması gerektiği, ancak güvenli elektronik imza ile sunulan tekliflerin de geçerlilik arz ettiği (EKAP gibi) düşünülmektedir.

Bu bağlamda, anılan Kanun'un 14'üncü maddesi uyarınca, yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunmasının zorunlu olduğu, Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinlerin de yazılı şekil yerine geçeceği hususun dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Fiyat araştırması konusunda gerek Kanunda ve gerekse alt düzey mevzuatta herhangi bir sınırlama olmadığı için her türlü araştırma yapılabileceği, hatta yurtdışı fiyat verilerinden de yararlanılmasının mümkün olduğu, ancak her fiyat araştırmasının teklif olarak yorumlanmaması gerekmektedir. Bu itibarla, piyasa fiyat araştırması tutanağına esas olan ve bağlayıcılık içeren tekliflerin, yazılı (imzalı) veya güvenli elektronik imza kullanılmış şekilde almasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Kaldı ki doğrudan temin yöntemiyle de olsa mal, hizmet veya yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda sözleşme düzenlenmesinin zorunlu olduğu, böyle bir durumda sadece elektronik ortamda teklif alınmasının sözleşme düzenlenmesi ve imzalanması açısından da belirsizlikler taşıdığı, tahsili gereken damga vergisinin tahsil sürecini de bu durumun zora soktuğu, ayrıca idare takdirinde olan iş deneyim belgesi gibi alım açısından bir belgenin ibrazının istenildiği durumlarda, işlem akışı açısından sürecin belirsizlikleri barındırdığı değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla, istekli ile geçerli bir alım sürecinin Borçlar Kanunu açısından sözleşmenin, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacağı, irade açıklamasının, açık veya örtülü olabileceği hükmüne karşın, kamu hukukunun bir parçası olan ihale ve harcama mevzuatı açısından konu değerlendirildiğinde;

Güvenli elektronik imza ya da yazılı şekilde sunulan tekliflerin koşulsuz kabul edilmesi, bu bağlamda, anılan Kanun'un 14'üncü maddesi uyarınca, yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunmasının zorunlu olduğu, Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinlerin de yazılı şekil yerine geçeceği hususun dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Kuşkusuz yapılan değerlendirmeler mevcut koşullar için geçerli olup, değişen mevzuat koşulları ışığında, örneğin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımların da EKAP üzerinde yürütülmesi durumunda, buna ilişkin yeni düzenlemelere göre hareket edilmesi uygun olacaktır.

21. Doğrudan temin kapsamında ticaret odaları ve meslek odaları nezdinde araştırma yapılması zorunlu mudur?

Özet: *Doğrudan temin yönteminde ihtiyaçlar, ihale yetkilisince (harcama yetkilisince) görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilir. Piyasada fiyat araştırması yapılması ve araştırmaya ilişkin belgelerin araştırma tutanağına eklenmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilecektir. 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuat kaynaklarında kamu görevlilerinin mali sorumlulukları ile ilgili hükümler mevcut olduğundan piyasa fiyatının tespitine yönelik çalışmaların somut ve dayanakları ile birlikte kanıtlanabilir olması gerekir. Bu bağlamda, piyasa fiyat araştırmasında belli sayıda veya belli yerlerden (belediye, ticaret odası, esnaf odası gibi) yazılı fiyat sorulması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu husus fiyat araştırması yapan görevlilerinin takdirindedir. Dolayısıyla zorunluluk olmamakla birlikte, belediye, ticaret odaları ya da meslek odaları nezdinde piyasa fiyat araştırması yapılması durumunda, buralardan alınan rakamların alım sürecinde kullanılması mümkündür. İlave olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 10'ncu maddesinde yer aldığı üzere, yapım işleri kapsamında yaklaşık maliyetin hesaplanması sürecinde, tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususunun Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilmesi gerekmektedir.*

2003 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda, doğrudan temin bir ihale usulü olarak düzenlenmişti. Ancak 15.08.2003 tarihli ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi ile doğrudan temin, bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır. Kanun'da açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü bir ihale usulü olarak belirlenmişken, doğrudan temin bir ihale usulü olarak değil bir alım yöntemi olarak düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde doğrudan temin; *"Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul"* şeklinde tanımlanmıştır.

Doğrudan temin ile idarelerin birtakım ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylık sağlanması

amaçlanmış olup, söz konusu yöntemle yapılan alımlarda, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Kamu İhale Mevzuatında piyasa araştırması yapacak kişi ya da kişilerin yazılı olarak görevlendirilmesine yönelik bir standart form bulunmamaktadır. Ancak görevlendirmenin yazılı olarak yapılması idare hukukuna uygun olacağı gibi uygulamada ihtilafların önlenmesinde de fayda sağlayacaktır. Bu görevlendirme onay belgesine kayıt düşülmek suretiyle de yapılabilir.

Piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. Gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilecektir. Ancak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.5.1'inci maddesi uyarınca 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde piyasa fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesi çevresinde yapılması zorunludur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre yapılan mal ve hizmet alımlarında, Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formun hazırlanması gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin ilgili kısmında;

"22.1.1.4. Diğer taraftan 22 nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir..." hususu yer almaktadır.

İhale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiler piyasada fiyat araştırması yapmak zorundadır. Ancak araştırması sırasında tespit edilen fiyatların mutlaka kapalı zarflar içinde yazılı teklif

alınmak suretiyle tespit edilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Fiyat araştırması teklif almak demek değildir.

Yani, fiyat araştırması yaparken Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan standart teklif mektuplarının kullanılması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu hususa Kamu İhale Kurumu düzenlemelerinde de yer verilmiştir.

Diğer taraftan, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin fiyatının tarife ile belirlendiği durumlarda (akaryakıt alımı vb.) ayrıca bir fiyat araştırmasına gerek bulunmadığı açıktır. Örneğin, herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinden (veya bunların web sitesinden) temin edilecek fiyat listesi yeterli olabilecektir.

Piyasa fiyat araştırmasında kaç kişiden teklif alınacağına ve bunların nasıl belgelendirileceğine ilişkin mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki piyasa fiyat araştırması tutanağının (Örnek No: 2) dipnotunda bu husus, *"Piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi/firma, yer sayısına ihale yetkilisi karar verebilecektir."* şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda piyasa fiyatını yansıtan rayiçlerin bulunmasının yanı sıra bunların belgelendirilmesi de önem arz etmektedir.

Bu noktada kaç kaynaktan fiyat sorulması gerektiğine dair her durum için geçerli tek bir kriter söylemek mümkün olmamakla birlikte, alınacak mal ve hizmet alımı ile yapım işinin özelliğine göre makul sayıda kaynaktan araştırma yapılması gerekmektedir. Bu noktada, alımı yapılacak ihtiyacın arz piyasasının genişliği dikkate alınarak piyasa fiyat araştırması yapacak kişilerce bu hususta karar verilmelidir.

Bu konuda uygulamaya baktığımızda, alım konusu işe bağlı olarak mümkün olması durumunda en az 3 kişiden fiyat sorulması gerektiğine yönelik yaygın bir uygulamanın varlığını görmekteyiz. Söz konusu uygulamayı destekler nitelikte Oda Muamelat Yönetmeliği'nin "Rayiç fiyat tespit usulü" başlıklı 36'ncı maddesinde, *"Rayiç fiyatlar, rayiç fiyat tespiti istenilen mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden mümkünse belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya birbirine en yakın değeri dikkate alınarak tespit edilir. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, kaç işletmeden fiyat alındığı ayrıca belirtilir. Borsaya tabi maddelerin rayiç fiyatı, istenilen tarihte borsada tescil edilen fiyatlar dikkate alınarak belirlenir."* düzenlemesi yer almaktadır.

Fiyat araştırmasının önemiyle ilgili bir diğer husus, bu sürece katılan kamu görevlilerinin sorumlulukları ve yapılan işlemlerin uygunluğunun kanıtlanabilirliğiyle ilgilidir. Zira kamu alımları sisteminde idarenin sağlamaya çalıştığı en önemli hedef uygun malın uygun fiyatla alınmasıdır. Bu nedenle piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmaların somut ve hesap edilebilir olması gereklidir.

Piyasa fiyat araştırması kapsamında, belirli bir yerlerden (belediye, ticaret ve/veya sanayi odası gibi) yazılı fiyat sorulması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu husus fiyat araştırması yapan görevlilerinin takdirine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ancak yeterli piyasa araştırması yapıldığına yönelik belgelendirme açısından, yapılan çalışmaya ait başvurulan kaynakların piyasa fiyat araştırması tutanağına açık bir şekilde yazılması uygun olacaktır.

Bu nedenle, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin fiyatının resmî olarak ya da tarife ile belirlendiği durumlarda ayrıca bir fiyat araştırmasına gerek bulunmadığı açıktır. Örneğin akaryakıt alımında EPDK tarafından fiyatların belirlendiği durumda, temin edilecek ya da web sayfasında yer alan fiyat listesi listeler yeterli olacaktır. Ya da ilan edilen bu fiyatlar ile alıma konu teklif fiyatı arasında karşılaştırma yapılıp doğru fiyata ulaşmak uygun bir davranış olacaktır.

Piyasa fiyat araştırmasında teklifler yazılı alınabileceği gibi, internet üzerinden fiyat araştırması yapılabilir veya sözlü olarak da alınabilir. Ancak yazılı olarak alınması Türk Hukuk Sistemi açısından geçerlilik açısından daha uygundur.

İhale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiler piyasada fiyat araştırması yapmak zorundadır. Ancak araştırması sırasında tespit edilen fiyatların mutlaka kapalı zarflar içinde yazılı teklif alınmak suretiyle tespit edilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Fiyat araştırması teklif almak demek değildir.

Piyasa fiyat araştırmasında kaç kişiden teklif alınacağına ve bunların nasıl belgelendirileceğine ilişkin mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin eki piyasa fiyat araştırması tutanağının dipnotunda piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi/firma, yer sayısına harcama yetkilisinin karar vereceği ifade edilmiştir. Alınacak mal ve hizmet alımı ile yapım işinin özelliğine göre makul sayıda kaynaktan (yetkili satıcılardan, üreticilerden, sanayi odalarından vb.) araştırma yapılması

gerekmektedir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinde Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı; Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaralı tutanağı ifade etmekle birlikte, uygulamada, piyasa fiyat araştırması kapsamında en az 3 istekliden fiyat alınması ve bu hususun belgelendirilmesi şeklindeki yerleşik anlayış mevcuttur.

Bu anlayışa göre, görevlendirilen kişilerce gerekli olan her türlü piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve kanıtlanabilir şekilde yapılması zorunludur. İhale usullerine göre yapılan alımlarda fiyat, isteklilerin verdiği tekliflere göre belirlenirken, doğrudan teminde idare tarafından yaptırılan piyasa fiyat araştırması ile belirlenmektedir. Dolayısı ile idarenin, sağlıklı ve gerçekçi piyasa fiyat araştırması yaparak, en uygun fiyatla ihtiyacını karşılaması noktasında titiz davranması gerekmektedir.

Nitekim 5018 sayılı Yasa'nın muhtelif maddelerinde kamu görevlilerinin sorumlulukları ile ilgili hükümler mevcuttur. Bu nedenle piyasa fiyatının tespitine yönelik çalışmaların somut ve kanıtlanabilir olması gerekir. Piyasa fiyatını araştırırken, belli sayıda ve belli yerlerden fiyat alınmasına yönelik rakamsal bir sınır ihale mevzuatımızda yoktur. Bu tamamen sorumluluk altına giren görevlilerin takdirindedir.

Eğer arz piyasasında yeteri kadar satıcı varsa, mümkün olan en fazla sayıda satıcıdan teklif almak, buna karşılık arz piyasasında yeteri kadar satıcı olmayan ürünlerde mümkün olan sayıda satıcıdan teklif almak, daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ancak asgari üç sayısına ilişkin teamül de göz ardı edilmemelidir.

Bunlarla birlikte, mümkün olan hallerde, oluşacak fiyatın gerçek piyasa rayicini yansıtıp yansıtmadığının tahkiki de yapılmalıdır.

Doğrudan temin yolu ile yapılan alımlarda, teklifler idareye geldikten sonra, teklifler bu kişilerin huzurunda açılır ve öncelikle teklif edilen malın uygunluğu, belgeler çerçevesinde incelenir. Söz konusu inceleme yapıldıktan sonra teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme

sırasında, ucuz olmakla birlikte tercih edilmeyen malın tercih edilmeme gerekçesi mutlaka piyasa fiyat araştırması tutanağında belirtilmelidir.

Netice itibarıyla; piyasa fiyatı araştırma sürecinde, belli yerlerden dolayısıyla meslek örgütlerinden de fiyat alınmasına yönelik ihale mevzuatımızda açık bir düzenleme yoktur. Bu husus, bu konuda görevlendirilenlerin tercihine bağlıdır. Uygulamada, piyasa fiyat araştırması kapsamında en az 3 istekliden fiyat alınması ve bu hususun belgelendirilmesi şeklindeki yerleşik anlayış mevcuttur. Ancak, ihale mevzuatımızda bu uygulamayı doğrular herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca 3 sayısını asgari olarak kabul etmek gerekir. Zira 5 veya 7 kişiden teklif alınmasına engel bir durum yoktur. Hatta daha çok rekabet sağlanmış olacağı için yasanın amacına daha uygun bir hareket tarzı olduğunu ifade edebiliriz.

22. Doğrudan temin kapsamı alımlarda piyasa fiyat araştırması ihale yetkilisince onaylanmalı mıdır?

Özet: *4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi kapsamında, doğrudan temin yönteminde, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilmektedir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinde ise Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı; "Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda, alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır. Bu nedenle piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmaların gerçekçi fiyat tespitini hedeflemeye dönük olması gerekmektedir. Doğrudan temini gerçekleştirecek kişi veya kişilerin ihale yetkilisince bizzat görevlendirilmesi gerekmektedir. Piyasa fiyat araştırması tutanağı, piyasa fiyat araştırmasını yapan görevli/görevliler tarafından imzalanmalıdır. Piyasa fiyat araştırması tutanağının altına İhale Yetkilisi tarafından uygundur şerhi konulması zorunlu olmamakla birlikte, konulması harcama yetkilisinin yapılan araştırmayı uygun bulduğunun belirtmesi bakımından yararlı olacaktır. Zira ihale yetkililerinin 5018 sayılı Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile birlikte konu değerlendirildiğinde, piyasa fiyat araştırması neticesinde görüşünün alınmasının, ikinci bir Onay olarak yorumlanmaması gerekir. Bu itibarla, mevzuatta açık bir zorunluluk olarak düzenlememekle birlikte, ihale yetkilisinin 5018 sayılı Yasa karşısındaki durumu dikkate alındığında, piyasa fiyat araştırma sonucuna ilişkin onayının (olurunun, görüşünün) sözlü ya da yazılı alınmasının anılan Yasa'nın ruhuna aykırı bir durum oluşturmayacağı düşünülmektedir.*

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin son fıkrasında; "Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir" denilmektedir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin son bendinde ise Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı; "Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat

araştırması sonucunda, alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

İhale yetkilisi, bir veya birden fazla kişiyi piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirebilir. Bu kapsamda sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler de piyasa fiyat araştırmasında görevlendirilebilir. Piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmalar dayanaklarıyla birlikte kanıtlanabilir olmalıdır. Piyasa fiyat araştırması ile ilgili görevlendirilen kişilerin muayene ve kabul sürecinde görev almalarında bir engel yoktur.

Görevlendirme ihale yetkilisince yapılmalıdır. Yazılı olur verme biçiminde yapılabileceği gibi, onay belgesinde belirtilmek sureti ile de yapılabilir. Her doğrudan temin için ayrı görevlendirme yapılabileceği gibi, ihtiyacın niteliği farklı görevlendirmeler gerektirmiyorsa, sürekli olarak aynı kişiler de görevlendirilebilir. İhtiyacın niteliği uzmanlık gerektiriyorsa, görevlendirilen kişilerde de buna uygun nitelikler aranmalıdır. İçlerinden birinin başkan olarak görevlendirilmesi uygundur ama zorunlu değildir.

Kamu İhale Mevzuatında piyasa araştırması yapacak kişi ya da kişilerin yazılı olarak görevlendirilmesine yönelik bir standart form bulunmamaktadır. Ancak görevlendirmenin yazılı olarak yapılması idare hukukuna uygun olacağı gibi uygulamada ihtilafların önlenmesinde de fayda sağlayacaktır. Bu görevlendirme onay belgesine bir kayıt düşülmek suretiyle de yapılabilir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde piyasa fiyat araştırması tutanağına ilişkin bahse konu tanım ışığında, piyasa fiyat araştırması tutanağı, piyasa fiyat araştırmasını yapan görevli/görevliler tarafından imzalanmalıdır. Çünkü MYHBY'nin 4'üncü maddesinde; "…söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaralı tutanağı,… ifade eder" düzenlemesi yer almaktadır.

İdare, ihtiyacın gerçek piyasa rayiçlerine uygun bir şekilde temin edilmesini sağlamak amacıyla, gerçekçi piyasa fiyat araştırması yaparak, piyasa fiyatlarını yansıtmayan verileri değerlendirme dışı bırakmalıdır.

Kanun'da fiyat araştırmasının şekil, yöntem ve esaslarıyla ilgili herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Konuya ilişkin olarak 22'nci maddenin son fıkrasında, maddenin farklı

durumları düzenleyen bütün bentleri için geçerli olmak üzere;"....ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir" denilmek suretiyle, bu şekilde temin edilecek ihtiyacın gerçek piyasa rayiçlerine uygunluğunun sağlanmasının hedeflenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Kaldı ki Kanun'un 22'nci maddesi uyarınca, piyasada fiyat araştırması yapılması bir tercih değil aynı zamanda bir zorunluluktur diyebiliriz.

Doğrudan temin yolu ile yapılan alımlarda, teklifler idareye geldikten sonra, piyasa fiyat araştırma sürecinde birden fazla görevli bulunuyorsa, teklifler bu kişilerin huzurunda açılır ve öncelikle teklif edilen malın uygunluğu, belgeler çerçevesinde incelenir. Söz konusu inceleme yapıldıktan sonra teklifler değerlendirilir.

Yapılan bu değerlendirme sırasında, ucuz olmakla birlikte tercih edilmeyen malın tercih edilmeme gerekçesi mutlaka piyasa fiyat araştırma tutanağında belirtilmelidir. Teknik şartname düzenlenmiş alımlarda teknik kişilerin piyasa fiyat araştırma sürecinde yer alması esastır. İdare teklif mektubunda ve/veya yapmışsa ilanında, düzenlemişse şartnamesinde belirtmesi koşulu ile yazılı tekliflerle yetinmemesi halinde hazırda bulunanlardan sözlü teklif vermelerini ister ve bu çerçevede satın alma süreci karara bağlanır. Sözlü teklif verilmemişse, aksi kararlaştırılmadıkça yazılı teklifi son teklif olarak kabul edilir.

Doğrudan temin yöntemiyle bağlantılı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde yer alan Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı; doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin ekindeki 2 örnek numaralı tutanaktır. Piyasa fiyat araştırması tutanağı, piyasa fiyat araştırmasını yapan görevli/görevliler tarafından imzalanmalıdır.

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı da gösterilir. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili uygulama yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir.

Görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından "Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı" düzenlenir. Piyasa fiyat araştırma tutanağının altına ihale yetkilisi tarafından uygundur şerhi konulması zorunlu olmamakla birlikte, konulması harcama yetkilisini yapılan araştırmayı uygun bulduğunun belirtilmesi bakımından yararlı olacaktır.

Ayrıca, fiyatın harcama yetkilisi tarafından onaylanması ikinci bir Onay olarak değerlendirilmemelidir. Aksi durumda, piyasa fiyat araştırma sürecinde karar verici olan ihale yetkilisi yerine, görevlendirdiği kişi ya da kişilerin karar alma sürecinde ön plana çıkmasına ortam hazırlanmış olacaktır.

Kaldı ki Sayıştaya karşı bizzat kendisi sorumlu olan bir ihale yetkilisi, doğrudan teminle yapılan bir alımın bedelini ve firma tekliflerini, ancak ödeme emri belgesini imzalama aşamasında görebilecek, böyle bir durumda ise, teslim ve muayene-kabul işlemleri tamamlanmış olduğundan sürece müdahalesi sınırlı olacaktır.

Bu itibarla, her ne kadar piyasa fiyat araştırma tutanağının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasına gerek olmadığı şeklinde yaklaşımlar olsa da ihale yetkililerinin, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile birlikte konu değerlendirildiğinde, piyasa fiyat araştırması neticesinde görüşünün alınması ikinci bir onay olarak değerlendirilmemelidir.

4734 sayılı Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde "İhale yetkilisi"; idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak belirlenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesi hükmü uyarınca, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların yetkili kılınmış mercilere hesap vermeleri zorunludur.

Aynı Kanun'un 3'üncü maddesinin (k) bendinde, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim harcama birimi olarak tanımlanmıştır. Kanun'un 31'inci maddesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu ifade edilmiş, 32'nci maddesinde ise; bütçeden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin, harcama talimatı vermesine bağlanmış, harcama talimatlarında da hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü

ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilerin yer alacağı, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken işlemlerden harcama yetkililerinin sorumlu oldukları belirtilmiştir. 5018 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesinde de giderin gerçekleştirilmesinin, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesi ile tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

5018 sayılı Kanun'da, giderin yapılmasından ödeme aşamasına kadar tüm işlemlerin harcama yetkilisinin gözetim ve denetimi altında, onun emir ve talimatı ile yürütülmesi öngörüldüğünden, sorumluluk konusunda da harcama yetkilisi ön plana çıkmaktadır. Kanun'da harcama yetkilisinin, bütçeyle ödenek tahsis edilen her harcama biriminin en üst yöneticisi olarak tanımlanması, bu durum idari açıdan üst yöneticilere; hukuka uygunluk açısından da yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle sorumlu olduğunu göstermektedir.

Bu itibarla, bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanun'da öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama/ihale yetkilisinin, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumlu olduğu dikkate alındığında, piyasa fiyat araştırması noktasında görüşünün alınması belirtilen durumlar nedeniyle makul bir hareket tarzıdır.

Dolayısıyla, ihale yetkilisinin 5018 sayılı Yasa karşısındaki durumu dikkate alındığında, piyasa fiyat araştırma sonucuna ilişkin onayının alınmasının anılan Yasa'nın ruhuna aykırı bir durum oluşturmayacağı düşünülmektedir.

23. Doğrudan temin yönteminde teklif alınacak kişi ya da firma sayısı kaç olmalıdır?

Özet: *Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, piyasa fiyat araştırması sürecinde kaç kişiden teklif alınacağına ve bunların nasıl belgelendirileceğine ilişkin mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin eki piyasa fiyat araştırması tutanağının dipnotunda piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi/firma sayısına harcama yetkilisinin karar vereceği vurgulanmıştır. Alınacak mal ve hizmet alımı ile yapım işinin özelliğine göre makul sayıda kaynaktan araştırma yapılması gerekmekle birlikte, uygulamada mümkün olması durumunda en az üç kişiden fiyat sorulması gerektiği noktasında bir teamülün oluştuğu görülmektedir. Ancak üç sayısı asgari olarak kabul edilmeli, bu sayının üzerindeki tekliflerin varlığı, sağlıklı fiyat oluşuma katkı olarak yorumlanmalıdır. Dolayısıyla, kaç kişi ya da firmadan fiyat sorulması gerektiğine dair mevzuatta açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, idarenin duyduğu ihtiyacın niteliği, miktarı ve aciliyeti gibi kriterler göz önünde bulundurularak hareket edilmesi ve asgari bir rekabet açısından 3 teklif sayısına özen gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak bu sayıdan az teklif alınması noktasında son sözün, alımı yapılacak ihtiyacın arz piyasasının genişliğini dikkate alarak, piyasa fiyat araştırması yapacak kişiler ve bu kişileri görevlendiren ve karar verme konumunda bulunan ihale yetkilisinin görev ve sorumluluğunda olduğunu söyleyebiliriz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu olup, Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca anılan Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmış ve bir alım yöntemi olarak 4734 sayılı Yasa'da yer almaya devam etmiştir.

Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları öncelikli olarak ihale usulleri kapsamında ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan,

teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi şeklinde doğrudan temin kapsamı alımları özetleyebiliriz.

Doğrudan temin yönteminde ihtiyaçlar ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmekle birlikte, Kamu İhale Mevzuatında piyasa araştırması yapacak kişi ya da kişilerin yazılı olarak görevlendirilmesine yönelik bir standart form bulunmamaktadır. Ancak görevlendirmenin yazılı olarak yapılması uygulamada yaşanacak problemlerin önlenmesi açısından faydalı olacaktır.

Görevlendirme harcama yetkilisince yapılmalıdır. Yazılı olur verme biçiminde yapılabileceği gibi, onay belgesinde belirtilmek sureti ile de yapılabilir. Her doğrudan temin için ayrı görevlendirme yapılabileceği gibi, ihtiyacın niteliği farklı görevlendirmeler gerektirmiyorsa, sürekli olarak aynı kişiler de görevlendirilebilir. İhtiyacın niteliği uzmanlık gerektiriyorsa, görevlendirilen kişilerde de buna uygun nitelik aranmalıdır. Birden fazla görevliden birinin başkan olarak görevlendirilmesinin de bir sakınca yoktur.

Piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde piyasa fiyat araştırması tutanağı; "*doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanak*" olarak tanımlanmıştır. Piyasa fiyat araştırması tutanağı, piyasa fiyat araştırmasını yapan görevli/görevliler tarafından imzalanmalıdır.

Ancak, piyasa fiyat araştırmasında kaç kişiden teklif alınacağına ve bunların nasıl belgelendirileceğine ilişkin mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki piyasa fiyat araştırması tutanağının (Örnek No: 2) dipnotunda bu husus, *"Piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi/firma, yer sayısına ihale yetkilisi karar verebilecektir."* şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda piyasa fiyatını yansıtan tekliflerin bulunmasının yanı sıra bunların belgelendirilmesi de önem arz etmektedir.

Bu noktada kaç kaynaktan fiyat sorulması gerektiğine dair her durum için geçerli tek bir kriter

söylemek mümkün olmamakla birlikte, alınacak mal ve hizmet alımı ile yapım işinin özelliğine ve alımı yapılacak ihtiyacın piyasada bulunma koşulları dikkate alınarak bu hususta karar verilmelidir.

Uygulamaya baktığımızda ise, alım konusu işe bağlı olarak mümkün olması durumunda en az 3 kişiden fiyat sorulması gerektiği noktasında bir teamülün olduğu görülmektedir. Söz konusu uygulamayı destekler nitelikte Oda Muamelat Yönetmeliği'nin "Rayiç fiyat tespit usulü" başlıklı 36'ncı maddesinde, *"Rayiç fiyatlar, rayiç fiyat tespiti istenilen mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden mümkünse belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya birbirine en yakın değeri dikkate alınarak tespit edilir. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, kaç işletmeden fiyat alındığı ayrıca belirtilir. Borsaya tabi maddelerin rayiç fiyatı, istenilen tarihte borsada tescil edilen fiyatlar dikkate alınarak belirlenir."* düzenlemesi yer almaktadır. Ancak söz konusu düzenlemeyi kamu alımları için temel kriter olarak alamayız.

Dolayısıyla, söz konusu düzenleme, merkezi kamu idarelerini kapsamamakla beraber, referans bir mevzuat olarak göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir. Bununla beraber, yan teklif şeklindeki sunulan gerçekçi fiyatlardan uzak uygulamanın Kanun'un temel düzenlemelerine de aykırı olduğunu söyleyebiliriz.

Görüldüğü üzere; en az 3 teklif alınması uygundur. Yasal dayanağı olmamakla beraber kaynakların verimli kullanılması için birden çok kişiden teklif alınması gerektiğini ilkesel olarak söyleyebiliriz. Zira Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağına ilişkin örnekte 4 sütun bulunduğunu görmekteyiz. Burada esas olan, alınan teklifin o anki piyasa fiyatlarına ait gerçek durumu yansıtmasıdır.

İhale yetkilisi, bir veya birden fazla kişiyi piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirebilir. Bu kapsamda sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler de piyasa fiyat araştırmasında görevlendirilebilir. Piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmalar, açık ve dayanaklarıyla birlikte kanıtlanabilir olmalıdır. Piyasa fiyat araştırması ile ilgili görevlendirilen kişilerin alıma konu mal, hizmet veya yapım işlerinin muayene ve kabulünde yer almalarında da herhangi bir sakınca yoktur.

Bu nedenle idare satıcılardan ıslak imzalı teklif almak dışında faks veya e-posta yoluyla fiyat alabileceği gibi mağazaların fiyat kataloglarını esas alarak da fiyat araştırması yapabilecektir.

Ayrıca on-line alışveriş sitelerinden de fiyat araştırması yapılabilecektir. Ancak alım bedelini tespit için yapılan fiyat araştırması her ne surette yapılırsa yapılsın belgelendirilmesi şarttır. Bu nedenle piyasa fiyat araştırması kapsamında sözlü veya telefonla teklif alınmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuat kaynaklarında kamu görevlilerinin mali sorumlulukları ile ilgili hükümler mevcut olduğundan piyasa fiyatının tespitine yönelik çalışmaların somut verilere dayanır olması gerekir. Ayrıca, süreçte bilgi ve tekliflerin yazılı olarak alınması hukuk sistemimiz açısından da uygundur.

İhale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiler, piyasada fiyat araştırması yapmak zorundadır. Ancak araştırma sırasında tespit edilen fiyatların mutlaka kapalı zarflar içinde alınması şeklinde bir yöntem/zorunluluk yoktur. Fiyat araştırması teklif almak demek değildir. Fiyat araştırması yaparken Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan standart teklif mektuplarının kullanılması gibi de bir zorunluluk yoktur.

Piyasa fiyat araştırmasında kaç kişiden teklif alınacağına ve bunların nasıl belgelendirileceğine ilişkin mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin eki piyasa fiyat araştırma tutanağının dipnotunda piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi/firma, yer sayısına harcama yetkilisinin karar vereceği ifade edilmiştir. Alınacak mal ve hizmet alımı ile yapım işinin özelliğine göre makul sayıda kaynaktan araştırma yapılması gerekmektedir. Uygulamada alım konusu işe bağlı olarak mümkün olması durumunda en az üç kişiden fiyat sorulması gerektiği noktasında bir teamülün oluştuğu görülmektedir.

Satıcılar tarafından fiyat tekliflerinin idareye kapalı zarf içerisinde verilmesi zorunlu değildir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde, teklif (öneri) tek taraflı bir hukuki işlemdir ve genel bir ifadeyle sözleşme yapma çağrısıdır. Teklifin kabulü ile sözleşme tamam olur.

Tespit edilen fiyatlar görevlendirilen kişilerce kayıt altına alınmalıdır. Fiyat araştırması sırasında teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmalıdır. Ve kanıtlanabilir şekilde yapılması zorunludur. Ayrıca, 5018 sayılı Yasa'nın muhtelif maddelerinde kamu görevlilerinin sorumlulukları ile ilgili hükümler dikkate alındığında, harcamaya esas teşkil edecek fiyat

araştırmalarının belgelendirilebilir olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Piyasa fiyatını araştırırken, belli sayıda ve belli yerlerden fiyat alınmasına yönelik ihale mevzuatımızda bir düzenleme yoktur. Bu tamamen sorumluluk altına giren görevlilerin takdirindedir. Ancak, alımı yapılacak malın varsa yetkili satıcısı veya bayilerinden de fiyat sormaya ve elde edilen gerçekçi verilerin piyasa fiyat araştırması tutanağına yansıtılması hususuna özen gösterilmelidir.

Kamu mali yönetiminin temel ilkesi uyarınca, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması önem arz etmektedir. 5018 sayılı Kanun'un amacı da bu yöndedir. Bu kapsamda idarelerce ihtiyaç duyulan malların en uygun fiyatla temin edilebilmesi, anılan Yasa'nın hükümlerinin hayata geçirilmesi açısından da önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında, belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Piyasa fiyat araştırmasında belli sayıda veya belediye veya esnaf odası belli yerlere yazılı fiyat sorulması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu husus fiyat araştırması yapan görevlilerinin takdirindedir. Ancak piyasadaki fiyatlardan tereddüt oluşması durumunda buralardaki fiyatlardan da yararlanılması mümkündür.

Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşecek bir alım süreci rekabete açık bir süreç olmaması nedeniyle, gerçekçi bir şekilde yapılacak piyasa araştırmasının 5018 sayılı Kanun'un amacını gerçekleştirmek açısından uygun bir hareket tarzı olduğunu söyleyebiliriz.

Kamu alım sürecinde, idarenin sağlamaya çalıştığı en önemli sonuç ihtiyacın uygun zamanda ve uygun fiyatla alınmasıdır. Bu sonucun sağlanmasına ilişkin görev ve sorumluluk ise, idare adına bu süreçte görev alan kişilerdedir. Bu nedenle piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmaların ispat açısından somut bilgilere dayanması gerekir.

İdare, satın alınacak mal veya hizmetin tam özelliklerini teklif mektubunda veya ekinde yer alan teknik şartnamede göstermelidir. İdare, alımla ilgili teknik ve idari şartname

düzenlenmişse, teklif edilen malın söz konusu dokümanlara uygunluğu tespit edilmelidir.

Doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, yazılı teklifler üzerinden gerektiğinde sözlü pazarlık yapılabileceği de belirtilmelidir. Tekliflerin ilgilileri tarafından imzalanmış olması gerektiği hususuna da özen gösterilmelidir.

Bahse konu yöntemle yapılan alımlarda, teklifler idareye geldikten sonra, inceleme yapıldıktan sonra teklifler değerlendirilir. İdarece yapılan değerlendirmelerde, sadece fiyata bakılmaması gerekmektedir. Keza fiyatı uygun olmakla birlikte, ihtiyaç karşılamaktan uzak malın tercih edilmemesi gerekmekte olup, bu hususa ait gerekçenin de mutlaka piyasa fiyat araştırması tutanağında belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, alımın niteliği dikkate alınarak teknik şartnamenin düzenlendiği alımlarda, teknik şartname sürecinde görev alanların, piyasa fiyat araştırma sürecinde veya muayene kabul sürecinde görev alması uygun olacaktır. Böyle bir tercihin kullanıldığı durumlarda, gerekli şartları taşımayan ürünün, idare tarafından teslim alımının engellenmesi söz konusu olabilecektir.

24. Doğrudan temin kapsamında yer alan ve istisna durumuna girmeyen alımlarda marka belirtilebilecek midir?

Özet: *Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği'ndeki açıklamalar uyarınca, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda şartname düzenlenmesi idarelerin takdirinde bulunsa da gerek teklif fiyatının oluşturulması gerekse kabul işlemlerinin yapılması açısından bu yöntemle yapılan alımlarda (küçük ölçekli alımlar hariç olmak üzere) da teknik şartnamelerin hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Doğrudan temin yönteminde alım konusu işin teknik özellikleri, teklif vermeye davet yazısında ya da ayrı bir teknik şartnamede gösterilebilir. İhale yetkilisi tarafından teknik şartnameyi hazırlayacak personelin yazılı görevlendirilmesi uygun olacaktır. Kanun'un 22'nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda marka veya model belirtilmesi işin doğası gereğidir. Söz konusu alımlar belli bir marka, model veya kişiye yönelik alımlardır. Ancak Yasa'nın 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise alımın niteliğine bağlı olarak belli durumlarda marka belirtilmesi söz konusu olabilmektedir.*

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

4734 sayılı Kanun'un 12'nci maddesi ile İhale Uygulama Yönetmeliklerinde, idareler tarafından teknik şartname hazırlanmasında uyulması gereken hususlar düzenlenmiş bulunmaktadır.

Mezkûr Kanun'un "Şartnameler" başlıklı 12'nci maddesinde;

"İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir…
Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer

verilmeyecektir.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir."

Hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu madde gereği teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

Madde metninde yer aldığı üzere, bu durumunun istisnası ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilmesi olanak dahilindedir. Yine yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan esas malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür.

4734 sayılı Kanun'un 12'nci maddesi ile İhale Uygulama Yönetmeliklerinde, idareler tarafından teknik şartname hazırlanmasında uyulması gereken hususlar düzenlenmiştir. Anılan maddede, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu maddeye göre, ihale ile yapılan tüm alımlar için teknik şartname düzenlenmesi zorunludur. Çünkü alınacak mal ve hizmetler ile yapım işlerinin teknik özellikleri bilinmeden işin yaklaşık maliyeti tespit edilemeyeceği gibi ihale sonucu imzalanan sözleşmede yer alan işin ihale dokümanında yer alan iş olup olmadığının muayene ve kabul komisyonu tarafından tespiti de mümkün olmayacaktır.

4734 sayılı Kanun'un "Şartnameler" başlıklı söz konusu maddesinde yer alan *"Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir."* şeklindeki düzenleme teknik şartname hazırlanmak suretiyle gerçekleşen alımları kapsamaktadır.

Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği'ndeki açıklama uyarınca doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda şartname düzenlenmesi idarelerin takdirinde bulunsa da gerek teklif fiyatının oluşturulması gerekse kabul işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması açısından bu yöntemle yapılan alımlarda da teknik şartnamelerin hazırlanması gerektiği düşünülmektedir.

Doğrudan temin yönteminde alım konusu işin teknik özellikleri, teklif vermeye davet yazısında ya da ayrı bir teknik şartnamede gösterilebilir. İhale yetkilisi tarafından teknik şartnameyi hazırlayacak personelin yazılı görevlendirilmesi uygun olacaktır. Teknik şartnameyi hazırlayan kişi veya kişilerin ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görev alabilmeleri de mümkündür.

Ayrıca, alınacak malın teknik kriterleri ve özelliklerine ait bilgilerin; idarece veya muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.

Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Nitekim konuyla bağlantılı olarak, Sayıştay 6. Dairesince verilen bir Kararda; doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda şartname ve sözleşme düzenlemenin idarenin takdirinde olduğu, düzenlenmesi halinde ise, Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan Tip Şartname ve Sözleşmelerin kullanılma zorunluluğu bulunmadığı ayrıca şartnamede belirtilen özelliklerin sadece bir tek ürüne işaret etmediğinden ilişilecek husus bulunmadığına karar verildiği görülmüştür.

Buna karşın, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda marka veya model belirtilmesi işin doğası gereğidir. Söz konusu alımlar belli bir marka, model veya kişiye yönelik alımlardır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.2. maddesinde de " *İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet alımlarında, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat*

araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır." açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarında da marka belirtilmesi hususuna ilişkin olarak KİK'in 01.04.2003 tarih ve 2003/DK-D.94 sayılı Kararı'nda da *"Bir taahhüt kapsamında, taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır."* ifadesi yer almaktadır.

Yasa'nın 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılan alımlarda marka belirtilip/belirtilemeyeceği hususu alıma göre değişkenlik gösterecektir.

Bu bağlamda, söz konusu (d) bendi için sadece sosyal tesisler için yapılan mamul mal alımlarında marka belirtilebilecektir. Yine Kanun'un 22'nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarında da marka belirtilebilecektir.

Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.5.1.4. maddesinde; "*İdarelerce işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, ordu evi, askeri gazino, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler tarafından, bu tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hallerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilir."* düzenlemesi yer almaktadır.

Bu çerçevede idarelerce işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, ordu evi, askeri gazino, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler tarafından, bu tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hâllerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilecektir.

Bunun dışındaki diğer idare ihtiyaçları için Yasa'nın 22'nci maddenin (d) bendine ilişkin alımlara yönelik düzenlenen teknik şartname ve teklif alma yazılarında marka belirtilmemesi gerektiğini, aksi yöndeki uygulamaların Yasa'nın temel ilkelerine aykırılık taşıyacağını ifade edebiliriz.

Netice itibarıyla; Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.5.1.4. maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca, Yasa'nın 22'nci maddesinin (d) için sadece sosyal tesisler için yapılan mamul mal alımları ile anılan maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarında da marka belirtilebilecektir. Bunun dışında marka veya model belirtilmemesi gerektiğini ifade edebiliriz.

25. Doğrudan temin yönteminde ihtiyacın gerçek veya tüzel tek kişiden temini (22/a) nasıl olmalıdır?

Özet: *Doğrudan temin kapsamı alımlar 4734 sayılı Yasa'da yer aldığı üzere, özel bir alım yöntemi olup ihale usulleri için öngörülen kural ve kriterlere bağlı kalınmadan alımların gerçekleştirildiği bir satın alma şeklidir. Bu madde kapsamındaki alımların farklı süreçlere tabi olması alım yönteminin amacına da uygundur. Yasa'nın 22/a maddesinin kullanılması gerekliliği ile ilgili olarak, öncelikle ihtiyacın bu kapsama girip girmediğinin objektif olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan araştırma neticesinde, ihtiyaçların sadece tek bir kaynaktan temin edilebileceğinin ortaya çıkması halinde, Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (a) bendine göre alım yapılabilir. İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi konusunun ve yapılacak piyasa fiyat araştırmasının, Kamu İhale Genel Tebliği'nde belirtilen Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form'da yer alan düzenlemeler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.*

Doğrudan temine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesi;

"Madde 22- (Değişik: 30/7/2003-4964/15 md.)

Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi*.*

b) *Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.*

...

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

Hükmüne amirdir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun kabulünden kısa bir süre sonra, 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun'un bazı maddelerinde kapsamlı değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişiklikler

ile Kanun'un ilk halinde ihale usulleri arasında sayılan "Doğrudan temin usulü", ihale türleri arasından çıkarılmıştır. Bu çerçevede, doğrudan temin yöntemini, ihale mevzuatında öngörülen usul ve esasların, belli ölçüde dışına çıkarılarak ihtiyaçların kısa sürede karşılandığı alım türü şeklinde tanımlayabiliriz.

Yasa gerekçesinde yer aldığı üzere, işin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden karşılanmasının kaçınılmaz olduğu durumlar dikkate alınarak bu alım yönteminin düzenlendiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda, maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin uluslararası mevzuat paralelinde hazırlandığı, bu bentlerin uygulanmasında, idarelerin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamasını sağlamak üzere, isteklilerle teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

4964 sayılı Yasa ile 4734 sayılı Yasa'da yapılan değişiklik gerekçesinde de, bir ihale usulü olmayan doğrudan temine ilişkin esas ve usullerin, uygulamada gözlenen güçlükler de dikkate alınarak yeniden belirlendiği belirtilmiş ve 22'nci maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki alımlarda isteklilerden teminat istenmesi, sözleşme yapılması ve Kanun'un 10'uncu maddesindeki yeterlik şartlarının aranılması çoğunlukla mümkün olmayıp, istenmesi durumunda isteklinin satıştan imtina etmesinin söz konusu olabileceği gerekçesiyle bu zorunlulukların kaldırıldığı ifade edilmiştir.

Doğrudan temin kapsamındaki alımlar çeşitlilik göstermektedir. Zira 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde yer verildiği üzere, bu kapsamda yapılan alımlara; ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesinin zorunluluk arz ettiği alımlar başta olmak üzere, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması gibi ihale usulleri ile karşılanması mümkün olmayan alımlar örnek verilebilir.

Doğrudan temin yönteminin, yasada yapılan değişikliklerden sonra da halen 4734 sayılı Kanun'da yer aldığını görmekteyiz. Doğrudan teminin bir ihale çeşidi olarak düzenlenmemesi nedeniyle diğer ihale usulleri için uygulanan bazı düzenlemeler, doğrudan temin için uygulanmamaktadır. Ayrıca, doğrudan temin şekli alımlarda, Kamu İhale Kurumu tarafından herhangi bir inceleme ve uygulamanın doğruluğunun kontrolü de yapılmaz.

Doğrudan temin kapsamı alımların düzenlendiği Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde; piyasada yapılan araştırma neticesinde ihtiyaçların sadece tek bir kaynaktan temin edileceğinin ortaya çıkması halinde anılan Yasa'nın 22'nci maddesinin (a) bendine göre alım yapılmasının mümkün olacağı öngörülmüştür.

Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde de 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a) bendinin uygulanması söz konusu olabilmektedir.

İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi konusunun ve yapılacak piyasa fiyat araştırmasının Kamu İhale Genel Tebliği'nde belirtilen Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form'da yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bahse konu tek satıcılık durumunun ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları gibi mercilere başvurarak buralardan temin edilecek belgelerle kanıtlanması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre ihtiyacın tek kişiden temin edilmesi hususunun buralardan alınacak bilgi ve belgelerle de gerekçelendirilmesi uygun bir hareket tarzı olarak kabul edilebilir.

Tek satıcılık hali her ihtiyaç için ayrı ayrı belirlenmesi gereken bir husus olup bu hususla ilgili olarak öncelikle ihtiyacın objektif olarak ortaya konulması ve tanımlanması gerekir.

İdareler, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.

Mal alımlarıyla ilgili olarak; ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların vb. bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup

olmadığı hususlarının da ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir.

Ayrıca, alımı yapılacak ihtiyacın gerekli bulunmayan bazı nitelikleri ihmal edildiğinde farklı kişi ya da firmalardan temin edilebiliyorsa, bu bent (22-a) kapsamına gerçek anlamda girdiğini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte, idare ihtiyaç konusu mal veya hizmetin teknik özelliklerini tanımlarken tek kaynağı işaret edecek şekilde belirleme yapmamalıdır. Bu yöndeki davranışların Yasa'nın temel ilkelerine aykırılık teşkil edecektir. Hatta bunun kasıtlı olarak yapılması durumu adli ve idari yaptırıma konu olabilir.

Bu kapsamda, tek satıcılık durumuna örnek olarak Asfalt açısından TÜPRAŞ'ı örnek gösterebilir. Çünkü bu tip malzemede TÜPRAŞ tek satıcı konumunda bulunmaktadır.

Konuyla bağlantılı Kamu İhale Kurumunun 2008/UH.Z-2410 sayılı Kararı'nda da yer aldığı üzere; satın alınan veya idarece kullanılan taşınırların yedek parça, tamir ve/veya bakımları gibi servis hizmetlerinin tek satıcı olarak tanımlanabilmesi için bunların Türkiye'de tek yetkili servisinin bulunması gerekmektedir.

Tek satıcılık hususu yıllara göre ve piyasa şartlarına göre değişebilir. Bu nedenle olası yeni yetkilendirme veya distribütörlükler de dikkate alınarak, idarece piyasa fiyatı araştırmasının, ihtiyacın her temininde yapılması daha doğru olacaktır.

Uygulamada bazen hatalı olarak 4734 sayılı Yasa'nın 22/a maddesi ile 22/b maddesi karıştırılmakta ve birbirlerinin yerine ifade edilebilmektedir.

İdarelerin, 22/a maddesi kapsamı mal ve hizmet alımlarında, Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formun kullanması, alımın tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konulması, fiyat araştırması yapılması, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerinin tarif edilmesi ve bu hususlara ilişkin bütün belgelerin standart forma eklenmesi gerekmektedir.

Buna karşın, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (b) bendi, sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir hakka sahip

olmasına bağlı olarak gerçekleşen alımı ifade etmektedir. Bu nedenle, ihale konusu mal veya hizmet, bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal gerekçelerle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından sağlanabiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır.

Örneğin; bir kamu kurumunun yeni binası için özel bir tablo alımı yapılması ya da bir belediyenin şehrin kurutuluşu için bir sanatçıdan beste yapmasını istemesi, idarelerin diğer usullerle temini mümkün olmayan ve bu bent kapsamında temin edilebilecek ihtiyaçlarıdır.

Bu kapsamdaki alımlara ilişkin olarak 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhale Uygulama Yönetmeliklerinde 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a), (b), (c) bentleri kapsamında idarece yapılacak alımlarda kullanılmak üzere, "4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form" yer almaktadır (KİK022.0/M ve KİK021.0/H).

Söz konusu Formda; ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin, modellerin, markaların vb. bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara yer verilir; alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri detaylı olarak yazılır ve yazılan gerekçelere ilişkin kanıtlayıcı belgeler forma eklenir; onay belgesinde yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından fiyat araştırması yapılır ve yapılan fiyat araştırmasına ilişkin belgeler de anılan forma eklenir. Form, uygun bulması durumunda ihale yetkilisi (harcama yetkilisi) tarafından imzalanır.

İdareler, her iki bent kapsamı alımda da yani 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre yapılan alımlarda Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu hazırlarken formun dipnotundaki belirlemelerine özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup, söz konusu formun boş haline, bu soru başlığının son kısmında yer verilmektedir.

Görüldüğü üzere; Yasa'nın 22'nci maddesinin birinci fıkrasının "a ve b bentleri" kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak tek yükleniciden alım yapılabilir olması piyasa fiyat araştırması yapma zorunluluğunu kaldırmamaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuat, alımın tek yükleniciden yapılacak olması dahi piyasa fiyat araştırmasını gerekli kılmaktadır.

Ayrıca, idarelerin Yasa'nın 22'nci maddesinin birinci fıkrasının "a ve b bentleri" kapsamında yaptıkları mal alımlarında, alımın niteliğinden dolayı marka belirtilmesinin mümkün olduğunu ifade edebiliriz.

22 NCİ MADDENİN (A) / (B) / (C) BENTLERİ KAPSAMINDA TEK KAYNAKTAN TEMİN EDİLEN MALLARA İLİŞKİN FORM [1]

İDARE:	**ALIM YAPAN BİRİM:**
ALIM YAPILACAK OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER: Adı Soyadı/ ticaret unvanı, uyruğu: Açık tebligat adresi: Bağlı olduğu vergi dairesi ve Vergi Kimlik Numarası: Telefon ve faks numarası: E-posta adresi: İlgili kişi:	**ÖNGÖRÜLEN TESLİMAT ZAMANI:** **YAKLAŞIK BEDEL:**

İHTİYAÇ KONUSU MALIN NİTELİKLERİ[2]:

GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN ALIMIN HANGİ KAPSAMDA YAPILDIĞI: (ilgili maddeyi işaretleyiniz)	
	İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi
	Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması
	Mevcut mal, ekipman ve teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan malın, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması

[1] Bu form 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerin Kanunun "Doğrudan Temin" başlıklı 22 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gerçek veya tüzel tek kişiden yapacakları mal alımlarına ilişkin olarak kullanılacaktır.

[2] İhtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların vb. bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara yer verilir.

BU ALIMIN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN YAPILMA SEBEPLERİ: *[Yukarıda belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sağlayan sebepler detaylı olarak yazılacak, bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgeler de forma eklenecektir. İstenirse ek bir sayfada devam edilebilir.]*

FİYAT ARAŞTIRMASI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Doğrudan Temin" Başlıklı 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre bu maddeye göre yapılacak alımlarda ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilecektir.

Yaklaşık Bedel aşağıda yer alan metotlar kullanılarak gerçekçi bir şekilde tespit edilmiştir (ilgili belgeler eklenecektir):

- Aynı malın, malı ilgili tek kaynaktan alan diğer kamu/özel tüzel kişiliklerine veya gerçek kişilere satış fiyatı
- Aynı mal daha önce ilgili tek kaynaktan alındıysa, daha önceki alım bedelinin tedavüldeki Türk parası cinsinden ise ÜFE kullanılarak güncellenmesi, döviz cinsinden ise tespit tarihinde geçerli TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden güncellenmesi
- İlgili tek kaynaktan istenen proforma fatura
- Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası'ndan ve varsa üretim ve/veya satış yapan kurum ve kuruluşlardan alınan fiyatlar
- Diğer (açıklanacaktır)

Yukarıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı alım konusu mala ilişkin bedelle ilgili piyasada her türlü fiyat araştırması yapılarak Kanunun "Doğrudan Temin" başlıklı 22 nci maddesinin *[*(a)/(b)/(c)*]* bendi kapsamında gerçek veya tüzel tek kişiden alım yapılması uygun görülmüştür.

İHALE YETKİLİSİ
Adı SOYADI
Görevi
İmza

26. İhtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden temini (22/b) nasıl gerçekleşmektedir?

Özet: *4734 sayılı Yasa'nın "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla, bu niteliklere sahip bir idare ihtiyacı, sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, bu ihtiyacın doğrudan temin yöntemiyle karşılanması mümkün bulunmaktadır. Yasa'nın 22/b maddesi kapsamında yapılacak alımlarda, ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları gibi mercilere başvurarak buralardan temin edilecek belgelerle kanıtlanması zorunluluğu bulunmamakta ancak ihtiyacın niteliğine göre ihtiyacın tek kişiden temin edilmesi hususunun buralardan alınacak bilgilerle gerekçelendirilmesi mümkündür. Söz konusu bendin uygulamasında; Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form kullanılarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceği bahse konu forma detaylı olarak yazılacak, bu hususta fiyat araştırması yapılacak, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin nitelikleri tarif edilecek ve buna ilişkin belgeler forma eklenecektir. Bu kapsamdaki alımın tek gerçek veya tüzel kişiden yapılacak olması piyasa fiyat araştırması yapılmasına engel değildir. Hatta Yasa'nın 22'nci maddesinin emredici hükmüdür.*

4734 sayılı Yasa'nın "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesi;

"Madde 22- (Değişik: 30/7/2003-4964/15 md.)

Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

***a)** İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.*

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

...

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

Hükmüne amirdir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun kabulünden kısa bir süre sonra, 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik ile Kanun'un ilk halinde ihale usulleri arasında sayılan "Doğrudan temin usulü"nün, ihale türleri arasından çıkarıldığını görmekteyiz. Bu çerçevede, doğrudan temin yöntemini, ihale mevzuatında öngörülen usul ve esasların, belli ölçüde dışına çıkarılarak ihtiyaçların kısa sürede karşılandığı alım türü şeklinde tanımlayabiliriz.

Doğrudan temin kapsamındaki alımlar çeşitlilik göstermekle birlikte, yasada yapılan değişikliklerden sonra, doğrudan temin yönteminin mevcut durum itibarıyla 4734 sayılı Kanun'da yer aldığını görmekteyiz. Doğrudan teminin bir ihale çeşidi olarak düzenlenmemesi nedeniyle diğer ihale usulleri için uygulanan bazı düzenlemeler, doğrudan temin için uygulanmamaktadır.

Yasa gerekçesinde, işin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden karşılanmasının kaçınılmaz olduğu durumlar dikkate alınarak bu alım yönteminin düzenlendiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda, maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin uluslararası mevzuat paralelinde hazırlandığı, bu bentlerin uygulanmasında, idarelerin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamasını sağlamak üzere, isteklilerle teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

4964 sayılı ile 4734 sayılı Yasa'da yapılan değişiklik gerekçesinde de bir ihale usulü olmayan doğrudan temine ilişkin esas ve usullerin, uygulamada gözlenen güçlükler de dikkate alınarak yeniden belirlendiği belirtilmiş ve 22'nci maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki alımlarda isteklilerden teminat istenmesi, sözleşme yapılması ve Kanun'un 10'uncu maddesindeki yeterlik şartlarının aranılması çoğunlukla mümkün olmayıp, istenmesi durumunda isteklinin satıştan imtina etmesinin söz konusu olabileceği gerekçesiyle bu zorunlulukların kaldırıldığı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin yönteminde, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu yöntemde, şartname

ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarelerin takdirindedir.

4734 sayılı Yasa'nın doğrudan temin kapsamı alımlara ilişkin hususların düzenlendiği 22'nci maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinde, sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir hakka sahip olması durumunu ifade etmektedir. Bu nedenle, ihale konusu mal veya hizmet, bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından sağlanabiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla, idarelerin diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim vb. mal veya hizmetler bu bent kapsamında temin edilebilecektir. Örneğin; bir kamu kurumunun yeni binası için özel bir tablo alımı yapılması ya da bir belediyenin şehrin kurutuluşu için bir sanatçıdan beste yapmasını istemesi, idarelerin diğer usullerle temini mümkün olmayan ve bu bent kapsamında temin edilebilecek ihtiyaçlardandır.

Bu kapsamdaki alımlar için parasal limit söz konusu değildir. Yani Yasa'nın 22/d maddesi kapsamındaki parasal sınır bu kapsamdaki alımlar için geçerli değildir.

İdareler, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (b) bendinin uygulamasında, (Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu-KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.

22'nci maddenin (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade etmektedir.

İhale konusu mal veya hizmet alımı; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, ilan yapılmaksızın doğrudan teminle ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır.

Konuyla bağlantılı Kamu İhale Kurumunun uyuşmazlık kararlarına baktığımız zaman,

örnek Kararlardan;

2004/UM.Z-1429 No.lu Karar'da;"... İhale konusu mal alımı, bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır." İdare, ihtiyacı olan ... sistemini belirleyerek, bunun teknik özelliklerini oluşturması, bu özelliklere göre başka gerçek yada tüzel kişiler tarafından da karşılanabilip karşılanamayacağını araştırarak, tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi ve özel bir hak bulunması halinde 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi gereğince doğrudan temin usulü ile alım yapabilecektir.",

Benzer şekilde, 2006/UH.Z-1689 No.lu Karar'da da;"... yaptırılacak heykel, anıt ve rölyeflere ilişkin ortaya çıkan ihtiyacın doğrudan temin yoluyla karşılanması için öncelikle bu ihtiyacın, ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olan gerçek veya tüzel kişiden temininin kaçınılmaz olması gerekmektedir. 22/(b) bendinde göre bir alım yapılabilmesi için öncelikle ihtiyacın doğduğu tarihte sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması durumunun var olması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu alım usulü, ihale konusu hizmet alımının bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa söz konusu olabilecektir.",

Hususlarının yer aldığı görülmüştür.

Uygulamada bazen Yasa'nın 22/a maddesi ile 22/b maddesi karıştırılabilmektedir. İçerik olarak farklı da olsa bazen hatalı yorumlamalara neden olmaktadır.

Bilindiği üzere, Yasa'nın 22/a maddesi kapsamında, ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi konusunun ve yapılacak piyasa fiyat araştırmasının Kamu İhale Genel Tebliği'nde belirtilen ve İhale Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formda yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tek satıcılık hali her ihtiyaç için ayrı ayrı belirlenmesi gereken bir husus olup, bu hususla ilgili olarak öncelikle ihtiyacın objektif olarak belirlenmesi ve tanımlanması gerekir. İhtiyacın ikame edilebilir olmaması gerekir.

Bu bağlamda, idareler, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a), (b), (c) bentleri kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Buna karşın, ihtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden temini kapsamında, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, bu kapsama giren ihtiyaçlar, bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından sağlanabiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır.

Yasa'nın 22/b maddesi kapsamına, idarelerin diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri kapsamı alımlar örnek olarak gösterilebilir. İdareler, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (b) bendinin uygulamasında, (Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu-KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini söz konusu forma detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.

Söz konusu formlar İhale Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer almakta olup, bu soru başlığının sonunda da söz konusu forma örnek olarak yer verilmektedir. Ancak bu kapsamda yapım işinin alınması mümkün değildir.

Bu bağlamda, her iki bent kapsamı alımlarda yani 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre yapılan alımlarda: 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında Tek Kaynaktan

Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form hazırlanır. Anılan form hazırlanırken formdaki dipnot belirlemelerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Formda; ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin, modellerin, markaların vb. bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlar açıklanır; ayrıca, alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri detaylı olarak yazılır ve yazılan gerekçelere ilişkin kanıtlayıcı belgeler forma eklenir; onay belgesinde ihale yetkilince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından fiyat araştırması da yapılır ve yapılan fiyat araştırmasına ilişkin belgeler forma eklenir. Son aşamada ise, form uygun görüşe sunulur ve ihale yetkilisi (harcama yetkilisi) tarafından herhangi bir olumsuzluk görülmemesi durumunda form imzalanır.

Görüldüğü üzere; 4734 Yasa'nın 22'nci maddesinin birinci fıkrasının "a ve b" bentleri kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarının özgün niteliklerine rağmen, her iki alım için de piyasa fiyat araştırması yapılma zorunluluğunun bulunduğunun bilinmesi gerekir.

22 NCİ MADDENİN (A) / (B) / (C) BENTLERİ KAPSAMINDA TEK KAYNAKTAN TEMİN EDİLEN MALLARA İLİŞKİN FORM [1]

İDARE:	**ALIM YAPAN BİRİM:**
ALIM YAPILACAK OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER: Adı Soyadı/ ticaret unvanı, uyruğu: Açık tebligat adresi: Bağlı olduğu vergi dairesi ve Vergi Kimlik Numarası: Telefon ve faks numarası: E-posta adresi: İlgili kişi:	**ÖNGÖRÜLEN TESLİMAT ZAMANI:** **YAKLAŞIK BEDEL:**

İHTİYAÇ KONUSU MALIN NİTELİKLERİ[2]:

GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN ALIMIN HANGİ KAPSAMDA YAPILDIĞI: (ilgili maddeyi işaretleyiniz)	
	İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi
	Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması
	Mevcut mal, ekipman ve teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan malın, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması

[1] Bu form 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerin Kanunun "Doğrudan Temin" başlıklı 22 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gerçek veya tüzel tek kişiden yapacakları mal alımlarına ilişkin olarak kullanılacaktır.

[2] İhtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların vb. bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara yer verilir.

BU ALIMIN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN YAPILMA SEBEPLERİ: *[Yukarıda belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sağlayan sebepler detaylı olarak yazılacak, bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgeler de forma eklenecektir. İstenirse ek bir sayfada devam edilebilir.]*

FİYAT ARAŞTIRMASI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Doğrudan Temin" Başlıklı 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre bu maddeye göre yapılacak alımlarda ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilecektir.

Yaklaşık Bedel aşağıda yer alan metotlar kullanılarak gerçekçi bir şekilde tespit edilmiştir (ilgili belgeler eklenecektir):

- Aynı malın, malı ilgili tek kaynaktan alan diğer kamu/özel tüzel kişiliklerine veya gerçek kişilere satış fiyatı
- Aynı mal daha önce ilgili tek kaynaktan alındıysa, daha önceki alım bedelinin tedavüldeki Türk parası cinsinden ise ÜFE kullanılarak güncellenmesi, döviz cinsinden ise tespit tarihinde geçerli TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden güncellenmesi
- İlgili tek kaynaktan istenen proforma fatura
- Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası'ndan ve varsa üretim ve/veya satış yapan kurum ve kuruluşlardan alınan fiyatlar
- Diğer (açıklanacaktır)

Yukarıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı alım konusu mala ilişkin bedelle ilgili piyasada her türlü fiyat araştırması yapılarak Kanunun "Doğrudan Temin" başlıklı 22 nci maddesinin *[*(a)/(b)/(c)*]* bendi kapsamında gerçek veya tüzel tek kişiden alım yapılması uygun görülmüştür.

İHALE YETKİLİSİ
Adı SOYADI
Görevi
İmza

27. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlara ait dokümanlarda bakım onarım kapsamında garanti ve yedek parçaya yönelik düzenlemeler nasıl olmalıdır?

Özet: *Doğrudan temin uygulamasında şartname ve sözleşme düzenlenmesi idarenin takdirinde bir husus olmakla birlikte; özellikle süreli alımlarda, bir başka ifadeyle işin gerçekleştirilmesinin belli bir süreye bağlı olduğu mal, hizmet veya yapım işlerinde sözleşme düzenlenmesinin gerekli olduğunu, ancak tip dokümanlara bağlı kalınmadan işin niteliğine göre sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşme metnini idarelerin kullanılabileceğini, bu bağlamda, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda da garanti ve satış sonrası servise yönelik düzenleme yapılmasının mümkün olduğunu, garantiye yönelik olarak düzenleme öngörülüyor ise yazılı sözleşme yapılması ve sözleşmede garantiye ilişkin bir maddeye yer verilmesi uygun olacağını, ayrıca süreçte 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade edebiliriz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanması ve sonraki süreç ise bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu yasal düzenlemeler esas olarak ihale kapsamı alımlar ve bu alımlara ilişkin sözleşmenin uygulanmasına ilişkin kuralları belirlemektedir. Bununla birlikte, doğrudan temin kapsamı alımlar, mevcut durum itibarıyla Kamu İhale Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

Doğrudan temin kapsamı ihtiyaçlar, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar olup, doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir satın alma yöntemidir. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle

temin edilmesi gereken bir ihtiyacın doğrudan temin kapsamında karşılanması mümkün değildir.

4734 sayılı Kanun'un "Şartnameler" başlıklı 12'nci maddesinde;

"...teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.
Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir."

Hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü gibi, Kanun'un şartnamelere ilişkin söz konusu maddesinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu maddeye göre, ihale ile yapılan tüm alımlar için teknik şartname düzenlenmesi zorunludur. Çünkü alınacak mal ve hizmetler ile yapım işlerinin teknik özellikleri bilinmeden ihale sonucu imzalanan sözleşmede yer alan işin teslim edilen iş olup olmadığının belirlenmesi pek mümkün olmayacaktır.

Söz konusu madde gereği teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Bu durumunun istisnası ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilmesi durumudur.

Yine yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür. Söz konusu durumlar dışında ihalelerde marka veya model belirtme imkânı yoktur.

Yukarıda yer verilen düzenleme ve hususlar esas itibarıyla ihale kapsamı alımlar için geçerli olan hususlardır. Dolayısıyla, bir ihale türü olmayan doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlar da bu kurallara bütünüyle bağlı kalınması gerekmemektedir. Ancak doğrudan temin yönteminde de olsa Kanun'un temel ilkelerinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla, söz konusu temel ilkeleri, tüm alımlar için dikkate alınması gereken temel referans noktaları olarak kabul edebiliriz.

Doğrudan temin bir ihale yöntemi değil alım yöntemi dolayısıyla uygulama yönetmelikleri ve eklerinde yer alan hususlar doğrudan temin için geçerli değildir.

Bu itibarla, doğrudan temin yönteminin özgün durumu dikkate alınarak Yasa'nın 22'nci maddesinin son fıkrasında yer aldığı üzere; "Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir." hükmü çerçevesinde hareket edilmesi gerekir. Bu yöntem istisnai başvurulan bir yöntem olduğu için farklı esaslara bağlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre doğrudan temin yöntemi, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar için öngörülmüş olup, bu alım yöntemi için getirilen kolaylıklardan, alımların herhangi bir kriterlere bağlı kalınmadan keyfi yöntemlerle gerçekleştirilebileceği sonucu çıkarılmaması gerekmektedir.

Ancak bu yöntemde şartname ve sözleşme yapma konusunda idareler esas olarak serbest bırakılmıştır. İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'da belirtilen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

Doğrudan teminde, sözleşme düzenlenmesi hususu idarelerin takdirinde olmakla birlikte, 22'nci madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda sözleşme yapılması zorunludur.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda yazılı sözleşme düzenlendiği durumlarda Kamu İhale

Kurumu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılması zorunlu değildir. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda, düzenlenecek sözleşmelerin emredici hukuk kurallarına, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ve konusunun objektif olarak imkânsız olmaması şartı ile idare tarafından istenildiği şekilde yapılabilmesi mümkündür.

Yazılı sözleşme yapılması durumunda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan tip sözleşme tasarılarının kullanılması zorunlu olmamakla birlikte, alımın niteliği dikkate alınarak ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki tip sözleşmelerin kullanılmasına da engel bir durum yoktur.

Ayrıca, yazılı sözleşme yapılması durumunda, sözleşme tasarısının piyasa araştırması kapsamında gönderilen teklif isteme yazılarının ekinde yer alması uygun olacaktır. Zira fiyat teklifi verecek kişiler sözleşme koşullarına göre fiyat teklifini oluşturacaklardır.

Bunlarla birlikte, her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlarda, sözleşme düzenlenmesi istisnai durumlar hariç idarenin takdirinde olmakla birlikte, teminat alınması, cezai yaptırımlar öngörülmesi gibi uygulamaların tercih edildiği durumlarda yazılı sözleşme düzenlenmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir. Keza bahse konu hususların ispatı yazılı sözleşme düzenlenmesi ile netlik kazanabilecektir.

Bu çerçevede, garanti ve yedek parçaya yönelik düzenlemeler ancak yapılacak sözleşme ile hayata geçebilecek hususlardır. Herhangi bir sözleşe yapılmaması durumunda bu hususlara ilişkin uygulamalarda belirsizlikler yaşanabilecektir.

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca, doğrudan temin yöntemiyle de olsa alıma konu mal veya hizmetin teslimi belli bir süreyi gerektiriyorsa, bu durumda sözleşme yapılması gerekmektedir.

Nitekim Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 03.03.2009 tarihli Kararı'nda da benzer şekilde; *"..ihtiyacın doğrudan temin yoluyla karşılanmasında kamu yararı olduğunu dikkate alarak idare ile satıcılar arasında sözleşme imzalamıştır….Kanunlara aykırı olmayan sözleşme hükümlerinin uygulanması da zorunlu olup, tarafları bağlar."* ifadelerine yer verilerek, doğrudan teminde düzenlenen sözleşmelerin tarafları bağlayacağı belirtilmektedir.

Belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da idarenin tercihine bağlı olarak yazılı sözleşme düzenlendiği durumlarda, daha sonra doğabilecek ihtilafların önlenmesi için, hazırlanacak sözleşme tasarısı ve idari şartnamenin fiyat araştırması yapılan kişilere (isteklilere) verilmesi uygun olacaktır.

Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmelikler ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olması gerekli değildir, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabilecektir.

Bu bağlamda, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, alımın niteliği çerçevesinde, garanti ve satış sonrası servise yönelik düzenleme yapılabilir.

Bu hususa ilişkin olarak KİK'in 01.04.2003 tarih ve 2003/DK-D.94 sayılı Kararı'nda da; *"Bir taahhüt kapsamında, taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır."* hususu yer almaktadır.

Zira Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.2. maddesinde bu hususa ilişkin olarak, " …*bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır."* açıklaması yer almaktadır.

Konuyla bağlantılı Kamu İhale Kurumunun 2008/UH.Z-2410 sayılı farklı bir Kararı'nda da yer aldığı üzere; satın alınan veya idarece kullanılan taşınırların yedek parça, tamir ve/veya bakımları gibi servis hizmetlerinin tek satıcı olarak tanımlanabilmesi için bunların Türkiye'de tek yetkili servisinin bulunması gerekmektedir.

Tek satıcılık hususu yıllara göre ve piyasa şartlarına göre değişebilecek olup, önceki yıl satın alınan mal veya hizmetin tek satıcısı bulunmakta iken, bir sonraki yıl ihtiyacın temininde piyasaya yeni arz firmaları çıkabilecek veya yeni yetkilendirme veya distribütörlükler verilerek arz durumu değişebilecektir. Bu nedenle, idarece piyasa fiyatı araştırmasının ihtiyacın her temininde yapılması daha uygun olacaktır.

Bu bağlamda, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, alımın niteliği çerçevesinde, garanti ve satış sonrası servise yönelik düzenleme yapılabilir. Garantiye yönelik olarak düzenleme öngörülüyor ise yazılı sözleşme yapılması ve sözleşmede garantiye ilişkin bir maddeye yer verilmesi uygun olacaktır.

Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulden sonra asgari garanti süresi de sözleşmede düzenlenebilir. Yüklenicinin mallara ait garanti belgelerini idare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını idareye teslim etmekle mükellef olduğunun ifade edilmesinde yarar bulunmaktadır. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenicinin garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi idareye sunması gerekmektedir ve alım dokümanlarına bu husus yansıtılmalıdır.

Ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun hükümlerinin de dikkate alınması gerekir. Bu bağlamda düzenlenecek sözleşmelerde anılan Kanun'un emredici hükümlerinin dikkate alınması ve aynı Kanun'a aykırı hususların sözleşmelere yansıtılmaması gerekir. Zaten Kanun'a aykırı sözleşmelerin hukuki geçerlilik duruma tartışmalıdır (geçersizdir).

İdarelerin cihaz ve makinaları ya da taşıtları için bakım ve onarım hizmeti alımı ihalelerinde, kullanılacak yedek parçanın "orijinal" ve "ikinci el olmamasına" yönelik düzenlemeler bağlamında, Kamu İhale Kurulunca verilen bir uyuşmazlık kararında, teknik şartnamenin yedek parçayı tanımlayan düzenlemelerinde yedek parçanın başka bir cihazdan çıkma veya ikinci el olmaması gerektiği hususunun belirtilmiş olması nedeniyle iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Farklı bir KİK Kararında ise alım kapsamı cihazların arızalanması ve cihazların onarımı sırasında "yeni ve orijinal yedek parça kullanılmasına" yönelik düzenlemenin maliyetleri artırdığı ve idareye katkı sağlamadığı iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusuna istinaden, Kamu İhale Kurulunca verilen bir kararda, sistemdeki aksamaların en aza indirilmesini teminen bu

yönde bir düzenleme yapıldığı ifade edildikten sonra idarenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirtilen şekilde düzenleme yapma hakkına sahip olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu hususlar ve KİK'in verdiği kararlar, ihale kapsamı alımlar için geçerlidir. Ayrıca doğrudan temin kapsamı alımlar KİK'e şikayet konusu olamaz. Bununla birlikte, ihale mevzuatının ruhunu yansıttığı için bütünüyle göz ardı edilmemelidir.

Bu itibarla, idarelerce garanti ve yedek parçaya yönelik yapılan alımlarda, idarenin yeni ve kullanılmamış malzeme veya parça değişimi söz konusu olan durumlarda, sistemin kesintisiz ve düzenli çalışması, meydana gelebilecek arıza oranlarının minimuma indirilmesi için onarımda orijinal parçaların kullanılmasına yönelik düzenleme yapılarak bu husus alım dokümanlarına yansıtabilir.

Ayrıca, temel ilkelere aykırı olmamak şartıyla, idare ihtiyaçlarını belirlerken kendi durumuna en uygun nitelikte alım yapılması için bu hususta düzenleme yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle, yıpranmış ve ikinci el cihazlarda sık arızalanmalar ile karşılaşılacağından kamu hizmetinin aksamaması yeni ürüne yönelik düzenlemelerin, kamu yararına daha uygun olduğu düşünülmektedir. Bilindiği gibi idare ihtiyaçlarının uygun koşullarda ve zamanında karşılanması gerekmektedir.

Tekrar ifade etmek gerekirse, idare ihtiyaç duyduğu cihazları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine aykırı olmayacak şekilde kendi ihtiyacına en uygun şekilde belirleme konusunda takdir hakkına sahiptir.

İhale konusu alımın niteliği çerçevesinde alım dokümanında, yedek parça ve malzemelerin yeni ve kullanılmamış olması şeklindeki düzenlemelerine, muayene ve kabul işlemlerinde de dikkat edilmesi gerekmektedir.

Netice itibarıyla; doğrudan temin yöntemiyle de olsa garanti ve yedek parçaya yönelik idare talep ve ihtiyaçlarının söz konusu olduğu durumlarda, alımın ve hizmetin gerçekleşmesi belli bir süreyi gerektirmesinden dolayı sözleşme yapılmasının zorunluluk arz ettiğini, yüklenicinin yaptığı teslimden sorumlu tutulabilmesi için sözleşme düzenlenmesinin bir anlamda elzem olduğunu söyleyebiliriz.

Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, alımın niteliği çerçevesinde, garanti ve satış sonrası servise yönelik düzenleme yapılabileceği, garantiye yönelik olarak düzenleme öngörülüyor ise yazılı sözleşme yapılması ve sözleşmede garantiye ilişkin bir maddeye yer verilmesinin bir anlamda zorunluluk arz ettiğini, yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulden sonra asgari garanti süresinin sözleşmede düzenlenebileceğini, yüklenicinin mallara ait garanti belgelerini idare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını idareye teslim etmekle mükellef olduğunu ifade edebiliriz.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine aykırı olmayacak şekilde kendi ihtiyacına en uygun şekilde garanti ve yedek parçayı belirleme konusunda idarenin takdir hakkının bulunduğunu söyleyebiliriz.

28. Doğrudan temin kapsamı alımlarda kısmi teklif ve dolayısıyla kısmi alım mümkün müdür?

Özet: *4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesi uyarınca doğrudan temin yöntemiyle hedeflenen amaç, parasal sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla, idarenin günlük ve aciliyeti olan ihtiyaçlarının ihale usulleri için öngörülen kurallara uyulmaksızın karşılanmasıdır. Bu yöntemde esas olan ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişilerin piyasa fiyat araştırması yapmak suretiyle alım yapmasıdır. Bu alım yönteminde, Yasa'da açıkça öngörülmemekle birlikte, idareye sağlanan serbestlik ve takdir hakkı çerçevesinde, idarece gerek görülmesi durumunda kısmı teklif ve dolayısıyla kısmi alım yapılması mümkündür. Ancak yapılacak alımın niteliğinin buna uygun olması gerekmektedir. Sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da kabul sonrasında yaşanacak olası problemler nedeniyle yazılı sözleşme düzenlenmesi gerekliliği unutulmamalıdır. Bu alım yönteminde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri ve tip sözleşmeler referans olarak kullanılabilecektir. Süreçte 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmaması halinde, yine aynı kanuna göre Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin süreçte dikkate alınması gerekmektedir.*

Doğrudan temin kavramı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde, (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmaktadır. Kanun'un ilk kabul edildiği haliyle, bir ihale türü olarak belirlenen "Doğrudan temin" 2003 yılında yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesi incelendiğinde, doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince

görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

Doğrudan temin kapsamı ihtiyaçlar, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar olup, doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir satın alma yöntemidir. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın doğrudan temin kapsamında karşılanması mümkün değildir.

Piyasa fiyat araştırmasında kaç kişiden teklif alınacağına ve bunların nasıl belgelendirileceğine ilişkin mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki piyasa fiyat araştırması tutanağının (Örnek No: 2) dipnotunda bu husus, "Piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi/firma, yer sayısına ihale yetkilisi karar verebilecektir." şeklinde ifade edilmiştir.

Kaç kaynaktan fiyat sorulması gerektiğine yönelik her durum için geçerli tek bir kriter söylemek mümkün olmamakla birlikte, alınacak mal, hizmet veya yapım işinin özelliğine göre makul sayıda araştırma yapılması uygun olacaktır. Uygulamaya baktığımızda, alım konusu işe bağlı olarak mümkün olması durumunda üç kaynaktan fiyat sorulması yönünde yaygın bir teamülün bulunduğunu ifade edebiliriz.

Bu bağlamda, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağına ilişkin örnekte 4 sütun bulunduğunu görmekteyiz. Ancak açık bir dayanağı yoktur. Burada esas olan alınan teklifin o anki piyasa fiyatlarını ve koşullarını yansıtması gerekliliğidir. Asıl olan alınan fiyat tekliflerinin gerçek durumu yansıtması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması ilkesidir.

Bununla birlikte, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin eki piyasa fiyat araştırması tutanağının dipnotunda piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi/firma, yer sayısına harcama yetkilisinin karar vereceği ifade edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesi piyasa fiyat araştırması yapılmasını öngörülmüş fakat piyasa fiyat araştırmasının nasıl yapılması gerektiğine dair herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Kuşkusuz idarenin gerçekçi piyasa fiyat araştırması yapması

gerekmektedir.

5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuat kaynaklarında kamu görevlilerinin mali sorumlulukları ile ilgili hükümler mevcut olduğundan piyasa fiyatının tespitine yönelik çalışmaların somut ve dayanakları ile birlikte kanıtlanabilir olması gerekir. Harcama süreci açısından da sorumlulukların belirlenmesi anlamında belgelendirme esastır.

Kanun'da fiyat araştırmasının şekil, yöntem ve esaslarıyla ilgili herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Konuya ilişkin olarak 22'nci maddenin son fıkrasında, maddenin farklı durumları düzenleyen bütün bentleri için geçerli olmak üzere;"....ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir" denilmektedir.

Doğrudan temin kapsamında gerçekleşecek alım süreci, rekabete açık bir süreç değildir. Bu nedenle görevli kişi veya kişilerce yapılacak piyasa araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi tespitlere dayanması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından önem arz etmektedir.

Alımla ilgili teknik ve idari şartname düzenlenmişse, verilen teklifler değerlendirmeye alınmadan önce, teklif edilen malın düzenlenmiş şartnameye uygunluğu tespit edilmelidir. Birden fazla kalemi ihtiva eden alımlarda tekliflerin kalemler itibarı ile değerlendirilebileceği belirtilmelidir.

Satıcılar tarafından fiyat tekliflerinin idareye kapalı zarf içerisinde verilmesi zorunlu değildir. Teklif (öneri) tek taraflı bir hukuki işlemdir ve genel bir ifadeyle sözleşme yapma çağrısıdır. Teklifin kabulü ile sözleşme tamam olur.

Bu bağlamda, kısmi teklif verilebilmesi için ihale dokümanın da hüküm bulunması gerekmektedir. Bu noktada alımın niteliği belirleyici olacaktır. İşin niteliği buna uygun değilse mümkün olmayabilir. Ayrıca idarenin bu noktada serbestliği de bulunmaktadır.

Dolayısıyla kısmı teklife bağlı olarak kısmi kabul de söz konusu olabilir. Genel olarak ihale kapsamı alımlar için bu durumun söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak kırtasiye malzemesi gibi çeşitlilik gösteren doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal alım sürecinde de bu yöntemin kullanılmasına engel yoktur. Yasa'da bu noktada açık bir yasaklama

olmaması nedeniyle, idarenin takdir hakkına bağlı olarak bu yönde bir tercih de bulunulması mümkündür.

Her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlarda, sözleşme düzenlenmesi istisnai durumlar hariç idarenin takdirinde olmakla birlikte, teminat alınması, cezai yaptırımlar öngörülmesi gibi uygulamaların tercih edildiği durumlarda yazılı sözleşme düzenlenmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir. Keza bahse konu hususların ispatı yazılı sözleşme düzenlenmesi ile netlik kazanabilecektir.

Böyle bir tercih ortaya konulduğunda, daha sonra doğabilecek ihtilafların önlenmesi için, hazırlanacak sözleşme tasarısı ve idari şartname fiyat araştırması yapılan kişilere verilmelidir. Doğrudan temin bir ihale yöntemi olmadığı için, ihale uygulama yönetmelikleri ve eklerinde yer alan hususlar doğrudan temin için geçerli değildir.

Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, bu alandaki düzenlemelerin açık ve net olmaması nedeniyle, taahhüdün yerine getirilmemesi ihtimali karşısında alacağını garanti altına almak isteyen idarenin bu hususa ilişkin olarak hazırlayacağı sözleşmeye yaptırım maddeleri koyabilir.

Bilindiği üzere, ihale sürecine ilişkin hukuki düzenlemeler 4734 sayılı Kanun'a göre, sözleşmenin imzalanmasından sonraki süreç ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre gerçekleştirilmektedir.

Yani 4735 sayılı Kanun, ihale kapsamında gerçekleştirilen alımlara ait sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin süreci kapsamaktadır. Dolayısıyla doğrudan temin kapsamı alımlar için söz konusu Kanun hükmünün uygulanması mümkün değildir. Ancak idareler tarafından alım öncesi idari şartname ve sözleşme tasarısı ve diğer ihale dokümanlarında yer vermek şartıyla bu hususta düzenlemeler yapılabilir.

İdare, almayı planladığı ihtiyacı tek mal kaleminden oluşması durumunda ihalede götürü bedel sözleşme yapabilecektir. Götürü bedel sözleşme yapılması öngörülen ihalede; isteklilerin tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerini, ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağının belirtmesi gerekir.

Buna karşın, idare işin özelliklerine göre, birim fiyat sözleşme yapılmasını öngörmesi halinde, istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerini, ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı belirtilmelidir.

Diğer taraftan, ihale kapsamı alımlarda olduğu gibi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlarda da kısmi teklif verilmesi, bu hususun alım dokümanlarına yansıtılması koşuluyla mümkündür. Şayet kısmı teklif verilmesi istenilmiyorsa işin tamamı için teklif verileceği belirtilmelidir. Doğrudan temin kapsamı alımlarda pek karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, kırtasiye malzemesi ve demirbaş alımı veya sarf malzemesi alımı gibi çeşitli ve değişkenlik gösteren ihtiyaçlarda bu durum söz konusu olabilir.

Bu bağlamda, kısmi teklif verilmesine izin verilen alımlarda kısmi teklifin ne şekilde verileceğine ilişkin bilgi, alım dokümanlarına veya piyasa fiyat araştırma sürecinde istekliye yönelik yazılarda bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, birim fiyat teklif cetvelinde de gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

İdareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden karşılanmasını sağlayan ve kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede; ihale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacak ise bu duruma ilişkin açıklamaya alım dokümanlarında yer verilmesi gerekir. Kısmı teklif verilmesine yönelik açıklamalar Uygulama Yönetmeliklerinin haricinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nde de yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde;

"16.4. Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi

16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir.

16.4.3. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin "Kısmi teklife ilişkin açıklamalar" başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır. "

Hususları yer almaktadır.

Yukarıda yer aldığı üzere, söz konusu düzenlemeler ihale kapsamında gerçekleştirilen alımlar için geçerli olan kurallar olmakla birlikte, zorunlu olmamakla birlikte doğrudan temin kapsamı alımlar için de bu hususlar göz önünde bulundurulabilir.

Normal şartlarda doğrudan temin kapsamı alımlar niteliği itibarıyla prosedür gerektirmeyen alımlar olup, karmaşık düzenlemelerden uzaktır. Kanun'un 22'nci maddesine ilişkin yasal gerekçede yer aldığı üzere, karmaşık iş ve işlemlerin varlığı halinde istekliler teklif vermekten imtina edebilecektir. Bu ise, idarenin acil ve özellik arz eden ihtiyaçlarının karşılanmama riskini gündeme getirecektir. Çünkü bu alım yönteminde piyasa fiyat araştırması ve buna bağlı olarak idare ihtiyacının karşılanması söz konusudur.

Özü itibarıyla, kısmı teklifin gündemde olduğu alımlar, ihale kapsamı mal alımlarıdır. Ancak doğrudan teminde parasal sınıra yakın alımlarda, kısmı teklif söz konusu olabilir. Örneğin, çok çeşitli demirbaş alımında (klima, fotokopi makinası, PC, yazıcı vb) ürün çeşitliliği tek firmadan olmayabilir. Bu nedenle, idarenin ihtiyaç duyduğu malların, farklı farklı isteklilerden karşılanması söz konusu olabilir.

İdarelerin çok tercih edebileceği bir yöntem olmamakla birlikte, bahse konu durumlarda idare ihtiyacının doğrudan temin limiti içinde kalması durumunda, kısmı teklif söz konusu olabilir.

İdare bu konuda bütünüyle takdir hakkına sahiptir. İsterse ilave bazı kriterler koyabilir. Şayet kısmi teklif verilmesini istiyorsa, bu hususa alım dokümanlarında yer verilmesi gerekir. Piyasa fiyat araştırmasının da bu koşul çerçevesinde yapılması gerekir.

Özetlemek gerekirse; doğrudan temin kapsamında pratik olmamakla birlikte kısmi alım yapılması mümkündür. Ancak kısmı teklif kapsamında Yasa'nın idare ihtiyacının kısımlara bölünmemesine yönelik temel ilkelerine aykırı şekilde alım yapılamaz.

Ayrıca, fiyat araştırmasıyla ilgili bir diğer husus, bu sürece katılan kamu görevlilerinin sorumlulukları bağlamında, piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmaların açık ve dayanaklarıyla birlikte kanıtlanabilir olması gerekliliğidir.

29. İhtiyacın kısımlara bölünerek doğrudan temin limitinin altına çekilmesi mümkün müdür?

Özet: *4734 sayılı Kanun ile belirlenen parasal değerler çerçevesinde, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için farklı eşik değerler öngörülmekte, yaklaşık maliyeti, eşik değerin altında kalan ihaleler ile eşik değere eşit veya üstünde olan ihaleler farklı prosedürlere tabi tutulmaktadır. İhale mevzuatında öngörülen kuralları aşmak amacıyla ihale kapsamı alımların doğrudan temin limiti altına çekilmesi, isteklilerden istenecek belgeleri ve uygulanacak hükümleri etkilemektedir. Bu itibarla, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin doğru şekilde belirlenmesi, ihale konusu işle ilgili ihtiyacın uygun şartlarla karşılanması gerekmektedir. İhale kapsamında karşılanması gereken bir ihtiyacın kısımlara bölünerek doğrudan temin kapsamında alınması, yaptırım uygulanmasını gerektirebilmektedir. Zira harcama sürecinde görev alanların sorumluluğu bulunmaktadır. İdari sorumluluğunun yanında yapılan hatanın niteliğine bağlı olarak adli sorumluluk da gündeme gelebilecektir. Danıştay bir kararında bu nitelikteki fiile ilişkin disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilmesinde yasal bir engel bulmamıştır. Adli olarak ihaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçu söz konusu olabilmektedir. Uygulanacak yaptırım ise olay bazında değişkenlik gösterecektir.*

4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca Kanun'un 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların genel alım yöntemi olan açık ihale usulü ile veya Kanun'daki şartların bulunması halinde belli istekliler arasında ihale usulü ya da pazarlık usulü ile ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir. Ayrıca idarelerin, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak ihtiyacın temin edilmesi şeklinde

doğrudan temin kapsamı alımları özetleyebiliriz.

Doğrudan temin, süreklilik arz etmeyen, Kanun'da belirtilen limitler dahilindeki ihtiyaçların ihale için belirlenen prosedürler ile uğraşılmadan alınmasına ilişkin bir yöntemdir. Doğrudan temin yöntemi de olsa alıma konu ihtiyaç birden fazla tekrarlanan ihtiyaçlara ilişkin ise bunların ihale yapılarak karşılanması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun'un "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesi;

"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. (Ek cümle: 2/7/2018-KHK-703/171 md.) Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartlarına uygun şekilde yerine getirilme zorunluluğu nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılabilir."

Hükmüne amirdir.

Bu meyanda, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde zikredilen, *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.*

...

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez." hüküm ve ilkeleri çerçevesinde açıklanması gereken husus, ihtiyacın kısımlara bölünerek doğrudan temin limitinin altına çekilmesi uygulamasıdır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.5.1.2. maddesinde; *"Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir."* açıklaması bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi, Kanun'da belirtilen ihale usulleriyle alımı gereken bir ihtiyacın, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında karşılanması Kanun'a aykırılık teşkil etmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda doğrudan teminin bir ihale usulü olmaması ve böylece içerdiği usul kolaylıkları sayesinde ihtiyaç konusu mal, hizmet veya yapım işinin temininde zaman tasarrufu öngörmesi idareler açısından her zaman tercih edilir bir yöntem olmuştur. Elbette idareler bu tercihlerini mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde şekillendirmelidirler.

Kanun'un "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesinde yer alan; *"Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir."* hükmünde görüleceği üzere esas olan açık ihale usulünün kullanılması gerekmektedir. Bunun temel nedeni ise açık ihale usulünde rekabet ilkesinin daha fazla olmasıdır. Şüphesiz ki birkaç firmadan teklif alınarak gerçekleştirilen doğrudan temin yöntemiyle alımda bu ilkenin olması beklenemez. Bu sebeple ihtiyacın niteliği buna uygunsa daha fazla kişiden fiyat teklifi almak belli düzeyde rekabetin artmasına katkı sağlayacaktır.

Kanun'un 60'ıncı maddesinde ise temel ilkelere hareket eden kamu görevlilerinin karşılaşacakları yaptırımlar hukuki zemine kavuşturmuştur. Ayrıca, ihale usulleri ile gerçekleştirilmesi gereken ihtiyacın doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesinin hukuka aykırılığının Sayıştay denetim raporlarına da yansıdığı görülmüştür.

Hukuka aykırı gerçekleşen bu satın alımlar çoğu zaman sorun oluşturmamakla beraber eğer bir sebeple soruşturma söz konusu olduğunda kanuna aykırı hareket eden kamu görevlileri hakkında önemli disiplin cezaları verilebilmektedir. Konuyla bağlantılı olarak Danıştay

tarafından verilmiş bulunan bir kararın bilinmesi önem arz etmektedir. Bir hastanede gerçekleşen bir olayda ihale yöntemleri ile gerçekleştirilmesi gereken bir satın alma işlemi doğrudan temin ile gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen soruşturma sonucunda ihale yetkilisine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin hükümlerinin yer aldığı 125'inci maddesinde çerçevesinde, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak fiiline girdiği gerekçesiyle 1/15 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir.

İhale yetkilisi bu işlemi verilen cezanın ağır bir ceza olduğu, satın almanın doğrudan temin ile gerçekleştirilmesinde kastının olmadığı gerekçesiyle idari yargı yerine taşımıştır. Bu olaya ilişkin dava süreci Danıştay tarafından hükme bağlanmıştır. Danıştay 12. Dairesince bu hususta verilen Kararda;

"... hastanede hizmet alım sözleşmesi uyarınca kurulan hasta tanıma sisteminin Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca ve ihale yoluyla gerçekleştirilmesinin gerektiği, uyuşmazlık konusu olayda ise davacının anılan mevzuat hükümlerine uymayarak bahse konu hizmet alım işini doğrudan ilgili firmaya tevdi ettiği, hal böyle iken mevzuat hükümlerine uyulmadan yapılan söz konusu hizmet alımı işinde davacının kusurla hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği gibi davacının hizmet alımında uygulanacak olan mevzuat hükümlerini bilmediğinden de söz edilemeyeceği, davacı hakkında ileri sürülen eylemin ancak kasıt ile gerçekleştirilebilecek bir eylem olduğu, eylemin kusur ile işlenmesine hukuki imkan bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-a maddesi uyarınca 1/15 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır."

Hususlarına yer verilerek söz konusu fiilin kasıtlı işlendiği, bunun en önemli delilinin de ihale yetkilisince mevzuatın bilinemeyeceği sebebinin geçersiz olduğu gerekçesiyle idare tarafından aylıktan kesme cezasının verilmesinin hukuka uygun olduğunu oy birliği ile kabul etmiştir.

Söz konusu Kararda yer aldığı üzere; ihale usulü ile gerçekleştirilmesi gereken bir alımın doğrudan temin ile gerçekleştirilmesi durumunda satın alma sürecinde görev yapanların

(özellikle satın almaya karar verenlerin) aylıktan kesme cezası ile karşı karşıya kalmaları mümkündür.

Kaldı ki 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı'nda yer aldığı üzere; harcama sürecinde görev alanların sorumluluğu bulunmaktadır. Bu idari sorumluluğunun yanında ilgililerin yapılan hatanın niteliğine bağlı olarak adli sorumluluğunun da gündeme geleceğinin unutulmaması gerekmektedir. 5018 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Konuyla bağlantılı birçok Sayıştay Kararında da bu hususa vurgu yapılmış ve alımların kanuna aykırı olarak kısımlara bölünmesinin kamu zararına neden olduğu vurgulanmıştır. Nitekim Kamu İhale Kurulunca bu hususta 2006 yılında verilen bir Kararda;

"Kamu İhale Genel Tebliğinde de açıklandığı üzere, 4734 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ve yapım işleri ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmetlerin temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitlerin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açı ihale usulü temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temininin, 4734 sayılı kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil edeceği izahtan varestedir."

Hususları yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde geçen ifadelerle; idareler ihtiyaçlarının temin edilmesinde saydamlığı, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. 4734 sayılı Yasa'nın

22'nci maddesi kapsamda yapılacak alımlarda da Kanun'un 5'inci maddesindeki rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi doğrudan teminin ruhuna da uygun ilkelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Zira Kamu İhale Genel Tebliği'nin "4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca mal ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temini" başlıklı 22.4. bendinin 22.4.1.1 kısmında açıkça Kanun'un 5'inci maddesindeki ilkelere atıfta bulunulmuş olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun " Görevlilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 60'ıncı maddesinde "5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır." hususu yer almakta olup, bu bağlamda, söz konusu alımlara ait piyasa fiyat araştırması sürecinde de temel ilkelere aykırı davranış, Yasa'nın 60'ıncı maddesi kapsamında sorumluluk içermektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesi hükmü uyarınca, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların yetkili kılınmış mercilere hesap vermeleri zorunludur.

Aynı Kanun'un 33'üncü maddesinde de giderin gerçekleştirilmesi, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesi ile son bulmaktadır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanun'da harcama yetkilisi ifadesiyle bir program sorumlusuna ve statü hukukunda tanımlanan daire/birim amirine işaret edilmektedir. Bu konumda olan yöneticilerin, 657 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinde belirtildiği gibi, amiri oldukları kuruluş ve hizmet biriminde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurları takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumlu tutulacakları da tabiidir.

5018 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince

imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanmaktadır.

Bahse konu Kanun'un 33'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca ödeme emri belgesi, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir görevli tarafından düzenlenecektir. Yapılan bu açıklamalara göre, aslî bir gerçekleştirme belgesi olan ödeme emri belgesini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisinin, düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulması gerekmektedir.

İdarelerin doğrudan temin kapsamında en çok kullandığı alım türü ise, Kanun'un 22/d maddesi kapsamında yer verilen ve her yıl Kamu İhale Tebliğince güncellenen "parasal tutarlar kapsamında aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar" oluşturmaktadır. Bu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, "Doğrudan temin" başlıklı Kanun'un 22'nci maddesi incelendiğinde; doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde; *"Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır."* hükmü; 32'nci maddesinde ise *"Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur."* hükmü bulunmaktadır.

4734 sayılı Yasa'nın "Görevlilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 60'ıncı maddesi uyarınca, ihale

yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17'nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılacağı ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyanın genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği, bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlilerinin, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyecekleri, bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanların, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamayacakları ve görev alamayacakları, 5'inci maddede belirtilen ilkelere ve 62'nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı yönünde hükmün yer aldığı görülmektedir.

Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun verilmiş bir Kararda da; "*...yargı kararını uygulamamak kamu görevlisinin kişisel kusurunu oluşturmaktan başka ceza hukuku bakımından da suçtur. Konusu suç teşkil eden bir emir, hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse ise sorumluluktan kurtulamaz…"* hususu yer almaktadır.

Anlatılanlar ışığında; 4734 sayılı Yasa hükümleri uyarınca gerçekleştirilen alımlarda uyulması gereken temel ilke ve esaslar bulunmakta olup, bunlara uyulmaması çeşitli adli ve idari yaptırımların uygulanmasını gündeme getirmektedir. Söz konusu kuralların bir kısmı sadece ihale kapsamı alımlar için geçerli iken, bir kısmı ise Kanun kapsamında gerçekleştirilen tüm alımlar için geçerlidir.

Bu bağlamda, Yasa'nın temel ilkelerine tüm alımlarda dikkat edilmesi gerekmektedir. Yasa'nın 60'ıncı maddesinde de yer aldığı üzere, buna aykırılıklar ise yaptırım uygulanmasını gerektirmektedir.

Dolayısıyla, ihale kapsamına giren bir alımın ihale süreçlerinden aykırı bir şekilde kısımlara bölerek doğrudan temin kapsamında alınması, yaptırım uygulanmasını gerektirmektedir.

Danıştay bir kararında bu nitelikteki fiile ilişkin disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilmesinde yasal bir aykırılık bulmamıştır. Adli olarak ise ihaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçu söz konusu olabilmektedir. Bu durum ise olay bazında değişkenlik gösterecektir.

Netice itibarıyla; 4734 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri uyarınca, ihtiyacın uygun şartlarda ve zamanında karşılanması gerekmektedir. Aralarında doğal bir bağlantı bulunmadığı sürece mal, hizmet ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Ancak mal alımları için bu kapsamda hazırlanacak ihale dokümanlarında gösterilmek şartıyla kalem bazında alım yapılabilir. Ancak ihale süreçlerine ilişkin zorunlu işlemlerden kaçınmak amacıyla, parasal sınırların altında kalacak şekilde ihtiyacın kısımlara bölünmesi ihale mevzuatı düzenlemelerine aykırıdır. Hatta belli koşulların oluşması durumunda ihaleye fesat karıştırma veya kamu görevini kötüye kullanma suçunun söz konusu olabileceğinin bilinmesi gerekir.

30. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda sözleşme düzenlenmesi zorunlu mudur?

Özet: *Doğrudan temin uygulamasında şartname ve sözleşme düzenlenmesi idarenin takdirinde bir husus olmakla birlikte; özellikle süreli alımlarda, bir başka ifadeyle işin gerçekleştirilmesinin belli bir süreye bağlı olduğu mal, hizmet veya yapım işlerinde sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Aynı şekilde, Yasa'nın 22/c maddesi kapsamında yapılan alımlar için de sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Bu iki durum dışında sözleşme düzenlenmesi zorunlu değildir. Şayet idarece şartname ve sözleşme düzenlenmesi söz konusu ise, bu gibi durumlarda; İhale Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan Tip Sözleşme ve Tip Şartnamelerin kullanılma zorunluluğu, 4734 sayılı Kanun'un 27'nci maddesinde düzenlenen idari şartnamede bulunması zorunlu hususlara uyma zorunluluğu, 4735 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinde yer alan sözleşmede bulunması zorunlu hususlara uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. İdare, işin niteliğine göre sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşme metni kullanılabilecektir. Bu esaslar çerçevesinde, sözleşme düzenleme konusunda takdir bütünüyle idareye aittir.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanmasındaki süreç ise bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir.

Anılan Yasa'nın "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesi ise; "İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

e) Açık ihale usulü.
f) Belli istekliler arasında ihale usulü.
g) Pazarlık usulü.
h) …" şeklinde düzenlenmiştir.

Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale

komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

Bunların dışında, satın alma sürecinde ihale usulleri için öngörülen diğer düzenlemelerin uygulanmamasına ilişkin Kanun'da aksi yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Söz konusu ihtiyaçlar, doğaları gereği ihale açılarak temini mümkün olmayan ve idarelerin tercih hakkının ortadan kalktığı ihtiyaçlardır. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın bu kapsamda karşılanması söz konusu değildir; doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir yöntemdir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.1. maddesinde bu hususa ilişkin olarak, "… *4734 sayılı Kanun'un 22. maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır."* açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. maddesinde yer alan; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenleme ile sözleşme yapma konusunda idareler (sözleşme düzenlenmesini gerektiren özel durumlar hariç olmak üzere) serbest bırakılmıştır.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinde belirtilen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

Bu arada, sözleşme yapılması halinde idarelerin sözleşme bedeli üzerinden ilgili mevzuatında

öngörülen oranda damga vergisi kesintisi yapması gerektiği unutulmamalıdır.

Doğrudan temin ile yapılan alımlarda yazılı sözleşme yapılması zorunlu değildir. Ancak aşağıda belirtilen iki durumda sözleşme imzalanması zorunludur:

- Doğrudan teminin (c) bendine göre yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunludur.
- Alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin veyahut yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda (ifası zaman alacak alımlarda), alımın yazılı bir sözleşmeye bağlanması zorunludur.

Bu iki durum dışındaki doğrudan temin ile yapılacak alımlarda yazılı sözleşme yapılıp yapılmaması idarelerin takdirindedir.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda yazılı sözleşme düzenlendiği durumlarda Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılması zorunlu değildir. Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda düzenlenecek sözleşmeler emredici hukuk kurallarına, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ve konusunun objektif olarak imkânsız olmaması şartı ile istenildiği şekilde yapılabilir.

Bahse konu temin yöntemiyle yapılan alımlarda yazılı sözleşme yapılmasının zorunlu olup olmadığına ilişkin açıklama Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.3'üncü maddesinde yer almaktadır. Buna göre kural olarak doğrudan temin ile yapılan alımlarda yazılı sözleşme yapılması zorunlu değildir.

Yazılı sözleşme yapılması durumunda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan tip sözleşme tasarılarının kullanılması zorunlu olmamakla birlikte, alımın niteliği dikkate alınarak ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki tip sözleşmelerin kullanılmasına da engel bir durum yoktur.

Ayrıca, yazılı sözleşme yapılması durumunda, sözleşme tasarısının piyasa araştırması kapsamında gönderilen teklif isteme yazılarının ekinde yer alması gerekir. Zira fiyat teklifi verecek kişiler sözleşme koşullarına göre fiyat teklifini oluşturacaklardır. Ayrıca yazılı sözleşme yapılması halinde sözleşme bedeli üzerinden sözleşme damga vergisi kesintisi

yapılması da gerekecektir.

Bu çerçevede, doğrudan temin bir ihale yöntemi olmayıp alım yöntemi olması nedeniyle uygulama yönetmelikleri ve eklerinde yer alan hususlar doğrudan temin için geçerli değildir. Bu bağlamda, doğrudan temin kapsamında yapılan sözleşmelerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekliliğinden hareketle, taraflar anlaştıklarında sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler.

Bunlarla birlikte, her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlarda, teminat alınması, cezai yaptırımlar öngörülmesi, kabulle ilgili bir kısım prosedürler veya kabul sonrası sorumluluklar getirilmesi gibi uygulamaların tercih edildiği durumlarda da yazılı sözleşme düzenlenmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir. Keza bahse konu hususların ispatı yazılı sözleşme düzenlenmesi ile netlik kazanabilecektir.

4735 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihaleler sonucunda sözleşme türleri;

"a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,

b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

d) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,

e) Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme,

Düzenlenir.

Çerçeve anlaşma ve münferit sözleşmede belirtilmesi zorunlu olan hususları

belirlemeye Kurum yetkilidir. ”

Hükmü yer almaktadır.

Nitekim Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 03.03.2009 tarihli bir Kararı’nda da benzer şekilde; *“Dilekçi dilekçesinde doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığından mal alımlarında herhangi bir cezai müeyyide bulunmadığını ileri sürmüş ise de, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin d bendine göre yapılan alımlar idarelerin ihtiyaçlarının temininde istisnai bir yöntem olup sınırlı durumlarda başvurulmaktadır. İhtiyacın giderilmesi acil olup da beklemeye tahammülü olmayan durumlarda idare bu yöntemle hemen ihtiyacını karşılayacaktır. Bu nedenle Kanunda bu alım yöntemi ile idarelere geniş bir takdir alanı tanınmıştır. Bunlardan biri de, sözleşme yapıp yapmama serbestliğidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tıbbi sarf malzemesi ihtiyacının doğrudan temin yoluyla karşılanmasında kamu yararı olduğunu dikkate alarak idare ile satıcılar arasında sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmelere, malzemenin zamanında teslim edilmemesi halinde gecikme cezası kesilmesi yönünde hükümler konulmuştur. Kanunlara aykırı olmayan sözleşme hükümlerinin uygulanması da zorunlu olup, tarafları bağlar.”* ifadelerine yer verilerek, doğrudan teminde düzenlenen sözleşmelerin tarafları bağlayacağı belirtilmektedir.

Açıklandığı üzere; sözleşme düzenlenmesi hususu idarelerin takdirinde olmakla birlikte, 22’nci madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumu ile 22’nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

Belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da, yükleniciden teminat alınması, cezai yaptırımlar ön görülmesi önem arz eden hususlar için yazılı sözleşme düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Böyle bir tercih ortaya konulduğunda, daha sonra doğabilecek ihtilafların önlenmesi için, hazırlanacak sözleşme tasarısı ve idari şartname, fiyat araştırması yapılan kişilere verilmelidir.

Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmeliklerin ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olması gerekli değildir, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabilecektir.

Her ne kadar doğrudan temin kapsamında, idareler tarafından sözleşme imzalanması zorunlu olmamakla birlikte, iş artışı, iş eksilişi yapılabilmesi, fiyat farkı verilebilmesi, cezai müeyyideler öngörülebilmesi gibi uygulamalar için sözleşme imzalanması ve bu uygulamaların ayrıntılarına bu sözleşmelerde yer verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen bir alıma ilişkin olarak, bedel içeren bir sözleşme düzenlenmiş olması halinde, ikincil mevzuattaki ilgili hükümler çerçevesinde iş deneyim belgesi de düzenlenebilecektir.

31. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda muayene ve kabul işlemleri nasıl yapılır?

Özet: *İdarece, alımı konu mal, hizmet veya yapım işinin, alım dokümanlarına göre idareye teslim edilmesi gereken edim konusu ile uyumlu olup olmadığının ortaya konulması gerekmektedir. Zira gerek ihale kapsamı alım olsun gerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alım olsun, alım kapsamının, muayene ve kabul aşamasında kontrol edilmesi bir zorunluluktur. Bu bağlamda, muayene ve kabul yönetmeliklerinin kapsam maddelerine bakıldığında, kapsamlarına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yine aynı Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin muayene ve kabul işlemlerinin girdiği görülmektedir. Dolayısıyla, alımın niteliğine bağlı olarak, uygulanacak muayene ve kabul işlemlerine dair esas ve usuller ilgili muayene ve kabul yönetmelikleri ile ortaya konulmuştur. Doğrudan temin, bir ihale usulü olmadığından muayene ve kabul yönetmelikleri kapsamında bir komisyon kurulması zorunlu değildir. İdarece komisyon kurulmadan bu kapsamdaki alımların muayene ve kabul işlemleri yapılabilir. Ancak malın veya hizmetin istenilen özelliklerde olup olmadığının tespiti için, komisyon kurularak kabulünün yapılması uygun olacaktır. Çünkü yüzeysel bilgi ile idareye teslim edilen mal veya hizmetin gerçekten alınması gereken olup olmadığı bilinemez. Ayrıntılı inceleme ve uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle, muayene ve kabul komisyonu kurulduğu zaman, bu komisyonlar, yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler ve kabulünü yapar. Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Görevleri ile ilgili olarak belirlenen kurallara aykırı fiillerin varlığında ise, adli ve idari yaptırımların uygulanması söz konusu olabilmektedir.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu Yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihaleye ait sözleşmenin imzalanmasındaki süreç ise bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri ile açıklığa kavuşturulmaktadır. 4734 sayılı Yasa'nın "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde ise ihale usulleri; "Açık ihale usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü ve Pazarlık usulü" olarak sıralanmıştır.

Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin, ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan

değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Kamu İhale Kanunu'ndaki hükümler çerçevesinde, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar hususunda Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.1. maddesinde, "… *4734 sayılı Kanun'un 22. maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır."* açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun hükümleri ışığında hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. maddesinde yer alan; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenleme ile belli noktalarda idareler serbest bırakılmıştır.

İhale usulleri veya doğrudan temin kapsamında alımı gerçekleştirilen eşyaların idarece kabulü gerekmektedir. Zira idareye teslim edilen ürünün, idarece istenilen şartlara uygun olup olmadığının kontrolü gerekmektedir. Genel anlamda bu süreç muayene ve kabul işlemleridir. Bu süreç ihale kapsamı alımlar ile doğrudan temin kapsamı alımlar için genel olarak farklıdır.

Örneğin; satın alınan yazıcının alınmak istenilen yazıcı ile aynı olup olmadığı veya hizmet binası girişine yaptırılan güvenlik kulübesinin alım dokümanlarında yer alan şekilde yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Kaldı ki muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, idari şartnamede ve idare ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşmede yer alması zorunlu hususlar arasında sayılmıştır. Ayrıca 4735 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinde muayene ve kabul işlemlerinin temel esasları belirlenmiştir. Söz konusu maddede;

"*Denetim, muayene ve kabul işlemleri*

Madde 11- Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal

veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.
Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir."

Şeklinde hükme bağlanmıştır.

4735 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri ışığında hazırlanan söz konusu Yönetmeliklere baktığımızda; Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımları ve Muayene Kabul Yönetmeliği'nin bulunduğunu görmekteyiz. Söz konusu Yönetmeliklerden;

Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği'n kapsam maddesinde; Yönetmeliğin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, anılan Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen mal için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile ara denetim, muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsadığı,

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği'nin kapsam maddesinde; Anılan Yönetmeliğin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, anılan Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda idareye teslim edilen hizmet işlerinin muayene ve kabul işlemleri için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsadığı,

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği'nin amaç ve kapsam maddesinde ise, Yönetmeliğin amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, anılan Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri için, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca

kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlediği,

Görülmektedir.

Kanuni düzenlemelerin dışında hizmet alımı ihaleleri için yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan her bir ihale usulü için tip idari şartname, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Yapım işlerinde de benzer dokümanlar bulunmakta olup, bunlardan yapım işleri genel şartnamesinde ayrıntılı hususlar bulunmaktadır.

Yukarıdaki muayene ve kabul yönetmeliklerinin kapsam maddelerine bakıldığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yine bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen mal, hizmet veya yapım işlerinin muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasına ilişkin olduğu görülmektedir. Doğrudan temin, bir ihale yöntemi olmadığından muayene ve kabul yönetmelikleri kapsamında bir komisyon kurulması zorunlu değildir.

Bunun yanında doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılan alımlarda kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonunun kurulacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, doğrudan temin yöntemi kapsamında olsa bile sözleşmenin düzenlendiği, mal veya hizmetin tesliminin belli bir süreyi gerektirdiği veya alımın niteliği bu tarz faaliyetleri bir anlamda zorunlu kılıyorsa, muayene ve kabul komisyonunun oluşturulması ve hatta duruma göre kontrol teşkilatının kurulması söz konusu olabilir. Hizmet alımlarında kontrol teşkilatı kurulurken, yapım işlerinde yapı denetim görevlisi belirlenmektedir.

Diğer bir anlatımla, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlara ilişkin muayene ve kabul işlemleri aynen ihale usulleriyle yapılan alımlarda olduğu gibi yapılabilir. Yapılmaması da mümkündür. Bu hususta bir zorunluluk yoktur. Ancak, zaman zaman idarelerin doğrudan teminle yapılan alımlarda, muayene ve kabul komisyonu kurulmadan kabul işleminin idarece yapılması şeklinde uygulamalar da bulunmaktadır.

Yani doğrudan temine göre yapılacak mal alımlarında, muayene ve kabul komisyonu

kurulmadan idare yetkilisince kabul işlemleri yapılabilir. Ancak ihtiyacın niteliğine göre istenildiği takdirde komisyon kurulmak sureti ile de alım gerçekleştirilebilir. Muayene ve kabul komisyonun kurulması durumunda, buna ilişkin olarak ilgili tutanakların düzenlenmesi gerekir. Ayrıca, 22'nci maddenin parasal sınırlamaya tabi olmayan (d bendi harici) büyük ölçekli alımlar için komisyon kurulması, olası risklerin bertaraf edilmesi adına uygun olacaktır.

Hizmet ve yapım işleri teslimlerinde taşınır işlem fişi düzenlenmesi söz konusu olmadığından, hizmet ve yapım işlerine yönelik kabul tutanaklarının düzenlenmesi gerekir. Sürece ilişkin belgeler ise, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde hakedişin ödenmesi kapsamında açıklanmıştır.

Muayenede aranacak hususlar, ihale dokümanında yazılı şartlardır. Muayene raporlarına, ihale dokümanında yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç olarak belirlenen niteliklere uygun olup olmadığı ortaya konulur.

Hizmet alımlarında, yüklenicinin işin kabulü için idareye yazılı başvurusundan sonra ilk olarak kontrol teşkilatının ön inceleme yapacağı, bu ön incelemenin olumlu neticelenmesi sonucunda idare tarafından muayene ve kabul komisyonunun kurulması söz konusudur.

Sözleşmeye göre işte kontrol teşkilatı öngörülmüş ise kontrol teşkilatı tarafından işin ne kadar yapıldığının tespit edilmesi, kontrol teşkilatı yoksa doğrudan temin kapsamı alımı yapan birim tarafından tespit edilerek yapılan işin tutarı kadar ödeme yapılması gerekmektedir.

İdareye teslim edilen mal, hizmet veya yapım işinin niteliğine göre muayene ve kabul işlemleri farklılık göstermektedir. Mal alımları sürecinde taşınır işlem fişi düzenlenirken, hizmet işlerinde kontrol teşkilatının kurulması, yapım işlerinde ise, komisyon üyelerinin tamamının teknik eleman olması gibi gereklilikler söz konusudur.

Muayene ve kabul yönetmelikleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yine bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucundaki muayene ve kabul işlemlerine ilişkin olduğundan, doğrudan temin bir ihale yöntemi olmadığından, anılan mevzuata tabi olmadığı gibi bu yöntemde, muayene ve kabul yönetmelikleri kapsamında oluşturulması gereken bir komisyon da bulunmamaktadır.

Bunun yanında, doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılan alımlarda kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonunun kurulacağına ilişkin mevzuatımızda bir hüküm bulunmamakla birlikte, doğrudan temin kapsamı alımın niteliğine göre idarenin tercihine bağlı olarak kontrol teşkilatı ile muayene ve kabul komisyonunun oluşturulması mümkündür.

Görüldüğü üzere; idarece alımı yapılan mal veya hizmetin, alım dokümanlarına göre hedeflenen mal veya hizmet ile uyumlu olup olmadığının ortaya konulması gerekmektedir. Zira gerek ihale kapsamı alım olsun gerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alım olsun, bunların kabul aşamasında kontrol edilmesi gerekir. Hatta özellikli kumaş gibi ilave bilgi ve uzmanlık gerektiren durumlarda, gerekirse laboratuvar ortamında ürünün test edilmesi bile söz konusu olabilir.

İhale kapsamı alımlar için muayene ve kabul işlemleri 4735 sayılı Kanun hükümleri ve bu Kanun'a dayanılarak hazırlanan muayene ve kabul yönetmeliklerine göre gerçekleştirilir. Bu yönetmelikler, mal, hizmet ve yapım işine göre farklı esaslar üzerine hazırlanmıştır. Çünkü mal alımı ile yapım işi aynı karmaşıklıkta değildir.

Buna karşın, doğrudan temin kapsamı alımlar noktasında idarede serbestlik söz konusudur. İdare herhangi bir komisyon kurmadan muayene ve kabul süreci gerçekleştireceği gibi tıpkı ihale kapsamı alımlara benzer şekilde, komisyon kurup işlemleri gerçekleştirebilir. Burada idarenin kamu yararı için en uygun olanı seçmesi gerekir. Ayrıca, basit bir kırtasiye işlemi için belki muayene kabul komisyonu kurulması gerekmese de parasal sınır içerisinde gerçekleşen bir yapım işinde komisyon kurulması gereklilik arz edebilir.

Netice itibarıyla; doğrudan temin bir ihale yöntemi olmamakla beraber, alımı gerçekleştirilen ve muayeneye konu eşya, yüzeysel bilginin ötesinde bir anlamda uzmanlık gerektiren niteliklere sahip ise, teslim aşamasında muayene kabul komisyonunun kurulmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Kaldı ki hizmet alımı ve yapım işleri için istenilirse, kontrol teşkilatı ve yapı denetim görevlisi belirlenmesi de mümkündür. Burada idarenin yaklaşımına göre hareket edilmesi gerekir. Mal alımları için taşınır işlemlerinin de dikkate alınması gerekir. Taşınır işlem fişi tanımı itibariyle malın kabulü yapıldıktan sonra düzenlenir.

Ayrıca, gerek ihale kapsamı olsun, gerekse doğrudan temin yöntemi olsun, kabul sürecinde kasıt unsurunun varlığına bağlı olarak gerçekleşecek suiistimallerde TCK kapsamında edimin ifasına fesat karıştırma suçu söz konusu olabilmektedir.

Çünkü ortada kamu kaynağı ve bunun kullanımı söz konusu olup, olası suiistimallerin de TCK kapsamında değerlendirilmesi bu sürecin önemini ortaya koymaktadır.

Hizmet alımı ve yapım işlerinde, yapılan işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.

Düzenlenen hakedişe, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne göre eklenmesi gereken belgeler eklenerek ve ödeme emri belgesi düzenlenerek muhasebe birimine intikal ettirilir. Buralarda da ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ödeme gerçekleşir. Süreçte bazı işlemlerin KBS üzerinden yürütülmesi söz konusudur.

İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir.

Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır.

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

32. Doğrudan temin yönteminde fiyat farkı ödenebilir mi?

Özet: *Fiyat farkı hesabında uyulacak esas ve usuller 4735 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi gereğince Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararları'yla yürürlüğe konulan "Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar" ile düzenlenmiş olup, söz konusu esaslar ile belirlenen ilkeler çerçevesinde mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin fiyat farkı ödenmesi öngörülmektedir. Anılan Esaslardaki düzenlemeler uyarınca doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda da fiyat farkı hesaplamasına yönelik düzenlemeler yapılması mümkündür. Bu bağlamda, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, bu hususun onay belgesinde belirtilmesi ve alıma ilişkin dokümanlarda (sözleşmelerde) da bu konuya ilişkin açık bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, fiyat farkı uygulamasının söz konusu olması durumunda, 4734 sayılı Kanun'un doğrudan temine ilişkin 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirlenen parasal limitin aşılmaması gerekliliğine dikkat edilmesi gerekir.*

Doğrudan teminin tanımını yaparak giriş yapacak olursak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde; Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, "Doğrudan temin" başlıklı Kanun'un 22'nci maddesi incelendiğinde ise, doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve

sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir.

Bununla birlikte, bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise, madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

Söz konusu hükümler uyarınca, belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarenin takdirindedir.

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu Yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanmasındaki süreç ise bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine gerçekleşmektedir. 4735 sayılı Yasa'nın 36'ncı maddesi uyarınca da anılan Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

4735 sayılı Kanun, Kamu İhale Kanunu'na tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsamakta olup, Kanun'a göre düzenlenecek sözleşmelerde; ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceği gibi, Kanun'da belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı ve ek sözleşme düzenlenemeyeceği yine aynı Kanun'la ifade edilmiştir.

Yine anılan Yasa hükmü uyarınca, kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği gibi, Kanun'un yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

4735 sayılı Yasa'nın "Fiyat farkı verilebilmesi" başlıklı 8'inci maddesi ise;

"Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından bu fıkraya göre sonuçlandırılması hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenir.

22/9/2012 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt giderinin oluşturduğu ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla fesih veya tasfiye edilmeksizin geçici kabulü yapılmış işler ile devam eden işlerin, 22/9/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olarak özel tüketim vergisinde gerçekleşen artış nedeniyle fiyat farkı hesaplanmasında 3l/8/20l3 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır."

Hükmüne amirdir.

Yukarıda yer verilen yasa hükmünün ilk fıkrası çerçevesinde, ihalelerde uygulanacak fiyat farkına ilişkin Esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenerek 31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Sonrasında ise Fiyat Farkı Esaslarında değişikliğe gidilerek 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yeni Fiyat Farkı

Esasları ile birçok yenilik getirilmiş olup, getirilen yeniliklerden biri de doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların Esaslar kapsamına alınmasıdır.

Bu bağlamda, Esaslar'ın "Kapsam" başlıklı 2'nci maddelerine, *"...4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin usulüyle yapılan ve birinci fıkrada fiyat farkı hesaplanabileceği öngörülen (mal)hizmet alım (ve yapım işi)sözleşmelerinde bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir."* hükmü eklenmiştir.

Fiyat farkına ilişkin esaslar özü itibarıyla ihale kapsamı alımlar için düzenlenmiş olmakla birlikte, yapılan düzenlemelerden sonra doğrudan temin yönteminin de bu kapsama alınması nedeniyle, alım türleri açısından esaslar ayrı ayrı belirtilerek, doğrudan temin yöntemi alımlarla bağlantısı ortaya konulacaktır.

Bu noktada, söz konusu Esaslara baktığımızda ise, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda fiyat farkı ödenmek isteniyorsa doküman ve sözleşmelerde bu konuya ilişkin açık düzenleme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Aşağıda ise söz konusu düzenlemelerden bağlantısı olan hususlara özetle yer verilmiştir.

A) 4735 sayılı Kanun'un 8'inci maddesine dayanılarak hazırlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen **Mal Alımlarında** Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uyarınca; Esaslarda geçen;

Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemleri için; götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları için bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli,

Götürü bedel: İdarece miktarı belirlenen mal için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan toplam bedeli,

Sözleşme: Birim fiyat veya götürü bedel teklif almak suretiyle Türk parası cinsinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

ifade etmektedir.

- (1)4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Türk parası üzerinden sözleşmeye bağlanan;

a) Elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında,

b) (a) bendi dışında kalan ve sözleşme süresi 180 takvim gününden fazla olan mal alımlarında teslimi 180 takvim gününden sonra yapılan kısım için,

uygulanacak fiyat farkı bu Esaslara göre hesaplanır.

(2) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, söz konusu Kanundan istisna olan ve birinci fıkrada sayılan mal alımlarının ihale dokümanlarında bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir.

(3) *4734 sayılı Kanunun 22'nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin usulüyle yapılan birinci fıkra kapsamındaki mal alım sözleşmelerinde bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir.*

- Bu Esaslara tabi mal alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

- (1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde;

a) 4735 sayılı Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde; verilen süre uzatımının, sözleşmesindeki teslim süresi 3 aydan az olan alımlarda 3 aydan; sözleşmesindeki teslim süresi 3 ay ile 12 ay arasında olan alımlarda ise 6 aydan fazla olması,

b) İdareden kaynaklanan nedenlerle, malın tesliminin sözleşmede öngörülen sürede yapılamaması halinde; sözleşmedeki teslim süresi 3 aydan az olan alımlarda teslimattaki gecikmenin 3 aydan fazla olması, sözleşmedeki teslim süresi 3-12 ay arasında olan alımlarda ise 6 aydan fazla olması,

hallerinde fiyat farkı hesaplanır.

…

(4) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen ihalelerde fiyat farkı verilmesine ilişkin yukarıda belirlenen şartların ortaya çıkması halinde 4735 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi uyarınca süre uzatımı verilmesi nedeniyle belirlenen yeni teslim tarihi, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarih olarak kabul edilerek bu maddede düzenlenmeyen hususlar için 6 ncı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

B) 4735 sayılı Kanun'un 8'inci maddesine dayanılarak hazırlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen **Hizmet Alımlarında** Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

- (1)4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Türk parası üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı bu Esaslara göre hesaplanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinde sayılan hizmetlerden; araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlar gibi nitelikleri itibarıyla kısa süreli hizmetler ile sigorta, muhasebe ve 4734 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde yer alan danışmanlık hizmetlerinden mali ve hukuki nitelikteki hizmetlere fiyat farkı ödenmez.

  (2) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, bu Kanundan istisna olmakla birlikte birinci fıkra kapsamında fiyat farkı hesaplanabileceği öngörülen hizmet alımlarının ihale dokümanlarında bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir.

(3) *4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin usulüyle yapılan ve birinci fıkrada fiyat farkı hesaplanabileceği öngörülen hizmet alım sözleşmelerinde bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir.*

- İdari şartnamesi ile sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak gerçekleştirilen iş kalemleri ya da iş grupları için fiyat farkı hesaplanır.

C) 4735 sayılı Kanun'un 8'inci maddesine dayanılarak hazırlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen **Yapım İşlerinde** Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

- 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Türk parası üzerinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkı bu Esaslara göre hesaplanır.

(2) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, bu Kanundan istisna olan yapım işlerinin ihale dokümanlarında bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir.

(3) *4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin usulüyle yapılan yapım işi sözleşmelerinde bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir.*

- Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

- İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

Yukarıda yer verilen farklı alım grupları için geçerli olan esaslarda yer aldığı üzere, yapılan düzenlemelerden sonra esaslara göre hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması durumunda doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar için de fiyat farkı ödenebilmektedir.

Fiyat farkı hesabında uyulacak esas ve usuller 4735 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi gereğince Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı'yla (Cumhurbaşkanı Kararları'yla) yürürlüğe konulan "Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar" ile düzenlenmiştir. Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin "fiyat farkı esasları" yürürlüğe konulmuştur. Anılan Esaslardaki düzenlemeler uyarınca doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplamasına yönelik düzenleme yapılması mümkündür.

Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde bu hususun onay belgesinde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca doküman ve sözleşmelerde de bu konuya ilişkin açık düzenleme yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan fiyat farkı uygulaması ile 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki parasal limitin aşılmaması uygun olacaktır.

Ayrıca, 7221 sayılı Yasa'nın 30'uncu maddesi uyarınca 4735 sayılı Yasa'ya 2020 yılında eklenen Ek Madde (Ek Madde 1) gereğince; Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında; sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görevli ve yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Yasa'nın "Görevlilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 60'ıncı maddesinde; İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17'nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılacağı ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği, Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlilerinin, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyecekleri, bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanların, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamayacakları ve görev alamayacakları, 5'inci maddede belirtilen ilkelere ve 62'nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı yönünde hükmün yer aldığı görülmektedir.

Benzer şekilde, 4735 sayılı Yasa'nın "Görevlilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 28'inci maddesi uyarınca; Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre

haklarında ceza kovuşturulması da yapılacağı ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği, bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyecekleri, bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanların, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamayacakları ve görev alamayacakları hükme bağlanmıştır.

Görüldüğü üzere; her iki Yasa'da da Kanun'un temel ilkelerine aykırılıklar yaptırıma bağlanmış olup, fiilin niteliğine ve kasıt unsurunun varlığına bağlı olarak, idari cezaların yanında, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçları duruma göre söz konusu olabilmektedir.

Bu meyanda, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesindeki *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…"* hüküm ve ilkelerinin süreçte dikkate alınması ve bu ilkeler çerçevesinde hareket edilmesinin olası riskler asgariye indireceği düşünülmektedir.

33. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda damga vergisi kesilir mi?

Özet: *Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme düzenlendiği takdirde sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerekir. Sözleşme düzenlenmemesi durumunda ise sözleşme damga vergisi tahsil edilmeyeceği açıktır. Dolayısıyla, idarelerin doğrudan temin kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir. 4734 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesine uygun bir ihale komisyonun kurulduğu ve bu komisyonunun yaptığı piyasa araştırması sonucunda uygun görülen kişiden alım yapılmasına yönelik bir karar alındığı ve bu kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde binde 5,69 oranında damga vergisi kesilmesi gerekir. Kanun'a uygun bir ihale komisyonunun kurulmadığı, bir veya birden fazla kişi görevlendirilerek yapılan piyasa araştırması sonucunda düzenlenen ve ihale yetkilisince onaylanan piyasa fiyat araştırması tutanağına dayalı olarak yapılan alımlarda ise, binde 5,69 oranında damga vergisi hesaplanmasına gerek bulunmadığı düşünülmektedir. Sözleşme düzenlenmeyen durumlarda ise sözleşme damga vergisi doğmayacağından, damga vergisi tahsil edilmesi söz konusu olmayacaktır. İhale kararı alınmaması ve sözleşme düzenlenmemesi durumunda sadece alıma ait tutarın ödenmesi esnasında, ödeme emri üzerinden damga vergisi kesilmesi gerekmektedir.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların, Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun "konu" başlıklı 1'inci maddesinde, damga vergisine tabi kâğıtlara (1 sayılı Tablo), 9'uncu maddesinde ise istisna edilen yazılı kağıtlara ilişkin bilgilere (2 sayılı Tablo) yer verilmiştir.

Söz konusu Kanun'a ekli (1) sayılı tablonun I.Akitlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli bir parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 9,48 nispetinde, II-Kararlar ve mazbatalar bölümünün 2'nci fıkrasında ise, (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 5,69 oranında damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu Kanun'daki kağıtlar teriminin ise, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği anlaşılmaktadır.

Aynı Kanun'un 3'üncü maddesinde ise; damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer bir anlatımla, vergiye tabi kâğıtların tanzim edilmesi, damga vergisinin doğabilmesi için düzenlenmiş bir kağıdın varlığı yeterli kabul edilmekte, vergiyi doğuran olay ise söz konusu işleme ilişkin kağıdın düzenlenmesi aşamasında doğmaktadır. Yani, bir kağıdın imzalı şekilde tanzim edilmiş olması damga vergisinin gerçekleşmesi için vazgeçilmez unsur olarak kabul edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği'nde;

"22.1.1.2. Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

22.1.1.3. Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci

maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur."

Hususları yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun uyarınca, doğrudan temin uygulamasında sözleşme yapma zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve bu husus tümüyle idarelerin takdirine bırakılmıştır. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir. Her ne kadar doğrudan temin yönteminde ihale komisyonu kurulması zorunlu değilse de eğer komisyon teşekkül ettirilerek karar alınmışsa, ihale komisyonunun aldığı karardan da damga vergisi kesintisinin yapılması gerekmektedir.

Bu paralelde, bir kağıdın damga vergisine konu edilebilmesi için;

- Düzenlendiği anda herhangi bir hususu ispat ve belli etmek için ibraz edilebilecek belge vasfında olması,
- Aynı zamanda söz konusu kağıdın 488 sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı tabloda yer alması.

şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.

Dolayısıyla, bu vasıflara sahip kağıda ilişkin damga vergisi, bu kağıdın düzenlenip imzalandığı anda doğacağını, böylelikle, damga vergisinde vergiyi doğuran olayın vergiye tabi kağıdın imzalandığı anda meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Diğer bir anlatımla, vergiye tabi kâğıtların tanzim edilmesi, damga vergisinin doğabilmesi için düzenlenmiş bir kağıdın varlığı yeterli kabul edilmekte, vergiyi doğuran olay ise söz konusu işleme ilişkin kağıdın düzenlenmesi aşamasında doğmaktadır. Yani, bir kağıdın imzalı şekilde tanzim edilmiş olması damga vergisinin gerçekleşmesi için vazgeçilmez unsur olarak kabul edilmektedir.

Doğrudan temin yöntemiyle, alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarenin takdirindedir.

Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar

nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir.

Bu bağlamda, doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda da damga vergisinin tahsilinin söz konusu olabileceğini, idarece belli bir parayı ifade eden sözleşmenin yükümlü ile imzalanması durumunda ise damga vergisinin tahsil edilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade edebiliriz.

İhale komisyonu kurmanın veya sözleşme imzalamanın idarenin takdirinde bulunduğunu, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile yapılan alımlarda, ihale komisyonu adı dışında her ne ad altında olursa olsun idare tarafından oluşturulacak komisyonların veya görevlendirilecek kişilerin, alım kararlarının, piyasa ve fiyat araştırması sonucunda verecekleri kararların, Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan 44 Seri No.lu Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bu çerçevede, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda damga vergisi uygulamalarının ne şekilde yürütüleceği Hazine ve Maliye Bakanlığı (mülga Maliye Bakanlığı) tarafından yayımlanan 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanmış olup, söz konusu Tebliğde;

"*İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi gereğince yaptıkları alımlar sırasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulamasının aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.*

Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu maddede belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceği belirtilmiş, aynı maddenin son fıkrasında da, "Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

Hususlarına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ hükümlerine göre, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların, idarenin takdiriyle ihale komisyonu kurmadan ve bu komisyonun aldığı bir ihale kararı olmadan ve sözleşme yapılmadan gerçekleşmesi durumunda damga vergisi kesintisinin yapılmaması, ihale kararı veya sözleşmeden herhangi birinin veya her ikisinin de mevcut olması halinde damga vergisinin uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2'nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı hususu düzenleme altına alınmış, aynı Kanun'a ekli (1) sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2'nci fıkrasında ise, (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 5,69 oranında damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale karar vergisi kesilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir. Zira ihale karar vergisi kesilebilmesi için ihale komisyonu kurularak bir ihale kararının alınması gerekmektedir. Doğrudan teminle yapılan alımlarda ise böyle bir husus söz konusu değildir.

Ancak doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale komisyonu kurulması zorunlu olmamakla birlikte Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2'nci maddesinde yer alan; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki açıklama gereği, ihale yetkilisi isterse bir alım komisyonu kurabilir. Doğrudan teminle yapılan alımların komisyon marifetiyle yapıldığı durumlarda sözleşme bedelinin binde 5,69 oranında damga (karar pulu) vergisi tahsil edilmesi gerekir.

Bu itibarla, birden fazla üye görevlendirmek suretiyle ihale komisyonuna benzer şeklinde alım

komisyonu teşekkül ettirilirse alınan kararda yazılı KDV hariç bedel üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır. Şayet bir kişi görevlendirilmek suretiyle alım komisyonu kurulmadan mal ve hizmet alımı yoluna gidiliyor ise, komisyon kararı bulunmadığından binde 5,69 oranındaki damga vergisinin ödenmesine gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlara ilişkin olarak sözleşme imzalanmış ise, binde 9,48 oranında damga vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla aksi durum olan, sözleşme düzenlenmemiş olması durumunda, damga vergisi tahsil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Yani sözleşmenin varlığı bu hususta vergisel anlamda belirleyici olmaktadır.

34. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda ihale karar pulu (vergisi) alınır mı?

Özet: *Doğrudan temin bir alım yöntemi olup, 4734 sayılı Yasa'da öngörülen ihale usullerinden olmaması nedeniyle, ihale usulleri için getirilmiş kriterlerin bu yöntem için uygulanması mümkün değildir. İdareler doğrudan temin yöntemine göre yaptıkları alımlarda genel olarak sözleşme serbestisi hükümlerine göre hareket ederler. İdarelerin Kanun'un 22'nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşme düzenlemesi halinde bu sözleşmenin, kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde de ayrıca bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir. Bu itibarla, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda ihale kararı alınmamışsa, ihale kararı alınmasını gerektirir bir ihale komisyonu kurulmamışsa ve buna yönelik ihale yetkilisi oluru süreci oluşturulmamışsa, doğrudan teminde ihale karar pulu kesilmez.*

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

Söz konusu ihtiyaçlar, doğaları gereği ihale açılarak temini mümkün olmayan, işin doğası, piyasa koşulları ve çeşitli yasal düzenlemelerle idarelerin tercih hakkının ortadan kalktığı ihtiyaçlardır. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın bu kapsamda karşılanması söz konusu değildir; doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir yöntemdir.

5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu İhale Mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama

yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır. Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı Kanun'a göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi nitelikleri itibariyle aynı mahiyette belgelerdir.

Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir.

Doğrudan temin kapsamında da olsa belli durumlarda vergisel durum söz konusu olabilir. Keza 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar damga vergisine tabidir. Anılan Kanun ile uygulama tebliğlerinde yer alan düzenlemeler uyarınca doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda alım komisyonu kurulduğunda, sözleşme imzalanıp imzalanmadığına bakılmaksızın, alım bedelinin binde 5,69 oranında sözleşme karar vergisinin (karar pulu) ödenmesi gerekir. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda yazılı sözleşme düzenlendiği durumlarda ise sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli 1 Sayılı Tablonun I-A Akitlerle İlgili Kağıtlar Bölümünün I-a bendi belli parayı ihtiva eden sözleşmelerden ihale bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi kesilmesini öngörmektedir. Sözleşme düzenlenmemesi durumunda ise sözleşme damga vergisi tahsil edilmesine gerek yoktur. Sözleşme düzenlenmediği durumlarda iş için kesilen faturaların sözleşme yerine geçmeyeceğinin bilinmesi gerekir.

Konuyla bağlantılı fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kıyas yoluyla sözleşme olarak kabul edilmeyeceği hakkında Sayıştay 1.Dairenin 21.03.2006 tarihli Kararı'nda;

...4914 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle doğrudan temin usulü ihale usulleri arasından çıkarılmış olup, bu tür alımlarda sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Kıyas yoluyla vergi ihdas edilemeyeceği, vergi hukukunun temel ilkelerinden olması nedeniyle de, doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarında sözleşme düzenlenmemesi durumunda, fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kıyas yoluyla sözleşme olarak kabul edilmesi mümkün

değildir.
Dolayısıyla söz konusu alım nedeniyle sözleşme damga vergisi kesilmemesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

Hususlarının yer aldığı görülmektedir.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2'nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı hususu düzenleme altına alınmış, aynı Kanun'a ekli (1) sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2'nci fıkrasında ise, (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 5,69 oranında damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

16.04.2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ise;

"Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir." şeklinde düzenlenmiştir.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale karar vergisi kesilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir. Zira ihale karar vergisi kesilebilmesi için ihale komisyonu kurularak bir ihale kararının alınması gerekmektedir. Doğrudan teminle yapılan alımlarda ise böyle bir husus söz konusu değildir.

Ancak doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale komisyonu kurulması zorunlu olmamakla birlikte Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2'nci maddesindeki "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık*

sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir." şeklindeki açıklama gereği, ihale yetkilisi isterse bir alım komisyonu kurabilir. Doğrudan teminle yapılan alımların komisyon marifetiyle yapıldığı durumlarda sözleşme bedelinin binde 5,69 oranında damga (karar pulu) vergisi tahsil edilmesi gerekir.

Diğer taraftan, piyasa fiyat araştırması tutanağının ihale yetkilisi tarafından imzalanması da ihale karar damga vergisi kesilmesi gerekliliği anlamına gelmemektedir. Keza ortada bir alım komisyonunun mevcudiyeti söz konusu değildir.

Zira artırma ve eksiltmeye tabi ihalelerden damga vergisi alınmaktadır. İhale karar damga vergisi ile karar pulu aynı anlama gelmektedir.

İhale karar pulunun dayanağı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'dur. 488 sayılı Kanun'a göre kağıtlardan damga vergisi alınmakta ve ekli 1 sayılı cetvelde yazılı kağıtlardan damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır. Ekli cetvelde ise;

"İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)" hükmü yer almaktadır:

Kanun'da resmi daire ve kamu tüzel kişiliği ifadelerine yer verildiğinden dolayı, ihale karar pulunun bu kapsamdaki idarelerde geçerli olacağını ifade edebiliriz. Bu bağlamda, belediye şirketleri ve kitler tarafından yapılan ihalelerde karar pulu alınmasının mümkün olamayacağını söyleyebiliriz.

Yukarıdaki hükümde, ihalenin yüklenicinin kusuru olmaksızın iptal edilmesi halinde hükmünden faydalanılmayan kısmının iade edileceği ifade edilmektedir. Yani, yüklenici kusuru ile sözleşme imza edilmemiş ise ihale karar pulunun alınması gerekir.

İhale karar pulu, ihale damga vergisi verilen ihale kararı üzerinden hesap edilir. Yani, ihaleyi alan firmanın attığı teklif bedeli matrah kabul edilip, bu matrah binde 5,69 oranı ile çarpılmak suretiyle, ihale karar pulu tutarına ulaşılır.

Bunlara ilave olarak, 4734 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi uyarınca; Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli Birmilyondörtyüzellialtıbinikiyüziki Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi Kamu İhale Kurumu payı olarak Kurum hesaplarına yatırılmalıdır. İdareler ve noterler, Kamu İhale Kurumu payının yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadırlar. Doğrudan temin yöntemi, bir ihale usulü olmadığından, bu yöntemle yapılan alımlara ilişkin düzenlenecek sözleşmeler üzerinden sözleşme bedeli ne olursa olsun Kamu İhale Kurumu payı tahsil edilemeyeceğinin bilinmesi gerekir.

35. Doğrudan temin kapsamı alımlarda süre uzatımı verilebilir mi?

Özet: *4735 sayılı Yasa'da süre uzatıma gerektiren hususlar ayrıntılı olarak yer almakla birlikte, süre uzatımına ilişkin bu düzenlemeler ihale usulleri kapsamı alımlar için geçerli olup, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda satıcıya süre uzatımı verilebileceği konusunda mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kuşkusuz doğrudan temin kapsamı alımlar için Yasa'nın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla alım sürecinde sözleşme düzenlenerek süre uzatımı verilmesini gerektiren durumlar, sözleşmeye yansıtılabilir. Dolayısıyla, satıcıya süre uzatımı verilmesi öngörülmekte ise kendisiyle sözleşme yapılması ve Kamu İhale Kurumunca hazırlanan sözleşme tasarıları (tip sözleşmeler) esas alınarak bu sözleşmenin ilgili maddelerinde bu duruma yer verilmesi uygun olacaktır. Ancak tip sözleşmelerin aynen kullanılması zorunluluğu bulunmamakta olup, idare temel hususları göz ardı etmeyen farklı bir sözleşme de tasarlayıp kullanabilir.*

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde; Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, "Doğrudan temin" başlıklı Kanun'un 22'nci maddesi incelendiğinde ise; doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak, belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir.

4734 sayılı Yasa'da yapılan değişiklikle, doğrudan temin bir ihale usulü olmaktan çıkarılmakla birlikte, Yasa'nın diğer maddelerinin bu değişikliğe uygun olarak yeniden düzenlenmemesi nedeniyle, doğrudan temine ilişkin temel düzenlemelerin mevcut durum itibarıyla, anılan Kanun'da yer aldığını görmekteyiz.

Bununla birlikte, doğrudan teminin bir ihale çeşidi olarak düzenlenmemesi nedeniyle diğer ihale usulleri için uygulanan bazı düzenlemeler, doğrudan temin için uygulanmamaktadır. Ayrıca, doğrudan temin şekli alımlarda, Kamu İhale Kurumu tarafından herhangi bir inceleme ve uygulamanın doğruluğunun kontrolü yapılmaz.

Doğrudan temin uygulamasında şartname ve sözleşme düzenlenmesi idarenin takdirinde olmakla birlikte, özellikle süreli alımlarda yani işin gerçekleştirilmesinin belli bir süreye bağlı olduğu mal, hizmet veya yapım işlerinde sözleşme düzenlenmesinin gerekli olduğunu ifade edebiliriz. Bu tür alımlarda, idare sadece sözleşme düzenleyebileceği gibi idari ve teknik şartnameler de hazırlayabilecek ve bunları sözleşmenin bir parçası olarak kullanabilecektir.

Doğrudan temin yönteminde, ihale mevzuatında öngörülen usul ve esasların, belli ölçüde dışına çıkarılarak ihtiyaçların kısa sürede karşılanması şeklinde tanımlayabiliriz. İdarenin acil nitelikteki bazı ihtiyaçlarının kısa sürede temin edilmesi bazen zorunluluk arz edebilir. Ayrıca, parasal miktarı düşük olan her mal ve hizmet temininde ihale usullerinin uygulanması çoğu zaman ekonomik olmayabilir. Hatta bazen idarenin yeterli insan kaynağı da olmayabilir.

Bu çerçevede, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda satıcıya süre uzatımı verilebileceği konusunda mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Satıcıya süre uzatımı verilmesi öngörülmekte ise kendisiyle sözleşme yapılması ve kamu ihale sözleşme tasarıları esas alınarak hazırlanacak sözleşmede bu hususlara yer verilmesi uygun olacaktır.

4734 sayılı Kanun'u tamamlar nitelikte, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ise, sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemekte olup, anılan Kanun'da hüküm bulunmayan durumlarda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.

Nitekim 4735 sayılı Yasa'nın "Mücbir sebepler" başlıklı 10'uncu maddesinde;

"- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur."

Düzenlemesi yer almaktadır.

4735 sayılı Yasa'nın "Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi" başlıklı 23'ncü maddesi ise; "Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir." hükmüne amirdir.

Aynı Kanun'un "Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi" başlıklı 24'üncü maddesi ise;

"*Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;*

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında %40 'a kadar artırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir."

Şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca, Kanun hükümleri dışında alt düzey düzenlemelerde de süre uzatımına ilişkin hususlar yer almaktadır. Bu çerçevede ihale kapsamı alımlar için geçerli olan tip dokümanlarda (örnek olarak hizmet alımları sözleşme tasarısı aşağıda yer almaktadır) süre uzatımı hususuna ilişkin olarak;

"Madde 17- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

17.1.1 Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:
17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
17.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır."

Hususları yer almaktadır.

Görüldüğü üzere; ihale kapsamı alımlar için esas olarak 4735 sayılı Kanun hükümleri olmak üzere, alt düzey dokümanlarda süre uzatımına ilişkin esaslar ortaya konulmuştur. Mevzuatın bir anlamda özeti diyebileceğimiz tip dokümanlar da bu esaslara göre hazırlanmış olup, özetle yukarıdaki hususları kapsamaktadır.

Bahse konu tip dokümanlara ilişkin sözleşme tasarılarında (hizmet ve yapım işi için) yer aldığı gibi, sözleşme tasarılarında yer verilen hususların haricinde sözleşmenin ayrılmaz parçası konumundaki genel şartnamedeki düzenlemelerin de esas alınması gerekir. Şüphesiz bu hususta idarenin farklı bir düzenleme yapması durumunda, imzalanan sözleşmede yer alan düzenlemelerin geçerli olması gerekmektedir.

Söz konusu genel şartnamelerde ise, alımın niteliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek farklı koşullara ait durumlar açıklığa kavuşturulmaktadır.

Nitekim örnek olarak Yapım İşleri Genel Şartnamesine baktığımız zaman, söz konusu genel şartnamenin "İşin süresi ve sürenin uzatılması" başlıklı 29'uncu maddesi;

" İşin veya kısmi kabul öngörülen hallerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. Cezalı çalışma süresi; varsa süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi

arasında geçen süredir. Sözleşmenin idarece feshedilmesi halinde ise bu süre; 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasına göre sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı tarih dikkate alınarak belirlenir. Cezalı çalışma süresince işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır.

(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(3) İkinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

(4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

(5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.

(6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.

(7) Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde, idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından

usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik etmesi zorunludur. Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. Ancak idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz.

(8) Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

(9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir."

Şeklinde düzenlenmiştir.

Yapım işleri için geçerli olan bu husus, mal veya hizmet alımları için ana esaslar ışığında detay düzenlemelere tabii olabilir. Söz konusu tip dokümanlar birbirine benzemekle birlikte, hizmet alımı ve yapım işine ait genel şartname bulunmasına karşın, mal alımlarında bulunmamaktadır.

Görüldüğü üzere; süre uzatımı verilebilecek haller, ihale mevzuatı uyarınca;

a) Mücbir sebep nedeniyle,
b) İdareden kaynaklanan nedenlerle,
c) İş artışı yapılması durumunda,

mümkündür.

Ancak, Yasa'nın 10'uncu maddesi çerçevesinde, süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;

- yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,

- taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
- yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
- mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması
- ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

Gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen süre uzatımı ilişkin düzenlemeler ihale usulleri kapsamı alımlar için geçerli olmakla birlikte, kuşkusuz doğrudan temin kapsamı alımlar için Yasa'nın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarece, alım sürecinde sözleşme hazırlanarak süre uzatımı verilmesini gerektiren durumlar bu sözleşmeye yansıtılabilir.

Nitekim Sayıştay Temyiz Kurulunca verilen bir Kararda; "*4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin d bendine göre yapılan alımlar idarelerin ihtiyaçlarının temininde istisnai bir yöntem olup sınırlı durumlarda başvurulmaktadır. İhtiyacın giderilmesi acil olup da beklemeye tahammülü olmayan durumlarda idare bu yöntemle hemen ihtiyacını karşılayacaktır. Bu nedenle Kanunda bu alım yöntemi ile idarelere geniş bir takdir alanı tanınmıştır. Bunlardan biri de, sözleşme yapıp yapmama serbestliğidir. ihtiyacının doğrudan temin yoluyla karşılanmasında kamu yararı olduğunu dikkate alarak idare ile satıcılar arasında sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmelere, malzemenin zamanında teslim edilmemesi halinde gecikme cezası kesilmesi yönünde hükümler konulmuştur. Kanunlara aykırı olmayan sözleşme hükümlerinin uygulanması da zorunlu olup, tarafları bağlar."* ifadelerine yer verilerek, doğrudan teminde düzenlenen sözleşmelerin tarafları bağladığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da idarelerce sözleşme düzenlenmesi koşuluyla, ihale mevzuatının temel ilkeleri ışığında, süre uzatımı verilebilecek haller belirlenebilir. Belirlenecek bu haller ise taraflar için bağlayıcılık anlamı taşımaktadır.

36. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

Özet: *Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Doğrudan temine ilişkin açıklamalar" başlıklı 22'nci maddesi uyarınca, madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur. Şayet idarece şartname ve sözleşme düzenlenmesi söz konusu ise, bu gibi durumlarda; İhale Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan Tip Sözleşme ve Tip Şartnameleri kullanılma zorunluluğu, 4734 sayılı Kanun'un 27'nci maddesinde düzenlenen idari şartnamede bulunması zorunlu hususlara uyma zorunluluğu, 4735 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinde düzenlenen sözleşmede bulunması zorunlu hususlara uyma zorunluluğu olmaksızın, işin niteliğine göre; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşme metni kullanılabilecektir. Bu bağlamda, doğrudan temin yöntemiyle bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda da İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesinin mümkün olduğunu ifade edebiliriz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu Yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanmasından sonraki süreç ise bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre şekillenmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların açık ihale usulü ile veya Kanun'daki şartların bulunması halinde belli istekliler arasında ihale usulü ya da pazarlık usulü ile ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi şeklinde doğrudan temin kapsamı alımları özetleyebiliriz.

Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

Doğrudan temin kapsamı ihtiyaçlar, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar olup, doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir satın alma yöntemidir.

4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. maddesinde yer alan; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenleme ile sözleşme yapma konusunda idareler (sözleşme düzenlenmesini gerektiren istisnai durumlar hariç olmak üzere) serbest bırakılmıştır.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'da belirtilen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

Doğrudan temin kapsamı alımlarda yazılı sözleşme düzenlenmesi zorunlu değildir. Ancak Yasa'nın 22'nci maddesinin (c) bendine göre yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunludur. Alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin veyahut yapım işinin belli bir süreyi

gerektirmesi durumunda (ifası zaman alacak alımlarda) da yazılı bir sözleşmeye düzenlenmesi zorunludur. Bu iki durum dışındaki doğrudan temin ile yapılacak alımlarda yazılı sözleşme yapılıp yapılmaması idarelerin takdirindedir.

Yazılı sözleşme yapılması durumunda, ihale uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan tip sözleşme tasarılarının kullanılması zorunlu olmamakla birlikte, alımın niteliği dikkate alınarak ilgili ihale uygulama yönetmeliğinin ekindeki tip sözleşmelerin kullanılmasına da engel bir durum yoktur.

Aynı şekilde, doğrudan temin bir ihale yöntemi olmadığı için ihale uygulama yönetmelikleri ve eklerinde yer alan hususlar doğrudan temin için geçerli değildir. Bu bağlamda, doğrudan teminde yapılan sözleşmelere ilişkin olarak Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasından hareketle, taraflar anlaştıklarında sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler.

Bunlarla birlikte, her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlarda, sözleşme düzenlenmesi istisnai durumlar hariç idarenin takdirinde olmakla birlikte, teminat alınması, cezai yaptırımlar öngörülmesi gibi uygulamaların tercih edildiği durumlarda yazılı sözleşme düzenlenmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir. Keza bahse konu hususların ispatı yazılı sözleşme düzenlenmesi ile netlik kazanabilecektir.

Sözleşme düzenlenmesi hususu idarelerin takdirinde olmakla birlikte, daha sonra doğabilecek ihtilafların önlenmesi için, hazırlanacak sözleşme tasarısı ve idari şartname, fiyat araştırması yapılan kişilere verilmelidir.

Doğrudan temin, süreklilik arz etmeyen, Kanun'da belirtilen limitler dahilinde ihtiyaçların anında temin edilmesi ve ihale için belirlenen prosedür ile uğraşılmadan alınmasına ilişkin bir yöntemdir.

Bu meyanda, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesindeki *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur..."* hüküm ve ilkelerin dikkate alınması gerekir.

Dolayısıyla, alım sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması önem arz etmektedir. Aksi

durumda kamu hizmetinin aksamasının yanında, kamu kaynağının verimsiz kullanımı da söz konusu olabilecektir. Bu nedenle ihalelere başvuran isteklilerde çeşitli kriterlerin aranması, yasal bir zorunluluk olmasından öte kamu kaynağının verimli kullanılması açısından yerinde bir yaklaşımdır.

Bu bağlamda, ihale sürecinde isteklilerin taşıması gereken kriterlerden biri olan "mesleki ve teknik yeterlikler kapsamında", ihale dokümanlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, iş deneyimi belgelerinin idarelere sunulması gerekmektedir.

Öncelikle iş deneyim belgesinin; adayın ve isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren, iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini kapsadığını söyleyebiliriz. İş deneyimini tevsik amacıyla bu dört belgelerin hangilerinin sunulacağı, ihalenin türü ve yaklaşık maliyetin büyüklüğüne göre uygulama yönetmeliklerinde ayrıntılı düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, kamu alımlarının elektronik ortama aktarılmasına bağlı olarak, iş deneyim belgelerinin de EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

Bu itibarla, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP'a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

Yukarıdaki hususlar uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

Ayrıca, ilanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler

tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.

Bu itibarla, ihale kapsamı ve EKAP üzerinden işlemleri yürütülen alımlarda, iş deneyim belgelerinin söz konusu platforma kayıtlı olması gerekmektedir.

İş deneyim belgesi düzenlenme şartlarından birisi iş deneyimine konu işin yazılı bir sözleşmeye bağlanmasıdır. Yazılı sözleşme imzalanan doğrudan temin yöntemine göre yapılan alımlarda diğer şartların gerçekleşmesi koşuluyla, iş deneyim belgesi düzenlenebilir.

Bu çerçevede Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.6. maddesinde; *"Doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür."* açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, sözleşme bedeli tamamlanmış olmakla birlikte iş artışı nedeni ile devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaşması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan iş için düzenlenen ve idareye teslim edilen faturalar sözleşme yerine geçmemektedir.

Sonuç olarak, doğrudan teminle yaptırılan işlerin, bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği durumlarda, söz konusu işler için iş deneyim belgesi düzenlenebilir. Ancak farklı alımların toplanarak tek bir iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi mümkün değildir.

37. Doğrudan temin yönteminde alım sürecinde pazarlık yapılması gerekli midir?

Özet: *4734 sayılı Kanun'da, Doğrudan temin; "Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" olarak tanımlanmıştır. Yasa maddesinde açık olarak görüldüğü üzere; doğrudan temin kapsamı alımlarda, ihtiyaçların karşılanması noktasında, ihtiyacın niteliğinin yanında fiyatının da görüşülmesine yasa hükmü izi vermektedir. Hatta Yasa'nın temel hedeflerinden biri de idare ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanmasıdır ve bu husus temel ilkeler arasında sayılmaktadır. Ayrıca, 5018 sayılı Yasa uyarınca da kaynakların etkin ve verimli kullanılması bir anlamda zorunluluk olup, aksi yöndeki eylemlerin kamu zararına (cezai durumlar hariç olmak üzere) sebebiyet verilmesinden kaynaklı ilave sorumlulukları gündeme getireceği açıktır. Bu itibarla, yasa maddesinden yer aldığı üzere, doğrudan temin kapsamı alımlarda, fiyat teklifleri üzerinde idare lehine her zaman görüşme yapılması ve gerekirse daha uygun teklif alınması yönünde çaba gösterilmesinin, hukuki ve uygun bir hareket tarzı olduğunu söyleyebiliriz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu olup, Kanun'un 18 inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca 22'nci maddesinde, Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmış ve bir alım yöntemi olarak 4734 sayılı Yasa'da yer almaya devam etmiştir.

Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları öncelikli olarak ihale usulleri kapsamında ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir. Ayrıca idarelerin, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların, Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi şeklinde doğrudan temin kapsamı alımları özetleyebiliriz.

Bunların dışında, satın alma sürecinde ihale usulleri için öngörülen diğer kuralların ve işlemlerin göz ardı edilmesi veya uygulanmamasına ilişkin açık bir hüküm Kanun'da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, doğrudan temin için geçerli olan temel kuralların da süreçte dikkate alınması gerekmektedir.

Doğrudan temin kapsamı ihtiyaçlar, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar olup, doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir satın alma yöntemidir. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın doğrudan temin kapsamında karşılanması mümkün değildir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. bendinde yer alan, "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenleme ile sözleşme yapma konusunda idareler (sözleşme düzenlenmesini gerektiren istisnai durumlar hariç olmak üzere) serbest bırakılmıştır.

Bunlarla birlikte, belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da yükleniciden teminat alınması, cezai yaptırımlar ön görülmesi, kabulle ilgili bir kısım prosedürler veya kabul sonrası sorumluluklar getirilmesi gibi geçerliliği yazılı kurala ihtiyaç gösteren durumlarda da yazılı sözleşme düzenlenmesi yararlı olacaktır. Keza, bahse konu hususların ispatı yazılı sözleşme düzenlenmesi ile netlik kazanabilecek niteliktedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, doğrudan teminin bir ihale usulü olmaması ve ayrıca, içerdiği kolaylıklar nedeniyle, idareler açısından ihtiyaç konusu mal, hizmet veya yapım işinin temininde öncelikle başvurulan bir yöntem olmuştur.

Doğrudan temin yöntemi alımlarda, piyasa fiyatı araştırması yapılırken öncelikle yakın çevrede araştırma yapılması tercih edilebilir. Şayet bu bölgedeki fiyatlar piyasa fiyatını yansıtmıyor ise buna göre değerlendirme yapılıp kamu yararı ilkesi ışığında daha geniş bir alanda araştırma

yapabilir.

İdarelerin doğrudan temin kapsamında en çok kullandığı alım türü ise, Kanun'un 22/d maddesi kapsamında yer verilen ve her yıl Kamu İhale Tebliğince güncellenen "parasal tutarlar kapsamında aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar" oluşturmaktadır. Bu kapsamda belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Doğrudan temin kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında pazarlık yapılmalıdır. Tek satıcı ya da özel hak sahibi olma hali kapsamında da idare ihtiyacının karşılanması pazarlığa engel olmayıp; bunun mümkün olduğu her durumda, idare yasal sebepten dolayı pazarlık yapmak zorundadır. Ancak doğrudan temin kapsamındaki pazarlık bir ihale usulü olan ve Yasa'nın 21'inci maddede düzenlenen pazarlık usulü ile karıştırılmaması gerekir. Doğrudan temin kapsamında yapılacak pazarlık (görüşme) sadece alımın niteliği ile sınırlı olmayıp isteklinin fiyat teklifinden indirim yapmasını da kapsamaktadır.

4734 sayılı Kanun'un "Tamımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; Doğrudan temin; "Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" olarak tanımlanmıştır.

Yasa maddesi hükmünde açık olarak görüldüğü üzere; doğrudan temin kapsamı alımlarda, idare ihtiyaçların karşılanması noktasında alım konusunun niteliğinin yanında fiyatının da görüşülmesine yasa izin vermektedir.

Hatta Yasa'nın temel amaçlarında idare ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanmasına vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, 5018 sayılı Yasa uyarınca da kaynakların etkin ve verimli kullanılması bir anlamda zorunluluk olup, aksi yöndeki eylemlerin kamu zararına (cezai durumlar hariç olmak üzere) sebebiyet verilmesinden kaynaklı sorumlulukları gündeme getireceği açıktır.

Bu itibarla, Yasa maddesinden yer aldığı üzere, doğrudan temin kapsamında alımlarda fiyat teklifleri üzerinde idare lehine her zaman görüşme yapılması ve gerekirse daha uygun teklif alınması yönünde çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Pazarlık yapılması ve daha uygun teklif alınması durumunda, ileride hukuki bir sorun yaşanmaması için bu tekliflerin yazılı olarak alınması ve yetkili teklif sahibine imzalatılması doğru bir yaklaşım olacaktır.

5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı'nda yer aldığı üzere, harcama sürecinde görev alanların sorumluluğu bulunmaktadır. İdari sorumluluğunun yanında, ilgililerce yapılan hatanın niteliğine bağlı olarak adli sorumluluk da gündeme gelebilecektir. 5018 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir.

4734 sayılı Yasa'nın temel ilkelerinde belirtildiği üzere, idareler ihtiyaçlarının temin edilmesinde saydamlığı, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılması için sadece kanun hükümlerine uygun olarak ihale usulünün belirlenmesi ile sınırlı olmayıp, bu bağlamda Yasa'nın 22'nci maddesi kapsamında yapılacak alımlarda da, Kanun'un 5'inci maddesindeki rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine riayet edilmesini de bir anlamda zorunlu kılmaktadır.

5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde ise; bütçeden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin, harcama talimatı vermesine bağlanmış, harcama talimatlarında da hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilerin yer alacağı, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken işlemlerden harcama yetkililerinin sorumlu oldukları belirtilmiştir.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde; *"Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden,*

raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır." hükmü; 32'nci maddesinde ise; *"Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur."* hükmü öngörülmüştür.

4734 sayılı Yasa'nın "Görevlilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 60'ıncı maddesi uyarınca da ihale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17'nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılacağı ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği, bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemeyecekleri, bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanların, Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamayacakları ve görev alamayacakları, 5'inci maddede belirtilen ilkelere ve 62'nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı yönünde hükmün yer aldığı görülmektedir.

Anlatılanlar ışığında; 4734 sayılı Yasa hükümleri uyarınca gerçekleştirilen alımlarda uyulması gereken temel ilke ve esaslar bulunmakta olup, bunlara uyulmaması çeşitli adli ve idari yaptırımların uygulanmasını gündeme getirmektedir. Söz konusu kuralların bir kısmı sadece ihale kapsamı alımlar için geçerli iken, bir kısmı ise Kanun kapsamında gerçekleştirilen tüm alımlar için geçerlidir.

Bu bağlamda, Yasa'nın temel ilkelerine tüm alımlarda dikkat edilmesi gerekmektedir. Kanun'un 60'ıncı maddesinde ise, "Temel ilkelere" aykırı hareket eden kamu görevlilerinin karşılaşacakları yaptırımlar ortaya konulmuştur.

Dolayısıyla, idare tarafından alım sürecinde tekliflerin verilmesinden sonra da pazarlık yapılabilir. Yasa'nın "Doğrudan temin"e ilişkin tanımında; "Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" olarak tanımlanmış olup, söz konusu tanım ışığında, fiyatların görüşülmesi veya yeniden teklif alınması mümkündür. Hatta isteklilerle pazarlık yapılmasına da bir engel bulunmamaktadır. Yasa bağlamında idare ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasına yönelik düzenlemelerin de bu bakış açısına uygun olduğunu ifade edebiliriz. Ancak idarece, bu işlemler gerçekleştirilirken eşit muamele ilkesine de riayet edilmesi gerekir. Yani tüm isteklilere aynı şekilde davranılması hukuki bir zorunluluktur.

38. Doğrudan temin kapsamı alımlarda tekliflerin eşit olması durumunda ne yapılması gerekmektedir?

Özet: *4734 sayılı Yasa'da doğrudan temin ihale yöntemi olarak öngörülmediği için, idarece düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısında, tekliflerin eşit olması durumunda nasıl hareket edileceğine yönelik bir düzenleme yapılması ve buna göre hareket edilmesi mümkündür. Ya da piyasa fiyat araştırmasına yönelik yazılarda da buna ilişkin açıklamalara yer verebilir. Şayet nasıl hareket edilmesi gerektiğine yönelik önceden bir belirleme yapılmamışsa ve idarece yapılan piyasa fiyatı araştırması sonucunda, birden fazla uygun ve eşit teklif çıkmış ise, teklif veren isteklilerden tekrar teklif alınması ya da sunulan teklif fiyatını idare lehine daha alt seviye çekmek ve aynı zamanda eşitliğin bozulmasını sağlamak amacıyla teklif bedellerinin isteklilerle görüşülmesinin (bir anlamda pazarlık yapılmasının) uygun olacağı değerlendirilmektedir.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Söz konusu Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır.

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarını karşılanması söz konusudur.

Doğrudan temin kapsamı ihtiyaçlar, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar olup, doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir satın alma yöntemidir. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın doğrudan temin kapsamında karşılanması mümkün değildir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. bendindeki "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme*

düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir." şeklindeki düzenleme ile sözleşme yapma konusunda idareler (sözleşme düzenlenmesini gerektiren istisnai durumlar hariç olmak üzere) serbest bırakılmıştır.

Bunlarla birlikte, her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlarda, sözleşme düzenlenmesi istisnai durumlar hariç idarenin takdirinde olmakla birlikte, teminat alınması, cezai yaptırımlar öngörülmesi gibi uygulamaların tercih edildiği durumlarda yazılı sözleşme düzenlenmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir. Keza bahse konu hususların ispatı yazılı sözleşme düzenlenmesi ile netlik kazanabilecektir.

İhale kapsamı alımlar için 4734 sayılı Kanun ve alt düzey mevzuatta, idarelerce uygulanabilecek tip şartname, tip sözleşme, standart form gibi dokümanlar öngörülmüştür. Bu dokümanların doğrudan temin yönteminde kullanılması zorunlu değildir. Ancak idareler Kanun'un 22'nci maddesi çerçevesinde, diğer ihale usulleri için öngörülmüş bulunan bahse konu şartname ve sözleşme içeriklerinden yararlanarak kendi tercihleri doğrultusunda uygun dokümanlar hazırlayıp kullanması mümkündür. Hatta bahse konu dokümanları alım yöntemine uyarlayarak aynen de kullanmaları olanak dahilindedir.

Doğrudan temin yönteminde tercihe bağlı olarak sözleşme düzenlenebilir. Yapılan sözleşme Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasından hareketle, taraflar anlaştıkları hususlarda sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler.

Nitekim Sayıştay Temyiz Kurulunun 03.03.2009 tarih ve 30679 tutanak No.lu Kararı'nda özetle; *"Dilekçi dilekçesinde doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığından mal alımlarında herhangi bir cezai müeyyide bulunmadığını ileri sürmüş ise de, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin d bendine göre yapılan alımlar idarelerin ihtiyaçlarının temininde istisnai bir yöntem olup sınırlı durumlarda başvurulmaktadır. İhtiyacın giderilmesi acil olup da beklemeye tahammülü olmayan durumlarda idare bu yöntemle hemen ihtiyacını karşılayacaktır. Bu nedenle Kanunda bu alım yöntemi ile idarelere geniş bir takdir alanı tanınmıştır. Bunlardan biri de, sözleşme yapıp yapmama serbestliğidir. ihtiyacının doğrudan temin yoluyla karşılanmasında kamu yararı olduğunu dikkate alarak idare ile satıcılar arasında sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmelere, malzemenin zamanında teslim edilmemesi halinde gecikme cezası kesilmesi yönünde hükümler konulmuştur. Kanunlara aykırı olmayan*

sözleşme hükümlerinin uygulanması da zorunlu olup, tarafları bağlar." ifadelerine yer verilerek, doğrudan teminde düzenlenen sözleşmelerin tarafları bağlayacağı belirtilmektedir.

Görüldüğü üzere; sözleşme düzenlenmesi hususu idarelerin takdirinde olmakla birlikte, tekliflerin eşit olması, cezai yaptırımlar ön görülmesi gibi geçerliliği için yazılı kurala ihtiyaç gösteren tercihlerin varlığı durumunda yazılı sözleşme düzenlenmesi ve sözleşme tasarısı ve idari şartnamenin fiyat araştırması yapılan kişilere verilmesi uygun olacaktır.

Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmelikleri ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olması gerekli değildir, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabilecektir.

Bu çerçevede, mal alımları için geçerli olmak üzere, Mal Alım İhaleleri Uygulamaları Yönetmeliği'nde tekliflerin eşit olması durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine yönelik düzenleme doğrudan temin yönteminin özgün durumu dikkate alınarak uyan kısımları referans alınabilir.

Mal Alım İhaleleri Uygulamaları Yönetmeliği'nde "Tekliflerin eşit olması" başlıklı söz konusu 62'nci maddesinde;

"(1) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalede, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin kriterleri aşağıdaki hususları esas alarak idari şartnamede belirtir:

a) Fiyat dışı unsur veya unsurlar, istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olması ile iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı, değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir. Fiyat dışı unsurlar ile istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olmasının değerlendirme kriteri olarak öngörülmesi idarenin takdirindedir. Ancak, her ihalede, tekliflerin eşitliği durumunda iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarının bir değerlendirme kriteri olarak düzenlenmesi zorunludur.

b) Değerlendirme kriterlerinde öncelik, sırasıyla; fiyat dışı unsur veya unsurlara, isteklilerce teklif edilen malın yerli malı olmasına ve iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına verilir.

c) İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak iş deneyimini gösteren belgelerin

istenilemediği veya istenilmediği ihalelerde de tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına değerlendirme kriteri olarak yer verilir. Bu ihalelerde, benzer işe yönelik düzenleme yapılması idarenin takdirindedir. Benzer iş düzenlemesi yapılmayan ihalelerde, isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki ihale konusu işe ilişkin iş deneyim tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır.

ç) İş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı daha fazla olan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir.

d) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı sağlanmayan ihalelerde de istekli tarafından yerli malı teklif edilmesi, tekliflerin eşitliği durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde bir değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir.

e) Elektronik eksiltme yapılan ihalelerde ihale üzerinde kalan istekli, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Fiyat dışı unsurların da eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, yerli malı teklif eden isteklidir. İsteklilerin teklif ettikleri malın yerli malı olmaması veya birden fazla isteklinin teklif ettiği malın yerli malı olması durumunda, iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.

(3) Tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenirken idari şartnamedeki kriterlerin öncelik sıralaması esas alınır. Bir sıralama kriterindeki değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenememesi halinde diğer sıralama kriterine geçilir. Üst sırada yer alan kritere göre yapılan değerlendirme sonucunda, birden çok isteklinin tekliflerinin birbirine eşit olması veya ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenememesi durumunda, sadece kriteri sağlayan isteklilerin teklifinin diğer kriter veya kriterler açısından değerlendirilmesine devam edilir.

(4) İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenilmeyen belgenin veya belgelerin, tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için istenildiği ihalelerde, bu belge veya belgeleri sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılamaz. Ancak, tekliflerin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenebilmesi amacıyla istenilen belge veya belgeleri, teklifleri kapsamında sunmayan eşit

teklif sahibi istekli veya isteklilere bu belge ya da belgeleri sunmaları için yeterli süre verilir. İstenilen belge veya belgeleri süresi içerisinde sunan isteklilerin belgeleri, idari şartnamede yapılan düzenlemeye göre değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. Ancak isteklilerce sunulacak yerli malı belgesinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması; iş deneyimini gösteren belgeye konu işin ise ihale tarihinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur…"

Hususları yer almaktadır.

Hizmet alımlarına ilişkin uygulama yönetmeliği ile yapım işlerine ilişkin uygulama yönetmeliğinde de benzer hükümlerin yer aldığı görülmektedir. Ancak alım şekli değiştiği için bazı hususlarda farklılıklar bulunduğunu ifade edebiliriz.

Kamu harcama yönetiminin temel ilkesi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Bu kapsamda idarelerce ihtiyaç duyulan malların en uygun fiyatla temin edilebilmesi, yapılan piyasa fiyat araştırmasının etkinliğine bağlıdır.

Dolayısıyla, idare öncelikle doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısında, tekliflerin eşit olması durumunda nasıl hareket edileceğine yönelik düzenleme yapabilir ve buna göre hareket eder.

Bununla birlikte, doğrudan temin kapsamı alımların niteliği ve idareye sağladığı avantaj ve hareket özgürlüğü göz önünde bulundurularak alım öncesinde bu kapsamda alıma ilişkin dokümanlara hüküm koyabilir. Bu durum olası belirsizliklerin aşılmasına yardımcı olabilir.

Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda, alımı yapmakla görevlendirilen kişi/kişilerce piyasa fiyat araştırması sonucunda uygun fiyat veren yükleniciden alım yapılmaktadır. Mevzuatta doğrudan teminde eşit teklif alınması konusunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, idare tarafından herhangi bir belirleme yapılmamışsa, yeniden teklif istenebilir. Keza 4734 sayılı Yasa'nın "Doğrudan temin"e ilişkin tanımında; "Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" olarak tanımlanmış olup, bu bağlamda fiyatların

görüşülmesi veya yeniden teklif alınması mümkündür.

Hatta isteklilerle pazarlık yapılmasına da bir engel bulunmamaktadır. İlgili Yasa'ların (4734 ve 5018) ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasına yönelik düzenlemelerinin de bu bakış açısının uygun olduğunu ifade edebiliriz.

Kaldı ki 4734 sayılı Yasa'nın üst paragrafta yer verilen doğrudan temin tanımında da "isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek" ifadesinin yer alması, idarece yeni fiyat istenilmesi ya da pazarlık yapılması yönündeki olası eylemlerinin, yasa hükmüne uygun bir hareket tarzı olduğunu söyleyebiliriz.

39. Doğrudan temin yönteminde iş artışı yapılabilir mi?

Özet: *4735 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinde Kamu İhale Kanunu'na tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmelerin anılan kanun hükümlerini kapsadığı hüküm altına alınmış, iş artışının ise Kanuna göre imzalanan mal ve hizmet alımlarıyla yapım işi sözleşmelerine uygulanacağı belirtilmiştir. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 24'üncü maddesine göre iş artışı yapılması ve anılan maddede belirtilen iş artışı kurallarının, doğrudan temin yönteminde uygulanması mümkün değildir. Ancak doğrudan temin, bir ihale usulü olmadığından, bu kapsamda temin edilen ihtiyaçlar için sözleşme yapılmış ise, 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekliliğinden hareketle, doğrudan temin sözleşmelerinin Borçlar Kanunu hükümlerine tâbi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde limit belirtilen hallerde limiti aşmamak (22/d maddesi) ve sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla, doğrudan temin kapsamı alımlarda da 4735 sayılı Yasa'nın 24'üncü maddesindeki kısıtlamalara tabi olunmaksızın iş artışı yapılabilir.*

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde; Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, "Doğrudan temin" başlıklı Kanun'un 22'nci maddesi incelendiğinde; doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak, belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve

sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Keza, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde 4964 sayılı Kanun'la yapılan değişiklik sonucu, doğrudan temin uygulamasında sözleşme yapma zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve bu husus tümüyle idarelerin takdirine bırakılmıştır. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir.

Bununla birlikte, bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise, madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

İdarelerin doğrudan temin kapsamındaki en çok kullandığı alım türü ise, Kanun'un 22/d maddesi kapsamında belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Doğrudan temin, süreklilik arz etmeyen, Kanun'da belirtilen limitler dahilindeki ihtiyaçların en kısa sürede temin edilmesi ve ihale için belirlenen prosedürler ile uğraşılmadan idare ihtiyacının karşılanmasına ilişkin bir yöntemdir. Ancak alıma konu ihtiyaç, idarenin süreklilik arz eden ihtiyacı niteliğinde ise bu alımın ihale yöntemlerinden biriyle esas olarak karşılanması gerekmektedir.

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde; *"Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır."* hükmü; 32'nci maddesinde, *"Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur."* hükmü bulunmaktadır.

Bu meyanda, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesindeki *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur..."* hüküm ve ilkelerinin süreçte dikkate alınması gerekmektedir.

Görüldüğü üzere; kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu Yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanmasındaki süreç ise bu Yasa'yı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. 4735 sayılı Yasa'nın 36'ncı maddesi uyarınca da anılan Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

4735 sayılı Kanun'un 24'üncü maddesinde; "*Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;*

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, (Değişik ibare: 02/07/2018-KHK-700/140 md.; yürürlük:09/07/2018) Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında %40 'a kadar artırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir."

Hükmü yer almaktadır.

İdareler ihaleye çıkarken ihtiyaç miktarını tam olarak belirleyip ona göre alım sürecini başlatmaları gerekmektedir. Her ne kadar idare tarafından ihtiyaç tam olarak belirlenerek ihaleye çıkılsa da sözleşme imzalandıktan sonra işin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç miktarında değişiklik yapılması zorunluluk haline gelebilir.

Yukarıda yer verilen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 24'üncü maddesinde, hangi koşullarda iş artışı veya eksilişi yapılabileceği hükme bağlanmıştır. İş artışı yapılabilmesi için öncelikle 4735 sayılı Kanun'a göre kurulmuş bir sözleşmenin varlığı şarttır.

Doğrudan temin yöntemi, bir ihale usulü olmadığı için, sadece söz konusu maddeye dayanılarak doğrudan iş artışı yapılması mümkün değildir. Zira söz konusu hüküm gereğince iş artışı yapılabilmesi için 4735 sayılı Kanun'a göre kurulmuş bir sözleşmenin olması gerekir. Bu yöndeki bir sözleşmeye göre ise, alımın ihale türleri kapsamında yapılması gerekir.

Buna karşın, doğrudan teminle yapılan alımlarda iş artışı yapılmasını engelleyen bir hüküm de mevcut değildir. Bu itibarla, doğrudan teminle yapılan alımlarda sözleşme düzenlendiği durumlarda, sözleşmeye iş artışı yapılabileceğine dair hüküm konulması mümkündür.

Ancak 4734 sayılı Kanun'un 22/d maddesinde belirlenen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda, iş artışı suretiyle parasal limitin aşılması mümkün değildir.

Bu bağlamda, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda yazılı bir sözleşme düzenlendiği durumlarda, sözleşmeye iş artışı yapılabileceğine dair hükümler konulabilir. Yani yapılan iş artışlarının da yazılı sözleşmeye bağlanması gerekmektedir. Ancak 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirlenen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda iş artışı yapılmak suretiyle bu limit aşılmamalıdır.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 14'üncü maddesinin, "*Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar* aynı nispette vergiye tabidir." hükmü gereğince binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisinin artış tutarı üzerinden ödenmesi gerekir.

Bu itibarla, doğrudan temin yönteminde iş artışı yapılabilmesi için öncelikle sözleşme yapılmış

olması ve sözleşmede iş artışı ve iş artışı yapılabilecek oranın sözleşmeye yazılması gerekmektedir. Ayrıca iş artışı sözleşme bedeli üzerinden yapılmaktadır.

4735 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinde Kamu İhale Kanunu'na tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsadığı hüküm altına alınmış, iş artışının ise bu Kanuna göre imzalanan mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerine uygulanacağı belirtilmiştir.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 24'üncü maddesine göre iş artışı yapılması ve bu maddede belirtilen iş artışı kuralları, doğrudan teminde mümkün değildir. Ancak doğrudan temin bir ihale olmadığından idarece alım kapsamında bir sözleşme yapılmış ise 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacağı belirtildiğinden, doğrudan temin kapsamı sözleşmelerin Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olduğunu söyleyebiliriz.

Dolayısıyla, Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesindeki limiti aşmamak (22/d maddesi) ve sözleşmede belirtilmesi şartıyla doğrudan teminle yapılan sözleşmelerde de 4735 sayılı Yasa'nın 24'üncü maddesindeki kısıtlamalara tabi olunmaksızın iş artışı yapılabilir.

Bunun yanında, doğrudan temin onay belgesinde iş artışını engelleyen bir hususa yer verilmemesi ve onay belgesine ekli piyasa fiyatı araştırma tutanağında alınan mal, hizmet veya yapım ile ilgili fiyatların bulunması gerektiğini de söyleyebiliriz. Zira iş artışında dikkate alınacak verilerdir.

4734 sayılı Yasa'nın "Görevlilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 60'ıncı maddesinde de; anılan Yasa'nın 5'inci maddede belirtilen "Temel ilkelere" ve 62'nci maddesinde yer alan "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar"a aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı yönünde hükmün yer aldığı görülmektedir.

Benzer şekilde, 4735 sayılı Yasa'nın "Görevlilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 28'inci maddesinde de aynı nitelikte hükümlerin yer aldığı görülmektedir.

Görüldüğü üzere; her iki Yasada (4734-4735) da ilgili Kanun'un temel ilkelerine aykırılıklar

yaptırıma bağlanmış olup, fiilin niteliğine ve kasıt unsurunun varlığına bağlı olarak, idari cezaların yanında, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçu gibi fiile bağlı olarak adli yaptırımlar da söz konusu olabilmektedir.

Bu itibarla, doğrudan temin yöntemi de olsa iş artışı sürecinde yasal koşulların oluşup oluşmadığına idarece dikkat edilmesi gerekir.

40. Doğrudan temin kapsamı alımlarda tekliflerde aritmetik hatanın bulunması durumunda ne yapılmalıdır?

Özet: *4734 sayılı Yasa'da yer alan ihale türlerinden biriyle gerçekleştirilen alımlarda aritmetik hata içeren tekliflerin ihale dışı bırakılması gerekirken, doğrudan temin kapsamı alımlar için bu yönde bir düzenleme olmadığını, bu alım yönteminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle, bu kapsamda yapılan aritmetik hataların düzeltilmesine engel bir durum bulunmadığını ve hatta suiistimal niteliğinde olmadığı anlaşılan hataların idarece düzeltilmesinin ve ilgililerce imzalanmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Keza 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde yer alan doğrudan temin tanımı uyarınca, idarelere kamu yararı çerçevesinde esneklik sunulmaktadır. Çünkü bahse konu alımlar, isteklilerle idarenin fiyatın ve teknik şartların görüşüldüğü bir alım yöntemidir. Yani Yasa bir anlamda buna olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, idarenin söz konusu işlemlerdeki takdir hakkını amaç dışı kullanmaması ön koşuluyla, Yasa'nın tüm alım türleri için geçerli olan temel (özellikle eşit muamele) ilkelerine aykırılık taşımamak şartıyla aritmetik hataların düzeltilmesinde idarenin esnek davranabileceği düşünülmektedir. Ancak idare isterse, olası eleştirilerin önüne geçmek adına alım dokümanlarında belirtilmesi koşuluyla, aritmetik hata olan tekliflerin değerlendirme dışı bırakabileceğine de karar verebilir.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, ihale kavramı; Kanun'da yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlere karşılık gelmektedir.

Dolayısıyla, ihale mevzuatı açısından ihale süreci, ihale onayının alınması ile başlamakta ve tekliflerin değerlendirilmesinden sonra en uygun teklifi veren istekli ile sözleşmenin yapılması ile sona eren bütün süreci kapsamaktadır.

"Doğrudan temin" ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir. Kanun'un ilk kabul edildiği haliyle, bir ihale türü olarak belirlenen "Doğrudan temin" 4964 sayılı Kanun'un 12'nci maddesiyle yapılan değişiklik ile bir ihale usulü

olmaktan çıkarılmıştır.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak, belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Özelikle tekliflerin idarece (veya ihale komisyonunca) değerlendirilmesi işlemleri diğer süreçlere oranla daha hassasiyet gerektirmektedir. Zira teklifi dışarıda bırakılmaması gereken bir isteklinin bırakılması veya aksi bir durumda; ilgili kamu görevlisinin kasıt veya ihmaline bağlı adli ve idari sorumluluklar gündeme gelecektir.

Ayrıca, böyle bir durum, alım sürecinin mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmaması ve eşit muamele başta olmak üzere Kanun'un birçok temel ilkesinin ihlaline de neden olacaktır. Bu bağlamda, çeşitli kalemlerden oluşan ihtiyacın tek parçada alınması sürecinde, aritmetik hata nedeniyle, bir isteklinin alım dışı bırakılıp bırakılmaması da yukarıda belirtilen çerçevede önem arz etmektedir.

Doğrudan temin kapsamı alımlar, ihale kapsamı diğer alım türlerine göre birçok açıdan farklılık arz etmektedir. Gerek 4734 sayılı Kanun ve gerekse İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan düzenlemeler, esas itibarıyla ihale kapsamı alımlar içindir. Aritmetik hatayı da bu eksende düşünmek gerekir. Yani söz konusu hususlar ihale kapsamı alımlar için geçerli olduğu için bu hükümleri doğrudan temin kapsamı alımlar için doğrudan kullanma imkânımız bulunmamaktadır.

İhale kapsamı alımlar için yer alan söz konusu düzenlemeler, referans alınarak doğrudan temin kapsamı alımlarda da kullanılabilir. Ancak idarenin bunları esas almaya mecburiyeti bulunmamaktadır. Bu bağlamda, öncelikle ihale kapsamı alımlara değinip, sonrasında doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlar için bu husus açıklanacaktır.

Öncelikli olarak 4734 sayılı Yasa'nın "Tekliflerin değerlendirilmesi" başlıklı 37'inci

maddesine baktığımızda;

Söz konusu maddenin; "… *Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır."* şeklinde hükme bağlandığını görmekteyiz.

Görüldüğü üzere; anılan Yasa hükmü uyarınca, aritmetik bir hatanın bulunması durumunda, teklifin değerlendirme dışı bırakılması öngörmektedir. Ancak, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, ihalelerde kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunması durumunda, değerlendirmenin her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

İhale sürecine ilişkin değerlendirmelerde ana ilke olarak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının mümkün olduğunu, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin ise, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Dolayısıyla, isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılması mümkündür.

Bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan resen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce isteklilere makul bir tamamlama süresinin verilmesi gerekmektedir.

Bunlarla birlikte, kısmi teklife açık ihalelerde kısım veya kısımların birden fazla kalemden oluşması durumunda kullanılabilecek birim fiyat cetveli örneği ışığında, örnek bir uygulama ile aritmetik hata hakkında ilave bilgi verebiliriz.

Birim Fiyat Teklif Cetveli Örneği

	A			B	
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
	1 inci Kısım				
1.	Notebook	Adet	6	250 TL	1500 TL
2.	Printer	Adet	10	50 TL	500 TL
3.	Fotokopi Makinesi	Adet	14	100 TL	1400 TL
				1. Kısmın Toplam Tutarı	3.400 TL
	2 nci Kısım				
1.	Buzdolabı	Adet	12	200 TL	2400 TL
2.	*Televziyon*	*Adet*	*15*	*100 TL*	*1400 TL*
3.	Tost Makinesi	Adet	11	40 TL	440 TL
				2. Kısmın Toplam Tutarı	4.240 TL
1 inci ve 2 nci Kısımların Toplam Tutarı (K.D.V Hariç)					7.640 TL

Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere, isteklinin 2'nci kısma ilişkin teklifinde aritmetik yani dört işlem hatası yapılmış olup, genel toplam doğru da olsa, teklifin 2'nci yapılan söz konusu hata nedeni ile bu kısmın ihale kapsamı alım olması (varsayım) nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

İhale değerlendirme sürecinde de birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hatanın varlığı kabul edilerek, teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde ise, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif

verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

Ancak, bu ihale kısmi teklife açık bir ihale olmasaydı, bu durumda isteklinin teklifinin bütünüyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte olup, gerek ihale komisyonun ve gerekse ihale yetkilisinin bu noktada takdir hakkı bulunmadığını ve sürece müdahalenin söz konusu olmadığını özellikle ifade edebiliriz.

Söz konusu aritmetik hata, birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplam gibi dört işlem niteliğindeki hataları kapsamakta olup, aritmetik hata taşıyan tekliflerin sadece ihale dışı bırakılacağını, bunlar hakkında teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama kararı verilmesi şeklinde hiçbir ilave yaptırım uygulanmayacağını belirtebiliriz.

İhale kapsamı alımlar ile doğrudan temin kapsamı alımlar için aritmetik hata ve eksikliklerin tamamlatılması sürecinin farklılıklar arz ettiği, ihale kapsamı alımlar için 4734 sayılı Kanun'da açıkça yazıldığı ve yukarıda yer verildiği üzere, aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Yine ihale kapsamı alımlar için geçerli olmak üzere, isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini, ancak aritmetik hata taşıyan tekliflerin sadece dışarıda bırakılacağını, bunlar hakkında teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama kararı verilmesi şeklinde hiçbir ilave yaptırım uygulanmayacağını belirtebiliriz.

Doğrudan temin kapsamı alımlarda, söz konusu alım türünün Kanun kapsamında belirlenen bir ihale usulü olmaması nedeniyle, bu kapsamda yapılan alımlarda, aritmetik hataların düzeltilmesine engel bir durum bulunmadığını düşünmekteyiz. Ancak, bu nitelikteki işlemlerde göz önünde bulundurulması gereken husus, idarenin söz konusu işlemlerdeki takdir hakkını amaç dışı kullanmaması ve eşit muamele ilkesinin göz ardı edilmemesidir.

Kanun'un emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere, alım dokümanlarına yer vermek şartıyla belli noktalarda esneklik de bulunmaktadır. Örneğin; doğrudan temin kapsamı alımların niteliği dikkate alınarak suiistimal maçı taşımayan basit bir işlem hatasından ibaret olduğu anlaşılan aritmetik hata bulunan tekliflerin, istekliye imzalatmak koşuluyla geçerli sayılması mümkündür. Zira aritmetik hatalar, birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplam

gibi dört işlem niteliğindeki hataları kapsamaktadır. Ancak herkes için aynı şekilde muamele edilmesi gerekir.

Veya alım sürecine ilişkin dokümanlarda, açık bir şekilde ortaya konulmak şartıyla aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı da bırakabilir.

Bunlarla birlikte, suiistimal niteliğinde olmadığı anlaşılan, aritmetik hataların idarece düzeltilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Keza 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; doğrudan teminin tanımının, (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu ise, idarelere kamu yararı çerçevesinde esneklik sağlamaktadır. Ancak nihai teklifin istekliye imzalatılması uygun olacaktır.

Zira bu alım yönteminin özelliği, isteklilerle idarenin, fiyat ve teknik şartların görüşüldüğü bir alım olmasıdır. Yani Yasa bir anlamda buna olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla, kamu kaynaklarının verimli kullanılması noktasında, idarelerin esnek davranması mümkündür.

Netice itibarıyla; doğrudan temin kapsamı alımlarda, söz konusu alım türünün 4734 sayılı Kanun kapsamında belirlenen bir ihale usulü olmaması nedeniyle, bu kapsamda yapılan alımlarda, aritmetik hataların düzeltilmesine engel bir durum bulunmadığını düşünmekteyiz.

Hatta idare tarafından herhangi bir belirleme yapılmamışsa, yeniden teklif istenebilir. Keza 4734 sayılı Yasa'da "Doğrudan temin"; "Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" olarak tanımlanmış olup, bu bağlamda fiyatların görüşülmesi veya yeniden teklif alınması mümkündür.

Ancak bu nitelikteki işlemlerde göz önünde bulundurulması gereken temel husus, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerekliliği çerçevesinde, idarenin söz konusu işlemlerdeki takdir hakkını amaç dışı kullanmaması ve eşit muamele ilkesinin varlığını göz ardı etmemesidir.

41. Doğrudan temin kapsamı alımlar Kamu İhale Kurumu'na (KİK) bildirilir mi?

Özet: *Kamu İhale Kurumunca yapılan düzenlemeler ve uygulamalar çerçevesinde, kamu alımları elektronik ortama büyük ölçüde aktarılmış ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) adı verilen bu sistem üzerinden ihale kapsamı alımlara ait işlemler yürütülmektedir. Buna karşın doğrudan temin kapsamı alımlar söz konusu platform üzerinden yürütülmemektedir. Ancak doğrudan temin kapsamı alımların da EKAP üzerinden yürütülmesine yönelik KİK'in çalışmaları bulunduğunu ve bu kapsamda şu an için doğrudan temin kapsamı alımların EKAP üzerinden duyurusunun yapıldığını görmekteyiz. Mevcut durum itibarıyla bu sistem üzerinde doğrudan temin kapsamı alımların gerçekleştirilmesi zorunluluk olarak öngörülmemiştir. Bununla birlikte, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için "Doğrudan Temin Kayıt Formu"nun temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar usulüne uygun olarak doldurulduktan sonra Kamu İhale Kurumuna EKAP üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Elektronik ortamda gönderilen formlar ayrıca posta ile gönderilmez.*

Doğrudan teminin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak ifade edildiği görülmektedir.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, "Doğrudan temin" başlıklı Kanun'un 22'nci maddesi incelendiğinde; doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak, belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. İdare, isterse sözleşme

düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir.

Bununla birlikte, bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise, madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

Doğrudan temin, süreklilik arz etmeyen, Kanun'da belirtilen limitler dahilindeki ihtiyaçların, en kısa sürede temin edilmesi ve ihale için belirlenen zorunluluklar ile uğraşılmadan alınmasına ilişkin bir yöntemdir. Ancak doğrudan temin limitine girmesine ve zorunluluk olmamasına rağmen, alım konusu tekrarlanan ihtiyaçlara ilişkinse bunların ihale yapılarak giderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde; *"Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır."* hükmü; 32'nci maddesinde, *"Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur."* hükmü bulunmaktadır.

Bu meyanda, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesindeki *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur..."* hüküm ve ilkelerinin süreçte dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, 4734 sayılı Kanun'un Elektronik Kamu Alımları Platformu başlıklı Ek Maddesi uyarınca (Ek Madde:1); Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; Kanunun 13'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve

sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebileceği, Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine ilişkin olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden sistemler kurulabileceği, bu sistemlerin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi, yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında KİK'in yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kanun hükmü çerçevesinde, İhale kapsamı alımların elektronik ortama aktarılması ve bu kapsamdaki işlemlerin Elektronik İhale Yönetmeliği ile belirlenen esaslara göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP'a kayıt olmak zorundadır. EKAP'a kayıt sonrasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve kendi oluşturdukları şifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmaması ve kullanıcıların tanımlanması işlemlerinden idareler ve EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler sorumludur.

EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve EKAP'ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından "kullanıcı adı ve şifresi" veya "e-imza" ya da diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden biri kullanılır.

EKAP üzerinden yapılan erişimler ve Kurum tarafından belirlenen işlemler EKAP'ta kayıt altına alınır. EKAP üzerinden yapılan ihale işlemlerinde, bu kayıtlar esas alınır. e-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgeler ve kayıtlar, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

İdareler, EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile KİK (Kurum) arasındaki EKAP üzerinden yürütülen ihale sürecine ilişkin her türlü bilgi ve belge alışverişinin güvenliği, gizliliği ve kişisel verilerin korunması KİK tarafından sağlanır. İhale sürecinde idareler tarafından aday ve isteklilerle ilgili olarak EKAP üzerinden elde edilen bilgiler, sadece sağlanma amacı ile sınırlı olarak kullanılır ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılamaz. İdareler ve EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler, kendi bilgisayarlarında EKAP'ta kullanılmak üzere oluşturacakları bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur.

Aday ve isteklilere ait, katılım ve yeterliğe ilişkin bilgiler, ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinin veri paylaşımına imkân vermesi durumunda, idareler tarafından EKAP üzerinden sorgulanarak teyit edilir. Yapılan sorgulama sonucunda gerekli bilgiler EKAP'a aktarılır. Hangi bilgilerin sorgulanabileceği Kurum tarafından belirlenerek EKAP üzerinden duyurulur. Bu durumda, aday ve istekliler tarafından bu bilgilere ilişkin belge sunulmaz.

İdareler ile aday ve isteklilerin, mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden KİK tarafından belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekmektedir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde, eksiklik veya hata giderilinceye kadar, EKAP'ın ilgililer tarafından kullanımına ilişkin KİK tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir.

Bu bağlamda, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'ne göre ihale sürecine ilişkin aşağıdaki işlemler EKAP üzerinden gerçekleştirilmektedir:

a) İhtiyaç raporunun hazırlanması.
b) İhale kaydının yapılması ve İhale Kayıt Numarası (İKN) alınması.
c) İhtiyaç raporunun ihaleyle ilişkilendirilmesi.
ç) Teknik şartnamenin yüklenmesi.
d) Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması.
e) Doküman indirenlerin kaydı.
f) İlan işlemlerinin yapılması.
g) Dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması.
ğ) İhale komisyonu oluşturma işlemleri.
h) Başvuru ve tekliflerin kaydı.
ı) Başvuru ve teklif değerlendirme işlemlerinin kaydı.
i) Teyit işlemleri.
j) Sonuç bildirim işlemleri.
k) İhale iptal işleminin kaydı.
l) İdareye verilen şikayet dilekçesinin kaydı.

İhalelerde sözleşme aşamasında teklifler elektronik ortamda alınabilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.

İhale türü alımlar için yukarıdaki hususlar yer almakla birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesi kapsamında yapılacak doğrudan teminler ile istisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin alım öncesi EKAP üzerinden duyurulabilmesine yönelik uygulama 1 Şubat 2022 itibariyle devreye alınmıştır.

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların, alım öncesi ilgililere duyurulması, varsa alıma ilişkin dokümanlara duyuru ile birlikte erişilmesi ve duyuruya çıkan alımların farklı kriterlerle aranmasına yönelik geliştirmeler tamamlanmış ve Doğrudan Temin Arama sayfası ekap.kik.gov.tr adresinde "İhale İşlemleri" menüsü altında erişime açıldığı görülmüştür.

KİK tarafından doğrudan temin kapsamı alımlar için duyuru imkânı getirilmiş ve ayrıca, alıma ilişkin bilgilerin EKAP'a kayıt edilmesi ve sonuç bilgisinin gönderilmesine ilişkin işlemler de sadeleştirilmiştir.

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların duyurulması idarelerin takdirinde olup söz konusu alımlar duyuru yapılmaksızın da neticelendirilebilecektir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 30.9. maddesinin "Doğrudan Temin Kayıt Formu" başlıklı bölümünde; "Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar Doğrudan Temin Kayıt Formu doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınır. " ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ hükmü gereğince; doğrudan temin yöntemiyle yapılan satın almalara ilişkin "Doğrudan Temin Kayıt Formu" usulüne uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra EKAP üzerinden Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi gerekmekle birlikte, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için "Doğrudan Temin Kayıt Formu" elektronik ortamdan gönderildikten sonra, formlar ayrıca posta ile gönderilmez.

42. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yükümlülüğünün kapsamı nedir?

Özet: *5510 sayılı Kanun ve anılan Kanun hükmü ışığında hazırlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin "İhalelerin Bildirilmesi, Hakedişlerin Mahsubu ve Ödenmesi İle Kesin Teminatın İadesi" başlıklı ikinci bölümün 5'inci maddesi gereğince; idareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden on beş gün içinde SGK (ilgili üniteye)'ya bildirmek zorundadır. Ancak doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, uygulanacak ihale usulleri arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla, SGK'nın ilgili Tebliğinde de yer aldığı üzere; doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal veya hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili olarak ihale makamlarının söz konusu işi üstlenenleri SGK'ya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.*

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde, Kanun kapsamındaki ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, "Doğrudan temin" başlıklı Kanun'un 22'nci maddesinde; doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı maddesinde de; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak, belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir. Doğrudan temin kapsamı alımların SGK'ya bildirim boyutunu açıklamazdan önce, konuyla bağlantılı temel düzenlemelere bakabiliriz.

Şöyle ki;

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu

"Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması" başlıklı 90'ıncı maddesi;

"(Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Hakedişlerin mahsubu ve ödenmesi ile teminatların prim ve idari para cezası borçlarına karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usûl ve esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.
(Değişik dördüncü fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.
Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak

kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından proje ve faaliyetleri karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarına sağlananlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden Kuruma muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunludur. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/43 md.) Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; işverenlerin muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlanılabilir. Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak Kurumca belirlenir."

Hükmüne amirdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi Ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik'in

Tanımlara ilişkin 4'üncü maddesinde; ".. –g) Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal: Projelendirme veya münhasıran bir talep üzerine üretimi yapılmayan malları,"

İhalelerin bildirilmesi başlıklı 5'inci maddesi; " (1) İdareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden onbeş gün içinde ilgili üniteye bildirmek zorundadır. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işler idare tarafından Kuruma bildirilmez."

Hakedişten kesinti ve mahsup başlıklı 6'ncı madde; "..(8) Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak işi üstlenenlere yapılacak hakediş ödemelerinden önce, işi üstlenenlerin idari para cezası, prim ve prime ilişkin borcunun olup olmadığı Kuruma yazılı olarak sorulur ve bir aylık süre içinde Kurumca yapılacak bildirime istinaden borcu varsa hakedişinden kesinti yapılır."

Kesin teminatın iadesi başlıklı 7'nci maddesi;"...(10) Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak kesin teminatın iadesinde Kurumca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi aranmaz."

Hususları yer almaktadır.

Konuyla bağlantılı SGK Genelgesi (2013 – 41)

Söz konusu Genelgede;

"İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 04/02/2011 tarihli, 2011 – 13 sayılı Genelgenin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse ünitelerimizce uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak söz konusu Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.
7- Doğrudan temin usulüyle yaptırılan işler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun,
"Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18 inci maddesinde, idarelerce, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde,
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c)Pazarlık usulü,
uygulanacağı öngörüldüğünden, "doğrudan temin usulü", uygulanacak ihale usullerine ilişkin 18 inci madde içeriğinden çıkartılmıştır.
Buna göre, doğrudan temin usulü ile yapılan mal veya hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili olarak ihale makamlarının söz konusu işi üstlenenleri Kurumumuza bildirme yükümlülüğü, yüklenicinin hakediş ödemesine esas muaccel borcunun bulunup bulunmadığı hususunu sorgulama yükümlülüğü ve teminat iadesi sırasında Kurumumuzdan alınmış ilişiksizlik belgesini isteme yükümlülüğü bulunmamaktadır."

Hususları yer almaktadır

Söz konusu mevzuat düzenlemelerinde yer aldığı üzere, Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanun hükümleri göre de sözleşmesi imzalanan hizmet alım işlerinde, idarelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bahse konu husus, hizmet alım ihalelerinin tamamında dikkate alınmaktadır. 5510 Sayılı Kanun'un 90'ıncı

maddesinde düzenlendiği üzere, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

İdareler ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri onbeş gün içerisinde SGK'ya bildirmekle yükümlüdürler. SGK'ya yapılacak bildirimlerde, temel olarak işi alan yükleniciler ile bu yüklenicilerin tebligat adreslerinin yer alması gerekmektedir. Bu itibarla, hizmet alım ihalelerinde de sözleşmenin imzalanmasına müteakip onbeş gün içerisinde SGK'ya ihaleyi alan yüklenicinin ve tebligat adreslerinin bildirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla doğrudan temin yoluyla yapılan işler, uygulanacak ihale usulleri arasında bulunmadığından bu işlerin SGK'ya bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak idareler yönetmelikler ya da düzenleyecekleri sözleşmeler ile sözleşme serbesti sınırları içerisinde bu yönde düzenlemeler yapabilmektedir.

Ayrıca, bu hususta 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 90'ıncı maddesince hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı, idarelerin ihale yoluyla yaptıkları her türlü işleri üstlenenlerin hak edişlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenmesine ve kesin teminatlarının ihale konusu işle ilgili Kuruma olan borçlarına karşılık tutulması ve iadesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "İhalelerin Bildirilmesi, Hakedişlerin Mahsubu ve Ödenmesi İle Kesin Teminatın İadesi" başlıklı ikinci bölümün 5'inci maddesinde; "İdareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden on beş gün içinde ilgili üniteye bildirmek zorundadır. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işler idare tarafından Kuruma bildirilmez." düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18'inci maddesinde ise "İdarelerce mal veya hizmet

alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: Açık ihale usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü ve Pazarlık usulüdür." hükmü yer almaktadır.

Ancak doğrudan temin kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri alınması durumunda söz konusu yöntem uygulanacak ihale usulleri arasında sayılmamıştır. Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde ise "…Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde, Kamu İhale Kanunu'na göre ihale usulleri arasında sayılmayan doğrudan temin yöntemiyle yapılan hizmet alımı ödemesinde SGK ilişiksiz belgesi aranma zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde, doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılan alımlarda, idarelerin alım yapılan kişileri ve bunların adreslerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelerine de gerek yoktur.

Doğrudan temin harici ihale kapsamı alımlarda ise, 5510 sayılı Kanun'un 102'nci maddesinin (g) bendi uyarınca, bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

İlave olarak, SGK'ya yapılan bildirim ve neticesinde yapılan kontroller sadece ihale bünyesinde çalışan işçilere yönelik değil aynı zamanda ihaleyi alan yüklenicilerin SGK'ya olan borçlarının da kontrolüne ve tahsiline imkân sağlamaktadır.

İdarelerce hizmet alım işlerini için getirilen bildirim yükümlülüğü, sadece ihale kapsamı işler için getirilmiştir. Bu sebeple doğrudan temin yöntemine göre yapılan hizmet alımlarında idarelerin SGK'ya bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Buna karşın, idareler doğrudan teminle yapılan alımlarda da bu yönde bir düzenleme koyabilirler ve sözleşme imzalamak veya doküman oluşturmak suretiyle, SGK ile ilişkileri düzenleyebilirler. Doğrudan teminlerde sözleşme yapmak ve bu hususları sözleşmelere yansıtmak bütünüyle idarelerin takdirindedir.

Görüldüğü üzere; Kanun hükmü uyarınca, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesi olan doğrudan temin bir ihale usulü sayılmadığından bu yöntemle yapılan alımlarda ve yapım işlerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yükümlüğü bulunmadığı gibi hakedişlerin ödenmesi ve kesin teminat iadesi sırasında ilişiksiz belgesi arama yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Doğrudan temin dışında ihale yolu ile yapılan mal veya hizmet alımı ile yapım işlerinde ise bildirim yükümlülüğünün yanı sıra hakediş ödemeleri esnasında ve kesin teminat iadesinden de ilişiksiz belgesi aranması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanun'un 90'ıncı maddedeki teminat iadelerinde ilişiksizlik belgesi aranması yükümlülüğünün kapsamına, piyasadan hazır halde alınıp satılan malların girmediğini ifade edebiliriz. Aynı şekilde, piyasadan hazır halde alınıp satılan mallar için isteklinin SGK'ya bildirim yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Ancak hak ediş ödemesinden önce mutlaka işverenin, SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin borcu bulunup bulunmadığının araştırılması ve borcunun bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ödenecek hak edişten kesinti yapılması gerekmektedir.

Netice itibarıyla; 5510 sayılı Kanun ve anılan Kanun hükümleri ışığında hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik'in 2'nci maddesine göre, sadece ihaleli işlerde SGK ilişiksizlik belgesinin aranılacağı net olarak hükme bağlandığından, ihale kapsamı alımlarda söz konusu belgeyi arama zorunluluğunun bulunduğu açıktır.

Buna karşın, gerek 5510 sayılı Kanun, gerek Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik ve gerekse SGK'nın 2013/41 sayılı Genelgesi'nde açık bir şekilde yer aldığı üzere, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda SGK ilişiksizlik belgesi arama zorunluluğu bulunmamaktadır. Zira doğrudan alım yöntemi, bir ihale usulü değildir. Oysa SGK mevzuatı ihale türleri için bahse konu zorunluluğu öngörmüştür.

43. Doğrudan temin kapsamı alımlarda gecikme cezası uygulanması mümkün müdür?

Özet: *4735 sayılı Yasa uyarınca ihale kapsamı alımlara ait sözleşmelerde gecikme halinde uygulanacak cezanın belirtilmesi zorunluluktur. Buna karşın doğrudan temin kapsamı alımlar için böyle bir zorunluluk yoktur. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gecikme cezası uygulanmasına yönelik sözleşmenin bulunması ve sözleşme konusu işin zamanında yapılmaması nedeniyle ceza gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde mutlaka ceza maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmelidir. Doğrudan teminde yapılan sözleşmede Borçlar Kanunu hükümler uygulanmaktadır. Taraflar anlaştıklarında sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler. Belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da cezai yaptırımlar ön görülmesi durumunda, mutlaka yazılı sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir. İdareler 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan tip sözleşmeleri referans olarak kullanılabilir. Süreçte 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmaması halinde, yine aynı Kanuna göre Borçlar Kanunu hükümlerinin süreçte dikkate alınması gerekmektedir. Sayıştay Temyiz Kurulunun bir kararında da doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen bir alımda, satıcı ile imzalanan sözleşmeye istinaden, zamanında teslim edilmeyen bir malzemeye istinaden gecikme cezası kesilmesi yönündeki hükümlerin, kanunlara aykırı olmamak koşuluyla tarafları bağladığını ve bahse konu sözleşme hükümlerinin uygulanmasının zorunluluk arz ettiğine dikkat çekildiği görülmüştür.*

"Doğrudan temin" kavramı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde, (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmaktadır. Kanun'un ilk kabul edildiği haliyle, bir ihale türü olarak belirlenen doğrudan temin, 2003 tarihli 4964 sayılı Kanun'un 12'nci maddesi ile bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

Her ne kadar 4734 sayılı Yasa maddeleri arasında yer verilmiş olsa da doğrudan temin aslında bir ihale türü (usulü) değildir. Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre ilan

yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar" başlıklı 7'nci maddesinde; "*Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: ...*

...n) Gecikme halinde alınacak cezalar..." hükmü ile

"İdarenin sözleşmeyi feshetmesi" başlıklı 20'nci maddesinde, *"Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:*

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi..." hükmüne yer verilerek, yüklenicinin edimini sözleşme hükümlerine aykırı surette yerine getirmemesi halinde ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezasının söz konusu olabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bilindiği üzere, ihale sürecine ilişkin hukuki düzenlemeler 4734 sayılı Kanun'a göre, sözleşmenin imzalanmasından sonraki süreçte ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla, doğrudan temin kapsamı alımlar için söz konusu Kanun hükümlerin uygulanması mümkün değildir.

Öte yandan, cezai şarta ilişkin olarak ihale mevzuatında ve tip dokümanlarda çeşitli hükümler bulunmaktadır. Örneğin; **"mal alımlarına"** ait açık ihaleler için geçerli sözleşme tasarısının ilgili kısmında;

"Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde …… gün[1] süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

[1] İdare tarafından, 4735 sayılı Kanunun 20/a maddesi gereğince on (10) günden az olmamak üzere yükleniciye verilecek ihtarın süresi belirlenir.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin .....(yazıyla) oranında[2] gecikme cezası uygulanır.[3]

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde [bir][4] defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır."

Hususları yer almaktadır.

Buna karşın **"Hizmet alımları"** için geçerli olan Tip sözleşme tasarısına göre;

"Madde 16-** (Değişik başlık: 20/06/2021-31517 R.G./15. md., yürürlük: 05/07/2021)* ***Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi

16.1. İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir. Cezalar, aykırılık halleri ve

---

2 İdare, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin onbinde birden az, yüzde ikisinden fazla olmamak üzere gecikme cezası oranı belirleyerek madde metnine yazacaktır.

3 İdare, kısmi kabul yapılması öngörülen ihalede bu maddeyi aşağıdaki şekilde yazacaktır:
"Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın/işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin ……*[İdare, onbinde birden az, yüzde ikiden fazla olmamak üzere belirlediği ceza oranını yazıyla buraya yazacaktır.]* oranında gecikme cezası uygulanır."

4 İdare tarafından alımın niteliği esas alınarak bu sayı değiştirilebilir.

sözleşmenin feshine ilişkin hususlar bu Sözleşmenin 16, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hususlara ilişkin olarak söz konusu maddeler dışındaki ve ihale dokümanındaki diğer düzenlemeler sadece 16.1.1 inci madde kapsamında değerlendirilir.

16.1.1. Bu sözleşmenin 16.1.2 nci maddesinde yer alan özel aykırılık ve 16.1.3 üncü maddesinde yer alan ağır aykırılık halleri dışında, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak ceza oranı, ilk sözleşme bedelinin [bu kısma %1'den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır.]'dır. Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran %50 artırımlı uygulanır.

16.1.2. Aşağıdaki tabloda yer alan özel aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır. 26.1 Tabloda yer verilen özel aykırılıklardan herhangi birinin ilgili aykırılık için aynı satırda belirtilen sayıya ve toplam özel aykırılık halinin de ... 26.2 sayısına ulaşması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

Özel Aykırılık Halleri

	Aykırılık Hali	İlk Sözleşme Bedeli Üzerinden Kesilecek Ceza Oranı	Aykırılık Sayısı[26.3]
1			
2			
3			
....			

"

16.1.3. Aşağıdaki tabloda yer alan ağır aykırılık hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

Ağır Aykırılık Halleri [26.4]

1	
2	
3	
....	

16.1.3.1. Ek madde: ……[26.5]

[26.4] Bu kısma somut fiiller yazılabilecek olup, bu aykırılık hallerinin, varsa 16.1.2 nci maddede yer alan aykırılık hallerinden farklı olması gerekmektedir.

[26.5] (1) 16.1.3 üncü madde kapsamında belirlenen bir aykırılığın gerçekleşmesi üzerine idarece ceza uygulanmasının da öngörülmesi halinde "Sözleşmenin feshine yol açan fiil nedeniyle ayrıca, ilk sözleşme bedelinin %2'si oranında ceza uygulanacaktır." yazılacaktır.

(2) 16.1.3 üncü madde kapsamında belirlenen bir aykırılığın gerçekleşmesi üzerine idarece ayrıca ceza uygulanmasının öngörülmemesi halinde "Bu madde boş bırakılmıştır." yazılacaktır.

16.1.4. Bu sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı hiçbir durumda ilk sözleşme bedelinin %30'unu geçemez. Toplam ceza tutarının ilk sözleşme bedelinin %30'unu geçtiğinin anlaşılması durumunda bu orana kadar ceza uygulanır ve 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

16.1.5. Bu sözleşmenin 16.1.2 nci ve 16.1.3 üncü maddelerinde yer verilen aykırılıklar kapsamında somut fiillere yer verilmemesi halinde, söz konusu maddelerde yer alan cezalar ve/veya fesih yaptırımları uygulanamaz. Ayrıca, aynı aykırılığın 16.1.2 nci ve 16.1.3 üncü maddelerde birlikte sayıldığı hallerde, sözleşme uygulamasında 16.1.3 üncü madde dikkate alınır.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

16.3. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için ilk sözleşme bedeli üzerinden 16.1.1 inci maddede belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse süresinde tamamlanmayan kısmın ilk sözleşme bedeli üzerinden) gecikme cezası uygulanır. Yapılacak ihtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gecikmenin yol açtığı aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir.

16.3.1. İşin tamamının ya da varsa kısmi kabule konu kısmının süresinde bitirilmemesi haline ilişkin olarak 16.1.2 nci veya 16.1.3 üncü maddelerde yapılan düzenlemeler uygulanmaz.

16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir."

Hususları yer almaktadır.

Buna karşın **"Yapım işleri"** için tip sözleşme tasarısında;

"Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin ……. (rakam ve yazıyla) ……..[5]oranında gecikme cezası uygulanır.[6]

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin %15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin %15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı

---

[5]İdareler; sözleşme konusu işin sözleşmesinde öngörülen sürede tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her gün için, ilk sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere gecikme cezası oranı belirleyerek madde metnine yazacaktır.

[6]İdare, kısmi kabul öngörülen ihalelerde madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir.

"25.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işin müstakil kullanımına elverişli kısmının zamanında bitirmemesi halinde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak aşağıdaki oranlarda gecikme cezası uygulanır:

İşin Kısımları	Bitirme Tarihleri	Kısmi Gecikme Cezaları
I.Kısım :	...../…/…….	kısmın (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./16. md., yürürlük: 18/08/2019) ilk sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir.
II.Kısım:	...../…/…….	kısmın (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./16. md., yürürlük: 18/08/2019) ilk sözleşme bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir.
……		

sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir."

Hususları yer almaktadır.

Görüldüğü üzere; ihale kapsamı alımlar için ilgili mevzuat ve dokümanlarda sözleşme kapsamında uygulanacak hususlar alım türleri itibarıyla ayrı ayrı belirlenmiştir. Ancak alım bazında farklılık arz eden hususlar, tip şartnamelerde yer almaktadır.

Öte yandan gecikme cezasına ilişkin olarak Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme ve Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme metinleri incelendiğinde, anılan Tip Sözleşmelerde de gecikme cezasının sözleşme bedelinin belli bir oranı olarak belirlendiği görülmektedir.

Sayıştay Temyiz Kurulunun yapım işi sözleşmesinde gecikme cezasının hesaplanmasıyla ilgili aldığı kararlarda da, gecikme cezasının iş artışı hariç bedel üzerinden kesilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

Aynı şekilde, mal alımı, hizmet ve danışmanlık hizmetleri ile yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde, gecikme cezasının hesaplanmasında sözleşme bedeli olarak ilk sözleşme bedelinin esas alınması gerektiğine, oy birliğiyle KİK tarafından karar verildiği belirlenmiştir.

Öte yandan, yüklenici çeşitli nedenlerden dolayı taahhüdünü yerine getirmeyebilir. Bunların bir kısmı tutukluluk, acze düşme veya sözleşme öncesi yasak fiil ve davranışlar gibi birçok nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Nitekim söz konusu Kanun'a baktığımız zaman; 4735 sayılı Kanun'un; 17'nci maddesinde "Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti" durumu, 18'inci maddesinde; "Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet" durumu, 19'uncu maddesinde; "Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi", 20'nci maddesinde; "İdarenin sözleşmeyi feshetmesi", 21'nci maddesinde "Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih", 22'nci maddesinde "Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler", 23'üncü maddesinde; "Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi",

24'üncü maddesinde "Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi"

Hususları düzenlenmiştir.

Söz konusu maddelerden Yasa'nın 20'nci maddesinde; *"Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir."* hükmü yer almaktadır.

Müteakip maddelerde açıklandığı üzere, bu kapsamda, sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında yasaklama kararı verilmesinden başka sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyanın yükleniciye tazmin ettirilmesi söz konusudur.

Yukarıda verilen ihale kapsamı alımlara ait tip sözleşme tasarılarında da yükümlülüğünü yerine getirmeyen yüklenicilere uygulanacak yaptırımlar ve bunlara ait cezalar ile cezalardaki asgari ve azami oranlar ortaya konulmuştur. Ayrıca hangi durumlarda, sözleşmenin feshine varacak düzeyde cezanın gerekli olduğu da ortaya konulmuştur.

Ancak 4735 sayılı Kanun, ihale kapsamında gerçekleştirilen alımlara ait sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin süreci kapsamaktadır. Dolayısıyla doğrudan temin kapsamı alımlar için söz konusu Kanun hükümlerin uygulanması mümkün değildir. Size söz konusu alım yöntemi bir ihale türü değildir. Bununla birlikte, idareler tarafından alım öncesi idari şartname ve sözleşme tasarısı ve diğer ihale dokümanlarında yer vermek şartıyla bu yönde düzenlemeler yapılabilir.

Sözleşme düzenlenmesi hususu idarelerin takdirinde olmakla birlikte, 22'nci madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumu ile 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

Belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da yükleniciden teminat alınması, cezai yaptırımlar ön görülmesi gibi yazılı kurala ihtiyaç gösteren hususların söz konusu olduğu durumlarda, yazılı sözleşme düzenlenmesi bir anlamda gereklilik arz etmektedir.

Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmelikleri ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olması gerekli değildir, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabilecektir. Dolayısıyla uygulama yönetmelikleri ve eklerinde yer alan tip sözleşmede yer alan ceza ile ilgili sınırlamalar doğrudan teminde düzenlenen sözleşme için geçerli değildir.

Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmadığı için, ihale usullerinin tabi olduğu mevzuata da tabi olmak zorunda değildir. Dolayısıyla doğrudan temin yöntemlerinde kural olarak gecikme cezasının olamayacağını ifade edebiliriz.

Ancak, eğer taraflar bu yöntemle yapılan alımlarda sözleşme imzalamışsa ve sözleşme hükümleri içerisinde de yüklenicinin kusurundan kaynaklı gecikmelerde ceza kesileceği sözleşmede yer almışsa bu durumda yükleniciden ceza kesilecektir.

Doğrudan teminde yapılan sözleşmelerde Borçlar Kanunu hükümler uygulanmaktadır. Taraflar anlaştıklarında sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler. Burada doğrudan temin ile ilgili sözleşmeyi idare tek taraflı olarak hazırladığından sözleşmeye konulacak ceza hükmü sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmemesi durumlarını ve bunlara ilişkin cezaları içermesi gerekmektedir.

Nitekim Sayıştay Temyiz Kurulunun 03.03.2009 tarihli bir Kararı'nda; *"Dilekçi dilekçesinde doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığından mal alımlarında herhangi bir cezai müeyyide bulunmadığını ileri sürmüş ise de, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin d bendine göre yapılan alımlar idarelerin ihtiyaçlarının temininde istisnai bir yöntem olup sınırlı durumlarda başvurulmaktadır. İhtiyacın giderilmesi acil olup da beklemeye tahammülü olmayan durumlarda idare bu yöntemle hemen ihtiyacını karşılayacaktır. Bu nedenle Kanunda bu alım yöntemi ile idarelere geniş bir takdir alanı tanınmıştır. Bunlardan biri de, sözleşme yapıp yapmama serbestliğidir. ... malzemesi ihtiyacının doğrudan temin yoluyla karşılanmasında kamu yararı olduğunu dikkate alarak*

idare ile satıcılar arasında sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmelere, malzemenin zamanında teslim edilmemesi halinde gecikme cezası kesilmesi yönünde hükümler konulmuştur. Kanunlara aykırı olmayan sözleşme hükümlerinin uygulanması da zorunlu olup, tarafları bağlar." ifadelerine yer verilerek, doğrudan teminde düzenlenen sözleşmelerin tarafları bağlayacağı belirtilmektedir.

Benzer şekilde, Sayıştay Temyiz Kurulunun 08.04.2008 tarihli bir Kararı'nda; alımın doğrudan temin yöntemi olmasına rağmen eğer sözleşme düzenlenip, sözleşmesinde de ceza öngörülmüşse bunun uygulanması gerekliliğine dikkat çekilmiş olup, söz konusu Kararda;

"4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin usulünde, ihtiyaçların Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu usulde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarelerin takdirindedir. ... alım sözleşmesi imzalamak suretiyle bu konudaki takdirini sözleşme yapma yönünde kullanmıştır. Dolayısıyla, bu aşamadan sonra artık idare ve yüklenici, malzeme alımının doğrudan temin usulüyle yapıldığından bahisle aralarında imzalamış oldukları bu sözleşme hükümlerine aykırı davranamazlar..." hususları yer almaktadır.

Bu bağlamda, gecikme cezası (cezai şart), borçlunun üstlendiği taahhüdü, sözleşme hükümlerine göre kararlaştırılan şekilde yerine getirmemesi nedeniyle alacaklıya ödemek zorundu olduğu bir bedeldir. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda işin sözleşmeye aykırı şekilde bitirilmesi hâlinde gecikme cezası uygulanabilir. Gecikme cezası uygulanabilmesi için yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede gecikme cezasına ilişkin düzenleme bulunması zorunludur.

Dolayısıyla, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda sözleşme yapılmayan durumlarda veya sözleşmede gecikme cezasına ilişkin düzenleme bulunmaması halinde ceza uygulanmaz.

Bu nedenle, idare tarafından, sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde teslim etmemesi/gerçekleştirmemesi halinde yazılı ihtar

yapılarak sözleşmeye göre işin yapılması gereken tarihten itibaren gecikme cezası uygulanacağının belirtilmesi uygun olacaktır. Gecikme cezasının, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesileceği, şayet bu ceza tutarının, hakedişden veya varsa kesin teminattan karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edileceği belirtilmelidir.

Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gecikme cezası uygulanmasına yönelik düzenleme bulunuyor ve sözleşme konusu iş zamanında yapılmamış ya da diğer ceza gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde mutlaka ceza maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmelidir. Hatta koşulların oluşması durumunda sözleşmenin feshi bile söz konusu olabilmektedir. Yukarıda referans olarak yer verilen tip idari sözleşme tasarılarında da bu yönde hükümler olduğu görülmektedir.

Konuyla bağlantılı bir KİK Kararında;

"*Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:*

...n) Gecikme halinde alınacak cezalar..." hükmü ile "İdarenin sözleşmeyi feshetmesi" başlıklı 20'nci maddesinde, *"Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:*

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi..." hükmüne yer verilerek, yüklenicinin edimini sözleşme hükümlerine aykırı surette yerine getirmemesi halinde ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezasının söz konusu olabileceği hüküm altına alınmıştır.

Gecikme cezası (cezai şart), borçlunun üstlendiği taahhüdü, sözleşme hükümlerine göre kararlaştırılan yer ve zamanda gereği gibi veya hiç yerine getirmemesi nedeniyle alacaklıya ödemek zorundu olduğu bedel yani bir borç niteliğindedir.

Netice itibarıyla; ihale kapsamı alımlar için yüklenicinin alım kapsamında idareye teslimi gereken mal, hizmet veya yapım işine ilişkin olarak, sözleşmede öngörülen koşullara aykırı biçimde taahhüdünü yerine getirirse veya hiç getirmezse, söz konusu dokümanlarda ön görülen cezaların uygulanması gerekir. Söz konusu tip dokümanlar idarenin isteğine bağlı olmaksızın

hazırlanması gerekmekle birlikte, uygulanacak ceza konusunda idarenin belli limitler dahilinde uygulanacak oranı belirlemek konusunda seçeneği mevcuttur.

Buna karşın, doğrudan temin bir ihale usulü değil, alım yöntemi olduğu için ihale kapsamı alımlar için öngörülen düzenlemeye bağlı değildir. Kural olarak da sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna rağmen, sözleşme düzenlenmişse bu taraflar için bağlayıcıdır ve bu dokümanda yer verilen cezaların, dolayısıyla gecikme cezasının tatbik edilmesi gerekir.

Dolayısıyla, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gecikme cezası uygulanmasına yönelik düzenleme bulunuyor ve sözleşme konusu iş zamanında yapılmamış ya da diğer ceza gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde mutlaka ceza maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmelidir. Hatta koşulların oluşması durumunda sözleşmenin feshi bile söz konusu olabilmektedir.

44. Doğrudan temin yönteminde hakediş ödemelerinde SGK'dan ilişiksizlik belgesi istenir mi?

Özet: *Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik'in "İhalelerin Bildirilmesi, Hakedişlerin Mahsubu ve Ödenmesi İle Kesin Teminatın İadesi" başlıklı ikinci bölümünde yer aldığı üzere, idareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden on beş gün içinde SGK'ya (ilgili üniteye) bildirmek zorundadır. Ancak doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, uygulanacak ihale usulleri arasında sayılmamıştır. SGK'nın ilgili Tebliğinde yer aldığı üzere; doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal veya hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili olarak ihale makamlarının, söz konusu işi üstlenen yüklenicinin hak ediş ödemesine esas muaccel borcunun bulunup bulunmadığı hususunu sorgulama ve SGK'dan alınmış ilişiksizlik belgesini isteme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, hakediş ödemesi gerçekleşmeden yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcunun sorgulanması için söz konusu alımın bir ihale sonucu gerçekleşmesi gerekmektedir. Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, bu yöntemle yapılan alımlarda hak ediş ödemesine esas muaccel borcun bulunup bulunmadığı hususunun Sosyal Güvenlik Kurumuna sorulmasına gerek yoktur. Öte yandan, hakediş ödemelerinde ilişiksizlik belgesi aranması SGK ödemelerinde sadece ihale kapsamı alımlar için geçerli iken, vergi borcu bulunup bulunmaması açısından alım türünün önemli olmadığını, burada 5000.-TL parasal sınır bulunduğunu, bu tutarı aşan tüm hakediş ödemelerinde vergi borcunun sorulması gerektiğini ifade edebiliriz. Ayrıca, ilişiksizlik belgesi kapsamında Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne gitmeden sorgulama başvurusunun direkt elektronik ortamdan (internet üzerinden) da yapılmasının mümkün olduğunu ifade edebiliriz.*

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, "Doğrudan temin" başlıklı Kanun'un 22'nci maddesi

incelendiğinde; doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir.

Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü değildir ve bu sebeple ihale usullerinin tabi olduğu mevzuata da tabi olmak zorunda değildir.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun; "Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması" başlıklı 90'ıncı maddesinin;

İkinci fıkrasında, *"İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder."*

Üçüncü fıkrasında, *"Hakedişlerin mahsubu ve ödenmesi ile teminatların prim ve idari para cezası borçlarına karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usûl ve esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir."*

Hükmü yer almaktadır.

İdareler ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri SGK'ya bildirmekle yükümlüdürler. Bu

bağlamda, hizmet alım ihalelerinde de sözleşmenin imzalanmasını müteakip onbeş gün içerisinde SGK'ya ihaleyi alan yüklenicinin ve tebligat adreslerinin bildirilmesi gerekmektedir. Kurumların SGK ilişkisi sadece ihale kapsamı alımların SGK'ya bildirilmesi ile sınırlı olmayıp hakediş ödeme sürecinde de SGK mevzuatının dikkate alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda, idarelerin, yaptığı ihaleler sonucunda işverene ödeyeceği her hakediş ödemesinden önce işverenin ve varsa alt işverenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer'ilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığını araştırmaları gerekmektedir. İhalelerle ilgili hakediş ödemesi yapılırken ilişiksizlik belgesi istenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, işverenlerin tahakkuk etmiş ve muaccel hale gelmiş idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının hak edişlerinden kesilerek ödenmesinin SGK tarafından idareden istenilmesi gerekmektedir.

Nitekim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 90'ıncı madde hükmüne dayanılarak hazırlanan SGK Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi Ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik'in Amaç başlıklı ilk maddesi; idarelerin ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenlerin hakedişlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenmesi ve kesin teminatlarının ihale konusu işle ilgili Kuruma olan borçlarına karşılık tutulması ve iadesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak Yönetmeliğin amacını belirlemiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesi uyarınca; idarelerin, ihale suretiyle yaptırdıkları işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden onbeş gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri zorunludur. Anılan Kanun'un 102'nci maddesinin (g) bendi uyarınca, bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Ancak ihale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işlerin idare tarafından SGK'ya bildirilmesine gerek yoktur.

Yine aynı madde uyarınca, ilgili ünite, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihini takip eden onbeş gün içinde işyeri sicil numarasını ve işyerine ilişkin gerekli diğer bilgileri ihaleyi yapan idareye bildirir. İdare bu bilgiler ile kendi kayıtlarındaki bilgilerin örtüşmemesi halinde durumu, onbeş gün içinde SGK'ya (üniteye) bildirmek zorundadır.

Aynı Yönetmeliğin "Hakedişten kesinti ve mahsup" başlıklı 6'ıncı maddesinde ise hak edişten kesinti ve mahsupların nasıl yapılması konusunda ayrıntılara yer verilmiştir. Söz konusu madde uyarınca; "İdarece işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir…" düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18'inci maddesinde; "İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: Açık ihale usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü ve Pazarlık usulüdür." yer almaktadır.

Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesi; "…Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir." şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde, Kamu İhale Kanunu'na göre ihale usulleri arasında sayılmayan doğrudan temin yöntemiyle yapılan hizmet alımı ödemesinde SGK ilişiksizlik belgesi aranma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İdarelerce yapılan hizmet alım işlerinde bildirim yükümlülüğü sadece ihaleli işler için getirilmiştir. Bu sebeple doğrudan temin yöntemine göre yapılan hizmet alımlarında idarelerin SGK'ya bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ancak idareler doğrudan teminle yapılan alımlarda da bu yönde bir düzenleme koyabilirler ve sözleşme imzalamak veya doküman oluşturmak suretiyle, SGK süreci ile kriterler düzenleyebilirler. Doğrudan temin yönteminde sözleşme yapmak ve bu hususları sözleşmelere koymak idarelerin takdirine bağlıdır.

Bu bağlamda, doğrudan temin yöntemine göre gerçekleştirilen alımlarda da idareler, SGK ilişiksizlik belgesi getirildikten sonra ödemelerin yapılacağına yönelik düzenlemelerle hizmet alımlarına ait işlemleri gerçekleştirebilirler.

Nitekim 5510 sayılı Kanun'un 90'ıncı maddesine dayanılarak çıkarılan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik'in 2'nci maddesinde sadece ihaleli işlerde SGK ilişiksizlik belgesinin aranacağı net olarak ortaya konulmuştur. Bu sebeple doğrudan temin yöntemine veya ihale dışı yöntemlere göre gerçekleştirilen alımlarda SGK ilişiksizlik belgesi aranılmayacaktır.

İşverenlerin hakedişleri, SGK'ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak SGK'ya borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

Mezkûr Yönetmeliğin 6'ncı maddesine göre, idarelerce hakediş ödemesi yapılmadan önce, hizmet alım ihalelerinde, öncelikle SGK'ya yazı ile başvurup borcunun olup olmadığı araştırılmalıdır. SGK yazısı olmadan yükleniciye hakediş ödemesi yapılamaz. İdarelerce bu sorgulama resmi yazı ile yapılabileceği gibi, SGK'ya sorgulama yapmak için başvuruda bulunarak sistem üzerinden de yapılabilir. İdarelerce, gerekli sorgulamalar yapıldıktan sonra hakediş ödemesi yapılır.

Yükleniciler tarafından aylık prim ve hizmet belgeleri SGK'ya verilmemiş veya yükleniciler tarafından sigortalı çalıştırılmamasına karşın bu durum dilekçeyle SGK'ya bildirilmemiş ise, bu durum SGK tarafından idarelere bildirilir. SGK tarafından bu yönde bildirim yapılması durumunda idarelerce hakediş ödemelerinden kesinti yapılmak suretiyle hakedişler ödenir. SGK tarafından bu yönde bir bildirim olmadığı müddetçe kesinti yapılmayacaktır.

İdareler tarafından yapılan hakediş ödemelerinde yüklenicinin SGK borcunun olması durumunda, yapılacak kesinti tutarı ödeme belgesinde gösterilir. Eğer yüklenicinin hakediş tutarı SGK borçlarını karşılamıyorsa, sonraki hakedişlerde de kalan borç kesilerek SGK'ya ödenir.

Hakediş ödemelerinde SGK ilişiksizlik belgesi, yüklenicinin SGK'ya olan bütün borçlarını kapsar. Yani yüklenicinin Türkiye'de yaptığı bütün işlerden dolayı SGK'ya borçlu olup olmadığının araştırılması gerekir.

Görüldüğü üzere; ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca hakediş ödemesi gerçekleşmeden yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcunun sorgulanması için söz konusu alımın bir ihale sonucu gerçekleşmesi gerekmektedir.

İlişiksizlik belgesine başvuru direkt Sosyal Güvenlik Birimine gitmeden İnternet üzerinden de yapılabilinmektedir. Bu şekilde başvuru için Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesi aracılığı ile işveren butonunun altında bulunan ilişiksizlik belgesi sekmesi tıklanarak bu belgenin alınması gerekir.

Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, bu yöntemle yapılan alımlarda hakediş ödemesine esas muaccel borcun bulunup bulunmadığı hususunun Sosyal Güvenlik Kurumuna sorulmasına gerek yoktur.

Oysa 5.000.-TL'nin üzerindeki alımlarda yüklenicinin vergi borcu sorgulaması yapılarak, Tahsilât Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde işlem tesisi gerekmektedir. Zira yapılan düzenlemelerde alımın ihale usulü veya doğrudan temin yöntemiyle yapılıp yapılmadığı açısından bir ayrım yapılmamıştır. Dolayısıyla ayrım yapılmadan tüm hakediş ödemelerinde bu rakamsal sınıra dikkat edilmesi gerekir. Buna karşın ilgilinin SGK borcunun varlığı halinde alımın ihale kapsamında olup olmadığına bakılacak, şayet bu hususta açık bir sözleşme düzenlenmediği sürece doğrudan temin kapsamı alımlar için SGK'dan ilişiksizlik belgesi istenilmeyecek ve sistemde sorgulaması yapılmayacaktır.

Diğer bir anlatımla, hakediş ödemelerinde ilişkisizlik belgesi SGK ödemelerin için ihale kapsamı alımlar için geçerli olup doğrudan temin yöntemi için geçerli değilken, vergi borcu bulunup bulunmaması açısından alım türünün bir önemli olmadığını, burada 5000.-TL parasal sınır bulunduğunu, bu tutarı aşan tüm hakediş ödemelerinde vergi borcunun sorulması gerektiğini ifade edebiliriz.

45. Doğrudan temin kapsamı alımlarda hakediş raporu hazırlanmalı mıdır?

Özet: *İhale kapsamı alımlarda, alımın niteliğine bağlı olarak, uygulanacak muayene ve kabul işlemlerine dair esas ve usuller, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Ancak doğrudan temin kapsamı alım ve ödeme sürecinde uygulanacak prosedür, söz konusu Yönetmeliklerden belirlenen düzenlemelerden farklılıklar içermektedir. İsterse muayene ve kabul süreci için komisyon kurulabilir, yetkili makam istemezse kurulmayabilir. Ancak, ödeme sürecinde uyulacak zorunluluklar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliğin 7'nci maddesine göre sözleşme yapılması durumunda doğrudan temin yöntemiyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlere ait bedellerinin ödenmesinde hakediş raporu düzenleneceği öngörülmüştür.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, ihale kavramı; Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade etmektedir.

İhale mevzuatı açısından ihale süreci ise, ihale onayının alınması ile başlamakta ve tekliflerin değerlendirilmesinden sonra en uygun teklifi veren istekli ile sözleşmenin yapılması ile biten süreci kapsamaktadır.

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir. Kanunun ilk kabul edildiği haliyle, bir ihale türü olarak belirlenen "Doğrudan temin" 4964 sayılı Kanun'un 12'nci maddesiyle yapılan değişiklik ile bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması

amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre yapılan ihtiyaç teminlerinde; alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, sözleşme yapılması zorunludur. Ancak bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir.

Örneğin; kırtasiye malzemesi alımında bir teslim etme fiili söz konusu olabilirken, yemek hizmetinde teslimden daha ziyade söz konusu hizmetin belirli bir süreçte yerine getirilmesi veya gerçekleştirilmesi söz konusudur.

İdarenin gerçekleştirdiği alıma ait mal, hizmet ve yapım işinin kabulü de gerekmektedir. Çünkü idarenin almak istediği mal veya hizmet ile yüklenicinin sunduğu arasında fark söz konusu olabilir. Bu nedenle muayene süreci, bir anlamda zorunluluk arz etmektedir. Muayene ve kabul süreci sonrasında ise, eğer herşey dokümanlara uygunsa ödeme süreci gerçekleşir.

Konunun bir de harcama belgeleri mevzuatı açısından değerlendirilmesi gerekli olup, bu bağlamda hakediş raporu birçok alımda söz konusu olabilmektedir. Zira mal alımları için geçerli olmasa da hizmet ve yapım işleri için hakediş raporun düzenlenmesi gerekmektedir.

Muayene ve kabul işlemleri, ihale kapsamı alımlar ile doğrudan temin yöntemine göre gerçekleştirilen alımlar açısından farklılıklar göstermektedir.

Bu bağlamda önce ihale kapsamı alımlara bakacak olursak; bu kapsamdaki alımlarda, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, idari şartnamede ve idare ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşmede yer alması zorunlu hususlar arasında sayılmıştır. Ayrıca 4735 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinde muayene ve kabul işlemlerinin temel esasları belirlenmiştir. Söz konusu madde;

"*Denetim, muayene ve kabul işlemleri*
Madde 11- Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal

veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.
Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir."

Hükmüne amirdir.

Kanuni düzenlemelerin dışında hizmet alımı ihalesi için Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan her bir ihale usulü için tip idari şartname, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nde muayene ve kabul işlemlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Yapım işleri için de benzer düzenlemeler bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliklerde yer aldığı üzere, alım türleri açısından muayene ve kabul işlemlerinde bazı farklılıklar söz konusu olabilmektedir.

Örneğin; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 8'inci maddesi ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin 44'üncü maddesinde, yüklenicinin işin kabulü için idareye yazılı başvurusundan sonra ilk olarak kontrol teşkilatının ön inceleme yapacağı, bu ön incelemenin olumlu neticelenmesi sonucunda idare tarafından muayene ve kabul komisyonunun kurulacağı ifade edilmektedir.

İkincil düzey mevzuat düzenlemeleri açısından bakıldığında kontrol teşkilatının varlığı, muayene ve kabul komisyonunun oluşturulması ve hizmet işinin kabul aşamasına geçilmesi için yerine getirilmesi gereken bir ön şart olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşın, kontrol teşkilatı mal alımları için pek uygulanabilir bir değildir.

Dolayısıyla, hizmet alımı ihalelerine özel bir uygulama olan kontrol teşkilatı uygulaması, yüklenicinin işi teslim için idareye başvurusu ile muayene ve kabul komisyonunun teşkili arasında kurulması öngörülen bir ara denetim/kontrol mekanizmasıdır. Kontrol teşkilatı, idare tarafından oluşturulur. Tek bir kişi veya bir komisyon kontrol teşkilatı olarak görev yapabilir.

Kontrol teşkilatının oluşturulması, muayene ve kabul komisyonunun kurulması ve komisyonun çalışması için bir ön koşul niteliğindedir. İster belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak ortaya çıkarılan hizmetlerde olsun, isterse sürekli nitelikteki işlerde olsun her iki hizmet türünde de kontrol teşkilatı tarafından ön inceleme yapılmadan muayene ve kabul işlemine geçilmez.

Belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak ortaya çıkarılan hizmetlerde kontrol teşkilatı, ön incelemesinde kabulü için başvurulan hizmet işinin durumunu, sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygunluk kriterini esas alır. Ancak sözleşmeye bağlanmamış hizmet işlerinde bu hususun nasıl gerçekleştirildiği ilgili mevzuatta açık değildir.

Süreklilik arz eden hizmet işlerinde, hizmet işine ait genel şartname çerçevesinde mevzuatta öngörülen diğer belgelerin yanı sıra işin yürütülmesi sırasında kontrol teşkilatınca tutulan kayıtlar da muayene ve kabul komisyonu tarafından esas alınır. Komisyon söz konusu kayıtlardan yola çıkarak işin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

Kontrol teşkilatının varlığı ve yerine getirdiği görevlerin muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluklarını değiştirmeyeceği ve kabulle ilgili nihai kararın muayene ve kabul komisyonlarının yetkisinde olduğu değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verildiği üzere, esas olarak ihale kapsamı alımlar için geçerli olan kontrol teşkilatı, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da idarece öngörülmesi durumunda kurulması mümkündür.

Bunun yanında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 7'nci maddesine göre sözleşme yapılması durumunda doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhüt bedellerinin ödenmesinde hakediş düzenleneceği belirtilmiştir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "Taahhüt dosyası" başlıklı 6'ncı maddesinde;

"İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan

yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (Örnek:2) veya söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir.
Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır. Ancak, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan belgelerden taahhüt dosyası dışındaki belgeler bağlanır. taahhüt dosyasının onaylı sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklanır. ”

Hususları yer almaktadır.

Öte yandan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ'de de taahhüt dosyasında bulunması gereken belgelere yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğin ilgili maddesi;

“6. Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler

(1) Kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderler için ilgili mevzuatında düzenlenmesi, aranması ve alınması öngörülen belgelerin düzenlenmesi, aranması ve alınması zorunludur. Kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan ihale işlem dosyasında, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgeler bulunur. Taahhüt dosyasında ise yalnızca ödeme belgesine bağlanması öngörülen belgelere yer verilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuatına göre istenen belgelerden Yönetmelikte ve bu Tebliğde sayılmayanlar ödeme belgesine bağlanmayacak, iç ve dış denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerinde muhafaza edilecektir.

(2) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve diğer ilgili maddeleri gereğince, taahhüt dosyasında bulunması öngörülen belgeler ile Bakanlığımızca taahhüt dosyasında bulunması gerekli görülen diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) İhale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde,

-İhale onay belgesi,

-İhale komisyonu kararı,

-Sözleşme,

-İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,

-Kesin teminatın alındığına ilişkin alındının örneği,

-Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı,

-Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge,

-Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

-Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

-Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı,

-Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi dışındaki bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda;

-Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi,

-Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, komisyon kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı; 22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form,

-Yukarıdaki (a) bendinde sayılanlardan düzenlenmesi gereken diğer belgeler.

...

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtildiği şekilde hazırlanan taahhüt dosyasının aslı, ödeme belgesinin Sayıştay'a gönderilecek nüshasına bağlanır. Taahhüt olunan işin bedelinin bir defadan fazla ödeme belgesi düzenlenmek suretiyle tahakkuk ettirilerek ödenmesinin söz konusu olduğu hallerde, taahhüt dosyasının harcama yetkilisi veya harcama yetkilisinin belirleyeceği görevli tarafından Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak onaylanmış bir nüshası da ayrıca muhasebe birimine gönderilir."

Şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "Hakediş raporu" başlıklı 7'nci maddesi;

"İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir.

a) Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3): Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.

b) Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4) :Bu rapor, hizmet işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Hizmet türüne ve işin özelliğine göre yalnızca ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır."

Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, doğrudan temin ile gerçekleştirilen söz konusu hizmet veya yapım işi sözleşmeye bağlanmış ise hakediş raporlarının da düzenlenmesi gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği hükmü doğrultusunda eğer doğrudan temin ile gerçekleştirilen yapım veya hizmet işi belirli bir süreyi kapsamaktaysa bu alım için sözleşme zorunludur. Dolayısıyla bu tarz alımları gerçekleştiren idarelerin ödeme evrakları arasına diğer belgelerle birlikte hakediş raporunu da düzenleyip eklemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, hakediş raporunda varlığı ve üzerinde yer alan bilgiler, hakediş süreci için kontrol amacı da taşımaktadır.

Sözleşmeye göre işte kontrol teşkilatı öngörülmüş ise kontrol teşkilatı tarafından işin ne kadar yapıldığının tespit edilmesi, kontrol teşkilatı yok ise doğrudan temini yapan birim tarafından tespit edilerek yapılan işin tutarı kadar ödeme yapılması gerekmektedir. Doğrudan temin kapsamı alımda da sözleşmeye ödemeye ilişkin bir hüküm konulmuş olması gerekmektedir.

Düzenlenen hakediş, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne göre eklenmesi gereken belgeler de dikkate alınarak, ödeme emri belgesi düzenlenerek ödenmek üzere muhasebe birimine intikal ettirilir. Saymanlık (ya da ilgili muhasebe birimince) da ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

Kontrol etmekle yükümlüdür.

Bu işlemlerde, muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Öte yandan, 5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. 5018 sayılı Kanun'a göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi nitelikleri itibariyle aynı mahiyette belgelerdir. Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir.

Kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderler için öngörülen belgelerin düzenlenmesi zorunludur. Kamu İhale Mevzuatına göre hazırlanan ihale işlem dosyasında, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgeler bulunur. Taahhüt dosyasında ise yalnızca ödeme belgesine bağlanması öngörülen belgelere yer verilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuatına göre istenen belgelerden Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ'de sayılmayanların ödeme belgesine bağlanmaması gerekmektedir.

46. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlara ilişkin ödemelerde vergi borcu sorulur mu?

Özet: *5766 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a eklenen 22/A maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, Tahsilat Genel Tebliği ve bu Tebliğde yapılan değişiklikler sonucunda mevcut durum itibarıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların, bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 5000.- TL üzeri yapacakları ödemelerde, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istemesi zorunluluk arz etmektedir. Şayet yapılan sorgulama sonucunda, 5000.- TL üstünde borç çıkması halinde hak sahibinden kesinti yaptıktan sonra ödeme yapılması gerekmektedir. SGK borcundan farklı olarak, vergi borcuna ilişkin sınırın (5000.- TL) belirlenmesinde, borcun kaynağı alımın ihale kapsamı veya doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alım olması açısından bir fark yoktur. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları tüm ödemeler sırasında bahse konu tutarı aşan ödemelerde, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması (veya sorgulanması) gerekmektedir.*

4734 sayılı Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin, ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi/kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

5766 sayılı Kanun'un, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a eklenen 22/A maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden çıkarılan Tahsilat Genel Tebliği ve bu Tebliğde yapılan değişiklikler sonucunda mevcut durum itibarıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlar, bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 5000.-TL üzeri yapacakları ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istemek zorundadır.

Keza Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)'in 1'nci maddesi uyarınca, Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölümünün "V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları" başlıklı bölümünün 2 ve 4 numaralı alt bölümlerinde yer alan "2.000,-" ibareleri "5.000,-" şeklinde değiştirilmiş olup, mevcut durum itibarıyla kamu idarelerinin hak sahiplerine hakediş ödemeleri sırasında vergi borcu yoktur sorgulaması yapması ve 5000.-TL üstünde borç çıkması halinde kesinti yaptıktan sonra ödeme yapması gerekmektedir.

Bu nedenle, 6183 sayılı Kanun'un 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği "yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu getirme" yetkiye istinaden, Tebliğ ile belirlenen tutarın üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunması halinde, borçlunun talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ödenecek tutardan, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede belirtilen borç tutarını aşmamak üzere kesinti yapılarak ilgili tahsil dairesi hesabına aktarılması zorunluluğu getirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı birden fazla tahsil dairesine borcun bulunması durumunda, kesinti tutarı vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi düzenleyen tahsil dairesinin hesabına aktarılması gerekmektedir.

Kesinti tutarının aktarıldığı tahsil dairesi ise bu tutarın hak sahibinin borçlarına mahsup edilmesini sağlayacaktır. Kesinti tutarının tahsil dairelerine olan borç toplamından az olması halinde, kesinti tutarı tahsil daireleri arasında garameten taksim edilecektir.

Dolayısıyla 5000.-TL tutarı üzerinde vadesi geçmiş borç bulunması halinde kişiye ödeme yapılmayacaktır. Bu kapsamda doğrudan teminle yapılan alımlara ilişkin ödemeler 5.000.-TL'nin üzerinde ise satıcıdan vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istenmelidir.

Diğer taraftan, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılmasını gerektiren ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, hak sahibi tarafından yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edecektir.

Dolayısıyla, hak sahipleri tarafından söz konusu ödemelere ilişkin olarak devir, temlik ve el değiştirme işlemi yapılmış olsa dahi ödenecek tutardan borç tutarı kadar kesinti yapılarak ilgili tahsil dairesi hesabına aktarılacaktır.

Ayrıca, kurum ve kuruluşlarca hak sahiplerine yapılacak ödemeden diğer kamu idarelerinin alacaklarına karşılık da kesinti yapılması gereken hallerde, kesinti tutarı tahsil daireleri ile diğer kamu idareleri arasında garameten taksim edilerek tahsil dairelerine ve ilgili idareye aktarılacaktır.

Kurum ve kuruluşlarca hak sahiplerine ödenecek tutar üzerine, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre haciz tatbik edilmiş olması halinde, hacze konu tutar düşüldükten sonra kalan tutar, kesintiye esas tutar olarak dikkate alınacaktır. Ancak yapılacak ödemelerden kesinti yoluyla tahsil dairelerine aktarım yapılacak olması, amme alacağının takibine engel teşkil etmemektedir.

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi, KDV, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri, vergi borcu kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'a eklenen 22/A maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden hazırlanan Tahsilât Genel Tebliğlerinin en güncel haline göre, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların bu kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları 5.000.- TL ve üzeri ödemelerde hak sahiplerinin ve ilgililerin anılan Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir.

Kamu İhale Kanunu kapsamında ödeme yapacak kurum ve kuruluşlar, hak sahiplerine ödeme yapmadan önce vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramaları gerekmekle birlikte, borçlunun tahsil dairesine olan borçlarını ödemesi veya sair sebeplerle, ihale nedeniyle kendisine yapılması gereken ödemenin yapılmasını engelleyen durumun kalkması üzerine, yeni alacağı belgeye göre ihaleyi yapan kurum ve kuruluşların gerekli ödemeyi hak sahibine yapmaları gerekmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere; doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda da 5.000.- TL'nin üzerindeki alımlarda yüklenicinin vergi borcu sorgulaması yapılarak Tahsilât Genel Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapmaları gerekmektedir.

Zira yapılan düzenlemelerde alımın ihale usulü veya doğrudan temin yöntemiyle yapılıp yapılmadığı açısından bir ayrım yapılmamıştır. Dolayısıyla ayrım yapılmadan tüm hakediş ödemelerinde bu rakamsal sınıra dikkat edilmesi gerekir. Buna karşın ilgilinin SGK borcunun varlığı halinde alımın ihale kapsamında olup olmadığına bakılacak, şayet bu hususta açık bir sözleşme düzenlenmediği sürece doğrudan temin kapsamı alımlar için SGK'dan ilişiksizlik belgesi istenilmeyecek ve sistemde sorgulaması yapılmayacaktır.

Öte yandan, Muhasebat Genel Müdürlüğünce ayrıca Genel Tebliğ (Sıra No: 77) (Ödeme Belgelerinde Vadesi Geçmiş Vergi Borçları İle Yasal Tevkifat Ve Diğer Kesintilerin Mahsubu) hazırlanmış olup, söz konusu Tebliğ ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ödemelerinde, öncelikle vadesi geçmiş vergi borcu ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğde yer alan mahsup işlemleri kapsamında;

"1) Hak sahibine ait hakedişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme gerçekleştirilebilir. Mahsuben ödemenin gerçekleştirilebilmesi için;

a) Vadesi geçmiş vergi borcunun mahsubunu isteyen hak sahibinden, ilgili vergi dairesi tarafından düzenlenmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu tutarını gösteren belge talep edilir. Bu belge, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de alınabilir. Bu belgenin teyidi Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri aracılığı ile https://ivd.gib.gov.tr internet adresinde yer alan

"Doğrulamalar" / "Mükellefiyet Yazısı / Borç Durum Yazısı Doğrulama" ekranından yapılır.

b) Harcama birimince, mevcut veya temin edilecek ödenek karşılığında, hakedişin vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için oluşturulacak ödeme emri belgesine, ödemeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin tamamı ve vadesi geçmiş vergi borcunu gösteren belge eklenir.

c) Harcama birimince ödeme emri belgesinin, muhasebe birimince muhasebe işlem fişinin açıklama alanına ödemenin vadesi geçmiş vergi borcu ve diğer kesintiler için yapıldığı belirtilir ve kanıtlayıcı belgeler (fatura vb.) üzerine de kısmi ödemeye konu tutar belirtilerek şerh düşülür.

ç) Mahsuba konu ödeme işleminde, faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi halinde, harcama birimince, e-faturanın kağıt çıktısı alınıp, yetkilendirilmiş görevli tarafından "Bu e-fatura elektronik imzalı aslı ile aynıdır." ibaresine yer verilir ve hak sahibinin vergi borcunun mahsubunda kullanılacağına ilişkin şerh düşülerek imzalanır.

d) Muhasebe birimince, işleme konu ödeme emri belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler, hakedişin kalan kısmına ilişkin ödeme sürecinde kullanılmak üzere, işlem tarihini izleyen üç iş günü içerisinde, 11/3/2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme başlıklı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) hükümleri çerçevesinde iade edilir.

e) Harcama birimince, ilgili faturaya ilişkin sonraki ödemelerde belgeler üzerinde yer alan şerhlerin kontrolünde azami özen ve önem gösterilir.

f) Mahsuben yapılan vadesi geçmiş vergi borcu tahsilatı, genel bütçe kapsamındaki idarelerde hesaben; genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde ise nakden ilgili vergi dairesine gönderilir…"

Hususları yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hususlar, hakediş ödeme sürecinde dikkate alınması gerekmekle birlikte, hakediş ödeme sürecinde, SGK borcu ile vergi borcu açısından mevzuattan kaynaklanan bir fark bulunmaktadır. Şöyle ki;

Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, bu yöntemle yapılan alımlarda hakediş ödemesine esas muaccel borcun bulunup bulunmadığı hususunun Sosyal Güvenlik Kurumuna sorulmasına gerek yoktur.

Oysa 5.000.-TL'nin üzerindeki alımlarda yüklenicinin vergi borcu sorgulaması yapılarak Tahsilât Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Zira yapılan düzenlemelerde alımın ihale usulü veya doğrudan temin yöntemiyle yapılıp yapılmadığı açısından bir ayrım yapılmamıştır. Dolayısıyla ayrım yapılmadan tüm hakediş ödemelerinde bu rakamsal sınıra dikkat edilmesi gerekir.

Buna karşın ilgilinin SGK borcunun varlığı halinde alımın ihale kapsamında olup olmadığına bakılacak, şayet bu hususta açık bir sözleşme düzenlenmediği sürece doğrudan temin kapsamı alımlar için SGK'dan ilişiksizlik belgesi istenilmeyecek ve sistemde sorgulaması yapılmayacaktır.

47. Doğrudan temin kapsamı alımlarda ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilir mi?

Özet: *İhalelerden yasaklama kararının ancak ihale türleri için verilebileceği dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla bir alım yapılması halinde, alım yapılacak kişinin/firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak anılan Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir. "Doğrudan temin" yoluyla yapılan alıma ilişkin olarak Kanun kapsamında "Yasaklama Kararı" verilmesinin, anılan alım türünün bir ihale usulü olmaması nedeniyle mümkün olmamakla birlikte, belirlenen fiile ilişkin olarak ceza takibatı gerektiren bir durumun varlığında, bu hususta Türk Ceza Kanunu kapsamında takibat yapılmasına engelleyen herhangi bir düzenleme de yoktur. Dolayısıyla böyle bir durumun varlığı halinde, cezai takibat yapılacağı açıktır.*

"Doğrudan temin" kavramı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde, (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmaktadır. Kanun'un ilk kabul edildiği haliyle, bir ihale türü olarak belirlenen doğrudan temin 15.08.2003 tarihli ve 25200 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun'un ilgili maddesi ile bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesi incelendiğinde, doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Her ne kadar 4734 sayılı Yasa maddeleri arasında yer verilmiş olsa da doğrudan temin aslında bir ihale türü (usulü) değildir. Kanun'un 22'nci maddesinde yer verildiği üzere, bu kapsamda yapılan alımlara, ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesinin zorunluluk arz ettiği alımlar başta olmak üzere, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya

hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması, idarenin taşınmaz mal kiralaması gibi normal ihale usulleri ile karşılanması mümkün olmayan alımlar örnek verilebilir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

İdarelerin doğrudan temin kapsamında en çok kullandığı alım türünü Kanun'un 22/d maddesi kapsamında yer verilen ve her yıl Kamu İhale Tebliği'nce güncellenen "parasal tutarlar kapsamında aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar" oluşturmaktadır. Bahse konu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

4734 ve 4735 sayılı Yasalar kapsamında bir yasaklamanın uygulanabilmesi için anılan Kanun'larda yer verilen fiil ya da fiillerin gerçekleşmesi gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bunların ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca istisna kapsamında yapılan alımlara ilişkin bir yasaklamanın söz konusu olması halinde de yine 4734 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca, yasaklama kararı verilmesi mümkündür.

Yasaklamaya ilişkin kararlar, Resmî Gazete'de yayım tarihinde yürürlüğe girdiği için ihaleyi yapan idare dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, ihale üzerinde kalan yüklenicinin yasaklı olup olmadığını KİK tarafından tutulan sicilden teyit ettiklerinden, henüz yürürlüğe girmemiş yasaklama kararlarının, diğer idareleri bağlaması mümkün değildir. Yani yasaklama kararı

yayınlanmadan önce diğer idareler, söz konusu firmanın başvurularını kabul edip ilgili firmanın ihaleyi kazanması halinde, aynı firma ile sözleşme de yapabileceklerdir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11'nci maddesinin (a) bendi gereği ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamamaları gerekmektedir. Söz konusu yasaklara rağmen ihalelere katılanların ihale dışı bırakılması, geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve Kanun'un 17'nci maddesinin atıfta bulunduğu 58'inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanması gerekmektedir. Bu nedenledir ki söz konusu yasakların uygulanabilmesi için ihale süreçlerinin çeşitli aşamalarında ihaleye katılan aday ve istekliler hakkında yasaklılık teyidi yapılması gerekmektedir.

İhale kapsamı alımlar için yasaklamaya ilişkin düzenlemeler ile doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda yasaklamaya ilişkin düzenlemelerde farklılıklar bulunmaktadır. Yukarıda ihale kapsamı için ifade edilen hususlar doğrudan temin kapsamı alımlar için esas olarak uygulanmaz.

Bu bağlamda, çeşitli (KİK) Kurul Kararlarında da yer verildiği üzere, sözleşmenin uygulanması aşamasındaki suç teşkil eden fiil ve davranışına ilişkin olarak hakkında adli makamlarca kamu davası açılmasına karar verilenlerin, doğrudan temin kapsamında yapılan bir alıma ilişkin olarak teklif vermesi durumunda, teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil ettiği gibi aynı esaslar çerçevesinde, doğrudan temin kapsamında alıma ilişkin olarak tespit edilen yasak bir fiile ilişkin olarak haklarında kamu davası açılmış olan isteklilerin, normal ihale usullerinden biri ile gerçekleştirilen alıma ilişkin olarak teklif vermesi durumunda, bu nitelikte bir teklifin de değerlendirme dışı bırakılması ve isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki işlemin de mevzuata aykırılık teşkil ettiğini söyleyebiliriz.

Keza doğrudan teminle yapılan ihaleler sonucunda düzenlenecek sözleşmelerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmaması ve ayrıca sözleşmenin uygulanması aşamasındaki suç teşkil eden fiil ve davranışlar nedeniyle hakkında kamu davası açılanların dava sonuçlanıncaya kadar kamu ihalelerine katılamayacağına dair bir hükme yer vermemesinden dolayı, hakkında kamu davası açılan kişi ve bu kişinin ortağı olduğu şirketler hakkında, 4735 sayılı Kanun'a göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama yaptırımının uygulanamayacağı açıktır.

Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi kapsamında yapılan bir alımda, alım yapılacak kişinin/firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak anılan Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 30.5.4. maddesi hükmü uyarınca söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.

Kamu İhale Kurumunun, yasaklama kararlarının verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin bir yetkisinin bulunmaması ve ayrıca şikâyete konu alımların Kanun'a göre ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu alımlar ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmaması nedeniyle, bu yöndeki başvuruların, 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin 10'uncu fıkrasının (c) bendi gereğince görev yönünden reddi gerekmektedir.

Doğrudan temin yöntemini, Kanun kapsamında yer verilen bir ihale türü olmaması nedeniyle, bu alım türüne ilişkin "Yasaklama kararı" verilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Bununla birlikte, tespit edilen fiile ilişkin olarak ceza takibatı gerektiren bir durumun varlığı halinde, ceza kanunları ve diğer kanunlardaki yaptırımlar uygulanacaktır.

Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı" başlıklı maddesinin ilgili bölümünde (28.1.10.);*"...doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez."* hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da 4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen usulsüzlüklerden birinin gerçekleştirilmesi durumunun ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini ifade etmektedir.

Zira rüşvet vermek, sahte evrak düzenlemek gibi yasak fiiller ve davranışlar, aynı zamanda TCK kapsamında tanımlanmış suçlar olması nedeniyle, 4734 ve 4735 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri aracılığıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde

yaptırım uygulanması söz konusu olabilecektir. Hatta bu fiillere memurların iştiraki halinde, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri gereğince, izin almadan adli makamlarca ilgili personelin resen soruşturulması söz konusudur.

Bu bağlamda, doğrudan temin yönteminde ihalelere katılmaktan yasaklılık iki husus çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bunlardan biri Kamu İhale Kurumu tarafından tutulan yasaklılık listesinde bulunan kişilerden doğrudan temin yöntemiyle alım yapılıp yapılamayacağı, bir diğeri ise doğrudan temin sürecinde teklif alınan kişiler ile kendisinden alım yapılan kişiye yasaklılık işleminin uygulanıp uygulanmayacağıdır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 30.5.4'üncü maddesindeki açıklama uyarınca, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi göre parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak kişinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekir. Bu istisna dışında doğrudan teminle yapılan alımlarda alım yapılacak kişinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmemelidir.

Mezkûr Tebliğin "Teyit işlemleri" başlıklı (30.5.4.) bahse konu maddesinde, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlara teyit zorunluluğu getirilmiş olduğundan temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarda teyide gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan doğrudan temin, bir ihale usulü olmadığından, bu yöntem kullanılarak yapılan alımlarda, 4734 sayılı Kanun'un 58'inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Ayrıca 4735 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin de doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer alan (30.5.4.) söz konusu açıklama uyarınca; doğrudan teminin sadece (d) bendine göre belirlenen limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak kişinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. Bahsi geçen kişinin yasaklı olduğunun anlaşılması hâlinde bu kişiden alım yapılmamalıdır.

Buna karşın, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin, yetkili satıcı ya da üretici firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde ise, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.

48. Doğrudan temin kapsamı alımlarda ihalelerde katılmaktan yasaklama teyidi yapılır mı?

Özet: *İhalelerden yasaklama kararının ancak ihale türleri için verilebileceği dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla bir alım yapılması halinde, alım yapılacak kişinin/firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir. Ancak mezkûr Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlara teyit zorunluluğu getirilmiş olduğundan temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarda teyide gerek bulunmamaktadır.*

"Doğrudan temin" kavramı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde, (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmaktadır. Yasa'nın ilk kabul edildiği haliyle bir ihale türü olarak belirlenen "Doğrudan temin", 4964 sayılı Kanun ile bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesi incelendiğinde, doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Her ne kadar 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde yer verildiği üzere, bu kapsamda yapılan alımlara, ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesinin zorunluluk arz ettiği alımlar başta olmak üzere, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması, idarenin taşınmaz mal kiralaması gibi normal ihale usulleri ile karşılanması mümkün olmayan alımlar örnek verilebilir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

İdarelerin doğrudan temin kapsamında en çok kullandığı alım türü Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında yer verilen ve her yıl Kamu İhale Tebliği'nce güncellenen *"parasal tutarlar kapsamında aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar"* oluşturmaktadır. Bu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Konu ihalelerden yasaklama kararı verilmesi hususunda değerlendirildiğinde, öncelikle 4734 ve 4735 sayılı Yasa'lar kapsamında bir yasaklamanın uygulanabilmesi için anılan Kanun'larda yer verilen fiil ya da fiillerin gerçekleşmesi gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bunların ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda, çeşitli (KİK) Kurul Kararlarında da yer verildiği üzere, sözleşmenin uygulanması aşamasındaki suç teşkil eden fiil ve davranışına ilişkin olarak hakkında adli makamlarca kamu davası açılmasına karar verilenlerin, doğrudan temin kapsamında yapılan bir alıma ilişkin olarak teklif vermesi durumunda, teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Aynı şekilde, doğrudan temin kapsamında alıma ilişkin olarak tespit edilen yasak bir fiile ilişkin olarak haklarında kamu davası açılmış olan isteklilerin, normal ihale usullerinden biri ile gerçekleştirilen alıma ilişkin olarak teklif vermesi durumunda, bu nitelikte bir teklifin

değerlendirme dışı bırakılması ve isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki işlemin de mevzuata aykırılık teşkil ettiğini söyleyebiliriz.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi kapsamında yapılan bir alımda, alım yapılacak kişinin/firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak anılan Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 30.5.4. maddesi hükmü uyarınca söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.

Kamu İhale Kurumunun, yasaklama kararlarının verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin bir yetkisinin bulunmaması ve ayrıca şikâyete konu alımların Kanun'a göre ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu alımlar ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmaması nedeniyle, bu yöndeki başvuruların, 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesi gereğince görev yönünden reddi gerekmektedir.

Doğrudan teminin, Kanun kapsamında yer verilen bir ihale türü olmaması nedeniyle, bu alım türüne ilişkin "Yasaklama kararı" verilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Bununla birlikte, tespit edilen fiile ilişkin olarak ceza takibatı gerektiren bir durumun varlığı halinde, ceza kanunları ve diğer kanunlardaki yaptırımlar uygulanacaktır.

Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı" başlıklı maddesinin ilgili bölümünde (28.1.10) ;*"...doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez."* hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da 4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen usulsüzlüklerden birinin gerçekleştirilmesi durumunun ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini öngörmektedir.

Buna karşın, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin, yetkili satıcı ya da üretici

firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.

Görüldüğü üzere; doğrudan temin yönteminde ihalelere katılmaktan yasaklılık iki husus çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bunlardan biri Kamu İhale Kurumu tarafından tutulan yasaklılık listesinde bulunan kişilerden doğrudan temin yöntemiyle alım yapılıp yapılamayacağı, bir diğeri ise doğrudan temin sürecinde teklif alınan kişiler ile kendisinden alım yapılan kişiye yasaklılık işleminin uygulanıp uygulanmayacağıdır.

Diğer taraftan doğrudan temin, bir ihale usulü olmadığından, bu yöntem kullanılarak yapılan alımlarda, 4734 sayılı Kanun'un 58'inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Ayrıca 4735 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin de doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Doğrudan temin ile yapılan alımlarda alım yapılacak kişinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi gerekli değildir. Buna rağmen Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Teyit işlemleri" başlıklı 30.5.4.'üncü maddesinde; *"4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir."* açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 30.5.4'üncü maddesindeki açıklama uyarınca 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi göre parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak kişinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekir. Bu istisna dışında doğrudan teminle yapılan alımlarda alım yapılacak kişinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmemelidir.

Buna karşın, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin, yetkili satıcı ya da üretici

firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.

Mezkûr Tebliğin "Teyit işlemleri" başlıklı 30.5.4'üncü maddesinde, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlara teyit zorunluluğu getirilmiş olduğundan temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarda teyide gerek bulunmamaktadır.

49. Kamu kuruluşları birbirlerinden doğrudan temin kapsamında alımlar yapılabilir mi?

Özet: *İdarelerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler, piyasada istekli konumunda bulunan kişilerden ihale süreçleri kapsamında veya doğrudan temin yöntemiyle piyasa fiyat araştırması yapılmak suretiyle karşılanmaktadır. İdarelerin mevzuatları izin verdiği sürece, doğrudan temin ile birbirlerinden alım yapmalarını hukuken engelleyen açık bir hüküm 4734 sayılı Yasa'da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, şartların oluşması durumunda 4734 sayılı Yasa'nın istisnalar hükmü ışığında, idareler birbirlerinden alım yapabilmektedir. Ayrıca, taşınır işlem fişi ile de idareler ihtiyaç fazlası taşınırları, birbirlerine koşullar oluşması durumunda devredebilirler. Bunların yanında, idarelerin teşkilat yapılarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca, ya da çeşitli özel kanunların izin vermesi durumunda gerek ihale kapsamı ve gerekse doğrudan temin yöntemiyle bu kuruluşlardan alım yapılabilir. Örneğin TÜBİTAK'tan Yasa'nın 22-b maddesi kapsamında alım yapılırken, Ptt'den kargo hizmeti satın alınması mümkündür. Bu nedenle idarelerin birbirinden alım yapmasını, ilgili idarenin niteliği ve faaliyet alanı başta olmak üzere, çeşitli hukuki düzenlemelerin buna izin vermesi ile mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.*

4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca anılan Yasa'nın 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların genel alım yöntemi olan açık ihale usulü ile veya Kanun'daki şartların bulunması halinde belli istekliler arasında ihale usulü ya da pazarlık usulü ile ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir.

İdareler, anılan Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların aynı Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi

veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi şeklinde doğrudan temin yöntemi alımları özetleyebiliriz.

İdareler alım sürecinde, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde düzenlenen, *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…"* hüküm ve ilkeleri çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir.

Bu yöntem kapsamı ihtiyaçlar, doğaları gereği ihale açılarak temini mümkün olmayan, genellikle kısa sürede karşılanması gereken küçük ölçekli ihtiyaçlardır. Doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir satın alma yöntemdir.

Doğrudan temine ilişkin bu genel bilgilerden sonra, bu alım yönteminde, diğer kamu kuruluşlarından bu kapsamda alıp yapılıp yapılmayacağını ortaya koyabiliriz.

Niteliği itibarıyla, idarelerin ihtiyaçları piyasadan karşılanmakta olup, ihale başvuru şartlarını taşıyan kişi ya da firmaların başvurularına istinaden yapılan ihale işlemlerinden sonra alım süreci sonuçlanmaktadır. Bu çerçevede, doğrudan temin yönteminde piyasa fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanır.

Dolayısıyla, bir kamu kurumunun diğer kamu kurumundan mal veya hizmet satın alması normal şartlarda mümkün değildir. Bazen kurumlar arası protokol ile iş birliği yapılabilir. Böyle bir süreçte iş birliği olsa da bir kamu kurumu, diğerine kamu hizmeti satmaz/satamaz. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) güvenlik konusunda iş birliği yapar. Fakat anılan Bakanlıkta kimse güvenlik alımı yapmaz. Kurumların görev alanına girmeyen noktalarda ise idarelerin bu yöndeki ihtiyaçlarının, piyasadan alım yapılmak suretiyle ancak karşılanması mümkündür.

4734 sayılı Yasa'nın istisna maddesi dışında, bazı kamu kuruluşlarının idari yapılarının farklı olması ya da teşkilat yasalarında/kararnamelerinde bulunan özel düzenlemeler nedeniyle çeşitli mal veya hizmeti satması mümkündür. Dolayısıyla bu özelliğe sahip kuruluşlardan alım yapılabilir.

Aynı şekilde, kamu kurumlarının birbirinden doğrudan temin kapsamında, alım yapması her koşulda mümkün değildir. Çünkü idarelerin faaliyet alanları ve hukuki durumları buna izin vermeyebilir. Ayrıca, alıma konu eşya taşınır mal mevzuatı kapsamında ise idarelerin birbirinden talep etmesi veya ihtiyaç fazlası taşınırın ilgili idareye gönderilmesinin de mümkün olduğunu ifade edebiliriz.

Bu kapsamda doğrudan temin kapsamındaki belli bir ihtiyacın farklı bir kamu idaresinden karşılanmasının mümkün olup olmadığı noktasında, 4734 sayılı Kanun hükümlerine baktığımızda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun yalnız 3/e (İstisnalar) maddesinde sayılan kuruluşlardan (bizzat üretmeleri şartıyla) bu Kanun'a tabi olmaksızın alım yapılmasına imkân tanındığını görmekteyiz.

Söz konusu madde;

"..e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar (Ek ibare: 20/11/2008-5812/1 md.) ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, (Ek ibare: 17/01/2019-7161/29 md.) çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar

...Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir."

hükmüne amirdir.

Görüldüğü üzere; 4734 sayılı Yasa'nın 3/e maddesi uyarınca, bazı kurumlara sağlanan istisnalar

nedeniyle, bunlardan istisna kapsamında alım yapılması mümkündür.

Dolayısıyla, Yasa'nın istisna kapsamına giren alımlarının, ihale mevzuatında öngörülen usullere tabi olmadan gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu kapsamda, Et Balık Kurumu, DMO gibi idari birimlerde alım yapılması mümkündür. Bunlar 4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesi kapsamındaki alımlar olmayıp, anılan Yasa'nın 3/e maddesi kapsamındaki istisna alımlardır.

Bununla birlikte, ilgili idarenin teşkilat yapısı izin verdiği sürece doğrudan temin kapsamında alım yapılması da mümkündür. Doğrudan temin kapsamı alımları, sadece 22/d kapsamı alımlar olarak düşünmemek gerekir. Zira Yasa'nın 22/a veya 22/b maddesi kapsamında da doğrudan temin yöntemiyle alımlar söz konusu olabilir.

Örneğin; TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından üretilen sertifikalar ve mini kart okuyucuların, Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesi kapsamında satın alınması mümkündür. Ayrıca, 22/b kapsamındaki alımların parasal limite dahil olmadığını ifade edebiliriz.

Yasanın bahse konu 22/d maddesindeki tutara kadar olan idare ihtiyaçlarının, Kanun kapsamındaki diğer kuruluşlardan, bu arada örneğin pirinç veya mercimek ihtiyacının Toprak Mahsulleri Ofisinden karşılanması mümkündür.

Ancak bu yönde bir alım yapılmasına kendi mevzuatlarınca engel bir durumun olmaması gerekmektedir. Örneğin; Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden mal alınmasına engel bir durum yoktur.

Dolayısıyla, merkezi idarelerin hukuki yapılarının farklı olması nedeniyle, bunlardan ihale veya doğrudan temin kapsamında alım yapılmasının pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Ancak TÜBİTAK, Ptt gibi teşkilat yapılarının farklılık arz ettiği ve kendi özel düzenlemeleri bulunan bu gibi yerlerden alım yapılması mümkündür.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü ve ek 10 uncu maddeleri kapsamındaki alımlar ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar" başlıklı 59'uncu maddesi uyarınca da;

" Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak alım bedelleri ile idarelerin

kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımların ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ürün alım bedellerinin ödenmesinde;
- Onay belgesi,
- Fatura,
-Düzenlenmesi gereken hallerde sözleşme,
-Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
- Taşınır işlem fişi,
ödeme emri belgesine bağlanır.

Aynı fıkra uyarınca, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak hizmet alım bedellerinin ödenmesinde; Onay Belgesi, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13) ve düzenlenmesi gereken hallerde fatura aranır...”

Hususları yer almaktadır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olan idareler, istisna kapsamındaki ihalelerine ilişkin esas ve usulleri, genellikle kendilerinin çıkardığı yönetmelik veya buna yakın hukuki düzenlemelerle belirlemektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinde düzenlenen istisna kapsamı alımlarda, Kanun’da düzenlenen esas ve usullere tabi olmaksızın, idarelerin kendi belirledikleri kriterlere göre alım yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Kanun hükümlerine, yasaklama ve ceza hükümleri hariç olmak üzere tabi olmayan bu kapsamdaki alımlarda, yaşanacak problemlerden dolayı, İdari Yargılama Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, idareye başvurabileceği gibi doğrudan doğruya idari yargıda da dava açılması mümkündür.

Netice itibarıyla; idare ihtiyaçlarının esas olarak piyasadan karşılanması mümkün olmakla birlikte, bazı durumlarda idarelerin birbirinden mal veya hizmet satın alması mümkündür. Buna başta teşkilat yapılarına ilişkin kararnameler olmak üzere, bağlantılı kanuni düzenlemelerin izin vermesi gerekir.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Yasa'nın 3/e istisna kapsamı alımlar uyarınca, idareler istisna yoluyla alım yapabilirken, diğer taraftan TÜBİTAK gibi kuruluşlardan 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında doğrudan temin yöntemiyle de alım yapılması mümkündür.

Söz konusu alımlar kapsamında gerçekleşen ödeme sürecinde ise Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde açıklanan hususların da dikkate alınması gerekmektedir.

50. Doğrudan temin yönteminde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması mümkün müdür?

Özet: *İhalelere yönelik şikayet mekanizması genel olarak ihale kapsamı alımları kapsamakta olup, 4734 sayılı Kanun'da, önce idareye sonra KİK'e yönelik bir şikayet mekanizması öngörülmüştür. İdari başvuru yolları tüketilmeden dava açılması mümkün değildir. Her ne kadar doğrudan temin kapsamındaki alımlar ihale kapsamı dışında olsa bile bu alımlar için de Anayasa'nın 125'inci maddesi çerçevesinde yargı yoluna başvurulması mümkündür. Ancak öncesinde çeşitli yargı kararlarına yansıdığı üzere, şikayetçinin alımı gerçekleştiren idareye başvurarak hatanın düzeltilmesini istemesi, bunun sonucuna göre uyuşmazlığın gerekirse dava konusu edilmesi hem 4734 sayılı Yasa hükümleri hem de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri açısından daha uygun bir işlem olacaktır. Ancak doğrudan temin kapsamı alımlarda, idareden sonra KİK'e yapılan başvuruların, KİK tarafından reddi söz konusu olmaktadır. Kuşkusuz bunun sonucuna göre yargı yoluna başvurması uygun olacaktır. Bunlarla birlikte, doğrudan temin kapsamı alımlar için doğrudan yargı makamlarına başvurulmasını engelleyen açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Böyle bir durumda ise şüphesiz yargı makamlarının vereceği karara göre hareket edilmesi gerekecektir.*

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak ifade edildiği görülmektedir.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, "Doğrudan temin" başlıklı Kanun'un 22'nci maddesi incelendiğinde; doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması

amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile birlikte mali yönden özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Sonrasında ise 5812 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun şikâyetle ilgili maddelerinde değişiklikler yapılmış olup, yapılan söz konusu değişikliklerle, isteklilerin ihalelere yönelik şikâyet başvurularının, ihale süreci ile sınırlı olarak yapılabilmesi hükme bağlanmıştır.

Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, gerçekleştirilen ihale şikâyet sürecinin iki başvuru boyutu bulunduğunu söyleyebiliriz. Bahse konu başvuru yolları ise; şikâyet ve itirazen şikâyettir. Bu bağlamda, ancak ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin öne idareye şikâyet, daha sonra Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri bir sistem öngörülmüştür. Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak Kanun'da düzenlenmiştir.

İstekliler, ihalelere yönelik şikâyet başvurularını, ihale süreci ile sınırlı olarak yapılabilmektedir. İhale süreci, ihale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreci ifade etmektedir.

Bu bağlamda, ihale sonrası sürecin şikâyet konusu edilmesi mümkün olmayıp, bunlarla ilgili doğrudan yargı makamlarına başvuru yapılması gerekmektedir.

Bilinmesi gereken bir husus da ihalelere katılan bir firma hakkında, ihalelere katılma yasağı verilip söz konusu karar da Resmi Gazete'de yayımlanmışsa bu durumun aynı zamanda o firma ile sözleşme yapılamayacağı anlamına gelmesidir. Yani, yasaklama kararının ilanı hem bundan sonra yapılacak ihalelere katılmayı hem de sözleşme yapılmasını engellemektedir.

Bu paralelde, ihalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurularının, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenmesi söz konusu olmaktadır.

1982 tarihli Anayasa'nın 125'inci maddesinde yer aldığı üzere, idare tarafından yapılan işlem veya eylemin yargı denetimine tabi olması sebebiyle, idarenin işlemi hukuka aykırılık teşkil ediyorsa dava açılabilecektir.

İdari yargıda bir işlemin dava konusu yapılabilmesi için yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımından, bir veya birkaç unsurun hukuka aykırılık teşkil etmesi gerekmektedir.

Ayrıca, idare işlemlerinde takdir yetkisini, kamu yararı, kamu hizmetlerinin gerekliliği çerçevesinde kullanılması gerekmekte olup, buna aykırılık ise söz konusu işlemin iptalini gündeme getirmektedir. İdare her işlemde olduğu gibi doğrudan teminle ilgili işlemlerde de bu hususa uyması gerekmektedir. Zira Kanun'un 22'nci maddesinin birçok bendine göre alım sürecinde idarenin takdir hakkı söz konusudur.

Ancak 4734 sayılı Yasa çerçevesinde şikayet mekanizması esas olarak ihale kapsamı alımlar için öngörülmüş olup, buna ilişkin dokümanlarda da esas olarak ihale sürecinden bahsedilmektedir. Doğrudan teminde ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan bir ihale sürecinden bahsedilemez. Dolayısıyla, Kanun'un yukarıda anılan 53'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda idarelerce tesis edilen işlemler itirazen şikâyete konu edilemez.

Bunların yanında, Kamu İhale Kurumuna yapılan şikâyetlere ilişkin olarak, karar alma süreleri, Kurulun alabileceği karar türleri, Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'te ihale sürecine ait usul ve esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yönetmelikte de yer aldığı üzere, ihalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayettir.

Şikayet başvuruları, elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise elden veya posta yoluyla ya da

EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet ile) Kuruma (KİK) yapılır.

Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.

İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulur. Bu şikayet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz.

Görüldüğü üzere; ihale kapsamı bir alımı için şikayet sürecinin söz konusu olması halinde, 4734 sayılı Yasa'nın öngördüğü kurallar uyarınca önce idareye başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak doğrudan temin yöntemi ile alım yapılmasının uygun olduğu durumlarda alımın niteliğine yönelik iddiaları incelemek Kurumun görev alanı dışındadır.

Dolayısıyla, doğrudan temin ile ilgili idari işlem ve eylemler hakkında KİK'in inceleme yetkisi bulunmadığından, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gerçekleştirilen idari işlem ve eylemler için 2577 sayılı Kanun çerçevesinde yargıya başvurulur.

Doğrudan temin suretiyle yapılan alımlara ilişkin olarak, açılan bir davada Danıştayın ilgili dairesince verilen Kararda; "…4734 sayılı Kanunun 54, 55 ve 56. maddelerinde öngörülen usul izlenmeden, başka bir anlatımla öncelikle idareye başvurulmadan ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılmadan açılan davada; 2577 sayılı Kanunun 14. maddesinin (3-b) işaretli bendinde belirtilen merci tecavüzü bulunduğundan, anılan Yasanın 15. maddesinin (1-e) işaretli bendi uyarınca dava dilekçesinin görevli idare merciine tevdiine

karar verilmesi gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır." hususlarına yer verildiği görülmektedir.

Böylelikle idari başvuru yollarından farklı olarak doğrudan temin kapsamı alımlarla ilgili idari yargıda açılan davaların, ayrı bir yargılama usulüne tabi olmadığı görülmektedir.

Farklı bir yargı kararında da ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde ihale makamı tarafından yapılan işlemlere karşı, doğrudan dava açılmasına olanak bulunmayıp, bu işlemlere karşı, anılan Kanun hükümlerinde öngörülen usullere göre ihaleyi yapan idareye yapılacak şikâyet başvurusundan sonra, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurusu sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından verilen kararlara karşı dava açılabilmesinin mümkün olduğu, ihale işleminin de ihale süreci içerisinde ve dolayısıyla da idarî itiraz sürecine tâbi bir işlem olduğunun açık olduğu, bu nedenle, bu ihale işlemine karşı şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında bulunulduktan sonra Kurulca verilen kararın dava konusu edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Karara konu alım türü ihale kapsamı bir alım olsa da kararda dikkat çekildiği üzere, yasanın öngördüğü koşul uyarınca, davadan önce idari mekanizmaların tüketilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, doğrudan temin kapsamı alım da olsa, önce bu işlemi gerçekleştiren idareye başvurmak suretiyle bu işlemin düzeltilmesinin talep edilmesi uygun olacaktır.

Keza idarece sehven olarak hatalı bir işlem yapmış olabilir. Böyle bir durumda dava konusu olmadan uyuşmazlık konusu çözülebilir. Bu durum, usul ekonomisi açısından uygun bir çözüm olacaktır. Kuşkusuz mahkeme kendisine yönelik başvuru doğrudan karara bağlayabilir. Temyiz süreci saklı kalmak üzere, böyle bir karar ise tarafları bağlayacaktır.

Nitekim KİK tarafından verilen bir Uyuşmazlık Kararında da; "… *Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşıldığından ve kapsamda yer almayan bu ihalede idarenin kararına karşın yetkili idare mahkemesine başvurulması gerektiğinden 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun görev yönünden reddine*

... " hususlarının yer aldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14'üncü maddesinde, açılan davada idarî merci tecavüzü bulunup bulunmadığının ilk inceleme sırasında inceleneceği; 15'inci maddesinde de, idarî merci tecavüzü halinde, dilekçelerin görevli idarî mercie tevdiine karar verileceği hususu hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun'un 57'nci maddesinde de, "Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihaî kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür." hükmüne yer verildiği görülmektedir.

Netice itibarıyla;

İdarelerin 4734 sayılı Kanun çerçevesinde yaptıkları alımlar nedeniyle, yüklenici ile aralarında oluşan uyuşmazlıklarda, 4734 sayılı Yasa uyarınca yargı öncesi için idari şikayet mekanizması öngörmüştür. Söz konu şikayet mekanizması ihale kapsamı alımlar ile doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlar açısından farklılıklar içermektedir.

4734 sayılı Yasa kapsamındaki alımlar için önce idareye sonrasında ise, KİK'e yönelik bir şikayet mekanizması söz konusu iken, doğrudan temin yöntemi için böyle bir süreç bahis konusu değildir. Zira Kanun'da yer alan şikayet mekanizması ile ilgili düzenlemeler ihale kapsamı alımlar için geçerlidir. Ancak çeşitli yargı kararlarında yer aldığı üzere, doğrudan temin yöntemiyle de olsa işin niteliği uygun olduğu sürece, yargı yerine başvurulmadan öncelikle idareye başvurulmasının İdari Yargılama Usul Kanunu hükümleri açısından daha uygun olacağı düşünülmektedir. Ancak yüklenicinin doğrudan yargı yerine başvurulmasını engelleyen açık bir düzenleme doğrudan temin kapsamı alımlar için mevcut değildir.

Dolayısıyla, öncelikle idareye başvurulması ve isteklinin talebinin idarece uygun görülmesi durumunda, konu yargıya intikal ettirilmeden çözülmesi suretiyle, hem yüklenici mağdur edilmemekte, hem de idarenin yargı sürecinin muhatabı olması engellenebilecektir.

51. 4734 sayılı Yasa'nın 22/c maddesi kapsamında idare ihtiyaçlarının ihalesiz olarak ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden karşılanması mümkün müdür?

Özet: *4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (c) bendi uyarınca, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden karşılanması mümkündür. Kanun'un 22'nci maddesinin "c" bendi kapsamında yapılacak alımlarda, daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi, toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak sonradan ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Diğer ifadeyle, temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmalıdır. Bu kapsamdaki alımlarda, Kanun'un 5'inci maddesindeki rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile Kanun'un temel alım usullerinin gereği olarak; yapılacak alımların, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak sonradan ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.*

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4'üncü maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir. Kanun'un ilk kabul edildiği haliyle, bir ihale türü olarak belirlenen doğrudan temin, 4964 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

4734 sayılı Kanun uyarınca, doğrudan temin yönteminde, alımın belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup, bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılmasının zorunlu olduğunu ifade edebiliriz.

Kanun'un 22'nci maddesinin (c) bendi uyarınca da mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden karşılanması mümkündür.

Söz konusu zorunlulukların idarece saptanması durumunda, yapılacak alımlarda; ihale komisyonu kurma ve 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilecektir. İdare ile yüklenici (ilk alım yapılan gerçek ve tüzel kişi) arasında asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek sözleşmelerin sürelerinin 3 yılı geçmemesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, Kanun'un 5'inci maddesindeki rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile Kanun'un temel alım usullerinin gereği olarak; daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi; toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmalıdır. Bu saptamaların idarelerin teknik birimlerince yapılması esas olmakla birlikte, bu hususta teknik yardım alınması da mümkün bulunmaktadır.

Yukarıdaki esasların yanında, bu nitelikteki alımlarda, Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart formun kullanılması ve ihale yetkilisince söz konusu formun imzalanması

gerekliliğini ilave olarak belirtebiliriz.

Nitekim 04.03.2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhale Uygulama Yönetmeliklerinde düzenlendiği üzere, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (c) bendi kapsamında idarece yapılacak alımlarda "4734 sayılı Kanunun 22'nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form"un kullanılması zorunluluk arz etmektedir.

Alımın niteliğinin mal (KİK022.0/M) veya hizmet (KİK021.0/H) olmasına göre düzenlenecek standart formun içeriği farklılık arz edecek olup, mezkûr form hazırlanırken dipnottaki belirlemelere özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu paralelde, bu kapsamda yapılacak alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde formda ortaya konulacak ve ayrıca, Kanun'un 22'nci maddesinin anılan bentlerinde belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sağlayan sebeplerin detaylı olarak forma yansıtılması gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılacak mal alımlarında; ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların vb. bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara da yer verilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, bu kapsamda mal ve hizmet alımları yapılırken, yapım işlerinin söz konusu bent (22/c) kapsamında gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağını özellikle söyleyebiliriz.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinin 2'nci fıkrasına göre bu madde kapsamında yapılacak alımlarda ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyacın temin edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, yaklaşık bedelin gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi ve ilgili belgelerin de forma eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu yaklaşık bedelin ise aşağıda yer alan metotlardan hangileri kullanılarak gerçekçi bir şekilde tespit edildiğinin ayrıca ortaya konulması gerekmektedir. Bahse konu yöntemler;

- Aynı hizmetin ilgili tek kaynaktan alan diğer kamu/özel tüzel kişiliklerine veya gerçek kişilere sunuluş fiyatı,
- Aynı hizmet daha önce ilgili tek kaynaktan alındıysa, daha önceki alım bedelinin ÜFE kullanılarak, döviz cinsinden ise tespit tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru üzerinden güncellenmesi,
- İlgili tek kaynaktan istenen proforma fatura,
- Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınan fiyatlar.

şeklinde sıralanabilir. Söz konusu fiyatlar dışında farklı bir yöntemin kullanılması durumunda da buna ilişkin açıklama yapılması ve bu fiyat belirlemeye ait belgelerin de forma eklenmesi gerekmektedir.

51.1. Düzenlenecek sözleşmelerin niteliği nasıl olmalıdır?

4734 sayılı Kanun gereğince, anılan Kanun'un 22/c maddesi kapsamında yapılacak alımlar için; asıl sözleşmeye dayalı olma ve asıl sözleşmenin süresinin bitim tarihinden itibaren üç yılı geçmeme koşulları öngörülmektedir. Asıl sözleşmeye dayalı olma koşulu, hem ilk alım yapılan kişiyle kurulmuş bir sözleşmenin varlığını, hem de bu sözleşmede toplam süreleri üç yılı geçmeyecek yeni sözleşmelerle alım yapılabileceği hususlarına yer verilmesini ifade etmektedir.

Kuşkusuz bu koşulların bir bütün olarak gerçekleşmediği, örneğin, asıl sözleşmede buna imkan veren bir düzenlemenin bulunmadığı durumlarda da mevcut mal, ekipman ve teknoloji ile uyum ve standardizasyon zorunluluğu doğabilecek ve bu zorunluluk idareyi ilk alım yaptığı kişiden alım yapmaya mecbur bırakabilecektir. Bu tür zorunluluklarda, Yasal koşulların oluşmaması durumunda, 22/c maddesi kapsamında alım yapılamayacak, ancak aynı prosedüre tabi bir alım yöntemi olan aynı maddenin "a" bendinin uygulanabilmesi de duruma göre söz konusu olabilecektir.

Altı çizilmesi gereken diğer bir husus ise Yasa maddesinin (22/c) ilk halinde yer alan ve sözleşmenin imzalanmasından sonraki üç yıl içinde sonraki sözleşmelerin yapılması koşulu 4964 sayılı Yasa ile ortadan kaldırılarak, yerine toplam süreleri üç yılı geçmeme koşulunun getirildiğini görmekteyiz.

Bu paralelde, Kanun'un 22/c maddesi kapsamındaki alımlara baktığımız zaman, burada üç unsurun birlikte gerçekleşmesi gerektiğini görmekteyiz. Bu koşullardan birincisi, daha önce alımı gerçekleştirilmiş mal veya hizmetin olması ve söz konusu alımın bir sözleşmeye bağlanmasıdır. İkinci koşul, ilk alımı yapılan kişiden sonraki alımın yapılması ilkesidir. Yani başka bir istekli ile bu kapsamda sözleşme yapılması mümkün değildir. Üçüncü koşul ise, daha önce ifade edildiği üzere, yapılacak sözleşmelerin süresi ile ilgili olup, bu kapsamda ilk sözleşmeye bağlı olarak yapılan sözleşmelerin, toplam sürelerinin 3 yılı geçmemesi kuralıdır.

Diğer bir anlatımla, idare tarafından bu kapsamda yapılacak alımlarda söz konusu üç koşulun aranması idarenin takdirde olmayıp, bunun yasal bir zorunluluk olduğu ifade edebiliriz. Böylelikle, konuya ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer alan düzenlemelerin, Kanun'un "Temel ilkelere" ilişkin 5'inci maddesi dahil olmak üzere, Kanunu tamamlayıcı ve diğer hükümlerinin yanlış yorumlanmasını engelleyici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

Sürecin en hassas noktalarından biri ise, 22/c maddesi kapsamında yapılacak alımlarda, söz konusu standart ve uyumun nasıl ortaya konulacağı hususudur. Bahse konu uyum ve standardizasyonun kapsamının objektif kriterler ışığında açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayabiliriz.

Özellikle mal alımlarına ilişkin bazı durumlarda, marka veya model belirlenmesi zaruri olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, marka ve model belirlemenin bazı gerekçelerinin olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin; herhangi bir idarenin kurum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla milyonlarca liralık bir sistem alması ve kurması durumunda, bu yapı üzerinde geliştirilen yazılımlar sadece o sisteme dönük çalışabilmektedir. Yani geliştirilen veya satın alınan yazılımların bazı sistemlere bağımlı olarak çalışması zorunluluk arz edebilmektedir. Bu durumda, aynı yazılımın çalıştırılabilmesi için, aynı marka veya modelin alınması bazen kaçınılmaz olabilmektedir. Aksi halde, yazılımın çalışmaması ve dolayısıyla idare faaliyetlerinin sekteye uğraması gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, söz konusu kapsamda yapılacak mal alımlarında, satın alınan ürünün, bir başka cihazla birlikte çalışabilme yeteneğine sahip olması gerektiğine dikkat edilmesi ve şartnamede bu hususlara yer verilmesi ve böylelikle, aynı firmaya bağımlı kalma zorunluluğu ortadan kaldırılmalıdır.

Ancak hiçbir şekilde, ihtiyaç olmadığı halde, özel bir firmayı işaret eden tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Bu nedenle, ihalelere ilişkin şartname hazırlanırken idare ihtiyaca en uygun mal veya hizmet tanımının yapılması gerekmektedir. Belirtilen nitelikteki teknik dokümanların ilgili uzman personel tarafından hazırlanması gerekmektedir. Şayet idarede bu nitelikte bir personel yoksa diğer idarelerden bu konuda yardım istenebilmelidir.

Örneğin; Bir kamu idaresinin 2017 yılının Haziran ayında da bilgisayar yazılım ihalesi yapılması ve aynı yılın Ağustos ayında da sözleşmenin imzalandığını ve söz konusu sözleşmenin 4734 sayılı Yasa'nın 22/c maddesi kapsamında 1 yıl ara ile 2 yıllık sözleşmelerle uzatılmasını kabul ettiğimiz bir durumda; söz konusu bent kapsamında 1 yıllık daha 22/c kapsamında sözleşme imzalanabilmesi mümkündür.

Burada dikkat edilmesi gereken, 22/c maddesine göre yapacağınız alımların sayısının değil, toplam süresinin limiti bulunduğu hususudur. Önemli olan, 22/c maddesini kaç kez uyguladığımız değil, uyguladığımız 22/c kapsamı alımlarının toplam sözleşme süresidir. Yani bu sürelerin toplamının 3 yılı aşmaması gerekmektedir.

Diğer bir ifadeyle, farklı dönemlerde, 22/c uygulanarak 12 aylık (toplamda 24 aylık) alım yapan bir idarenin, toplam 3 yıllık süreden geriye kalan 12 aylık alım yapma imkânını, istediği bir dönemde kullanabileceğini söyleyebiliriz. Yani, bu 3 yıllık süre sözleşmenin imzalanması ile başlayan bir süre olarak kabul edilmemelidir.

Görüldüğü üzere; 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin "c" bendi kapsamı alımlarda; Kamu İhale Genel Tebliği'nde de ifade edildiği gibi, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve standardizasyon zorunluluğunun tespiti teknik bir iş olduğundan bu yöndeki tespit ve değerlendirmelerin idarelerin teknik birimlerince veya bu konuda uzman başka kuruluşlarca yapılmasında zaruret vardır. Bu çerçevede, uzman kişi veya kuruluşlar, alımı yapılacak mal veya hizmetin idarede mevcut olan ve halen kullanılan mal, ekipman, teknoloji veya hizmetler için gerekli olduğu, bunların ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesinde uyum ve standardizasyon açısından teknik zorunluluk bulunduğu hususlarını tespit etmelidir.

Bu tespitlerin yapılamadığı, ihtiyacın, uyum ve standardizasyon sorunu yaşanmaksızın başka gerçek veya tüzel kişilerden teminin mümkün olduğu durumlarda, 22/c maddesi kapsamında alımın yapılmaması bunun yerine, ihale usulleri kullanılmak suretiyle alımın gerçekleştirilmesi

gerekmektedir.

22/c maddesi kapsamı alımların bir doğrudan temin kapsamı alım olduğu dikkate alınarak, söz konu alımların, mümkün veya ekonomik olmaması veya gecikmesinde sakınca bulunan koşullarda ihtiyaçların karşılanması için öngörüldüğü unutulmamalıdır.

Bu itibarla, söz konusu bent (22-c) kapsamında yapılacak alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebeplerinin ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konulması ve bunlara ilişkin belgelerin de anılan forma eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, mal alımlarıyla ilgili olarak; ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin ve markaların bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara da ayrıca yer verilmesi gerekmektedir.

Diğer bir anlatımla, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak ihalelere ilişkin yetki ve sorumluluk idarelerin takdirinde olup, idarelerin, 22/c maddesi kapsamındaki yapacakları alımlarda, belli bir marka veya modelin işaret edilmesi, teknik şartnamenin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmaması gibi, rekabetin engelleyen hususlara yönelik işlem ve uygulamaların varlığının, Kanun'un emredici hükümlerine aykırılık taşıyacağı şüphesizdir.

Netice itibarıyla; idarelerin, 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesinin "c" bendi kapsamında yapacakları alımın özel bir alım türü olduğu ve ancak Kanun'da sayılan özel koşulların gerçekleşmesi halinde bu kapsamda alım yapılabileceği, belirtilen koşullara aykırı bir şekilde gerçekleştirilen alımların ise, Kanun'un temel ilkelerine aykırılık taşımasının yanında, adli ve idari takibatı da beraberinde gündeme getirebileceği düşünülmektedir.

52. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilebilir mi?

Özet: *5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 26'ncı maddesi uyarınca kural olarak yüklenme süresi malî yılla sınırlı olmakla birlikte, anılan Yasa'nın 27'nci maddesinde ertesi mali yıla geçen yüklenmelere ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. 5018 sayılı Yasa'nın ilgili hükümleri ile 4734 sayılı Yasa'nın ihale mevzuatında ihale kapsamı alımlar için ön görülen düzenlemeleri saklı kalmak koşuluyla, 5018 sayılı Yasa'nın 27'nci maddesinde alım türleri açısından bir ayrım yapılmadığı için doğrudan temin kapsamı alımlar için de parasal sınırlara uyulmak koşuluyla ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilmesinin mümkün olduğunu düşünmekteyiz.*

"Doğrudan temin" kavramı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde, (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmaktadır. Kanun'un ilk kabul edildiği haliyle, bir ihale türü olarak belirlenen doğrudan temin, 4964 sayılı Kanun'un 12'nci maddesi ile bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde, Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmış olup, Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinde ise, doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Doğrudan temin yöntemi, idarelerin çeşitli günlük ihtiyaçları için ihale usullerince kullanılan prosedürlerden asgari düzeyde gerçekleştiği bir alım şeklidir. İdarelerin doğrudan temin kapsamında en çok kullandığı alım türünü Kanun'un 22/d maddesi kapsamında yer verilen ve her yıl Kamu İhale Tebliğince güncellenen *"parasal tutarlar kapsamında aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar"* oluşturmaktadır.

Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin

aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Doğrudan temin yöntemi kapsamında olmakla birlikte, sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da yükleniciye cezai yaptırımlar ön görülmesi için mutlaka yazılı sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

İhale kapsamı alımlar için 4734 sayılı Kanun, ikincil ve hatta üçüncül düzey mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde alım süreci sonuçlandırılmakla birlikte, ertesi yıla geçen yüklenmelerin bütçe ile ilişkisi 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre şekillenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 26'ncı maddesi uyarınca kural olarak yüklenme süresi malî yılla sınırlı olmakla birlikte, 27'nci maddesinde ertesi mali yıla geçen yüklenmelere ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, söz konusu maddelerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin doğrudan temin ile yaptıkları alımlarda ertesi yıla geçen yüklenme yapabilmelerini engelleyen bir hükmün bulunmadığını söyleyebiliriz.

5018 sayılı Yasa'nın bahse konu hükümlerine bakacak olursak;

"*Yüklenmeye girişilmesi"* başlıklı 26'ncı maddesi;

"Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz."

"Ertesi yıla geçen yüklenme" başlıklı 27'nci maddesi;

"Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın

Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.

b) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.

c) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri.

d) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri.(1)

e) Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt dışından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası.

f) Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri.

g) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, yiyecek ve giyecek alımları makine-teçhizat ile silah, mühimmat ve teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.

h) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.

ı) Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar,

Ancak (d) bendinde sayılan işler için bütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisinin aşılmayacağı hükmü Millî Eğitim Bakanlığı için aranmaz."

Hükmüne amirdir.

Her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlar için başta 4734 sayılı Yasa olmak üzere, Kamu İhale Genel Tebliği ve diğer dokümanlarda alım sürecine ait ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemekle birlikte, bu alım türünden de kamu kaynağı kullanılmak suretiyle harcama yapılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesi hükmü uyarınca, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların yetkili kılınmış mercilere hesap vermeleri zorunludur. Dolayısıyla doğrudan temin kapsamı alımlar için de bu sorumluluk geçerlidir.

5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde ise bütçeden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin, harcama talimatı vermesine bağlanmış, harcama talimatlarında da hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilerin yer alacağı, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken işlemlerden harcama yetkililerinin sorumlu oldukları belirtilmiştir. 5018 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesinde de giderin gerçekleştirilmesinin, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesi ile son bulmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinde, doğrudan temin kapsamı alımlar açısından ertesi geçen yüklenmeye girişilmesini engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Her ne kadar Yasa'nın 62'nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği'nde ertesi yıla geçen yüklenmelerde ihale kapsamı alımlara ait hususlara yer verilmiş olsa da bu düzenlemelerin doğrudan temin kapsamı alımlarda ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilmesini engellendiği şeklinde yorumlanmaması gerekir. Zira ihale türleri için belirlenmiş esaslar, kuşkusuz bu alım türleri için de geçerlidir.

Bu çerçevede, ertesi yıla geçen yüklenme ve ödenek planlanmasına yönelik 5018 sayılı Yasa'nın 27'nci maddesi uyarınca, niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilmesi mümkündür.

Ertesi yıla geçen yüklenmeye ilişkin koşullara baktığımızda;

- *Ertesi yıla geçen yüklenmenin ilk koşulu Yasa'nın 27'nci maddesinde sayılan iş ve hizmetler kapsamından birinin olması gerekmektedir. Bu ilk koşuldan sonra madde metninde yer aldığı üzere,*

- *niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan bir alım olması,*

- *her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisinin, izleyen yılın haziran ayını geçmemesi,*

- *yüklenme süresinin on iki ayı aşmaması,*

- *üst yöneticinin onayı,*

koşullarının sağlanması durumunda ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilmesi mümkündür.

4734 sayılı Yasa'nın "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62'nci maddesinde;

"Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek, yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmak üzere, proje maliyetinin %10'undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. (Ek ibare: 30/7/2003-4964/38 md.) Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir…"

Hususları yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliğinde olan işlere ait ihalelerin yapılma zamanı" başlıklı 19'uncu maddesinde;

"19.1. 4734 sayılı Kanunun "İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar" başlıklı 62 nci maddesinin (b) bendinde; "Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım

niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır." hükmü yer almaktadır. Kanunun anılan maddesinde yer alan düzenlemeyle, ihale konusu işin öngörülen sürede bitirilmesi ve bu iş için öngörülen ödeneklerin zamanında kullanılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılmasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak, idarelerin hukuken geçerli nedenleri bulunması halinde, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlere ilişkin ihalelerin, yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılması yasal bir zorunluluk olarak değerlendirilmemelidir." hususları yer almaktadır.

4734 sayılı Yasa'nın doğrudan temin hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, bu nitelikteki bir alımın sözleşmeye bağlanması ve sözleşmeye gerekli hak ve yükümlülüklerin yazılması uygun olacaktır.

Yasa'nın 62'nci maddesinin gerekçesinde yer aldığı üzere; birden fazla yılı kapsayan işlerde başlangıç yılı ödeneğinin çok az belirlenmesi ve sonraki yıl ödeneklerinin de programlanandan az olacak şekilde sonradan revize edilmesi nedenleriyle işlerin öngörülen sürede bitirilemediği ve sürüncemede kalmaması amacıyla, bu nitelikte işlerin ihale edilebilmesi için proje maliyetinin %10'u oranında başlangıç yılı ödeneğinin ayrılması ve daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimlerinin azaltılmamasının zorunlu kılındığı ifade edilmiştir.

Ayrıca bu esas ile öngörülen amacın sağlanabilmesi için, ihalelerin söz konusu ödeneklerin kullanılabilmesine imkân verecek süre dikkate alınarak zamanında yapılması ve yıllara sari işlerde ise (doğal afetler hariç) yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılması esası getirilmiştir.

Bahse konu maddede daha sonra yapılan değişiklik ile de; bütçeye konulan ödeneklerin verimli ve etkin biçimde kullanılabilmesi ve özellikle yatırım projelerinin zamanında tamamlanabilmesi açısından ihalelerin yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılması esasının benimsendiği, genellikle bir yıllık sözleşmelere dayalı olarak gerçekleştirilen periyodik bakımlar, personel taşıma işleri, kiralama gibi süreklilik arz eden ve her yıl bir önceki yılın tekrarı mahiyetindeki mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelerin ertesi mali yılbaşından önce sonuçlandırılmasının zorunlu olduğu; bu gibi işlerde ertesi mali yıl bütçesi yürürlüğe girmeden ihalelere başlanmasını ve sonuçlandırılmasını mümkün kılan bir düzenlemenin yapıldığı ifade edilmektedir.

4734 sayılı Yasa'da yer almış olsa da doğrudan temin aslında bir ihale türü (usulü) olmayıp, bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur.

Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Doğrudan temin bir ihale yöntemi olmaması nedeniyle, uygulama yönetmelikleri ve eklerinde yer alan hususlar doğrudan temin için geçerli değildir. Bu bağlamda, doğrudan teminde yapılan sözleşmelerde, Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasından hareketle, taraflar anlaştıklarında sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler. Sadece ceza değil, takdir hakkının olduğu konularda da idare belirleme yapıp, düzenlenecek sözleşmelere bu hususları yansıtabilir.

İhale mevzuatı açısından ihale usulleri için esaslar belirlenmiş olmakla birlikte, ödenek kullanımına ilişkin esaslar ve ertesi yıla geçen yüklenmeler 5018 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun'da, ertesi yıla geçen yüklenme için ihale türleri veya doğrudan temin açısından bir belirleme yapılmamıştır.

Diğer bir anlatımla, doğrudan temin kapsamı alımlar için ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilmesini engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yasada öngörülen koşulların varlığı halinde doğrudan temin kapsamı alımda da ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilebilir.

Ayrıca, emredici hükümlere uyulmak koşuluyla doğrudan temin kapsamındaki alımlarda sözleşme de yapılabilir. Sözleşme tarafları bağlar. Zira Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca, bu sözleşmeler bağlayıcıdır.

Netice itibarıyla; yukarıda yer verilen açıklama ve düzenlemeler çerçevesinde, 5018 sayılı Yasa'nın ilgili hükümleri ile 4734 sayılı Yasa'nın ihale kapsamı alımlar için ön gördüğü

düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla, emredici kurallara uyulmak şartıyla, doğrudan temin kapsamı alımlarda da ertesi yıla geçen yüklemeye girişilebileceği, bu bağlamda, 5018 sayılı Yasa'nın 27'nci maddesinde alım türleri açısından bir ayrım yapmadığı için doğrudan temin kapsamı alımlar için de ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilmesinin mümkün olduğunu ifade edebiliriz.

53. Doğrudan temin kapsamı alımlarda ödeme süreci nasıl işlemektedir?

Özet: *5018 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca, bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir. Yani mali işlemin gerçekleştirilmesinde, görevli olanların imzası olmadan ödeme belgesinin tamamlanmış sayılmaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Hakkında Genel Tebliğ'de doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda ödeme emri ekinde yer alması gereken kanıtlayıcı belgeler açıklanmış olup, dolayısıyla, doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödenmesinde ilgisine göre; "Onay belgesi, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Sözleşme (düzenlenmesi gerekli görülmüş ise), Sözleşme düzenlenmesi halinde damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı, Fatura, Muayene ve Kabul Tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece bu hususta düzenlenmiş belge, Mal ve malzeme alımlarında Taşınır İşlem Fişi, Hizmet alımlarında Hizmet İşleri Hakediş Raporu, Mali Hizmetler Biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde görüş yazısı, 22 (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda "Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form", İzne tabi alımlarda ilgili Makamdan alınan izin yazısı ve gerekmesi halinde anılan Yönetmelik ve Tebliğde belirtilen diğer belgeler", ödeme belgesine eklenir.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı maddesinde "Doğrudan temin"; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak ifade edildiği görülmektedir.

Her ne kadar 4734 sayılı Yasa maddeleri arasında yer verilmiş olsa da doğrudan temin aslında bir ihale türü (usulü) değildir. Kanun'un 22'nci maddesinde yer verildiği üzere, bu kapsamda yapılan alımlara, ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesinin zorunluluk arz ettiği alımlar başta olmak üzere, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması gibi normal ihale usulleri ile karşılanması

mümkün olmayan alımlar örnek verilebilir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde; *"Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır."* hükmü; 32'nci maddesinde ise, *"Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur."* hükmü bulunmaktadır.

Bu meyanda, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur..."* hüküm ve ilkelerinin süreçte dikkate alınması gerekmektedir.

Ödeme sürecinde gerekli olan belgeler ise, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ'de belirlenmiştir. Ödeme belgeleri ise, harcama yetkilisi tarafından belirlenen gerçekleştirme görevlisi tarafından düzenlenir ve ekine Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenmiş olan kanıtlayıcı belgeler eklenir.

Buna karşın, Ödeme belgesi, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde tanımlanmış olup, bütçeden yapılacak kesin ödemelerde ödeme emri belgesi kullanılmaktadır. Ödeme belgesinin en az üç nüsha düzenlenmesi, ilk iki nüshasının kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilmesi gerekir. Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının da bağlanması esastır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemeler uyarınca doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde söz konusu belgeler ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri

onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilmelidir.

Ayrıca, doğrudan temin yöntemiyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme ve/veya şartname hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde hakediş raporu da düzenlenmelidir.

Ödemelerde bulunması gereken belgeler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 63'üncü maddesinde belirtilmiş olup, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda ödeme emri ekinde yer alması gereken kanıtlayıcı belgeler anılan Yönetmeliğin Taahhüt dosyası başlıklı 6'ncı maddesinde; Hakediş raporu başlıklı 7'nci maddesinde; Çeşitli hizmet alımları başlıklı 46'ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar başlıklı 63'ncü maddesinde düzenlendiği görülmektedir.

Bu çerçevede, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 7'nci maddesine göre sözleşme yapılması durumunda doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhüt bedellerinin ödenmesinde hakediş düzenleneceği belirtilmiştir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "Taahhüt dosyası" başlıklı 6'ncı maddesinde;

"İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (Örnek:2) veya söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir.
Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır. Ancak, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan belgelerden taahhüt dosyası dışındaki

belgeler bağlanır. taahhüt dosyasının onaylı sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklanır. ”

Hususları yer almaktadır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin “Hakediş raporu” başlıklı 7’nci maddesi ise;

“İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir.
a) Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3) : Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.
b) Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4) :Bu rapor, hizmet işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Hizmet türüne ve işin özelliğine göre yalnızca ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.”

Şeklinde düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere; bahse konu Yönetmelik doğrultusunda eğer doğrudan temin ile gerçekleştirilen söz konusu hizmet veya yapım işi sözleşmeye bağlanmış ise hak ediş raporlarının da düzenlenmesi gerekmektedir.

Konuyla bağlantılı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde;

“- Onay Belgesi,
- Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Fatura,

- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
-Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi,
ödeme belgesine bağlanır."

Her ne kadar Yönetmelik, Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlar için yukarıdaki belgeleri saymış olsa da anılan Yönetmeliği'n 63'üncü maddesi ile diğer hükümleri birlikte dikkate alındığında yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde ilgisine göre;

-Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi,
- Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Sözleşme düzenlenmesi halinde damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı,
- Fatura,
- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
- Mal ve malzeme alımlarında Taşınır İşlem Fişi,
- Hizmet alımlarında Hizmet İşleri Hakediş Raporu,
- Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde görüş yazısı,
- (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda "Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form"
- İzne tabi alımlarda ilgili Makamdan alınan izin yazısı ve gerekmesi halinde Yönetmelik ve Tebliğde belirtilen diğer belgeler,

ödeme belgesine eklenir.

Şayet idarece yapılan harcama temsil ağırlama niteliğinde ise, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde öngörülen belgelerin ödeme emrine bağlanması gerekecektir.

Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ'de; "sınai, teknolojik, malî ve benzeri zorunluluklar nedeniyle yaklaşık maliyetin tespit edilemediği haller dışında, yaklaşık maliyet hesap cetveli veya yaklaşık bedelin tespitine ilişkin belgeler de yukarıda belirtilen ihale onay belgesi veya onay belgesi ile birlikte ödeme belgesine bağlanacaktır." yönünde düzenlemeyle bağlantılı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 2014 yılında yayınladığı bir yazı ile yaklaşık maliyet hesap cetveli ekleme zorunluluğunu kaldırmıştır.

Dolayısıyla bütüncül olarak konuya bakılması ve alımın özelliğine göre ilgili belgelerin beklenmesi daha uygun olur. Bu bağlamda, mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı ve düzenlenmiş ise sözleşme dışındaki belgeler aranır. Yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan hakediş raporları düzenlenir.

Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'da düzenlenmiştir. İdarelerce, usul ve esaslarda belirlenen karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de mali hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde, yapılan alım ön mali kontrole tabi tutulmuş ise, ödeme belgesinin harcama yetkilisi tarafından imzalanmasından sonra ön mali kontrolünün yapılması için ilgili kurumun strateji geliştirme başkanlığına gönderilir. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi danışma ve önleyici niteliği haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

5018 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Giderlerin hak sahiplerine ödenmesinden muhasebe yetkilisi sorumludur. Muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 61'inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme

emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

Kontrol etmekle yükümlüdür.

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

5018 sayılı Kanun'un 61'inci maddesi ile Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, taahhüt ve tahakkuk aşamaları tamamlanmış, ödeme emri belgesi düzenlenmiş ve ön mali kontrolden geçerek ödenmek üzere muhasebe birimine gelmiş bulunan gider ve muhasebe belgeleri ile ön ödeme belgeleri üzerinde, ödemeye ilişkin belgelerin tamam olup olmadığını ve maddi hata bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğu, ilgili mevzuatında belirtilen belgeler dışında belge aramayacağı ve sorumluğunun görevi gereği incelemesi gereken belgelerle sınırlı olduğu belirtilmiştir.

Bu hususta anılan Yönetmeliğin 30'uncu maddesinde de "Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç dört iş günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına aktarılır. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenler, en geç iki iş günü sonuna kadar incelenerek muhasebeleştirme ve ödeme işlemi gerçekleştirilir. Hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaksızın kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabilecek ödeme tür ve tutarları ile kontrol, muhasebeleştirme ve ödeme süresini dört iş gününden daha az olarak belirlemeye, genel bütçe

kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlık, kapsamdaki diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir." düzenlemesi bulunmaktadır.

Muhasebe yetkilisinin, usul ve mevzuatına göre tahakkuk ettirilmiş gideri hak sahibine ödemek ve ödeme yaparken hak sahibinin kimliğini kontrol etmekle görevli olduğu, 5018 sayılı Kanun'un 61'inci maddesinde ve Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 23 ve 29'uncu maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, Muhasebat Genel Müdürlüğünce ayrıca Genel Tebliğ (Sıra No: 77) (Ödeme Belgelerinde Vadesi Geçmiş Vergi Borçları İle Yasal Tevkifat Ve Diğer Kesintilerin Mahsubu) hazırlanmış olup, söz konusu Tebliğ ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ödemelerinde, öncelikle vadesi geçmiş vergi borcu ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ uyarınca mahsup işlemlerinde;

"1) Hak sahibine ait hakedişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme gerçekleştirilebilir. Mahsuben ödemenin gerçekleştirilebilmesi için;

a) Vadesi geçmiş vergi borcunun mahsubunu isteyen hak sahibinden, ilgili vergi dairesi tarafından düzenlenmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu tutarını gösteren belge talep edilir. Bu belge, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de alınabilir. Bu belgenin teyidi Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri aracılığı ile https://ivd.gib.gov.tr internet adresinde yer alan "Doğrulamalar" / "Mükellefiyet Yazısı / Borç Durum Yazısı Doğrulama" ekranından yapılır.

b) Harcama birimince, mevcut veya temin edilecek ödenek karşılığında, hakedişin vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için oluşturulacak ödeme emri belgesine, ödemeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin tamamı ve vadesi geçmiş vergi borcunu gösteren belge eklenir.

c) Harcama birimince ödeme emri belgesinin, muhasebe birimince muhasebe işlem fişinin açıklama alanına ödemenin vadesi geçmiş vergi borcu ve diğer kesintiler için yapıldığı belirtilir ve kanıtlayıcı belgeler (fatura vb.) üzerine de kısmi ödemeye konu tutar belirtilerek şerh düşülür.

ç) Mahsuba konu ödeme işleminde, faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi halinde, harcama birimince, e-faturanın kağıt çıktısı alınıp, yetkilendirilmiş görevli tarafından "Bu e-fatura elektronik imzalı aslı ile aynıdır." ibaresine yer verilir ve hak sahibinin vergi borcunun mahsubunda kullanılacağına ilişkin şerh düşülerek imzalanır.

d) Muhasebe birimince, işleme konu ödeme emri belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler, hakedişin kalan kısmına ilişkin ödeme sürecinde kullanılmak üzere, işlem tarihini izleyen üç iş günü içerisinde, 11/3/2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme başlıklı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) hükümleri çerçevesinde iade edilir.

e) Harcama birimince, ilgili faturaya ilişkin sonraki ödemelerde belgeler üzerinde yer alan şerhlerin kontrolünde azami özen ve önem gösterilir.

f) Mahsuben yapılan vadesi geçmiş vergi borcu tahsilatı, genel bütçe kapsamındaki idarelerde hesaben; genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde ise nakden ilgili vergi dairesine gönderilir…"

Hususları öngörülmüştür.

54. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda kurum bütçesinin %10 sınırı nasıl uygulanır?

Özet: *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinde yer alan "...ı) Bu Kanunun 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz." hükmü uyarınca, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21'inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç, 22'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadan aşmaması gerekmektedir. Bu hususlara uyumun ise, KİK'in sağlıklı verilere ulaşmasının yanında, idare ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması yönündeki yasanın temel ilkelerinin de hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.*

4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların genel alım yöntemi olan açık ihale usulü ile veya Kanun'daki şartların bulunması halinde belli istekliler arasında ihale usulü ya da pazarlık usulü ile ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca idareler, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi şeklinde doğrudan temin kapsamı alımları özetleyebiliriz.

Doğrudan temin, süreklilik arz etmeyen, Kanun'da belirtilen limitler dahilinde ihtiyaçların en kısa sürede temin edilmesi ve ihale için belirlenen prosedürler ile uğraşılmadan alınmasına ilişkin bir yöntemdir.

İhale kapsamı alım türlerinden olduğu gibi doğrudan temin kapsamı alımlarda da 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesindeki *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…"* hüküm ve ilkelerinin süreçte dikkate alınması gerektedir.

Doğrudan temin konusu alımlarda, idarelerin bütünüyle serbest bırakıldığı söylenemez. Yasa'nın 19'uncu maddesinde yer verilen açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verdiği bir ihale usulüdür. Dolayısıyla, Yasa'nın temel ilkelerine en uygun alım yöntemidir. Zira Yasa'nın temel ilkelere ilişkin maddesinde yer verildiği üzere, bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usul olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 4734 sayılı Yasa'da yer verilen özel durumlar olmadığı sürece, alımların bu kapsamda yapılmasını tüm idareler hedeflemelidir. Dolayısıyla Yasa'nın bu temel ilkesi doğrultusunda sınırlı işlemlerle alımın gerçekleştiği 21/f kapsamı alımlar ile 22/d kapsamı alımlara Yasa bir sınır getirmiştir.

Söz konusu yasal sınır ile dolaylı şekilde rekabet koşullarının daha fazla sağlanması suretiyle, bütçe ilkelerinin verimli kullanılmasına yönelik yasal hedef de gerçekleşmiş olacaktır.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin (ı) bendine göre Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21'inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç, 22'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadan aşamamaktadırlar.

Diğer bir anlatımla, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının, mal ve hizmet alımları için 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan parasal limitlerin toplamını; yapım

işlerinde ise 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan parasal limiti geçmemesi halinde, %10 oranının aşılması için Kamu İhale Kurulu'ndan uygun görüş alınması şartı aranmamaktadır.

4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır.

Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı %10 oranını hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil, kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %10'unun aşılıp aşılmamasıdır. İlgili veya bağlı birimler %10 oranının aşılması zorunluluğu doğması durumunda buna ilişkin başvurularını, ilgili veya bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlara yapacaklardır.

Uygun görüş başvuruları, KİK tarafından standartları belirlenen ve EKAP üzerinden doldurulacak form ile yapılır. KİK tarafından uygun görüş talepleri değerlendirilirken, idarelerin ihale ve doğrudan temin yoluyla yaptıkları alım ve işlere ilişkin olarak KİK'e gönderdikleri bilgiler de dikkate alınır.

Bu bağlamda, sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için doğrudan temin kapsamı alımlara ilişkin bildirimlerin EKAP kanalıyla Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi önem arz etmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin (ı) bendinde *"idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin" ifadesinden, bu bentte belirtilen %10'luk sınırlamaya 5018 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen ödeneklerin kullanılması ile ilgili düzenlemeye tabi ödenekler konu olabilecektir. Buna karşılık orduevleri, askeri gazinolar ve sosyal tesislere bütçeden ödenek aktarılmadığı sürece, bunlar Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları alımlar için %10'luk sınırlamaya tabi tutulmayacaklardır. Ancak bütçeden ödenek aktarılması halinde, aktarılan ödeneklerin harcanması sırasında Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları alımlar için %10'luk sınırlamaya tabi olacaklardır."* açıklaması da bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanun'a göre, açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanun'un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

İdarelerin doğrudan temin kapsamında en çok kullandığı alım türünü Kanun'un 22/d maddesi kapsamında yer verilen ve her yıl Kamu İhale Tebliğince güncellenen *"parasal tutarlar kapsamında aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar"* oluşturmaktadır.

Yukarıdaki bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Ancak bu konuda ilgili idarenin bütçesinin %10 seviyesinde bir sınır öngörülmekle birlikte; kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde mal ve hizmet alımları için öngörülen ödenek tutarının %10'unun, Kanun'un 21'nci maddesinin (f) bendi ve 22'nci maddesinin (d) bentlerinde yer alan parasal limitlerin toplamının altında kalması halinde bu maddelerde belirtilen parasal limitlerin toplamı kadar, yapım işleri için bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının %10'unun 22'nci maddenin (d) bendinde yer alan parasal limitin altında kalması halinde ise bu parasal limite kadar olan harcamalar için de Kamu İhale Kurulu'ndan uygun görüş alma şartı aranmayacaktır.

Aşması durumunda, bu nitelikte başvuruların Kamu İhale Genel Tebliği ekinde yer alan forma uygun olarak KİK'e yapılması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin (f) bendi ile 22'nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limitlerin toplamı dikkate alınırken mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ayrılan ödenek tutarları ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Diğer bir anlatımla, "21/f +22/d" kapsamında yapılan alımların toplamı ilgili idarenin

bütçesinin %10'unu aşamaz.

Kamu İhale Kurulu tarafından verilen uygun görüş, verildiği yıl için geçerli ve talepte bulunulan hususlar ile sınırlı olacaktır. Başvuruya ilişkin alınan Kurul Kararları idareye EKAP üzerinden bildirilir.

Kurumlarda ödenek takibi ise, Strateji Geliştirme Başkanlıkları (Mali Hizmetler Birimi) tarafından yerine getirildiği için bu süreçte etkin görev anılan birimlere düşmektedir.

55. İhale usulü olmayan doğrudan temin yönteminde ödeneksiz alım yapılabilir mi?

Özet: *4734 sayılı Yasa'nın, "Temel ilkelerinde" yer aldığı üzere, ödeneksiz alım yapılmaması yasal bir zorunluluktur. Buna aykırılık ise yaptırıma neden olmaktadır. Ödeneksiz harcama yapılmasına yönelik katı hükümler, sadece 4734 sayılı Yasa'da değil aynı zamanda 5018 sayılı Yasa'da da yer almaktadır. Hatta 5018 sayılı Yasa'nın 70'nci maddesi ile yaptırıma bağlanmıştır. Ayrıca, KBS üzerinden işlemler yürütülürken ve KBS üzerinden harcama talimatı düzenlenirken sistem ödeneğinin bulunup bulunmadığını otomatik olarak kontrol etmekte, söz konusu alıma ilişkin yeterli ödeneğin bulunmaması durumunda ise, sistem sonraki aşamaya geçilmesine izin vermemektedir. Muhasebe birimlerinin de bu süreçte yani ödeme aşamasında, görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Mevzuat temelli bu yöndeki bir otokontrolün ise, 5018 sayılı Yasa ile 4734 sayılı Yasa'nın temel ilkelerine uyumluluk arz ettiğini söyleyebiliriz.*

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde, ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmış olup, aynı Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinde ise, doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4'üncü maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir. Ancak buradaki usul kelimesinin, yöntem olarak yorumlanması gerekir. Zira üst paragrafta ifade edildiği üzere, ihale usulleri arasında doğrudan temin yer almamaktadır.

TBMM tarafından kabul edilen, merkezi yönetim bütçe kanunları ile 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere ait giderler için ödenek verilmekte olup, söz konusu Kanun'la kendilerine ödenek tahsis edilen kamu idarelerinin, gerek ihale kapsamı ve gerekse doğrudan temin yöntemiyle ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için harcama yapması ancak ihale mevzuatı ve harcama mevzuatı gibi ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

İhale mevzuatı işlemlerinde temel kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu olup, söz konusu

Kanun'un 5'inci maddesinde sayılan "ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz" hükmü kamu idarelerinin, harcama yaparken Bütçe Kanunu ile belirlenmiş parasal sınırları ve belirlenen kuralları dikkate alma zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Ancak harcama yaparken sadece Bütçe Kanunu'nun madde metni değil, aynı zamanda eki cetvellerde yer alan hususların da dikkate alınması gerekir. Örneğin E cetveli ile "Bazı Ödeneklerin Kullanımına Ve Harcamalara İlişkin Esaslar" belirlenmiştir. Belirlenen bu esaslara aykırılık aslında Bütçe Kanunu'na bir anlamda aykırılık taşımaktadır. Çünkü Bütçe Kanunu ve bağlantılı cetveller, idarelere belirlenen esaslar çerçevesinde hareket edilmesi noktasında hukuki zemin ve zorunluluk oluşturmaktadır. Çünkü bir Kanun'dur ve bağlayıcılık taşımaktadır.

Kamu idarelerinin temel amacı kamu hizmeti yürütmektedir. Şüphesiz bu görevi yerine getirirken mal, hizmet veya yapım işine (hatta danışmanlık faaliyetine) ihtiyaç duyabilirler. Bahse konu ihtiyaçları karşılayabilmek için parasal kaynağa ve kurallara ihtiyaç duyulmaktadırlar. Bütçe Kanunu ile öngörülen bu kaynak, idarelerin harcama yapması suretiyle somutlaşmaktadır.

Bütçe Kanunu yıllık olması nedeniyle taşıdığı hükümler de o yıl için geçerlilik taşımaktadır. Oysa kamu mali yönetimi alanında temel yasal düzenleme 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'dur. Ödenek sürecinde, Bütçe Kanunu ile birlikte 5018 sayılı Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Bahse konu 5018 sayılı Kanun kapsamına, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolü girmektedir.

Söz konusu Kanun; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolünü düzenlemektedir.

Ödeneklerin aşılmaması hususu ise yine 5018 sayılı Kanun hükmü ile ortaya konulmuş olup,

aynı Kanun'a göre ödeneklerin aşılması yaptırıma konu olabilmektedir. Bu nedenle olası yaptırıma muhatap olmamak ve aynı zamanda, bütçe kaynaklarının zamana ve ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmesi için takip ve kontrolü gerekmektedir. Zira mevcut düzenlemeler istisnai durumlar hariç olmak üzere, ödenek üstü harcamaya izin vermemektedir.

Nitekim 5018 sayılı Kanun'un "Ödeneklerin kullanılması" başlıklı 20'nci maddesi; *"Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:*

(a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

(b) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar

(c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usûl ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

d) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir…"

Hükmüne amirdir.

Bütçe kullanımı ile ilgili temel esaslar 5018 sayılı Kanun'da düzenlenmekle birlikte, 4734 sayılı Kanun'da bu hususta sınırlı da olsa düzenlemeler yapıldığını görmekteyiz. Nitekim 4734 sayılı Kanun hükmü çerçevesinde, alım için yeterli ödeneğin ilgili idare bütçesinde yer almaması durumunda alımın gerçekleşmemesi gerekmektedir. Bu durum anılan Kanun'un 5'inci maddesinde hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Yasa'nın "Temel ilkelere" ait hususların yer aldığı 5'inci maddesinin "Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz." hükmü, idareleri olası iş artışlarını ve bütçe imkânlarını da göz önünde bulundurarak alım sürecini başlatmalarına dikkat çekmektedir. Zira ödeneği olmayan veya yetersiz olan bir işe girişilmesi, söz konusu alım sürecinin yarıda kalmasına neden olabilir.

Yasa'da yer alan söz konusu düzenleme İhale Uygulama Yönetmeliklerine de yansıtılmış olup, benzer şekilde, Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca; ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

İdareler, ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmelerini tabi oldukları mali mevzuat ve diğer mevzuatı esas alarak gerçekleştirir. Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla öngörülen ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. Yatırım projesi kapsamındaki işlerde ilk yıl için öngörülen ödenek, proje maliyetinin %10'undan az olamaz ve başlangıçta programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

İdarece, tespit edilen ihtiyacın giderilebilmesi, dolayısıyla mal veya hizmet satın alınabilmesi, yapım işlerinin yaptırabilmesi için yeterli ödeneğe sahip olunması zorunludur. 4734 sayılı Kanun'da ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, idarelerin süreklilik arz eden ihtiyaçlarının giderilebilmesi için, ertesi mali yıl bütçesi yürürlüğe girmeden önce ihalenin başlaması ve sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, ihtiyacın belirlenmesi/bildirilmesi aşamasında, ödenek kontrolünün yapılması gerekmektedir. Çünkü ödeneği olmayan hiçbir mal veya hizmet alımı veya yapım işi için alımın gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi hükmüne göre, kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer

alır. Kamu İhale Mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almaktadır.

Bu nedenle, 5018 sayılı Kanun'a göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgelerdir.

Bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir. Dolayısıyla, ihale konusu işler için bütçede yeterli ödeneğin bulunması ve harcamanın başlangıcını teşkil eden harcama talimatlarının ödenek dahilinde imzalanması gerekmektedir.

4734 sayılı Yasa'nın "Temel ilkelerinden" sayılan, ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz hükmünün tüm alım türleri için geçerli olduğu düşünülmektedir. Çünkü söz konusu maddede alım türleri açısından bir ayrım yapılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, doğrudan temin yönteminde de kamu kaynağı kullanıldığı hususu dikkate alındığında, bu ilkenin doğrudan temin kapsamı alımlar için de geçerlilik arz ettiği açıktır.

Kamu idarelerinin, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapmasına ilişkin hususların yer aldığı 5018 sayılı Yasa'nın "Ödenek üstü harcama" başlıklı 70'nci maddesinin; *"Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir."* yönündeki hükmü de ödenek üstü harcamayı yaptırıma bağlamak suretiyle engellemektedir.

5018 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanılan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar"da ise, ödenek gönderme süreci ve ödenek aktarmaları konusunda da açıklamalar yer almaktadır. Bu düzenlemede ise;

Bütçe ödeneklerinin dağıtımının ödenek gönderme belgesiyle yapılacağı, ödenek gönderme belgelerinin harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderileceği, yılı merkezi yönetim bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe

tertibine, ayrıntılı harcama veya finansman programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgelerinin en geç üç işgünü içinde sonuçlandırılacağı, uygun görülmeyen ödenek gönderme belgelerinin gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderileceği hususları yer almaktadır.

Öte yandan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kanun ve merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar ile diğer idarelerin ilgili düzenlemeler çerçevesinde bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine malî hizmetler biriminin bütçe ve performans programı alt birimi tarafından hazırlanacağı ve üst yöneticinin onayına sunulmadan önce iç kontrol alt birimi tarafından kontrol edileceği, bu şekilde yapılacak aktarmaların ilgisine göre Kanun, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kontrol edilerek en geç iki işgünü içinde sonuçlandırılacağı, mevzuatına aykırı bulunan aktarma taleplerinin, gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderileceği hususları yer almaktadır. Yapılan düzenlemeler uyarınca, ödenek aktarmalarının idarenin mali hizmetler biriminin iç kontrol alt birimi dışında diğer alt birimleri tarafından elektronik ortamda hazırlanıp onaylanması halinde ön mali kontrol yapılmış ve uygun görüş verilmiş sayılmaktadır.

Onay belgesinde "Bütçe Tertibi" bilgisi de yazılmakta olup, ihale yetkilisi ihale onay belgesinde belirtilen bilgilere onay vermekte ve alım süreci burada belirtilen usulde gerçekleşmektedir. Bu süreçte, bütçe tertibinin yazılmaması veya hatalı yazılması ise ihale onay belgesinde işin esasını etkileyecek bir husus olmadığından, bunun ihale iptal gerekçesi olmayacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, alım sürecinde bütçe tertibi olarak farklı bir tertip belirtilmesi durumunda çeşitli nedenlerle oradan ödenmeyip farklı bir tertipten de ödenme söz konusu olabilir. Esas olan alım sürecine ait yeterli ödeneğin bulunmasıdır. Bazen ödenek aktarımı suretiyle de ödenek sorunu çözülebilmektedir.

Ayrıca, 4734 sayılı Yasa'nın, 21 ve 22'nci maddelerdeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz yönündeki hükmü de idareleri ödenek kullanımı konusunda dikkatli davranmaya sevk etmektedir.

Bu ise, Bütçe Kanunu'yla kendilerine ödenek tahsis edilen kamu idarelerinin, doğrudan temin yoluyla da olsa ihtiyaç duydukları alım türleri için harcama yapmasını ancak mevzuatta öngörülen belirli yükümlülükleri yerine getirmeleri ile mümkün olabileceğini göstermektedir.

Diğer bir anlatımla, harcama yetkililerince ihale onay belgelerini imzalanırken, yani harcama talimatı verilirken, bütçede ödeneğin bulunması, bir ön koşul olarak ortaya çıkarmaktadır. Buna rağmen ödeneği bulunmayan işler için talimat verilmesi, anılan Kanun'un 70'inci maddesine göre harcama yetkililerinin para cezası ödemesine sebep olacaktır.

Nitekim 5018 sayılı Yasa'nın "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinin "Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır." şeklindeki hükmünün de süreçte görev alanların mevzuat dışında hareket etmesini engelleyici şekilde düzenlendiğini söyleyebiliriz.

Bunlarla birlikte, manuel düzenlenen belgeler hariç olmak üzere, KBS üzerinden harcama talimatı düzenlenirken sistem ödeneğinin bulunup bulunmadığını otomatik olarak kontrol etmekte, söz konusu alıma ilişkin yeterli ödeneğin bulunmaması durumunda sistem sonraki aşamaya geçilmesine izin vermemektedir. Bu uygulama çerçevesinde, ödeneksiz alım yapılmasını engelleyen gerek 4734 sayılı Kanun'un ve gerekse 5018 sayılı Kanun hükümlerinin pratik karşılığının, iş ve işlemlere yansıtıldığını dile getirebiliriz.

56. Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan temini için doğrudan temin yöntemi kullanılabilir mi?

Özet: *4734 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri ışığında Kamu İhale Genel Tebliği'nde açıklık getirildiği üzere, ihalenin iptal edilmesi, mahkemece yürütmenin durdurulması veya iptal kararının verilmesi gibi sebeplerle ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin (b) bendindeki "idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar" kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62'nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanun'un 21'inci maddesinin (f) bendi ya da 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların anılan maddelere göre temin edilebilmesinin mümkün olduğunu ifade edebiliriz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu Yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanmasındaki süreç ise bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir.

Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların genel alım yöntemi olan açık ihale usulü ile veya Kanun'daki şartların bulunması halinde belli istekliler arasında ihale usulü ya da pazarlık usulü ile ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların, Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi

veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi şeklinde doğrudan temin kapsamı alımları özetleyebiliriz.

4734 sayılı Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Satın alma sürecinde ihale usulleri için öngörülen diğer kuralların ve işlemlerin göz ardı edilmesi veya uygulanmamasına ilişkin bir hükmün 4734 sayılı Yasa'da olmadığını söyleyebiliriz.

Söz konusu ihtiyaçlar, doğaları gereği ihale açılarak temini mümkün olmayan, işin doğası, piyasa koşulları ve çeşitli yasal düzenlemelerle idarelerin tercih hakkının ortadan kalktığı ihtiyaçlardır. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın bu kapsamda karşılanması söz konusu değildir; doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir yöntemdir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. bendinde yer alan; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenleme ile sözleşme yapma konusunda idareler serbest bırakılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda doğrudan temin uygulamasına ilişkin düzenleme ilgili Kanun'un 22'nci maddesi kapsamında yer almıştır. İlgili madde kapsamında idarelerin, hangi nitelikteki alımlarının doğrudan temin kapsamında yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliği'nin doğrudan temine ilişkin 22'nci maddesinde ise, doğrudan temin kapsamı alımlar ve alım yönteminin uygulama esasları Kamu İhale Kanunu çerçevesinde açıklanmıştır.

5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu İhale Mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama

yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır.

Kamu idarelerinin temel görevi kamu hizmeti üretmektedir. Söz konusu hizmetleri üretirken çeşitli ihtiyaçları da söz konusu olabilmektedir. Bazı ihtiyaçlar dönemsel iken, bazı ihtiyaçlar ise süreklilik arz edebilir. Dolayısıyla, bu nitelikteki ihtiyaçların kesintiye uğramadan karşılanması gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 20'nci maddesinin;

"20.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıştır. Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki "idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar" kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve sorumluluğundadır." şeklinde belirlenen düzenlemesi doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, ihalenin iptal edilmesi, mahkemece yürütmenin durdurulması veya iptal kararının verilmesi gibi sebeplerle ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin (b) bendindeki "idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar" kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62'nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanun'un 21'inci maddesinin (f) bendi ya da 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların anılan maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve sorumluluğundadır.

Açık ihale usulü ihtiyaçların temininde temel usul olup, Kanun'da öngörülen durumlarda kullanılan pazarlık ihale usulü (21/f) ile doğrudan temin yöntemi (22/d) limitler dahilinde kullanılabilir.

Ancak 4734 sayılı Kanun'a eklenen 62'nci maddenin (ı) bendi ile 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiştir. Söz konusu madde ile Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapacakları harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı öngörülmüştür. Her ne kadar ödeneklerin takip süreci mali hizmetler birimine ait olsa da idarelerin de bu hususa dikkat etmesi gerekir.

Dolayısıyla, alıma konu ihtiyaç 22'nci maddenin (d) bendinde belirtilen tutarları aştığı durumlarda ise, Kanun'un 21'inci maddenin (b) bendi veya 21'inci maddenin (f) bendine göre de alım yapılma imkânı bulunmaktadır.

Şayet ihalenin iptal edilmesi durumda ise konu Kamu İhale Genel Tebliği'nin bu düzenlemesi uyarınca doğrudan temin kapsamında alınabilir. Ancak ihtiyaç konusu alım için aciliyet gerektiren bir durum yoksa normal ihale usulü ile karşılanması daha uygun olacaktır.

Kamu idarelerinin temel görevi başta Anayasa olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nde ve ilgili yasalarla verilen görevleri yerine getirmeleridir. Bu görevi yerine getirmek için mal alımı, hizmet alımı veya yapım işi alımı söz konusu olabilir.

Nitekim 4734 sayılı Yasa'nın "Temel ilkeler"e ilişkin 5'inci maddesinde yer aldığı üzere; idareler, bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Bu itibarla, idarenin süreklilik arz eden ihtiyaçlarının kesintiye uğramadan temin edilmesi amacıyla doğrudan temin kapsamında bu ihtiyaçların karşılanması, aynı zamanda Yasa'nın "ihtiyaçların zamanında karşılanması" şeklindeki temel ilkesi ile de örtüşmektedir.

57. Doğrudan temin kapsamında kullanılmış makine, taşıt veya demirbaş alımı yapılabilir mi?

Özet: *Kamu İhale Mevzuatı düzenlemelerinde kullanılmış makine, demirbaş veya taşıt alımını engelleyen açık bir hüküm bulunmaktadır. Bilakis idare ihtiyaçlarının uygun koşullarda ve zamanında karşılanması gerekliliği Yasanın temel ilkeleri arasında sayılmıştır. Bu nedenle gerek ihale usulü kapsamında ve gerekse doğrudan temin yönteminde sıfır veya kullanılmış makine veya araç satın alınması mümkündür. Ancak bu hususa ilişkin olarak ihale dışı mevzuatta bir engel bulunmaması gerekir. Bu kapsamda alınacak makina, demirbaş, taşıt/taşıtlar için şartların ve sınırlamaların (örneğin araç için Bütçe Kanunu'nun T Cetveli) dikkate alınması, bir engel yoksa alıma konu eşyanın teknik özelliklerinin, ihale dokümanında belirtilmesi önem arz etmektedir. Muayene kabul sürecinde de bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dolayısıyla, ihale mevzuatı dışındaki hukuki düzenlemelerde bir engel bulunmadığı sürece, kullanılmış veya kullanılmamış taşıt, makine ve demirbaş alımı yapılması noktasında, hizmetin niteliği dikkate alınarak idarenin kendi tercihini kendisinin belirleyebileceğini söyleyebiliriz. Vermiş olduğu bu kararı da ihale (alım) dokümanlarına yansıtması önem arz etmektedir.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Söz konusu Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır.

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur. Bunların dışında, satın alma sürecinde ihale usulleri için öngörülen diğer düzenlemelerin uygulanmamasına ilişkin Kanun'da açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, duruma göre söz konusu genel düzenlemeler, doğrudan temin yöntemi için de söz konusu olabilecektir.

Söz konusu ihtiyaçlar, doğaları gereği ihale açılarak temini mümkün olmayan, işin doğası, piyasa koşulları ve çeşitli yasal düzenlemelerle idarelerin tercih hakkının ortadan kalktığı ihtiyaçlardır. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın bu

kapsamda karşılanması söz konusu değildir; doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir yöntemdir.

4734 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. bendinde yer alan; *"Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir."* şeklindeki düzenleme ile sözleşme yapma konusunda idareler serbest bırakılmıştır.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'da belirtilen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin idarece işin niteliğine göre düzenlenip kullanılması mümkündür.

Ancak doğrudan teminle yapılan alımlarda hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılması zorunluluğu olmamakla birlikte, bu kapsamda düzenlenecek sözleşmelerin emredici hukuk kurallarına, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmaması gerekmektedir.

Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde gerek ihale kapsamı alımlar ve gerekse doğrudan temin kapsamı alımlarda, kuşkusuz ihale mevzuatı hükümleri ilk aşamada göz önünde bulundurulsa da alım sürecine ilişkin iş ve işlemler sadece ihale mevzuatı ile sınırlı değildir.

Alımın niteliğine bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları da kendi görev ve yetkileri çerçevesinde düzenlendiği mevzuat ile süreci etkileyebilmektedir. Çünkü her kurumun görev alanı ve uzmanlaşması farklılık arz edebilmektedir.

Bu kapsamda ihale sürecinde yani kullanılmış makine ithalatının yüklenici tarafından idareye sunulması durumunda bunu kabul edip etmeyeceği hususu önem arz etmektedir.

Tüm eşya ithalatında olduğu gibi kullanılmış makine ithalatına ait temel yetki Ticaret Bakanlığına aittir. Bu hususta düzenlenmiş bulunan İthalat Rejim Kararı'nın "Özel nitelikli eşya" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve

yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ithali Ticaret Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)'nın iznine tabidir.

Söz konusu rejim kararına istinaden anılan Bakanlıkça "Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)" hazırlanmış olup, söz konusu tebliğ ile kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ ekinde yer alan listelerde izin alınarak veya izin alınmadan ithal edilebilecek kullanılmış eşyaların listesi bulunmaktadır. Kullanılmış malların teklif edilmesine izin verilen veya verilecek ihale kapsamı alımlarda bu Tebliğin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde izne tabidir. Söz konusu Tebliğ ile belirlenen eşyaların ithalat sürecinde uygunluk yazısı düzenlenmesi söz konusu olup, anılan Tebliğde ayrıca ithalat sürecinde yapılması gereken iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

İsteklilerin kullanılmış mal teklif edebilmelerine yönelik ihale dokümanında düzenleme yapılıp yapılamayacağı konusunun, idarelerin tabi oldukları diğer (4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat dışında) mevzuat ile alım konusu malın piyasaya arzını ve satış sonrası servisini, bakımını ve garantisini düzenleyen mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İdarelerin tabi oldukları mevzuatta kullanılmış mal teklif edilmesini engelleyen hüküm bulunmaması durumunda, kamu hizmetinin niteliği dikkate alınarak isteklilerin kullanılmış mal teklif edebilmelerine yönelik ihale dokümanında düzenleme yapılması idarelerin takdirinde bulunmaktadır.

İdarelerce kullanılmış mal teklif edilmesine izin verilmesi için ihale dokümanında düzenleme yapılırken ilgili mevzuatın dikkate alınması, ilgili kuruluşların düzenlemelerinde kullanılmış mal alınmamasına yönelik düzenleme var ise kullanılmış mal alımı yapılamayacağı açıktır.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerde yabancı isteklilerin de teklif verebileceği veya ithal ürünlerin teklif edilebileceği göz önünde bulundurularak, kullanılmış mal teklif edilip edilemeyeceği konusunda yapılacak düzenlemelerde, ithalata ve standardizasyona ilişkin teknik mevzuat hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

İdarenin tabi olduğu mevzuatta veya ürüne ilişkin mevzuatta kullanılmış mal teklif edilmesini engelleyen hükmün bulunmaması ve idare tarafından isteklilerin kullanılmış mal teklif etmelerine izin verilmesi durumunda, sağlıklı bir değerlendirme ve muayene ve kabul işlemleri için ihale dokümanında ürünlerin değerlendirilmesine yönelik açık düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, kullanılmış mal teklif edilebilmesine izin verilmesine dair gerekçenin, ihale onay belgesi ekinde yer alması gerekmektedir.

Dolayısıyla, kullanılmış mal teklif edilebilecek mal alımı ihalelerinde, isteklilerin kullanılmamış mal teklif etmelerini önleyecek düzenleme yapılmamalıdır. İdarelerce kullanılmış malların yaşına yönelik düzenleme yapılması mümkündür. Örneğin; Ticaret Bakanlığı yurda eşya giriş sürecine ait kontroller kapsamında almayı düşündüğü x-ray cihazları için belli bir yaşı geçmemesine yönelik kurum içi düzenleme yapabilir. Bu kurala Bakanlığın tüm birimleri uymak zorundadır. Ya da Sağlık Bakanlığınca insan tedavisinde kullanılan bir tıbbi cihaz için kullanımım için yıl veya model şartını düzenlediği bir Tebliğ ile sınırlandırmışsa bu hususa sadece anılan Bakanlık değil tüm kamu kurumları uymak zorundadır.

Kullanılmış makine veya demirbaş gibi kullanılmış taşıt alımı da söz konusu olabilir. Mevzuatta kullanılmış taşıt alımını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki açık ihale usulü kullanılarak veya doğrudan temin yöntemlerinden birisi kullanılarak sıfır veya kullanılmış araç satın alınabilir. Alınacak taşıt/taşıtların Bütçe Kanunu'nda belirtilen şartların ve sınırlamaların (T Cetveli) dikkate alınması ve ihale dokümanında (özellikle teknik şartnamede) teknik özelliklerinin belirtilmesi önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, hizmet alım ihaleleri kapsamında KİK tarafından verilen 2012 tarihli bir Uyuşmazlık Kararında; teknik şartnamenin yedek parçayı tanımlayan düzenlemelerinde, yedek parçanın başka bir cihazdan çıkma veya ikinci el olmaması gerektiği hususunun belirtilmiş olması, idare açısından uygun bir eylem olarak yorumlanmıştır.

Farklı bir alım kapsamında, bakım ve cihazların onarımı sırasında "yeni yedek parça kullanılmasına" yönelik ihale dokümanındaki düzenlemenin maliyetleri artırdığı ve idareye katkı sağlamadığına ilişkin iddia ile ilgili olarak verilen farklı Kamu İhale Kurulu Kararında ise, sistemdeki aksamaların en aza indirilmesini teminen bu yönde bir düzenleme yapıldığı

ifade edildikten sonra idarenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu nitelikte bir düzenleme yapma hakkına sahip olduğuna karar verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, 4734 sayılı Yasa'da ihale türleri için belirlenmiş olan düzenleme ve kısıtlamalar, bazen doğrudan temin için de geçerlilik arz edebilir. Dolayısıyla, yasaklama ve kısıtlamanın kaynağı, ihale mevzuatı dışı farklı bir mevzuattan kaynaklanıyorsa ve bu mevzuatta alım türleri veya parasal sınır açısından bir ayrım görülmemişse, bu düzenleme doğal olarak doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımı da kapsayacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ithalat mevzuatı yurda kullanılmış makine ithalatını izne tabi tutuyorsa, alımı gerçekleştirecek idare bu mevzuatı göz ardı edemez. Ancak serbest dolaşımda olan yani vergileri ve yükümlülükleri yerine getirilmek suretiyle, millileşmiş bir eşya için artık ithalat süreci bitmiştir. Bu nitelikte bir eşyanın alımının mümkün olup olmadığına ise idare, hizmetin niteliğini dikkate alarak karar verecektir.

Kanun'un 22'nci maddesi incelendiğinde ise doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak, belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir.

Şartname ve sözleşme düzenlenmesi idarenin takdirinde bir husus olmakla birlikte özellikle süreli alımlarda, bir başka ifadeyle işin gerçekleştirilmesinin belli bir süreye bağlı olduğu mal, hizmet veya yapım işlerinde sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Şayet idarece şartname ve sözleşme düzenlenmesi söz konusu ise, bu gibi durumlarda; şartname ve sözleşme düzenlenecek hallerde; Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan Tip Sözleşme ve Tip

Şartnamelerin kullanılma zorunluluğu, 4734 sayılı Kanun'un idari şartnamede bulunması zorunlu hususlara uyma zorunluluğu, 4735 sayılı Kanun'un sözleşmede bulunması zorunlu hususlara uyma zorunluluğu olmaksızın, işin niteliğine göre; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşme metni kullanılabilecektir.

Bu itibarla, kullanılmış makinenin veya demirbaşın idare tarafından alımın söz konusu olması durumunda, bu hususta ithalat mevzuatı hükümlerinin dikkate alınması gerektiğini, anılan mevzuat uyarınca ithalat yükümlülüğü biten bir eşyayı idare isterse, alım dokümanlarında buna yer vermek şartıyla satın alabileceğini ifade edebiliriz.

Dolayısıyla, ihale mevzuatı dışındaki diğer mevzuattan kaynaklanan özel bir durum olmadığı sürece, gerek ihale kapsamı alım olsun, gerekse doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alım olsun, idare ihtiyacının niteliği, dolayısıyla kamu hizmetinin sunumunu olumsuz etkilemediği sürece ihale (alım) dokümanlarında gösterilmek şartıyla kullanılmış makine veya demirbaş alımı da yapması mümkündür.

Bu nedenle, doğrudan temin yönteminde de piyasa fiyat araştırma yazısında ya da düzenlenmesine karar verilmişse idari veya teknik şartname gibi diğer dokümanlarda bu hususa ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verilmesi şartıyla, kullanılmış makine ve demirbaş alımı yapılmasının mümkün olduğunu ifade edebiliriz.

58. Doğrudan temin kapsamı alıma ait ödeme sürecinde Bütçe tertibi yönünden "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" açısından parasal sınır var mıdır?

Özet: *5018 sayılı Yasa hükümleri uyarınca, ödeneksiz harcama yapılması mümkün olmadığı gibi ödenek üstü harcama yapılması da mümkün değildir. Bütçe Kanunu'na ekli cetvellerden "E cetveli" ile de bazı ödeneklerin kullanımına ait esaslar belirlenmiş olup, söz konusu cetvel ile belirlenen düzenleme ve limitler bağlayıcılık taşımaktadır. Bu bağlamda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "E cetvelinde" yer verildiği üzere; Menkul mal alımlarında 28.000 Türk Lirasını, Gayrimaddi hak alımlarında 23.000 Türk Lirasını, Menkul malların bakım ve onarımlarında 28.000 Türk Lirasını, Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 62.000 Türk Lirasını aşan tutarların "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerinden ödenemeyeceğini, bunun yerine "06- Sermaye Giderleri" tertibinden ödenmesi gerektiğine dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca 2022 yılı için geçerli olan söz konusu limitler sadece ihale kapsamı alımlar için geçerli olmayıp doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda da ilgili bütçe tertibinin belirlenmesinde bahse konu tutarların dikkate alınması gerekmektedir.*

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

TBMM tarafından kabul edilen, merkezi yönetim bütçe kanunları ile 5018 sayılı Kanun kapsamı idarelere ait giderler için ödenek verilmekte olup, söz konusu Kanunla kendilerine ödenek tahsis edilen kamu idarelerinin, gerek ihale kapsamı ve gerekse doğrudan temin yöntemiyle ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için harcama yapması ancak ihale mevzuatı ve harcama mevzuatı gibi ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

İhale mevzuatı işlemlerinde temel kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu olup, söz konusu Kanun'un "Temel ilkelerine" ait 5'inci maddesinde sayılan "ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz" hükmü; kamu idarelerinin, harcama yaparken Bütçe Kanunu ile belirlenmiş parasal sınırları ve belirlenen kuralları dikkate alma zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Ancak harcama yaparken sadece Bütçe Kanunu'nun madde metni değil, aynı zamanda eki cetvellerde yer alan hususların da dikkate alınması gerekir. Örneğin E cetveli ile "Bazı Ödeneklerin Kullanımına Ve Harcamalara İlişkin Esaslar" belirlenmiştir. Belirlenen bu esaslara aykırılık aslında Bütçe Kanunu'na bir anlamda aykırılık taşımaktadır. Çünkü Bütçe Kanunu ve bağlantılı cetveller, idarelere belirlenen esaslar çerçevesinde hareket edilmesi noktasında hukuki zemin ve zorunluluk oluşturmaktadır. Çünkü bir Kanun'dur ve bağlayıcılık taşımaktadır.

Kamu idarelerinin temel amacı kamu hizmeti yürütmektedir. Şüphesiz bu görevi yerine getirirken mal, hizmet veya yapım işine (hatta danışmanlık faaliyetine) ihtiyaç duyabilirler. Bahse konu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için parasal kaynağa ve kurallara ihtiyaç duyulmaktadırlar. Bütçe Kanunu ile öngörülen bu kaynak, idarelerin harcama yapması suretiyle somutlaşmaktadır.

Bütçe Kanunu yıllık olması nedeniyle taşıdığı hükümler de o yıl için geçerlilik taşımaktadır. Oysa kamu mali yönetimi alanında temel yasal düzenleme 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'dur. Ödenek sürecinde, Bütçe Kanunu ile birlikte 5018 sayılı Kanun hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Bahse konu 5018 sayılı Kanun kapsamına, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolü girmektedir.

Ödeneklerin aşılmaması hususu ise 5018 sayılı Kanun ile hükme bağlanmış olup, aynı Kanun'a göre ödeneklerin aşılması yaptırıma konu olabilmektedir. Bu nedenle olası yaptırıma muhatap olmamak ve aynı zamanda, bütçe kaynaklarının zamana ve ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmesi için takip ve kontrolü gerekmektedir. Zira mevcut düzenlemeler istisnai durumlar hariç olmak üzere, ödenek üstü harcamaya izin vermemektedir.

Nitekim 5018 sayılı Kanun'un "Ödeneklerin kullanılması" başlıklı 20'nci maddesi; *"Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:*

(a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

(b) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar

(c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usûl ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

d) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir…"

Hükmüne amirdir.

Bütçe kullanımı ile ilgili temel esaslar 5018 sayılı Kanun'da düzenlenmekle birlikte, 4734 sayılı Kanun'da da bu hususta sınırlıda olsa düzenlemeler bulunduğunu görmekteyiz. Nitekim 4734 sayılı Kanun hükmü çerçevesinde, alım için yeterli ödeneğin ilgili idare bütçesinde yer almaması durumunda alımın gerçekleşmemesi gerekmektedir. Bu durum anılan Kanun'un 5'inci maddesinde ifade edilmiştir.

4734 sayılı Kanun'un temel ilkelerine ait düzenlemelerin yapıldığı maddesinde yer alan "ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz" hükmü kamu idarelerinin, bütçe kanunu ile belirlenmiş limit ve düzenlemeler çerçevesinde harcama yapabilmesine olanak sağlamaktadır.

Söz konusu ödeneklerin aşılmaması ise, yine 5018 sayılı Kanun hükmü ile ortaya konulmuştur. Ödeneklerin aşılması yaptırıma konu olabilmektedir. Gerek 5018 sayılı ve gerekse 4734 sayılı Kanun hükmü çerçevesinde, alım için yeterli ödeneğin ilgili idare bütçesinde yer almaması

durumunda alımın gerçekleşmemesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, KBS üzerinden harcama talimatı düzenlenirken sistem ödeneğinin bulunup bulunmadığını otomatik olarak kontrol etmekte, söz konusu alıma ilişkin yeterli ödeneğin bulunmaması durumunda sistem sonraki aşamaya geçilmesine izin vermemektedir. Böylelikle söz konusu Kanun hükmünün pratik karşılığı uygulamaya yansıtılmış olmaktadır.

Nitekim 5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu İhale Mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır.

Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı Kanun'a göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgelerdir.

4734 sayılı Yasa'nın "Temel ilkelere" ait 5'inci maddesindeki "Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz" hükmünün tüm alım türleri için geçerli olduğu düşünülmektedir. Çünkü söz konusu maddede alım türleri açısından bir ayrım yapılmadığı gibi doğrudan temin yönteminde de kamu kaynağı kullanıldığı hususu dikkate alındığında, bu ilkenin doğrudan temin kapsamı alımlar için de geçerlilik arz ettiği düşünülmektedir.

5018 sayılı Yasa'nın "Ödenek üstü harcama" başlıklı 70'nci maddesinin; *"Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir."* hükmü ise ödenek üstü harcama yapmayı bir anlamda caydırmaktadır.

Bu ise, Bütçe Kanunu'yla kendilerine ödenek tahsis edilen kamu idarelerinin, doğrudan temin yoluyla da olsa ihtiyaç duydukları alım türleri için de harcama yapmasını ancak mevzuatta

öngörülen belirli yükümlülükleri yerine getirmeleri ile mümkün olabileceğini göstermektedir.

5018 sayılı Yasa'nın "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinin " Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır." şeklindeki hükmü de süreçte görev alanların mevzuat dışında hareket etmesini engellemektedir.

Bütçe Kanunu eki cetvellerden E cetveli, Bütçe Kanunu hükümleri açısından uygulamaya yön veren düzenlemelerden biridir. Söz konusu Cetvel, ödeneklerin kullanıma ilişkin esasları ortaya koymaktadır. Kuşkusuz Kanun'un ayrılmaz parçası diyeceğimiz bu kuralların dikkate alınması gerekmektedir.

Sadece onay aşamasında değil ödeme aşamasında da ilgili birimce ödeneklerin yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir. Keza başlangıçtaki ödenek, ödenek aktarımı veya başka bir nedene bağlı olarak azalmış olabilir.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun E cetvelinde yer verildiği üzere;

"Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere;
a) Menkul mal alımlarında 28.000 Türk Lirasını,
b) Gayrimaddi hak alımlarında 23.000 Türk Lirasını,
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 28.000 Türk Lirasını,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 62.000 Türk Lirasını, aşan tutarlar "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerinden ödenemez.
"(06) Sermaye Giderleri"ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerine analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak tahsis edilen ödeneklerle yapılacak askeri amaçlı alımlarda yukarıda belirtilen limitler uygulanmaz."

Hususları yer almaktadır.

Aynı hususa, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Bütçe Genel Tebliğlerinde de yer verilmiştir.

5018 sayılı Yasa'nın "Bütçe ilkeleri" başlıklı 13'üncü maddesinde ise;

"...n) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.
o) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir."

Hükmü yer almaktadır.

Ödeneklerin kullanımına ilişkin olarak Bütçe Uygulama Tebliği'nde de aynı husus;

"j) 7258 sayılı Kanuna ekli (E) işaretli cetvelin 31 sıra numaralı hükmü gereğince, Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehberin giderin ekonomik sınıflandırması bölümünde parasal tutarına bakılmaksızın "03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerinden karşılanacağı belirtilen giderler hariç olmak üzere, ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dâhil her bir alım için;
- Menkul mal alımlarında 28.000 Türk Lirasını,
- Gayrimaddi hak alımlarında 23.000 Türk Lirasını,
- Menkul malların bakım ve onarımlarında 28.000 Türk Lirasını,
- Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 62.000 Türk Lirasını,
aşan tutarlar, "03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerinden ödenemez.

Bu itibarla yukarıda yer verilen parasal tutarları aşan ihtiyaçlar, Devlet Malzeme Ofisinden temin edilse dahi "06- Sermaye Giderleri" tertiplerinden ödenecektir. Ayrıca doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlarda ilgili bütçe tertibinin belirlenmesinde de söz konusu parasal tutarlar esas alınacaktır. Bu hususlara bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde de riayet edilecektir."

Şeklinde ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere; gerek Bütçe Kanunu ve gerekse buna ilişkin diğer dokümanlarda alım şekline bağlı olarak ödenek kullanım esasları belirlenmiştir. Buna aykırılık ise ödenek üstü kullanımını

gündeme getirebilecektir. Ödenek üstü kullanım ise, 5018 sayılı Yasa ile yasaklanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri birçok Sayıştay Raporuna konu olabilmektedir. Söz konusu raporlarda özetle; Bütçe Kanunu'nun E Cetvelinde bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar düzenlendiğinden bahisle, ilgili idare tarafından bu ödeneklerin harcanmasında E Cetvelinde yer alan ve yukarıda yer verilen limitlere uyulmadığı tespiti ışığında, söz konusu tutarları aşan harcamaların "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerinden ödenmemesi gerektiği vurgulanarak, bu şekilde yapılan alımların (ödemelerin) bulgu konusu yapıldığı görülmüştür.

Bütçe Kanunu ve alt düzey mevzuat dikkate alınarak, idarelerin ödeneklerini göz önünde bulundurarak alım sürecini başlatmasının yanında, alımın niteliği dikkate alınarak farklı birimlerin ödeneklerinin alıma yapacak birime aktarılması suretiyle de alım söz konusu olabilir. Bu bağlamda, bütçe tertibi açısından ödemelerde farklı tertipler belirlenmiş ise, belirlenen tertiplerden ve belirlenen ekonomik koddan ödemenin yapılması gerekmektedir.

5018 sayılı Yasa'nın "Ödenek aktarmaları" başlıklı 21'nci maddesi de *"Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır. ...Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Ancak, ihtiyaç halinde yüzde yirmiyi aşan ödenek aktarma işlemlerini kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere yapmaya Cumhurbaşkanlığı, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya ise ilgili idareler yetkilidir. Kamu idarelerinin bütçeleri içinde; personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere ödenek aktarılamaz. Ancak, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde, aktarma yapılan tertiplerden diğer tertiplere ödenek aktarılabilir."* hükmüne amirdir.

5018 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanılan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Ait Usul ve Esaslar"da ise, ödenek gönderme sürecine ait hususlarda da açıklamalar yer almaktadır. Buna göre;

Bütçe ödeneklerinin dağıtımı ödenek gönderme belgesiyle yapılacağı, ödenek gönderme belgelerinin harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderileceği, yılı merkezi yönetim bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama veya finansman programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgelerinin, en geç üç işgünü içinde sonuçlandırılacağı, uygun görülmeyen ödenek gönderme belgelerinin gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderileceği hususları yer almaktadır. Yapılan düzenlemeler uyarınca, ödenek aktarmalarının idarenin mali hizmetler biriminin iç kontrol alt birimi dışında diğer alt birimleri tarafından elektronik ortamda hazırlanıp onaylanması halinde de ön mali kontrol yapılmış ve uygun görüş verilmiş sayılmaktadır.

Görüldüğü üzere; harcama yaparken sadece Bütçe Kanunu'nun madde metni değil, aynı zamanda eki cetvellerde yer alan hususların da dikkate alınması gerekir. Bu bağlamda, E cetveli ile "Bazı Ödeneklerin Kullanımına Ve Harcamalara İlişkin Esaslar" belirlenmiştir. Belirlenen bu esaslara aykırılık aslında Bütçe Kanunu'na bir anlamda aykırılık taşımaktadır. Çünkü Bütçe Kanunu ve bağlantılı cetveller, idarelere belirlenen esaslar çerçevesinde hareket edilmesi noktasında hukuki zemin ve zorunluluk oluşturmaktadır. Çünkü TBMM tarafından kabul edilen bir Kanun olduğu için bağlayıcılık taşımaktadır.

Dolayısıyla, bir kamu idaresinin harcamayı gerçekleştirirken, başta 4734 sayılı Kanun olmak üzere, 5018 sayılı Kanun, Bütçe Kanunu ve eki cetveller ile bağlantılı mevzuatta yer alan düzenlemeleri de bir bütün olarak dikkate alması ve bunlara göre alımı sürecini şekillendirmesi gerektiğini ifade edebiliriz.

59. Doğrudan temin kapsamında (22/d) yapılan temsil ve ağırlama giderleri parasal sınırlamaya tabi midir?

Özet: *4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde bahsi geçen "Temsil ve Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Konaklama, Seyahat ve İaşeye İlişkin Alımlar" parasal sınırlamaya tabi olmayıp, idarelerin bu kapsama giren ihtiyaçlarını doğrudan temin yöntemiyle karşılaması mümkündür. Konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar dışındaki temsil ağırlamaya ilişkin alımların ise, 22'nci maddenin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde veya ihale usulleri kapsamında karşılanması gerekmektedir. Ayrıca, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile açıklanan ödeme sürecine ait belgelerin ise ödeme belgesine eklenmesi gerektiğini ifade edebiliriz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Söz konusu Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır.

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idarelerin ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur. Söz konusu ihtiyaçlar, doğaları gereği ihale yapılmak suretiyle temini mümkün ve pratik olmayan, bir anlamda idarenin günlük sayılabilecek ihtiyaçlarıdır.

4734 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. bendinin *"Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir."* şeklindeki düzenlemesi ile sözleşme yapma konusunda idareler (istisnai durumlar hariç) serbest bırakılmıştır.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'da yer alan hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek;

sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılması zorunluluğu olmamakla birlikte, bu kapsamda düzenlenecek sözleşmeler emredici hukuk kurallarına, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmamak şartı ile idare tarafından istenildiği şekilde yapılabilir.

Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde gerek ihale kapsamı alımlar ve gerekse doğrudan temin kapsamı alımlarda, söz konusu mevzuat hükümleri ilk aşamada göz önünde bulundurulsa da alım sürecine ilişkin işlemler sadece Kamu İhale Mevzuatı ile sınırlı değildir.

Alımın niteliğine bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları da kendi görev ve yetkileri çerçevesinde yapmış olduğu düzenlemeler veya verilen izinler/onaylar ile alım sürecine ait işlemleri etkileyebilmektedir.

4734 sayılı Yasa'nın "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesi; "Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

…

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin … aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar…" hükmüne amirdir.

Görüldüğü gibi, 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen parasal sınır, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için geçerlidir. Diğer bir ifadeyle, temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar parasal sınırlamaya tabi değildir.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin; "temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar .." şeklindeki düzenleme uyarınca sadece bahse konu alımların doğrudan temin ile gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu ifade edebiliriz. Bu yönde bir belirleme yapılmıştır.

Zira temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı bir kısmının ihale edilmesi mümkün olmayan alımlardır. Örneğin; bir konaklama veya seyahate ilişkin ihale yapılması pek uygulanabilir değildir.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise burada temsil ağırlama kapsamındaki tüm alımlar değil, madde metninde de yer aldığı üzere, sadece konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar kapsama alınmıştır.

Konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar dışındaki temsil ağırlamaya ilişkin alımların ise, 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddenin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde veya ihale usulleri kapsamında karşılanması gerektiğini ifade edebiliriz.

Benzer şekilde, temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarda 22'nci maddenin (d) bendinde belirtilen parasal limit sınırlaması yoktur.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Teyit işlemleri" başlıklı 30'uncu maddesinde, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlar için teyit zorunluluğu getirildiğinden, temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak olan konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarda teyide gerek bulunmamaktadır.

Temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak olan konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar Kanun'un 62'nci maddesindeki %10'luk limite de dahil değildir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak olan konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar ile ilgili olarak çerçevesi yukarıda yer verilen genel düzenlemeler dışında ayrıca ayrıntılı bir düzenlemenin yapılmadığını görmekteyiz. Ancak harcama mevzuatı açısından ödeme boyutuyla bu hususta düzenlemeler bulunduğunu ifade edebiliriz.

Nitekim Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin Beşinci Bölümünde; *"Temsil ve Tanıtma Giderleri Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri" başlıklı 47'nci maddesi; "Temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, bu Yönetmeliğin*

ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde;

- Harcama talimatı,
- Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon,
- Mihmandar Hesap Cetveli (Örnek: 35), ödeme belgesine bağlanır.
Ziyafete ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde alınacak harcama talimatında, davetli ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapacağı harcamaların neleri kapsayacağı belirtilir."

şeklinde düzenlemelerin bulunduğu görülmektedir. Kuşkusuz ödeme sürecinde söz konusu belgelerin varlığının dikkate alınması gereklilik arz etmektedir.

Söz konusu giderlerin kapsamını, Bütçe Hazırlama Rehberi bünyesinde bulunan Analitik Bütçe Sınıflandırmasının "Temsil ve Tanıtma Giderleri"ne yönelik açıklamaları da göz önünde bulundurarak belirleyebiliriz. Şöyle ki;

03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
03.06.10 Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri

03.06.10.01 Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri:
• Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler ile cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedelleri, Bakanlar Kurulu Kararı ya da Cumhurbaşkanı Kararı gereğince vergi muafiyeti tanınan vakıflardan kiralanan madeni çelenklerin kira bedelleri,
• Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konuklama ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderler,
• Dışişlerinde, icabında yetkililerin eşleri tarafından, gelecek resmi yabancı konuklara verilecek ziyafet giderleri,
• Protokol Genel Müdürlüğünce yabancı konuklar için hazırlanan programlar gereğince yapılan törenin gerektirdiği giderler ve bunlarda görev alanlara verilecek kumanyalar, konukların yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle, korunmaları için görevlendirilenlere

yapılacak giderler,

• Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler,

• Konukların ikametlerine ayrılacak köşk ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve bunların kira bedelleri,

• Yurdumuza çağrılmalarında yarar görülen yabancılar ile yabancı basın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki ağırlama, konuklama ve gezi giderleri ile zaruri görüldüğü takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri,

• Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri,

• Temsil amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler,

• Yurt dışında turizm ve ihracat imkânlarının artırılması amacıyla halkla ilişkiler ve pazarlama firmalarına, uzmanlarına ve bu işlerle uğraşan kuruluşlara verecekleri hizmetler karşılığı yapılacak ödemelerle, bu konularda yaptırılacak araştırma giderleri,

• Yurtdışından ülkemize davet edilen sanatçı ve toplulukların yol parası, konuklama, kaşe vb. giderler,

• Yukarıda sayılanların dışında kalan temsil, tanıtma ve ağırlama giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

03.06.20 Toplantı ve Organizasyon Giderleri

03.06.20.01 Toplantı ve Organizasyon Giderleri:

• Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı vb. anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler açılış ve sancak devir teslim törenleri ile üniversitelerin açılış törenlerinin gerektirdiği giderler,

• Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile ilgili alım ve giderleri ile bütçe hazırlama sürecinde yapılacak tanıtma ve ikram giderleri; plan, program ve bütçelerin ulusal çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, konferans, broşür, radyo, televizyon, film, fotoğraf vb. araç ve malzeme giderleri,

• Ekonomik ağırlıklı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ticaret heyeti, alım heyeti ve ihraç ürünlerinin tanıtım hizmetleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılacak organizasyonlara

ilişkin giderler (yolluklar hariç),

• Ülkemizin yatırım imkânlarının yabancılara tanıtılması ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonlar ve bunlara ilişkin baskı, yayın, broşür vb. araç, gereç ve malzeme giderleri, ağırlama, konaklama ve bu işlemle ilgili hazırlıkların gerektirdiği her türlü giderler (yolluklar hariç),

• Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtma amaçlı olmak üzere kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtmaya yönelik reklam giderleri,

• Tanıtma amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler,

• Yukarıda sayılanların dışında kalan toplantı ve organizasyon giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar ışığında bu kapsama giren, harcamalar görülmektedir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde de giderin ödenme sürecinde belgelendirilmesine ait düzenlemelere yer verildiğini görmekteyiz.

Konuyla bağlantılı bir Sayıştay Kararında; Temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin aranacağı, yine aynı yönetmeliğin ilgili maddelerine göre; ihale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı ve kamu idareleri için belirlenen diğer belgeler ödeme emri belgesine ekleneceği, harcama talimatı ve Onay belgesinde, alım konusu işin niteliği, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti kullanabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulünün belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Konuyla bağlantılı farklı bir Sayıştay Kararında da; Satın alınan bahse konu hizmetlerin piyasa fiyat araştırması yapılmadan, tek firmadan teklif alınmak suretiyle temsil, ağırlama ve tören giderleri ekonomik kodundan gerçekleştirildiği, bunun yanında; harcama talimatı ve onay belgesinde, alım konusu işin niteliği, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usul belirtilmesi gerektiği halde, ilişikli belgelerde bu

bilgilerin yer almadığı, temsil, ağırlama ve tören giderleri ekonomik kodundan yapılacak harcamalar mutlaka 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale usullerinde birisi ile ya da doğrudan temin yöntemiyle yapılması gerektiği, bunun için gerekli olan kanuni prosedüre uymanın zorunlu olduğu, bu nedenle tek firma tespit edip bu firmadan ihtiyacın temin edilmesi mümkün olmadığı, piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığının mutlaka ispat edilmesi gerektiği, 4734 sayılı Kanun'un temel ilkeleri olan açıklık, rekabet, saydamlık, güvenilirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gerçekleşmesi için bir zorunluluk olduğu, doğrudan temin ile yapılan bu alımlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin birçoğunun ödeme emri belgelerine eklenmediği ifade edilerek, yapılan alımların belge eksikliği ve ... aykırı olması itibari ile de mevzuata aykırılığı açık olduğu, gerekçeleriyle verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE oyçokluğuyla karar verildiği görülmüştür.

Netice itibarıyla;

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin; "…temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar ..." şeklinde düzenlenen hükmü uyarınca, bahse konu alımların sadece doğrudan temin ile karşılanmasının mümkün olduğunu, temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımların işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı bir kısmının ihale edilmesinin mümkün olmadığını,

Dolayısıyla konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar dışındaki temsil ağırlamaya ilişkin alımların ise, 22'nci maddenin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde veya ihale usulleri kapsamında karşılanması gerektiğini,

İfade edebiliriz.

60. Doğrudan temin kapsamı alımlarda yerli malı/yerli istekliye sağlanan avantajlar nelerdir?

Özet: *4734 sayılı Kanun ve bağlantılı mevzuata ilişkin düzenlemeler uyarınca, ihale kapsamı alımlarda, yaklaşık maliyetin, eşik değer karşısındaki durumunun; mal veya hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde; yerli istekli, yerli malı teklif eden istekli veya yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine olmak üzere, çeşitli avantajların sağlanıp sağlanmaması konusunda temel belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Eşik değerler ise her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenmektedir. Yerli isteklilere yönelik sağlanan avantajların mal, hizmet ve yapım işleri için geçerli olduğunu, ancak mal alımı ihalelerinin konumunun farklı olduğunu, keza mal alım ihalelerinde bu haktan yararlanabilmek için istekli tarafından sunulan malın yerli malı olması ve bu durumun belgelendirmesi gerektiğini belirtebiliriz. 4734 sayılı Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının ilk üç bendinde, ihtiyaçların sadece tek gerçek veya tüzel kişilerden karşılanabildiği durumlarda, yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınması imkânı bulunmamaktadır. Ancak anılan maddenin (d) ve müteakip bentlerinde yapılacak alımlarda ise fiyat avantajı uygulama imkânı idarelerin takdirindedir. Zira piyasa fiyat araştırması aşamasında görevli kişiler tarafından yerli istekliler ve yerli mallara öncelik verilerek ihtiyaçların karşılanabilmesi imkânı bulunmaktadır. Ya da idarece alım konusu için hazırlanacak dokümanlarda (şartname ve sözleşme tasarısında), bu hususa yer verilmesi ve belirlenen esaslara göre alım yapılması mümkündür.*

2003 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda uluslararası ihale uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin olmak üzere dört ihale usulü belirlenmiş, ancak sonrasında 4734 sayılı Kanun'da değişiklik yapan ile "doğrudan temin" ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu çerçevede, doğrudan temin yöntemi sadece Kanun'da belirtilen hallerde kullanılabilecek olup, bu usule ilişkin esaslar anılan Kanun'un 22'nci maddesinde düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4'üncü maddesinde, doğrudan temin "*Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul*" şeklinde tanımlanmış olup, yine aynı

Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinde, belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceği, bu usule göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilebileceği düzenlenmiştir.

Doğrudan temin yönteminin gerek ihale usulü olmayıp bir satın alma yöntemi olması nedeniyle, bazı hususlarda 4734 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmadığı dikkate alındığında, bu alım yöntemi için yerli istekliye fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Yerli malı kullanımında veya yerli isteklinin varlığı halinde, mevcut ihale düzenlemeleri uyarınca, bu hususlarda ihale mevzuatında lehe düzenlemelerin yapıldığını görmekteyiz. Söz konusu düzenlemelerin başta 4734 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesi olmak üzere, İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer aldığını görmekteyiz.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesi uyarınca, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. 4734 sayılı Kanun'un "Eşik değerler"e ilişkin 8'inci maddesi çerçevesinde, (2022/1) sayılı Kamu İhale Tebliği ile belirlenen güncel eşik değerleri tablo yardımıyla gösterecek olursak, bu rakamların;

4734 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca 2022 yılı Eşik Değerlere ait Tablo

Kanun Kapsamına Giren İdare Türleri	Alımın Türü	31.01.2022 tarihine kadar uygulanan eşik değerler (TL)	01.02.2022-31.01.2023 döneminde uygulanacak eşik değerler (TL)
Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler	Mal ve Hizmet alımlarında	2.225.824	4.004.034
Kanun kapsamındaki diğer idarelerin (genel ve katma bütçe dışındaki idarelerin)	Mal ve Hizmet alımlarında	3.709.717	6.673.409

Kanun kapsamındaki bütün idarelerin	Yapım İşlerinde	81.614.303	146.815.969

Şeklinde olduğunu görürüz.

Dolayısıyla, yukarıda yer verilen eşik değerlere ilişkin parasal sınırlar dikkate alınarak, 4734 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesi uyarınca, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak malzemelere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, KİK tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.

Mal alımları açısından, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal alımı ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme (idari şartnamede) yapılabilir. Ayrıca sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Zaten diğer isteklilerin alım sürecine katılmasına izin verilmediği için bunların girmesi söz konusu değildir.

Ancak, ihale dokümanında tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmış ve bu ihalede yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar (bu oran üst sınır) fiyat avantajı sağlanacağı belirtilmiş ise burada hangi istekli yerli malı sunmuş ise ona fiyat avantajı uygulanmakta olup, yerli istekli yabancı istekli ayrımı yapılmamaktadır.

Ayrıca, mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Böyle bir durumda ise, ihale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir.

Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerin, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesi ve fiyat avantajı tanınan her bir kısmın tek bir mal kaleminden oluşması zorunludur. Ancak, birbirini tamamlayan veya teknik zorunluluklar nedeniyle birlikte alınması gereken mal kalemlerine bir kısımda yer verilebilir.

Kısmi teklife açık ihalelerde, kısımların birinde, birkaçında veya tamamında yerli malı teklif eden istekliler lehine aynı veya farklı oranlarda fiyat avantajı sağlanabilir. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunur.

Diğer taraftan, her yıl Ocak ayında Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Söz konusu zorunlu fiyat avantajı uygulaması, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde uygulanması gerekmektedir. Aynı şekilde, yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunludur.

Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin yerli istekliye ilişkin düzenlemeleri gereğince, gerçek kişinin yerli istekli olduğu başvuru veya teklif mektubunda yer alan T.C. kimlik numarasından anlaşılacağından, tüzel kişilerin ise başvuru veya teklif kapsamında sundukları belgeler üzerinden değerlendirileceğinden, idarelerce, başvuru veya teklif kapsamında yerli istekli olunduğuna ilişkin başka bir belge istenilmemesi gerekmektedir.

Tüzel kişilerin yerli istekli olmaları için, Türk Kanunlarına göre kurulmuş olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, sadece yerli isteklilerin katılmasının öngörüldüğü veya yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacak ihalelerde idari şartnamelerde yer alan "yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler" hükmü uyarınca, tüzel kişiliğin yerli istekli olup olmadığına ilişkin tereddüt bulunması halinde bu hususun belgelendirilmesi amacıyla, bu durumun bilgi eksikliğinin tamamlattırılması kapsamında istenilmesi

gerekmektedir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilik niteliğine haiz aday ve istekliler, 4734 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince yerli istekli kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu hükümler ve düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık maliyetin, eşik değer karşısındaki durumunun; mal veya hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde; yerli istekli, yerli malı teklif eden istekli veya yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine olmak üzere, çeşitli avantajların sağlanıp sağlanmaması konusunda karar verilmesi ve ihale dokümanlarında buna yönelik düzenleme yapılması noktasında belirleyici olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, yerli isteklilere yönelik sağlanan avantajların mal, hizmet ve yapım işleri için geçerli olduğunu, ancak mal alımı ihalelerinin konumunun farklı olduğunu, keza mal alım ihalelerinde bu haktan yararlanabilmek için istekli tarafından sunulan malın yerli malı olması ve bu durumun belgelendirmesi gerektiğini ifade edebiliriz.

Tekrar ifade edersek, 4734 sayılı Kanun'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında KİK tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konu doğrudan temin kapsamında ilişkilendirildiğinde, 4734 sayılı Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının ilk üç bendinde, ihtiyaçların sadece tek gerçek veya tüzel kişilerden karşılanabildiği durumlarda, yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınması imkânı bulunmamaktadır. Ancak anılan maddenin (d) ve müteakip bentlerinde yapılacak alımlarda ise fiyat avantajı uygulama seçeneği idarelerin takdirindedir. Zira piyasa fiyat araştırması aşamasında görevli kişiler tarafından yerli istekliler ve yerli mallara öncelik verilerek ihtiyaçların karşılanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, yerli istekliler ve yerli malı teklif eden isteklilere öncelik verilerek ihtiyaçların karşılanması hususunda, hukuki engel bulunmadığı durumlarda konunun idarelerin takdirinde

olduğuna Kamu İhale Kurulunun konuyla bağlantılı kararı uyarınca ifade edebiliriz.

Bu oran her ihalede uygulanması zorunlu tek oran olmayıp, idareler ihalelerinin özelliklerine göre, Kanun'la belirlenen üst limit olan %15 oranının aşılmaması kaydıyla, farklı oranlar belirleyebilme özgürlüğüne sahiptir.

Doğrudan temin kapsamı alımlarda, yerli istekliler lehine tanınacak fiyat avantajına ilişkin düzenlemelere, alım dokümanında yer verilmesi zorunludur. Şayet şartname ve sözleşme düzenlenmesi öngörülüyorsa, bu hususa idari şartnamede yer verilmesi uygun olacaktır. Şartname veya sözleşme düzenlenmesi öngörülmüyorsa, bu durumda, piyasa fiyat araştırması sürecinde, isteklilere yönelik yazılarda bu hususlara yer verilmesi uygun olacaktır.

Görüldüğü üzere; 4734 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesi başta olmak üzere, ihale uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer verilen düzenlemelerde, yerli istekli ve yerli malı kullanımına ilişkin esasların belirlendiğini, ancak bunlardan açık bir husus bulunmaması üzerine, KİK tarafından doğrudan temin kapsamı alımlarda alımın niteliğine bağlı olarak yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanabileceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının ilk üç bendinde, ihtiyaçların sadece tek gerçek veya tüzel kişilerden karşılanabildiği durumlarda, yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasının alımın niteliğinden dolayı mümkün olmadığını, ancak anılan maddenin (d) ve müteakip bentlerinde yapılacak alımlarda ise fiyat avantajı uygulama imkânının idarelerin takdirinde olduğunu ifade edebiliriz.

61. Doğrudan temin kapsamı alımlarda ön mali kontrol yapılır mı?

Özet: *Mali hizmetler biriminin, ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'da düzenlenmiştir. İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için beş milyon Türk Lirasını, yapım işleri için on beş milyon Türk Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbidir. Yani, doğrudan temin kapsamında alım olsa dahi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'a ait limit üzerinde olanların ön mali kontrole tabi tutulması zorunlu olmakla birlikte, bunun altındaki rakamlar ise idarenin düzenlemelerine göre şekillenecektir. Yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde, yapılan alımın ön mali kontrole tabi tutulması gerekiyor ise, ödeme belgesinin harcama yetkilisi tarafından imzalanmasından sonra ön mali kontrolünün yapılması için strateji geliştirme başkanlığına (mali hizmetler birimine) gönderilir. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi danışma ve önleyici niteliği haiz olup, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir. Mali karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde, nedenleri açıkça belirtilen bir yazı yazılarak, ödeme emri belgesi ve ekleri ilgili harcama birimine gönderilir. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde, uygun görülmediğine ilişkin görüş yazısının ödeme belgesine bağlanması gerekir.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu Yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanmasındaki süreç ise bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir. Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Anılan Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen söz konusu ihtiyaçlar, doğaları gereği ihale açılarak temini mümkün olmayan, esas itibariyle ancak Yasa'nın 22'nci maddesinde sayılan

koşulların varlığı halinde istisnai olarak başvurulması gereken bir yöntemdir.

İhale mevzuatında 4734 sayılı Kanun ile getirilen yeni alım sistemine benzer şekilde, kamu mali yönetimi alanında da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yasalaşması ile birlikte, anılan Kanun ile ödenek tahsis edilen her birim harcama birimi olarak kabul edilmiş olup, harcama öncesi kontrol görevinin yönetsel sorumluluk çerçevesinde ilgili birimler tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

5018 sayılı Kanun'un 58'inci maddesine göre ön mali kontrol; harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsamaktadır. Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülmektedir. Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgari kontrollerin, mali hizmetler birimi tarafından ön mali kontrole tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Kurumlarda ön mali kontrol görevi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55, 56,57 ve 58'inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 31.11.2005 tarih ve 26040 sayılı (3.mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yerine getirilmektedir (10.md.). Söz konusu Usul ve Esasların 16 ila 26'ncı maddeleri arasında ise Mali Hizmetler Birimince (SGB) ön mali kontrole tabi tutulması öngörülen işlemlere yer verilmiştir. 18.02.2006 tarihli, 26084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te de benzer hususlara yer verilmiştir.

Öte yandan, 31.12.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'da ise, ön mali kontrol; "Kamu idarelerinin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrol" şeklinde tarif edilmiştir.

5018 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi hükmüne göre, kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama

talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu İhale Mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır.

Anılan Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca, bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilir. Ön malî kontrol, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Malî hizmetler birimi tarafından yapılacak ön malî kontrol, Usul ve Esaslarda belirtilen kontroller ile idarelerce yapılacak düzenlemeler çerçevesinde yapılması öngörülen kontrollerden meydana gelir.

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.

Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Malî hizmetler birimince kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olmak zorundadır. Malî hizmetler biriminin görüş yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir.

Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülerek imzalanır.

Harcama birimlerinde ve malî hizmetler biriminde yapılan kontrol sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir. Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine gönderilir.

Malî hizmetler birimince, bahse konu Usul ve Esasların 17 ve 26'ncı maddeleri uyarınca yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda malî karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir. Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir.

Bu kapsamda, malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisi malî hizmetler birimi yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri malî hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır. Malî hizmetler birimi yöneticisi, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Malî hizmetler birimi yöneticisinin harcama yetkilisi olması durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür.

Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç

kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir. Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir.

Öte yandan, Malî Hizmetler Biriminin Ön Malî Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve İşlemler söz konusu Usul ve Esaslarda; Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, Ödenek gönderme belgeleri, Ödenek aktarma belgeleri, Kanun tasarılarının malî yükünün hesaplanması, Kadro dağılım cetvelleri, Seyahat kartı listeleri, Seyyar görev tazminatı cetvelleri, Geçici işçi pozisyonları, Yan ödeme cetvelleri, Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri ve Yurtdışı kira katkısı olarak belirlenmiştir.

Doğrudan temin kapsamı alımlar açısından bunlardan, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrol kapsamında incelenmesi önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için beş milyon Türk Lirasını, yapım işleri için on beş milyon Türk Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dâhil değildir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yapım işleri ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 28/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında illerin yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecek olan yapım işlerinde bu tutar iki kat olarak uygulanır. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu tutarları üç katına kadar artırmaya yetkilidir. İdareler belirlenen tutarlar içinde kalmak ve üst yöneticiden onay almak kaydıyla merkez ve taşra teşkilatı ile birimler bazında risk analizleri çerçevesinde farklı tutarlar belirlemeye yetkilidirler.

Görüldüğü üzere; ön mali kontrole ilişkin parasal sınır içinde kalmak koşuluyla alım yönteminin önemli olmadığı görülmektedir. Yani ister ihale kapsamında ister doğrudan temin yöntemine göre alım gerçekleşsin, belirlenen limiti aşıyorsa söz konusu alım işlemleri ön mali kontrole tabidir. Dolayısıyla bu yönde bir belirleme yapılmadığı sürece söz konusu parasal tutarların altındaki taahhüt evrakları ve sözleşme tasarılarının, ön mali kontrole tabi tutulması mümkün olmayacaktır.

Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri

içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malî hizmetler birimine gönderilir. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.

Diğer taraftan, Usul ve Esaslarda belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Bu düzenlemelerde, malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve yılda bir kez değerlendirilir. İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, üst yöneticinin onayını izleyen on işgünü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "Vize veya uygun görüş alınması gereken hallerde aranacak belgeler" başlıklı 65'inci maddesi; *"Kamu idarelerinin yapacakları harcamalarında, ilgili mevzuatında vize veya uygun görüş alınmasının belirtildiği hallerde, duruma göre vize yazısı veya cetveller ile uygun görüş yazıları ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen alımların ödenmesinde, uygun görülmediğine ilişkin görüş yazısının da ödeme belgesine bağlanması gerekir."* şeklinde düzenlenmiş olup söz konusu hükmün de ödeme sürecinde dikkate alınması gerekir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'da, ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri de ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapacaklardır. Bu nedenle ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisinin yaptığı işlemler nedeniyle sorumluluğu söz konusudur. Ayrıca, harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılarak her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanıp uygulanacak, mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol edeceklerdir. Bu bağlamda ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri de, ödeme emri belgesi ve eki belgeler

üzerinde ön mali kontrol yaparak, ödeme emri belgesi üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşüp imzalamaları gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilmesidir. Ancak her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemeyeceğini, harcama yetkisinin devredilmesinin, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağının bilinmesi gerekir.

Kamu idarelerinin yapacakları harcamalarında, ilgili mevzuatında vize veya uygun görüş alınmasının belirtildiği hallerde, duruma göre vize yazısı veya cetveller ile uygun görüş yazıları ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen alımların ödenmesinde, uygun görülmediğine ilişkin görüş yazısının da ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Mali hizmetler birimi tarafından mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulmasının ve ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmesinin, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı, ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesinin danışma ve önleyici nitelikte olduğu, mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasına da engel teşkil etmediğini ifade edebiliriz.

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanmasında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

İdarelerde etkin bir ön mali kontrolün sağlanması mevzuatın gerektirdiği bir zorunluluğun yanında, harcama sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi açısından da gereklilik arz etmektedir. Zira bu sürecin etkin bir şekilde işletilmemesi, idare işlemlerindeki hatalı ve eksik uygulamalara, dolayısıyla, kamu kaynaklarının verimsiz kullanmasına neden olabilecektir.

62. Danışmanlık hizmetleri doğrudan temin yöntemiyle alınabilir mi?

Özet: *4734 sayılı Kamu İhale Kanun'u ile mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetlerin, danışmanlık hizmet sunucularından belli istekliler arasında ihale usulü ile karşılanması öngörülmüştür. Ancak yine Kanun'da öngörülen parasal sınırın altındaki alımlar, yani 31.01.2023 tarihine kadar 3.494.820.-TL (873.705 x 4= 3.494.820 TL)'nin altındaki alımların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi de mümkündür. Bunlarla birlikte, 4734 sayılı Kanun'un 21 veya 22'nci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiği durumlarda, danışmanlık hizmetlerinin, ilgisine göre; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık usulüyle ihale edilerek veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanun'u ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri uyarınca, doğrudan temin yöntemine başvurularak karşılanması mümkündür. Bu itibarla, doğrudan temine ilişkin koşulların oluşması durumunda, bu alım için ön görülen parasal sınır ve esaslara uyulmak şartıyla, bahse konu alım yönteminin kullanılmasının mümkün olduğunu ifade edebiliriz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Söz konusu Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır.

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Doğrudan temin kapsamı ihtiyaçlar, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar olup, doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir satın alma yöntemidir.

4734 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. maddesinde; *"Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların*

karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir." şeklindeki düzenleme uyarınca idareler (sözleşme düzenlenmesini gerektiren istisnai durumlar hariç olmak üzere) serbest bırakılmıştır.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'da belirtilen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

İhale kapsamı alımlar için 4734 sayılı Kanun ve alt düzey mevzuatta, idarelerce uygulanabilecek tip şartname, tip sözleşme, standart form gibi dokümanlar öngörülmüştür. Bu dokümanların doğrudan temin yönteminde kullanılması zorunlu değildir. Ancak idareler Kanun'un 22'nci maddesi çerçevesinde, diğer ihale usulleri için öngörülmüş bulunan bahse konu şartname ve sözleşme içeriklerinden yararlanarak kendi tercihleri doğrultusunda uygun dokümanlar hazırlayıp kullanması mümkündür. Hatta bahse konu dokümanları alım yöntemine uyarlayarak aynen de kullanmaları olanak dahilindedir.

Bunlarla birlikte, her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlarda, sözleşme düzenlenmesi istisnai durumlar hariç idarenin takdirinde olmakla birlikte, teminat alınması, cezai yaptırımlar öngörülmesi gibi uygulamaların tercih edildiği durumlarda yazılı sözleşme düzenlenmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir. Keza bahse konu hususların ispatı yazılı sözleşme düzenlenmesi ile netlik kazanabilecektir.

Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde gerek ihale kapsamı alımlar ve gerekse doğrudan temin kapsamı alımlarda, kuşkusuz ihale mevzuatı hükümleri ilk aşamada göz önünde bulundurulsa da alım sürecine ilişkin iş ve işlemler sadece ihale mevzuatı ile sınırlı değildir. Örneğin, 5018 sayılı Kanun hükümleri ile yıllara yaygın alımlara ait esaslar belirlenmiştir.

Kamu İhale Mevzuatına göre alımlar değişkenlik göstermektedir. Alımın niteliğine ve parasal tutarına bağlı olarak ihale kapsamı veya doğrudan temin yöntemine göre alım söz konusu olabilir.

İhale kapsamında gerçekleştirilen alımlar ise mal veya hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi yapım işi de söz konusu olabilir. Bu bağlamda, hizmet alımları alımın özellik arz etmesine bağlı olarak danışmanlık hizmet alımı şeklinde de gerçekleşebilir.

Danışmanlık hizmet alımları özellik arz eden bir alım olması nedeniyle gerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda, gerek ilgili ihale uygulama yönetmeliğinde ve gerekse Kamu İhale Genel Tebliği'nde bu alıma ilişkin özellikler ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Öncelikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na baktığımız zaman "Danışmanlık hizmetleri" başlıklı 48'inci maddesinde;

"Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.
Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir."

Hükmünün yer aldığı görmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı" başlıklı 6'ncı maddesinde de Kanun'un 48'inci maddesinde belirtilen hizmetler sıralanarak, bu alımların danışmanlık hizmet sunucularından alınabileceği öngörülmüştür.

Diğer ihalelerde olduğu gibi, danışmanlık hizmet alımlarında da idareler, Kanun'un temel ilkelerine uymak zorundadır. Yani yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Dolayısıyla, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece danışmanlık hizmet alımı ile mal alımı, yapım işleri ve danışmanlık dışındaki hizmet alımları bir arada ihale

edilemez. Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu anılan Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla danışmalık hizmet alımları kısımlara bölünemez.

Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri 4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılır. Ancak 4734 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yaklaşık maliyeti Kanun'un 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'ne göre hizmet alımı ihalesiyle göre gerçekleştirilebilecektir.

Kanun'un " Eşik değerler" başlıklı 8'inci maddesi;

" Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

*a) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası. (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası)**

b) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası. (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz Türk Lirası)

c) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası. (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası)

(Mülga son fıkra: 12/6/2002-4761/12 md.)"

Hükmüne amirdir.

4734 sayılı Yasa'nın 13'üncü maddesi ise;

"...b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar Türk Lirasına (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirasına)

* 20/01/2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01/02/2022 – 31/01/2023 dönemini kapsamaktadır.

kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar Türk Lirasına (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirasına)kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

2) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası) ile altmışmilyar Türk Lirası (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası) arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası) ile beşyüzmilyar Türk Lirası (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası) arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

3) Yaklaşık maliyeti altmışmilyar Türk Lirasının (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirasının) üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüzmilyar Türk Lirasının (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde… "*

Şeklinde hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun'da teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetlerin danışmanlık hizmeti olarak ihale edilmesi ve ihale usulünün belli istekliler arasında ihale usulü olması gerektiği öngörülmüştür. Yaklaşık maliyeti anılan Kanun'un 13'üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının 4 katının (873.705 x 4 = 3.494.820 TL) altında kalan danışmanlık hizmetlerinin, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun'un 21 veya 22'nci maddesinde belirtilen koşulların gerçekleştiği durumlarda, danışmanlık hizmetleri, ilgisine göre; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık usulüyle ihale edilerek veya koşulların oluşması durumunda doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilecektir.

Kanun'un 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmeti alımı

* 20/01/2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01/02/2022 – 31/01/2023 dönemini kapsamaktadır.

ihalelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilmesi halinde, iş deneyimini gösteren belgelerin düzenlenmesi, verilmesi ve değerlendirilmesinde Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan hükümlerin uygulanması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti alımlarında Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin ekinde yer alan standart formların kullanılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır. Danışmanlık hizmet alımları özelliği itibarıyla hizmet alımı olup, alımın niteliğinden dolayı Kanun'un ön gördüğü şekliyle ihale usulünün belli istekliler arasında ihale usulü olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Kanun'da öngörüldüğü üzere; belirlenen parasal sınırın altındaki alımlar, yani (873.705 x 4= 3.494.820 TL) 31.01.2023 tarihine kadar 3.494.820.-TL'nin altındaki alımların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

Bunlarla birlikte, 4734 sayılı Kanun'un 21 veya 22'nci maddelerinde belirtilen koşulların gerçekleştiği durumlarda, danışmanlık hizmetleri ilgisine göre; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık usulüyle veya Kanun ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerince öngörülen koşulların oluşması durumunda, doğrudan temin yöntemine uygun olarak bu yönteme ait esaslara göre ihtiyacın karşılanması ve alımın gerçekleşmesi mümkündür. Yani doğrudan temin yöntemiyle de bu kapsamda alım yapılmasına engel bir durum yoktur.

63. 4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesi kapsamı doğrudan temin yönteminde yakın akrabadan alım yapılabilir mi?

Özet: *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının d bendi kapsamında parasal sınırlamaya tabi alımlarda, yasaklılık teyidi yapılmasına ilişkin zorunluluğa uyulduktan sonra, teklif sunan her istekliden alım yapılmasının mümkün olacağını söyleyebiliriz. 4734 sayılı Yasa'nın 11'nci maddesinde yer verilen ihalelere katılamayacak olanlara ilişkin yasaklama ise, ihale kapsamı alımlar için geçerli olup, yine Yasa uyarınca ihale usulleri; Açık ihale usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü ve Pazarlık usulü olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin yöntemi için bu yasaklamaların geçerli olmadığını ifade edebiliriz. Ancak her ne kadar açıkça bir yasak söz konusu olmamakla birlikte, olası yanlış değerlendirmelerin önüne geçilmesi ve etik açıdan alım sürecinden görev alanların yakınlarından alım yapmaktan kaçınılmasının (zorunluluk olmadığı sürece) daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması sürecinde görev alan personelin, kabul edilebilir somut gerekçelere dayanmadan, rekabet ve eşit muamele ilkelerini gözetmeden yakın akrabalarında alım yapması ve bu alımlara ilişkin olarak da usulen piyasa fiyatı tutanağı düzenlemesi durumunda, doğrudan temin yöntemi de olsa bu eylemlere ilişkin olarak adli ve idari yaptırımların uygulanmasının söz konusu olabileceğini ifade edebiliriz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Söz konusu Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır.

Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir.

Söz konusu ihtiyaçlar, doğaları gereği ihale açılarak temini mümkün olmayan, işin doğası, piyasa koşulları ve çeşitli yasal düzenlemelerle idarelerin tercih hakkının ortadan kalktığı ihtiyaçlardır. Yoksa diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın bu

kapsamda karşılanması söz konusu değildir; doğrudan temin esas itibariyle istisnai olarak başvurulması gereken bir yöntemdir.

4734 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. bendinde yer alan; *"Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir."* şeklindeki düzenleme ile sözleşme yapma konusunda idareler serbest bırakılmıştır. Ancak sözleşme düzenlenmesini gerektiren serbestlik, istisnai durumlar hariç olmak üzere geçerlidir.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'da belirtilen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

Dolayısıyla, ihale kapsamı alımlar için 4734 sayılı Kanun ve alt düzey mevzuatta, idarelerce uygulanabilecek tip şartname, tip sözleşme, standart form gibi dokümanlar öngörülmüştür. Bu dokümanların doğrudan temin yönteminde kullanılması zorunlu değildir. Ancak idareler Kanun'un 22'nci maddesi çerçevesinde, diğer ihale usulleri için öngörülmüş bulunan bahse konu şartname ve sözleşme içeriklerinden yararlanarak kendi tercihleri doğrultusunda uygun dokümanlar hazırlayıp kullanması mümkündür. Hatta bahse konu dokümanları alım yöntemine uyarlayarak aynen de kullanmaları olanak dahilindedir.

Her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlarda, sözleşme düzenlenmesi istisnai durumlar hariç idarenin takdirinde olmakla birlikte, teminat alınması, cezai yaptırımlar öngörülmesi gibi uygulamaların tercih edildiği durumlarda yazılı sözleşme düzenlenmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir. Keza bahse konu hususların ispatı yazılı sözleşme düzenlenmesi ile netlik kazanabilecektir.

Kanun'da açıkça sayılan durumlar dışında, satın alma sürecinde ihale usulleri için öngörülen diğer düzenlemelerin uygulanmamasına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde gerek ihale kapsamı alımlar ve gerekse doğrudan temin kapsamı alımlarda, kuşkusuz ihale mevzuatı hükümleri ilk aşamada göz önünde bulundurulsa da alım sürecine ilişkin iş ve işlemler sadece ihale mevzuatı ile sınırlı değildir.

Kamu İhale Mevzuatına göre alımlar değişkenlik göstermektedir. Alımın niteliğine ve parasal tutarına bağlı olarak ihale kapsamı veya doğrudan temin yöntemine göre alım söz konusu olabilir.

Doğrudan temin, süreklilik arz etmeyen, Kanun'da belirtilen limitler dahilinde ihtiyaçların anında temin edilmesi ve ihale için belirlenen kurallara uğraşılmadan alınmasına ilişkin bir yöntemdir. Ancak süreklilik arz eden idare ihtiyaçlarının, ihale kapsamında karşılanması mümkündür.

Bu meyanda, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan; *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…"* hüküm ve ilkeleri çerçevesinde, ihtiyacın kısımlara bölünerek doğrudan temin limitine çekilmemesi gerekmektedir.

Aktarılan hususlara ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.5.1.2. maddesinde; *"Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir."* açıklaması bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Teyit işlemleri" başlıklı (30.5.) maddesinde ise; *"4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun*

belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir." açıklaması yer almaktadır.

Görüldüğü gibi, 4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, diğer usullere göre daha basit ve pratik yollarla gerçekleştirilmesine imkân tanınmış olmakla birlikte, ihalelere katılmaktan yasaklanmış kişilerden bu bent kapsamında alım yapılması mümkün değildir.

Dolayısıyla, Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Teyit işlemleri" başlıklı söz konusu maddesi uyarınca, 22'nci maddenin sadece (d) bendine göre belirlenen limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak kişinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. Bahsi geçen kişinin yasaklı olduğunun anlaşılması hâlinde bu kişiden alım yapılmamalıdır.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlara teyit zorunluluğu getirilmiş olduğundan temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarda teyide gerek bulunmamaktadır.

Ancak doğrudan temin yöntemiyle idare ihtiyaçları karşılanırken, yapılacak piyasa fiyat araştırmasında, eşit muamele ilkesi çerçevesinde, kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına etkin bir piyasa araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin kanıtlanabilir olmasına özen gösterilmesi gerekir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre doğrudan temin yöntemi, niteliği veya parasal tutarı gereği ihale türlerinden biri ile karşılanması gerekmeyen küçük ölçekli alımlar için öngörülmüş olup, bu alım yöntemi için getirilen kolaylıklardan, alımların herhangi bir kriterlere bağlı kalınmadan keyfi yöntemlerle gerçekleştirilebileceği sonucu çıkarılmaması gerekmektedir.

Yapılan düzenlemeler uyarınca doğrudan teminde, Kanun'un temel amacına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurulmadan, Kanun'da sayılan yeterlik kriterlerini dikkate almadan, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilmesi esastır.

Doğrudan teminde, 4734 sayılı Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların uygulanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ihale kapsamı alımlar için geçerliliği söz konusu olan bazı

kuralların (temel ilkeler, idarelerce uyulması gereken diğer kurallar gibi) bu alım yönteminde de uygulanması gerekmektedir. Çünkü bahse konu düzenlemeler alım yöntemlerinden bağımsız çerçeve düzenlemeler içeren, genel kurallar niteliğindedir.

Yapılan bu değerlendirme sırasında, ucuz olmakla birlikte tercih edilmeyen malın tercih edilmeme gerekçesi mutlaka piyasa fiyat araştırması tutanağında belirtilmelidir. Teknik şartname düzenlenen alımlarda teknik personelin piyasa fiyat araştırma sürecinde yer alması esastır. İdare teklif mektubunda ve/veya yapmışsa ilanında, düzenlemişse şartnamesinde belirtmesi koşulu ile yazılı tekliflerle yetinmemesi halinde hazırda bulunanlardan sözlü teklif vermelerini ister ve bu çerçevede satın alma karara bağlanır. Sözlü teklif verilmemişse, aksi kararlaştırılmadıkça yazılı teklifi son teklif olarak kabul edilir.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Yasa'nın 11'inci maddesinde "İhaleye katılmayacaklar olanlar" belirlenmiş olup, söz konusu maddenin;

"*Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:*

...

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

....

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir."

Hükmüne amir olduğu görülmektedir.

Görüldüğü üzere; Yasa'nın 11'inci maddesi çerçevesinde, ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılmaları mümkün değildir.

Aynı madde uyarınca, hatta bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri de doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları vurgulanmıştır.

Ancak söz konusu madde başlığında ve içeriğinde açık bir şekilde yer aldığı üzere, söz konusu yasaklama ve kısıtlamalar ihale kapsamı alımlar için geçerlidir. Yasa'nın tanımlara ilişkin maddesinde yer aldığı üzere *"İhale; Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri"* ifade etmektedir.

Mezkûr Kanun'un "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesinde yer alan *"Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir."* hükmünde görüleceği üzere, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin için bu yasakların geçerli olmadığını ifade edebiliriz. Zira doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel

hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

4734 sayılı Yasa'nın 60'ıncı maddesinde "Temel ilkelere" aykırı hareket eden kamu görevlilerine uygulanacak yaptırımlar hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, yasa hükümlerine aykırılıklar duruma göre, adli ya da idari yaptırıma konu olabilmektedir.

Anlatılanlar ışığında; 4734 sayılı Yasa hükümleri uyarınca gerçekleştirilen alımlarda uyulması gereken temel ilke ve esaslar bulunmakta olup, bunlara uyulmaması çeşitli adli ve idari yaptırımların uygulanmasını gündeme getirmektedir. Söz konusu kuralların bir kısmı sadece ihale kapsamı alımlar için geçerli iken, bir kısmı ise Kanun kapsamında gerçekleştirilen tüm alımlar için geçerlidir.

Bu bağlamda, Yasa'nın temel ilkelerine tüm alımlarda dikkat edilmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Yasa'nın 60'ıncı maddesinde de yer aldığı üzere, buna aykırılık yaptırım uygulanmasını gerektirmektedir.

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren durumlar hariç olmak üzere, uygulanacak olası adli yaptırımlar kapsamında, ihaleye fesat karıştırma suçunun söz konusu olup olmayacağına yönelik yapılan değerlendirmede neticesinde, alım ihale türleri arasında sayılmayan bir (doğrudan temin) yöntem ile alımın gerçekleştirilmesi nedeniyle, ihaleye fesat karıştırma suçu söz konusu olmamakla birlikte, görevi kötüye kullanma suçunun söz konusu olabileceği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde görevi kötüye kullanma tanımlanmış olup söz konusu maddede; "*Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.*
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile

cezalandırılır" hükmü yer almaktadır.

Anlatılanlar ışığında, 4734 sayılı Yasa'da ihale kapsamı alımlar için çeşitli yasak ve kısıtlamalar söz konusu olmakla birlikte, doğrudan temin yöntemi bir ihale türü olmadığı için yasaklamaların bu alım yöntemi için geçerli olmadığını ifade edebiliriz.

Bu itibarla, doğrudan temin kapsamında yapılan piyasa fiyat araştırması sürecinde görev alanların ve söz konusu belgeleri imzalayanların, ikinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde teklif alması ve en uygun fiyatın da teklif aldığı akrabaya ait olması halinde; bahse konu akrabasından alınmasını 4734 sayılı Kanun'da yasaklayan açık bir hüküm bulunmadığını (konunun etik boyutu hariç olmak üzere) söyleyebiliriz.

Bununla birlikte, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması sürecinde görev alan personelin, kabul edilebilir somut gerekçelere dayanmadan, rekabet ve eşit muamele ilkelerini gözetmeden yakın akrabalarında alım yapması ve bu alımlara ilişkin olarak usulen piyasa fiyatı tutanağı düzenlemesi durumunda, doğrudan temin yöntemi de olsa bu eylemlere ilişkin olarak disiplin hükümleri hariç olmak üzere, TCK kapsamında "görevi kötüye kullanma" suçunun gündeme gelebileceğinin bilinmesi gerekir.

64. Doğrudan temin kapsamı alımlarda sözleşmenin feshi söz konusu olabilir mi?

Özet: *4735 sayılı Kanun'da sözleşmenin feshine ilişkin hususlar düzenmişse de bu hususlar esas olarak ihale kapsamı sözleşmeler için geçerlidir. Ancak taraflar doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda sözleşme imzalamışsa ve sözleşme hükümleri içerisinde de yaptırıma ilişkin düzenlemeler varsa, bu hususta, sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi temel ilke olarak kabul edilmelidir. Konuyla bağlantılı birçok Sayıştay Kararının incelenmesinden de alımın doğrudan temin yöntemi yapılması ve bu alıma ilişkin olarak sözleşme düzenlenmesi durumunda, bu sözleşmelerin taraflar için bağlayıcı olacağı belirtilmiştir. İdare tarafından, yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde gerçekleştirmemesi halinde yazılı ihtar yapılarak sözleşmeye göre işin yapılması gereken tarihten itibaren gecikme cezası uygulanacağının belirtilmesi uygun olacaktır. İdare tarafından, sözleşmenin feshedilmesine yönelik yükleniciye verilecek ihtarlı süre de sözleşmede belirtilmelidir. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminatın gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek, alım konusu işin genel hükümlere göre tasfiye edileceğinin sözleşmede belirtilmesinde yarar bulunmaktadır. Doğrudan temin kapsamı alımlara ilişkin dokümanlarda ihale kapsamı alımlara ait tip dokümanlar referans alınarak kullanılabileceği gibi idare kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak farklı bir dokümanı da kullanabilecektir.*

4734 ve 4735 sayılı Yasalar çerçevesinde, ihale süreçlerini genel olarak iki kategoriye ayırabileceğimizi, bu evrelerin sözleşme öncesi ve sonrası dönemler olduğunu, bu dönemlerden sözleşme öncesi dönemin 4734 sayılı Kanun kapsamına girdiğini ve bu sürecin ihale onayının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar sürdüğünü, buna karşın sözleşme sonrası dönemin ise, 4735 sayılı Kanun kapsamı çerçevesinde, sözleşmenin imzalanmasından sonra başladığını ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin dönemi kapsadığını söyleyebiliriz.

Bu bağlamda, sözleşmenin feshi noktasında öncelikle ihale kapsamı alımlar sonrasında ise, doğrudan temin yönteminde feshi gerektiren durumlar hakkında bilgi verebiliriz.

Sözleşmenin feshine ilişkin hususların yasal düzeyde 4735 sayılı Kanun'da yer almakta olup, Yasa'nın "İdarenin sözleşmeyi feshetmesi" başlıklı 20'nci maddesi;

" *Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:*

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir."

Hükmüne amirdir.

Ancak söz konusu (4735) Yasa'da sözleşmenin feshini gerektirir durumlar sadece bunlar ile sınırlı olmayıp feshi gerektiren durumlar çeşitlilik göstermektedir.

Bu bağlamda, ihale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması durumunda da tespit tarihi itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınarak, bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. 4735 sayılı Kanun'un 20'nci maddesi uyarınca, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İzinsiz devretme veya devir alma ile üç yıllık süre içinde başka bir sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması hallerinde ayrıca bu gerçek veya tüzel kişiler hakkında 4735 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

Yüklenicinin ölümü halinde ise, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

Öte yandan, ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün

içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilir ancak yasaklama kararı verilmez. Yüklenicinin iflas etmesi halinde, aynı şekilde sözleşme feshedilmekle beraber, yüklenici hakkında yasaklama kararı verilmez.

Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

4735 sayılı Kanun'da da 4734 sayılı Kanun'a benzer şekilde, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek ihalelerden yasaklamayı gerektiren fiiller olarak sayılmıştır. Şayet, yasak fiil ve davranış sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmenin uygulanması sırasında gerçekleşmiş veya tespit edilmiş ise, öncelikle sözleşmenin feshedilmesi gerekmekte olup, akabinde, feshe neden olan fiilen veya davranışta bulunan veya iştirak eden ortak hakkında yasaklama kararı verilmesi gerekmektedir.

Ancak bu düzenlemenin tek istisnası, kamu yararı çerçevesinde taahhüdün en az %80'inin tamamlanmış olması ve yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması kaydıyla; ivediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması ve taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması hallerinde işin aynı yüklenici tarafından tamamlanmasına izin verilmesi durumudur. Bu durumda da yine sonuçta, yasaklama kararı verilmekle birlikte, yüklenicinin işi bitirmesi beklenmektedir.

Yasaklama kararının verilmesi durumunda, alınan teminatların ne yapılacağı hususunun da değerlendirilmesi gerekmektedir. Burada yasak fiilin tespit edilme tarihi uygulanacak işlemde belirleyici olmaktadır. Bu çerçevede, ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin; ihaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerekir. Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması

durumunda, isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerekecektir.

Belirtilen durumun ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ise, ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerekir. Ancak aynı durumun sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanun'un 21'inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi (yukarıda belirttiğimiz işin %80'inin tamamlandığı istisna durum hariç olmak üzere) ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, sözleşmenin ifası sırasında yüklenicinin yasak fiil ve davranışlarda bulunması veya sözleşme öncesinde, yasak fiil ve davranışta bulunduğunun sözleşmenin uygulanması sırasında tespit edilmesi halinde idarece tek yanlı olarak (kamu yararı gerektiren istisnai durumlar hariç olmak üzere) sözleşme feshedilebilir.

Kanun'la, yüklenicinin kusurundan kaynaklanan sözleşmenin feshi hallerinde yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatının irat kaydedileceği hüküm altına alındığından, aksi durumda, yani yükleniciye kusur atfedilmeyen sözleşmenin feshi hallerinde yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatının iade edilmesi gerekmektedir.

Sözleşmenin feshedilmesi halinde, ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. Buna karşın, mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edilmesi gerekir.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler ihale kapsamı alımlar için geçerli olup, bu düzenlemelerin doğrudan temin kapsamı alımlar için doğrudan uygulanması mümkün değildir. Bilindiği üzere, doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü değildir ve bu sebeple ihale usullerinin tabi olduğu mevzuata da tabi olmak zorunda değildir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin yönteminde, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan

Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca bu usulde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarelerin takdirindedir. Eğer taraflar doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda sözleşme imzalamışsa ve sözleşme hükümleri içerisinde de belli koşullarda sözleşmenin devrine ilişkin düzenlemeler varsa, bu hususta, sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi temel ilke olarak kabul edilmelidir.

Konuyla bağlantılı birçok Sayıştay Kararında da alımın doğrudan temin yöntemi yapılması ve bu alıma ilişkin olarak sözleşme düzenlenmesi durumunda, bu sözleşmelerin taraflar için bağlayıcı olduğuna dikkat çekildiği görülmüştür.

Belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda, bir kısım yükümlülükler ön görülüyorsa, yazılı sözleşme düzenlenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmelikleri ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olması gerekli değildir, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabilecektir.

4735 sayılı Kanun'da yer aldığı üzere, Kanun kapsamında yapılan sözleşmede, tarafların sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği gibi Kanun'un yorum ve uygulanmasında bu prensibin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bundan dolayıdır ki, yine aynı Kanun hükmü gereğince, 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağının hükme bağlanması ve söz konusu Kanun'la da (TBK) tarafların eşitliğinin ilke edinilmesi ve sözleşme hükümlerine aykırılığın da yaptırıma bağlanmasını, yapılan işlemlerde dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak ayrıca vurgulayabiliriz.

Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda sözleşme yapılmayan durumlarda veya sözleşmede gecikme cezasına ilişkin düzenleme bulunmaması halinde ceza uygulanamayacağı

görüşündeyiz. Aksi durum olan yani bu hususta sözleşme hükümlerinin bulunması halinde yaptırım uygulanması söz konusu olabilecektir.

Yani doğrudan temin kapsamı alımlar için de geçerli olmak üzere, borçlu üstlendiği taahhüdü, sözleşme hükümlerine göre kararlaştırılan yer ve zamanda gereği gibi veya hiç yerine getirmemesi veya sözleşmeye aykırı şekilde bitirilmesi hâlinde yaptırım uygulanabilir.

İdare tarafından, sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde gerçekleştirmemesi halinde yazılı ihtar yapılarak sözleşmeye göre işin yapılması gereken tarihten itibaren gecikme cezası uygulanacağının belirtilmesi uygun olacaktır. Gecikme cezasının, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesileceği belirtilmelidir. Bu ceza tutarının, ödemelerden ve varsa kesin teminattan karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edileceği belirtilmelidir.

Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gecikme cezası uygulanmasına yönelik düzenlemenin varlığına rağmen, sözleşme konusu iş zamanında ya da gereği gibi yapılmamışsa, mutlaka ceza maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmelidir. İdare tarafından, sözleşmenin feshine yönelik yükleniciye verilecek ihtarlı süre de sözleşmede belirtilmelidir. Belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminatın gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek, alım konusu işin genel hükümlere göre tasfiye edileceğinin sözleşmede belirtilmesinde yarar bulunmaktadır.

Sözleşmeye ilişkin ceza uygulanabilmesi için yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede buna ilişkin düzenleme bulunması zorunludur. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda, sözleşme yapılmaması veya sözleşmede yaptırıma ait düzenleme bulunmaması halinde ceza uygulanamaması gerektiği düşünülmektedir.

65. Doğrudan temin kapsamı alımlarda düzenlenmiş ise sözleşmenin devri mümkün müdür?

Özet: *Doğrudan temin kapsamı alımlar için sözleşmenin devrine ilişkin ihale mevzuatı açısından açık bir hüküm bulunmadığını, ancak gerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve gerekse anılan Kanun hükümlerinden hareketle Borçlar Kanunu hükümleri açısından sözleşmenin devrinin doğrudan temin kapsamı alımlar için mümkün olabileceğini, ancak bunun için bu hususta bir sözleşmenin düzenlenmesini ve düzenlenecek sözleşmelerde bu duruma ilişkin hususlara yer verilmesinin mümkün olabileceğini ifade edebiliriz.*

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükmü uyarınca, ihalelere ilişkin sözleşmelerde değişiklik yapılmaması genel kural olmakla birlikte, bazı hallerde değişiklik yapılabilmesine yasal olanak tanınmıştır. Keza söz konusu Kanun'un 15'inci maddesine göre, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, "İşin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları"nda değişiklik yapılabilmektedir.

Bu bağlamda, 4734 ve 4735 sayılı Yasa'lar çerçevesinde, ihale süreçlerini genel olarak iki kategoriye ayırabileceğimizi, bu evrelerin sözleşme öncesi ve sonrası dönemler olduğunu, bu dönemlerden sözleşme öncesi dönemin 4734 sayılı Kanun kapsamına girdiği ve bu sürecin ihale onayının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar sürdüğünü, buna karşın sözleşme sonrası dönemin ise, 4735 sayılı Kanun kapsamı çerçevesinde, sözleşmenin imzalanmasından sonra başladığını söyleyebiliriz.

Söz konusu dönem farklılıkları sadece kategorik bir inceleme için ayrılmayıp, uygulanan mevzuat açısından da farklılık arz etmektedir. Keza sözleşme öncesi dönemi ilişkin iş ve işlemler KİK'e itirazen şikayet konusu olurken, sözleşme sonrası dönem ise, ancak adli makamlar nezdinde dava konusu olabilmektedir.

4735 sayılı Kanun'a göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceği gibi, Kanun'da belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağını ve ek sözleşme düzenlenemeyecektir.

4735 sayılı Kanun'un muhtelif maddelerinde, ihale süreçlerine ilişkin hükümlerin bulunduğunu, keza anılan Kanun'a göre düzenlenecek sözleşmelerde bulunması gereken hususlar ile sözleşmede değişiklik yapılma ve sözleşmenin feshine ilişkin şartların bu kapsamda yer aldığını görmekteyiz. Bu bağlamda, 4735 sayılı Kanun'da (16.md.) sözleşmenin devrine ilişkin düzenlemelere de yer verilmek suretiyle, sözleşmenin devri belli koşulara bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde, bir sözleşmenin devri için;

a) Sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması,
b) İhale yetkilisinin yazılı izninin bulunması,
c) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması,
zorunludur.

Diğer bir anlatımla, yukarıda yer alan koşulların birlikte gerçekleşmediği durumlarda ihalelere ilişkin sözleşmelerin devri yapılamaz. Ancak burada unutulmaması gereken "isim ve statü değişikliği" gereği yapılan devirlerin, sözleşmenin devri olarak kabul edilemeyeceği hususudur. Ayrıca, sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde, aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemeyeceği gibi, devir de alınamaz.

Nitekim ihale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması suretiyle, sözleşmenin 4735 sayılı Kanun'a aykırı şekilde devredilmesi veya devir alınması halinde tespit tarihi itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınarak, bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. 4735 sayılı Kanun'un 20'nci maddesi uyarınca, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İzinsiz devretme veya devir alma ile üç yıllık süre içinde başka bir sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması hallerinde ayrıca bu gerçek veya tüzel kişiler hakkında 4735 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

Tekrar ifade etmek gerekirse, ihalelere ait sözleşme ancak Kanun'da yazılan hallerde devredilebilir. Kanun'da belirtilen şartları taşımayan sözleşmelerin devri ise feshi ve ihalelerden yasaklamayı gerektirmektedir. Sözleşmenin 4735 sayılı Kanun'a aykırı şekilde devredilmesi veya devir alınması halinde tespit tarihi itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayıldığını

ve bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınarak yükleniciye bildirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği'nde de sözleşmenin devri konusunda düzenlemeler bulunmakta olup, söz konusu Tebliğin "Madde 27- Sözleşmenin devrine ilişkin açıklamalar" başlıklı kısmının;

"27.1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 ncı maddesinde sözleşmenin devrine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre sözleşmenin devrine ilişkin işlemlerde;

a) Sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması,

b) İhale yetkilisinin yazılı izninin bulunması,

c) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması,

zorunludur.

27.2. İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler, sözleşmenin devri olarak kabul edilmez. İsim veya statü değişikliğinden;

a) Ticarî işletmenin adı veya unvanındaki değişiklik,

b) İşletmenin nev'inde meydana gelen değişiklik,

anlaşılır.

27.3. Sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde, aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. Devir tarihi, devir sözleşmesinin noterce onaylandığı tarihtir.

...

27.6. (Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./12. md.) Aşağıda belirtilen hallerde sözleşme feshedilir ve devreden ve devralanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ncı maddeleri uygulanır:

a) İhale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması,

b) Sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde sözleşmeyi devreden yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredilmesi veya devralınması.

27.7. Sözleşmenin 4735 sayılı Kanuna aykırı şekilde devredilmesi veya devir alınması halinde tespit tarihi itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

27.8. (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 6.md.) 4735 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) göre güncellenir, güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminat tutarları arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir, hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedilir ve sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

27.9. İzinsiz devretme veya devir alma ile üç yıllık süre içinde başka bir sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması hallerinde ayrıca bu gerçek veya tüzel kişiler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

27.10. Kurumun görevlerini etkin ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi ve sözleşme devir hallerinin tespit edilerek idarelere bu konuda gerektiğinde bilgi verilmesi amacıyla; sözleşmenin devredilmesinde idarece aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi gerekmektedir:

(Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./12. md.) İdarelerin sözleşmenin devrine ilişkin işlemi onaylamadan önce, sözleşmeyi devredenin ve devralanın son üç yıllık süre içerisinde başka bir sözleşmeyi devredip devretmediğini, İKN'si Kamu Satın Alma Platformu üzerinden alınmış olan ihalelerde Kurumumuz internet sayfasında bulunan Kamu Satınalma Platformunu, İKN'si Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden alınmış olan ihalelerde ise Elektronik Kamu Alımları Platformunu kullanarak elektronik ortamda teyit ettirmeleri gerekmektedir. Teyit işleminden sonra, Sözleşme Devir Teyit Belgesinin çıktısı alınarak ihale işlem dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen fesih ve müeyyide hükümlerinin uygulaması söz konusu olacaktır. Devir sözleşmesi yapıldıktan sonra, idarece Sözleşme Devri Bildirimi Belgesi doldurularak elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Sözleşme Devir Belgesinin de çıktısı alınarak ihale işlem dosyasında muhafaza edilir."

Şeklinde düzenlendiği görülmektedir.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler ihale kapsamı alımlar için geçerli olup, bu düzenlemelerin doğrudan temin kapsamı alımlar için doğrudan uygulanması mümkün değildir. Bilindiği üzere, doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü değildir ve bu sebeple ihale usullerinin tabi olduğu mevzuata da tabi olmak zorunda değildir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin yönteminde, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu usulde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarelerin takdirindedir.

Eğer taraflar doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda sözleşme imzalamışsa ve sözleşme hükümleri içerisinde de belli koşullarda sözleşmenin devrine ilişkin düzenlemeler varsa, bu hususta, sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi temel ilke olarak kabul edilmelidir.

Konuyla bağlantılı birçok Sayıştay Kararının incelenmesinden de alımın doğrudan temin yöntemi yapılması ve bu alıma ilişkin olarak sözleşme düzenlenmesi zorunlu ise bu sözleşmelerin taraflar için bağlayıcı olacağı belirtilmiştir. Şöyle ki;

- *Konuyla bağlantılı bir Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin usulünde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarelerin takdirinde olduğu belirtilerek, bu aşamadan sonra artık idare ve yüklenici, alımının doğrudan temin usulüyle yapıldığından bahisle aralarında imzalamış oldukları bu sözleşme hükümlerine aykırı davranamayacakları belirtilerek, sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesinin mevzuata aykırılık oluşturmadığı ifade edilmiştir.*

- *Başka bir Kararda ise; doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığından mal alımlarında herhangi bir cezai müeyyide bulunmadığını ileri sürmüş ise de, ... kamu yararı olduğunu dikkate alarak idare ile satıcılar arasında sözleşme imzalandığı, bu sözleşmelere, malzemenin zamanında teslim edilmemesi halinde gecikme cezası kesilmesi yönünde hükümler konulduğu, kanunlara aykırı olmayan sözleşme hükümlerinin uygulanması da zorunlu olup, tarafları bağlayacağı tespitlerine yer verilerek, doğrudan temin yönteminde düzenlenen sözleşmelerin tarafları bağlayacağı belirtilmektedir.*

Doğrudan temin kapsamı alımlarda genel kural, sözleşme düzenlenmesi hususu idarelerin takdirinde olmakla birlikte, 22'nci madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi ile 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

Belli esnekliklere rağmen, bu alım yönteminde de kamu kaynağı kullanıldığı dikkate alınarak, kamu idarelerinin, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için harcama yapması ancak mevzuatta öngörülen bazı yükümlülükleri yerine getirmeleri ile mümkün olabilmektedir.

İhale kapsamı alımlar için 4734 sayılı Kanun ve alt düzey mevzuatta, idarelerce uygulanabilecek tip şartname, tip sözleşme, standart form gibi dokümanlar öngörülmüştür. Bu dokümanların doğrudan temin yönteminde kullanılması zorunlu değildir. Ancak idareler Kanun'un 22'nci maddesi çerçevesinde, diğer ihale usulleri için öngörülmüş bulunan bahse konu şartname ve sözleşme içeriklerinden yararlanarak kendi tercihleri doğrultusunda uygun dokümanlar hazırlayıp kullanması mümkündür. Hatta bahse konu dokümanları bu alım yöntemine uyarlayarak aynen de kullanmaları olanak dahilindedir.

Bununla birlikte, her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlarda sözleşme düzenlenmesi istisnai durumlar hariç idarenin takdirinde olmakla birlikte, teminat alınması, cezai yaptırımlar öngörülmesi gibi uygulamaların tercih edildiği durumlarda yazılı sözleşme düzenlenmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir. Keza bahse konu hususların ispatı yazılı sözleşme düzenlenmesi ile netlik kazanabilecektir.

Bu gibi alımlarda alıma ilişkin yükümlülüklerin devredilmesi yani sözleşmenin devredilebileceği noktasında mevzuat açık bir hüküm bulunmamaktadır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile de hükme bağlandığı üzere, Kanun kapsamında yapılan sözleşmelerin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceğini ve Kanun'un yorum ve uygulanmasında bu prensibin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade edebiliriz.

Bundan dolayıdır ki yine aynı Kanun hükmü gereğince, 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağının hükme

bağlanması ve söz konusu Kanun'la da (TBK) tarafların eşitliğinin ilke edinilmesi ve sözleşme hükümlerine aykırılığın da yaptırıma bağlanmasını, yapılan işlemlerde dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak ayrıca vurgulayabiliriz.

Söz konusu 6098 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine baktığımız zaman, anılan Kanun'un;

"A. Sözleşmenin kurulması

I. İrade açıklaması

1. Genel olarak

MADDE 1- *Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.*

İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.

2. İkinci derecedeki noktalar

MADDE 2- *Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır.*

İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar.

Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır…"

II.

A. Sözleşmenin devri

MADDE 205- *Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşmadır.*

Sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan ve sözleşmede kalan diğer tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaşma da, sözleşmenin devri hükümlerine tabidir.

Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlıdır.

Kanundan doğan halefiyet hâlleri ile diğer özel hükümler saklıdır. "

Hükümlerine amir olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde, devir halini de kapsayacak şekilde aranacak belgeler anılan Yönetmeliğin 64'ncü maddesinde yer almakta

olup, "Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler" başlıklı söz konusu maddeye göre;

"Kamu ihale mevzuatına göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bedellerinin ödenmesinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan belgelerden başka, duruma göre aşağıda belirtilen belgeler de ödeme belgesine bağlanır. Söz konusu belgelerin onaylı birer nüshaları muhasebe biriminde saklanan taahhüt dosyalarına eklenmek üzere ayrıca alınır.
a) Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi..."

Şeklinde ifade edildiği görülmüştür.

Görüldüğü üzere; sözleşmenin devri noktasında Türk Borçlar Kanunu, özel hükümlerin geçerli olduğuna dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, Kamu İhale Mevzuatınca özel bir düzenleme yapılmışsa öncelikle bunun geçerli olduğunu, bu hususta bir hüküm bulunmamışsa, bu durumda Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasının söz konusu olabileceğini belirtebiliriz.

Anlatılanlar ışığında netice itibarıyla;

- Gerek 4734 sayılı Kanun ve gerekse 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu yer alan sözleşmenin devrine ilişkin hükümlerin ihale kapsamı hükümler için geçerli olduğunu, bu hükümlerin doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar için uygulanmasının mümkün olmadığını,

- Ancak doğrudan temin kapsamı alımlar için sözleşme düzenlenebileceğini, düzenlenecek bu sözleşmelerde tarafların yükümlülüklerinin ortaya konulması gerektiğini, bu kapsamda sözleşmenin devrine ilişkin olarak da sözleşmelere hükümler konulabileceğini,

- 4735 sayılı Kanun'da, anılan Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasına yönelik hüküm bulunması ve ayrıca, söz konusu Kanun'la da (TBK) tarafların eşitliğinin ilke edinilmesi ve sözleşme hükümlerine aykırılığın da yaptırıma bağlanmasına yönelik düzenlemeler ışığında, 6098 sayılı Kanun'da sözleşmenin devrine ilişkin hükümlerin de bulunduğunu, bu hükümlerin doğrudan temin yöntemi için de geçerli olabileceğini,

- Doğrudan temin kapsamı alımlarda, ihale kapsamı alımlara ait tip dokümanların referans alınarak kullanılabileceği gibi idare kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak farklı bir dokümanı da hazırlayarak da kullanabileceğini,

İfade edebiliriz.

66. Piyasa fiyat araştırması kapsamında yurtdışından alım yapılabilir mi?

Özet: *Doğrudan temin kapsamı alımlarda ihale prosedürlerinin dışına çıkılmasına bağlı olarak idarelere çeşitli esneklikler sağlanmıştır. Bu nedenle yurtiçinde olduğu gibi yurtdışındaki bir istekliden idare ihtiyacının karşılanmasına bir engel yoktur. Ancak yurtdışında yaşayan kişilerden veya yurtdışı on-line alışveriş sitelerinden doğrudan teminle alım yapılması hususunda yasal bir engel bulunmamakla birlikte, bu sitelerden doğrudan teminle alım yapılması pratikte mümkün olmayabilir. Zira bu sitelerden alım yapılması halinde, sözleşme yapılması durumunda sözleşme bedeli üzerinden sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerekecek olup, bu verginin tahsil edilmesinde sıkıntılar yaşanabilecektir. Ayrıca idarenin bu şekilde yapılan bir alımda, mali mevzuat dikkate alındığında, tedarikçiye ödeme yapılmasında da sıkıntılar yaşanabilecektir. Bu nedenle, her ne kadar yurtdışı kanalıyla doğrudan temin kapsamında alım yapılmasına bir engel yoksa da ihale mevzuatı ve bağlantılı mevzuata ilişkin düzenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiği zaman, bu durumun birçok riski barındırdığı ve bu nedenle öncelikle başvurulması gereken bir yol olmadığı düşünülmektedir. Örneğin, alıma konu eşyaya ait ithalat mevzuatı hükümlerinin düzenlemelerinin dikkate alınması ve bunun çözülmesi için karmaşık süreçler söz konusu olabilir. Bu da idare ihtiyaçlarının uygun koşul ve zamanında karşılanması gerekliliğine yönelik 4734 sayılı Yasa'nın temel ilkelerine aykırılığa neden olabilir. Dolayısıyla, mevcut düzenlemeler ışığında, yasal bir engel bulunmamakla birlikte, idare ihtiyacının karşılanması noktasında, çeşitli teknik ve hukuki olası sorunlar nedeniyle, idare ihtiyacı için zorunluluk arz etmedikçe bu yola başvurulmaması gerektiğini düşünmekteyiz.*

Doğrudan temin yöntemi, 4734 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde; "*Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul*" şeklinde tanımlanmaktadır.

Yasa'nın "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinde ise, bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edileceği öngörülmüştür.

Söz konusu alım yönteminde ihtiyaçlar ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilir. Kamu İhale Mevzuatında piyasa

araştırması yapacak kişi ya da kişilerin yazılı olarak görevlendirilmesine yönelik bir standart form bulunmamakla birlikte, görevlendirmenin yazılı olarak yapılması olası hukuki belirsizliklerin giderilmesi adına yaralı olacağı düşünülmektedir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde piyasa fiyat araştırması tutanağı; "*doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanak*" olarak tanımlanmıştır.

Doğrudan temin konusu yapılabilecek ihtiyaçlar Kanun'un 22'nci maddesinde sayılmış olup, sayılanlarla sınırlı olup, bunların kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. Zira madde metni buna izin vermemektedir. Doğrudan teminde, Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların uygulanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, temel ilkeler gibi tüm alımlar için geçerli olan kuralların doğrudan temin için de geçerli olması söz konusudur. Zira her iki alımda da yöntemler farklı da olsa kamu kaynağı kullanılmaktadır.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddenin son fıkrasında, piyasa fiyat araştırması öngörülmüş olmakla birlikte, bu fiyat araştırmasına ilişkin olarak yurtiçi veya yurtdışı şeklinde bir ayrım yapılmadığı için, söz konusu ifadenin yurtdışını da kapsadığı düşünülmektedir.

İdarelerin yurtdışında doğrudan temin kapsamında alım yapması sadece 22/d kapsamı için söz konusu olmayıp, istisnai durumlar olarak ifade edebileceğimiz Yasa'nın ilk fıkrasının "a, b ve c bentleri" kapsamında yapılan alımlar için de söz konusu olabilir. Ancak "c bendi" için yurtdışı müşteriden alım yapılması pek öngörülebilir bir durum değildir.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında alım tutarları, 2022 yılı için büyükşehir belediye sınırlar içerisinde kalan idareler için 218.395.-TL, diğer idareler için 72.752.-TL olarak belirlenmiş olup, bu rakamsal sınırların yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da idarece piyasa fiyat araştırma sürecinde dikkate alınması gerekir.

Piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmalar somut ve dayanaklarıyla birlikte kanıtlanabilir olması gerekmektedir. Piyasa fiyat araştırmasında kaç kişiden teklif alınacağına ve bunların nasıl belgelendirileceğine ilişkin mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin eki piyasa fiyat araştırma tutanağının dipnotunda piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi/firma, yer sayısına harcama yetkilisinin karar vereceği ifade edilmiştir. Alınacak mal ve hizmet alımı ile yapım işinin özelliğine göre makul sayıda kaynaktan araştırma yapılarak en uygun fiyata ulaşılması görevlilerin önceliği olması gerekmektedir.

Bu nedenle idare satıcılardan faks veya e-posta yoluyla fiyat alabilecektir. Ayrıca on-line alışveriş sitelerinden de fiyat araştırması yapılabilecektir. Ancak alım bedelini tespit için yapılan fiyat araştırmasının, her ne surette yapılırsa yapılsın belgelendirilmesi şarttır. Bu nedenle piyasa fiyat araştırması kapsamında sözlü veya telefonla nihai teklif alınmasının uygulanabilir olmadığı değerlendirilmektedir. Alım bedelini tespit için fiyat araştırması her ne suretle yapılırsa yapılsın belgelendirilmesi şarttır.

Yurtdışı kişi ya da firmalardan ya da alışveriş sitelerinden doğrudan teminle alım yapılması hususunda yasal bir engel bulunmamakla birlikte, buralardan doğrudan teminle alım yapılması pratikte mümkün olmayabilir. Zira bu sitelerden alım yapılması durumunda sözleşme yapılacağı için sözleşme bedeli üzerinden sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerekecek olup, bu verginin tahsil edilmesinde sıkıntılar yaşanabilecektir. Ayrıca idarenin bu şekilde yapılan bir alımda, tabi olduğu mali mevzuat dikkate alındığında, tedarikçiye ödeme yapmasında da sıkıntılar yaşanabilecektir. Aynı şekilde, garanti ve bakım sürecinde de çeşitli problemler yaşanabilir.

Bu itibarla, pratik sıkıntılara rağmen, gerek Kanun ve gerekse alt düzey mevzuatın birlikte değerlendirilmesi neticesinde, yurtiçinde olduğu gibi 22/d kapsamında yurtdışında piyasa fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların karşılanabileceği düşünülmektedir. Yani olası zorluklara rağmen, açık bir hukuki engel yoktur.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, yurtdışında alıma konu eşya ile ilgili olarak ihale mevzuatı dışındaki mevzuat açısından da bir sorunun olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla, söz konusu eşya ile ilgili ithalat veya vergi mevzuatı açısından bir yükümlülük öngörülüyorsa, bu yükümlülüklerin yerine istekli tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, yurda girişi farklı bir kurumun iznine tabi ise bu kurumdan izin alınması gerekir. Ya da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) mevzuatı açısından bir yükümlülük söz konusu ise bu yükümlülüğün de yerine

getirilmesi gerekir. Özetle, alıma konu eşya için yükümlülükler sona erip milli eşya olmadan (istisnai bir durum olmadığı sürece), idareye sunulmaması gerekir.

Diğer bir anlatımla, fiyat araştırma sürecinde idarenin (görevlilerin) yurt içinde veya yurt dışında araştırma yapmasına engel bulunmamakla birlikte, istekli, idareye sunmuş olduğu teklifte bütün bu hususları düşünerek ürünü problemsiz bir şekilde nihai teklifini kapsayacak şekilde sunması gerekir. Yoksa hukuki sorunlar sonrasında yaşanabilir.

Yasa'nın 22'nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında da yurtdışından idare ihtiyaçlarının doğrudan temin yöntemiyle karşılanabileceği düşünülmekte olup, mezkûr madde ise;

"Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması… Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

Şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler uyarınca, Yasa'nın 22'nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartların bulunması halinde, yurtdışındaki üreticilerden de doğrudan temin kapsamında mal ve hizmet satın alınması mümkündür. Yani yurt içi ve yurt dışı açısından yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla, bir ayrım bulunmamaktadır.

Zira bu nitelikteki alımlar istisnai nitelikte alımlar olup, piyasada yapılan araştırma neticesinde, ihtiyaçların sadece tek bir kaynaktan temin edileceğinin ortaya çıkması halinde Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (a) bendine göre alım yapılabilir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir

marka veya model bir malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, bu bendin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Yasa'nın 22'nci maddenin (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade etmektedir.

İhale konusu mal veya hizmet alımı; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, ilan yapılmaksızın doğrudan teminle ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin "c bendi" kapsamında yapılacak alımlarda ise, daha önce bu kapsamda sözleşme imzalanmış olması gerekmekte olup, doğrudan temin yöntemi için yurtdışı bir istekli ile daha önce sözleşme imzalanması çok olası bir durum olmadığı düşünülmektedir.

İdareler, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.

Tek satıcılık halinin ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları gibi mercilere başvurarak buralardan temin edilecek belgelerle kanıtlanması zorunluluğu bulunmamakta ancak ihtiyacın niteliğine göre ihtiyacın tek kişiden temin edilmesi hususunun buralardan alınacak bilgilerle gerekçelendirilmesi ve temini mümkün olan bilgi ve belgelerle da gerekçe veya gerekçelerin temellendirilmesinin doğru olacağını düşünmekteyiz.

Bu bağlamda, tek satıcılık hali her ihtiyaç için ayrı ayrı belirlenmesi gereken bir husus olup, bu hususla ilgili olarak öncelikle ihtiyacın objektif olarak belirlenmesi ve tanımlanması gerekir. İhtiyacın ikame edilebilir olmaması gerekir.

Yasa'nın 22/b maddesinin uygulamasında ise idarece, Tek Kaynaktan Temin Edilen

Mallara/Hizmetlere İlişkin Form kullanarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceği detaylı olarak yazılacak, fiyat araştırması yapılacak, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin nitelikleri tarif edilecek ve buna ilişkin belgeler forma ekleyeceklerdir.

Diğer taraftan, bu kapsamdaki alımlara ait ödeme sürecinde hangi belgelerin gerekli olduğu hususu ise, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Söz konusu Yönetmelikte;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde;
- Onay Belgesi ,
- Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Fatura,
- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
-Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi,
ödeme belgesine bağlanır.
Söz konusu alım bedellerinin ödenmesinde aranılacak belgelere ilişkin diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir.
a) Yurtdışından yapılacak tüketim malı, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde birinci fıkrada belirtilen belgelere ilaveten;
- Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildiğine ilişkin belge,
- Taşıma senedi (konşimento),
ödeme belgesine bağlanır.
Yurtdışından yapılan satınalmalarda ödenen vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örneği aranır…" hususları yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin "Taahhüt dosyası"na ilişkin 6'ncı maddesi ise; "İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (Örnek:2) veya söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek

kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir…" şeklinde düzenlenmiştir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ'de de; *"Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler;*

(1) Kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderler için ilgili mevzuatında düzenlenmesi, aranması ve alınması öngörülen belgelerin düzenlenmesi, aranması ve alınması zorunludur. Kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan ihale işlem dosyasında, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgeler bulunur. Taahhüt dosyasında ise yalnızca ödeme belgesine bağlanması öngörülen belgelere yer verilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuatına göre istenen belgelerden Yönetmelikte ve bu Tebliğde sayılmayanlar ödeme belgesine bağlanmayacak, iç ve dış denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerinde muhafaza edilecektir.

(2) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve diğer ilgili maddeleri gereğince, taahhüt dosyasında bulunması öngörülen belgeler ile Bakanlığımızca taahhüt dosyasında bulunması gerekli görülen diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir.

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi dışındaki bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda;

-Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi,

-Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, komisyon kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı; 22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form,

-Yukarıdaki (a) bendinde sayılanlardan düzenlenmesi gereken diğer belgeler.

bağlanır…"

Hususları yer almaktadır.

Görüldüğü üzere; yurtdışından herhangi bir şekilde Yasa'nın 22'nci maddesi kapsamında bir alım yapılması halinde, buna ilişkin ödeme sürecinde, yurtiçinden farklı olarak döviz

transferine ilişkin belge ile taşıma senedinin aranması söz konusu olabilmektedir.

Bu kapsamda görevlendirilen kişilerce gerekli olan her türlü piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı, gerçekçi ve kanıtlanabilir şekilde yapılması zorunludur. Hatta isteklilerle fiyat konusunda idare lehine pazarlık yapılması, kamu kaynaklarının kullanılması adına uygun bir hareket tarzı olur. Zaten doğrudan temin yönteminin niteliği de buna izin vermektedir.

5018 sayılı Yasa'nın muhtelif maddelerinde kamu görevlilerinin mali sorumlulukları ile ilgili hükümler mevcuttur. Bu nedenle piyasa fiyatının tespitine yönelik çalışmaların somut verilere dayanılır olması gerekir.

Piyasa fiyatını araştırırken, belli sayıda ve belli yerlerden fiyat alınmasına yönelik ihale açık bir düzenleme yoktur. Bu tamamen sorumluluk altına giren görevlilerin takdirindedir. Alıma konu eşyanın tedarik süreci kolay ve parasal tutarı nispeten yüksek ise, teamül niteliğinde olan üç teklif sayısı ile sınırlı kalınmaması daha uygun bir davranış olacaktır.

Ayrıca, oluşacak fiyatın gerçek piyasa rayicini yansıtıp yansıtmadığını da ilgili görevliler tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin; farklı zincir mağazalar veya internet alışveriş siteleri dikkate alınarak sunulan fiyatın doğruluğu bir anlamda sorgulanmalıdır.

Zira 5018 sayılı Yasa'nın amacına ilişkin ilk maddesinde yer aldığı üzere, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması temel hedeftir.

Bu itibarla, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında ihtiyacın en uygun fiyatla ve koşullarda temin edilebilmesi için, öncelikle alıma konu eşyanın teknik özelliklerinin iyi bir şekilde belirlenmesi ve bu belirleme göz önünde bulundurularak fiyat araştırması yapılması gerekir. Hatta gerekli ise alıma ait özelliklerin piyasa fiyat araştırması yazısında yazılması yeterli görülmüyorsa, bahse konu yazı ekinde teknik veya idari şartname düzenlenerek gönderilmesi olası belirsizliklerin aşılması adına uygun bir hareket tarzı olacaktır.

67. Doğrudan temin yöntemindeki parasal limit ve alımlardaki hesaplamaya KDV dahil midir?

Özet: *Kamu İhale Mevzuatı uyarınca belirlenen parasal limitler, KDV hariç olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, gerek doğrudan temin ve gerekse ihale kapsamı alımlarda yaklaşık maliyet hesabı başta olmak üzere, hakediş ödemesi dahil olmak üzere, KDV'nin hesaplamalarda ayrıca dikkate alındığı göz önünde bulundurularak buna göre ödenek planlaması yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani hesaplamalarda isteklilerden KDV hariç fiyat istenir, ödemelerde ise KDV ayrıca ödenir. Ödeme esnasında KDV tevkifatı söz konusu ise, bu kesintinin de ayrıca yapılması bir zorunluluktur.*

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde, Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, "Doğrudan temin" başlıklı Kanun'un 22'nci maddesi incelendiğinde; doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, Yasa'nın 67'nci maddesi gereğince Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen parasal limit ve eşik değerlerin dikkate alınması gerekmektedir. Zira anılan Kanun'un eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin bahse konu maddesi çerçevesinde, 2022 yılı için Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenmiş ve 20.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.

İlan edilen bu parasal tutarlar (1 Şubat 2022-31 Ocak 2023) tarihleri arasında bir yıl süre ile geçerli olup, bu tutarların, bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar kullanılması söz konusudur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanması bağlamında, anılan Kanun'un 8'inci maddesi ile düzenlenen mezkûr değerler, ihale ilan süreleri ve kuralları gibi hususlarda yaklaşık maliyet esas alınarak kullanılan parasal değerleri temsil etmektedir.

Eşik değer dışında kalan ve Kanun'da yer alan diğer parasal limitler ise, ihalenin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için göz önünde bulundurulması gereken tutarları ifade etmektedir. Bu parasal limitler, belirli unsurlar esas alınarak hesaplanan bir değer olmayıp, uluslararası düzenlemeler çerçevesinde esasları Kanun ile belirlenen bir niteliğe sahiptir.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendine göre parasal sınırlar kapsamında harcama yapılması mümkündür. Diğer bentler için parasal sınır yoktur. Hatta 22/d kapsamı temsil ve ağırlama giderleri için parasal sınır geçerli değildir.

20.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ çerçevesinde, 2022 yılı için geçerli olan eşik değerleri tablo ile gösterilebiliriz. Şöyle ki;

4734 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca 2022 yılı Eşik Değerlere ait Tablo

Kanun Kapsamına Giren İdare Türleri	Alımın Türü	31.01.2022 tarihine kadar uygulanan eşik değerler (TL)	01.02.2022-31.01.2023 döneminde uygulanacak eşik değerler (TL)
Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler	Mal ve Hizmet alımlarında	2.225.824	4.004.034
Kanun kapsamındaki diğer idarelerin (genel ve katma bütçe dışındaki idarelerin)	Mal ve Hizmet alımlarında	3.709.717	6.673.409
Kanun kapsamındaki bütün idarelerin	Yapım İşlerinde	81.614.303	146.815.969

Şeklinde olduğunu görürüz.

Öte yandan, eşik değerlere benzer şekilde 2022 yılı için yine 2022/1 sayılı Tebliğ ile belirlenen parasal limitleri, ilgili Kanun maddelerini de ortaya koyacak şekilde tablo halinde gösterecek olursak;

4734 sayılı Kanun'da yer alan 2022 yılı Parasal değerlere ilişkin Tablo

İlgili Kanun Maddesi ve Açıklaması	**Önceki Parasal Limit (TL)** 31.01.2022 tarihine kadar uygulanan parasal limitler	**2022 için Parasal Limit (TL)** 01.02.2022-31.01.2023 döneminde uygulanacak parasal limitler
• İstisna maddesi (3-g)	18.619.202	33.494.082
• "İhale İlan Süreleri ve Kuralları" başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;		
-1 no.lu alt bendi	242.832	436.830
-2 no.lu alt bendi	485.689	873.705
-3 no.lu alt bendi	4.047.628	7.281.278
• "Pazarlık Usulü" başlıklı 21 inci maddenin; (f) bendinde	404.732	728.072
• "Doğrudan Temin" başlıklı 22 nci maddenin; (d) bendinde		
-Büyükşehir belediye sınırları dahilinde	121.405	218.395
-Diğer idareler için	40.443	72.752
• "Kamu İhale Kurumu" başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının (KİK Gelirleri)		
-1 no.lu bendi için (ihale sözleşme bedeli sınırı)	809.496	1.456.202
-2 no.lu alt bendi için (KİK'e yönelik itirazen şikâyet bedeline ilişkin yaklaşık maliyet aralıkları ve şikâyet bedelleri tutarları)	1.281.438	2.305.178
	7.682	13.819
	5.125.768	9.220.744
	15.373	27.654
	38.443.271	69.155.600
	23.060	41.482
	30.750	55.316
• "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62 nci maddenin (h) bendi için (iş deneyimi bulunmayan mimar ve mühendisler için dikkate alınacak iş deneyim tutarı)	449.259	808.172

Şeklinde olduğunu görmekteyiz.

Eşik değer ve parasal limitlerin ihale sürecine olan ilişkisini bir örnek yardımıyla ortaya

konulabiliriz. Şöyle ki; bir hizmet alımına ilişkin ihale sürecinde, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan ihalelerde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenebilmesi bir zorunluluk değilken; yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, aynı belgenin istenilmesinin zorunlu olması eşik değer ve parasal limitlerin sürece etkisini ortaya koymaktadır.

Aynı şekilde, bir mal alımı veya yapım işinde de eşik değer ve parasal limitlere bağlı olarak talep edilen belgeler ve bu belgelerin niteliği değişebilmektedir. Bu bağlamda, ihale sürecinin doğru bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için ihale işlem ve süreçlerin söz konusu eşik değer ve parasal limitlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, ihale sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yapılacak işlemlerde, eşik değer ve parasal limitlerin dikkate alınması gerekmektedir. Keza söz konusu tutarlar, 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi ile 13 (ilan süreleri) ve 63'üncü maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanmasını etkilemektedir. Yani, söz konusu tutarlar, sadece alım türü açısından değil, ilan ve yeterlik gibi temel işlem adımları açısından da önem arz etmektedir.

Yukarıda yer verilen eşik değer ve parasal değerler gerek ihale kapsamı alımlar ve gerekse doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlarda mutlaka dikkate alınması gereken parasal tutarlardır. Söz konusu değerlerin dikkate alınmaması hatalı ve geçersiz noktasına varacak olumsuzluklara sebebiyet verebilir.

Örneğin; Yasa'nın 22/d kapsamı doğrudan teminler için büyükşehir sınırları için öngördüğü limit olan 218.395 .-TL tutarının aşılması durumunda bu bent kapsamında alım yapılması mümkün değildir. Yapılması durumunda bu davranış yaptırımı gerektirmektedir. Aynı şekilde 21/f kapsamı limit 2022 yılı için 728.072.-TL rakamıdır. Bu tutarı aşan alımların da bu bent kapsamında yapılması mümkün değildir.

Doğrudan temin boyutuyla konuya baktığımızda, bilindiği gibi, doğrudan temin bir ihale usulü değildir ve Kanun'un ihale usulleri için öngördüğü kuralların doğrudan temin sürecinde uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.5.1.1. maddesinde "Bu bentte (22/d) belirlenen parasal

limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir." şeklindeki düzenleme uyarınca, gerek görülmesi durumunda yapılan yaklaşık maliyet araştırma sonucuna göre ya da yapılacak piyasa fiyat araştırması sonucunda limit aşılırsa alımın doğrudan teminle yapılmaması ve diğer ihale usulleri kapsamında ihtiyacın karşılanması gerekmektedir.

Bu itibarla, idarelerce, Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında gerçekleştirilen alımlarda söz konusu parasal limitin göz önünde bulundurulması koşuluyla, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. maddesinin; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenlemesi çerçevesinde hareket edilmesi uygun olacaktır. Ancak sözleşme düzenlenmesini gerektiren istisnai durumların da bulunduğunun unutulmaması gerekir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanması bağlamında, anılan Kanun'un 8'inci maddesi ile belirlenen mezkûr değerler, ihale ilan süreleri ve kuralları gibi hususlarda yaklaşık maliyet esas alınarak kullanılan parasal limitleri temsil etmektedir.

Eşik değer dışında kalan ve Kanun'da yer alan diğer parasal limitler ise, ihalenin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için göz önünde bulundurulması gereken tutarları ifade etmektedir. Bu parasal limitler, belirli unsurlar esas alınarak hesaplanan bir değer olmayıp, uluslararası düzenlemeler çerçevesinde esasları Kanun'la belirlenen bir niteliğe sahiptir.

4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendine göre parasal sınırlar kapsamında harcama yapılması mümkündür. Diğer bentler için parasal sınır yoktur. Hatta 22/d kapsamı temsil ve ağırlama giderleri için parasal sınır geçerli değildir.

4734 sayılı Kanun'da geçen limitlere KDV dâhil değildir. Gerek piyasa fiyat araştırma sürecinde ve gerekse alım sürecinin sonunda ödeme sürecinde bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

Aynı şekilde, doğrudan kapsamı alımlar ile ilgili olarak EKAP üzerinden girilen (bildirimlerin) bilgilerin de KDV'siz olarak girilmesi gerekir.

İdareler tarafından zaman zaman yapılan yanlışlardan birisi de katma değer vergisi (KDV) hariç olarak belirlenmesi gereken yaklaşık maliyetin KDV dahil olarak belirlenmesidir. Böyle bir hareket tarzı ise, 4734 sayılı Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliklerindeki hükümlere aykırılık taşımaktadır.

Ayrıca, böyle bir davranış, Kanun'un "*mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet* belirlenir…" şeklindeki hükmü (9.md.) ile de çelişmektedir.

Dolayısıyla, ihale yetkilisine onaylanmak üzere sunulacak ihale onay belgesindeki ilgili bölüme KDV hariç olarak belirlenmiş yaklaşık maliyet tutarının yazılması ve yanında ("KDV Hariç") ibaresinin belirtilmesinin hatalı değerlendirmeleri engelleyeceği açıktır.

Bir alım kapsamında, idare yaklaşık maliyet hesaplanmasına karar verdiği zaman, idare yaklaşık maliyetin hesaplanmasında; alım konusu malın niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç fiyat bildirilmesini ister.

Ayrıca, tek kaynaktan temin edilecek alımlarda kullanılacak standart formlarda (KİK021.0/H ve KİK022.0/M) yaklaşık bedel hazırlanmasına ilişkin açıklamalar yer aldığından dolayı, 22'nci maddenin a, b ve c bentlerine göre yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet hazırlanması zorunlu, diğer bentleri için ise zorunlu olmadığını ifade edebiliriz.

Aynı şekilde, doğrudan temin ile yapılan mal ve hizmet alımında da oluşturulan yaklaşık maliyete KDV dahil değildir.

Kamu alım süreçlerinde kamu kaynağı kullanılmaktadır. Bu alımlar için bütçeye ödenek konulmaktadır. Ödenek, harcama yapılabilmesi ve yüklenime girilebilmesi için yetki anlamına gelir. Yetkisiz harcama/ihale yapılamaz. Nitekim 5018 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi hükmü de bu doğrultudadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı belirtilmektedir.

Gerek ihale kapsamı ve gerekse doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar ve hakediş ödeme sürecinde; hesaplama ve ödemelerin KDV dâhil yapılacağı dikkate alınarak ödeneklerin KDV dâhil temin edilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, ihaleye çıkılmadan önce ödeneğin temini sağlanmalıdır. Yeterli ödenek bulunmaması durumunda, bütçe içi aktarma, yedek ödenekten aktarma ve ek ödenek suretiyle ödenek temini yollarına gidilmesi gerekmektedir.

Mal alımlarına benzer şekilde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 7'nci maddesine göre de; "İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir." hükmüne göre KDV hariç olarak alım sürecinin başlatılması gerekmektedir.

Bu itibarla, Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan temel ilkelerden olan "Ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz" hükmü çerçevesinde, alım sürecinde yeterli ödeneğin bulunması ve KDV'nin de ayrıca yükleniciye ödeneceği dikkate alınarak, ödenek hesaplamasında bu hususunda göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır.

68. İhalelerden katılmaktan yasaklananlar doğrudan temine teklif verebilir mi?

Özet: *4734 ve 4735 sayılı Yasalar uyarınca, ihalelerden yasaklama kararı ancak ihale kapsamı alımlar için uygulanabilmektedir. Dolayısıyla bir ihale türü olmayan doğrudan temin yöntemi alımlar için ihalelerden yasaklama kararı verilmesi mümkün değildir. "Doğrudan temin" kapsamında "Yasaklama kararı" verilmesinin, anılan alım türünün bir ihale usulü olmaması nedeniyle mümkün olmamakla birlikte, belirlenen fiile ilişkin olarak ceza takibatı gerektiren bir durumun varlığında, Ceza Kanunları kapsamında takibat yapılmasına engelleyen herhangi bir düzenleme de yoktur. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla bir alım yapılması halinde, alım yapılacak kişinin/firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak anılan Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir. Buna karşın, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin, yetkili satıcı ya da üretici firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.*

4734 sayılı Yasa maddeleri arasında yer verilmiş olsa da doğrudan teminin aslında bir ihale türü değildir. Kanun'un 22'nci maddesinde yer verildiği üzere, bu kapsamda yapılan alımlara; ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesinin zorunluluk arz ettiği alımlar başta olmak üzere, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması, idarenin taşınmaz mal kiralaması gibi normal ihale usulleri ile karşılanması mümkün olmayan alımlar örnek verilebilir. Zira herhangi bir idarenin kiralamak istediği bir binaya ilişkin olarak açık ihale usulü de yapılmış olsa, kiralanmak istenilen taşınmazın tek olduğu (ve tek sahibi bulunduğu) gerçeği dikkate alındığında, diğer isteklilerin katılımı sağlansa bile sonucun değişmeyeceği açıktır.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya

kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Bununla birlikte, bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise, madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

İdarelerin doğrudan temin kapsamındaki en çok kullandığı alım türü ise, Kanun'un 22/d maddesi kapsamında yer verilen ve her yıl Kamu İhale Tebliğince güncellenen "parasal tutarlar kapsamında aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar" oluşturmaktadır. Bu bentte belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

4734 ve 4735 sayılı Yasa'lar kapsamında, ihalelerden yasaklama kararının verilebilmesi için, anılan kanunlarda yer verilen fiil ya da fiillerin gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizebiliriz. Bu çerçevede, yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bunların ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, istisna kapsamında yapılan alımlara ilişkin bir yasaklamanın söz konusu olması halinde de yine 4734 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca yasaklamalar 4734 sayılı Kanun'da belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

Yasaklamaya ilişkin kararlarının, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden, ihaleyi yapan idare dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, ihale üzerinde kalan yüklenicinin yasaklı olup olmadığını KİK tarafından tutulan sicilden teyit ettiklerinden, henüz yürürlüğe girmemiş yasaklama kararlarının, diğer idareleri bağlaması mümkün değildir.

Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlara ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliği'nde (Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı" başlıklı 28.1.10 maddesinde); doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanun'un 58'inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesinin mümkün olmadığı açıklamasına yer verildiği görülmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Teyit işlemleri" başlıklı 30.5.4 maddesinde "*4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir."* hususu yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kamu İhale Kanunu kapsamında verilen "Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama" yaptırımının Türk Ceza Kanunu anlamında bir ceza niteliğinde olmamakla birlikte, idari ceza niteliğine sahip olduğu açıktır.

Bu çerçevede; Kanun'un "Kamu İhale Kurumu" başlıklı 53'üncü maddesinin (b) bendinde ise Kurumun görevleri sayılmakta olup, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak da bu kapsamda sayılmıştır.

Kamu İhale Kurumunun görevlerinin düzenlendiği 4734 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesine göre, KİK'in, anılan Kanun'a göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Aynı Kanun'un "İhalelere Yönelik Başvurular" başlıklı 54'üncü maddesinin 10'uncu fıkrasında ise"…şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir." hükmü bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanun uyarınca, idarelerce ve yargı organlarınca verilen İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararları, Kamu İhale Kurumunca izlenerek kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin sicile işlenmektedir. Kamu İhale Kurumunun, yasaklama kararlarının

verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin bir yetkisi bulunmamasının yanında, şikâyete konu alımların Kanun'a göre ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin satın alma yöntemi ile gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu alımlar ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin 10'uncu fıkrasının (c) bendi gereğince bu yöndeki başvuruların görev yönünden reddi gerekmektedir.

Bu bağlamda, çeşitli Kurul Kararlarında da yer verildiği üzere, sözleşmenin uygulanması aşamasındaki suç teşkil eden fiil ve davranışına ilişkin olarak hakkında Adli Makamlarca kamu davası açılmasına karar verilenlerin, doğrudan temin kapsamında yapılan bir alıma ilişkin olarak teklif vermesi durumunda, teklifinin değerlendirme bırakılması mevzuata aykırılık teşkil ettiği gibi, aynı esaslar çerçevesinde, doğrudan temin kapsamında alıma ilişkin olarak tespit edilen yasak bir fiile ilişkin olarak haklarında kamu davası açılmış olan isteklilerin, normal ihale usullerinden biri ile gerçekleştirilen alıma ilişkin olarak teklif vermesi durumunda, bu nitelikte bir teklifin değerlendirme dışa bırakılması ve isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemi de aynı şekilde mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Görüldüğü üzere; 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla bir alım yapılması halinde, alım yapılacak kişinin/firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak anılan Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.

Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumunun görev alanı ihalenin başlangıcından itibaren sonuçlandırılması aşamasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetlerin incelenmesi ile sınırlı olması nedeniyle; ihale süreci içerisinde idarece tesis edilen bir işlem niteliğinde olmayan ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınması işleminin, mevzuata aykırılığına yönelik iddianın Kamu İhale Kurumu tarafından incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde Kanun

kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, "Doğrudan temin" başlıklı Kanun'un 22'nci maddesi incelendiğinde; doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir. Bu nedenle, "Doğrudan teminin" Kanun kapsamında yer verilen bir ihale türü olmaması nedeniyle, bu alım türüne ilişkin yasaklama kararı verilmesi mümkün değildir.

Kaldı ki doğrudan teminle yapılan ihaleler sonucunda düzenlenecek sözleşmelerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmaması, ayrıca 4735 sayılı Kanun'a tabi olsa bile, anılan Kanun'un 27'nci maddesinde hakkında kamu davası açılanların dava sonuçlanıncaya kadar kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacağına dair bir hükme yer verilmemiş olması sebebiyle, doğrudan teminle yapılan bir alıma ilişkin olarak hakkında kamu davası açılan kişi ve bu kişi sebebiyle de ortağı olduğu şirketi hakkında, 4735 sayılı Kanun'a göre de kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama yaptırımının uygulanamayacağı düşünülmektedir.

Bu itibarla, doğrudan temin yöntemine ilişkin olarak Kanun kapsamında "Yasaklama kararı" verilmesinin, anılan alım türünün bir ihale usulü olmaması nedeniyle mümkün olmamakla birlikte, belirlenen fiile ilişkin olarak ceza takibatı gerektiren bir durumun varlığında, Ceza Kanunları kapsamında takibat yapılmasına engelleyen herhangi bir düzenleme de yoktur.

Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği'nin doğrudan temin yönteminde yasaklama kararı başlıklı maddesinde;"… doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez." hususu yer almaktadır. Söz konusu hüküm, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da anılan Yasalarda öngörülen usulsüzlüklerden birinin gerçekleştirilmesi durumunun ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini ifade etmektedir.

Buna karşın, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin, yetkili satıcı ya da üretici firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.

Bunlara ilave olarak, doğrudan temin bir ihale usulü olmadığı için söz konusu alımlarda 4734 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan ihaleye katılmayacak olanlara ilişkin hükmün uygulanmayacağını ilave olarak belirtebiliriz.

69. Doğrudan temin kapsamında taşıt kiralanması mümkün müdür?

Özet: *Doğrudan temin kapsamında da taşıt kiralama işleminin Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller'deki düzenlemeler çerçevesinde mümkün olduğunu, çünkü buna ilişkin mevzuatta bahse konu hizmet alımının ihale türlerinden biriyle alınmasına yönelik açık bir hükmün bulunmadığını, ayrıca, taşıt alımına ilişkin esas ve usullere uygun hareket edilmesi durumunda ancak kiralama işleminin yapılabileceğini, buna aykırılığın ise kamu zararını gündeme getirdiğini ifade edebiliriz. Bu itibarla, 4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesinde geçen parasal limitler dahilinde olması koşuluyla, taşıt kiralama işleminin doğrudan temin yöntemiyle karşılanmasının mümkün olduğunu, bu tutarın aşılması durumunda ise ihtiyacın ihale usullerinden biriyle karşılanması gerektiğini ifade edebiliriz.*

İdarelerin kamu hizmetini gerçekleştirmek için çeşitli mal veya hizmet alımına ya da yapım işine ihtiyacı olabilir. Bu kapsamda, idareler tarafından ihtiyaca binaen araç kiralaması da söz konusu olabilir. Bu kiralama işlemlerine ilişkin süreçler her ne kadar ihale mevzuatı hükümlerine göre yürütülmekle birlikte diğer mevzuat hükümlerinin de süreçte dikkate alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda, Taşıt Kanunu ve Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller'in alım sürecinde dikkate alınması gerekir. Ancak "Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği" uyarınca yapılan servis kiralamaları bahse konu esas ve usullere tabi değildir. Ayrıca, bahse konu Esas ve Usullerde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre kurumlar tarafından belirlenebilecektir.

Söz konusu esas ve usullerle belirlenen kriterler çerçevesinde alım işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla gerek ihale kapsamı ve gerekse doğrudan temin suretiyle olsa bahse konu dokümanlara aykırılık taşıyorsa bu işlemi yapanların hukuki sorumluluğu söz konusu olabilecektir.

Bu çerçevede, konumuzla bağlantısı dikkate alınarak kamu idarelerinin hangi koşullarda hizmet alımı suretiyle bu ihtiyacının karşılanabileceği ortaya konulduktan sonra, doğrudan temin yöntemiyle taşıt kiralama işleminin yapılıp yapılmayacağı da ayrıca açıklığa kavuşturulacaktır.

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin son fıkrasında; "Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir." denilmiştir.

Merkezi İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne göre piyasa fiyat araştırması tutanağı; doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı ifade ettiği görülmektedir.

Dolayısıyla, doğrudan temin suretiyle gerçekleştirilen alımlardaki süreç; ihtiyacın tespit edilerek ihale yetkilisince alıma karar verilmesi, bu ihtiyaç için fiyat araştırması yapmak üzere bir veya birden fazla kişinin ihale yetkilisi tarafından görevlendirilmesi, bu kişi veya kişilerin piyasadan alınan mevcut teklifleri gösteren ve bu teklifler arasından en uygun fiyatlı teklifi belirlemek ve sonrasında ise muayene kabul süreci ve son olarak ödeme süreci ile işlemeler sonuçlandırılmaktadır.

Tutanakta tespit edilen fiyatın, mevzuatın öngördüğü azami fiyatın üzerinde olması halinde yani ihale usulleri kapsamında karşılanması öngörülen bir tutara sahipse, bu durumda doğrudan temin yöntemine başvurulmaması gerekmektedir. Aksi yöndeki hareket tarzı Kanun'un temel ilkelerine aykırılık anlamı taşımaktadır.

Doğrudan temin kapsamında da araç kiralama alımı söz konusu olabilir. Keza 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 12'nci maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller (Esas ve Usuller) yürürlüğe konulmuş ve sonrasında ise bazı değişiklikler söz konusu olmuştur.

Bu bağlamda, araç kiralama ihaleleri yakıt hariç yapılacaktır. Yakıt dâhil olarak yapılan araç kiralama ihalelerinin ise iptali gerekmektedir. Bu süreçte yabancı menşeli taşıt ifadesi ise, yerli muhteva oranı %50'nin altında kalan taşıtları ifade etmektedir.

Araç kiralama ihaleleri şoförlü veya şoförsüz olarak yapılabilecektir. Ancak şoförlü araç kiralama ihalelerinde şoförlere verilecek ücretlere sınırlama getirilmiştir. Şoförlere en fazla brüt

asgari ücretin %50 fazlası ödenebilecektir. Bu durum binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi araçlar için geçerli olup, bu tip araçları kullanmayan şoförler bu kapsamda ele alınmayacaktır.

Dolayısıyla, sayılan tipte araçları kullanmayan şoförlere, asgari ücretin %50 fazlasından daha fazla ödeme yapılabilecektir.

Araç kiralama ihalelerinde yaklaşık maliyet tespitine yönelik olarak piyasa araştırması yapılabileceği gibi, kasko sigorta değerleri de yaklaşık maliyette kullanılabilecektir.

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller'e göre; genel yönetim kapsamındaki idareler ile bağlı döner sermayeler tarafından kiralanan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi araçlar için en fazla kasko sigorta değerinin %2'si ödenebilecektir.

Söz konusu Usul ve Esasların "Genel esaslar" başlıklı 6'ncı maddesine baktığımız zaman söz konusu maddede;

" - (1) Temel amaç çerçevesinde hizmet alımı suretiyle taşıt edinilebilmesinin genel esasları şunlardır:

a) Hizmet alımının yapıldığı yılın başında, binek ve station-wagon cinsi taşıtlar 10 yaşım, diğer taşıtlar ise 15 yaşını doldurmamış olacaktır.

b) Hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilmesini Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı olacaktır.

c) Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında kullanılacak binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 cc'yi geçmeyecektir.

ç) Taşıtlar, yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebilecektir.

d) Taşıtların, her türlü vergi, sigorta ve bakım-onarım gibi giderleri yükleniciye ait olacaktır.

e) Yüklenicilerce çalıştırılan şoförlerin, sözleşmeye aykırı her türlü davranışlarından, bunların taşıtlara, kurum mensuplarına ve üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan dolayı yükleniciler sorumlu olacaktır.

f) Hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtların (Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç) ön camına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla "Resmi hizmete mahsustur" ibaresi yazılı bir levha görünür bir şekilde konulacaktır.

g) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinin gerektirdiği giderler kurum bütçesinde öngörülen ödenekler çerçevesinde karşılanacaktır.

ğ) Kurumlar ve yükleniciler karayolları trafik mevzuatı hükümlerine uyacaklardır.

h) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinimi kurumların tabi oldukları ihale mevzuatına göre gerçekleştirilecektir.

ı) Kurumlar, sosyal tesis kaynaklarından karşılanmak şartıyla sosyal tesis hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle taşıt edinebileceklerdir.

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı azami satın alma bedellerini gösterir (T) işaretli cetvelde belirtilen taşıtlardan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up'lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ay itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır.

b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.

c) Şoför gideri dahil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak; işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir…"

Hususları yer almaktadır.

Diğer taraftan, "Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği" uyarınca

yapılan servis kiralamaları bahse konu Esas ve Usullere tabi değildir. Ayrıca, bu Esas ve Usullerde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre kurumlar tarafından belirlenebilecektir.

Bu kapsamda, birim fiyat teklif cetvellerinde teklif edilen birim fiyatın üst limitinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sinin ve ihale tarihi itibariyle yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarını geçmemek üzere idari şartnamede belirtilen tutarların toplamı olarak dikkate alınması gerekir.

Teklif tutarı, harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sinin ve brüt asgari ücretin %50 tutarının toplamını aşmadığı durumda teklifler, bu çerçevede değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.

Fiilen arazi üzerinde çalışmak şartıyla arazi binek ve pick-up'lar, %2 kasko sigorta değerini aşabilmektedir. Yani pick-up fiilen arazi üzerinde çalışacak ise %2 kasko sigortası değerine ilişkin sınır burada uygulanmayacaktır. Ancak arazide çalışmayacak ise Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır.

Ayrıca, söz konusu Usul ve Esasların 6'ncı maddesine aykırı alım, mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesi gereğince, doğrudan temin usulü ile yapılan taşıt kiralamalarında araç kasko bedeline göre, taşıt kiralanması gerektiği ve kamu zararı oluşması halinde harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ile kamu zararının tamamından 5018 sayılı Kanun'un 71'inci maddesi uyarınca sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Doğrudan temin kapsamı alımlarda mal veya hizmetin teslimi belli bir süreyi gerektirmesi durumunda Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca sözleşme düzenlenmesi gereklilik arz etmektedir. Burada da yani taşıt kiralama alımı da belli bir süreyi gerektirdiğinden sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

Kaldı ki her ne kadar doğrudan temin kapsamı alımlarda, teminat alınması, cezai yaptırımlar öngörülmesi, kabulle ilgili bir kısım yükümlülüklerin söz konusu olduğu durumlarda, yazılı sözleşme düzenlenmesinin yararlı olduğu düşünülmektedir. Bu itibarla, taşıt kiralamanın doğrudan temin yöntemiyle karşılanması durumunda sözleşme düzenlenmesi bir anlamda gereklilik arz etmektedir.

Konuyla bağlantılı bir Sayıştay Kararında ise;

"Sorumlular tarafından her ne kadar söz konusu taşıt kiralamasının, aciliyet nedeniyle … 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği ve bu yöntemin ihale usulü olmaması nedeniyle anılan esas ve usuller kapsamında değerlendirilmediği belirtilmişse de, esas ve usullerin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; taşıt kiralama usulüyle ilgili bir ayrıma gidilmemiş "yapılan taşıt kiralamalarında" ifadesi kullanılarak tüm kiralamalar kapsama dahil edilmiş olup yine esas ve usullerin başka bir maddesinde de istisnai bir hükme yer verilmemiştir." hususuna yer verilerek, doğrudan temin kapsamı alım ile diğer alım türleri açısından mevzuata aykırılık açısından bir fark olmadığı belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanun'un "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan; "Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır." hükmü uyarınca, genel olarak kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, harcama sürecinde buna dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.

70. Avans kullanmak suretiyle doğrudan temin kapsamında alım yapılabilir mi?

Özet: *5018 sayılı Yasa'nın 35'inci maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Bütçe Kanunu, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:55), Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:67) ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde yer verilen düzenlemeler dikkate alınarak ön ödeme ve avans işlemlerinin yürütülmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kanun'da ön ödeme alım türleri arasında sayılmadığı gibi, Kanun'un istisnalara ilişkin 3'ncü maddesinde de yer verilmediğini, bu nedenle ön ödeme yöntemiyle Bütçe Kanunu ile belirlenen limitler içerisinde doğrudan temin kapsamında idare ihtiyacının karşılanabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, bu hususa ilişkin mevzuatta alım türü itibarıyla bir ayrım yapılmadığını, dolayısıyla alıma ilişkin olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde de ön görülen belgelerin ödeme belgesine süresi içerisinde bağlanması (eklenmesi) gerektiğini ifade edebiliriz.*

Ön ödeme, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde yapılan geçici bir ödeme olup, ön ödemeye ilişkin yasal düzenleme 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer almaktadır.

Söz konusu Kanun'un "Ön ödeme" başlıklı 35'inci maddesi;

" Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Cumhurbaşkanı, diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur.

Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş

ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yıl sonunda yüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir.
Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır…"

Hükmüne amirdir.

Ön ödeme konusunda harcama yetkilisi söz sahip olup, bu bağlamda, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğinin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilmektedir.

Bu kapsamda verilecek avansın üst sınırları ise, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda gösterilmektedir. Verilecek avansın üst sınırı her yıl olduğu gibi 2022 yılı için de Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli "İ" cetveli ile belirlenmektedir. Bu yıl için söz konusu tutar "yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için" *İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde 2100 TL* olarak belirlenmişken, *diğer ilçeler için* bu tutar 1095.- TL olarak öngörülmüştür.

Avans şeklinde yapılacak ön ödemeler kapsamdaki kamu idarelerinde harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırları, gider türleri ve idareler itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ'de gösterilmiştir. Ayrıca, avans nakit olarak doğrudan harcama yetkilisi mutemedine verilebileceği gibi mutemedin banka hesabına da aktarılabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 5018 sayılı Kanun'a ilişkin Parasal Sınırlara ve Oranlara ait Tebliği uyarınca "avans limitlerine" ait Tablo (Sıra No:67)

A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI	**(TL)**
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:	
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi	2.100

sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde	
1.2. Diğer ilçelerde	1.095
2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevkinde kullanılmak üzere	24.200
3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara	14.035
4. Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere	40.665
5. Mahkeme harç ve giderleri	
5.1.İstanbul il merkezi için	153.000
5.2. Ankara ve İzmir il merkezleri için	100.000
5.3. Diğer il ve ilçeler için	38.000
6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere	111.165
7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere	10.940
8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere	44.530
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı	805.990
10. Yargılama Giderleri	22.930
11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)	5.085
12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için	
12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde	11.050
12.2. Diğer il ve ilçelerde	6.630
B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI	
1. Yükseköğretim Kurumları için:	
1.1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için	10.940
1.2. Diğer birimleri için	2.100
1.3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (yurt dışındaki harcamalarda kullanılmak üzere)	50.000
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine	6.100
3. Türk Patent ve Marka Kurumu mutemetlerine	24.300

4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine ……..	67.400

Şeklinde belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun hükümleri gereğince idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütülmesi gerekmektedir.

2003 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda uluslararası ihale uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin olmak üzere dört ihale usulü belirlenmiş, ancak sonrasında 4734 sayılı Kanun'da değişiklik yapan ile doğrudan temin ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu çerçevede, doğrudan temin yöntemi sadece Kanun'da belirtilen hallerde kullanılabilecek olup, bu usule ilişkin esaslar anılan Kanun'un 22'nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, Kanun'un 3'üncü maddesinde ise istisna kapsamına giren alımlar belirlenmiştir. Yasa'da bunların dışında bir alım yöntemi belirlenmemiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4'üncü maddesinde Doğrudan temin; "Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" şeklinde tanımlanmış olup, yine aynı Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinde, belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceği, bu usule göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilebileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler ve açıklamalar çerçevesinde, avans kapsamında yapılan alım doğrudan temin sınırı içerisinde ise, doğrudan temin yöntemine göre, bu rakamı aşıyorsa ihale usulü ile kapsamında ihtiyacın karşılanmasını gerektiğini ifade edebiliriz. Kanun'da ve diğer düzenlemelerde bunu engelleyen bir husus bulunmamaktadır.

Diğer bir anlatımla, doğrudan temin kapsamı alımlarda da (22/d) belirlenen bu rakamsal sınırlar

esas alınmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda, Büyükşehir sınırları dahilinde geçerli olan parasal limit 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 31.01.2023 tarihine kadar 218.395 TL (diğerleri için 72.752) olarak belirlenmiş olup, bu tutarın üzerindeki ihtiyaçların bahse konu madde kapsamda karşılanması mümkün değildir. Gerek görülmesi durumunda yapılan yaklaşık maliyet araştırma sonucuna göre ya da yapılacak piyasa fiyat araştırması sonucunda bahse konu limitler aşılırsa alımın doğrudan teminle yapılmaması ve diğer ihale usullerine başvurulması gerekmektedir. Bu nedenle, avans kapsamında yapılan alım bahse konu tutarların altında olduğu sürece doğrudan temin yöntemine göre alım yapılması gerekir.

Bu nedenle, ön ödemenin aslında bir alım şekli olmadığını, bu yöntem ile sadece, malın teslim alınıp gerçekleştirme belgelerinin tamamlanmasından sonra yapılacak ödemeler öne çekilmekte ve bu belgeler düzenlenmeden ödeme yapılmasına imkân tanınmaktadır.

Bu hususta Ön Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin 55 Sıra No.lu Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde de açıklamalar yapılmıştır. Tebliğin "Ön Ödemenin Niteliği" başlıklı maddesinde; *"...Ön ödeme uygulamasının bir alım usulü olmaması sebebiyle ön ödeme yapılacak mal veya hizmet alımlarında, alımların idarelerin tabi oldukları ihale mevzuatı hükümlerine göre yapılması, mal alındığının veya hizmetin gerçekleştirildiğinin ihale mevzuatına uygun olarak görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması gerekir."* açıklaması yer almaktadır.

Ön ödeme sadece, gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesinden sonra yapılacak ödemeleri öne çekmekte ve bu belgeler düzenlenmeden ödeme yapılmasına imkân tanımaktadır. Dolayısıyla, bu alım yöntemi ihale türlerinden biri değildir. Kaldı ki böyle bir durumdan bahsedebilmek için 4734 sayılı Kanun'da bu hususa yer verilmesi gerekirdi.

Nitekim bu durum, Ön Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde de belirtilmiştir. Tebliğin "Ön Ödemenin Niteliği" başlıklı 3'üncü maddesi uyarınca, ön ödeme alınmak suretiyle yapılacak alımlarda da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne uyulması gerektiği ifade edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 35'inci maddesine dayanılarak Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Yönetmelikte yer aldığı üzere,

"Ön ödeme"; İlgili mevzuatında öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde yapılan ödemeyi kapsamaktadır.

"Mutemet" ise Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan harcama yetkilisi mutemedini ifade ettiği görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde; idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilerek yasada alım türleri sayılmış, istisna edilen işlere ise Kanun'un 3'üncü maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu maddeye göre ön ödeme suretiyle gerçekleştirilen alımlar Kanun'dan istisna değildir. Yani, ön ödeme suretiyle gerçekleştirilen alımların da Kanun'da öngörülen ihale usulleriyle veya doğrudan teminle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, ön ödemede, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; ilgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabileceğini, avansın, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan mutemede verileceğini dile getirebiliriz.

Avans verilmek suretiyle yapılacak ön ödemelerde ise, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen tutara kadar olan yapım işleri, mal ve hizmet alımları, yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanmasına ilişkin giderler ile benzeri giderler için avans verilebilir.

Diğer taraftan, ilgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı tutarda teminat alınmak koşuluyla yüklenicilere; mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının yüzde 10'una, yapım işlerinde ise yüklenme tutarının yüzde 15'ine kadar bütçe dışı avans verilmesi de mümkündür.

Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde muhasebe

yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdür.

Bu hususta Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) de bulunmaktadır.

Ön ödeme, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde yapılan geçici bir ödeme olup, ön ödemenin bir alım usulü olmaması sebebiyle ön ödeme yapılacak mal veya hizmet alımlarında, alımların idarelerin tabi oldukları ihale mevzuatı hükümlerine göre yapılması, mal alındığının veya hizmetin gerçekleştirildiğinin ihale mevzuatına uygun olarak görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması gerekir.

Ayrıca, ön ödemenin kesin ödemeye dönüştürülmesinde verilen avansın veya açılan kredinin mahsubunda kullanılacak gerçekleştirme belgelerinin, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde öngörülen belgeler olması esastır. Yani zorunluluktur.

Diğer yandan, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi olarak ön ödeme yapılabilmesi için, harcama yetkililerinin harcama yetkilisi mutemedi görevlendirmeleri gerekir. Her harcama birimi için bir mutemet görevlendirilmesi asıldır.

Harcama yetkilisi tarafından kredi şeklinde ön ödeme yapılması uygun görülen giderler ile avans sınırlarını aşan giderler için kredi açılabilir. Kredi mutemede nakden verilmez veya şahsi hesabına aktarılmaz.

Sözleşmelerinde belirtilmek ve karşılığında aynı tutarda teminat alınmak koşuluyla yüklenicilere; mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının yüzde 10'una, yapım işlerinde ise yüklenme tutarının yüzde 15'ine kadar bütçe dışı avans verilebilecektir.

Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yüklenicilere bütçe dışı avans ödemesi yapılabilmesi için bu hususun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince idari şartnamede belirtilmesi zorunludur.

5018 sayılı Kanun'un 35'inci maddesi ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince harcama yetkilisi mutemetleri; kendilerine verilen avanslara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri bir ay içerisinde ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe yetkilisine

vermekle yükümlüdür. Mahsup süresi, avansın verildiği güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde, sürenin bittiği ayda avansın verildiği güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer.

Ayrıca, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde de ön ödeme suretiyle yapılacak alımlarda sadece faturayla mahsup yapılabileceğine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, ön ödeme ile doğrudan temin yöntemine göre yapılan alımlarında, mahsup evrakları arasında, piyasa fiyat araştırması tutanağı, muayene ve kabul komisyonu tutanağı veya bu belge yerine geçen bir belgenin sunulması gerekmektedir.

Zira söz konusu kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak işlemlerin yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya kişilerce düzenlenip onaylanan belgelerdir.

Nitekim Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler" başlıklı 5'inci maddesinde;

"Ödeme belgesi iki nüsha olarak Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Kanıtlayıcı belgeler ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır, ödeme belgesinin ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır.
Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. Kesin veya ön ödeme şeklinde yapılacak kamu harcamalarında ödeme belgesi olarak bağlanacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Kesin ödemelerde;
Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek numaralı Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.
b) Ön ödemelerde;
1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;
-Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,
-Gereken hallerde kredi izin yazısı;
2)Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda;
-Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,

-Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği,
-Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı,
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem Fişine kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.
Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının bağlanması esastır. Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri bağlanmak suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir.
Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz ...”

Hususları yer almaktadır.

Konuyla bağlantılı mevzuat düzenlemeleri ışığında, ön ödeme uygulamasının bir alım usulü olmaması sebebiyle ön ödeme yapılacak mal veya hizmet alımlarında, alımların idarelerin tabi oldukları ihale mevzuatı hükümlerine göre yapılması, mal alındığının veya hizmetin gerçekleştirildiğinin ihale mevzuatına uygun olarak görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması gerekliliğine uyulması gerektiğini ifade edebiliriz.

Nitekim 4734 sayılı Kanun hükümleri arasında da ön ödeme alım türleri arasında sayılmadığı gibi, Kanun’un istisnalara ilişkin 3’ncü maddesinde de yer almamaktadır.

Bu itibarla, ön ödeme yöntemiyle Bütçe Kanunu ile belirlenen limitler içerisinde doğrudan temin kapsamında idare ihtiyacının karşılanmasının mümkün olduğunu, buna ilişkin mevzuatta alım türü (ihale türü/doğrudan temin) itibarıyla bir ayrım yapılmadığını, ancak alımın gerçekleşmesi ile birlikte Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde ön görülen belgelerin ödeme belgesine bağlanması gerektiğini ifade edebiliriz.

71. Farklı kamu idareleri adına tek idare veya aynı kurumun harcama birimleri adına tek birim ortak alım yapabilir mi?

Özet: *4734 sayılı Yasa (Ek madde 7) ve buna dayanılarak hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği (97/A) uyarınca, birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale mevzuatında öngörülen düzenlemeler çerçevesinde ihtiyacın karşılanması mümkündür. Bu kapsamındaki ihale işlemlerinde görev alanlar, yürüttükleri işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla işlemlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur. Farklı idareler adına tek bir idarenin yaptığı bu ortak alımların dışında, ayrıca, 5018 sayılı Yasa'nın 60'ıncı maddesi çerçevesinde, tüm harcama birimlerinin ortak sayılabilecek ihtiyaçlarının destek birimi tarafından yerine getirilmesi mümkündür. Buna göre, ayrı ayrı her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla, harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin idarelerin destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamdaki ihtiyaçların doğrudan temin yöntemiyle de karşılanması mümkündür. Bununla birlikte, birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarının ise, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün bulunmaktadır.*

4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca anılan Kanun'un 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların genel alım yöntemi olan açık ihale usulü ile veya Kanun'daki şartların bulunması halinde belli istekliler arasında ihale usulü ya da pazarlık usulü ile ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir.

Doğrudan temin yöntemi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir.

Kamu idarelerinin alım sürecinde dikkate alması gereken temel kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu olup, anılan Kanun'a göre ihtiyaçlar istisna maddesi hariç olmak üzere, ya ihale usulleri ile ya da doğrudan temin yöntemiyle karşılanması gerekmektedir.

Yine aynı Kanun'a göre temel ilkeler belirlenmiş olup, söz konusu temel ilkelere göre, idarelerin bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na, birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin, 4734 sayılı Kanun'da yer alan ihale usulleri uygulanarak tek bir ihale ile yapılabilmesine imkân tanıyan (Ek) 7'nci madde eklenmiştir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Kamu İhale Genel Tebliği'nin 97/A maddesinde düzenlenmiştir.

Öncelikle 4734 sayılı Kanun'un Ek 7'nci maddesine bakacak olursak, "**Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması**" başlıklı söz konusu madde;

"Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin, bu Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanarak tek bir ihale yapılabilir.
Birinci fıkra kapsamındaki işler için idareler, düzenlenecek bir protokol ile kendi aralarından bir idareyi, kesin teminatın alınması ve sözleşmenin imzalanması hariç olmak üzere diğer ihale işlemlerini bu idareler adına gerçekleştirmek üzere görevlendirir.
Protokole taraf olan her bir idare ile ihalenin üzerine bırakılmasına karar verilen istekli/istekliler arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır.
Protokole taraf diğer idarelerin ihalelerinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihaleye iştirak ettirilmeyecek olanlar, görevlendirilen idarenin yapacağı ihaleye de katılamaz.
Bu madde kapsamındaki ihale işlemlerinde görev alanlar, yürüttükleri işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla işlemlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."

Hükmüne amirdir.

Söz konusu Kanun maddesinin gerekçesinde ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılan

bu değişiklikle, idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla alımların toplulaştırılmasına, yapılacak bir protokol ile ortak ihtiyaçların ihale işlemlerini yürütmek üzere tek bir idarenin görevlendirmesine imkân tanıyan bir düzenleme şeklinde gerekçenin açıklandığını görmekteyiz.

Ortak alımlar konusunda Kamu İhale Genel Tebliği'nin ilgili maddesinin ise;

Madde 97/A – Birden Fazla İdarenin Ortak İhtiyaçları İçin İhale Yapılması

*"**97/A.1.** Birden fazla idare ortak ihtiyaçlarını, düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunda yer alan ihale usullerini kullanarak ortak bir ihale ile karşılayabilir. Alımı yapılacak mal veya hizmet ile bakım veya onarım işine ilişkin aynı nitelikteki ortak ihtiyaç farklı teknik özelliklere sahip olabilir.*

***97/A.2.** İdarelerce düzenlenecek protokolde; ortak ihtiyacın niteliği, türü, miktarı, ihale usulü, ihale hazırlık işlemlerinin hangi idare/idarelerce yerine getirileceği ve koordinatör idareye ilişkin bilgiler belirtilir. İdarelerce protokolde bulunması gerekli görülen diğer hususlara ayrıca yer verilebilir. Eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde koordinatör idarenin tabi olduğu tutarlar dikkate alınır.*

***97/A.3.** İhale ilanında/davette ve ihale/ön yeterlik dokümanında ihalenin birden fazla idarenin ortak ihtiyacının karşılanması maksadıyla yapıldığı belirtilir.*

***97/A.4.** 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler göz önünde bulundurulmak kaydıyla idareler tarafından ihalenin kısmi teklife açılıp açılmaması hususu ihale ilanında/davette ve ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.*

***97/A.5.** 4734 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde; kesin teminatın alınması ve sözleşmenin imzalanması işlemleri kapsamında sözleşmeye davet, **(Ek ibare: 13.09.2019-30887 R.G./2. md., yürürlük:23.09.2019)** son başvuru ve/veya ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlara ilişkin belgelerin incelenmesi, KİK sözleşme payının yatırılıp yatırılmadığının kontrolü ve 42 nci madde çerçevesinde yasaklılık teyidi ile sözleşmenin fiilen imzalanması protokole taraf idarelerce, bunların dışında kalan ihale süreci işlemleri ise koordinatör idare tarafından diğer idareler adına yerine getirilir.*

***97/A.6.** Protokole taraf idarelerle istekliler arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmelere ilişkin sonuç bildirimleri sözleşmeleri imzalayan idareler tarafından gerçekleştirilir. Sözleşmelerin yürütülmesi 4735 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeyi*

imzalayan idarelerin sorumluluğundadır. Ortak ihaleye yönelik iş deneyim belgeleri sözleşme imzalayan idareler tarafından düzenlenir.

***97/A.7.** Protokole taraf idarelerin ihalelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar ile anılan Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihaleye iştirak ettirilmeyecek olanlar, protokol çerçevesinde yapılacak ihaleye de katılamaz. Bu çerçevede, ihale komisyon kararı alınmadan önce protokole taraf idareler anılan maddeler kapsamında olanların bulunup bulunmadığını koordinatör idareye bildirir.*

***97/A.8.** Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararını vermeye yetkili idari mercilerin tespitinde, kesin teminatın alınması ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaşıldığı takdirde ilgili protokole taraf idare; diğer ihale süreci işlemlerine yönelik olarak ise koordinatör idare esas alınır.*

***97/A.9.** Bu madde kapsamındaki ihale işlemlerinde görev alanlar, yürüttükleri işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla işlemlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur.*

***97/B.** (Ek madde: 30/09/2020-31260 R.G./24. md.) Fiyat Farkına İlişkin Esasların Uygulanması*

Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uyarınca fiyat farkı hesabında kullanılacak formülde yer alan temel endeksin/fiyatın/sayının tespitinde ihale tarihi olarak aşağıdaki tarihler dikkate alınır:

a) Elektronik eksiltme uygulanan ihalelerde eksiltme tarihi.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilen işlerde, ön yeterliğin tespitinden sonraki teklif tarihi.

c) Pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde, son yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih."

Şeklinde düzenlendiği görülmektedir.

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ortak ihale ile toplu alımdan kaynaklanan birim alım maliyetinin düşmesi suretiyle kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve aynı zamanda ihale süreçlerinin karmaşıklığından kurtararak zaman ve işlem masrafı açısından tasarruf imkânı sağlanmaktadır. Süreçte koordinatör konumunda bulunan idarenin ise, süreçte aktif rol oynadığı görülmektedir.

Bu itibarla, idarelerin ortak alım yapmasına yönelik düzeleme ve uygulamalar iki boyutu bulunmakta olup, ilki yukarıda 4734 sayılı Kanun (Ek 7.md) ve Kamu İhale Genel Tebliği'nde

(97/A) ayrıntılarına yer verilen alımlardır. Burada birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları söz konusu olup, ihale kapsamı bir ihtiyacın koordinatör idare öncülüğünde karşılanması söz konusudur.

Diğeri ise aynı kurum içerinde farklı birimlere ait bazı ihtiyaçların tüm birimler adına tek birimce yapılmasına yönelik alımlardır. Burada 5018 sayılı Yasa'nın hükümleri ve bağlantılı mevzuata ait hükümler ön plana çıkmaktadır. Bu kısma giren ihtiyaçların ise, doğrudan temin yöntemiyle karşılanması mümkündür.

İhale kapsamı alımlara benzer şekilde doğrudan temin yönteminde de aynı nitelikteki ihtiyaçların yine destek birimince karşılanması mümkün olmakla birlikte, burada parasal limitlere dikkate edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Yasa'nın 60'ıncı maddesi;"…Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir…" şeklinde düzenlenmiştir.

5018 sayılı Yasa çerçevesinde harcama yetkilisi olan her bir birimin aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece ihtiyaçlarını karşılaması mümkündür. Ancak bir anlamda kurumun ortak ihtiyaç ve giderleri diyebileceğimiz kırtasiye, demirbaş gibi ihtiyaçların ilgili kurumun destek birimleri (genel müdürlük, başkanlık, müdürlük) tarafından karşılanması mümkündür. Birçok idare tarafından bu uygulama yaygın olarak kullanılmaktadır.

Zira alım miktarı arttıkça ortalama maliyet düşecek bu da kamu kaynaklarının verimli kullanılması anlamına gelmektedir. Bu şekilde, farklı birimler adına tek birimce alım yapılması, 5018 sayılı Yasa'nın amacına uygun bir şekilde kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına bu durum ortam sağlayacaktır.

Bu bağlamda, doğrudan temin kapsamı alımlarda da (22-d) belirlenen bu rakamsal sınırlar esas alınması gerekmekte olup, söz konusu parasal sınır, Büyükşehir sınırları dahilinde 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 31.01.2023 tarihine kadar 218.395 TL (diğerleri için 72.752) olarak

belirlenmiş olup, bu tutarın üzerindeki ihtiyaçların bahse konu madde kapsamda karşılanması mümkün değildir. Gerek görülmesi durumunda yapılan yaklaşık maliyet araştırma sonucuna göre ya da yapılacak piyasa fiyat araştırması sonucunda bahse konu limitler aşılırsa alımın doğrudan teminle yapılmaması ve diğer ihale usullerine başvurulması gerekmektedir.

Ayrıca, 2 Seri No.lu Harcama Yetkililerin Devri Hakkında Genel Tebliğ'de bu hususta açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer verildiği üzere, destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün bulunmaktadır.

İdarelerin ilçe sınırları dahilinde bulunan birimlerinin harcama işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda personelinin bulunmaması nedeniyle harcama yetkililerinin belirlenmesinde ve harcama işlemlerinin yürütülmesinde güçlük bulunması hallerinde, söz konusu birimlerin harcama yetkiliği görevinin kaymakam, il müdürü veya bölge müdürü tarafından da yürütülmesi mümkündür.

5018 sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesinde, harcama birimlerini ilgilendiren harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği, ancak harcama yetkiliği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet birimleri olarak yer alan idari ve mali işler, makine-ikmal, satın alma, yapı işleri, personel gibi birimler destek hizmetleri birimi sayılmaktadır.

Bu şekilde alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin harcama birimi veya destek hizmetleri biriminden hangisi tarafından yürütüleceği hususu da belirtilecektir. Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, bu görevli veya görevliler, destek hizmetleri birimi yöneticisi tarafından kendisi veya yardımcısı veya bunlara hiyerarşik olarak en yakın yönetim kademesinde bulunan kişi veya kişiler arasından belirlenmesi gerekmektedir.

Destek hizmetleri birimleri tarafından diğer harcama birimleri adına harcamaların

gerçekleştirilmesi halinde, harcama talimatı/onay belgesi destek hizmetleri birimine gönderilerek mali işlemlerin destek hizmetleri birimi tarafından yapılması sağlanacaktır. Harcama işlemleri, üst yöneticiden alınan onayda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilen ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emrine bağlanarak imzalanmak üzere ilgili birimin harcama yetkilisine sunulması gerekmektedir.

Gerçekleştirme işlemleri destek hizmetleri birimi tarafından yapılan mali işlemlerde, harcama talimatlarında iş ve işlemlerin destek hizmetleri birimi personeli tarafından yürütüleceğinin belirtilmesi yeterli bulunmaktadır. Ancak ilgili mevzuatında bizzat harcama yetkilisi tarafından belirlenmesi gereken hususlarda ilgili harcama yetkilisinin onayının alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar" başlıklı 63'üncü maddesinde;

" 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde;
- Onay Belgesi,
- Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Fatura,
- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
-Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi, ödeme belgesine bağlanır.

Alımı bir merkezden yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır."

Hususları yer almaktadır.

Görüldüğü üzere; kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla gerek 4734 sayılı Kanun ve gerekse 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, idarelerin ortak alım yapmasının mümkün

olduğunu ifade edebiliriz. Buna ilişkin olarak 4734 sayılı Yasa'da hukuki altyapı sağlanmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği'nde ise buna ilişkin ilave açıklamalar yapıldığını görmekteyiz. Ayrıca, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile ödeme sürecinde gerekli olan evraklar ortaya konulmuştur.

Farklı kurumların ortak ihtiyaçlarının tek bir idare üzerinde yapılması suretiyle, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması da söz konusu olabilmektedir. Bu alım sürecinde parasal sınırlara dikkat edilmesi, doğrudan temin limitlerinin üzerinde ise ihale kapsamında ortak ihtiyacın karşılanması gerekmektedir. Ancak 4734 sayılı Kanun'un Ek-7 maddesinde yer verilen hususlar ihale kapsamı alımlar için düzenlenmiştir. Aynı şekilde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 97/A maddesinde yer verilen hususlar da ihale kapsamı alımlar için geçerlilik arz etmektedir.

Ancak 5018 sayılı Yasa çerçevesinde (4734 sayılı Kanunun Ek-7 maddesinde sayılmayan durum) ortak nitelikteki ihtiyaçların destek hizmetleri birimince karşılanması mümkün olup, bu kapsamda gerekli onay ve izinler alınmak suretiyle, bu kapsamda alımların doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi mümkündür.

Bu nitelikte alımlarda, alımı yapan birimlere ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Kararnameleri'nde (teşkilat düzenlemelerinde) yer verilen görevlerle ilişkili bir alım olmasına dikkat edilmesi uygun olacaktır. Ya da Bakanlıkların üst amiri konumunda olan Bakanlık Makamında bu konuda Onay alınması gerekir. Örneğin, Bilgi İşlem Birimince tüm birimler adına PC alımı yapılarak dağıtımı yapılabilir. Ancak alıma ilişkin olarak ödenek planlamasının önceden yapılması uygun olacaktır.

Şayet bahse konu alım ertesi yıla geçen yüklenme ise, 5018 sayılı Kanun hükümlerinin de ayrıca dikkate alınmasını ve buna uygun ödenek planlaması yapılması gerektiğini ifade edebiliriz.

72. 4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesi kapsamı alımlara ait ödeme süreci ve ödeme sürecinde maddi hatanın varlığında ne yapılır?

Özet: *Doğrudan temin kapsamı alımlar için gerekli olan belgeler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ'de belirlenmiştir. Ayrıca başta SGK, Vergi mevzuatı ve diğer hukuki düzenlemelere göre gerekli olan belgelerin de ödeme sürecinde dikkate alınması gerekmektedir. Muhasebe yetkilisinin, usul ve mevzuatına göre tahakkuk ettirilmiş gideri hak sahibine ödemek ve ödeme yaparken hak sahibinin kimliğini kontrol etmekle görevli olduğu, 5018 sayılı Kanun'un 61'inci maddesinde ve Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 23 ve 29'uncu maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Ödeme sürecinde 5018 sayılı Yasa'nın 61'inci maddesi uyarınca gerekli belgelerin saymanlıklarca (muhasebe müdürlüğü) dikkate alınması, belirtilenler dışında ayrıca belge istenilmeyeceğini ifade edebiliriz. Yani, muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir. 5018 sayılı Kanun'un 61'inci maddesi uyarınca muhasebe yetkilisinin, ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yetkililerin imzasını arama yükümlülüğü de bulunmaktadır. Muhasebe yetkilisi, harcama sürecinde belge kontrolü ve sonrasında ödeme işlemini gerçekleştirmektedir.*

Muayene kabul işleminden sonra ödeme işlemi yerine getirilir. Ödeme işlemi ödeme emri belgesi ile gerçekleştirilir. Ödeme emri belgesine Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirtilen belgelerin eklenmesi gerekir. Alım bedellerinin ödenmesinde, alımın niteliğine bağlı olarak değişkenlik gösterecek belgelerin de ödeme emrine bağlanması gerekir. Ödeme, muhasebe yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalamasının ardından tutarın hak sahibine ödenmesi ile gerçekleştirilmiş olur.

Söz konusu işlemler muhasebe birimince yerine getirilmektedir. Bu bağlamda, muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda düzenlendiğini görmekteyiz.

Zira muhasebe yetkilisinin, usul ve mevzuatına göre tahakkuk ettirilmiş gideri hak sahibine ödemek ve ödeme yaparken hak sahibinin kimliğini kontrol etmekle görevli olduğu, 5018 sayılı Kanun'un 61'inci maddesinde ve Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yer almaktadır. Ayrıca, 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı'nda da muhasebe yetkililerinin sorumluluklarının kapsamına dair tespitlere yer verilmiştir.

Ödeme belgesi, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde tanımlanmış olup, bütçeden yapılacak kesin ödemelerde ödeme emri belgesi kullanılmaktadır. Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. İlk iki nüshası, kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının bağlanması esastır. Ödeme belgeleri harcama yetkilisi tarafından belirlenen gerçekleştirme görevlisi tarafından düzenlenir ve ekine Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenmiş olan kanıtlayıcı belgeler bağlanır. Ayrıca, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ'de yer alan hususlar da dikkate alınır.

Ödemelerde bulunması gereken belgeler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 63'üncü maddesinde belirtilmekle birlikte, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda ödeme emri ekinde yer alması gereken kanıtlayıcı belgeler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin Taahhüt dosyası başlıklı maddesinde; Hakediş raporu başlıklı maddesinde; Çeşitli hizmet alımları başlıklı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar başlıklı 63'üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Bu bağlamda, söz konusu 63'üncü madde uyarınca, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde ilgisine göre;

-Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi,
- Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Sözleşme düzenlenmesi halinde damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği

veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı,
- Fatura,
- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
- Mal ve malzeme alımlarında, Taşınır İşlem Fişi,
- Hizmet alımlarında Hizmet İşleri Hakediş Raporu,
- Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde görüş yazısı,
- (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda "Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form"
- İzne tabi alımlarda ilgili Makamdan alınan izin yazısı ve gerekmesi halinde Yönetmelik ve Tebliğde belirtilen diğer belgeler,

ödeme belgesine eklenir.

Bunlarla birlikte, yukarıdakiler haricinde kamu ihale mevzuatının diğer hükümleri, SGK mevzuatı, mali mevzuat ve diğer mevzuat çerçevesinde ödeme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar da dikkate alınır.

Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanun ve anılan Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik uyarınca hakediş ödemesi gerçekleşmeden yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcunun sorgulanması gerekmekte olup, anılan Yönetmelik uyarınca, bu yönde bir sorgulama yapılabilmesi için alımın bir ihale türü ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından, bu yöntemle yapılan alımlarda hakediş ödeme sürecinde, borcun bulunup bulunmadığı hususunun Sosyal Güvenlik Kurumuna sorulmasına gerek yoktur.

Aynı şekilde, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlar, bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları 5.000.- TL üzeri ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istemek zorundadır. 5000.- TL üzerinde vadesi geçmiş borç bulunması halinde satıcıya ödeme yapılmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken, vergi borcunda SGK borcundan farklı olarak alım türü önemli değildir. Yani doğrudan temin kapsamı alıma ait hakediş ödeme sürecinde de ödeme tutarı bahse konusu tutarı aşıyorsa, vergi borcunun sorulması gerekir.

Bunlarla birlikte, ayrıca, Damga vergisi, KDV (Katma Değer Vergisi) Tevkifatı ve varsa Gelir Vergisi Stopajı gibi mali mevzuatın öngördüğü yükümlülük ve kesintilerin de yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Muhasebat Genel Müdürlüğünce hazırlanan (Ödeme Belgelerinde Vadesi Geçmiş Vergi Borçları İle Yasal Tevkifat Ve Diğer Kesintilerin Mahsubu) Genel Tebliğ (Sıra No: 77) ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ödemelerinde, öncelikle vadesi geçmiş vergi borcu ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, ödeme sürecinde bunun da dikkate alınması gerekir.

5018 sayılı Kanun uyarınca ödeme emri belgesi, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir görevli tarafından düzenlenecektir. Ödeme emri belgesi tek başına mali bir işlem sayılmamakla birlikte taahhüt ve tahakkuk aşamalarından sonra ödeme aşamasına geçilmesine esas teşkil etmektedir. Ödeme emri belgesini düzenleyen görevli, gerçekleştirme belgelerinin ödeme emri belgesine doğru aktarılması yanında, düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan da sorumludur.

Muayene kabul işleminden sonra ödeme işlemi yerine getirilir. Ödeme işlemi ödeme emri belgesi ile gerçekleştirilir. Ödeme emri belgesine Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirtilen belgelerin eklenmesi gerekir. Ödeme, muhasebe yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalamasının ardından tutarın hak sahibine ödenmesi ile gerçekleştirilmiş olur.

Bu çerçevede, 5018 sayılı Yasa'nın 61'inci maddesi uyarınca; Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

Kontrol etmekle yükümlüdür.

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz.

Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Bu nedenle; ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin imzaları olmakla birlikte, ödeme emri belgesi eki belgeler üzerinde herhangi bir imza eksiği varsa muhasebe yetkilisinin, ödeme emri belgesi üzerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması gerekmektedir.

Ancak ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisinden sadece birinin imzası varsa, muhasebe yetkilisinin, imzası bulunan görevliyle birlikte sorumlu olması söz konusudur.

Şayet ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin imzaları yoksa muhasebe yetkilisinin, tek başına sorumlu tutulması gerekmektedir.

5018 sayılı Kanun'un 61'inci maddesi ile Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29'uncu maddesinde, muhasebe yetkilisinin taahhüt ve tahakkuk aşamaları tamamlanmış, ödeme emri belgesi düzenlenmiş ve ön mali kontrolden geçerek ödenmek üzere muhasebe birimine gelmiş bulunan gider ve muhasebe belgeleri ile ön ödeme belgeleri üzerinde, ödemeye ilişkin belgelerin tamam olup olmadığını ve maddi hata bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğu, ilgili mevzuatında belirtilen belgeler dışında belge aramayacağı ve sorumluğunun görevi gereği incelemesi gereken belgelerle sınırlı olduğu belirtilmektedir.

Anılan Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca, bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede gerçekleştirme görevlilerinin, harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, yanında bu işlemlerin belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevi de bulunmaktadır.

Giderin taahhüt ve tahakkuk aşamalarına ait olup, çeşitli gerçekleştirme görevlilerinin kendi yasal görevleri çerçevesinde düzenledikleri ve imzaladıkları belgelerdeki maddi hatalardan muhasebe yetkilisi de sorumlu tutulmaktadır.

Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; "Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir mali işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura, alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçilmesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştirmeye esas toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır. Teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri sorumlu olup, muhasebe yetkililerinin bu belgelere ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır." şeklinde bir çerçeve çizilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 30'uncu maddesinde de "Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç dört iş günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına aktarılır. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenler, en geç iki iş günü sonuna kadar incelenerek muhasebeleştirme ve ödeme işlemi gerçekleştirilir. Hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaksızın kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabilecek ödeme tür ve tutarları ile kontrol, muhasebeleştirme ve ödeme süresini dört iş gününden daha az olarak belirlemeye, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlık, kapsamdaki diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir." ilave açıklamalar yapılmıştır.

Yukarıda ifade edildiği üzere, bir mali işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden belgelerde gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas rakamlardaki açık, kolayca görülebilen ve yorum gerektirmeyen hatalar maddi hata olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu mevzuat hükümleri karşısında, ödemeye esas teşkil etme niteliği bulunan, fakat

gider evrakı arasında yer almayan bir belge nedeniyle ortaya çıkan kamu zararı ile giderin taahhüt ve tahakkuk aşamalarına ait olup çeşitli gerçekleştirme görevlilerinin kendi yasal görevleri çerçevesinde düzenledikleri ve imzaladıkları belgelerdeki açık ve kolayca görülebilen ve yorum gerektirmeyen maddi hatalardan muhasebe yetkilisinin, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması söz konusudur. Ancak hatanın bariz olup olmadığı hususunun ise yargı dairelerince kararlaştırılacak bir konu olduğunu ifade edebiliriz.

Muhasebe yetkilisinin, usul ve mevzuatına göre tahakkuk ettirilmiş gideri hak sahibine ödemek ve ödeme yaparken hak sahibinin kimliğini kontrol etmekle görevli olduğu, 5018 sayılı Kanun'un 61'inci maddesinde ve Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 23 ve 29'uncu maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 32'nci maddesinde de idarelerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş kamu gelir ve alacaklarının yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesinden muhasebe yetkilisinin sorumlu olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Bu nedenle, idarelerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş kamu gelir ve alacaklarının takip ve tahsil edilmesinden muhasebe yetkilisinin tek başına sorumluluğu söz konusudur.

Giderlerin hak sahiplerine ödenmesinden muhasebe yetkilisi sorumludur. Muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 61'inci maddesinde düzenlenmiştir. Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz.

Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

5018 sayılı Kanun'un 61'inci maddesi ile Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca; taahhüt ve tahakkuk aşamaları tamamlanmış, ödeme emri belgesi düzenlenmiş ve ön mali kontrolden geçerek ödenmek üzere muhasebe birimine gelmiş bulunan gider ve muhasebe belgeleri ile ön ödeme belgeleri üzerinde, ödemeye ilişkin belgelerin tamam olup olmadığını ve maddi hata bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğu, ilgili mevzuatında belirtilen belgeler dışında belge aramayacağı ve sorumluğunun görevi gereği incelemesi gereken belgelerle sınırlı olduğu ifade edilmiştir.

73. Doğrudan temin kapsamı alım sürecinde fatura ve fatura yerine geçen belgeler kıyas yoluyla sözleşme kabul edilip damga vergisi kesintisine tabi tutulur mu?

Özet: *Damga vergisi mevzuatı çerçevesinde, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, zorunlu olarak veya takdire bağlı olarak sözleşme düzenlenmişse bu durumda damga vergisinin kesilmesi gerektiğini, ancak doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmadığı durumlarda, idare ile istekli arasında herhangi bir sözleşme düzenlenmemişse, yüklenici tarafından alım kapsamında eşyanın teslimi ile birlikte idareye sunmuş olduğu, fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kıyas yoluyla sözleşme olarak kabul edilmesinin verginin yasallığı ilkesinden dolayı mümkün olmadığını, dolayısıyla, ortada bir sözleşme olmadığı için damga vergisi kesilmesinin de mümkün olmadığını ifade edebiliriz.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır.

4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. maddesinde yer alan; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenleme ile sözleşme yapma konusunda idareler (sözleşme düzenlenmesini gerektiren istisnai durumlar hariç olmak üzere) serbest bırakılmıştır.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'da belirtilen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

Öte yandan, bu kapsamda alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarenin takdirindedir.

Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin kesilmemesi gerekmektedir.

Görüldüğü üzere; sözleşme düzenlenmesi hususu idarelerin takdirinde olmakla birlikte, 22'nci madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumu ile 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur. Bu bağlamda, doğrudan teminde yapılan sözleşme Borçlar Kanunu hükümler çerçevesinde tarafları bağlamaktadır.

Sözleşme yapılması halinde idarelerin sözleşme bedeli üzerinden ilgili mevzuatında öngörülen oranda damga vergisi kesintisi yapılması ise, takdire bağlı olmayıp zorunluluk arz eden bir durumdur.

Bu bağlamda, 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu çerçevesinde gerek açık teklif usulü gibi sözleşme düzenlenmesi zorunlu olan ihale usullerinde, gerekse doğrudan temin gibi sözleşme düzenlenmesi zorunlu olmayan fakat buna rağmen sözleşme düzenlenen durumlarda tanzim edilen sözleşmelerin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Nitekim 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na göre damga vergisine tabi işlemlerden birisi de düzenlenen sözleşmelerdir. Anılan Yasa'ya ekli 1 sayılı Tablonun 1.Akitlerle İlgili Kağıtlar bölümünün A bendine göre belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin damga vergisine tabi tutulması öngörülmüştür.

Bu paralelde, bir kağıdın damga vergisine konu edilebilmesi için;

- Düzenlendiği anda herhangi bir hususu ispat ve belli etmek için ibraz edilebilecek belge vasfında olması,

- Aynı zamanda söz konusu kağıdın 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alması.

şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.

Dolayısıyla, bu vasıflara sahip kağıda ilişkin damga vergisi, bu kağıdın düzenlenip imzalandığı anda doğacağını, böylelikle, damga vergisinde vergiyi doğuran olayın vergiye tabi kağıdın imzalandığı anda meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Diğer bir anlatımla, vergiye tabi kâğıtların tanzim edilmesi, damga vergisinin doğabilmesi için düzenlenmiş bir kağıdın varlığı yeterli kabul edilmekte, vergiyi doğuran olay ise, söz konusu işleme ilişkin kağıdın düzenlenmesi aşamasında doğmaktadır. Yani, bir kağıdın imzalı şekilde tanzim edilmiş olması damga vergisinin gerçekleşmesi için vazgeçilmez unsur olarak kabul edilmektedir.

Ancak sözleşme düzenlenmemesi durumunda ise, sözleşme damga vergisi tahsil edilmesine gerek yoktur. Bu nedenle, idarece yapılan bir alıma ilişkin olarak sözleşme düzenlemediği durumlarda, yüklenicinin alıma konu eşyanın teslim sürecinde idareye sunduğu fatura ve diğer belgelerin sözleşme yerine geçip geçmediği, diğer bir ifadeyle bunları sözleşme kabul edip bunlardan damga vergisi kesilip kesilmeyeceğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Bu bağlamda, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda yazılı sözleşme düzenlenmediği durumlarda faturaların sözleşme olarak değerlendirilerek sözleşme damga vergisi kesilmesinin mümkün olmadığını gerek Damga Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca ve gerekse bu hususa ilişkin Sayıştay Kararı çerçevesinde söyleyebiliriz.

Zira Sayıştay 1. Dairesince verilmiş olan bir kararda da fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kıyas yoluyla sözleşme olarak kabul edilmeyeceğine karar verilmiştir.

Söz konusu Kararın incelenmesinde ise; yapılan yasal düzenlemeye istinaden doğrudan temin usulü ihale usulleri arasından çıkarıldığı, dolayısıyla bu tür alımlarda sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmadığı, kıyas yoluyla vergi ihdas edilemeyeceği, vergi hukukunun temel ilkelerinden olması nedeniyle de, doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarında sözleşme düzenlenmemesi durumunda, fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kıyas yoluyla sözleşme olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığının ifade edildiği görülmüştür.

Dolayısıyla, satışa ait fatura ve benzeri belgelerin sözleşme kabul edilerek damga vergisi ile ilişkilendirilmesinin hukuki olmadığı anılan mevzuat çerçevesinde söylenebilir.

Diğer taraftan, 4735 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihaleler sonucunda sözleşme türleri;

"a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,

b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

d) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,

e) Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme,

Düzenlenir.

Çerçeve anlaşma ve münferit sözleşmede belirtilmesi zorunlu olan hususları belirlemeye Kurum yetkilidir."

Şeklinde yasal olarak belirlenmiştir.

Görüldüğü üzere; sözleşme türler arasında, fatura ve fatura yerine geçen belgelerin dikkate alınması gerekliliğine yönelik uzak veya yakın herhangi bir ibare bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2'nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve

şerhlerin damga vergisine tabi olacağı hususu düzenleme altına alınmış, aynı Kanun'a ekli (1) sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2'nci fıkrasında ise, (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) *İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 5,69 oranında damga vergisine tabi tutulacağı* hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kanun uyarınca, doğrudan temin uygulamasında sözleşme yapma zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve bu husus tümüyle idarelerin takdirine bırakılmıştır. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir. Her ne kadar doğrudan temin yönteminde ihale komisyonu kurulması zorunlu değilse de eğer komisyon teşekkül ettirilerek karar alınmış ise ihale komisyonunun aldığı karardan da damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Nitekim 16.04.2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin 5'inci maddesinde;"...*Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir*..." şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Bu nedenle, 4734 sayılı Kanun uyarınca, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda sözleşme düzenlendiği durumlarda sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerekir. Sözleşme düzenlenmemesi durumunda ise sözleşme damga vergisi tahsil edilmesine gerek yoktur. Dolayısıyla, idarelerin doğrudan temin kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bu bağlamda, doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda da belli durumlarda Damga Vergisi kesintisinin söz konusu olduğunu, zira idarece belli bir parayı ifade eden sözleşmenin yükümlü ile imzalanması durumunda alım şekli doğrudan temin de olsa damga vergisinin tahsil edilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade edebiliriz.
Çünkü damga vergisi açısından alımın ihale türü veya doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşmesi açısından bir fark bulunmadığını, değerlendirmede esas olanın sözleşmenin

varlığı olduğunu söyleyebiliriz.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale karar vergisi kesilmesine de gerek olmadığı düşünmekteyiz. Zira ihale karar vergisi kesilebilmesi için ihale komisyonu kurularak bir ihale kararının alınması gerekmektedir. Doğrudan teminle yapılan alımlarda ise böyle bir husus söz konusu değildir.

Dolayısıyla, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir. Sözleşme düzenlenmeyen durumlarda ise, sözleşme damga vergisi doğmayacağından, damga vergisi tahsil edilmesi söz konusu olmayacaktır. İhale kararı alınmaması ve sözleşme düzenlenmemesi durumunda sadece ödeme esnasında ödeme emri üzerinden damga vergisi kesilir.

Konuyla bağlantılı olarak verilen bir Sayıştay Kararında yer aldığı üzere, doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmadığı, kıyas yoluyla vergi ihdas edilemeyeceği, vergi hukukunun temel ilkeleri arasında olduğu, doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarında sözleşme düzenlenmemesi durumunda, fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kıyas yoluyla sözleşme olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı ifade edilerek, fatura ve fatura geçen belgelerin kıyas yoluyla sözleşme olarak kabul edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle, damga vergisi kesilmesinin de mümkün olmadığı sonucuna ulaşıldığı görülmektedir.

Aynı bağlamda, doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale karar vergisi kesilmesine gerek olmadığını, zira ihale karar vergisi kesilebilmesi için ihale komisyonu kurularak bir ihale kararının alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğrudan teminle yapılan alımlarda ise böyle bir husus söz konusu değildir.

Bununla birlikte, 4734 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde her ne kadar doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale komisyonu kurulması zorunlu olmamakla birlikte ihtiyacın niteliğine göre, ihale komisyonu kurulması halinde ve doğrudan teminle yapılan alımların bu komisyon tarafından yapılması durumunda, damga vergisi tahsil edilmesinin gereklilik arz ettiğini söyleyebiliriz.

Gerek ihale ve vergi mevzuatı ve gerekse konuyla bağlantılı Sayıştay Kararında yer aldığı üzere, yapılan yasal düzenlemeye istinaden doğrudan temin usulü ihale usulleri arasından çıkarıldığı, dolayısıyla bu tür alımlarda sözleşme düzenleme zorunluluğu bulunmadığını, kıyas yoluyla vergi ihdas edilemeyeceğini, bu itibarla, doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarında sözleşme düzenlenmemesi durumunda, satışa ait fatura ve benzeri belgelerin sözleşme kabul edilerek damga vergisi ile ilişkilendirilmesinin hukuki olmadığını anılan mevzuat çerçevesinde söyleyebiliriz

74. Doğrudan temin yöntemiyle milletlerarası alanda avukatlık hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet hakkı tescil sürecine ilişkin hizmet alımlarının kapsamı nedir?

Özet: *659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile belli durumlarda avukatlık hizmet alımlarını düzenleyen 4353 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 4734 sayılı Yasa uyarınca doğrudan temin yöntemi, ihale usulleri arasında sayılmayan bir alım yöntemi olup, ancak Kanun'un öngördüğü durumlar için kullanılabilir. Bu bağlamda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerine göre doğrudan temin yöntemiyle alım yapılması mümkündür. Söz konusu durumlardan biri milletlerarası tahkim davalarına ait avukatlık hizmetleri diğeri ise ulusal veya uluslararası kuruluşlar nezdinde fikri ve sınai mülkiyet hakların tesciline ilişkin hizmet alımlarıdır. Bahse konu alımların niteliğinden dolayı ihale usullerine başvurmadan doğrudan temin yöntemiyle, parasal sınırlamaya tabi tutulmadan alım yapılması mümkündür.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu olup, bahse konu Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiştir. Söz konusu Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmasına rağmen, bir alım yöntemi olarak anılan Yasa'nın 22'nci maddesinde yer almaya devam etmektedir.

Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları öncelikli olarak ihale usulleri kapsamında ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi şeklinde doğrudan

temin kapsamı alımları özetleyebiliriz.

Yaygın olarak kullanılmasına karşın, istisnai bir yöntem olarak Kanun'da yer alan doğrudan temin kapsamına giren ihtiyaçlar, niteliği itibarıyla ihale yöntemiyle temini mümkün olmayan ihtiyaçlardır. Zira diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın bu kapsamda karşılanması söz konusu değildir.

Her ne kadar istisnai durumlar hariç olmak üzere, sözleşme düzenleme konusunda idarelerin takdir hakkı da olsa, yükleniciye çeşitli sorumluluklar yüklenilmesinin söz konusu olduğu alımlarda yazılı sözleşme düzenlenmesinin pratik bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönde bir tercih de bulunulmadığı durumlarda, ileride çeşitli hukuki sorunların yaşanmasının söz konusu olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle alım sürecine ilişkin hassas konuların (yaptırım uygulanması gibi) yazılı kurala bağlanmasının idarenin lehine olacağını söyleyebiliriz.

4734 sayılı Yasa'nın "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinde hangi hallerde doğrudan temin kapsamında alım yapılabileceği hususu düzenlenmiştir. Söz konusu madde;

"Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (İkiyüzonsekizbinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası)*, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını

* 20/01/2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01/02/2022 – 31/01/2023 dönemini kapsamaktadır.

(Yetmişikibinyediyüzelliiki Türk Lirasını)* aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

ı) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.; Değişik: 19/11/2013-6504/1 md.) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

Şeklinde hükme bağlanmıştır.

Söz konusu maddenin birinci fıkrasının "g" ve "h" bentleri kapsamı alımlarla bağlantılı olarak

çeşitli hukuki düzenlemelerin değişikliğe uğradığını görmekteyiz.

Daha önceleri 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğü'nün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayet Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun uyarınca idarelerin belli durumlarda avukatlık hizmeti alımları düzenlemekteydi.

Ancak söz konusu Kanun, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 18'inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ve avukatlık hizmet alımları yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu 659 sayılı KHK'nın "Muhakemat hizmeti temini" başlıklı 5'inci maddesi uyarınca, idareler, muhakemat hizmetleri ihtiyaçlarını; hukuk birimlerinde istihdam edecekleri hukuk müşavirleri ve avukatlardan veya ihtiyaç duyulması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan talep etmek suretiyle sağlayabilirler. Hatta Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere birbirlerinden hizmet talebinde bulunabilmeleri de mümkündür.

Ancak yukarıda ifade edilen her iki durumda da muhakemat hizmetlerinin temin edilememesi veya özel uzmanlık gerektirdiği ilgili bakanın onayı ile belirlenen hallerde muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınabilir.

Hizmet satın alınarak kendisine vekâlet verilen serbest avukatlar ve avukatlık ortaklıkları kendilerine vekalet verilen dava ve icra işlemlerinin takibiyle ilgili olarak, ilgili mevzuatla idareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan görevlilerle aynı yetki ve sorumlulukları haiz olduğunu söyleyebiliriz.

Buna karşın, anılan Yasa'nın 22'nci maddesinin ilk fıkrasının "g" bendi ise, "Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları" şeklindeki düzenleme uyarınca, ihtiyaçların doğrudan temin yöntemiyle karşılanması olanaklı hale gelmiştir.

Dolayısıyla, madde metninde açık bir şekilde görüldüğü üzere; milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımlarının doğrudan temin yöntemiyle karşılanması mümkündür. Milletlerarası tahkim dışındaki yollarla çözülen uyuşmazlıklarda bu bende göre alım yapılamayacağı açıktır. Çünkü bu yönde bir belirleme yapılmıştır.

Söz konusu KHK'nın ilgili maddeleri uyarınca, Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik de ayrıca hazırlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin "Avukatlık hizmeti satın alınacak haller" başlıklı 4'üncü maddesinin, bahse konu KHK'nın ilgili maddesi ile paralellik kurulacak şekilde hazırlandığını görmekteyiz.

Dolayısıyla, idareler, muhakemat hizmetlerini kendi hukuk birimlerinden, bakanlıklarından veya bağlı kuruluşlarından ve Hazine ve Maliye Bakanlığından temin edemediği ya da hizmetin özel uzmanlık gerektirdiği ilgili bakan onayı ile belirlendiği hallerde, serbest avukatlardan hizmet satın almak suretiyle karşılayabilmektedirler.

Hizmet alımının konusu bir veya birden fazla dava ve icra işinin takip ve sonuçlandırılması olabileceği gibi belirli bir yerdeki dava ve icra takiplerinin belirli bir süreyle sınırlı olarak görülmesi şeklinde de olabileceğini söyleyebiliriz.

Bahse konu Yönetmeliğin "Doğrudan temin" başlıklı 5'inci maddesi de "(1) Muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere hizmet alımları 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılır." şeklinde düzenlenmiştir. Yani 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesi ile uyumluluk arz edecek şekilde hazırlanmıştır.

Bu bağlamda, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, hukuk hizmetleri, muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri ifade etmektedir. Dolayısıyla, belirtilenlerin dışında kalan hizmet, iş ve işlemlerin Kanun'un 22'nci maddesinin (h) bendine dayanılarak alınmasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Benzer şekilde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.8'inci maddesinde ise, bu kapsamda yapılacak hizmet alımları milletlerarası tahkim yoluyla çözülecek anlaşmazlıklara münhasır olduğundan, anlaşmazlıkların milletlerarası tahkim dışındaki çözümü yollarında idarelerin Kanun'un genel hükümlerine göre hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Yasa'nın 22'nci maddesinin birinci fıkrasının diğer bendi olan "h" bendi ise; " 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları." şeklinde hükme bağlanmıştır.

Aynı şekilde, önceleri 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğü'nün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayet Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun uyarınca idarelerin belli durumlarda avukatlık hizmeti alımlarını düzenlemekte iken, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 18'inci maddesi ile söz konusu kanunun yürürlükten kaldırıldığını ve avukatlık hizmet alımlarının yeniden düzenlendiğini vurgulayabiliriz.

Bu itibarla, bahse konu bent kapsamında; ihtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hallerde serbest avukatlardan (avukatlık ortaklıklarından); milletlerarası yargı organlarında devletin taraf olduğu davalar ile milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenmesi öngörülen ve Hazine avukatlarınca takibine imkân bulunmayan uyuşmazlıklarla ilgili davalarda devleti ve genel bütçeli idareleri temsil etmek ve savunmak üzere Türk veya yabacı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınması mümkündür.

Yukuırduki bende göre ayrıca fikri ve sınaî mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilinin sağlanmasına yönelik hizmetler de alınabilir.

Bunlarla birlikte, doğrudan temin yöntemi kullanmak suretiyle alım yapılabilecek durumlar 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde sayma yoluyla belirlendiğini, bahse konu durumlar haricinde doğrudan teminle alım yapılmasının mümkün olmadığını ifade edebiliriz.

Dolayısıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerine göre doğrudan temin yöntemiyle alım yapılmasının mümkün olduğu durumların, yorum ya da kıyas yoluyla genişletilmesinin uygun olmadığını, çünkü bahse konu alımların niteliğinden dolayı farklılık arz ettiğini, bu durumun ise Kanun maddesi ile net bir şekilde hükme bağlandığını ifade edebiliriz.

75. Doğrudan temin kapsamında idareler taşınmaz alımı veya kiralaması yapılabilir mi?

Özet: *4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (e) bendi uyarınca, taşınmaz malların alım ve kiralama işinin doğrudan teminle yapılması mümkündür. Taşınmaz mal alımı ve kiralanmasında; alım veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçenin belirtilmesi, alınması veya kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi, alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki bilgilerin alıma veya kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan mevzuatının öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi gerekmektedir. Genel yönetim kapsamındaki idarelerce taşınmaz kiralanırken Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge'ye uyulması gerekmektedir. Düzenlenecek sözleşmelerde kira bedelinde artış yapılmasının öngörülmesi halinde; sözleşmeye, genel yönetim kapsamındaki idareler için artış oranının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan kira artış oranlarını geçmeyeceği yönünde hüküm konulması, diğer idarelerce ise genel uygulamalar dikkate alınarak belirlenecek oranlarda artış yapılacağı yönünde madde konulması zorunluluk arz etmektedir.*

4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca anılan Yasa'nın 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların genel alım yöntemi olan açık ihale usulü ile veya Kanun'daki şartların bulunması halinde belli istekliler arasında ihale usulü ya da pazarlık usulü ile ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir.

Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi şeklinde doğrudan temin yöntemi alımları özetleyebiliriz.

İdareler alım sürecinde, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde düzenlenen *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…"* hüküm ve ilkeleri çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Yasa'nın "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinde hangi hallerde doğrudan temin kapsamında alım yapılabileceği hususu düzenlenmiştir. Söz konusu madde;

"Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (İkiyüzonsekizbinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası)*, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (Yetmişikibinyediyüzelliiki Türk Lirasını)* aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda,

* 20/01/2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01/02/2022 – 31/01/2023 dönemini kapsamaktadır.

Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

ı) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

…

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

Şeklinde hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen yasa maddesinde de görüleceği üzere; idareler 4734 sayılı Yasa'nın "İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması" şeklinde düzenlenen 22/e maddesi kapsamında, ihtiyacı olan taşınmazı kiralayabilir veya satın alabilir.

İdarenin taşınmaz ihtiyaçlarının 4734 sayılı Kanun'un doğrudan temin yöntemi kapsamında karşılanması bir anlamda zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bahse konu nitelikte bir ihtiyacın ihale usulleri kapsamında karşılanması pratik nedenlerle pek mümkün gözükmemektedir. Zira o niteliklere uygun binanın sadece bir sahibinin olması bu nitelikteki bir alım için ihale türleri kapsamında alım yapılmasını engellemektedir. Ayrıca, ortada gerçek anlamda bir rekabet süreci de yoktur.

Yani bu alım yöntemi istisnai olarak kullanılması gereken bir alım yöntemidir ve Kanun'un aradığı yasal koşulların varlığı halinde tercih edilmelidir.

Esas olan idare ihtiyaçlarının, Yasa'nın temel ilkeleri çerçevesinde, uygun şart ve zamanda karşılanmasıdır. İlgili kamu idaresinin yaptığı değerlendirme sonucunda, insan kaynağı, ulaşım vb. faktörleri dikkate alarak en uygun şekilde hizmet vereceği binayı satın alması veya

kiralaması bir anlamda zorunluluk arz etmektedir.

Ancak bu husus, idarenin bütünüyle serbest hareket edeceği anlamına gelmemektedir. Keza Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer aldığı üzere, neden söz konusu binanın alındığı veya kiralandığının çok yönlü olarak fiyat dahil olarak açıklanması gerekmektedir.

Bu noktada Kamu İhale Genel Tebliği ve 16.01.2019 tarihli ve 30657 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge'de yer alan düzenlemelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Söz konusu genelge de dikkat alınarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.

4734 sayılı Kanun kapsamındaki diğer idarelerin kira bedellerinin ise, sözleşmelerinde belirtilen oranlarda artırılması mümkündür.

Alım bedeli, piyasada fiyat araştırılması yapılması suretiyle veya İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde tespit edilebilir.

Bu bent (22'nci maddenin "e" bendi) kapsamında yapılacak alımlarda tutar limiti bulunmamaktadır. Ayrıca, aynı maddenin (d) bendinde olduğu gibi bütçenin %10'unu aşmama sınırlamasına tabi değildir.

Kamu İhale Genel Tebliği'ne göre, taşınmaz mal alımı ve kiralanmasında; alım veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçenin belirtilmesi, alınması veya kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi, alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki bilgilerin alıma veya kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan mevzuatının öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi gerekmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 217'nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi ile "Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak" görev ve yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiştir.

İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alınması veya kiralanması işleri bu bent kapsamında doğrudan temin edilebilmektedir. Bu bent kapsamında yapılan alımlarda da ilgili mevzuatı gereğince sözleşme imzalanmaktadır.

Bu bağlamda, genel yönetim kapsamındaki idarelerce taşınmaz kiralanırken Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge'ye uyulmaları gerekmekte olup, bu hususta düzenlenecek sözleşmelerde kira bedelinde artış yapılmasının öngörülmesi halinde; sözleşmeye, genel yönetim kapsamındaki idareler için artış oranının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan kira artış oranlarını geçmeyeceği yönünde hüküm konulması, diğer idarelerce ise genel uygulamalar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artış yapılacağı yönünde hüküm konulması zorunludur.

Buna göre; Türk parası cinsinden, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin daha önce 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca kiralamış olduğu taşınmazların kira artış oranının belirlenmesinde ve bu idarelerce 4734 sayılı Kanun'a göre yeni yapılacak taşınmaz kiralamalarında belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.

Daha önceki yıllarda kiralanmış olup da sonraki yıllarda kiralanmasına devam edilecek taşınmazların kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranım geçmeyecek şekilde artırılması gerekmektedir. Ancak söz konusu yüzde değişim oranının kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması hâlinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacaktır.

Sözleşme veya protokollerinde artış yapılmayacağına dair hüküm bulunan kiralamalar ile kira başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacaktır.

Yine söz konusu Genelge çerçevesinde, yeni yapılacak taşınmaz kiralamalarına ait sözleşmelere;

- Yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık (tercihen aylık) eşit taksitler hâlinde ve dönem başlarında ödeneceğine,

- Bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra kiralamaya devam edilmesi hâlinde kira bedelinde artış yapılacak ise bu artışın; Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranını aşamayacağına,
- Üstte belirtilen yüzde değişim oranının kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması hâlinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacağına,
- Kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçların kiraya verene ait olduğuna,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre, kira bedelinden vergi tevkifatı yapılması gereken hâllerde; kira bedelinden gelir vergisi ve sair kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının kiraya verene ödeneceğine,
- Yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanacağına,
- Ödemelerin kiraya verenin belirteceği banka hesabına makbuz karşılığı yapılacağına,

Dair hükümler konulacaktır.

Bu itibarla, genel yönetim kapsamındaki idarelerin taşınmaz kiralamasına ilişkin Kamu İdarelerinin Taşınmaz Mal Kiralamalarına İlişkin Genelge'nin yukarıda yer verilen hususları dikkate alınarak, hareket edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz.

Konuyla bağlantılı bir Sayıştay Kararına göre, idarenin doğrudan temin ile kiralama için doğrudan mülk sahibinden kiralamanın yapılması gerektiği ifade edilmiş, ayrıca kiraya ek olarak, temizlik, ısıtma, soğutma ve sair hizmet alımları ile birlikte yapılması durumunda doğrudan temin yerine ihale usullerine başvurulması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Farklı bir Sayıştay Kararında ise doğrudan temin usulüne başvurularak yapılan ihtiyaca uygun taşınmaz alımında; taşınmazın, taşınır mal niteliğindeki eklentilerinin de bu bent kapsamına girdiğine ve doğrudan temin yoluyla alınmasının mümkün olduğuna karar verildiği anlaşılmıştır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "Kiralar"a ilişkin 45'inci maddesinde ise; " Kira bedellerinin ödenmesinde, kiralamanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.
a) Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası,
- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır…" şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Taahhüt dosyası" başlıklı 6'ncı maddesi ise;

" İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (Örnek:2) veya söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir.

Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin (Değişik ibare: RG-5/11/2016-29879) birinci nüshasına bağlanır. Ancak, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan belgelerden taahhüt dosyası dışındaki belgeler bağlanır. Taahhüt dosyasının onaylı sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklanır." şeklinde düzenlenmiştir.

Netice itibarıyla; idareler 4734 sayılı Yasa'nın "İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması" şeklinde düzenlenen 22/e maddesi kapsamında, ihtiyacı olan taşınmazı kiralayabileceğini veya satın alabileceğini, idarenin taşınmaz ihtiyaçlarının doğrudan temin yöntemiyle karşılanmasının bir anlamda zorunluluktan kaynaklandığını, genel yönetim kapsamındaki idarelerce taşınmaz kiralanırken 16.01.2019 tarihli ve 30657 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge'nin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade edebiliriz.

76. Doğrudan temin kapsamında yapım işi gerçekleştirilebilir mi?

Özet: *Doğrudan temin yöntemi, istisnai bir satın alma yöntemi olsa da, bu kapsamdaki yapım işleri diğer alım türleri açısından farklılık göstermektedir. Her şeyden önce bu kapsamdaki piyasa fiyat araştırması (bir anlamda yaklaşık maliyet tespit) sürecinin, ihale uygulama yönetmeliklerinde belirtilen şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu alım türünde, iş programı, kontrol teşkilatı, kabul işlemi, iş yerinin sigortalanması, işçilerin hakedişleri vb. durumlara ilişkin hukuki durumlar dikkate alınarak düzenlenecek sözleşmelerde, her ihtimalin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dolayısıyla, yapım işi ihalelerine ait tip dokümanlar kullanılabilir. Hatta yapım işleri genel şartnamesinde yer verilen hususlara, düzenlenecek sözleşmelerde de yer verilmesi veya atıf yapılmasının, idareyi karşılaşabileceği risklere karşı koruyacağı düşünülmektedir.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Bu hususta, Kamu İhale Genel Tebliği'nde; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" açıklaması yer almaktadır.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'da belirtilen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

Öte yandan, bu kapsamda alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarenin takdirindedir.

Doğrudan temin kapsamı alımlar, 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesinde sayılmış olup, belirtilen alımların dışındaki alımların kıyas yoluyla yapılması mümkün değildir. Söz konusu madde kapsamındaki alımlardan bir tanesi de parasal limitler dahilinde (22-d) gerçekleştirilen ihtiyaçlardır. Limiti dahilinde yapım işlerinin de gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir.

Yapım işinin hangi anlama geldiği ise, 4734 sayılı Yasa'nın "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde açıklığa kavuşturulmuştur. Söz konusu tanıma göre *"Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini"* ifade etmektedir.

4734 sayılı Yasa'nın "Temel ilkeleri" bu alım türü içinde geçerli olmakla birlikte, yapım işleri doğası gereği mal ve hizmet alımlarından bazı noktalarda farklılık göstermektedir. Aynı şekilde bu alım kapsamında da idareler, yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde de yer aldığı üzere, ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ise ancak Kanun'da belirtilen özel hallerde mümkündür.

Doğrudan temin kapsamı yapım işleri, yaklaşık maliyetin hazırlanması boyutuyla, mal ve hizmet alımlarından farklılık arz etmektedir. Çünkü doğrudan temin (22/d) kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

Yapım işinin de belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Ancak yapım işinin bir anda bitirilmesinin pratik olmadığı düşünüldüğünde sözleşme yapılması bir anlamda gereklilik arz etmektedir. Doğrudan temin kapsamında yapılan sözleşmeler Borçlar Kanunu hükümler çerçevesinde geçerlidir.

Doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılacak alımlarda teminat alınması sözleşmede

belirtilmiş ise alınır. Şayet alıma ilişkin dokümanlarda bu hususta bir açıklama yoksa teminat alınması söz konusu olmayacaktır. Ancak bu alım türü için teminat alınmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Yapım işleri ihale kapsamında "İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması" söz konusu olabilmektedir. Zira ihale kapsamı alımlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 9'uncu maddesine göre, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur.

Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı "inşaat sigortası (bütün riskler)", geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

Ancak doğrudan temin ile yaptırılan yapım işleri bu kapsama dahil olmayıp ancak sözleşme imzalanmış ve sözleşmede all risk sigortası yapılacağı belirtilmiş ise yapılabilir. İş programı da aynı şekilde sözleşme veya eklerinde belirtilmiş ise istenebilir. Zira söz konusu genel şartname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre sözleşmeye bağlanan yapım işleri için geçerlilik arz etmektedir.

Yine doğrudan temin (22/d) ile alımı gerçekleştirilen bir yapım işinde geçici ve kesin kabul yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. Ancak sözleşmede belirtilmiş ise kesin teminatın alınması, geçici ve kesin kabulün sözleşmede belirtildiği şekilde yapılması gerekir. En kapsayıcı çözüm olarak düzenlenecek sözleşmede yapım işleri genel şartnamesine atıf yapılmak suretiyle söz konusu genel şartnamedeki hükümlerin uygulanması benimsenebilir.

Geçici ve kesin kabul işlemlerinde de sözleşmede yer alan düzenlemelerin uygulanması gerekmektedir. Sözleşmede belirtilmemiş ise bir defada kabul işlemi yapılabilir.

Ancak tek bir kabul işlemi yapıldığı ve kesin teminat alınmadığı takdirde, kabulden sonra ortaya çıkabilecek problemlerde yükleniciye uygulanacak bir yaptırım bulunmamaktadır. Burada sözleşmede buna ilişkin hükümler yer almıyor ise idare talebine rağmen gerekli düzeltmeyi yapmıyorsa, böyle bir durumda dava açılması söz konusu olabilmektedir. Bu olası belirsizlik bile sözleşme yapılma zorunluluğunu bir anlamda ortaya koymaktadır.

Doğrudan temin kapsamıyla gerçekleştirilen yapım işleri açısından düzenlenecek sözleşmelerin götürü bedel olarak mı yoksa birim fiyat şeklinde mi sözleşmeye bağlanacağı hususuna da değinebiliriz.

Bilindiği üzere, Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme; Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşmeyi ifade etmektedir.

Buna karşın, Birim fiyat sözleşme ise; Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden yapılan sözleşmeyi ifade etmektedir.

Bu bağlamda, doğrudan temin birim fiyatlı ya da götürü şeklinde bir ayrım olmadığını söyleyebiliriz. Buna karşın, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin ekinde yer alan piyasa fiyatı araştırma tutanağında (MYHBY Örnek 2) kalem bazında düzenlendiğinden birim fiyat anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, doğrudan temin yönteminde, Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme de uygulanabilir ancak bu şekilde yapıldığı zaman işin niteliğine göre yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması, şartname, teknik şartname, proje vs. hazırlanması ve sözleşme imzalanması gereklidir. Aynı şekilde götürü şekilde yaptırılacak işin kapsam ve özelliklerinin net olarak ortaya konulması gerekli olup tam olarak tarif edilmediği ve teknik şartname hazırlanmadığı ve sözleşme imzalanmadığı taktirde belirsizlik taşıyan

konularda idare ile yüklenici arasında ihtilaflar doğabileceği açıktır.

Bu itibarla, doğrudan temin yöntemi de kullanılmış olsa da yapım işleri için sözleşme düzenlenmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Kaldı ki Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca, idarenin ihtiyaç duyduğu alımın dolayısıyla yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda sözleşme düzenlenmesi gereklilik arz etmektedir. Bu boyutuyla, doğrudan temin kapsamı yapım işleri için sözleşme düzenlenmesinin bir anlamda zorunluluk arz ettiğini söyleyebiliriz.

Yapım işleri açısından dikkate çeken bir durum ise, esas olarak ihale kapsamı alımlar için geçerli olmak üzere, işçi alacakları boyutuyla kendini göstermektedir. Zira idare adına görev yapan yapı denetim görevlisi iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacaktır.

Bunun için yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği tahmini tarih, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 36'ncı maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan olunur. İlanın yapıldığı, yapı denetim görevlisinin ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir sureti, hakedişin ödeme yerine gönderilir.

Yükleniciden alacağı olan işçi, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden başlamak üzere bir hafta içinde yapı denetim görevlisine başvurabilirler. Alacaklar, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez. Dolayısıyla ilan yapılmış ve tutanak tutulmuş ve başvuran olmamışsa idarenin sorumluluğu ortadan kalkmaktadır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde yer alan bu husus, 4857 sayılı İş Kanun'un 36'ncı maddesi ile paralellik arz etmektedir. Aynı maddenin son fıkrası ise, "İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür." şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda doğrudan temin yöntemiyle de alınsa yapım işlerinde idarece, işçilerden

müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler. Zira İş Kanunu'nda alım şekline yönelik bir belirleme bulunmamaktadır.

Doğrudan temin kapsamı istisnai bir alım yöntemi de olsa yapım işlerinin niteliği dikkate alınarak düzenlenecek sözleşmelerde, zorunlu olmamakla birlikte yukarıda açıklanan hususlara yer verilmesi uygun olacaktır. Bu süreçte, yapım ihalelerine ait tip dokümanlar da kullanılabilir. Hatta Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde yer verilen hususlara, düzenlenecek sözleşmelerde de yer verilmesi veya atıf yapılması idareyi karşılaşabileceği risklere karşı koruyacaktır.

Çünkü yapım işinin niteliğinden dolayı idare ve yüklenicinin sorumlulukları çeşitlilik ve değişkenlik göstermektedir. Burada sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.

Yüklenici projelerde kendiliğinden hiçbir değişiklik yapamaz. Proje ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen sürede bedelsiz olarak değiştirmek veya yeniden yapmak zorundadır.

Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder.

Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.

Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak

zorundadır.

Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu işlemler yapım işleri muayene ve kabul yönetmeliği de dikkate alınarak belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kabul aşamasına gelindiğinde yüklenici kabul için dilekçesinin verir ve öncelikle kontrol teşkilatı sözleşme ve şartname hükümlerine uygun ise kabul aşamasına geçilir ve kabul komisyonu tarafından eksik ve kusur tespit edilmez ise kabul aşaması gerçekleştirilerek kesin hakediş hazırlanır. Eksik ve kusur var ise kontrol teşkilatınca yükleniciye süre verilir bu süre içinde yükleniciye ceza uygulanır, eksik ve kusurlar tamamlanır ise yine kabul aşamasına geçilerek muayene ve kabul komisyonu işin kabulünü yapar. Kabul komisyonu işin eksik ve kusuru olmadığına kanaat getirir ise işin kesin kabul aşamasına geldiğini ve muayene ve kabul komisyonu tarafından kabule hazır bulundurduğunu belirtir ve imzasını atar. Komisyon işin kabulü sırasında bir eksiklik bulursa veya belirlenen sürede yapılmazsa, idarece yaptırılarak hakedişinden veya kesin teminatından bu tutar kesilir.

Üst kısımda ifade edilen hususlar esas olarak ihale kapsamı alımlar ve bu bağlamda, yapım işleri genel şartnamesinde yer verilen hususlar olmakla birlikte, doğrudan temin yöntemi alımlara ait düzenlenecek sözleşmelerde veya alıma ait diğer dokümanlarda da bu hususlara yer verilebilir. Hatta alımın yapım işinin niteliği dikkate alınarak olası belirsizliklerin yaşanmaması adına ihale kapsamı alımlar için ön görülen düzenleme ve dokümanlar referans alınarak, doğrudan temin yönteminde de bu yönde düzenleme yapılmasının (veya önemli kısımlarının yansıtılmasının) idareler için daha uygun olacağı düşünülmektedir.

İlave olarak, doğrudan temin yöntemiyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme ve/veya şartname hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde hakediş raporu da düzenlenmesi gerektiğini ifade edebiliriz.

77. Doğrudan temin kapsamı alımlarda KDV tevkifatı yapılır mı?

Özet: *Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, vergi emniyetinin sağlanması açısından gerekli gördüğü işlemlerde, alıcının teslim ya da hizmetin KDV'sini kısmen ya da tamamen satıcıya ödemeyerek sorumlu sıfatıyla bağlı bulunduğu vergi dairesine yatırması konusunda mecburiyet getirme yetkisi verilmiştir. Bu bağlamda, KDV tevkifatının vergi mevzuatı uyarınca zorunlu bir uygulama olduğunu, KDV dahil değeri 2000.-TL'yi geçen hizmet ve teslimlerde tevkifatın yapılması gerektiğini, doğrudan temin kapsamı alımlarda da tevkifat yapılmasının zorunlu olduğunu, söz konusu oranların KDV Uygulama Genel Tebliği'nde açık bir şekilde belirtildiğini ancak KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerektiğini belirtebiliriz.*

İdarelerce gerek ihale kapsamında ve gerekse ihale türleri arasında sayılmayan doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı veya yapım işi alımı gerçekleştirmektedirler. Söz konusu alım işlerinde, ihale mevzuatı dışında, mali ve diğer mevzuat hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede 4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesine ait alımlarda KDV tevkifatının uygulanması söz konusu olabilmektedir. Zira KDV tevkifatı sadece ihale kapsamı alımlar için değil, doğrudan temin yöntemi kapsamı alımlar için de söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda, KDV tevkifatı öncelikle mali mevzuat çerçevesinde açıklanıp, sonrasında ise söz konusu tevkifatın ihale mevzuatı ile ilişkilendirilmesi önem arz etmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 9'uncu ve 29'uncu maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 120'nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiler çerçevesinde, KDV tevkifat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

KDV Kanunu'nun 9'uncu maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Bahse konu vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde sadece ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar için öngörülmüş değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilmektedir.

Bu kapsamdaki işlemlere taraf olanlar kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve kurumlardır. Bunlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu tutulmaktadırlar.

Diğer bir anlatımla, KDV tevkifatı, satıcıya ödenen KDV değerinin tamamını ya da bir kısmını ana tutardan düşürerek direkt vergi dairesine ödeme uygulamasına verilen isimdir. KDV tevkifatında faturaya işlenen verginin bir kısmı satıcıdan bir kısmı da alıcıdan alınır. Bu uygulamayla, bir anlamda KDV ödemelerinden direkt olarak devlete vergi ödenmesi söz konusu olmaktadır.

KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemeleri uyarınca, kapsama giren ödemelerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir.

Böylelikle, KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi şeklinde özetleyebiliriz.

Bu hususta, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği hazırlanmış olup, söz konusu Genel Tebliğde hangi iş ve işlemlerin KDV tevkifatına tabi olacağı, tevkifattan sorumlu olanlar ve tevkifat oranları gibi hususlar açıklığa kavuşturulmuştur.

Doğrudan temin kapsamında alımı gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için gerek 3065 sayılı KDV Kanunu ve gerekse KDV Genel Uygulama Tebliği'nde tevkifata ilişkin olarak herhangi bir istisna bulunmamaktadır. Dolayısıyla, KDV Genel Uygulama Tebliği'nde

tevkifat kapsamına alınan işler için doğrudan teminle de alınsa KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

5018 sayılı Kanun'a ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

KDV mükellefiyeti bulunmayanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır. Ancak kısmi tevkifat uygulanan hallerde, hesaplanan verginin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi, diğer kısmının ise (teslim ve hizmeti) işlemi yapan tarafından beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

KDV Kanunu uyarınca, KDV'nin konusuna giren işlemler, 3065 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinde sayılmış olup, mal teslimi veya hizmet ifalarının verginin konusuna girebilmesi için, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmış olmaları veya aynı maddede belirtildiği üzere, "diğer" faaliyetler kapsamında yapılmaları gerekir. İthalatta ise prensip olarak her türlü mal ve hizmet ithali vergiye tabidir.

KDV tevkifatı uygulaması ile teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi suretiyle kamu alacağı için otokontrol mekanizması öngörülmektedir.

Bu bağlamda, "Tam tevkifat" işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; "kısmi tevkifat" ise hesaplanan verginin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

Tam tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulur. Tam tevkifat uygulanacak işlemler, mezkûr tebliğin ilgili bölümünde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından tam tevkifat uygulaması kapsamında

işlem yapılmayacaktır. Yani, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetler KDV'ye tabi olacaktır.

İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yapılan 3065 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi kapsamındaki mal teslimlerinde de işlem tesis edilir. Teslimin vergiden müstesna olması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla vergi beyan edilmez.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
- Sendikalar ve üst kuruluşları,
- Vakıf üniversiteleri,
- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları.

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.

5018 sayılı Kanun'a ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetlere ait oranlar söz konusu Tebliğde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunlara örnek verecek olursak, Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında, Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında, Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri alımlarında, alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde ise alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi

teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise; KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanun'a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekliliğidir.

KDV tevkifatı kapsamında olmayan işlemlere, tevkifat yapma zorunluluğu bulunan kurum ve kuruluşların birbirlerine karşı yaptığı inşaat işlerini örnek olarak verebiliriz. Bu kapsamda, Toplu Konut İdaresi'nin SGK'ya yapmış olduğu inşaat işinde tevkifat uygulanmayacaktır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000.-TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Buna karşın, fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen vergi bulunması halinde, gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir. Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade edilir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimleri tarafından yapılan fazla veya yersiz tevkifatlar, satıcının beyanlarını düzelttiğini gösterir vergi dairesi yazısını ibraz etmesi üzerine ödemeyi yapan muhasebe birimlerince düzeltilir ve gereken durumlarda iade edilir.

Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip

ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklarını belirtebiliriz.

Netice itibarıyla;

- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na istinaden hazırlanan KDV Uygulama Genel Tebliği'nde belirlenen teslim ve hizmetlerde alıcı konumunda bulunan kamu idarelerinin KDV tevkifatı uygulaması gerektiğini, bunun ihtiyarı bir uygulama olmadığını,

- İlgili mevzuatta KDV tevkifatı için alım türleri itibarıyla bir ayrım yapılmadığı için, gerek ihale usulleri ve gerekse doğrudan temin kapsamı alımlarda KDV tevkifatı kesilmesinin söz konusu olduğunu,

- KDV Uygulama Genel Tebliği'nde kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000.- TL'yi aşmadığı takdirde tevkifata tabi tutulmaması gerektiğini, ancak tutarın 2000.- TL'yi aşması durumunda ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılması gerektiğini,

- KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanun'a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarına ifa edilen ve Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerektiğini,

  İfade edebiliriz.

78. Gelir vergisi stopajı (tevkifatı) doğrudan temin kapsamı alımlarda uygulanır mı?

Özet: *193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde, gelir vergisine tabi olan bir kazancın işverenler veya vergi tevkifatı yapmaya sorumlu olan kişiler tarafından, nakden veya hesaben yaptıkları ödemeler esnasında, Kanunda belirtilen oranlarda, istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapılması ve yine bunlar adına peşin olarak ödenmesine gelir vergisi tevkifatı diyebiliriz. Gelir Vergisi Kanunu ve alt düzey mevzuatta gelir vergisi tevkifatı yapılması gereken durumların ayrıntılı olarak anlatıldığını, anılan mevzuatta yer aldığı üzere kesinti yapılması gereken kazançların çeşitlilik gösterdiğini, ticari, zirai ve serbest meslek kazancı ile menkul ve gayri menkul sermaye iratları ile ücret ve diğer kazanç ve iratlardan stopaj kesilmesinin söz konusu olduğunu, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi uyarınca, tevkifat kapsamına giren kesintilerin varlığı halinde, sadece gerçek kişilerin değil kamu kurum ve kuruluşlarının da söz konusu ödemelerde tevkifat yapması gerektiğini, bahse konu ödemeler açısından alım türünün önemli olmadığını, dolayısıyla ödemenin kaynağı olan alım şekli doğrudan temin yöntemi de olsa koşulların varlığı halinde tevkifat yapılmasının gerekli olduğunu ifade edebiliriz.*

Kavramsal olarak Vergi tevkifatı, ilgili mevzuat uyarınca ödemeler sırasında, ödemenin ilgili olduğu verginin tamamı veya bir kısmının ödeme yapan tarafından kesilip ilgili vergi dairesine ödenmesini ifade eder.

Vergi tevkifatı, ilgili olduğu Kanuna göre çeşitli şekillerde isimlendirilir. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılan vergi kesintileri gelir vergisi tevkifatı olarak isimlendirilirken, Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan vergi kesintileri kurumlar vergisi tevkifatı olarak isimlendirilmektedir. Aynı şekilde, KDV mevzuatı uyarınca yapılan tevkifatı da KDV tevkifatı olarak adlandırabiliriz.

Bu bağlamda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde ifade edilen tevkifatı; Gelir vergisine tabi olan bir kazancın işverenler veya vergi tevkifatı yapmaya sorumlu olan kişiler tarafından, nakden veya hesaben yaptıkları ödeme esnasında, Kanun'da belirtilen oranlarda, istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapılması ve yine bunlar adına peşin olarak ödenmesi şeklinde tanımlanabilir.

"Vergi tevkifatı" başlıklı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesine baktığımız zaman söz konusu maddenin; *"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar."* hükmüne amir olduğu görülmektedir.

Stopajda ana ilke olarak ödemeyi yapan taraf, kesintiyi beyan eder ve öder. Ödemeyi alan taraf ise, yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan ederek, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edebileceği gibi, mahsubu yapılan miktarın gelir vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine ret ve iade olması gerekmektedir.

İşverenler tarafından gelir vergisine bağlı olan bir kazanca ait tutarın, iş yapan kişiye ödenmesi esnasında, Kanun ile tespit edilmiş oranlara göre, bu tutarın bir bölümünün, iş yapan namına, peşinen vergi dairesine ödenmesi söz konusudur.

Stopaj esasen bir vergi ödeme şeklidir, kısaca kaynakta kesilen vergi de denilebilir. Stopajın amacı, bilhassa düşük tutarlı matrahların vergilendirilmesinin garanti altına alınmasını sağlamaktır.

Gelir Vergisi Kanunu'nda, kimlerin hangi koşullarda stopaj ödemesi gerektiği detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Yasalarda türlü stopaj oranları açıklansa da, genellikle stopaj vergisi, ücretli çalışanlar, ev veya iş yeri sahipleri ve serbest meslek erbaplarına uygulanmaktadır. Yıllara sari inşaat ve onarım işleri istihkaklarında da söz konusu olabilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'ncü maddesine göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanları;

- Kamu idare ve müesseseleri
- İktisadi kamu müesseseleri
- Sair kurumlar

- Ticaret şirketleri
- İş ortaklıkları
- Dernek ve vakıflar
- Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri
- Kooperatifler
- Yatırım fonu yönetenler
- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı
- Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.

Şeklinde sıralayabiliriz.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'ncü maddesinde vergi tevkifatı yapacaklar arasında basit usulde vergilendirilen mükellefler sayılmadığından söz konusu mükelleflerin tevkifat yapmamaları ve beyanname vermemeleri söz konusudur.

Tevkifata tabi ödemelere ise, Ticari kazanç, Zirai kazanç, Ücret, Serbest meslek kazancı, Gayri menkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları ile Diğer kazanç ve iratların dahil olduğunu söyleyebiliriz.

Tevkifat kapsamında olan ticari kazançlara; Yıllara sari inşaat ve onarım işleri istihkaklarında tevkifatı, Vergiden muaf esnaftan yapılan alışlarda tevkifatı örnek olarak gösterebiliriz.

Örnek olarak yıllara sari inşaat ve onarım işleri istihkaklarında tevkifata (stopaj) kısaca değinebiliriz. Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde idareler doğrudan temin kapsamında da olsa yıllara sari yüklenmelere girişebilmektedir.

Bu bağlamda, yapım işi ihalelerine münhasır olmak üzere ihale konusu işin yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olması halinde bu işlerin devamı süresince işleri yapanlara (gerçek kişi ve kurumlar) ödenen istihkak bedelleri üzerinden işi yapanın vergisel durumuna göre 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30'uncu maddelerine göre istihkak sahiplerinin Gelir ve Kurumlar Vergisine mahsuben %3 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Ancak bir işin yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu

işin;

-Faaliyet konusu iş, inşaat ve onarım işi olmalı.
-İnşaat ve onarım işi başkalarının hesabına ve taahhüde bağlı olarak yapılmalıdır.
-İnşaat ve onarım işi birden fazla takvim yılına sirayet etmelidir.

Koşullarını taşıması gerekir.

Ayrıca, bir inşaat ve onarım işinin yıllara sari olarak vergilendirilebilmesi için işin başlangıç ve bitim tarihlerinin aynı takvim yılında olmaması gerekir. Buradaki takvim yılından kasıt 12 aylık bir süre değildir. İşin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 12 aydan az bir süre olsa dahi başlangıç ve bitiş tarihleri ayrı takvim yıllarında ise bu işin birden fazla takvim yılına sirayet ettiği kabul edilir.

Bu çerçevede, yıllara sâri inşaat ve onarma işlerinin tevkifat kapsamın giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil), ödenen istihkak bedellerinden avans olarak ödenenler dahil bu ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada %3 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. Yapılan bu kesinti, yıllık gelir vergisi beyannamesinde mahsuba konu olacaktır yani düşülmesi söz konusudur.

Bu itibarla, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen yapım işlerinin birden fazla yıla sirayet etmesi durumunda gelir vergisi tevkifatının yapılması söz konusu olabilmektedir.

Benzer şekilde, Vergiden Muaf Esnaftan Yapılan Alışlarda Tevkifata değinecek olursak; Gelir Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin son fıkrası çerçevesinde; kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gelir beyanı zorunlu bulunan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler esnaf muaflığından yararlananlara yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmak zorundadırlar. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi uyarınca, esnaf muaflığından yararlananlar yıllık beyanname vermeyeceklerinden, bunlardan yapılan vergi kesintisi nihai vergileme olacağından mahsup imkânı bulunmayacağını ifade edebiliriz.

Aynı şekilde, Gelir Vergisi Kanunu'nun 65'inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazancın serbest meslek kazancı olduğu hükme bağlanmış olup, serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara yapılan ödeme esnasında yapılan kesinti bir ön vergileme olup, bu kesinti, yıllık beyannamede hesaplanan vergi tutarından mahsup edilecektir.

Mahsubu yapılan kesinti tutarı, beyannamede hesaplanan vergiden fazla olduğu takdirde, vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilmesi ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine iade edilmesi söz konusu olmaktadır.

Öte yandan, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin gelir vergisine tabi olmayan kişilerden alınması durumunda harcama pusulası düzenlenmektedir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne göre harcama pusulası, fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden yapılan iş, mal veya hizmet alımlarında düzenlenmektedir.

Bu kapsamda doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden temin edilmesi durumunda Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin ekinde örnek olarak yer alan "harcama pusulasının" düzenlenmesi ve harcama pusulası üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi kapsamı alımlarda ve oranlarda tevkifatın yapılması gerekmektedir.

Gelir vergisi stopajı kapsamında, söz konusu kesintilerin kimlerden ne kadar yapıldığına genel olarak bakacak olursak; ücretli çalışanlar için stopaj kesintisi işverenlerden yapılmakta olup, stopaj oranı %15, %20, %27 ve %35 olarak değişiklik göstermekte olup, burada artan oranlı vergi dilimleri uygulanmaktadır. Kira ödemelerinde ise, söz konusu kesinti kiracılardan yapılmaktadır ve oranı %20'dir. Serbest meslek erbaplarına yapılan ödemeler için stopaj kesintisi hizmet alanlardan yapılmakta olup, stopaj oranı ise %20'dir.

Buna karşın, çiftçilerde satın alınan zirai ürünler ve hizmetler için yapılan ödemeler için stopaj kesintisi ürün veya hizmeti alanlardan yapılmakta olup, oranı borsaya tescil ettirilenler de %2, tescil ettirilmeyenler de %4 olarak uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Ressam (C), 2021 yılında (B) Belediyesine sattığı resimler karşılığında elde ettiği

kazançtan, (B) Belediyesi tarafından Ressam (C)'ye yapılan ödeme üzerinden 193 sayılı Kanun'un 94'üncü maddesi uyarınca %17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması, tevkifat uygulamasına örnek olarak gösterilebilir.

Benzer şekilde, idarece tercüme hizmetine bağlı olarak bu kapsamda bir ödeme yapması durumunda gelir vergisi tevkifatının söz konusu olabileceğini örnek olarak ifade edebiliriz.

Netice itibarıyla; Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde sayılan ödemelerin gelir vergisi tevkifatına tabi olduğu, sadece gerçek kişilerin değil kamu idare ve müesseselerinin de söz konusu ödemelerde tevkifat yapması gerektiğini ifade edebiliriz. Buradaki ödemeler açısından ödemenin ihale veya doğrudan temin kapsamında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın söz konusu Kanun maddesi kapsamına girdiği zaman, anılan Kanun ve alt düzey düzenlemelerde yer verilen usul ve oranda, stopaj kesintisi (tevkifatı) yapılması gerektiğini ifade edebiliriz.

79. Doğrudan temin kapsamı alımlarda alacağın temliki (alacağın devri) mümkün müdür?

Özet: *"Alacağın temliki", 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 183'üncü ve devamı maddelerinde alacağın devri adıyla düzenlenmiş olup, anılan Kanun'a göre; kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığı için, sözleşme yapılmasının zorunlu olmamasına bağlı olarak ihale usullerinde olduğu gibi tip sözleşme bulunmamaktadır. Buna göre doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda idare ile yüklenici arasında sözleşme yapılmış ve bu sözleşmede temlike ilişkin bir hüküm var ise, bu hükmün uygulanması gerekir. Eğer sözleşme yapılmamışsa, Borçlar Kanunu'ndaki temlik ile ilgili genel hükümlerin uygulanması gerekir. Ayrıca, alacağın temlik edilmesi, bu alacağı kamu borcunun önüne geçirmez. Yani, hakediş ödemeleri yapılırken, öncelikle temlik edilen alacaklar değil, kamu borçları ödenir. Kamu alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde temlikin hüküm ifade ettiğini belirtebiliriz. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca da doğrudan temin yönteminde temlik yapılmış ise temlikin noter onaylı olması gerekmekte olup, bunun dışında herhangi bir şartın öngörülmediğini ifade edebiliriz.*

"Alacağın temliki" müessesesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 183'üncü ve devamı maddelerinde alacağın devri adıyla düzenlenmiş olup, anılan Kanun'a göre; kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir.

Alacağın temliki aslında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen bir hususdur. Ancak bu konunun ihale mevzuatına da ilgilendiren boyutu bulunmaktadır. Sadece ihale kapsamı alımlar için değil doğrudan temin kapsamı alacak veya farklı bir ifadeyle ödemler sürecinde de alacağın temliki söz konusu olabilir.

Ancak alacağın temlikinde, bütünüyle tüm alacakların farklı bir kişiye kamu ödemeleri açısından devri söz konusu değildir. Bu nedenle, temlik işleminde, vergi ve diğer alacaklar durumu önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, ihale mevzuatı alıma ait düzenlenen sözleşmeye istinaden yüklenicinin

gerçekleştirmiş olduğu ihale konusu mal, hizmet alımları ile yapım işlerinden doğan hakedişini veya diğer alacaklarını alacağın temliki (alacağın devri) yoluyla üçüncü kişilere devredebilmektedir.

Alacağın temliki (alacağın devri), 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 183'üncü ve devamı maddelerinde alacağın devri adıyla düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu'na göre; Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Yine aynı Kanun hükümlerine göre; alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.

Buna göre alacağın temliki (alacağın devri), Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca sözleşmede aksi belirtilmedikçe, borçlunun, başka bir deyişle idarenin rızasına bağlı değildir. Bu sebeple, alacağın temlikine izin veren idare, alacağı devralan üçüncü kişiye karşı borcunu yerine getirme yükümlülüğü altına girer.

Kamu idareleri, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri sonucunda ihale üzerine bırakılan yüklenici ile sözleşme imzalamakta, yapılan işe karşılık ödeme yükümlülüğü altına girmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde, yüklenicinin ihale karşılığı idareden alacağı hakedişi ve diğer alacaklarının temlik edip edemeyeceği yapım işleri ihaleleri ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin Tip Sözleşmelerde belirtilmiştir.

Buna göre söz konusu Tip Sözleşmelerin "Ödeme yeri ve şartları" başlıklı maddesinde;

"Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir."

"Avans verilmesi şartları ve miktarı" başlıklı 13'üncü maddesinin dip notunda ise; "Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez." düzenlemeleri bulunmaktadır.

Bu kapsamda yapım işleri ihaleleri ve hizmet alımı ihalelerinde temlikin şartları belli olmasına rağmen, mal alımı ihalelerinde, danışmanlık ihalelerinde ve doğrudan temin yöntemiyle yapılan

alımlarda temlikin noter onaylı olması dışında temlik için başka şartın öngörülmediği sonucuna ulaşılmaktadır.

Mal alımı ihaleleri ve danışmanlık ihalelerinde yapım işleri ihaleleri ile hizmet alımı ihalelerinden farklı olarak avansın temlike konu edilemeyeceği ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde yer alan temliknamenin noter onaylı olması şartları dışında başka bir hüküm bulunmadığını söyleyebiliriz.

Ancak yapım işleri ihaleleri ile hizmet alımı ihalelerinde aşağıda belirtilen temlik şartları öngörülmüştür. İdareler bu şartların yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünü yaptıktan sonra yüklenicinin idareden alacakları ve hakedişi üzerine temlike izin verebilir.

- Yüklenicinin hakediş ve alacağının bulunması
- İdarenin yazılı izninin olması
- Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi
- İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Yukarıda temlik için gerekli şartlar ifade edilmişse de önem arz eden diğer bir husus ise, alacağın temliki suretiyle ilgili şahsın bütün alacaklarını rakamsal sınır olmadan devredip devredemeyeceği hususudur.

Bu kapsamda, vergi alacakları için ilgili Tahsilat Genel Tebliği uyarınca, kamu idarelerince yüklenicilere 5.000.- TL'nin üzerindeki hakediş ödemelerinde borcunun olup olmadığını araştırması ve bu yönde bir borcunun olması durumunda bahse konu tutarın üzerindeki borçlar için hakedişinden kesinti yapılması gerekmektedir.

Burada önem arz eden husus vergi alacakları açısından alacağa konu alımın gerek ihale kapsamı alım olsun, gerek doğrudan temin kapsamı alım olsun, vergi alacağı açısından bir farkın olmamasıdır. Yani vergi alacakları açısından alım türünün bir farkı yoktur.

SGK borcu açısından da ihale konusu işle ilgili olarak SGK'ya olan borçlarının olup olmadığının sorgulanması yani "borcu yoktur" yazısının istenilmesi ve bu bağlamda, idare yükleniciye hakediş ödemeleri sırasında yüklenicinin vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik

prim borcu olup olmadığını da kontrol etmesi gerekmektedir.

Ancak burada farklılık arz eden husus, SGK kapsamı alacaklar için alımın ihale türlerinden birisi ile yapılması kuralıdır. Yani doğrudan temin kapsamı alımlar için SGK borcu sorgulanmayacaktır. Çünkü SGK açısından ilgili mevzuat ihale kapsamı alım türleri itibarıyla bir sınır çizmiştir.

Alacağın temlikinde ise, ihaleyi yapan idarede ihale (aynı zamanda harcama) yetkilisinin alacağın temlikine (alacağın devrine) yetkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu işlemlerde, harcama yetkilisi, onayına sunulan temlikin şartlarının oluşup oluşmadığının kontrol etmesi ve şartların oluşmadığı durumda buna izin vermemesi gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili kişiler açısından hukuki sorumluluk gündeme gelebilmektedir.

Konu doğrudan temin açısından irdelendiğinde, bilindiği üzere bu kapsamdaki alımlar 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen durumların varlığı halinde istisnai olarak başvurulan bir yoldur. Yani ihale türlerinden farklı esaslara bağlanılan bir alım yöntemidir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Söz konusu alım yöntemi farklı esaslara bağlandığı için, doğrudan teminde sözleşme yapılması zorunlu yoktur. İsteğe bağlı olarak sözleşme yapılsa bile, ihale usullerinde olduğu gibi tip sözleşme kullanımı da zorunlu değildir. İster kullanır, ister kullanmaz.

Buna göre doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda idare ile yüklenici arasında sözleşme yapılmış ise ve bu sözleşmede temlik hususunda bir hüküm var ise bu hükmün uygulanması gerekir. Eğer sözleşme yapılmamış ise Borçlar Kanunu'ndaki temlik ile ilgili genel hükümler uygulanması gerekir. Yani buradaki tek şart temlikin noter onaylı olması olup, idarenin burada izninin alınmasına ilişkin mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır.

Çeşitli Sayıştay Kararlarında da yer aldığı üzere, idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme tarafları bağlamakta olup, böyle bir durumda Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması söz konusudur.

Diğer taraftan, alacağın temliki sürecinde vergi, sosyal güvenlik kurumu ile diğer idare ve kişilerin alacaklarının önceliğinin nasıl olması gerektiğini de açıklayabiliriz.

Devlete yani kamuya ait vergi alacakları ve bu alacaklara ait takip sürecinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Anılan Kanun hükümleri uyarınca, 5018 sayılı Kanun'a tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemeler ile bunların dışında ve 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamındaki ödemeleri için Tahsilât Genel Tebliği ile belirlenen 5000.- TL sınırını aşan ödemelerde vergi borcunun sorması gerekmektedir. Söz konusu Tebliğde;

"...5000.-TL sınırını aşan ödemelerde, işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirmede, maliye tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. Şu kadar ki bu hükmün uygulanmasında diğer kamu idarelerinin alacaklarına karşılık kesinti yapılması gereken hallerde kesinti tutarı garameten taksim olunur.
Diğer taraftan, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılmasını gerektiren ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, hak sahibi tarafından yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edecektir.
Dolayısıyla, hak sahipleri tarafından söz konusu ödemelere ilişkin olarak devir, temlik ve el değiştirme işlemi yapılmış olsa dahi ödenecek tutardan borç tutarı kadar kesinti yapılarak ilgili tahsil dairesi hesabına aktarılacaktır...."

Hususları yer almaktadır.

Buna karşın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması"

başlıklı 90'ıncı maddesinde;

"İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Yükleniciler, kendilerine yapılacak olan hakediş ödemelerini alacağın temliki yöntemiyle başkalarına devretmektedirler. Söz konusu uygulama bazı hallerde doğrudan mümkünken, bazı hallerde de idarenin iznine tabi tutulmaktadır.

Alacağın temlik edilmesi, bir alacağı kamu borcunun önüne geçirmez. Yani, hakediş ödemeleri yapılırken, öncelikle temlik edilen alacaklar değil, kamu borçları ödenir. Gerek 6183 sayılı Kanun'da, gerekse de 5510 sayılı Kanun'da yer aldığı üzere; zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu veya Kurum (SGK) alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade etmektedir. Yani verilen temlik, vergi ve işçi alacaklarından sonraki kısım için geçerlilik taşımaktadır.

Alacağı temellük edenin sigorta borcunu ise sorgulamaya gerek yoktur. Ancak kendi talebi üzerine, temlik alacağını sigorta borcuna mahsup talebinde bulunur ise takas talebinin ayrıca değerlendirilmesi mümkündür. Temellük edenin vergi borcunun ise sistemden sorgulanması gerekir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "Ödemenin kimlere yapılacağına" yönelik 8'inci maddesi;

"Ödeme; gerçek kişilerde alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine; alacaklının ölümü halinde varislere; tüzel kişilerde ise kanuni temsilcilerine veya

bunların tayin ettikleri vekillere; kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma yapılır. Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:
... h) Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesi"

Şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda yer aldığı üzere, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "Ödemenin kimlere yapılacağı"na ait 8'inci maddesi hükmü uyarınca, doğrudan temin yönteminde temlik yapılmış ise temlikin noter onaylı olması gerekmekte olup, bunun dışında herhangi bir şart öngörülmediğini mevcut düzenlemeler ışığında söyleyebiliriz.

Netice itibarıyla; alacağın temliki (alacağın devri), 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 183 ve devamı maddelerinde alacağın devri adıyla düzenlenmiş olup, anılan Kanun'a göre; Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Yine aynı Kanun hükümlerine göre; alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlı olup, alacağın temlikine izin veren idarenin, alacağı devralan üçüncü kişiye karşı borcunu yerine getirme yükümlüğü altına girdiğini (yükümlülük devam ettiğini) söyleyebiliriz.

80. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen hangi ödemelerde Taşınır İşlem Fişi (TİF) aranmaktadır?

Özet: *Doğrudan temin yöntemi mal ve malzeme alımlarında genel kural, TİF'in ödeme belgesine bağlanması gerekliliğidir. Ödeme sürecinde hangi belgelerin ve dolayısıyla TİF'in yer almasına ilişkin düzenleme ise, MYHBY'nin 63'üncü maddesinde yer almaktadır. Aynı Yönetmeliğin taşınır işlem fişine ilişkin istisnai hükümler başlıklı 66'ncı maddesinde ise, Taşınır Mal Yönetmeliği'ne göre taşınır işlem fişi düzenlenmesi öngörülmeyen hallerde bu belgenin aranmayacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu hususta hazırlanan rehberde yer aldığı üzere, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) arasında entegrasyon sağlanarak taşınır işlemlerine ilişkin harcama ve muhasebeleştirme süreçleri, elektronik olarak gerçekleştirilebilmesi olanağına kavuşturulmuştur. Bu bağlamda, doğrudan temin yöntemiyle de olsa taşınır işlem fişi düzenlenmesi gereken alımlara ilişkin olarak söz konusu belgenin düzenlenmesi ve ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir. Zira Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 63'üncü maddesi uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde; "Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi"nin ödeme belgesine bağlanacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla yukarıda yer verilen Yönetmelik maddeleri uyarınca, doğrudan temin yöntemi de olsa bahse konu işlemlerde TİF aranması gerekmektedir.*

İdare ihtiyaçları çeşitlilik göstermekte olup, söz konusu ihtiyaçlar niteliğine bağlı olarak ihale kapsamında karşılanabileceği gibi doğrudan temin yöntemiyle de karşılanması mümkündür. Tercih edilen alım şekline bağlı olarak uygulanacak prosedürler de şüphesiz farklılık gösterecektir. Şayet doğrudan temin kapsamında karşılanacak bir ihtiyaç ise, isteğe bağlı olarak birçok işlemin yapılmasına gerek bulunmayacaktır.

4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir.

Ayrıca, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı

maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi şeklinde doğrudan temin kapsamı alımları ifade edebiliriz.

5018 sayılı Kanun'a göre, kamu idareleri tarafından kurum bütçesinden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle ya da Kamu İhale Kanunu'na göre ihale yetkilisinin onay belgesini vermesiyle mümkün olmaktadır.

Doğrudan temin kapsamı olup, parasal limite bağlı olarak yapılan alımlar sonucunda, piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlenmektedir. Bu tutanakta, piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifler ve uygun görülen fiyat ile yükleniciyi göstermenin yanında söz konusu kişi veya kişilerce imzalanması söz konusudur. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde ise, şablon olarak örneği yer almaktadır. Aynı bilgileri kapsayacak şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir.

İhale kapsamı alımlarda, yüklenici tarafından sözleşme kapsamında teslimi yapılan mal veya malzemenin eksiksiz ve tam olarak teslim edildiğini teyit edilmesi gerekmektedir. Yani muayenesi yapılmalıdır. Bu bağlamda, muayene kabul komisyonu yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşacak şekilde kurulur. Ancak ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanun'a tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir. Komisyonun, görev ve sorumlulukları kapsamında, yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler, kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir.

Buna karşın, doğrudan temin kapsamı alımlarda muayene ve kabul komisyonu düzenlenmesi zorunlu değildir. İlgili muayene ve kabul yönetmeliğine benzer şekilde komisyon

kurulabileceği gibi, farklı bir şekilde de komisyon kurulabilir. Komisyon kurulmadan doğrudan idarece kabul işleminin yapılması da söz konusu olabilmektedir.

Muayene ve kabul sürecinde, yüklenici tarafından alıma ait fatura idareye teslim edilir. Fatura, kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen iş, mal veya hizmet alımlarında bu alımların özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerdir. Faturanın düzenlenmiş olması, bir anlamda satın alma işleminin yüklenici tarafından tamamlanmış olduğunu göstermektedir.

İdare ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlı olarak ekonomik değeri olan ve satın alınan mal ve/veya malzemelerin, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında idare hesaplarına giriş kaydının yapılması gerekir.

Bahse konu alıma konu mal veya malzemelerin doğrudan temin kapsamında da edinilmesi mümkündür. Bu çerçevede, taşınır mevzuatı ile doğrudan temin yöntemi arasındaki mevzuat boyutuyla bağlantı kurularak, satın alınan mal ve malzemelere ait taşınır bilgilerine değinilecektir. Ayrıca, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile doğrudan temin kapsamı alımlar da taşınırın boyutuyla ilişkilendirilecektir.

Taşınır işlemlerine ilişkin olarak, 5018 sayılı Yasa'ya dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği bulunmakta olup, söz konusu Yönetmelik ile kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Görüldüğü gibi, taşınırların edinme şekline bağlı kalınmadan kayıt işlemi ön görülmektedir.

Muayene ve kabul komisyonu istenilen mal veya malzemenin önceden belirtilen şartlara uygunluğu kontrol edilip uygun görüldüğü takdirde (mal alımlarında kısaca TİF denilen Taşınır İşlem Fişi düzenlenir) imza altına alınır. Doğrudan teminde komisyon kurulmadan da idarece aynı nitelikteki eşyanın muayene edilerek teslim alınması mümkündür.

Mal alımlarında satın alınan taşınır mal ve/veya malzemeler, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş kaydı yapılır. Söz konusu giriş

kayıtları taşınır işlem fişine dayanılarak yapılır. Her bir kaydın belirli bir belgeye dayandırılması şarttır. Söz konusu belgenin üzerinde belirtilen tarih ve sayısı taşınır işlem fişine kaydedilir.

Satın alınan tüketim malzemeleri, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından teslim alındıktan sonra üç nüsha olarak taşınır işlem fişi düzenlenir. Muayene ve kabul komisyonu tutanağının tarihi ve sayısı, fatura veya fatura yerine gecen belgenin tarihi ve sayısı ile satıcı firma bilgileri ve satın alınan malzemelerin taşınır kodları taşınır işlem fişine yazılır. Taşınır işlem fişinin ilk nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası ise muayene ve kabul komisyonu tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte sıralı bir şekilde dosyalanır.

En az üç nüsha düzenlenen taşınır işlem fişlerine, her mali yılbaşında 1' den başlamak üzere 1 sıra numarası verilir. Fiş dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz. Taşınır işlem fişinin elektronik ortamda düzenlemediği hallerde, seri ve sıra numaralı olarak bastırılmış fişler kullanılır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile ödeme sürecinde taşınır işlem fişinin ödeme belgesine bağlanması gereken durumlara yer verilmiş olup, incelendiği zaman bunların çeşitli olduğu görülmektedir.

Örneğin; 4734 sayılı Yasa'nın 3-e maddesi kapsamındaki istisnai alımlardan DMO kapsamı alımlara kadar birçok alım sürecinde TİF düzenlenmesi söz konusu olabilmektedir. Çünkü taşınırların edinme şekline bağlı olmadan kaydı mevzuata göre öngörülmektedir.

Ancak burada çalışma konumuzla bağlantılı olarak doğrudan temin kapsamı alımlar için TİF'in düzenlenme durumu ve ödeme belgesine eklenip eklenmeyeceği hususu açıklanmaktadır.

Konuyla bağlantılı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin "Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım giderleri" başlıklı 48 nci maddesi;"Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı,
-Taşınır işlem fişi,
ödeme belgesine bağlanır.
...
Alımı bir merkezden yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır."

Aynı Yönetmeliğin "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar" başlıklı 63. Maddesi ise; " 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde;
- Onay Belgesi ,
- Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Fatura,
- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
-Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi,
ödeme belgesine bağlanır..."

Şeklinde düzenlenmiştir.

Dolayısıyla yukarıda yer verilen Yönetmelik maddeleri uyarınca, bahse konu işlemlerde TİF aranması gerekmektedir.

Buna karşın, Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesinde ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 66'ncı maddesinde taşınır işlem fişinin düzenlenmeyeceği belirtilen taşınır alımlarında, ödeme emri belgesine taşınır işlem fişinin bağlanmaması gerekmektedir. Benzer şekilde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ'de de taşınır işlemlerine ilişkin açıklamalar yapılmış ve taşınır alımlarında ödeme emri belgesine bağlanmayacak taşınır işlem fişleri hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Bu bağlamda, aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.

- Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler,

- Tesis, makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar,

- Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları,

- Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri,

- Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler.

Ancak bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan bakım-onarım yedek parçaları ile likit gaz, akaryakıt ve yağlar için taşınır işlem fişi düzenlenir. Dergi ve gazete gibi süreli yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

Dolayısıyla, Taşınır Mal Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde taşınır işlem fişinin düzenlenmeyeceği belirtilen taşınır alımlarında ödeme emri belgesine taşınır işlem fişinin bağlanmaması gerekmektedir.

Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimce iki nüsha taşınır geçici alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere taşınır işlem fişi düzenler.

Taşınır işlemlerinin KBS'yi de ilgilendiren boyutu bulunmaktadır. Zira KBS içerisinde birçok sistemi barındıran bir yazılımdır. Bu yazılımdaki sistemler muhasebe birimleriyle birlikte çalışır. Şöyle ki KBS üzerinde yapılan bir işlem muhasebe birimini ilgilendiriyor ve muhasebe

kaydı gerektiriyorsa, muhasebe sistemine gönderilir ve burada muhasebeleştirilir. KBS içerisinde taşınırların (TKYS) izlenmesi için de modüller bulunmaktadır. KBS ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanması hedeflenmiştir.

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) KBS içerisinde yer alan uygulamalardan biridir. Bu uygulama ile idarelerce tüm taşınır işlemleri bu uygulamada yerine getirilmektedir. Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) arasında entegrasyon sağlanarak taşınır işlemlerine ilişkin harcama ve muhasebeleştirme süreçleri elektronik olarak gerçekleştirilebilme olanağına kavuşmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) hazırlanan Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu çerçevesinde; Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) içerisinde önemli bir değişiklik söz konusu olmayıp, Entegrasyon, onaylı Taşınır İşlem Fişlerinde (TİF) yer alan veriler baz alınarak, maddi ve maddi olmayan tüm varlık işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde gerekli belge olarak tasarlanan Varlık İşlem Fişlerinin (VİF) oluşturulması ve süreçte bir sonraki sisteme elektronik iletimiyle sağlanmaktadır. Bu bağlamda, TKYS'ye Onaylı Taşınır İşlem Fişleri alt menüsünde butonlar bulunmaktadır.

Bu butonlar ile seçilen her bir onaylı TİF'e ilişkin VİF belgesini oluşturarak güvenli tekil bir numarayla ilgisine göre harcama veya muhasebe sistemine gönderilmesini sağlar. Aynı şekilde, VİF Durum Sorgula butonu ile de seçili her bir onaylı TİF'in sürecin hangi aşamasında olduğunu dair sorgulama yapılır. Sorgu sonucunda "Muhasebe (Fiş Durumu)" sütunu güncellenir.

TKYS'nin BKMYBS'yle entegre olması iki ayrı sistemin iletişimi şeklinde olduğundan, üzerinde işlem yapılan yahut kontrol edilmek istenen TİF'ler için TKYS'de yer alan VİF Durum Sorgula butonunun kullanılması mümkündür.

Diğer taraftan, Mali Yönetim Sistemi (MYS), "Harcama Talimatı Onay Belgesi" ile "Ödeme Emri Belgesi"nin e-belge standartlarına uygun olarak elektronik ortamda hazırlamasına ve harcama işlemlerini yürütebilmesine imkân tanıyan bilişim sistemidir. Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında entegrasyonu sağlayan MYS, vergi borcu sorgu, ödeme belgesi,

aboneliğe bağlı ödemeler ve e-yolluk uygulamalarını kapsamaktadır. Mali Yönetim Sistemi (MYS) Personel ödemeleri dışında kalan su, elektrik, doğalgaz, telefon ödemeleri gibi aboneliğe bağlı ödemeler, her türlü mal ve hizmet alımı ödemeleri, tarifeye bağlı ödemeler, ilama bağlı borç ödemeleri kısacası bir harcama biriminde 4/A ve 4/B personel ödemeleri dışındaki bütün ödemeler ve 4/C personel ödemeleri ve geçici personel ödemeleri MYS üzerinden hazırlanarak muhasebe birimine gönderilir.

Mali Yönetim Sistemi (MYS), MYS'de Varlık Yönetimi menüsü altında 'VİF Listesi'ne ulaşıldığında ilgili harcama biriminde TKYS'den oluşturularak gönderilen Satın Alma ve Değer Artırımı TİF'lerine ait VİF'ler ekranda listelenmektedir. VİF Listesinde istenilen VİF seçilerek Görüntüle butonu yardımıyla VİF görüntülenebilir. Aynı fatura ile alımı gerçekleşen taşınırlar tek bir VİF belgesinde yer alarak tek bir ödeme emri belgesi oluşturulmasına zemin hazırlanmaktadır.

VİF'ler, ancak Mal ve Hizmet Alımı harcama türü altındaki Taşınır Mal Alımı ile Diğer Mal Alımı alt türleri veya Temsil ve Tanıtma Gideri harcama türü seçilerek oluşturulan harcama talimatlarıyla ilişkilendirilebilir. Harcama talimatıyla ilişkilendirilen bir VİF için kullanıcı, Durum sütununda yer alan harcama no linkine tıklayarak harcama talimatına ulaşır ve ödeme emri oluşturma aşamasını başlatabilir.

Ödeme emri detay bilgilerinde, hak sahibinin (öeb'nin ilgilisinin) VKN/TCKN verisi, ödeme kalem türleri ve tutarlar otomatik olarak oluşturulmakta ve değiştirilmesine olanak tanınmamaktadır. Bu hususlar haricinde MYS'de oluşturulan diğer ödeme emirlerinden farklı bir kontrol veya işleyiş söz konusu değildir. Aynı faturada yer alıp, mevzuatı gereği taşınırın maliyetine eklenemeyen kalemler mevcut ise, yeni detay eklenmek suretiyle aynı ödeme emrinde taşınır haricinde de ödeme kalemi oluşturulabilmektedir.

81. Doğrudan temin kapsamı alımlarda ihaleye fesat karıştırma suçu oluşur mu?

Özet: *Türk Ceza Kanunu'nda ihale süreci ve edimin ifası sürecine fesat karıştırma şeklinde iki suç ayrı tanımlanmış olup, ihale süreci ile ilgili yaptırımlar ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında iken, sözleşmenin uygulanması sürecine ilişkin fiiller ise edimin ifasına fesat karıştırma suçu kapsamındadır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu kaynağı kullanılarak gerçekleştirilen alımlara ilişkin yaptırımlar kapsamında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca ihaleye fesat karıştırma suçunun işlenebilmesi için söz konusu alımın ihale türleri kapsamında gerçekleştirilmesi gerekir. Doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılmadığından bu alım yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda ihaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesi söz konusu değildir. Ancak doğrudan temin kapsamı alımlarda TCK'nın 257'nci maddesinde yer alan görevi kötüye kullanma suçunun işlenmesi mümkündür. Bununla birlikte, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda edimin ifasına fesat karıştırma suçunun işlenmesi mümkün olup, bu husus ayrı bir başlık altında incelenmektedir.*

4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi uygulanmasını gerektiren alımlar düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların genel alım yöntemi olan açık ihale usulü ile veya Kanun'daki şartların bulunması halinde belli istekliler arasında ihale usulü ya da pazarlık usulü ile ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde ise *"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…"* şeklinde Yasa'nın temel ilkeleri sıralanmıştır.

Anılan Kanun'un 22'nci maddesinde yer alan doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü değildir ve bu sebeple ihale usullerinin tabi olduğu mevzuata da tabi olmak zorunda değildir. Kamu

İhale Genel Tebliğince öngörülen zorunluluklar nedeniyle sözleşme düzenlenmişse, söz konusu sözleşmede öngörülen hususlara aykırılıklar yaptırıma konu olacaktır. Çünkü hukuken geçerli bir sözleşmenin varlığı söz konusudur.

Nitekim konuyla bağlantılı birçok Sayıştay Kararında da alımın doğrudan temin kapsamında yapılması ve bu alıma ilişkin olarak sözleşme düzenlenmesi zorunlu ise, bu sözleşmelerin taraflar için bağlayıcı olacağı hususu dile getirilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda, 4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklikle, doğrudan temin bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır. Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü değildir ve bu sebeple ihale usullerinin tabi olduğu mevzuata da tabi olmak zorunda değildir.

Bu durumda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların Kanun'un ihale usulleri için belirlenen kurallarına uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyacın temin edilmesi şeklinde doğrudan temin kapsamı alımları özetleyebiliriz.

Her ne kadar doğrudan temin kapsamı ihale usulleri arasında sayılmasa da söz konusu alım yöntemi için de belli kurullar belirlenmiş olup, bu kurallara aykırı davranmalar ise yaptırım uygulanmasına neden olacaktır.

Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı" başlıklı maddesinde (28.1.10.); *"...doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez."* açıklaması yer almaktadır. Söz konusu düzenleme, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da 4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen usulsüzlüklerden birinin gerçekleştirilmesi durumunun ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği hususunu açıklığa kavuşturmaktadır.

Zira rüşvet vermek, sahte evrak düzenlemek gibi yasak fiiller ve davranışlar, aynı zamanda TCK kapsamında tanımlanmış suçlar olması nedeniyle, 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında tanımlanan bir suçu uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği açıktır. Zira her şeyden söz konusu Kanunların kapsam ve nitelikleri farklıdır. Hatta bahse konu fiillere memurların iştiraki halinde, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri gereğince, izin almadan adli makamlarca ilgili personelin resen soruşturulması söz konusudur.

Bu bilgi ışığında, doğrudan temin kapsamı alımlar açısından ihaleye fesat karıştırma suçunun gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirebiliriz. Öncelikle 5237 sayılı TCK'nın Ekonomi, Sanayi ve Ticarete ilişkin suçlar kapsamında yer alan ve 235'inci maddesinde yer alan "*İhaleye fesat karıştırma"* suçuna ilişkin madde hükümlerine bakacak olursak, söz konusu maddenin;

"(1) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:
a) Hileli davranışlarla;
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,
3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.
b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.
d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.
(3) (Değişik: 11/4/2013-6459/12 md.) İhaleye fesat karıştırma suçunun;

a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.
b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.
(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması halinde de uygulanır."

Hükmüne amir olduğu görülür.

Madde metninde açık bir şekilde görüldüğü üzere; ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşabilmesi için kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal, hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım işi ihaleleri kapsamında söz konusu suçun işlenmesi gerekir. Hâlbuki 15.08.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile doğrudan temin bir ihale usulü olmaktan çıkarılmış olup, bir alım yöntemi haline getirilmiştir. Dolayısıyla doğrudan temin bir ihale türü olmadığından yapılan alımlarda ihaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesi mümkün değildir.

Konunun anlaşılmasına katkı yapmak amacıyla bu hususla bağlantılı bir Yargıtay Kararını örnek olarak irdeleyecek olursak, Yargıtay 5'inci Dairesi'ne ait bir Kararda; *Dairelerinin istikrar kazanan uygulamalarına göre ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için kanunlarda öngörülmüş ihale usullerinden biri kapsamında alım yapılması gerektiği, doğrudan temin yönteminin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18. maddesinin (d) bendinde bir ihale usulü olarak öngörülmüş iken, 4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunda değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12. maddesi ile "4734 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (d) bendi madde metninden çıkarıldığı, doğrudan temin yönetiminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde*

metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu ifade edilerek; sanıklara atılı ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı, ……. sübutu kabul olunan eylemlerin zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı,…" hususlarının yer aldığı görülmektedir.

Yukarıda yer aldığı üzere, ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi için kanunlarda öngörülmüş ihale usullerinden biri ile usulüne uygun yapılmış ya da yapılacak bir ihale olmasının zorunlu olduğu, doğrudan temin yönteminin ise bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın yöntemi olması nedeniyle bu kapsamdaki alımlarda ihaleye fesat karıştırma suçunun değil görevi kötüye kullanma suçunu oluşacağı ifade edilmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 235'inci maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçu, 4734 sayılı Kanun'un uygulanması açısından, anılan Kanun'a tabi mal veya hizmet alımı ile yapım işi ihalelerinde ortaya çıkmakta olup, ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan biçimsel kanunilik ilkesi gereğince, suçun gerçekleşmesi için kamu kurum ve kuruluşları adına ihale türleri kapsamında yapılan/yapılacak alımlara fesat karıştırılması gerekmektedir.

Başka bir ifadeyle, ihaleye fesat karıştırma suçu bakımından önemli olan nokta, suça konu olacak nitelikteki bir ihalenin varlığıdır. Bu itibarla 4734 sayılı Kanun'da ihale usulleri arasında sayılmayan doğrudan temin yöntemi ile gerçekleşen alımların, suçun konusunun yokluğu nedeniyle, ihaleye fesat karıştırma suçunun konusunu teşkil edemeyeceği düşünülmektedir.

Nitekim Yargıtay'ın istikrar kazanmış kararlarına göre de doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle, bu yöntemle yapılan alımlarda 5237 sayılı Kanun'un 235'inci maddesinin uygulanması imkânı bulunmamakta, ancak koşulları oluştuğu takdirde bu yöntemle gerçekleştirilen alımlardaki fiiller, 5237 sayılı Kanun'un 257'nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabilmektedir.

4734 sayılı Kanun'un "İsteklilerin cezaî sorumluluğunun" düzenlendiği 59'uncu maddesinde, taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17'nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edilmiş ve hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 58'inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58'inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanacakları belirtilmiştir.

Haklarında bu şekilde ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58'inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları öngörülmüştür.

Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler ile mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilmekte olup, sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle duyurulması söz konusudur.

Kamu görevlilerinin sorumluluğunun düzenlendiği 60'ıncı maddesinde ise; "İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler." hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere; ihale sürecinde Kanun'da yer alan esaslara uyulmaması durumunda gerek istekliler gerek kamu görevlileri bakımından birtakım idari yaptırımlar öngörülmüş, aynı zamanda bu fiillerin Türk Ceza Kanunu'nda da suç kapsamında tanımlanması halinde, söz konusu sorumluluk açısından da yaptırım uygulanmasının gündeme geleceği vurgulanmıştır.

Tekrar vurgulamak gerekirse, 5237 sayılı Kanun'un "İhaleye fesat karıştırma" başlıklı 235'inci maddesinde, kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım işi ihaleleri için öngörülmüştür. Söz konusu madde de ayrıca, hangi durumlarda ihaleye fesat karıştırma sayılacağı tek tek belirtilmiştir.

Bu bağlamda, ceza hukukumuzda geçerli olan "Suçların ve Cezaların Kanuniliği" ilkesi uyarınca, ancak kanunda suç sayılan hâllerde ve Kanun'da öngörülen ceza ile cezalandırılabilir. Dolayısıyla, Kanun'da o suçun varlığı için aranılan koşullar sağlanmıyorsa, suçun varlığından söz edilemediği gibi, cezalandırma da söz konusu olamaz.

Bu itibarla, doğrudan temin bir ihale usulü olmayıp alım yöntemi olduğu için Kanun'un aradığı "Tipiklik" şartına uymadığından bu alım içi ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşması söz konusu değildir. Tipiklik, fiilin kanunda tanımlanan suç tipinin unsurlarını taşımasını ifade etmekte olup, Kanun'da o suçun varlığı için aranılan şartların taşınmaması durumunda suçun varlığından da söz edilemez ve cezalandırma cihetine gidilemez. Nitekim Yargıtay Kararları da bu yöndedir.

Buna karşın, doğrudan temin yönteminde herhangi bir cezai işlemin uygulanmayacağı şeklinde bu durum yorumlanmamalıdır. Çünkü alım yöntemi farklı da olsa doğrudan temin kapsamında da bir kamu kaynağı kullanılmaktadır. Kamu kaynağının doğru bir şekilde kullanılmaması ise, şüphesiz yaptırım uygulanmasını gerektirecektir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı" başlıklı maddesinin ilgili bölümünde,*"...doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez."* düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu hüküm, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da 4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen usulsüzlüklerden birinin gerçekleştirilmesi durumunun ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğine karşılık gelmektedir.

Zira rüşvet vermek, sahte evrak düzenlemek gibi yasak fiiller ve davranışlar, aynı zamanda TCK kapsamında tanımlanmış suçlar olması nedeniyle, 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümleri

aracılığıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında tanımlanan ilgili suç maddesine gidilmesi gerekmektedir.

Bahse konu fiillere memurların iştiraki halinde, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 17'nci maddesi hükmü gereğince, 4483 sayılı Yasa'dan farklı olarak izin almadan adli makamlarca ilgili personelin resen soruşturulması söz konusu olabilmektedir.

82. Doğrudan temin kapsamı alımlarda edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenebilir mi?

Özet: *İhale sürecine ilişkin işlemlerde 4734 sayılı Kanun hükümleri yani kamu hukuku geçerli iken, sözleşme imzalandıktan sonraki süreç 4735 sayılı Yasa'da yer aldığı üzere, özel hukuk hükümleri çerçevesinde şekillenmektedir. TCK'da, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifası sürecine fesat karıştırma şeklinde iki suç ayrı düzenlenmiş olup, ihale süreci ile ilgili yaptırımlar ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında iken, sözleşmenin uygulanması sürecine ilişkin fiiller ise edimin ifasına fesat karıştırma suçu kapsamındadır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu kaynağı kullanılarak gerçekleştirilen alımlara ilişkin yaptırımlar kapsamında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca ihaleye fesat karıştırma suçunun işlenebilmesi için söz konusu alımın ihale türleri kapsamında gerçekleştirilmesi gerekir. Doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılmadığından bu alım yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda ihaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda edimin ifasına fesat karıştırma suçunun işlenmesi mümkündür. Çünkü söz konusu fiil için Yasa maddesinde alım şekline yönelik bir kriter belirlenmemiştir.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu Yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale kapsamında sözleşmenin imzalanmasındaki süreç ise bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir.

Kamu İhale Mevzuatı uyarınca gerek ihale usulleri kapsamında olsun ve gerekse doğrudan temin yöntemiyle olsun, belirlenen kurallara uymamak çeşitli yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir. Bunlar adli veya idari düzeyde olabilir.

Adli nitelikteki takibatı gerektiren fiiller 5237 sayılı TCK'da yer almakta olup, söz konusu Türk Ceza Kanunu'nda bu hususta "İhaleye fesat karıştırma" ve "Edimin ifasına fesat karıştırma" olmak üzere iki ayrı suç tanımlanmıştır.

Kamu alımlarında sözleşme imzalanması ve sözleşme gereği edimin yerine getirilmesi süreci 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlendiği Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesinde sözleşme yapılırken geçerli olacak temel ilkelere yer verilmiştir. Buna göre; sözleşmede ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceği, Kanunda belirtilen durumlar dışında sözleşmede değişiklik veya ek sözleşme yapılamayacağı ve sözleşmenin uygulanmasında tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olacağı öngörülmüştür. Ayrıca, hüküm bulunmayan durumlarda, Borçlar Kanunu hükümlerinin dikkate alınacağı da öngörülmüştür.

Bu çerçevede, kamu kaynakları kullanılmak suretiyle yapılan sözleşmelerde yer alan taahhüt edilen işe ilişkin yükümlülüklerin yerine hiç getirilmemesi veya eksik getirilmesi suretiyle sözleşmeye aykırı davranılması durumunda ceza hukuku bakımından birtakım müeyyideler söz konusu olabilmektedir. Bahse konu yaptırım ise, TCK'da yer alan edimin ifasına fesat karıştırma suçu olup, söz konusu fiile değinmezden önce, konuyla bağlantılı 4735 sayılı Yasa'nın ilgili maddelerine değinebiliriz.

4735 sayılı Yasa'nın;

"Yasak fiil ve davranışlar" başlıklı 25'inci maddesi; *"Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:*

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.
d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.
e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek.
f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.
g) Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması."

Hükmüne amirdir.

Anılan Yasa'nın "İhalelere katılmaktan yasaklama" başlıklı 26'ncı maddesi uyarınca, 25'inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2'nci ve 3'üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi öngörülmüştür.

4735 sayılı Yasa'nın "Yüklenicilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 27'nci maddesi uyarınca ise iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25'inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Anılan Yasa'nın "Görevlilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 28'inci maddesi uyarınca da muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

4735 sayılı Yasa'nın "İdarenin sözleşmeyi feshetmesi" başlıklı 20'nci maddesi uyarınca, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25'inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve ayrıca, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İlave olarak 4735 sayılı Yasa'nın "Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı" ile belirlenen hususlara aykırı hareket edenler hakkında ilgisine göre 26 veya 28'inci maddede belirtilen müeyyideler uygulanması gerektiğini yine anılan Yasa hükümleri uyarınca ifade edebiliriz.

Bunlarla birlikte, yapım işlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin, danışmanlık hizmeti sunucularının, tedarikçilerin ve hizmet sunucularının sorumluluğu kapsamında, öngörülen yaptırımlar haricinde ayrıca haklarında 27'nci madde hükümlerinin uygulanmasını gerektiğini ifade edebiliriz. Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu kapsamında ise sorumlular hakkında ayrıca 28'inci madde hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 236'ncı maddesine baktığımızda ise söz konusu maddede; *"Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır"* hükmüne yer verilmek suretiyle edimin ifasına fesat karıştırma kabul edilen hâller sayılmış olup, edimin ifasına fesat karıştırma suçundan söz edilebilmesi için failin davranışının Kanun hükmünde sayılan fiillerden birini oluşturması yani Kanun'daki suç tanımına (tipiklik şartına) uyması gerekmektedir. Bu bağlamda TCK'nın 236'ncı maddesinde yer alan suça ilişkin madde metnine aşağıda yer verebiliriz.

TCK'nın "Edimin ifasına fesat karıştırma" başlıklı 236'ncı maddesi;

"(1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması halinde, edimin ifasına fesat karıştırılmış sayılır:
a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın teslim veya kabul edilmesi.
b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya kabul edilmesi.
c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi.
d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul edilmesi.
e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi.
(3) Edimin ifasına fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu

nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar. "

Hükmüne amirdir.

Edimin ifasına fesat karıştırma sayılan haller, Kanun'da, hileli davranış ön koşuluna bağlı olarak yukarıdaki gibi sıralanmış olup, söz konusu suç, yukarıda sayılan unsurlardan birinin kasten yani bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi ile tamamlanır. Kanun'da suçun tamamlanması için herhangi bir zarar meydana gelmesi şartı aranmamıştır. Tedbirsizlik veya bilgisizlik sebebiyle fiilin gerçekleşmesi durumunda suç oluşmaz. Suçun faili kamu görevlileri olabileceği gibi diğer kişiler de olabilir.

Bu hususta Yargıtay 5. Ceza Dairesince verilen bir Kararda; "5237 sayılı TCK'nın 235 ve 236. maddelerinde İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddelerde sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasa'nın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı, her ne kadar bir kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metinleri gerekçeleriyle birlikte incelendiğinde; 235. maddenin 2. fıkrasının "a" ve "b" bentlerinde sayılan hallerde ihale sürecinde görev alan ilgili kamu görevlileri, "d" bendinde belirtilen halde ise ihaleye katılan ya da katılmak isteyen kişilerin suçun faili olabileceği, 236. maddenin 2. fıkrasının "a" ve "b" bentlerinde yüklenici konumundaki kişiler ve temsilcileri ile edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerinin, "c", "d" ve "e" bentlerinde ise edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerinin suçun faili olabileceği, dolayısıyla söz konusu suçların özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiği, bu itibarla 5237 sayılı TCK'nın 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan ve TCK'nın 235/2(a2) maddesi uyarınca ihale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçuna ya da TCK'nın 236/2e maddesi uyarınca ihale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri gözetilmelidir." hususlarının yer aldığını görmekteyiz.

Öte yandan, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma

ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklı olduğu yönündeki hükmü uyarınca edimin ifasına karıştırma suçu için farklı bir usul öngörülmüştür.

Nitekim 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerinin de bu süreçte dikkate alınması gerekmekte olup, Kanun'un 17'nci maddesinde; "Bu kanunda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı" belirtilmiştir.

Bu itibarla, kamu görevlilerinin gerek ihaleye fesat karıştırma gerek edimin ifasına fesat karıştırma suçunu işlediklerine dair delil elde edilmesi hâlinde Cumhuriyet Savcısı diğer kişilerde olduğu gibi kamu görevlileri hakkında da doğrudan soruşturma yapmak suretiyle kamu davası açabilecektir. Çünkü bu suç, takibi şikayete bağlı suçlar kapsamında değildir.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçlar ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçların, idarece ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan temin yöntemiyle karşılanması mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, konuyla bağlantılı yargı kararlarının incelenmesinde edimin ifasına fesat karıştırma suçunun doğrudan temin kapsamı alımlar için de gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır. Zira konuyla bağlantılı örnek niteliğinde Yargıtay 5. Ceza Dairesinin bir Kararında da doğrudan temin yöntemiyle satın alınan ve edimin ifası sırasında taahhüt edilenden farklı markanın yüklenici tarafından teslim edilmesine ilişkin olarak piyasa araştırma tutanağı, teklif mektubu ve teklif açma tutanağında marka gösterilmeden alınan malın cinsi olarak sadece "dijital fotokopi makinesi 1650" ibaresine yer verildiği dikkate alınarak, ihale mevzuatı ve suça konu fotokopi makinelerinden anlayanlardan oluşturulacak bilirkişi heyetinden sanıkların hile kullanarak idareye sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka malı teslim edip etmedikleri hususlarında açıklayıcı rapor alınmasından sonra hasıl olacak sonuca göre hukuki durumlarının tayin ve takdir edilmesi gerekliliğine vurgu yapmak suretiyle doğrudan temin kapsamı

alımlarda edimin ifasına fesat karıştırma suçunun söz konusu olabileceği ifade edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı" başlıklı maddesinde;*"...doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez."* hususu yer almaktadır. Söz konusu hüküm, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da 4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen fillerden birinin gerçekleştirilmesi durumunun ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğine dikkat çekmektedir.

Zira rüşvet vermek, sahte evrak düzenlemek gibi yasak fiiller ve davranışlar, aynı zamanda TCK kapsamında tanımlanmış suçlar olması nedeniyle, 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümleri aracılığıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine gidilmesi gerekmektedir. Çünkü bahse konu suç TCK'da yer almakta olup, cezası da anılan Kanun'da hükme bağlanmıştır. Hatta bu fiillere memurların iştiraki halinde, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri gereğince, izin almadan adli makamlarca ilgili personelin resen soruşturulması da söz konusu olmaktadır.

83. Doğrudan temin kapsamında firmadan alınan "yazılı teklif" teklif sahibini bağlar mı?

Özet: *Doğrudan temin kapsamı alıma ilişkin olarak idareye vermiş olduğu fiyat teklifinin gereğini yerine getirmek istemeyen isteklinin varlığı halinde idare, her şeyden önce taahhüdünü yerine getirmeyen istekliden bundan sonra alım yapmaktan kaçınabilir. Doğrudan temin yöntemi ihale türlerinden biri olmadığı için her ne kadar ihalelerden yasaklama kararı verilmesi mümkün olmamakla birlikte, idare bu süreçte şayet bir zararı uğramışsa genel hükümlere göre bu zararın giderilmesini isteyebilir. Ayrıca, teklif sahibinin (esnaf/tüccar) meslek durumuna bağlı olarak bağlı olduğu meslek örgütüne konunun intikali suretiyle ilgili için disiplin cezası hükümlerinin işletilmesinin de söz konusu olabileceğini ifade edebiliriz. Bu itibarla, idarenin önem arz eden ve gecikmesinde sakıncası olacağını düşündüğü alımları için sözleşme yapılmasının -bu sözleşmelerin geçerli olduğu dikkate alınarak- idare haklarını korumak adına daha yararlı olacağı düşünülmektedir.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin yönteminde, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu usulde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Ancak taraflar doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda sözleşme imzalamışsa, sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi temel ilke olarak kabul edilmelidir.

Konuyla bağlantılı birçok Sayıştay Kararının incelenmesinden de alımın doğrudan temin yöntemiyle yapılması ve bu alıma ilişkin olarak sözleşme düzenlenmişse bu sözleşmelerin taraflar için bağlayıcı olacağı belirtilmiştir. Şöyle ki;

Örnek nitelikte bir Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin usulünde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarelerin takdirinde olduğu belirtilerek, bu aşamadan sonra artık idare ve yüklenici, alımının doğrudan temin usulüyle yapıldığından bahisle aralarında imzalamış

oldukları bu sözleşme hükümlerine aykırı davranamayacakları belirtilerek, sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesinin mevzuata aykırılık oluşturmadığı ifade edilmiştir.

Bu bağlamda, doğrudan temin yönteminde istekli, piyasa fiyat araştırması sonucuna ilişkin malı teslim etmeden bu teklifinden vazgeçebilir mi, farklı bir anlatımla taahhüdünü yerine getirmezse herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususunu irdeleyebiliriz.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun (KİK) "Tanımlar" başlıklı maddesinde: "Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" şeklinde tanımlanmıştır.

Doğrudan temin kapsamı alımlarda genel kural, sözleşme düzenlenmesi hususu idarelerin takdirinde olmakla birlikte, 22'nci madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumu ile 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükmü uyarınca, ihalelere ilişkin sözleşmelerde değişiklik yapılmaması genel kural olmakla birlikte, bazı hallerde değişiklik yapılabilmesine yasal olanak tanınmıştır. Keza söz konusu Kanun'un 15'inci maddesine göre, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, "İşin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları"nda değişiklik yapılabilmektedir.

Bu bağlamda, 4734 ve 4735 sayılı Yasalar çerçevesinde, ihale süreçlerini genel olarak iki kategoriye ayırabileceğimizi, bu evrelerin sözleşme öncesi ve sonrası dönemler olduğunu, bu dönemlerden sözleşme öncesi dönemin 4734 sayılı Kanun kapsamına girdiği ve bu sürecin ihale onayının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar sürdüğünü, buna karşın sözleşme sonrası dönemin ise, 4735 sayılı Kanun kapsamı çerçevesinde, sözleşmenin imzalanmasından sonra başladığını ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin dönemi kapsadığını söyleyebiliriz.

Söz konusu dönem farklılıkları sadece kategorik bir inceleme için ayrılmayıp, uygulanan

mevzuat açısından da farklılık arz etmektedir. Keza sözleşme öncesi dönemi ilişkin iş ve işlemler KİK'e itirazen şikayet konusu olurken, sözleşme sonrası dönem ise dava konusu olabilmektedir.

4735 sayılı Kanun, Kamu İhale Kanunu'na tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsamaktadır.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile de hükme bağlandığı üzere; Kanun kapsamında yapılan sözleşmelerin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği gibi, Kanun'un yorum ve uygulanmasında da bu prensibin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bundan dolayıdır ki, yine aynı Kanun hükmü gereğince, 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağının hükme bağlanması ve söz konusu Kanun'la da tarafların eşitliğinin ilke edinilmesi ve sözleşme hükümlerine aykırılığın da yaptırıma bağlanmasını, yapılan işlemlerde dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak vurgulayabiliriz.

Bu çerçevede, idareye sunduğu teklife bağlı kalmak istemeyen bir kişinin durumu anılan bilgiler çerçevesinde öncelikle Borçlar Kanunu hükümleri ortaya koyup, sonrasında bahse konu durumun Borçlar Kanunu ile ilişkisini açıklayabiliriz.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK)

A. Sözleşmenin kurulması

I. İrade açıklaması

1. Genel olarak

1. Maddesinde; *Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacağı, İrade açıklamasının, açık veya örtülü olabileceği,*

İkinci derecedeki noktalar başlıklı 2. maddesinde; *Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılacağı,*

II. Öneri ve kabul

Süreli öneri başlıklı 3. maddesinde; *Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını önerenin, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle bağlı olduğunu, kabul bu süre içinde kendisine ulaşmazsa; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulacağı,*

2. Süresiz öneri

"a. Hazır olanlar arasında" başlıklı 4. maddesinde; *Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye yapılan öneri hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulacağı, telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan önerinin, hazır olanlar arasında yapılmış sayılacağı,*

"b. Hazır olmayanlar arasında" başlıklı 5. maddesinde; *Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olmayan bir kişiye yapılan öneri, zamanında ve usulüne uygun olarak gönderilmiş bir yanıtın ulaşmasının beklenebileceği ana kadar, önereni bağlayacağı, önerenin, önerisini zamanında ulaşmış sayabileceği, zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve öneren onunla bağlı olmak istemezse, durumu hemen kabul edene bildirmek zorunda olduğu,*

"3. Örtülü kabul" başlıklı 6. maddesinde; *Önerenin, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek zorunda değilse, öneri uygun bir sürede reddedilmediği takdirde, sözleşmenin kurulmuş sayılacağı,*

"5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri" başlıklı 8. maddesinde; *Önerenin, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse veya işin özelliğinden ya da durumun gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisi kendisini bağlamayacağı, fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılacağı,*

"7. Önerinin ve kabulün geri alınması" başlıklı 10. maddesinde; *Geri alma açıklamasının, diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa, önerinin yapılmamış sayılacağı, bu kuralın, kabulün geri alınmasında da uygulanacağı,*

"III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı" başlıklı 11. maddesinde; *Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmelerin, kabulün gönderildiği andan başlayarak hüküm doğuracağı, açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hüküm doğuracağı,*

B. Sözleşmelerin şekli

"I. Genel kural" başlıklı 12. maddesinde; *Sözleşmelerin geçerliliğinin, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı olmadığı, kanunda sözleşmeler için öngörülen şeklin, kural olarak geçerlilik şekli olduğu, öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmelerin hüküm doğurmayacağı,*

II. Yazılı şekil

1. Yasal şekil

"a. Kapsamı" başlıklı 13. maddesinde; *Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulmasının zorunlu olduğu, ancak, sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümlerin bu kuralın dışında olduğu, bu kuralın, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanacağı,*

"b. Unsurları" başlıklı 14. maddesinde; *Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunlu olduğu, kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçeceği,*

"c. İmza" başlıklı 15. maddesinde; *İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılmasının zorunlu olduğu, güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağı, imzanın el yazısı dışında bir araçla atılması, ancak örf ve âdetçe kabul edilen durumlarda ve özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılacağı,*

"2. İradi şekil" başlıklı 17. maddesinde; *Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan*

sözleşmenin tarafları bağlamayacağı, herhangi bir belirleme olmaksızın yazılı şekil kararlaştırılmışsa, yasal yazılı şekle ilişkin hükümler uygulanacağı,

"II. Kesin hükümsüzlük" başlıklı 27. maddesinde; *Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüz olduğu, sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemeyeceği, ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamının kesin olarak hükümsüz olacağı,*

Hususları hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre; Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olmadığı sürece sözleşmeler geçerli olup, sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun açıklamalarıyla kurulabilmektedir. Ancak ilgili kişi teklifinde teklifinin belli bir süre için geçerli olduğunu söylerse, bu sürenin sonunda teklifi geçerliliğini yitireceği için sorumluluktan kurtulacaktır. Yoksa önerisiyle bağlıdır. Dolayısıyla isteklinin piyasa fiyat araştırmasında vermiş olduğu teklif Borçlar Hukuku hükümleri çerçevesinde kendini bağlamaktadır.

Hatta piyasa fiyat araştırması kapsamında idarenin, telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan önerinin, hazır olanlar arasında yapılmış sayılmakta olup, aynı şekilde firma kataloglarında yer alan fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılacağının bilinmesi gerekir. Bu boyutuyla da Yasa'da sayılan iletişim araçlarıyla verilen teklifler de geçerli sayılmaktadır.

Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmelerin, kabulün gönderildiği andan başlayarak hüküm doğuracağı, açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hüküm doğuracağının bilinmesi gerekir. Bu ise, posta yoluyla istekli tarafından verilen imzalı tekliflerin geçerli olacağı anlamına gelmektedir.

Sözleşmelerin geçerliliğinin, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı olmadığını, kanunda sözleşmeler için öngörülen şeklin, kural olarak geçerlilik şekli olduğunu, öngörülen

şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmelerin hüküm doğurmayacağını, bu kapsamda idarelerin tip sözleşmelere bağlı kalmadan serbestçe sözleşme düzenleyebileceğini söyleyebiliriz.

Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunlu olduğu, kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçeceğinden, istekli tarafından sunulan fiyat teklifinin bu bağlamda geçerli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, imzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunlu olup, bu yönüyle de imzalı teklif sunan kişiyi, sunduğu teklif bağlamaktadır.

Anlatılanlar ışığında, 4735 sayılı Kanunu'nun anılan Kanun'da hüküm bulunmayan durumlarda Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğine yönelik hümü uyarınca, her ne kadar 4735 sayılı Kanun'da ihale kapsamı sözleşmeler kapsama girse de doğrudan temin mevzuatı alımların ihale mevzuatında düzenlenmesi ve ayrıca bu süreçte Borçlar Hukuku anlamında bir borç alacak ilişkisinin varlığından hareketle anılan Kanun hükmünün uygulanabileceği düşünülmektedir.

Borçlar Kanunu bağlamında doğrudan temin kapsamı alımlara bakacak olursak, piyasa fiyat araştırma kapsamında, teklif alma sürecinde, bir anlamda öneri ve kabul gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Kanun'da yer aldığı şekliyle öneri ve kabul süreci tamamlanmakta bir anlamda sözleşme gerçekleşmektedir. Çünkü Kanun'a göre, sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Anılan Kanun'da, sözlü şekil mevcut değildir; yazılı şekil esastır, ancak yazılı sözleşmelerin şekil şartı yoktur. Doğrudan teminde sözleşme yazılı olarak kurulmuşsa, buna göre taahhüdün yerine getirilmesi istenebilir.

Bilindiği üzere, doğrudan temin; ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen gerçek/tüzel kişilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olup, bu alımlarda genel kural, sözleşme düzenlenmesi hususu idarelerin takdirinde olmakla birlikte, 22'nci madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumu ile 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur. Bunun dışında sözleşme düzenlenmesi zorunlu tutulmamıştır. Dolayısıyla ortada düzenlenmiş bir sözleşme varsa, söz konusu sözleşme tarafları bağlamaktadır.

Bu çerçevede borçlu olarak teklif sahibi borcunu ifa etmezse 6098 sayılı Kanun'un "Borcun ifa edilmemesi" kapsamında 112'nci maddesinin *"Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür."* hükmü çerçevesinde işlem tesis edilebileceği, dolayısıyla idarenin bir zararı söz konusu ise bunun karşılanması gerekmektedir.

İhale mevzuatı açısından yaptırım boyutuna baktığımızda; doğrudan temininin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda yer alan müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, verilen teklifine uymayan veya sözleşme konusu şeyi teslim etmeyen kişiler hakkında ihale mevzuatına göre uygulanacak bir müeyyide bulunmamaktadır.

Doğrudan teminin, Kanun kapsamında yer verilen bir ihale türü olmaması nedeniyle, bu alım yöntemine ilişkin yasaklama kararı verilmesi de mümkün değildir. Bununla birlikte, tespit edilen fiile ilişkin olarak ceza takibatı gerektiren bir durumun varlığı halinde, ceza kanunları ve diğer kanunlardaki yaptırımların uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı" başlıklı maddesinde (28.1.10.);*"...doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez."* açıklaması yer almaktadır. Söz konusu hüküm, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da 4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen fiillerden birinin gerçekleştirilmesi durumunun ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini ifade etmektedir.

Zira rüşvet vermek, sahte evrak düzenlemek gibi yasak fiiller ve davranışlar, aynı zamanda TCK kapsamında tanımlanmış suçlar olması nedeniyle, 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümleri aracılığıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine gidilmesi gerekmektedir. Hatta bu fiillere memurların iştiraki halinde, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri gereğince, izin almadan adli makamlarca ilgili personelin resen soruşturulması söz konusudur.

Diğer taraftan her ne kadar ihalelerde yasaklama kararı söz konusu olmasa da idareye karşı taahhüdünü yerine getirmeyen esnaf veya tacire ilişkin olarak ilgili odalarca idari ceza uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Bu bağlamda, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun "Disiplin kurulu ve disiplin cezaları" başlıklı 24'üncü maddesi uyarınca, Birliğin disiplin kurulu, birliğe bağlı oda üyelerinin meslekî faaliyetleri sırasında meslek ahlakı ile bağdaşmayan hareket ve işlemlerini soruşturmaya ve durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu maddede belirtilen disiplin cezalarını vermeye yetkili olduğu ifade edilmiştir.

Verilen cezalar kapsamında; Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen hareketleri olana "Uyarma cezası", buna karşın, Müşterilerine ve diğer kişilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen kişiye ise "Kınama cezası" öngörülmektedir.

Aynı şekilde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na istinaden hazırlanan Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde, Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak "Uyarma cezasını" gerektirirken, Müşterisine veya iş sahiplerine karşı taahhütlerini yerine getirmemek ise "Kınama cezası" kapsamında sayılmıştır.

Netice itibarıyla;

-İdareye vermiş olduğu yazılı ve imzalı geçerli teklifinin gereğini yerine getirmeyen istekliye karşı, kamu ihale mevzuatı açısından ihalelerden yasaklama kararının verilemeyeceği,

-Ancak bu süreçte isteklinin yasak fiil veya davranışlarının Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil etmesi durumunda, bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında alımın doğrudan temin yöntemi kapsamında olmasının engel teşkil etmeyeceği,

-İsteklinin vermiş olduğu teklifin Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde kendisini bağladığı ve yasal süresi içerisinde teklifinden vazgeçtiğini idareye bildirmediği durumda teklifin geçerli

olduğu, teklif kapsamında geçerli olan taahhüdünü yerine getirmezse anılan Kanun'un 112'nci maddesi çerçevesinde idarenin varsa zararını karşılamak zorunda olduğu,

-İlave olarak teklif sahibinin meslek durumuna bağlı olarak ilgili meslek sahibi için disiplin cezası hükümlerinin işletilmesinin söz konusu olabileceği,

Düşünülmektedir.

84. Doğrudan temin kapsamı alımlar açısından harcama yetkilisi/ihale yetkilisi nedir ve harcama yetkisinin devri mümkün müdür?

Özet: *4734 sayılı Kanun uyarınca ihale yetkilisi, "İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri" olarak tanımlanmış olup, 5018 sayılı Kanun'un 31'inci maddesinde harcama yetkilisi, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi" olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanun'un 31'inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olup, harcama yetkisinin devri mümkündür. Yetki devri yazılı olmak ve devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmak koşuluyla mümkündür. Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir. Ancak her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez. Ayrıca, harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.*

4734 sayılı Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde "İhale yetkilisi"; idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak belirlenmiştir. İdarelerin bu yetkilere sahip kişi, kurul veya görevlileri ise, kendi mevzuatlarında belirlenmektedir. Bu nedenle, idarenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, ihale yetkilisinin idarelerce belirlenmesi gerekmektedir.

İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.

5018 sayılı Kanun başta olmak üzere, konuyla ilgili olarak 5018 sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı (Karar Tarihi:14.06.2007 Karar No:5189/1) bulunmakta olup, söz konusu Karar ve ayrıca Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğler (1-2) ışığında değerlendirmelerde bulunulmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesi hükmü uyarınca, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların yetkili kılınmış mercilere hesap vermeleri zorunludur.

5018 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin (k) bendinde, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim, harcama birimi olarak tanımlanmıştır. Kanun'un 31'inci maddesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu ifade edilmiş, 32'nci maddesinde ise; bütçeden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin, harcama talimatı vermesine bağlanmış, harcama talimatlarında da hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilerin yer alacağı, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken işlemlerden harcama yetkililerinin sorumlu oldukları belirtilmiştir. 5018 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesinde de giderin gerçekleştirilmesinin, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesi ile tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır. Mevzuatın yukarıda belirtilen hükme göre, bütçeden yapılacak harcamalarda süreç, harcama talimatı ile başlamakta ve ödeme emri belgesi uyarınca hak sahibine ödeme yapılması ile son bulmaktadır.

Bahse konu Kanun'da, giderin yapılmasından ödeme aşamasına kadar tüm işlemlerin harcama yetkilisinin gözetim ve denetimi altında, onun emir ve talimatı ile yürütülmesi öngörüldüğünden, sorumluluk konusunda da harcama yetkilisi ön plana çıkmaktadır. Kanun'da harcama yetkilisinin, bütçeyle ödenek tahsis edilen her harcama biriminin en üst yöneticisi olarak tanımlanması, idari açıdan üst yöneticilere; hukuka uygunluk açısından da yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle sorumlu olduğunu göstermektedir.

5018 sayılı Kanun'da harcama yetkilisi ifadesiyle daire/birim amirine işaret edilmektedir. Bu konumda olan yöneticilerin, 657 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinde belirtildiği gibi, amiri oldukları kuruluş ve hizmet biriminde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurları takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumlu tutulacakları da tabiidir. Bu hükümler karşısında, bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanun'da öngörülen harcama sürecinde tek ve tam

yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisinin, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumlu olduğu açıktır.

5018 sayılı Kanun'un 31'inci maddesinin birinci fıkrasında, harcama yetkilisi, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir" şeklinde tanımlanmış, harcama yetkisinin devredilmesinin, yetkiyi devredenin "idari sorumluluğunu" ortadan kaldırmayacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden, imza yetkisi olarak adlandırılan yönetsel uygulama kapsamında bir devir anlamı çıkartılamayacağı gibi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu kaldırmayacağına dair hükümde geçen idari sorumluluğun, mali sorumluluğu da içerdiği varsayımıyla yetkiyi devredenle devralanın Sayıştaya karşı birlikte sorumlu tutulmaları, başka bir deyişle harcama yetkilerini devretmeleri halinde dahi, harcama yetkililerinin mali sorumluluklarının devam ettiği sonucu da çıkartılamaz.

Literatürde de yetki devri halinde, yapılan işlemin yetki devredilenin işlemi olduğu ve dolayısıyla bu işlemden doğan sorumluluğun yetki devredilen makama geçtiği genel kabul gören bir husustur. Harcama yetkisini devreden harcama yetkilisinin mali sorumluluğunun bulunmaması, 5018 sayılı Kanun'la öngörülen mali sorumluluk sisteminin de doğal bir sonucudur.

5018 sayılı Kanun'dan önceki mevzuatımızda mali sorumluluk için tek şart, mevzuata aykırılık olup, buna ilaveten zarar, kusur gibi başkaca bir şart öngörülmemiştir. Sorumlulukta sadece mevzuata aykırılığın yeterli sayıldığı bu sistem, 5018 sayılı Kanun'la değiştirilmiş bulunmaktadır. Gerçekten, anılan Kanun'un 71'inci maddesinde, "Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır" şeklinde tanımlanarak kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak unsurlar sayılmıştır. Harcama yetkilisinin bu durumda sorumlu tutulması, hem 5018 sayılı Kanun'la hem de hukukun genel ilkeleriyle bağdaştırılamaz. 5018 sayılı Kanun'un anılan maddesinin dördüncü fıkrasının harcama yetkisinin devrinin yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan

kaldırmayacağı yolundaki hükmünde geçen idari sorumluluğun, mali sorumluluğu da içerdiği söylenemez. Zira "idari sorumluluk" ve "mali sorumluluk" ayrı kavramlar olup, idari sorumluluk, mali sorumluluğu içermemektedir.

Sayıştay açısından mali sorumluluğun bir tazmin sorumluluğu olmasına karşın, 31'inci maddenin dördüncü fıkrasında geçen idarî sorumluluk, 657 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi anlamında, Devlet memurlarının, amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumlu olduklarına dair yönetsel bir sorumluluktur. Bahse konu 31'inci madde, harcama yetkisinin devrinin idari sorumluluğu kaldırmayacağını belirtilmektedir.

Dolayısıyla, harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu kaldırmamakla birlikte, yetkiyi devreden harcama yetkilisinin malî sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenlerle, harcama talimatının kullanılmasından doğan sorumluluğun, harcama yetkisinin devredildiği görevliye ait olması gerekmektedir.

5018 sayılı Kanun'un 31'inci maddesi hükmü uyarınca ya da bütçe kanunlarında yer verilen bazı hükümler ile idareler veya idarelerin değişik birimleri arasında iş ve hizmet ilişkisine bağlı olarak yapılan ödenek aktarımları ve buna bağlı olarak harcama süreçleri, genel harcama sürecinin dışına çıkabilmektedir. Kanun'dan veya işin gereğinden kaynaklanan bu tür görev paylaşımlarında, aktarılan ödeneğin kullanım yetkisi ve bu ödenekle yerine getirilen işlemlerin gerçekleştirilmesi görevi, ödeneği devralan idareye veya birime geçeceğinden, harcama yetkisinden doğan sorumluluğun da genel harcama yetkililerinin sorumluluğu çerçevesinde, ödenek aktarımının yapıldığı idare veya birimin harcama yetkilisine ait olması gerekmektedir. Bu nedenlerle, mevzuatta yer alan bazı hükümler nedeniyle kamu idareleri arasında veya idarenin değişik birimleri arasında iş ve hizmet ilişkisine bağlı olarak yapılan ödenek aktarmalarında, harcama yetkisinden doğan sorumluluk, ödenek aktarılan birimin en üst yöneticisine aittir.

Öte yandan, Kanun'da öngörülen harcama yetkilisinin izin, hastalık ve geçici görev gibi sebeplerle görevlerinde bulunmadığı durumlarda, bu kişilerin yerine, mevzuatlarında öngören usulle vekâleten atanan kişi asilin tüm yetki ve sorumluluklarını taşıyacağından harcama yetkisini de kullanacaktır. Bu nedenle, harcama yetkilisinin yerine, mevzuatında öngörülen

usullere uygun olarak vekâleten atanan görevlinin, vekâlet ettiği göreve ait harcama yetkisini kullanmasından doğan sorumluluğun bu görevi vekâleten yürüten görevliye aittir.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin (k) bendinde ise "Harcama birimi" kamu idare bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim olarak tanımlanmıştır. 5018 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi uyarınca kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlerine ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ancak üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez.

Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler.

Buna göre kamu idarelerinin;

- Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
- Merkez dışı birimlerinde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 50.000'i aşan ilçelerin ilçe müdürleri veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına,
- Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
- Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine,

kısmen veya tamamen devredebilirler.

Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:

- Yetki devri yazılı olmak zorundadır.
- Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.
- Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst

yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.

İdarelerin teşkilat yapısında yer almayan birimler ile yurtdışı teşkilatına tahsis edilen ödeneklerin harcama yetkilileri üst yöneticiler tarafından belirlenir ve bunlar mali hizmetler birimi ile muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir.

Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.

5018 sayılı Kanun'un 5436 sayılı Kanun'la değişik 60'ıncı maddesi uyarınca, harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar.

4734 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde ihale yetkilisi, "İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri" olarak tanımlanmıştır. 5018 sayılı Kanun'un 31'inci maddesinde harcama yetkilisi, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi" olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanun'un 31'inci maddesince belirlenmiş harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisidir.

Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi

destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır.

Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün bulunmaktadır.

İdarelerin ilçe sınırları dahilinde bulunan birimlerinin harcama işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda personelinin bulunmaması nedeniyle harcama yetkililerinin belirlenmesinde ve harcama işlemlerinin yürütülmesinde güçlük bulunması hallerinde, söz konusu birimlerin harcama yetkiliği görevi kaymakam, il müdürü veya bölge müdürü tarafından yürütülebilir.

Diğer taraftan, idarelerin bütçelerinde belirli bir harcama birimine tahsis edilmemiş ve toplu olarak bütçeleştirilmiş ödeneklerin harcama yetkilileri üst yönetici tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde belirlenen harcama yetkilileri mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkililerine bildirilir.

5018 sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesinde, harcama birimlerini ilgilendiren harcamaların ilgili harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği, ancak, harcama yetkiliği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet birimleri olarak yer alan idari ve mali işler, makine-ikmal, satın alma, yapı işleri, personel gibi birimlerin destek hizmetleri birimi olarak sayılması gerekmektedir.

85. Doğrudan temin kapsamı alımlarda düzenlenecek sözleşmeler birim fiyat şeklinde mi yoksa götürü bedel olarak mı sözleşmeye bağlanmaktadır?

Özet: *Doğrudan temin yönteminde, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin esas alınması zorunlu olmayıp, işin niteliğine göre sözleşmenin konusu, bedeli, süresi ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin yer aldığı sözleşmelerin de doğrudan teminde kullanılması mümkündür. Bu kapsamdaki alımlar için ne şekilde fiyat teklifi alınacağı noktasında mevzuatta açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, piyasa fiyat araştırması kapsamında tekliflerin genel olarak birim fiyat şeklinde alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu yöndeki referans düzenlemeler de dikkate alındığında, mal ve hizmet alımlarına ait tekliflerin bu yönde olması uygun olacaktır. Ancak yapım işlerinin özgünlüğü dikkate alınarak, uygulama projesinin bulunması durumunda, Anahtar teslimi götürü bedel teklif alma, Ön veya kesin projesi var ise Birim fiyat teklif almak daha uygun olacaktır. İlave olarak, idarece sözleşme yapılmasının öngörüldüğü durumlarda, daha sonra doğabilecek ihtilafların önlenmesi için, hazırlanacak sözleşme tasarısı ve idari şartnamenin fiyat araştırması yapılan kişilere verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Yapım işlerinin niteliği dikkate alınarak doğrudan temin yöntemi de olsa idarenin sözleşme düzenlemesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.*

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Yasa'nın ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

Doğrudan temin konusunda düzenlemelerin yer aldığı Kamu İhale Genel Tebliği'nin 22.1.1.2. bendinde yer alan; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenleme ile sözleşme yapma konusunda idareler (sözleşme düzenlenmesini gerektiren iki durum hariç olmak üzere) serbest bırakılmıştır.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'da öngörülen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

Sözleşme serbestliği dikkate alınarak doğrudan temin kapsamı alımlarda teklifler birim fiyatlarla mı yoksa götürü bedel olarak alınıp alınmayacağını irdeleyebiliriz. Kuşkusuz söz konusu teklif alma ve sonrasında sözleşme yapılması açısından alıma konusunun mal veya hizmet ya da yapım işi olması önem arz etmektedir.

4735 sayılı Kanun hükümleri, ihale türleri kapsamında yapılan alımlar için de geçerli olsa, doğrudan temin kapsamı alımlar için de göz önünde bulundurulabileceği dikkate alınarak, 4735 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca, "Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda sözleşme türleri;

"a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,

b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

d) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,

e) Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme,

Düzenlenir. "

Hükmü çerçevesinde belirlenmiştir.

Anılan Kanun'un sözleşmede yer alması zorunlu hususlar başlıklı 7'nci maddesinin incelenmesinde ise; sözleşme bedeli, kesin teminat, garanti süresi, gecikme halinde alınacak cezalar gibi birçok hususun anılan Kanun'a göre düzenlenecek sözleşmelerde belirtilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede KİK tarafından hazırlanan tip sözleşmelerde bunlara ilişkin hususlara yer verildiği anlaşılmıştır.

Yasa metninde yer aldığı üzere, ihale sürecine ilişkin işlemler 4734 sayılı Kanun'la belirlenmesine rağmen, 4735 sayılı Kanun ile de sözleşme türleri belirlenmiştir. Buna karşın, doğrudan temin bir ihale türü olmadığı için söz konusu düzenlemeler bu boyutuyla bağlayıcılık taşımamaktadır. Yani bahse konu sözleşme türleri doğrudan temin için zorunlu değildir.

Ancak bu kapsamda düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceğine dikkate edilmesi gerekir. Ayrıca, sözleşmelerinin tarafları, eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemediği gibi, kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensibin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da yükleniciden teminat alınması, cezai yaptırımlar ön görülmesi önem arz eden hususlarda, hukuki belirsizlikler yaşanmaması adına yazılı sözleşme düzenlenmesinde fayda olduğu düşünülmektedir.

Bu çerçevede, şayet düzenlenecekse, alım şekline bağlı olarak doğrudan temin kapsamı alımlarda imzalanacak sözleşmeler farklılık gösterecektir. Doğrudan temin kapsamı alımlarda Yasa'nın 22'nci maddesinde yer aldığı üzere sınır, 22/d kapsamı parasal sınırlamaya tabi alımlarda 2022 yılı için büyükşehir belediyeleri 218.395.-TL, diğer belediyeler için 72.752.-TL olarak uygulanmaktadır.

Söz konusu rakamlar dikkate alındığında, bu düşük tutarlar ile büyük ölçekli alımların yapılması zaten mümkün değildir. O yüzden çoğu zaman karmaşık sözleşmelerin düzenlenmesine zaten gerek kalmayabilir. Doğrudan temin zaten idarenin küçük ölçekli alımları için öngörülen bir yöntemdir.

Kaldı ki bu alım kapsamında sadece kırtasiye, demirbaş gibi küçük ölçekli malzeme alımı

gerçekleşebileceği gibi bu yöntemle bir yapım işi de söz konusu olabilir. Örneğin; ilgili idarenin girişine bir nizamiye veya güvenlik kulübesi yapımı söz konusu olabilir.

Bilindiği gibi doğrudan temin yönteminde genel kural piyasa fiyat araştırması şeklinde teklifler alınmakta ve bu teklifler üzerinden alım şekli sonuçlanmaktadır. Bu boyutuyla doğrudan teminde birim fiyat ya da götürü bedel şeklinde bir ayrım olmadığını söyleyebiliriz.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer aldığı üzere; birden fazla mal kaleminden oluşan ihaleler, birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilecektir. Mal alımı ihalelerinde ihalenin kısmi teklif verilmesine izin verilmesi ve kısmın veya kısımların birden çok kalemden oluşması durumunda, birim fiyat teklif cetvelinin hazırlanmasında anılan Tebliğ ekinde ekte yer alan form örneği esas alınarak birim fiyat cetveli hazırlanması mümkündür.

Yine anılan Tebliğe göre, bazı hizmet alımı ihalelerinin de birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur.

Ancak yapım işi için durum biraz farklılık arz etmektedir. Çünkü bu tip alımlarda fiyat araştırmasının (bir anlamda yaklaşık maliyetin), ilgili ihale uygulama yönetmeliğinde yer alan kurallara göre hazırlanması gerekmektedir.

Çünkü yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İstisnai haller hariç olmak üzere, genel kural, bütün yapım işlerinde ihaleye çıkılmadan önce uygulama projesi hazırlanması ve uygulama projesi bulunan bütün yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınması zorunludur.

Götürü bedel sözleşme ile ihaleye çıkabilmek için uygulama projesinin bulunması zorunludur. İstekli işin tamamı için tek bir fiyat vermekte ve verdiği bu fiyatla ihale konusu işi uygulama projesine, mahal listelerine ve teknik şartnameye uygun olarak yapmayı üstlenmektedir. Yapılması gereken bir imalatın; uygulama projesinde, mahal listesinde ve varsa teknik şartnamesinde ayrı ayrı ve birbiriyle çelişmeden detaylarıyla ve yapım şartlarıyla birlikte açıkça yer alması istenilen bir husustur.

Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.

Öte yandan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar"a ilişkin 4'üncü maddesi uyarınca;

Ön proje; Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,

Kesin proje; Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,

Uygulama projesi; Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

İfade etmektedir.

Yapım işlerinde, uygulanacak sözleşme türünün tespitinde belirleyici olan projenin niteliğidir. Bu bağlamda; uygulama projesi varsa anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, şayet ön veya kesin proje varsa birim fiyat sözleşme türünün uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, işin niteliğine göre hangi işler için uygulama projesi yapılması gerektiği, hangi işler için ön veya kesin proje ile ihaleye çıkılabileceği 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin (c) bendinde yer almaktadır.

Bahse konu (c) bendi uyarınca; ihale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği işler ile doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan,

bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilmesi ve bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarında ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilmesi mümkün olup, bu şekilde gerçekleştirilen ihaleler sonucunda da 4735 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin (d) bendi uyarınca karma sözleşme düzenlenebilir.

Böylelikle, yapım işlerinde arsası temin edilmiş, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemleri ve uygulama projeleri tamamlanmış şekilde ihale yapılması gerektiği öngörülmüştür. Uygulama projesi yapılan işlerde, işin her türlü ayrıntılı özellikleri tanımlanmış olacağından, işin miktarı ile toplam bedelin sabit olduğu anahtar teslimi götürü bedel teklif alınması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak gerçekleşen doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işlerde ön proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan enerji, su, ulaşım, altyapı ve haberleşme sektörlerindeki yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılmasına imkân tanınmıştır. Ancak bu hususların ihale kapsamı alımlar için geçerli olduğunun bilinmesi gerekir.

Anlatılanlar ışığında, istisnai bir alım yöntemi olan doğrudan temin kapsamında fiyat teklifin yönelik mevzuatta açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu çerçevede İhale Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan tip sözleşmelerin incelenmesinde ise;

- Mal alımları için; Birim Fiyat veya Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesinin öngörüldüğü ancak tip sözleşmenin dipnotunda, idare tarafından alımın niteliği ve ihale dokümanında yapılan düzenleme esas alınarak, uygun sözleşme türü seçileceği belirtilmiştir. Ancak idare, bir mal kalemden daha fazla mal alımının gerçekleştirildiği ihalede Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi kullanmak zorundadır.
- Hizmet alımları için; Birim Fiyat veya Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi öngörülmüştür.
- Yapım işleri için; Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme veya Birim Fiyat Sözleşme ya da Karma Sözleşme öngörülmektedir.

Yukarıda yer verilen hususlar esas olarak ihale kapsamı alımlar için geçerli olmakla birlikte, doğrudan temin yönteminde de bu düzenlemelerin referans olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Doğrudan temin yöntemine ilişkin olarak bağlantılı mevzuatın incelenmesinde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan örnek formda, piyasa fiyat araştırması tutanağında kalem bazında, bir anlamda birim fiyatlı teklife uygun hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamdaki ihtiyaçların idarenin günlük ve acil nitelikteki ihtiyaçlar için öngörülen bir alım şekli olduğu dikkate alındığında formun içeriğinin pratik duruma uygun olduğu düşünülmektedir.

Götürü bedel ihalenin ise, niteliğinden dolayı ağırlıklı olarak yapım işleri için söz konusu olabileceği düşünülmektedir. Buna karşın, yapım işlerinde, arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İstisnai haller hariç olmak üzere, genel kural, yapım işlerinde ihaleye çıkılmadan önce uygulama projesi hazırlanması ve uygulama projesi bulunan bütün yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınması zorunludur.

Burada şu hususa dikkat edilmelidir ki, anahtar teslimim götürü bedel ihale gerektiği halde birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmesi 4734 sayılı Kanun'un 62/c maddesine aykırılık nedeniyle iptal sebebi olabilmektedir.

Bu çerçevede, doğrudan teminle yapılan alımlarda yazılı sözleşme düzenlendiği durumlarda Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılması zorunlu değildir. Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda düzenlenecek sözleşmeler emredici hukuk kurallarına, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ve konusunun objektif olarak imkânsız olmaması şartı ile idare tarafından istenildiği şekilde hazırlanabilir.

Yazılı sözleşme yapılması durumunda, sözleşme tasarısının piyasa araştırması kapsamında gönderilen teklif isteme yazılarının ekinde yer alması gerekir. Zira fiyat teklifi verecek kişiler sözleşme koşullarına göre fiyat teklifini oluşturacaklardır.

Doğrudan temin bir ihale yöntemi değil alım yöntemi olduğundan, uygulama yönetmelikleri ve eklerinde yer alan hususlar doğrudan temin için geçerli değildir. Yani mal, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerine ilişkin uygulama yönetmelikleri ekinde yer alan tip sözleşmede yer alan ceza ile ilgili sınırlamalar doğrudan teminde düzenlenen sözleşmeler için geçerli değildir.

Bu bağlamda, doğrudan teminde yapılan sözleşmelerde, Borçlar Kanunu hükümler uygulanmasından hareketle, taraflar anlaştıklarında sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler. Dolayısıyla, ihale türleri için geçerli olan tip dokümanlarda yer alan ceza oranları kullanıp kullanmama noktasında idarenin takdir hakkı bulunmakla birlikte, bu oranların referans olarak da kullanılması mümkündür.

86. Doğrudan temin yönteminde iş artışı, fiyat farkında damga vergisi alınır mı?

Özet: *4734 sayılı Kanun uyarınca, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda sözleşme düzenlendiği durumlarda sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisinin tahsil edilmesi gerekir. Dolayısıyla, idarelerin doğrudan temin kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde de bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, sözleşme hükümlerince iş artışı veya fiyat farkı yapılması halinde, ilave işin yükleniciye yaptırılması için alınan olur sözleşme miktarını artıran bir ek kağıt mahiyetinde olduğundan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı tablonun (1-1 a) bendine göre damga vergisine tabidir. Buna karşın, ilave işin yaptırılması ihale niteliğinde olmadığından ve yeni bir ihale kararı gerektirmediğinden böyle bir durumda ayrıca damga vergisi (karar pulu) alınmaması gerektiği düşünülmektedir. Bunlarla birlikte, iş artışı ve fiyat farkı uygulamasının söz konusu olması durumunda, 4734 sayılı Kanun'un doğrudan temine ilişkin 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirlenen parasal limitin aşılmaması gerekliliğine de dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı maddesinde; (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlandığı görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur. Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Ancak bu kapsamda alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise, madde metninde belirtildiği üzere

sözleşme yapılması zorunludur.

Görüldüğü üzere; kamu alımlarını düzenleyen temel yasa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Bu Yasa ihale sürecine ilişkin esasları belirlerken, ihale sürecine ilişkin sözleşmenin imzalanmasından sonraki süreç ise, bu yasayı tamamlar nitelikteki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. 4735 sayılı Yasa'nın 36'ncı maddesi uyarınca ise, anılan Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

İdareler ihaleye çıkarken ihtiyaç miktarını tam olarak belirleyip ihaleye çıkmak zorundadır. Her ne kadar idare tarafından ihtiyaç tam olarak belirlenerek ihaleye çıkılsa da sözleşme imzalandıktan sonra işin yürütülmesi aşamasında ihtiyaç miktarında değişiklik yapılması zorunlu hâle gelebilir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 24'üncü maddesinde hangi koşullarda iş artışı veya eksilişi yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda iş artışı yapılabilmesi için 4735 sayılı Kanun'a göre kurulmuş bir sözleşmenin varlığı şarttır.

İş artışına ilişkin olarak 4735 sayılı Kanun'un 24'üncü maddesinde; "*Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;*

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında %40 'a kadar artırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve

yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir."

Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm gereğince iş artışı yapılabilmesi için 4735 sayılı Kanun'a göre kurulmuş bir sözleşmenin olması gerekir. Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmadığı için söz konusu maddeye dayanılarak doğrudan iş artışı yapılması mümkün değildir.

Ancak doğrudan teminle yapılan alımlarda iş artışı yapılmasını engelleyen bir hüküm de mevcut değildir. Bu itibarla, doğrudan teminle yapılan alımlarda sözleşme düzenlendiği durumlarda, sözleşmeye iş artışı yapılabileceğine dair hükümler konulması mümkündür.

Ayrıca yapılan iş artışlarının da yazılı sözleşmeye bağlanması gerekmektedir. Ancak 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendinde belirlenen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda iş artışı yapılmak suretiyle bu limit aşılmamalıdır.

Diğer taraftan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "*Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir."* hükmü gereğince, binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisinin artış tutarı üzerinden ödenmesi söz konusudur.

Dolayısıyla, Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde limit belirtilen hallerde limiti aşmamak (22/d maddesi) ve sözleşmede belirtilmesi şartıyla doğrudan teminle yapılan sözleşmelerde 4735 sayılı Yasa'nın 24'üncü maddesindeki kısıtlamalara tabi olunmaksızın iş artışı yapılabilir. Bunun yanında doğrudan temin onay belgesinde iş artışının olmayacağı yönünde bir sınırlamanın bulunmaması ve onay belgesine ekli piyasa fiyatı araştırma tutanağında alınan mal, hizmet veya yapım işine ilişkin fiyat bilgilerinin açık bir şekilde bulunması gerekmektedir.

Konuyla bağlantılı 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümlerine baktığımız zaman, Kanun'un;

-1'inci maddesinde, bu Kanun'a ekli 1 sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi

olacağı,

-2'nci maddesinde, vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olacağı,

-3'üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği,

-4'üncü maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise üzerlerindeki yazının tazammum ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kâğıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergisinin alınacağı,

-6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde, damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı,

-8'inci maddesinde, bu Kanun da yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı,

-14'üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabi olacağı, üçüncü fıkrasında ise, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı,

Hükümlerine amir olduğu görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun "Konu" başlıklı 1'inci maddesinde, damga vergisine tabi kâğıtlara (1 sayılı Tablo) yer verilmiş olup, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I.Akitlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli bir parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 9,48 nispetinde, II-Kararlar ve mazbatalar

bölümünün 2'nci fıkrasında ise; (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 5,69 oranında damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun'daki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği öngörülmüştür.

Diğer bir anlatımla, vergiye tabi kâğıtların tanzim edilmesi, damga vergisinin doğabilmesi için düzenlenmiş bir kağıdın varlığı yeterli kabul edilmekte, vergiyi doğuran olay ise, söz konusu işleme ilişkin kağıdın düzenlenmesi aşamasında doğmaktadır. Yani, bir kağıdın imzalı şekilde tanzim edilmiş olması damga vergisinin gerçekleşmesi için vazgeçilmez unsur olarak kabul edilmektedir.

Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı açıktır.

Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda, damga vergisi uygulamalarının ne şekilde yürütüleceği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklığa kavuşturulmuş olup, söz konusu Tebliğe göre, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların, idarenin takdiriyle ihale komisyonu kurmadan ve bu komisyonun aldığı bir ihale kararı olmadan ve sözleşme yapılmadan gerçekleşmesi durumunda damga vergisi uygulamasının yapılmaması, ihale kararı veya sözleşmeden herhangi birinin veya her ikisinin de mevcut olması halinde damga vergisinin uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2'nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve

şerhlerin damga vergisine tabi olacağı hususu düzenleme altına alınmış, aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2'nci fıkrasında ise, (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 5,69 oranında damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale karar vergisi kesilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir. Zira ihale karar vergisi kesilebilmesi için ihale komisyonu kurularak bir ihale kararının alınması gerekmektedir. Doğrudan teminle yapılan alımlarda ise böyle bir husus genel olarak söz konusu değildir.

Ancak doğrudan teminle yapılan alımlarda ihale komisyonu kurulması zorunlu olmamakla birlikte idarelerin takdirindedir. İhale yetkilisi isterse bir alım komisyonu kurabilir. Doğrudan teminle yapılan alımların komisyon marifetiyle yapıldığı durumlarda sözleşme bedelinin binde 5,69 oranında karar vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir.

Şayet bir kişi görevlendirilmek suretiyle alım komisyonu kurulmadan mal ve hizmet alımı yoluna gidiliyor ise, komisyon kararı bulunmadığından binde 5,69 oranındaki damga vergisinin ödenmesine gerek bulunmamaktadır. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlara ilişkin olarak sözleşme imzalanmışsa binde 9,48 oranında damga vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sözleşmenin düzenlenmemiş olması durumunda ise damga vergisi tahsil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

4735 sayılı Kanun'da öngörülen şartlarda ve oranda ihale yetkilisinin onayı ile iş artışı gerçekleşebilmektedir. İş miktarının artırılması ihale kararını değiştiren bir husus olmadığından yeni bir ihale kararı alınmadığı sürece bu artıştan dolayı ihale kararı üzerinden damga vergisi alınamayacağı belirtilmiştir. İş artışında ek sözleşme yapılmaz ancak iş artışı kadar tutar sözleşme tutarı artığından artan kısım kadar damga vergisinin alınması gerekir.

Damga vergisi, Kanun'da sayılan belgelerin düzenlenmesi ile ortaya çıkan bir vergi türü olup vergiyi doğuran olan bu belgelerinin tanzimi ile olmaktadır. Belge düzenlenmeksizin salt işlem tesisi suretiyle damga vergisi alınmasına olanak bulunmamaktadır. İdareler ihalelerde iş artışlarını olur alarak yapmaktadır. Alınan olur ile idareler daha önce yaptıkları sözleşmenin tutarında artırıma gitmekte ve Damga Vergisi Kanunu'na göre vergiyi doğuran olay

gerçekleştiği için damga vergisi alınması gerekmektedir. Fiyat farkı ödemelerinde ise sözleşmede fiyat farkı ödeneceğine dair düzenleme yapılmakta ve sözleşmede yer alan hüküm esas alınarak ödeme yapılmaktadır. İdareler fiyat farkı ödemelerinde genellikle onay, olur gibi belge düzenlememektedir. Belge düzenlenmeyen durumlarda fiyat farkı ödemelerinden ilave damga vergisi alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak idarelerin fiyat farkı ödemesi için belge düzenledikleri durumda damga vergisi alınması gerekmektedir. İş artışı ve fiyat farkı ödemeleri dolayısıyla belge düzenlenmesi durumunda alınan yeni bir ihale kararı olmaması sebebiyle karar pulu bedeli alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Fiyat farkı hesabında uyulacak esas ve usuller 4735 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi gereğince Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararlarıyla yürürlüğe konulan "Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar" ile düzenlenmiş olup, söz konusu Esaslar ile belirlenen ilkeler çerçevesinde mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin fiyat farkı ödeme esasları belirlenmiştir. Anılan Esaslardaki düzenlemeler uyarınca doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplamasına yönelik düzenleme yapılması mümkündür. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde bu hususun onay belgesinde belirtilmesi ve alıma ilişkin doküman ve sözleşmelerde de bu konuya ilişkin açık düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, fiyat farkı uygulamasının söz konusu olması durumunda, 4734 sayılı Kanun'un doğrudan temine ilişkin 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirlenen parasal limitin aşılmaması gerekliliğine de dikkat edilmesi gerekir.

Uygulamada, iş artışı veya fiyat farkı uygulaması nedeniyle oluşan ilave ihale komisyon kararları ile artan sözleşme bedelleri için genelde yeni bir kâğıt düzenlenmesi veya daha önce düzenlenen sözleşmeye ya da başka bir kâğıda sonradan şerh konulması yolu tercih edilmektedir.

Bu takdirde söz konusu değişikliği sağlamak üzere düzenlenen kâğıdın ya da konulan şerhin de diğer düzenlenen kâğıtların damga vergisine tabi olması gibi belirtilen genel esaslar çerçevesinde değerlendirilerek damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Herhangi bir kâğıt düzenlenmeksizin ihale makamı ile yüklenici arasında düzenlenen ilk sözleşmede, fiyat farkı ödenebileceğine ilişkin bir hüküm bulunması damga vergisi alınabilmesine gerekçe olamaz.

Ayrıca fiyat farklarının, ödenmesi için başkaca bir kâğıt düzenlenmeksizin hakediş tutarlarına ilave edilmek suretiyle yüklenici firmalara ödenmesi halinde, sadece ödemeyi sağlayan kâğıdın ödeme tutarı üzerinden Kanun'a ekli 1 sayılı tablonun IV-1/a bendi uyarınca binde 9,48 oranında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Netice itibarıyla;

-İhale kapsamı alımlarda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 24'üncü maddesinde belirtilen limitler aşmamak kaydıyla iş artışı yapılmasının mümkün olduğu,

-İş artışları ile fiyat farkı ödemeleri nedeniyle meydana gelen ilave bedellerden dolayı ihale komisyon kararları ile sözleşmelerden damga vergisi alınabilmesi için muhakkak surette ihale kararı, ek sözleşme veya bu kâğıtlar mahiyetinde bulunan protokol, tespit tutanağı gibi herhangi bir kâğıt düzenlenmesi veya mevcut karar veya sözleşmeye sonradan bu konuda şerh konulması gerektiği,

-Sözleşme hükümlerince iş artışı yapılması halinde, ilave işin yükleniciye yaptırılması için alınan olur sözleşme miktarını artıran bir ek kağıt mahiyetinde olduğundan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı tablonun (1-1 a) bendine göre damga vergisine tabi olduğu, buna karşın, ilave işin yaptırılması ihale niteliğinde olmadığından ve yeni bir ihale kararı gerektirmediğinden ayrıca damga vergisi (karar pulu) alınmaması gerektiği,

- Buna karşın, doğrudan temin kapsamında yapılacak alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde de bu kararın damga vergisine tabi tutulması gerektiği, ayrıca, sözleşme hükümlerince iş artışı veya fiyat farkı yapılması halinde, ilave işin yükleniciye yaptırılması için alınan olur sözleşme miktarını artıran bir ek kağıt mahiyetinde olduğundan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı tablonun (1-1 a) bendine göre damga vergisine tabi olduğu, buna karşın, ilave işin yaptırılması ihale niteliğinde olmadığından ve yeni bir ihale kararı gerektirmediğinden böyle bir durumda ayrıca damga vergisi (karar pulu) alınmaması gerektiği,

-İş artışı ve fiyat farkı uygulamasının söz konusu olması durumunda, 4734 sayılı Kanun'un doğrudan temine ilişkin 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirlenen parasal limitin aşılmaması gerekliliğine de dikkat edilmesi gerektiği,

Düşünülmektedir.

87. Doğrudan temin yönteminde KİK'e şikâyet başvurusu yapılabilir mi?

Özet: *İhalelere yönelik şikayet mekanizması genel olarak ihale kapsamı alımları kapsamakta olup, önce idareye sonra KİK'e yönelik bir şikayet mekanizması söz konusudur. Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmadığından 4734 sayılı Kanun'da anlatılan şikayet mekanizması doğrudan temin kapsamı alımları kapsamamaktadır. İdari başvuru yolları tüketilmeden dava açılması mümkün değildir. Her ne kadar doğrudan temin kapsamında yer alan alımlar, ihale türleri dışında olsa da Anayasa'nın 125'inci maddesi çerçevesinde yargı yoluna başvurulması mümkündür. Ancak öncesinde çeşitli yargı kararlarına yansıdığı üzere, alımı gerçekleştiren idareye başvurarak hatanın düzeltilmesinin istenilmesi, bunun sonucuna göre gerekirse dava konusu edilmesi hem 4734 sayılı Yasa hükümleri hem de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri açısından daha uygun bir işlem olacaktır. Ancak istekli/yükümlü isterse doğrudan yargıya da başvuru yapabilir, buna yasal bir engel yoktur. Doğrudan temin kapsamında KİK'e yapılan şikayet başvurularının KİK tarafından reddi söz konusu olmaktadır.*

Kamu İhale Mevzuatına göre, ihale onayının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreç, ihale süreci olarak kabul edilmekte ve bu süreç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değerlendirilmekte, buna karşın, bu süreç dışında kalan işlemlere yönelik başvurular ile sözleşme imzalandıktan sonra yapılan başvurular idarece veya KİK tarafından inceleme konusu yapılamamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, gerçekleştirilen ihale şikâyet sürecinin iki başvuru boyutu bulunduğunu söyleyebiliriz. Bahse konu başvuru yolları ise; şikâyet ve itirazen şikâyettir. Ancak ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin öne idareye şikâyet, daha sonra Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri bir sistem öngörülmüştür. Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak Kanun'da düzenlenmiştir.

İstekliler, ihalelere yönelik şikâyet başvurularını, ihale süreci ile sınırlı olarak yapılabilmektedir. İhale süreci, ihale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve

tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreci ifade etmektedir. Keza ihale sonrası sürecin şikâyet konusu edilmesi mümkün olmayıp, bunlarla ilgili doğrudan yargı makamlarına başvuru yapılması gerekmektedir.

Ancak 4734 sayılı Yasa çerçevesinde şikayet mekanizması esas olarak ihale kapsamı alımlar için öngörülmüş olup, buna ilişkin dokümanlarda ihale sürecinden bahsedilmektedir. Doğrudan teminde ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan bir ihale sürecinden bahsedilemez. Dolayısıyla, Kanun'un yukarıda anılan 53'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda idarelerce tesis edilen işlemler itirazen şikâyete konu edilemez.

Bunların yanında, Kamu İhale Kurumuna yapılan şikâyetlere ilişkin olarak, karar alma süreleri ve Kurulun alabileceği karar türleri, Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'te ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'te yer aldığı üzere; şikayet başvuruları, elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet ile) Kuruma yapılır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, gerçekleştirilen ihale şikâyet süreçlerinde ikili bir uygulamanın söz konusu olduğunu görmekteyiz. Söz konusu başvuru yolları, şikâyet ve itirazen şikâyettir. Bunlardan, şikâyet; ihale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur.

Bu bağlamda, itirazen şikâyet ise;

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,
b) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,

c) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı,

Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurudur.

Öncelikle, ihalelere yönelik başvuru için, belli ehliyet şartlarının varlığının gerektiğini söyleyebiliriz. Zira ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden "İstekli, İstekli Olabilecekler ve Adaylar" ancak başvuruda bulunabilir.

Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.

İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulur. Bu şikayet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

Doğrudan temin kapsamı alımlar için Kamu İhale Kuruluna şikayet başvuruya konu işin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleme yetkisi bulunmasına karşın, doğrudan temin yöntemi ile alım yapılmasının uygun olduğu durumlarda alımın niteliğine yönelik iddiaları incelemek Kurumun görev alanı dışındadır.

Dolayısıyla, doğrudan temin ile ilgili idari işlem ve eylemler hakkında Kamu İhale Kurumunun inceleme yetkisi bulunmadığından, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gerçekleştirilen idari işlem ve eylemler için 2577 sayılı Kanun çerçevesinde yargıya başvurulur. Böylelikle idari başvuru yollarından farklı olarak, doğrudan temin alımı ile ilgili idari yargıda açılan davalar belli başlı niteliklere ilişkin olup, ayrı bir yargılama usulüne tabi olmadığı görülmektedir.

KİK tarafından verilen bir Uyuşmazlık Kararında da; "… *Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşıldığından ve kapsamda yer almayan bu ihalede idarenin kararına karşın yetkili idare mahkemesine başvurulması gerektiğinden 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun görev yönünden reddine …"* karar verilmiştir.

Ancak bazı yargı kararlarında, Yasanın öngördüğü koşul uyarınca, davadan önce idari mekanizmaların tüketilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda, doğrudan temin kapsamı alımda olsa önceden idare başvuru yoluyla bu işlemin düzeltilmesinin talep edilmesi daha uygun olacaktır.

İhale kararları idari bir işlem olup, Anayasa'nın "idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açık olduğu" yönündeki 125'inci maddesine göre söz konusu idari tasarruflara karşı idari yargı yolu açıktır.

Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14'üncü maddesinde, açılan davada idarî merci tecavüzü bulunup bulunmadığının ilk inceleme sırasında inceleneceği; 15'inci maddesinde de, idarî merci tecavüzü halinde, dilekçelerin görevli idarî mercie tevdiine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Nitekim 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Yargısal inceleme" başlıklı 57'nci maddesinde; "Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür" hükmü ile konu yasal bir düzenlemeye tâbi tutulmuştur.

İhale türlerinden farklı olarak, doğrudan teminde ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan bir ihale sürecinden bahsedilemez. Dolayısıyla, Kanun'un yukarıda yer verilen 53'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda idarelerce tesis edilen işlemler itirazen şikâyete konu edilemez. Bu nedenle, doğrudan temin yöntemi ile alım yapılması durumunda, alımın niteliğine yönelik iddiaları incelemek

Kurumun görev alanı dışında kalmaktadır.

Doğrudan temin ile ilgili idari işlem ve eylemler hakkında Kamu İhale Kurumunun inceleme yetkisi bulunmadığından, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gerçekleştirilen idari işlem ve eylemler için 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde idari yargıya başvurulması yasal olarak mümkündür.

Görüldüğü üzere; 4734 sayılı Kanun çerçevesinde, Kamu İhale Kurumunun temel görevi kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak olup, bu kapsamda Kuruma kamu alımları alanını düzenlemek yanında, ihale sürecindeki şikâyetleri incelemek görevi de verilmiş olup, ihale kapsamı alımlarda, şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır. Aksi takdirde Ankara İdare Mahkemesi "idari merci tecavüzü" (2577.md.13) nedeniyle, "dilekçenin görevli idare merciine tevdiine" karar vermesi söz konusudur. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir.

Bu çerçevede, sözleşmenin imzalanmasına kadar sürecin ihale süreci olarak kabul edilmesi nedeniyle ancak şikâyet konusu edilebileceğini ve ayrıca, doğrudan temin kapsamında yapılan alımlara ilişkin olarak söz konusu alım türünün 4734 sayılı Yasa kapsamında öngörülen bir ihale türü olmaması nedeniyle, bu konuda KİK'e yönelik ihale şikâyet başvurusunda bulunulmayacağını ve son olarak Kamu İhale Kurulunun bireysel nitelikli kararlarına karşı ilk derece mahkemesi olarak Ankara İdare Mahkemesinde, düzenleyici nitelikteki işlemlerine karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda dava açılabileceğini söyleyebiliriz.

Netice itibarıyla;

-Kamu İhale Mevzuatında yer alan şikayet mekanizmasına ilişkin düzenlemeler ihale mevzuatı alımlar için geçerli olup, bu düzenlemelerin doğrudan temin kapsamı alımları kapsamadığını,

-Doğrudan temin kapsamı alımlarda KİK'e yönelik bir şikayet mekanizmasının söz konusu olmadığını, bu yönde yapılan şikayetlerin ise görev yönünden reddi gerektiğini,

-Doğrudan temin kapsamı alımlar için söz konusu olduğu iddia edilen hukuka aykırılıklar için doğrudan yargı makamlarına başvurulmasının öncesinde ilgili makamda bu hususun

düzeltilmesinin talebinin de mümkün olduğunu, böyle bir durumda idari merci tecavüzüne yönelik olası durumdan da söz edilemeyeceğini,

- Doğrudan temin alımı ile ilgili idari yargıda açılan davalar belli başlı niteliklere ilişkin olup, ayrı bir yargılama usulüne tabi olmadığını,

İfade edebiliriz.

88. Mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi doğrudan temin kapsamı alımlara engel midir?

Özet: *Mahkemece, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde, sanık ile ceza arasındaki bağlantının belirli şartlarla askıya alınması, denetim süresinin şartlara uygun olarak tamamlanması halinde ise kamu davasının düşürülerek sanığın tamamen cezadan veya hükümlülük kararından kurtulması sonucunu doğurması ve bu bağlamda, söz konusu hükmün bunlara özgü bir sisteme sadece belirli Makamlara (Cumhuriyet Savcısı, Mahkeme gibi) verilmek üzere kaydedilmesi ve bunların ötesinde, CMK'nın 231/5. maddesinde, kurulan hükmün sanık hakkında belirtilen sürede konulan yükümlülüklere uyulmak şartıyla bir hukuki sonuç doğurmadığının açıkça hükme bağlanmış olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında öngörülen süre içerisinde tüm hukuki sonuçlar ortadan kalktığı için gerek ihale kapsamı ve gerekse doğrudan temin yöntemiyle alım olsun bu durumun alım yapılmasına engel olmadığını söyleyebiliriz. Kaldı ki doğrudan temin kapsamı alımlarda ihalelere ilişkin (idare istemezse) yeterlik kriterleri söz konusu olmadan da alım yapılmasının mümkün olduğunu ifade edebiliriz.*

Doğrudan temin kavramı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde, (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmaktadır. Kanun'un ilk kabul edildiği haliyle, bir ihale türü olarak belirlenen "Doğrudan temin" 15.08.2003 tarihli ve 25200 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun'un 12'nci maddesi ile bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesi incelendiğinde, doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun konusu olan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi durumunda doğrudan temin kapsamında alım yapılmasına engel olup olmadığı

ortaya konulacaktır.

Bu bağlamda, mahkemece haklarında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verilen kişilerin bu hukuki durumunun Kanun'un 10/b maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu ile yine 4734 sayılı Yasa'nın 59'uncu maddesi uyarınca haklarında Kanun'un 17'nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlardan dolayı kamu davası açılanların yargılama süresince ihalelerde başvuruda bulunamaması nedeniyle, hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verilen kişinin yasaklı kabul edilip edilemeyeceği hususunun bu çerçevede açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesi gereğince, idareler yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Ayrıca, isteklilere talimatları içeren ihale dokümanlarının da bu ilkeler ışığında hazırlanması zorunludur.

Bu çerçevede, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla istenilecek bilgi ve belgelerin, hiçbir şekilde rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmemesi gerekmektedir. Yani, yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu alımın niteliği dikkate alınarak, gerçekçi bir şekilde belirlenmesi ve eşit muamele ilkesine uygun olması gerekmektedir.

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10/b maddesinin 9'uncu fıkrasının ihale dışı bırakılacaklarla ilgili (e) bendinde "İhale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler" de sayılmış olup, söz konusu bent kapsamında hüküm giymiş olan isteklilerin ihalelere başvuruda bulunamayacağı açıktır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için, kovuşturma evresinde mahkemece bir hüküm tesis edilmesi gerektiğini, ancak verilen bu hükmün, hukuki sonuç doğurup doğurmamasının belli bir süreye ve bazı ilave şartların gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı kaldığını söyleyebiliriz.

Diğer yandan, gerek 4734 sayılı Kanun'da ve gerekse 4735 sayılı Kanun'da yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışlar belirlenmiş olup, söz konusu fiillerin varlığı ve tespiti halinde,

ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği yine anılan Kanunlarla hükme bağlanmıştır.

Doğal olarak, hakkında ihalelerde yasaklama kararı verilen kişiler, yasaklılığın kapsamına bağlı olarak, yasaklılık süresince ilgili kanun kapsamındaki ihalelere başvuruda bulunamayacaktır.

4734 sayılı Kanun'un "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı (10'uncu) maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerin belirlenmesine ilişkin belgelerin istenebileceği, bu bilgi ve belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirilmesinde kullanılacağının ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtileceği hükmüne yer verildikten sonra, "ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenlerin" ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği (17.5.1.3)'nde; "Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından yalnızca, 'mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali', 4734 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Bu nedenle idarelerin, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinin uygulamasında, mahkumiyet kararlarının mesleki faaliyetten kaynaklanıp kaynaklanmadığını göz önünde bulundurması gerekmektedir.." düzenlemesinin yer aldığı görülmektedir.

Bu bağlamda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 231'inci maddesiyle getirilen bu müessesenin en önemli özelliği hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde, sanık beş yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulmaktadır. Ayrıca, mahkûm olunan cezanın **(**ertelenemeyip), kısa süreli olması hâlinde seçenek yaptırımlara çevrilmesi de mümkün değildir**.** Denetimli süresi içinde dava zamanaşımı da durmaktadır**.**

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmekte olup, bu kararlar, ancak bir soruşturma ve kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde CMK'nın 231'inci maddesinde belirtilen amaç için kullanılabilmektedir. Adli sicil kaydında da gözükmemektedir.

Bu kapsamda, sanığın öngörülen denetimli serbestlik süresi içerisinde başkaca kasıtlı bir suç

işlememesi ve mahkeme tarafından belirlenen yükümlülüklere de uygun davranması halinde, açıklanması geri bırakılan hüküm tüm hukuki sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacak ve sanık başından hiçbir yargılama geçmemiş gibi kabul edilecektir.

Diğer taraftan, sanığın denetimli serbestlik süresi içinde kasıtlı başkaca bir suç işlemesi veya mahkeme tarafından öngörülen yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanacaktır. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşulların varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü de kurabilecektir.

Açıklandığı üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi af değil, bir usul hukuku müessesesidir. Kaldı ki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında kanunda belirtilen objektif ve sübjektif koşullar tam olarak gerçekleşse bile bunun uygulanması hakimin takdirine bırakılmıştır. Zira hâkimin bu müesseseye başvurmayıp vermiş olduğu cezayı Türk Ceza Kanunu'nun 51'inci maddesine göre ertelemesi de olanak dahilindedir.

Mahkemece 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5'inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde, sanık ile ceza arasındaki bağlantının belirli şartlarla kesilmesi ve askıya alınması, denetim süresinin şartlara uygun olarak tamamlanması halinde ise, sanığın tamamen cezadan veya hükümlülük kararından kurtulması yani hakkındaki kamu davasının düşürülmesi sonucunu doğurması ve ayrıca, söz konusu Kanun maddesinde, kurulan hükmün sanık hakkında belirtilen sürede konulan yükümlülüklere uyulmak şartıyla bir hukuki sonuç doğurmamasını açık bir şekilde ifade edildiği hususları dikkate alındığında; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 4734 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi çerçevesinde "yargı kararıyla hüküm giymek" kapsamında değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.

Aynı paralelde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu kararın adli sicil kaydı dışında bunlara özgü bir sisteme kaydedilerek sadece belirli kişi ve kurumların (Cumhuriyet Savcısı, Mahkeme gibi) kullanımına sunulduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belge ile bu durumun belgelendirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle, haklarında bu yönde karar verilen

isteklilerin, ihalelere ilişkin başvurularının idarelerce dikkate alınması gerekmektedir.

Yoksa ihale mevzuatı ile ilişkilendirilmeyecek bir konuda (örneğin, konut dokunulmazlığının ihlali halinde), verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının konumuzla bir ilgisi yoktur ve süreci bu boyutuyla etkilememektedir.

Nitekim KİK Uyuşmazlık Kararlarına da belli ölçüde yansıdığı üzere, CMK'nın 231'nci maddesinde, "kararla birlikte kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder" açıklamasının madde metninde yer alması gerekçesiyle, söz konusu kararın 4734 sayılı Kanun'un 58 ve 59'uncu maddeleri ile ilişkilendirilemeyeceği ve hakkında karar verilen isteklilerin ihalelere başvuru yapabileceği yönünde olduğunu söyleyebiliriz.

Görüldüğü üzere; yaptırımda esas alınan husus, fiilin işlendiğinin Kanun'da belirtildiği üzere tespit edilmesidir. Aynı şekilde, hükmün açıklanmasına geri bırakılması halinde yine mahkemece, açıkça bir suç tespit edilmekle birlikte, sadece suçun doğrudan karşılığı cezanın, uygulanması belli koşullara bağlı olarak süreli ertelenmektedir. Yani, suçun tespit edilmesi kriteri her iki durumda da gerçekleşmektedir.

Diğer yandan, 5271 sayılı Yasa'nın 231/5'inci maddesinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile birlikte yargılamanın hukuki sonuçlarının ortadan kaldırılmış olduğu hususunun vurgulanması, düzenlemenin gerekçelerinde yer aldığı üzere, kişinin toplumdan soyutlanmasını engellemeye ve bireyi korumaya yönelik bir amaca dönük olduğu açıktır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonucunda mahkeme tarafından sanığın suçluluğu yönünde karar verilmekle birlikte, belirlenen bazı şartların oluşması halinde mahkemenin sanık hakkında verdiği mahkûmiyet kararını yine ileriye yönelik belli bazı şartların sanık tarafından gerçekleştirilmesi halinde açıklamaması anlamına gelmektedir.

Başka bir anlatımla, sanık hakkında yargılama tamamlanmakta ve sanığın suçlu olduğu yönünde mahkemede kanaat oluşmakta, fakat mahkeme sanığa hiç yargılama geçirmemiş sayılması için bir olanak daha tanımaktadır.

Böylelikle, sanık belirlenen yükümlülüklere uyduğu takdirde, verilen hüküm hukuki bir sonuç

doğurmayacaktır. Sanığı mümkün oldukça damgalamamak ve onları topluma sağlıklı ve normal bireyler olarak tekrar kazandırmak, bu düzenlemede temel hedef olarak öngörülmüştür.

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilk halinde doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılırken sonradan yapılan değişiklikle ihale usulleri arasında çıkarılmıştır. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, Kanun'da belirtilen özel hallerde ilân yapma, ihale komisyonu kurma, teminat alma ve 10'uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak idare ihtiyaçlarının karşılanması söz konusudur.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde (22.1.1.2.) yer alan; "*Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.*" şeklindeki düzenleme ile sözleşme yapma konusunda idareler (sözleşme düzenlenmesini gerektiren durumlar hariç olmak üzere) serbest bırakılmıştır.

İdarenin takdiri doğrultusunda sözleşme yapılan hallerde 4735 sayılı Kanun'da belirtilen hususlara uyma zorunluluğu bulunmaksızın, idarece işin niteliğine göre düzenlenecek; sözleşmenin konusunu, bedelini, süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme metinlerinin kullanılması mümkündür.

Buna karşın, bu kapsamda düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceğine dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca, sözleşmelerinin tarafları, eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemediği gibi, Kanun'un yorum ve uygulanmasında bu prensibin göz önünde bulundurulması gerekir.

Belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da yükleniciden teminat alınması, cezai yaptırımlar ön görülmesi, kabulle ilgili bir kısım prosedürler veya kabul sonrası sorumluluklar getirilmesi gibi geçerliliği yazılı kurala ihtiyaç gösteren uygulamaların tercih edildiği durumlarda da mutlaka yazılı sözleşme

düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Doğrudan teminle yapılan alımlarda yazılı sözleşme düzenlendiği durumlarda Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılması zorunlu değildir. Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda düzenlenecek sözleşmeler emredici hukuk kurallarına, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ve konusunun objektif olarak imkânsız olmaması şartı ile idare tarafından istenildiği şekilde yapılabilir.

Bu çerçevede, doğrudan temin bir ihale yöntemi değil satın alma yöntemi olması nedeniyle uygulama yönetmelikleri ve eklerinde yer alan hususlar doğrudan temin için geçerli değildir. Ancak doğrudan teminde yapılan sözleşmeye Borçlar Kanunu hükümler uygulanmasından hareketle, taraflar anlaştıklarında sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler. Keza bahse konu hususların ispatı yazılı sözleşme düzenlenmesi ile netlik kazanabilecektir.

Bunlarla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği (17.5.1.3'üncü maddesi)'nin; *"Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından yalnızca, "mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali", 4734 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Bu nedenle idarelerin, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinin uygulamasında, mahkumiyet kararlarının mesleki faaliyetten kaynaklanıp kaynaklanmadığını göz önünde bulundurması gerekmektedir.."* şeklindeki düzenlemesi uyarınca, mesleki faaliyetten kaynaklanmayan durumların dikkate alınmaması gerekmektedir.

Netice itibarıyla,

-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında öngörülen süre içerisinde tüm hukuki sonuçlar ortadan kalktığı için gerek ihale kapsamı ve gerekse doğrudan temin yöntemiyle alım olsun alım yapılmasına engel olmadığı ve adli sicil kaydında bu durumun gözükmediği,

-Kaldı ki doğrudan temin kapsamı alımlarda ihalelere ilişkin yeterlik kriterleri söz konusu olmadan alım yapılmasının mümkün olduğu,

-Doğrudan temin yöntemiyle alım kapsamında, alıma ilişkin olarak yeterlik kriterleri

belirlenerek şartname ve sözleşme düzenlenmek suretiyle alım yapılması durumunda, bu kapsamda düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceğine, ayrıca, sözleşmelerinin tarafları, eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği,

Değerlendirilmektedir.

89. İdareler doğrudan temin yöntemini kullanarak piyasadan güvenlik veya temizlik elemanı (taşeron) alımı yaparak bunları çalıştırılabilir mi?

Özet: *696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron olarak adlandırılan çalışanların kadroya geçişiyle birlikte, 2018 yılından sonra kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında gerek ihale suretiyle ve gerekse doğrudan temin yöntemiyle özel sektör elemanlarının şirketler aracılığıyla çalıştırılması mümkün değildir. Bu bağlamda, personel çalıştırılması dayalı hizmet alımı kapsamında, park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri ile temizlik işlerinin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan; refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işlerin ihale edilmesi mümkün değildir. Bu ihtiyaçların ancak sürekli işçi kadrolarına alım yapılması suretiyle karşılanması mümkündür. Ancak bu ve benzeri kapsamda sayılmayan ve yaklaşık maliyetinin %70'lik kısmından daha azının asgari işçilik maliyetinin oluşturduğu (yani personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında olmayan) alımların, Yasa'nın 22/d maddesinde sayılan parasal limitlere uygun olmak koşuluyla doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilmesi mümkündür.*

24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve söz konusu KHK'ya dayanılarak hazırlanan 1/1/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geçici Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar"da, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine dayalı sözleşmeler kapsamında çalıştırılanların, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Usul ve Esasların 4'üncü maddesinin beşinci fıkrasında "*Sürekli işçi kadrolarına geçirilmede dayanak alınan ihalenin, geçici 23 üncü maddedeki düzenlemeler ile bu Usul ve Esaslar çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığının belirlenmesine ilişkin görev, yetki ve sorumluluk idarelere aittir*" düzenlemesine yer verilmiş

ve ayrıca 51'inci maddesinde, bu işçilerin kadro veya statüye geçiş sürecinde, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23'üncü maddede yer alan ve özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı tanımı ile mevcut ihale sözleşmelerinin yürütümüne ilişkin hükümlerden kaynaklanabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumunun görevli ve yetkili kılındığı öngörülmüştür.

Mevcut durum itibarıyla, 696 sayılı KHK'nın 127'nci madde ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan değişiklikle taşeron konumunda bulunan ve 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar; kadrolu işçi olarak istihdamına yönelik düzenlemeler sonucunda bunların kadroya geçiş işleri tamamlanmıştır.

Yapılan bu düzenlemeden sonra, kapsama giren idarelerin 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacağı yine anılan düzenlemeler ile hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, artık idareler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri yoluyla istedikleri zaman insan kaynağı ihtiyacını karşılayamamaktadır. Zira ancak kadrolu işçi istihdamı ile bu nitelikteki ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.

Tekrar ifade etmek gerekirse, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet kapsamında olanların piyasadan karşılanması mümkün değildir. Buna karşın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet kapsamında olmayan insan kaynağı ihtiyacının eskiden olduğu gibi piyasadan karşılanması mümkündür.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ile personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı arasındaki temel kriter ise, asgari işçilik maliyeti için Kamu İhale Genel Tebliği'nden yer alan %70 asgari işçilik oranıdır.

Diğer taraftan, bu hususa ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun'un 62/e maddesinde gerekli ilave düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu maddede yer aldığı üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı

cetvellerde yer alan kamu idareleri (Milli İstibarat Teşkilatı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise **kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz.**

Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konuşu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade etmektedir. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.

Kamu İhale Kurumu, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

Konuyla ilgili Kamu İhale Genel Tebliği'nden de açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Tebliğde yer aldığı üzere, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemelerin, 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uygulanması söz

konusudur. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23 ve 24'üncü maddeleri gereğince kadroya geçiş uygulamasına tabi olan hizmet alımları ile bu hizmetlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan hizmetler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak değerlendirilmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarına karşılık gelmektedir.

Tebliğde yer verildiği üzere, danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilmez.

Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işler ile Kurum tarafından belirlenecek diğer işler ise, diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilir.

İhalelerin 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine uygunluğunun tespit edilmesinde; kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığına ilişkin değerlendirme, ilgili kısma ilişkin yaklaşık maliyet de dikkate alınarak her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Herhangi bir kısmın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olması halinde, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmesi gerekir.

Ayrıca, kısmi süreli çalışanlar ile tam zamanlı çalışanların tek bir hizmet alımına konu edilmesi halinde 696 sayılı KHK'nin 127'nci maddesiyle 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici 23'üncü maddenin onuncu fıkrasında düzenlenen "%70" oranının hesabının, çalışan tüm personel için yaklaşık maliyette öngörülen işçilik gideri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uygulanacak kurallara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunca belirlenen kurallar çerçevesinde,

- Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden;
- Park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri,
- Park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işlerinin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan; refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işler,
- KİK tarafından belirlenecek diğer işler,

Diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilecektir.

Ayrıca;

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23 ve 24'üncü maddeleri gereğince kadroya geçiş uygulamasına tabi olan hizmet alımları ile bu hizmetlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan hizmetler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak değerlendirilecektir.
- Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığına ilişkin değerlendirme, ilgili kısma ilişkin yaklaşık maliyet de dikkate alınarak her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Herhangi bir kısmın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olması halinde, ihale personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilecektir.
- İdareler tarafından; ihale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına, ihale konusu iş kapsamında tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışma yapılıp yapılmayacağına veyahut işin m, km, m^2, m^3, lt, ton, adet vb. birimler üzerinden birim fiyat veya götürü bedel teklif alınıp alınmadığına bakılmaksızın, ihale konusu hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi ile varsa malzeme ve makine gibi diğer hizmet girdilerinin belirtildiği analizler ile bu girdilerin yaklaşık maliyet içindeki ağırlık oranlarına yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekinde yer verilmesi zorunludur. Yapılacak analiz kapsamında, işçilik girdisine yönelik olarak, personel sayısı, personel maliyeti ve çalışma süreleri (kısmi/tam zamanlı)

bilgilerine yer verilecek, bu bilgiler EKAP üzerinde Hizmet Alımı İhalelerinde İş Tanımı ve İhale Bilgileri Formuna işlenecektir.

Kamu alımlarını düzenleyen temel yasa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu olup, anılan Kanun'un 18'inci maddesinde ihale usulleri; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak belirlenmiş, ayrıca 22'nci maddesinde, ihale usulü olarak sayılmayan doğrudan temin yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların genel alım yöntemi olan açık ihale usulü ile veya Kanun'daki şartların bulunması halinde belli istekliler arasında ihale usulü ya da pazarlık usulü ile ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, idarelerin Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendindeki limite kadar olan ihtiyaçları ile aynı maddenin diğer bentlerinde düzenlenmiş olan özel hallere ilişkin ihtiyaçlarını ihale yöntemlerine tabi olmadan, doğrudan teminle karşılamaları da mümkün bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda doğrudan temin uygulamasına ilişkin düzenlemeler Kanun'un 22'nci maddesinde yer almakta olup, bu madde kapsamında idarelerin yapılabilecekleri alımlar açıklanmıştır.

Bu bağlamda, Kanun'un 22'nci maddesinde belirtilen ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi şeklinde doğrudan temin kapsamı alımları özetleyebiliriz.

Diğer ihale usullerinden biriyle temin edilmesi gereken bir ihtiyacın bu kapsamda karşılanması söz konusu değildir. Zira doğrudan temin yönteminde parasal sınır mevcuttur.

İhalenin iptal edilmesi, mahkemece yürütmenin durdurulması veya iptal kararının verilmesi gibi sebeplerle ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin (b) bendindeki "idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar" kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62'nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da

dikkate alınarak aynı Kanun'un 21'inci maddesinin (f) bendi ya da 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve sorumluluğundadır.

İlave olarak, idare ihtiyaçlarının karşılanması noktasında açık ihale temel usul olup, Kanun'da öngörülen hallerde pazarlık usulü ihale ile doğrudan temin yöntemi ise özel durumlarda başvurulan alım şekillerdir.

Netice itibarıyla;

-696 sayılı KHK ile yapılan değişiklikler sonucunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında kamuda çalışan taşeron olarak adlandırılan çalışanların sürekli işçi kadrolarına alındığını, bu nedenle mevcut düzenlemeler uyarınca ihale suretiyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında temizlik personeli alımının gerek ihale kapsamında ve gerekse doğrudan temin yöntemiyle çalıştırılmasının mümkün olmadığını ifade edebiliriz.

-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olmayan alım kapsamında özel şirket elemanlarının 4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle çalıştırılmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

-Çalıştırılan kişinin personel çalıştırılması kapsamında olup olmadığında Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer alan düzenlemelerin esas alınması gerektiği, söz konusu düzenleme uyarınca, "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı"; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarına karşılık geldiğini belirtebiliriz.

Bu itibarla, yukarıda aktarılan kurallar da dikkate alınarak, KİK tarafından açıklandığı üzere, ilan ön kontrol sürecinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğurduğu tespit edilen ilanların idaresine iade edilmesinin söz konusu olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, ilan işlemlerine, söz konusu alımın 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil etmediği hususuna ilişkin,

Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı tarafından imzalı yazının Kuruma ulaşmasından sonra devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Dolayısıyla, bu sürece aykırı işlemlerin gerek çalışanlar ve gerekse yöneticiler düzeyinde sorumluluklara neden olduğunu ifade edebiliriz.

90. Doğrudan temin yöntemi alımlara ilişkin olarak KİK'in resen inceleme yetkisi var mıdır?

Özet: *İhalelere yönelik şikayet mekanizması genel olarak ihale kapsamı alımları kapsamakta olup, önce idareye sonra KİK'e yönelik bir şikayet mekanizması söz konusudur. İdari başvuru yolları tüketilmeden dava açılması mümkün değildir. Her ne kadar doğrudan temin kapsamında yer alan alımlar, ihale usulleri dışında olsa bile Anayasa'nın 125'inci maddesi çerçevesinde yargı yoluna başvurulması mümkündür. Ancak öncesinde çeşitli yargı kararlarına yansıdığı üzere, isteklinin alımı gerçekleştiren idareye başvurarak hatanın düzeltilmesini istemesi, bunun sonucuna göre gerekirse dava konusu edilmesi hem 4734 sayılı Yasa hükümleri hem de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri açısından daha uygun bir işlem olacaktır. Ancak doğrudan temin kapsamında idareden sonra KİK'e yapılan şikayet başvuruların KİK tarafından reddi söz konusu olmaktadır. Ayrıca, 5812 sayılı Yasa ile 4734 sayılı Yasa'da yapılan değişiklikle KİK'in resen inceleme yetkisi kaldırılmış olup, mevcut durum itibarıyla bu yönde bir yetkisi bulunmamaktadır.*

Kamu İhale Mevzuatına göre, ihale onayının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre, ihale süreci olarak kabul edilmekte ve bu süreç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değerlendirilmekte, buna karşın, bu süreç dışında kalan işlemlere yönelik başvurular ile sözleşme imzalandıktan sonra yapılan başvurular idarece veya KİK tarafından inceleme konusu yapılamamaktadır.

İhalelere yönelik başvuru yolları, şikâyet ve itirazen şikâyettir. Şikâyet, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur. İtirazen Şikâyet ise Kuruma (KİK'e) yapılan başvurudur.

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden, "aday, istekli ve istekli olabilecekler" şikâyet başvurusunda bulunabilmektedir.

Ayrıca, şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler idareye şikâyet başvurusunda bulunmadan doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilir.

Kuruma yapılan başvurulardan; idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadan doğrudan Kuruma yapılan, idareye yapılan şikâyet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan Kuruma yapılan, idarenin 10 günlük karar verme süresi beklenmeden kuruma yapılan, idareye yapılan şikâyet başvurusundan tamamen farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.

Aynı bağlamda, Kurum tarafından yapılacak incelemenin kapsamı, ilan veya ön yeterlik/ihale dokümanına yapılan başvurular, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlarla sınırlıdır. Dolayısıyla, ihalenin iptali kararlarına karşı yapılan başvurular, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.

5812 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun şikâyet konusuyla ilgili maddelerinde kapsamlı değişiklikler yapılmış olup, yapılan bu değişiklikler kapsamında; Kanun'un 54'üncü maddesindeki "inceleme talebinde bulunulması" kavramı yerini "ihalelere yönelik başvurular" şeklinde değiştirilmiş ve başvuru usul ve esasları ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu bağlamda, ancak ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin önce idareye şikâyet, daha sonra Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri şeklinde iki aşamalı inceleme sistemi öngörülmüştür. Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak düzenlenmiştir.

Gerekli şikâyet şekil şartlarını taşımayanlar ile henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilecektir.

Öte yandan, Kamu İhale Kurumuna yapılan şikâyetlere ilişkin olarak, karar alma süreleri ve Kurulun alabileceği karar türleri, Kamu İhale Kanunu'nda ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, herhangi bir şikâyet başvurusu üzerine Kurulca yapılan inceleme sonucunda, şikâyet başvurusunun reddi yanında, hukuka aykırı işlemi yapan idare tarafından düzeltme yapılması yoluna gidilebileceği durumlarda düzeltici işlem, düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka

aykırılıkların tespiti durumunda ise ihalenin iptali yönünde karar verilebilmektedir.

Ayrıca, Kurumun verdiği şikâyet başvurusu üzerine verdiği kararlar idari yargı denetimine açık olduğu gibi, tamamı EKAP'ta yayınlanmak suretiyle kamuoyu denetimine de açılmıştır.

Şekil şartlarını taşıyan ve başvuru süresi aşılmayan durumlarda, Kurum tarafından esas incelemeye geçilir. Yapılan esas inceleme; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerinde aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından "eşit muamele" ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönündeki incelemeye karşılık gelmektedir.

Eşit Muamele ise, dayanağı bakımından itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ifade etmektedir.

Kaldı ki sözleşmenin Kanun'da belirtilen sürelere ve usule uyulmadan imzalanmış olması veya itirazen şikâyet başvurusundan feragat edilmesi, Kurum tarafından itirazen şikâyet başvurusunun incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.

İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Kurul tarafından alınan kararların eksik ya da yanlış uygulandığı iddiasıyla, yeniden itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

Görüldüğü üzere; ihale kapsamı bir alımı için 4734 sayılı Yasa'nın öngördüğü kurallar uyarınca önce idareye başvuru yapılması gerekmektedir.

Doğrudan temin yöntemi ile alım yapılmasının uygun olduğu durumlarda alımın niteliğine yönelik iddiaları incelemek Kurumun görev alanı dışındadır.

Dolayısıyla, doğrudan temin ile ilgili idari işlem ve eylemler hakkında Kamu İhale Kurumunun inceleme yetkisi bulunmadığından, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gerçekleştirilen idari işlem ve eylemler için 2577 sayılı Kanun çerçevesinde yargıya başvurulur.

Doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarda idari dava türlerine bakılacak olursa, doğrudan temin alım yönteminin 4734 sayılı Kanun'a tabi olan ihale usullerinden olmaması ve idarenin takdir yetkisinin ağırlıkta olarak kullanılması nedeniyle, bu konuda açılan bir davaya ilişkin olarak Danıştay'ın ilgili dairesince verilen bir Kararda da; "…4734 sayılı Kanunun 54, 55 ve 56. maddelerinde öngörülen usul izlenmeden, başka bir anlatımla öncelikle idareye başvurulmadan ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılmadan açılan davada; 2577 sayılı Kanunun 14. maddesinin (3-b) işaretli bendinde belirtilen merci tecavüzü bulunduğundan, anılan Yasanın 15. maddesinin (1-e) işaretli bendi uyarınca dava dilekçesinin görevli idare merciine tevdiine karar verilmesi gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır." hususu yer almaktadır.

Böylelikle idari başvuru yollarından farklı olarak, doğrudan temin alımı ile ilgili idari yargıda açılan davalar belli başlı niteliklere ilişkin olup, ayrı bir yargılama usulüne tabi olmadığı görülmektedir.

Her ne kadar karara konu alım türü ihale kapsamı bir alım olsa da kararda da dikkat çekildiği üzere, yasanın öngördüğü koşul uyarınca, davadan önce idari mekanizmaların tüketilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, doğrudan temin kapsamı alım da olsa önceden idare başvuru yoluyla bu işlemin düzeltilmesinin talep edilmesi uygun olacaktır.

Nitekim KİK tarafından verilen bir Uyuşmazlık Kararında da; "… *Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşıldığından ve kapsamda yer almayan bu ihalede idarenin kararına karşın yetkili idare mahkemesine başvurulması gerektiğinden 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun görev yönünden reddine …"* karar verilmiştir.

Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14'üncü maddesinde, açılan davada idarî merci tecavüzü bulunup bulunmadığının ilk inceleme sırasında inceleneceği; 15'inci maddesinde de idarî merci tecavüzü halinde, dilekçelerin görevli idarî mercie tevdiine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanun'un 57'nci maddesinde de "Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihaî kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür." hükmüne yer verilmiştir.

Hukuk devletinin en temel özelliklerinden biri olan idarenin hukuka bağlılığı ilkesi gereği, idareler tarafından yapılan bütün işlem ve eylemlerin hukuka uygun olarak yapıldığı kabul edilir. İdarenin her ne kadar bazı işlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi olmaması hukuk devleti ile bağdaşmayan bir durum olsa da, idarenin yapmış olduğu bütün eylem ve işlemeleri yargı denetimine tabi olması esastır.

Bu husus Anayasa'nın 125'inci maddesinde açıkça düzenlenmiş olup, bu kapsamda idare tarafından yapılan işlem veya eylem hukuka aykırılık teşkil ediyorsa dava açılabilecektir.

İdari yargıda bir işlemin dava konusu yapılabilmesi için yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımından, bir veya birkaç unsurun hukuka aykırılık teşkil etmesi gerekmektedir. İdari davalarda sıklıkla karşılaşılan sorun idarenin takdir yetkisine ilişkindir.

Zira Danıştay kararlarında, takdir yetkisinin keyfiyetten uzak bir irade ile yapılması gerektiği sıklıkla vurgulanmıştır. Yargı denetimi yapılırken yargı organları sadece hukuka uygunluk denetimi yapabilmekte, idarenin yerine geçerek karar verme yetkisini kullanamamaktadır.

Bu bağlamda, doğrudan temin alımı ile ilgili idari yargıda açılan davalar belli başlı niteliklere ilişkin olup, ayrı bir yargılama usulüne tabi olmadığı söylenebilir.

Diğer taraftan, 26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11, 12 ve 13'üncü maddeleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53 ve ek 1'inci maddelerinde değişiklik yapılmış ve aynı Kanun'a geçici 21'inci madde eklenmiştir.

Söz konusu değişiklikler kapsamında 7421 sayılı Kanunun 11'nci maddesi; "Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen

otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez. Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez."

Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu değişiklikle birlikte, KİK'e yapılan itirazen şikâyet başvuruları ile ilgili olarak 26/11/2022 tarihinden önce alınan Kamu İhale Kurulu kararlarında uygulanmak üzere; İddialarının tamamında haklı bulunan başvuru sahipleri tarafından, 7421 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 26/11/2022 tarihini izleyen 30 gün içinde itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine yönelik olarak Kuruma yazılı talepte bulunulması durumunda, başvuru sahiplerine Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesine karar verileceğine, ayrıca bedel iadelerinin Kurum tarafından, talep tarihini izleyen 30 gün içinde yapılacağına, yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bunlarla birlikte, öncesinde 2008 yılında 5812 sayılı Yasa ile Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkilerinde de önemli değişiklikler yapılmış ve Kurumun resen iddiaları inceleme yetkisine son verilmiştir. Kurumun daha etkin çalışması gerekçesiyle bu değişiklik yapılmış olup, böylelikle, KİK'in incelemesi sadece şikayet başvuruları ile sınırlandırılmıştır.

Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun çerçevesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı eylem ve işlemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler tarafından yapılabilen şikâyet başvuruları dışında, KİK'in herhangi bir ihaleyi kendiliğinden inceleme yapması hukuken mümkün değildir.

Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde ilgililer doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir. Ayrıca, Kamu İhale Kurulunun bireysel nitelikli kararlarına karşı ilk derece mahkemesi olarak Ankara İdare Mahkemesinde, düzenleyici nitelikteki işlemlerine karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da dava açılması mümkündür.

91. Doğrudan temin kapsamı alımlarda taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda ne yapılır?

Özet: *İdarece satın alımı yapılan doğrudan temin kapsamı edimin yüklenici tarafından yerine getirilmemesi durumunda, bu durum doğrudan veya dolaylı bir şekilde kamu hizmetinin aksamasına neden olabilir. Bunu ortadan kaldırmak için alıma ilişkin dokümanlara gecikme cezasına ilişkin hükümler konulabilir. Bu nedenle sözleşme düzenlenmesinde fayda olduğunu söyleyebiliriz. Kamu İhale Genel Tebliği'nde sözleşme düzenlenmesinin zorunlu olduğunun belirtildiği iki durum hariç olmak üzere, idarenin takdirine bırakılan hususlarda da olası belirsizliklerin yaşanmaması adına yazılı sözleşme düzenlenmesi yararlı olacaktır. 4735 sayılı Kanun hükümleri ve tip sözleşmeler referans olarak kullanılabilecektir. Süreçte 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmaması halinde, yine aynı Kanuna göre Borçlar Kanunu hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, çeşitli Sayıştay Kararlarına yansıdığı üzere, yükümlü ile idarenin sözleşme düzenlemesi durumunda, bu sözleşme iki taraf için de bağlayıcıdır. Ancak yükümlünün hukuki gerekçeler olmadan taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda, uygulanacak idari yaptırımların dışında, konunun adli bir boyutu da varsa kuşkusuz bu hususta gerekli takibatın yapılması icap eder.*

"Doğrudan temin" kavramı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde, (4734 sayılı) Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmaktadır. Kanun'un ilk kabul edildiği haliyle, bir ihale türü olarak belirlenen "Doğrudan temin" 15.08.2003 tarihli ve 25200 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır.

4734 sayılı Kanun'un "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesinde Kanun kapsamındaki ihale usulleri açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olarak sayılmakta olup, Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesi incelendiğinde, doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece madde metninde belirtilen durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu görülmektedir.

4734 sayılı Yasa maddeleri arasında yer verilmiş olsa da doğrudan temin aslında bir ihale türü (usulü) olmayıp, bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve Kanun'un

10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi söz konusudur.

Ancak belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

İdarelerin doğrudan temin kapsamında en çok kullandığı alım türünü Kanun'un 22/d maddesi kapsamında yer verilen ve her yıl Kamu İhale Tebliğince güncellenen belirlenen parasal değerleri aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak alımlar oluşturmaktadır. Belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanun'un ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme düzenlenmesi zorunlar durumlar hariç idarelerin takdirinde olmakla birlikte, belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da yüklenicinin yükümlülüklerinin net olarak ortaya konulması ve olası çeşitli yaptırımların açıklığa kavuşturulması amacıyla, yazılı sözleşme düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Böyle bir durumda, hazırlanacak sözleşme tasarısı ve idari şartnamenin, fiyat araştırması yapılan kişilere verilmesi ve bunların da isteklilerle bu esaslı noktaları paylaşması gerekir.

Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmelikleri ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olması gerekli değildir, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, ihale uygulama yönetmelikleri ekinde yer alan tip sözleşmede yer alan ceza ile ilgili sınırlamalar, doğrudan teminde düzenlenen sözleşmeler için geçerli değildir. Ancak idareler isterlerse, bu dokümanlarda kısmen veya tamamen yararlanabilir.

Doğrudan teminde yapılan sözleşmelerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmakta olup, taraflar anlaştıklarında sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler. Bu hükümler, çeşitli

Sayıştay Kararlarına da yansıdığı üzere, bağlayıcılık taşımaktadır. Zira mevcut ihale mevzuatı hükümlerinde doğrudan temin yöntemi ve sözleşme sürecine ilişkin açıklayıcı düzenlemelerin bulunmadığını söyleyebiliriz.

Bu bağlamda, idare bu yöntemle yaptığı alıma ilişkin hususları bir yazılı sözleşme bağlamak ve bu sözleşmede malın/işin geç teslim edilmesi/gerçekleştirilmesi veya hiç teslim edilmemesi/gerçekleştirilmemesi durumlarında uygulanacak cezai müeyyidelere yer vermek suretiyle gerçekleştirebilir. İdarenin taahhüdünü geç yerine getiren veya hiç yerine getirmeyen kişiyi bağlı bulunduğu ticaret/meslek odasına şikâyet etmesi de mümkündür.

Nitekim 2009 tarihli bir Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı'nda; *"Dilekçi dilekçesinde doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığından mal alımlarında herhangi bir cezai müeyyide bulunmadığını ileri sürmüş ise de, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin d bendine göre yapılan ... alım yöntemi ile idarelere geniş bir takdir alanı tanınmıştır. Bunlardan biri de, sözleşme yapıp yapmama serbestliğidir. ...idare ile satıcılar arasında sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmelere, malzemenin zamanında teslim edilmemesi halinde gecikme cezası kesilmesi yönünde hükümler konulmuştur. Kanunlara aykırı olmayan sözleşme hükümlerinin uygulanması da zorunlu olup, tarafları bağlar."* ifadelerine yer verilerek, doğrudan teminde düzenlenen sözleşmelerin tarafları bağlayacağı belirtilmektedir.

Başka bir Kararda ise *"4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin usulünde, ... Müdürlüğü de, ihtiyacı olan malzemelerin dorudan temin usulüyle alınması sırasında yüklenici firma ile, ... tarihinde bir mal alım sözleşmesi imzalamak suretiyle bu konudaki takdirini sözleşme yapma yönünde kullanmıştır.* ***Dolayısıyla, bu aşamadan sonra artık idare ve yüklenici, malzeme alımının doğrudan temin usulüyle yapıldığından bahisle aralarında imzalamış oldukları bu sözleşme hükümlerine aykırı davranamazlar…*** *tarihinde teslim edilmesi sözleşme hükmüne aykırı olduğundan, bu geç teslimden dolayı gecikme cezası kesilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır."* hususlarının yer aldığı görülmektedir.

Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar" başlıklı 7'nci maddesinde; "*Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: ...*

...n) Gecikme halinde alınacak cezalar..." hükmü ile

"İdarenin sözleşmeyi feshetmesi" başlıklı 20'nci maddesinde, *"Aşağıda belirtilen*

hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi…" hususuna yer verilerek, yüklenicinin edimini sözleşme hükümlerine aykırı surette yerine getirmemesi halinde ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezasının söz konusu olabileceği hüküm altına alınmıştır.

Konuyla bağlantılı olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun "Sözleşmenin kurulması"na yönelik düzenlemeleri dikkate alındığında, anılan Kanun'da;

1 nci maddesinde; Sözleşmenin, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacağı, irade açıklamasının, açık veya örtülü olabileceği,

4 üncü maddesinde; kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye yapılan öneri hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulacağı, telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılacağı,

12 nci maddesinde; sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı olmadığı, Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şekli olduğu, öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmelerin hüküm doğurmayacağı,

13 üncü maddesinde; Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulmasının zorunlu olduğu, ancak, sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümlerin bu kuralın dışında olduğu, bu kuralın, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanacağı,

14 üncü maddesinde; yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunmasının zorunlu olduğu, kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçeceği,

17 nci maddesinde; Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşmenin tarafları bağlamayacağı, herhangi bir belirleme olmaksızın yazılı şekil kararlaştırılmışsa, yasal yazılı şekle ilişkin hükümlerin uygulanacağı,

27 nci maddesinde; Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik

haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüz olduğu, sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemeyeceği, ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamının kesin olarak hükümsüz olacağı,

Hususları yer almaktadır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile hükme bağlandığı üzere, Kanun kapsamında yapılan sözleşmelerin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı hususlara yer verilemeyeceği gibi, Kanun'un yorum ve uygulanmasında da bu prensibin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bundan dolayıdır ki yine aynı Kanun hükmü gereğince, 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağının hükme bağlanması ve söz konusu Kanun ile de tarafların eşitliğinin ilke edinilmesi ve sözleşme hükümlerine aykırılığın da yaptırıma bağlanmasını önemli bir husus olarak ayrıca vurgulayabiliriz.

Bu çerçevede, yukarıda yer verilen Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olmadığı sürece sözleşmeler geçerli olup, sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulabilmektedir. Ancak ilgili kişi teklifinde teklifinin belli bir süre için geçerli olduğunu söylerse, bu sürenin sonunda teklifi geçerliliğini yitireceği için sorumluluktan kurtulacaktır. Yoksa önerisiyle bağlıdır. Dolayısıyla isteklinin piyasa fiyat araştırmasında vermiş olduğu teklif Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde kendini bağlamaktadır.

Sözleşmelerin geçerliliğinin, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı olmadığı, kanunda sözleşmeler için öngörülen şeklin, kural olarak geçerlilik şekli olduğu, öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmelerin hüküm doğurmayacağı, bu kapsamda idareler tip sözleşmelere bağlı kalmadan serbestçe sözleşme düzenleyebilir.

Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunlu olduğu, kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce

imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçeceğinden, istekli tarafından sunulan fiyat teklifinin bu bağlamda da geçerli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, imzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunlu olup, bu yönüyle de imzalı teklif sunan kişiyi bu teklif bağlamaktadır.

4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan durumlarda, Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğinden hareketle, her ne kadar 4735 sayılı Kanun'da ihale kapsamı sözleşmeler kapsama girse de doğrudan temin kapsamı alımların ihale mevzuatında düzenlenmesi ve ayrıca burada Borçlar Kanunu anlamında bir borç alacak ilişkisinin varlığından hareketle anılan Kanun hükümlerinin uygulanabileceği düşünülmektedir.

Diğer bir anlatımla, Borçlar Kanunu bağlamında, piyasa fiyat araştırması boyutuyla teklif alma sürecinde, bir anlamda öneri ve kabul gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Kanun'da yer aldığı şekliyle öneri ve kabul süreci tamamlanmakta bir anlamda sözleşme oluşturulmaktadır. Çünkü Kanun'a göre, sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulmaktadır.

Dolayısıyla, isteklinin vermiş olduğu teklifin Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde kendisini bağladığı ve yasal süresi içerisinde teklifinden vazgeçtiğini idareye bildirmediği durumda teklifin geçerli olduğu, teklif kapsamında geçerli olan taahhüdünü yerine getirmezse anılan Kanun çerçevesinde idarenin zararını karşılamak zorunda olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan gecikme cezasına ilişkin olarak Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme ve Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme metinleri incelendiğinde, anılan Tip Sözleşmelerde de gecikme cezasının sözleşme bedelinin belli bir oranı olarak belirlendiği görülmektedir.

İlave olarak, mal alımı, hizmet ve danışmanlık hizmetleri ile yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde, gecikme cezasının hesaplanmasında sözleşme bedeli olarak ilk sözleşme bedelinin esas alınması gerekmektedir. Gecikme cezası, borçlunun üstlendiği yükümlülüğü kararlaştırılan şekilde yapmaması nedeniyle alacaklıya ödemek zorundu olduğu parasal tutardır.

Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gecikme cezası uygulanmasına yönelik düzenleme varsa, bu durumda sözleşme konusu iş gereği gibi yapılmamışsa, mutlaka ceza maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmelidir. İdare tarafından, sözleşmenin feshedilmesine yönelik yükleniciye verilecek ihtarlı süre de sözleşmede belirtilmelidir. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminatın gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek, alım konusu işin genel hükümlere göre tasfiye edileceğinin sözleşmede belirtilmesinde yarar bulunmaktadır.

Doğrudan temin; ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen gerçek/tüzel kişilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olup, bu alımlarda genel kural, sözleşme düzenlenmesi hususu idarelerin takdirinde olmakla birlikte, 22'nci madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumu ile 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur. Bunun dışında sözleşme düzenlenmesi zorunlu tutulmamıştır. Dolayısıyla ortada düzenlenmiş bir sözleşme varsa, bunun gereğinin yapılması gerekmektedir. Söz konusu sözleşme tarafları bağlamaktadır.

Bu çerçevede borçlu olarak teklif sahibi borcunu ifa etmezse 6098 sayılı Kanun'un, "Borcun ifa edilmemesi" kapsamındaki 112'nci maddesinin " Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür." hükmü çerçevesinde işlem tesis edilebileceği, dolayısıyla idarenin bir zararı söz konusu ise bunun karşılanması gerektiğini söyleyebiliriz.

İhale mevzuatı açısından yaptırım boyutuna baktığımızda; doğrudan temininin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda yer alan müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu alım yönteminde verilen teklifine uymayan veya sözleşme konusunu teslim etmeyen kişiler hakkında ihale mevzuatına göre uygulanacak bir müeyyide bulunmamaktadır.

İhale sürecine ilişkin iş ve işlemler, 4734 sayılı Kanun'a göre, sözleşmenin imzalanmasından sonraki süreç ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre gerçekleşmektedir.

Ancak 4735 sayılı Kanun, ihale kapsamında gerçekleştirilen alımlara ait sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin süreci kapsamaktadır. Dolayısıyla doğrudan temin kapsamı alımlar için

söz konusu Kanun hükümlerin uygulanması mümkün değildir. Ancak idareler tarafından alım öncesi idari şartname ve sözleşme tasarısı ve diğer ihale dokümanlarında yer vermek şartıyla bu yönde düzenlemeler yapılabilir.

Yüklenici çeşitli nedenlerden dolayı taahhüdünü yerine getirmeyebilir. Bunların bir kısmı tutukluluk, acz içine düşme veya sözleşme öncesi yasak fiil ve davranışlar gibi birçok nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Bu bağlamda, söz konusu Kanun'a baktığımız zaman; Kanun'un 17'nci maddesinde; "Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti" durumu, 18'inci maddesinde; "Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet" durumu, 19'uncu maddesinde; "Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi", 20'nci maddesinde; "İdarenin sözleşmeyi feshetmesi", 21'inci maddesinde; "Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih", 22'nci maddesinde; "Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler", 23'üncü maddesinde; "Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi", 24'üncü maddesinde; "Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi" hususları anılan Kanun'da düzenlenmiştir.

Söz konusu maddelerden Yasa'nın 20'nci maddesinde; "Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir." hükmü yer almaktadır.

Müteakip maddelerde açıklandığı üzere, bu kapsamda, sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında yasaklama kararı verilmesinden başka sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Doğrudan teminin, Kanun kapsamında yer verilen bir ihale türü olmaması nedeniyle, bu alım yöntemine ilişkin yasaklama kararı verilmesi de mümkün değildir. Bununla birlikte, tespit edilen fiile ilişkin olarak ceza takibatı gerektiren bir durumun varlığı halinde, ceza kanunları ve diğer kanunlardaki yaptırımların uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı" başlıklı maddesinin ilgili bölümünde (28.1.10.),*"...doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez."* açıklaması yer almaktadır. Söz konusu hüküm, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da 4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde belirtilen fiillerden birinin gerçekleştirilmesi durumunun ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini ifade etmektedir.

Zira rüşvet vermek, sahte evrak düzenlemek gibi yasak fiiller ve davranışlar, aynı zamanda TCK kapsamında tanımlanmış suçlar olması nedeniyle, 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümleri aracılığıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine gidilmesi gerekmektedir. Hatta bu fiillere memurların iştiraki halinde, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri gereğince, izin almadan adli makamlarca ilgili personelin resen soruşturulması söz konusudur.

Diğer taraftan her ne kadar ihalelerde yasaklama kararı söz konusu olmasa da idareye karşı taahhüdünü yerine getirmeyen esnaf veya tacire ilişkin olarak ilgili odalarca idari ceza verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Bu itibarla, 4735 sayılı Yasa uyarınca ihale kapsamı alımlara ait sözleşmelerde gecikme halinde uygulanacak cezanın belirtilmesi zorunluluk olmasına karşın, doğrudan temin kapsamı alımlar için böyle bir zorunluluk yoktur. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gecikme cezası uygulanmasına yönelik sözleşmenin bulunması ve sözleşme konusu işin zamanında yapılmaması nedeniyle ceza gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde mutlaka ceza maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmelidir.

Doğrudan teminde yapılan sözleşmelerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Taraflar anlaştıklarında sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler. Belli bir süreye ihtiyaç göstermediği için sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmayan alımlarda da cezai yaptırımlar ön görülmesi durumunda, mutlaka yazılı sözleşme düzenlenmesi

gerekmektedir. İdareler 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan tip sözleşmeleri kısmen veya tamamen referans olarak kullanılabilir.

Netice itibarıyla; doğrudan temin kapsamı alıma ilişkin olarak idareye karşı vermiş olduğu fiyat teklifinin gereğini yerine getirmek istemeyen isteklinin varlığı halinde, idare, her şeyden önce taahhüdünü yerine getirmeyen istekliden bundan sonra alım yapmaktan kaçınabilir. Doğrudan temin yöntemi ihale türlerinden biri olmadığı için her ne kadar ihalelerden yasaklama kararı verilmesi mümkün olmamakla birlikte, idare bu süreçte şayet bir zararı uğramışsa (adli boyuta ilişkin hususlar saklı kalmak üzere) genel hükümlere göre bu zararın giderilmesini isteyebilir. Ayrıca, teklif sahibinin (esnaf/tüccar) meslek durumuna bağlı olarak bağlı olduğu meslek örgütüne konunun intikali suretiyle ilgili için disiplin cezası hükümlerinin işletilmesinin de söz konusu olabileceğini ifade edebiliriz.

92. Çeşitli hukuki düzenlemelerde birlikte ifade edilen 4734 sayılı Yasa'nın 22/d ve 21/f maddeleri kapsamı alımlar arasında bir bağlantı var mıdır?

Özet: *4734 sayılı Yasa'nın "Temel ilkelere" ilişkin 5'inci maddesinde yer verildiği üzere, anılan Kanun'a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuller olup, gerek pazarlık usulü kapsamındaki alımlar ve gerekse doğrudan yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar istisnai durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Ayrıca, doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmamasına karşın, pazarlık usulü bir ihale türü olup, bazı noktalarda pratik süreçler olsa bile özü itibarıyla farklı düzenleme ve esaslara tabi olduğunu ve pazarlık usulü kapsamındaki alımlara ait işlemlerinin EKAP üzerinde yürütüldüğünü ifade edebiliriz. Yasa'nın 22/d kapsamı alımları için 2022 yılı için öngördüğü parasal sınır, Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için 218.395.- Türk Lirası, diğer idarelerin için 72.752 Türk Lirası iken, 21/f kapsamı alımlar için bu sınır her durum için 728.072.-TL olup, idare ihtiyaçlarının parasal sınıra uymak şartıyla öngörülen yöntemle alınabileceğini, ancak 21/f kapsamında yapım işi alımının mümkün olmadığını ifade edebiliriz.*

Zaman zaman idareler tarafından pazarlık veya doğrudan temin kapsamında benzer nitelikte alımların gerçekleştirilmesi söz konusu olabilmektedir. Söz konusu alım türlerinin kullanılmasının idare açısından olumlu ve olumsuz yönlerinin bulunduğunu öncelikle ifade edebiliriz.

Doğrudan temin kapsamı alımlar ile pazarlık usulü kapsamındaki alımların nitelikleri itibarıyla farklı özellikleri olduğunu, ancak bazı noktalarda bu alımlar arasında bir ilişki bulunduğunu ifade edebiliriz.

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Yasa'nın 21'inci maddesinde pazarlık usulü kapsamında yapılan alımlar bentler halinde sayılmakta, doğrudan temin kapsamı alımlar ise, 4734 sayılı Yasa'nın 22'nci maddesinde aynı şekilde bentler halinde sayılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin yönteminde, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın,

ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu alım yönteminde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarelerin takdirindedir.

Söz konusu iki alım yöntemi 4734 sayılı Yasa'da tanımlanmış olsa da doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımların farklı usullere tabi olduğunu çünkü söz konusu alımın bir ihale usulü olmayıp ihale yöntemi olduğunu söyleyebiliriz.

Bu kapsamda 4734 sayılı Yasa'da yer aldığı şekliyle;

"Pazarlık usulü; Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü" ifade etmektedir.

Buna karşın, "Doğrudan temin; Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü" ifade etmektedir.

Özellikle söz konusu alım türleri açısından Yasa'nın 22/d maddesi ile 21/f maddesi açısından birçok noktada benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır.

Bu bağlamda, pazarlık usulünün yaygın olarak kullanıldığı 21/f kapsamında İdarelerin yaklaşık maliyeti 728.072 Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları, bu kapsamda karşılanırken,

Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle 2022 yılı için geçerli olan parasal değerler, Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 218.395.- Türk Lirası, diğer idarelerin 72.752 Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar kapsama girmektedir.

Görüldüğü üzere; Yasa'nın rakamsal sınırı aşmamak kaydıyla aynı nitelikteki bir ihtiyacın 21/f veya 22/d kapsamında alınmasına engel yoktur.

Dolayısıyla, 2022 yılı için geçerli olan rakamsal sınırlar dikkate alınarak, örneğin İkiyüz bin

Türk Lirası değerinde bir demirbaş alımı 21-f pazarlık kapsamında karşılanabileceği gibi, doğrudan temin yöntemiyle de alınabilir. Burada dikkat edilmesi gereken 21-f kapsamında yapım işi ihalesi yani alım yapılması mümkün değildir.

Nitekim Yasa'nın 21'inci maddesine ilişkin pazarlık usulüne ilişkin ilk fıkrada yer aldığı üzere, söz konusu hallerde …"yapılabilir" şeklinde belirleme yapılmıştır. Yasa'nın 22'nci maddesinde de benzer şekilde … "doğrudan temini usulüne başvurulabilir" şeklinde yine bir tercih durumundan söz edilmiştir. Yani bir zorunluluk söz konusu değildir.

Her iki alım kapsamında karşılanabilecek ihtiyaçlar tek tek sayılarak bir belirleme yapıldığı için, kıyas yoluyla bunların genişletilmesi söz konusu değildir.

Diğer taraftan, Yasa'nın temel ilkelere ilişkin maddesinde yer verildiği üzere, 4734 sayılı Kanun'a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.

Zira Kanun'un temel ilkelerinde yer verildiği gibi, gerek pazarlık usulü kapsamındaki alımlar ve gerekse doğrudan yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar istisnai durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Yoksa her iki alım yönteminden vazgeçilerek ihtiyacın açık ihale usulü ile karşılanmasına engel yoktur.

Ancak her iki alım kapsamında da uygulanacak prosedürlerden kaçınmak amacıyla alım konu ihtiyacın kısımlara bölünmemesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, her iki alım yönteminde de pratik süreçler söz konusu olabilmektedir. Doğrudan temin kapsamında, ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilmesi noktasında idare bütünüyle serbest iken, pazarlık usulünde kısmi bir serbestlik söz konusudur. Zira, Yasa'nın pazarlık usulünün düzenlendiği 21'nci maddesinde yer aldığı üzere, (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Pazarlık usulü 4734 sayılı Kanun'da açıklandığı üzere, bir ihale usulü olup, ihale süreçlerinin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İhaleye katılmak için ise belli yeterlik

kuralları bulunmaktadır.

Hatta pazarlık usulü kapsamında alımlar da kendi içinde alımın niteliğine bağlı olarak, (a), (d) ve (e) bentleri ile (b), (c) ve (f) bentleri açısından uygulanacak ihale prosedürleri ve yeterlik kriterleri açısından farklılıklar söz konusu olabilir. Örneğin; alım şekline göre istenilecek iş deneyim belgeleri farklılık gösterebilmektedir.

Öte yandan, 8/05/2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilanı/duyurusu 03/10/2022 tarihi veya sonrasında yapılan tüm açık ihaleler ile 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin, elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu olması hükme bağlanmıştır.

Buna karşın, doğrudan temin Yasa'nın 22'nci maddesinde düzenlenmiş olup, bu kapsamdaki alımlarda ihale usulleri için öngörülen hükümlere de aynen uyulmasına gerek bulunmamaktadır.

Temel ilkelere uyulması her ikisi için de zorunluluktur. Pazarlık usulü için ihaleye fesat karıştırma suçu söz konusu iken, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alıma ilişkin benzer nitelikteki bir fiil için görevi kötüye kullanma suçu söz konusu olabilecektir. Ancak her iki alım için edimin ifasına fesat karıştırma suçu söz konusu olabilmektedir.

Doğrudan temin kapsamı alımlar için sadece Yasa'nın 22'nci maddesinin "d bendi" için parasal limitler belirlenmiştir. Söz konusu tutar her yıl parasal sınırlara ilişkin tebliğler ile güncellenmektedir. Söz konusu tutarlara KDV dahil değildir.

Yasa'nın 22/d dışındaki doğrudan temin kapsamı alımları için parasal sınırlar mevcut değildir. Yani, söz konusu bent kapsamında yer alan temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar için de parasal sınırlama bulunmamaktadır. Diğer bentlerde yer verilen alımlar için de parasal sınır söz konusu değildir.

Diğer taraftan, doğrudan temin ile pazarlık usulü arasından esastan bir farklılık bulunmaktadır. Zira doğrudan temin bir ihale usulü olmasına rağmen, pazarlık usulü Kanun ile öngörülen bir

ihale usulüdür. Pazarlık usulü Kanun'la öngörülen bir ihale usulü olduğu için EKAP'a kaydı gerekmekte ve öngörülen temel düzenlemelere uyulması gerekmektedir. Buna karşın, doğrudan temin için bu durum farklılık arz etmektedir.

Ancak Yasa'nın 22/d maddesi ile 21/f maddesi arasında pratiklik açısından bazı benzerlikler bulunmakla beraber, 21/f kapsamı alımların kapsamının farklılık arz ettiği ve bu kapsamda yapım işinin ihale edilmesinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Yine 21/f maddesi kapsamında ilan yapılmaması, teminat alınmaması gibi bazı alımlar için doğrudan temin kapsamı alımlara benzer nitelikte kolaylıklar sağlanmış olsa da, pazarlık usulünün bir ihale usulü olduğu için temel ilkelere ve düzenlemelere uyulması gerektiğini, buna karşın doğrudan temin için idarelerin daha esnek bir hareket alanı olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak pazarlık usulünün ilanlı yapılması durumunda başvuran sayısı artacağı için rekabet şartlarının sağlanması için daha uygun olmakla birlikte, 22/d maddesi kapsamında da çok sayıda kişiden teklif alınarak aynı şekilde rekabetin daha üst düzeyde sağlanması söz konusu olabilmektedir.

Görüldüğü üzere; pazarlık usulü ihale türlerinden biri olup, bu kapsamdaki alımlarda ihale usul ve esaslarına uyulması gerekmektedir. Alım sürecine ait işlemler EKAP üzerinden yürütülmektedir.

Buna karşın doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmayıp, bu yöntemde Yasa'nın 22'nci maddesinde sayılan ihtiyaçların belli kurallara bağlı kalınmadan karşılanması söz konusudur. Bazı işlemlerin EKAP üzerinden yürütülmesi ise, bütünüyle isteğe bağlıdır ve mevcut durum itibarıyla zorunluluk içermemektedir.

Diğer taraftan, 22/d maddesi kapsamında yapım dahil her türlü alım söz konusu iken, 21/f maddesi kapsamı alımlarda yapım işinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

İhale yeterlik kuralları pazarlık usulünde söz konusun iken doğrudan temin kapsamı alımlarda ancak idare isterse ve bu hususu alıma ilişkin dokümanlara yansıtırsa alım için yeterlik kriterleri uygulanabilir.

Ancak 21/f ve 22/d kapsamı alımlar için 4734 sayılı Yasa'nın 62'nci maddesinde bir ilke belirlenmiştir. Söz konusu 62'nci maddenin "ı bendi";

"ı) Bu Kanunun 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz." hükmüne amirdir.

Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının, mal ve hizmet alımları için 4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan parasal limitlerin toplamını; yapım işlerinde ise 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan parasal limiti geçmemesi halinde %10 oranının aşılması için Kamu İhale Kurulu'ndan uygun görüş alınması şartı aranmamaktadır.

4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşların, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır.

Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı %10 oranını hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil, kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %10'unun aşılıp aşılmamasıdır. İlgili veya bağlı birimler %10 oranının aşılması zorunluluğu doğması durumunda buna ilişkin başvurularını, ilgili veya bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlara yapacaklardır. Yasa'nın 62-i maddesinde geçen parasal sınırın aşılması durumunda Kamu İhale Kurumundan izin alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda, sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için doğrudan temin kapsamı alımlara ilişkin bildirimlerin EKAP kanalıyla Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi önem arz etmektedir.

Netice itibarıyla;

-İdarelerin yaygın olarak kullandığı 21/f ve 22/d kapsamı alımlarda, uygulanan prosedürleri açısından bazı kolaylıklar sağlanmakla birlikte, 21/f kapsamı alımların ihale türü arasında yer alan pazarlık usulünde yer alması ve mevcut durum itibarıyla 4734 sayılı Kanun'un 21'inci

maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin, elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu olacağı hükme bağlanmasına karşın, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımların EKAP üzerinden yürütülmesinin isteğe bağlı olduğu,

- 21/f kapsamı alımlar için 2022 yılının parasal sınırı 728.072.-TL iken, doğrudan temin yöntemiyle 2022 yılı için geçerli olan parasal değer, Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 218.395.- Türk Lirası, diğer idarelerin için 72.752.- TL olarak belirlendiği, ancak doğrudan temin yöntemiyle tüm ihtiyaçlar karşılanabilirken, 21/f kapsamında parasal sınır içerisinde olsa da yapım işinin ihale edilmesinin mümkün olmadığı,

-Doğrudan temin bir ihale değil alım yöntemi olması nedeniyle uygulanacak işlemlerin farklılık arz ettiği, bu bağlamda, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün iken, pazarlık usulünde bazı kolaylıklar (ilan yapılıp yapılmaması gibi) sağlanmış olmakla birlikte, bir ihale türü olduğu için ihaleye yeterlik kriterleri ve ihale dokümanları (şartname, sözleşme tasarısı yani tip dokümanlar mevcuttur) söz konusu olup, bunlara uyulması gerektiği,

Değerlendirilmektedir.

93. Doğrudan temin kapsamı alımlarda tebligat usul ve esasları nasıldır?

Özet: *4734 sayılı Yasa'da yer verilen tebligata ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olarak ihale kapsamı alımlar için öngörülmesi ve EKAP üzerinden işlemlerin (tebligat dahil) yürütülmesi nedeniyle bu düzenlemelerin doğrudan temin kapsamı alımlar için uygulanmayacağını genel olarak söyleyebiliriz. Ancak söz konusu alım türü için, temel hukuki düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla tebligata ilişkin hususlara düzenlenecek sözleşmelerde yer verilebileceğini, herhangi bir belirleme yapılmaması ve bu hususta Kamu İhale Mevzuatında hüküm bulunmaması durumunda doğrudan temin yöntemi alımlarda Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğini ifade edebiliriz. Ayrıca, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun "Usulüne aykırı tebliğin hükmü" başlıklı 32'nci maddesinde yer alan "Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur." hükmüne göre; tebligatın muhatabı, kendisine yapılan tebligatın usulüne uygun yapılmadığını iddia etse bile, bahse konu durumda da anılan kişiye tebligat yapıldığının kabul edilmesi gerekmektedir.*

İhale sürecinin birçok aşamasında tebligatın zorunlu olduğunu öncelikli olarak belirtebiliriz. Tebligattaki yanlışlık veya eksiklik birçok hukuk ihlalinin doğmasına da ortam hazırlayabilecektir. İhalelere ilişkin tebligat işlemlerinde ise, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 01.02.1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri esas olarak uygulanmaktadır.

Bu bağlamda, tebligatın güvenilir bir şekilde yapılmasının yanında, mümkün olan en kısa sürede, en basit şekilde yapılması tüm taraflar için önem arz etmektedir. İhale mevzuatı ile ilgili işlemlere ait tebligat işlemlerinde 4734 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması esas olmakla birlikte, anılan Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Keza 4734 sayılı Kanun ve İhale Uygulama Yönetmelikleri ihalelere ilişkin tüm süreçleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, süreçte 7201 sayılı Kanun hükümleri de önem arz etmektedir.

4734 sayılı Kanun'un "Bildirim ve tebligat esasları" başlıklı 65'inci maddesi;

"Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki

hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

(...)[7] *yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün (...). Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.*

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz.

c) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

d) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır."

Hükmüne amirdir.

Görüldüğü üzere; 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesinin son fıkrası; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır." şeklinde ifadeye yer vermek suretiyle, 7201 sayılı Kanun'a atıf yapmıştır. Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken husus; Kamu İhale Kanunu'nun birçok maddesi karşısında, Tebligat Kanunu'nun hangi hükümlerinin uygulanabileceği hususudur. Süreçte ilk dikkate alınması gereken kriter olarak, Kamu İhale Kanunu'nda hüküm bulunan durumlarda Tebligat Kanunu'na başvurulamayacağını ifade edebiliriz.

[7] Anayasa Mahkemesinin 27/9/2012 tarihli ve E:2012/20, K: 2012/132 sayılı kararıyla bu fıkrada yer alan "İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, … kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır" hükmü iptal edilmiştir.

Kamu İhale Kanunu'nun "Bildirim ve tebligat esasları" başlıklı 65'inci maddesine göre; Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatların idareler veya Kurum tarafından "İmza karşılığı elden, İadeli taahhütlü mektupla, Elektronik ortamda ve Faks" yöntemleri kullanılarak yapılabilmesi mümkün olmakla birlikte, İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Elektronik İhale Yönetmeliği hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Söz konusu Kanun maddesi çerçevesinde, İhale Uygulama Yönetmeliklerine baktığımız zaman; ilgili Yönetmeliklerin "Bildirim ve tebligat esasları" başlıklı maddelerine göre; idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle bu yöntem kullanılarak yapılamaması halinde 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan diğer yöntemlere başvurulur.

İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanunu'nun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda, EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

Benzer şekilde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nin "Bildirim ve Tebligat esasları" başlıklı maddesinde ise; Bu kapsamda, Kurum tarafından idarelere, Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabilecekler ile yüklenicilere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın ilgililere ait EKAP'ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak tebligatın EKAP tarafından ilgililere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi ile Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligatların, İmza Karşılığı Elden Yapılması da mümkündür. Bu tebligat usulünde, isminden de anlaşılacağı üzere, tebliğ edilecek evrak, isteklinin kendisine veya yetkili olarak atadığı temsilcisinin imzası alınmak suretiyle yapılmaktadır.

Diğer bir tebligat şekli olan İadeli Taahhütlü Mektupla Yapılan Tebligatlarda, tebligat yapmaya tek yetkili makam PTT Genel Müdürlüğü'dür (Tebligat Kanunu mad.1). Bazı idarelerce, yaygın olarak kullanılmakta olan kargo, kurye gibi araçlarla istekliye yazı gönderilerek yapılan bildirimlerin iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligat kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca, idarece bu şekilde yapılacak tebligatlarda, bildirime konu evrakın, tebliğ mazbatalı kapalı bir zarf içinde gönderilmesi gerekmektedir.

Muhatabın ihaleye girerken beyan etmiş olduğu tebligat adresi daha sonra değişmiş ve bu değişiklik idareye bildirilmiş ise tebligat son adrese yapılacaktır. Ancak bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

Yine Tebligat Kanunu'na göre, "Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir." hükmü gereğince tebligat idarenin adresinde dahi yapılabilecektir. Ancak bunun için muhatabın kabul etmesi veya bu şekilde tebligat yapılması için bizzat kendisinin müracaatı şarttır. Muhatap bu konuda zorlanamaz.

Buna karşın, 7201 sayılı Kanun'a eklenen (7/a) maddeye göre, "Elektronik tebligat"; Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla yapılan tebligat şeklinde ifade edilmiştir.

Hızlı bir iletişim aracı olarak ihale işlemlerinde kullanılabilecek başka bir yöntem ise, faksla yapılan tebligattır. Elektronik ortamda tebligatta olduğu gibi, doküman satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru mektubunda veya teklif mektubunda faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından faksla bildirim yapılması mümkündür. Ancak elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatların teyit edilmesi gerekmektedir.

Zira Kanun'da ayrıca elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatların aynı gün teyit edilmesi bir zorunluluk olarak öngörülmüştür. Usulüne uygun bir bildirim yapılmış olsa bile herhangi bir nedenle aynı gün teyit işlemi yapılmadığı takdirde, yapılan bildirim tebligat olarak kabul edilmeyecektir. Bunun tek istisnası ise, Kanun'da da yer verildiği üzere, "elektronik ortamda" kullanılarak veya "Elektronik Kamu Alımları Platformu" üzerinden yapılacak işlemlerde teyit yapılması gerekli görülmemiştir.

İhale mevzuatı ışığında hazırlanan ihale usulleri kapsamında gerçekleştirilen tip dokümanlara baktığımızda ise, söz konusu düzenlemelerde yer aldığı üzere, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle yukarıda belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanun'un 65'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur. Bu kapsamda, iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanunu'nun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilerek tebligat buraya yapılacaktır. Ayrıca Kanun'a göre, resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılmasına engel bir durum yoktur.

Öte yandan, doğrudan temin kapsamı alımların durumunu da tebligat boyutuyla değerlendirebiliriz. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin yönteminde, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu usulde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarelerin takdirindedir.

4734 sayılı Yasa'nın 65'inci maddesinde; tebligata ilişkin esaslar *"Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:"* şeklinde belirlenerek bu düzenlemelerin ihale kapsamı alımlar için öngörüldüğü hükme bağlanmıştır.

Yasa'nın "Tanımlar" maddesinde; "Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul" olarak ifade edilmiştir.

Doğrudan temin kapsamı alımlar için farklı bir alım yöntemi öngörülmekte olup, söz konusu alımlarda piyasa fiyat araştırması ve neticesine bağlı olarak alım süreci sonuçlanmaktadır. Ancak alım sürecinde gerek zorunlu ve gerekse isteğe bağlı nedenlerle sözleşme yapılması ve yeterlik kriterlerinin istenilmesi isteğe bağlı olarak gerekebilir. Bu çerçevede tebligat yapılması da söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda tebligata ilişkin olarak Yasa'nın emredici kuralları çerçevesinde tebligata ilişkin özel düzenlemeler yapılabilir.

4734 sayılı Yasa'nın 65'inci maddesi uyarınca Kamu İhale Kanunu'nda hüküm bulunmayan durumlarda Tebligat Kanunu hükümlerine başvurulacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla herhangi

bir düzenlemenin yapılmaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanmasına engel bir durum yoktur.

Keza 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca, …10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları…tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligatın, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Nitekim öncelikle özel bir kanun olması nedeniyle Kamu İhale Kanunu'nun ihale işlemlerinde uygulanması ve söz konusu Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu'na gidileceği hükmünün bilinmesi gerekmektedir.

Bu nedenle öncelikle ihale kapsamı alımlarda Kamu İhale Kanunu'nun tebligat hükümlerinin bu hususta anılan Kanun'da bir düzenleme yoksa Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir. Doğrudan temin kapsamı alımlar için ise, düzenlenecek ihale dokümanlarına ilişkin hususlar göz önünde bulundurulmakla birlikte, ihale türleri için belirlenen hususların belli ölçüde kullanılması mümkün olmakla birlikte, esas olarak Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanmasının gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz.

Zira elektronik alanda yaşanan gelişmelere bağlı olarak ihalelerinin büyük ölçüde elektronik ortama aktarılması ve EKAP üzerinden işlemlerin yürütülmesine rağmen, doğrudan temin kapsamı alımlarda belli ölçüde yansıtılsa bile EKAP üzerinden işlemlerin yürütülmesi isteğe bağlı olup, mevcut durum itibarıyla zorunluluk ve yaptırım yoktur.

Dolayısıyla Kanun, İhale Uygulama Yönetmelikleri ve bu bağlamda Elektronik İhale Yönetmeliği'nin hükümlerinin bütünüyle uygulanması hukuki ve teknik nedenlerle olası değildir.

Diğer taraftan, 16/11/2022 tarihli, 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli kanunlarda olduğu gibi 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu'nda da değişiklik yapılmış olup, 7421 sayılı Kanun'un 12'nci maddesi; *"4734 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.*

Bu Kanunun 13 üncü maddesi saklı kalmak üzere bu Kanunda veya diğer kanunlarla bu Kanundan istisna edilenler ile doğrudan teminle yapılanlar da dâhil olmak üzere, her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin alım, ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin olarak; yaklaşık maliyetin ve dokümanların hazırlanması, ilanların yayımlanması, tekliflerin veya yeterlik başvurularının sunulması ve değerlendirilmesi, ihalelerin sonuçlandırılması, sözleşmelerin imzalanması, sonuç bildirimi, hakedişlerin düzenlenmesi gibi her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatlar ile şikayet ve itirazen şikayet başvuruları kısmen veya tamamen Kurum tarafından kurulan ve işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kurum, EKAP'ın kurulması ve işletilmesine, birinci fıkra kapsamında yapılacak işlemlere, alım, ihale ve sözleşme süreçlerinde elektronik araçların kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile EKAP üzerinden yapılması zorunlu işlemleri belirlemeye yetkilidir."

Şeklinde hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kanun maddesinin gerekçesinde ise; kaydedilen teknolojik gelişmeler ışığında EKAP üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemlerin, kapsamının genişletilmesi ve EKAP'ın 4734 sayılı Kanun'dan istisna edilen ihaleler, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlar ve sözleşme süreçlerinde de etkin bir şekilde kullanılabilmesinin amaçlandığı hususu yer almaktadır.

Aynı hususta Kamu İhale Kurumunca; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihaleler ile Kanun'dan istisna edilen ve doğrudan teminle yapılan alımlarda, ayrıca tüm alım ve ihalelere ilişkin sözleşme süreçlerinde her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatın Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılabileceğine,

Bu kapsamda EKAP üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile yapılması zorunlu işlemleri belirlemeye Kurumun yetkili olduğuna yönelik düzenleme yapıldığı ifade edilerek, bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu alımlarına katılım sağlayan kişilerin alım, ihale ve sözleşme süreçlerinde kullanacakları yeni hizmetlerin EKAP üzerinde geliştirilmesine devam edileceği ifade edilmiştir.

Netice itibarıyla;

-4734 sayılı Yasa uyarınca ihale usulü kapsamında öngörülen tebligata ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olarak ihale kapsamı alımlar için öngörülmesi ve EKAP üzerinden işlemlerin yürütülmesi nedeniyle bu düzenlemelerin doğrudan temin kapsamı alımlar için uygulanmayacağını,

-İdarelerce ihale kapsamı yapılacak alımlarda tip dokümanların kullanılması gerektiğini ve söz konusu dokümanlarda tebligata ilişkin düzenlemelerin bulunduğunu, ihale türüne girmeyen alımlarda ise, temel hukuki düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla tebligata ilişkin hususlara düzenlenecek sözleşmelerde yer verilebileceği, herhangi bir belirlemenin yapılmaması ve Kamu İhale Kanunu'nda hüküm bulunmayan durumunda Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğini,

-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun "Usulüne aykırı tebliğin hükmü" başlıklı 32'nci maddesinde yer alan "Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur." hükmüne göre; tebligatın muhatabı, kendisine yapılan tebligatın usulüne uygun yapılmadığını (elektronik ortamda yapılan tebligat işlemi sonunda teyit yapılmaması gibi) iddia etse bile, bu durumda bu kişi için tebligat yapıldığının kabul edileceğini,

İfade edebiliriz.

94. İdarenin doğrudan temin kapsamı alımlarda takdir hakkı bulunmakta mıdır?

Özet: *Takdir yetkisi, idarenin serbestçe ya da mevcut seçeneklerinden birini tercih ederek karar alabilme ve bu kararı uygulayabilme olanağıdır. Takdir yetkisi idarenin istediği şekilde davranması anlamına gelmemelidir. İdare takdir yetkisini kullanırken bazı ilkelere uymak zorunda olup, bu bağlamda idare işlemlerini gerçekleştirirken takdir yetkisini yasaların koyduğu sınırlar içerisinde kullanmalı ve bu yetkiyi kullanımı sırasında kamu yararı ön plana çıkmalıdır. Doğrudan temin kapsamı alımlar için de takdir hakkı kullanımı söz konusu olup, alımın niteliği esas alarak bu hakkın kullanılmasına geniş olanak sağlamaktadır. Bu alım yönteminde, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarenin takdirinin bulunduğunu genel olarak ifade edebiliriz. Çeşitli yargı kararlarında da idarenin takdir yetkisini yasal sınırlar ve kamu yararı çerçevesinde kullanması gerektiğine vurgu yapıldığı görülmüştür.*

Kamu idarelerinin amacı, kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve böylelikle kamunun yararının sağlanmasıdır. Kamunun yararını ve kamu hizmetini eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla zaman zaman ivedilikle karar alması ve bunu yerine getirmesi söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda takdir hakkı kullanılması gerekebilir.

Bahse konu takdir hakkı kamu alımları ve dolayısıyla doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlar için de söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda, öncelikli olarak takdir yetkisine ilişkin kavramsal açıklamalar yapıp sonrasında ise, doğrudan temin kapsamı alımlar ile ilişkisi ortaya konulacaktır.

İdareye belli bir konudaki idari işlemin nedenini seçmede veya belirlemede bir serbestlik tanımış olabilir. Bazı hallerde ise hiç tanınmamaktadır. Ayrıca ilgili kanun belli bir nedenin gerçekleşmesi halinde idareye farklı kararlardan birini seçme yetkisi de vermiş olabilir.

İdare, kamu hizmetinin yerine getirilmesi ve kamu yararı amacı ile birtakım tasarruflarda bulunmaktadır. İdare bu tasarrufları kanunlar çerçevesinde yerine getirir. Buna "bağlı yetki" denir. Bağlı yetki, idare tarafından tesis edilecek olan işlemin unsurlarının önceden hukuk kuralları tarafından belirlenmiş olduğu ve idarenin bu hukuk kuralları çerçevesinde idari işlem tesis edebileceği yetkidir. Bağlı yetkinin varlığı halinde, aksi bir durum olan idare için takdir

yetkisinden bahsedemeyiz.

İdarenin görevi hukuk kuralları içinde kalarak kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla, idareye takdir yetkisi tanınması zorunluluk arz edebilir. Takdir yetkisi idarenin belli koşulların ortaya çıkması durumlarında belirli bir işlemi yapıp yapmama hususunda serbest bırakılması halidir. Fakat bu durumun takdir yetkisinin sınırsız ve yargı denetimi dışında tutulacağı anlamını doğurmamalıdır.

İdare işleminin yetki ve şekil unsurları ile amaç unsurunda takdir yetkisi olamaz. Zira idari işlemlerin tek amacı kamu yararının sağlanmasıdır. İdarenin takdir yetkisinin sınırları Danıştay Kararlarına göre; mutlak ve sınırsız değildir. Hukukun genel ilkeleri ile kamu yararı ve hizmet gerekleri ölçütü sınırları içinde kullanılabilecek nitelikteki idarenin takdir yetkisi kullanılırken hukukun genel ilkelerinden eşitlik ilkesinin göz ardı edilmemesi, hizmet gerekleri yönünden de görev için en uygun davranış biçiminin uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz.

Yetki, şekil ve amaç unsurlarında idarenin takdir yetkisi yoktur. Zira yetki konusunda takdir yetkisinin kullanılması mümkün değildir. Yine şekilde de takdir yetkisi kullanılamaz çünkü kanun bir işlemin yapılmasını hangi şekil şartlarına bağlamış ise o şekil şartlarına uyulması zorunluluk arz etmektedir. Amaç unsurunda da takdir yetkisi kullanılamaz. İdari işlemlerin sadece tek bir amacı vardır o da kamu yararıdır.

İdareye belli konularda takdir yetkisi verilse de bu yetkinin amacının, sınırlarının ve çerçevesinin hukuk kurallarına uygun olarak kullanılması gerekir. Nitekim Anayasa Mahkemesince verilen bir Kararda da idarenin takdir yetkisinin kullanımında keyfiyete varabilecek uygulamalardan kaçınması gerektiği ifade edilmiştir.

Takdir yetkisinin kullanımı konusunda Danıştay'ın ilgili dairesince verilen kararlarda bulunmakta olup, bu hususta 5'inci Dairece verilen bir Kararda; *"..İdarenin takdir yetkisi mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile sınırlı olduğu"* ifade edilirken, aynı Dairenin farklı bir Kararında ise; *Takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde tutulmadan kullanılmasının söz konusu işlemin iptali sonucunu doğuracağına vurgu yapılmıştır.*

İdare, hukuk sınırları içerisinde somut bilgi veya belgeler ile tasarrufunu gerekçelere dayandırarak takdir yetkisini kullanmalıdır. Takdir yetkisi konusunda Danıştay ilgili dairesince uyulması gereken ilkeler;

- İdare, yasaların koyduğu sınırlar içinde kalmalıdır.
-İdare takdir yetkisini kullanırken eşitlik ilkesine önem vermelidir.
-Takdir yetkisi kamu yararı için kullanılmalıdır.
-Takdir yetkisinin kullanılması için kanunlar özel koşullar öngörmüş ise idare bunlara uymalıdır.

şeklinde belirlenmiştir.

Yukarıda ilkeleri belirlenen takdir yetkisinin doğrudan temin kapsamı alımlarda kullanılıp kullanılamayacağı hususunu da açıklayabiliriz.

Doğrudan temin yönteminde, Kanun'un temel amacına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurulmadan, Kanun'da sayılan yeterlik kriterlerini dikkate almadan, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesi esastır.

Genel kural bu olmakla beraber, ihtiyaçların niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerden belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarenin takdirindedir.

İhale işlemleri bakımından takdir yetkisinin denetiminde, 4734 sayılı Kanun'un 5'inci maddesindeki temel ihale ilkelerinin gözetilmesi gerektiği gibi idare hukukuna hâkim olan ilkelerin de dikkate alınması zorunludur.

İdare işlemlerinde ve dolayısıyla ihale mevzuatı kapsamında, önceden belirlenen hukuki düzenlemeler çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda başta 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar olmak üzere, Bütçe Kanunu hükümleri, kurum teşkilat yapısına ait Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve 2007/1 sayılı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ gibi birçok hukuki düzenlemeler çerçevesinde hareket edilmesi bir anlamda zorunluluk arz etmektedir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 33'üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı (3'üncü mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgelere ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Bahse konu düzenlemeler idare ve personel açısından bağlayıcıdır. Ancak belli konularda idarenin takdir hakkı vardır. Takdir hakkı kapsamında, uygun kişiler arasında istediğini görevlendirebilir. Bu süreçte referans alınacak temel ilke, takdir hakkının yasal sınırlar kapsamında olması gerektiğidir.

Bu bağlamda, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca, bir belgenin ibrazı gerekmiyorsa idare bu belgenin ibrazını isteyemez. Ancak idarece belgenin geçerliliği ile ilgili dikkat çekici durumların varlığını tespit etmesi durumunda, bu hususta araştırma yapabilir.

Doğrudan temin ile ilgili mevzuattaki düzenlemelere baktığımızda idareye geniş takdir yetkisi verildiği görülmektedir. Zira Kanun'un 22'nci maddesinin "a bendinde" ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel kişiden karşılanacağının tespiti ile aynı maddenin (e) bendinde yer alan ihtiyaca uygun taşınmazların yorumu idare tarafından takdir edilecektir.

Doğrudan temin yöntemi ihale usulleri arasından çıkarılmış olmakla birlikte, bazı kurallara uyma yükümlülüğü bulunduğunu da ifade edebiliriz. Doğrudan temin yöntemi ile ihale mevzuatındaki düzenlemelerin dışına çıkılarak idarelere ihtiyaçların karşılanması noktasında bazı kolaylıklar sağlanmış olmakla birlikte, getirilen bu kolaylıklardan, alımların keyfi yöntemlerle yapılabileceği anlam ve sonucu çıkarılmamalıdır.

4734 sayılı Yasa'nın 22/d maddesi kapsamında, belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın ihale yoluyla karşılanması gerekmektedir.

Anılan Yasa'nın 22'nci maddesinde yer aldığı üzere, "…ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir."

şeklinde düzenleme gibi söz konusu hukuki metinde idareler için bağlayıcı ifadeler içeriyorsa burada takdir hakkından söz etmek mümkün değildir. Çünkü burada tercih yerine idare için bir zorunluluk söz konusudur.

Ayrıca, Kanun'un 22'nci maddesinde, görevlendirmenin şekli ile ilgili herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Ancak görevlendirilecek kişilerin alımdan doğrudan sorumlu tutulabilmeleri için, görevlendirmenin yazılı olarak yapılması zarureti vardır. Görevlendirme ihale yetkilisi tarafından yapılmaktadır. Bu şekilde görevlendirmelerde, görevlendirilen kişinin onayını almak zorunda değildir. 657 sayılı Yasa uyarınca konusu suç olmayan görevlerin yerine getirilmesi ilgili açısından zorunluluk arz etmektedir.

4734 sayılı Yasa'nın ilk halinde bir ihale usulü olarak yer alan doğrudan temin yöntemi, 4964 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır. Doğrudan temin yöntemi ihale usulü olmadığından, ihale usulleri için öngörülen kurallara tabi olmayıp, bu bağlamda, gerçek veya tüzel kişilerden, diğer yöntemlerden farklı olarak, ilan yapılmadan ve yeterlik koşulları aranmadan ihtiyaçların karşılanması nedeniyle doğrudan temin yönteminde idarenin takdir yetkisi geniştir. Ancak Yasa'nın 22/d maddesi uyarınca, piyasa fiyat araştırması yaparken, kişileri seçme konusunda belli düzeyde takdir hakkından söz edebiliriz.

Görüldüğü üzere; gerek 4734 sayılı Kanun'da ve gerekse Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer aldığı üzere, doğrudan temin yönteminde, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması, şartname düzenlenmesi gibi hususlar idarenin takdirine bırakılmış olup, bu ise idareye geniş bir hareket alanı sağlamaktadır. İdare gerçekleştireceği alımın niteliğini dikkat alarak hazırlayacakları dokümanlarda bu hususlara yer vermesi gerekmektedir.

İhale usulü alımlarda olduğu gibi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşen alımlarda da eşit muamele ilkesi önem arz etmektedir. Bu ilke uyarınca, ayrım yapmaksızın aynı durumda olanlara idarece aynı şekilde davranılması gerekmektedir.

Doğrudan temin kapsamı alımlarda zorunlu durumlar hariç olmak üzere sözleşme düzenlenmesi hususu da idarenin takdirindedir. Ancak mal ve hizmet alımı ya da işin teslimi bir zaman gerektiriyorsa sözleşme düzenlenmesi bir tercih değil bu durumda zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aynı şekilde, ihale kapsamı alımlar için tip şartname ve standart form söz konusu iken doğrudan temin kapsamı alımlarda, idarenin yine bir tercihi yani takdir hakkı söz konusu olabilmektedir. İhale dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan tip dokümanlara (şartname, sözleşme tasarısı) göre hazırlanmak zorunda olduğundan idarenin bu konudaki takdir yetkisi oldukça kısıtlanmıştır. Ancak istenmesi zorunlu olmayan bilgi ve belgelerde idarenin hareket alanı geniştir ve takdir yetkisi kullanılmaktadır.

Hukuk devletinin en temel özelliklerinden biri olan idarenin hukuka bağlılığı ilkesi gereği, idareler tarafından yapılan bütün işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasıdır.

Söz konusu husus Anayasa'nın 125'inci maddesinde açıkça düzenlenmiş olup, bu kapsamda idare tarafından yapılan işlem veya eylem hukuka aykırılık teşkil ediyorsa dava açılabilecektir. İdari yargıda bir işlemin dava konusu yapılabilmesi için yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımından, bir veya birkaç unsurun hukuka aykırılık teşkil etmesi gerekmektedir.

95. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda kontrol teşkilatı kurulur mu?

Özet: *4735 sayılı Kanun hükümlerine yapılan sözleşmelerden hizmet alımı ve yapım işleri için işin niteliğine bağlı olarak kontrollük (kontrol teşkilatı/yapı denetim görevlisi) faaliyetinin gereklilik arz ettiğini, bu hususta sözleşmede hüküm varsa buna göre hareket edilmesi gerektiğini, ancak ihale dokümanlarında kontrol teşkilatının yetkilerine yer verilmemişse, bu durumda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nde yer alan düzenlemelerin geçerli olacağını söyleyebiliriz. Buna karşın doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda esas olarak kontrol teşkilatı/yapım denetim görevlisi belirlenmesine gerek olmadığını, gerek duyulması halinde bu görevlerin idarece yerine getirilmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, doğrudan temin yöntemi de olsa alımın niteliğine bağlı olarak hizmet işleri için hizmet işleri genel şartnamesinde yer alan kontrol teşkilatına ilişkin hükümlerin, yapım işleri için de yapım işleri genel şartnamesinde yer alan yapı denetim görevlisi için belirlenen görev ve yetkilerin sözleşmelere yansıtılmasına bağlı olarak, kullanılmasının mümkün olacağını ifade edebiliriz. İdare isterse bunlardan yer alan hususları aynen veya kısmen kullanabileceği gibi alım dokümanlarında bunlara atıf yapmak suretiyle de bunları kullanması mümkündür.*

İdarelerin ihale kapsamı mal, hizmet ve yapım işine ilişkin alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleşmekte, buna karşın ihalenin gerçekleşmesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına yönelik işlemlerde ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

4735 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin esaslar, ihale kapsamı alımlara istinaden düzenlenen sözleşmeler için geçerli olup, bu düzenlemelerin doğrudan temin kapsamı alımlar için uygulanması mümkün değildir. Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü değildir ve bu sebeple ihale usullerinin tabi olduğu mevzuata da tabi olmak zorunda değildir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin yönteminde, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması

yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu usulde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarelerin takdirindedir.

Ancak, taraflar doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda sözleşme imzalamışsa ve sözleşme hükümleri içerisinde de belli koşullarda sözleşmenin devrine ilişkin düzenlemeler varsa, bu hususta, sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi temel ilke olarak kabul edilmelidir.

Konuyla bağlantılı birçok Sayıştay Kararının incelenmesinden de alımın doğrudan temin yöntemi yapılması ve bu alıma ilişkin olarak sözleşme düzenlenmesi zorunlu ise bu sözleşmelerin taraflar için bağlayıcı olacağı belirtilmiştir.

Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmelikleri ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olması gerekli değildir, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabilecektir.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile de hükme bağlandığı üzere, Kanun kapsamında yapılan sözleşmedeki tarafların, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği gibi, Kanun'un yorum ve uygulanmasında bu prensibin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yine aynı Kanun hükmü gereğince, 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağının hükme bağlanması ve söz konusu Kanun ile de tarafların eşitliğinin ilke edinilmesi ve sözleşme hükümlerine aykırılığın da yaptırıma bağlanmasını, yapılan işlemlerde dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak ayrıca vurgulayabiliriz.

Yani doğrudan temin kapsamı alımlar için de geçerli olmak üzere, borçlu üstlendiği taahhüdü, sözleşme hükümlerine göre kararlaştırılan yer ve zamanda gereği gibi veya hiç yerine getirmemesi veya sözleşmeye aykırı şekilde bitirmesi hâlinde yaptırım uygulanması söz konusudur.

İhale dokümanları, ne kadar doğru bir şekilde hazırlanmış olursa olsun bu sürecin anlamlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi, ancak sözleşme sonrası sürecin de idare tarafından etkin bir şekilde kontrolü ile mümkündür. Zira aksi bir durum olan hizmetin eksik gerçekleşmesi halinde ise, idare ihtiyaçlarının uygun şartlarla karşılanması gerektiği yönündeki 4734 sayılı Kanun'un "Temel ilkelere" ilişkin 5'inci maddesine aykırılık taşıması, buna bağlı olarak da kamu kaynağının verimsiz kullanılması gündeme gelmektedir.

Bu çerçevede, öncelikle ihale kapsamı hizmet ve yapım işleri için kontrollük faaliyetlerine ve fonksiyonuna değinildikten sonra, bunların doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda kurulup kurulmayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Öncelikli olarak doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılan alımlarda kontrol teşkilatı kurulacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte doğrudan temin yöntemi kullanılarak belirli süreli olarak alınan işler veya sözleşme imzalanan işler veya teknik şartnamesi olan ve sözleşmeye eklenen işler için işin niteliğine göre kontrol teşkilatının oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Sözleşmenin uygulanması bağlamında muayene kabul süreci büyük önem arz etmekte olup, bu sürecin etkin bir şekilde sonuçlandırılmasında özellikle kontrol teşkilatının fonksiyonu büyüktür. Dolayısıyla, özellikle hizmet alımı kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, kontrol teşkilatının etkin bir şekilde çalışmaması durumunda, muayene kabul komisyonunun da sağlıklı karar vermesinin olanaklı olmadığını söyleyebiliriz. Zira anılan komisyona dayanak tespit ve kayıtlar büyük ölçüde kontrol teşkilatınca tutulmaktadır.

Bu bağlamda, "Kontrol Teşkilatı" veya diğer ifade şekliyle "Kontrollük" kavramının, idare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri ifade ettiğini belirtebiliriz.

Kontrol teşkilatının yetkilerinin ihale dokümanlarında gösterilmesi gereklidir. Ancak herhangi bir nedenle bu yetkinin belirtilmemesi durumunda da anılan teşkilatın bazı yetkileri kullanması söz konusu olabilmektedir. Nitekim sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının

tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirmektedir.

Üst paragrafta ifade edilen yetkiler, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nde yer alan ve ihale dokümanlarında aksi bir yetki belirlemesi yapılmayan durumlar için geçerlidir. Şayet bu yönde bir yetki verilmişse, bu durumda söz konusu Genel Şartnamedeki bu alandaki yetkilerin dikkate alınmaması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, ihale dokümanlarında kontrol teşkilatının yetkilerine ihale dokümanlarında yer verilmemişse, bu durumda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nde yer alan düzenlemeler geçerli olmaktadır.

Hizmet Alımı İhalelerine İlişkin Yönetmeliği'n ekleri arasında yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile de 4735 sayılı Kanun'a göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usuller belirlenmiştir. Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan bahse konu Genel Şartname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi idareler tarafından 4735 sayılı Kanun uyarınca götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan "danışmanlık" dışındaki hizmet işlerini kapsamaktadır.

İdare, yüklenici ve kontrol teşkilatı arasındaki her türlü iletişimin, yazı ile yapılması gerekmekte olup, sözleşmeye göre bir izin, onay, belge, tebligat, olur verilmesi veya tespit yapılması, emir, ihbar, çağrı veya davette bulunulması veya dağıtılması gerektiğinde, bunların, taraflar aksi kararlaştırmadıkça yazılı olması gerekmektedir.

İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine yerine getirmek zorundadır.

İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği idare tarafından görevlendirilen Kontrol teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol teşkilatı, bahse konu Genel

Şartnamede belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Şayet işin niteliği ve özelliğine göre, kontrol teşkilatının görev ve yetkilerine ilişkin olarak idare tarafından farklı bir düzenleme yapılması olanaklıdır.

Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilmesi ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Keza yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

Bu bağlamda, yüklenici, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, üstlenilen işler için kontrol teşkilatının öngöreceği formda ve detaylarda ayrıntılı bir iş programı düzenler ve kontrol teşkilatının uygun görüşüne sunar. İş programları idarenin onayı ile geçerli olur.

Yapılan işler, idarece verilecek talimat üzerine kontrol teşkilatınca incelemeden geçirilir. İhale edilen işin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi esastır. Yüklenici bu esasa herhangi bir şekilde uymazsa sözleşmede gösterilen cezalar uygulanır.

Ayrıca, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek duruma göre yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.

İhale sürecinde görev alan yüklenici personeline benzer şekilde hakediş ödeme sürecinde de kontrol teşkilatının görev ve yetkileri bulunmaktadır. Keza yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde sadece kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonun aynı kişilerde oluşmayacağı kuralına yer verilmiş olup, 4735 sayılı Yasa gereğince kontrol teşkilatının yaptığı görevlerin, yüklenici sorumluluktan kurtarmamaktadır. Keza yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek sözleşmede öngörüldüğü şekilde işleri tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir.

Kaldı ki ilgili bütün bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere yüklenici, işlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, malları veya hakları, işler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı idarenin zararını karşılayacaktır.

Nitekim 4735 sayılı Yasa'nın "Hizmet sunucularının sorumluluğu" başlıklı 34'üncü maddesine göre de hizmet sunucuları taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumlu olup, bu zarar ve ziyanın genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilmesi söz konusu olabilmektedir.

Hizmet işlerine gibi, yapım işlerinde de kontrollük faaliyetleri söz konusudur. Bu çerçevede, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği'nin yanında, ihale dokümanı kapsamında Yapım İşleri Genel Şartnamesi de söz konusudur. Söz konusu Genel Şartname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsamaktadır.

Yapım işlerinde söz konusu faaliyetler yapı denetim görevi olarak ifade edilmekte olup, yapım işlerine ait Genel Şartnamenin 4'üncü maddesinde, *"Yapı denetim görevlisi: İdare tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,"* ifade ettiği vurgulanmıştır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu" başlıklı 31'inci maddesi ise; *"Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında 28 inci madde hükümleri uygulanır."* şeklinde hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde yapı denetim hizmetleri, sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister iş yerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Nitekim 4735 sayılı Yasa'nın 30'ncu maddesinin "Yapım işlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu" başlıklı maddesine göre; "Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun'un "Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu" başlıklı 31'inci maddesi ise; "Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında 28 inci madde hükümleri uygulanır." şeklinde hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, yapı denetim görevlilerinin; yüklenici ve alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin sözleşme ve eklerinde belirlenmiş esaslara uygun biçimde imal ve inşasından, fen ve sanat kurallarına uygun yapılmasından yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ifade edebiliriz.

Netice itibarıyla;

-4735 sayılı Kanun'a göre gerçekleştirilen ve belli bir sürede gerçekleşmesinin söz konusu olduğu hizmet ve yapım alımlarında kontrol teşkilatının/yapım denetim görevinin (kontrollük) kurulmasının zorunluluk arz ettiğini, bu komisyonlarının yetkilerinin mutlaka sözleşmede belirtilmesi gerektiğini, ancak herhangi bir nedenle sözleşmede yer almazsa Hizmet İşleri/Yapım İşleri Genel Şartnamesi gereğince söz konusu dokümanda yer alan görevleri kullanılması gerektiğini, bahse konu düzenlemelerin sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası konumunda olduğu için tarafları bağladığını,

-İhale kapsamı alımlar için sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatının (kontrollük); işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen personelin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirdiğini,

-Kontrol teşkilatının doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar için söz konusu olmadığını, sözleşme yapılmasının zorunlu olduğu ya da idarece takdir hakkı kullanılarak sözleşme yapılmasına karar verilen hizmet alımı ile yapım işlerinde kontrollük faaliyetlerinin (kontrol teşkilatı/yapım denetim görevi) işin niteliğine bağlı olarak söz konusu olabileceğini, ancak zorunluluk arz etmediğini,

-Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmelikleri ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olmasının gerekli olmadığını, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabileceğini, doğrudan temin kapsamı alımlarda alıma ilişkin dokümanlarda kontrollük faaliyetlerine ilişkin bir belirleme yapılabileceği gibi hizmet alımı ve yapım işleri için ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan genel şartnamelerin referans alınabileceğini ya da alım dokümanlarında bunlara kısmen/tamamen atıf yapılabileceğini,

-Gerek hizmet ve gerekse yapım işlerinde, yüklenici ve alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin sözleşme ve eklerinde belirlenmiş esaslara uygun biçimde yapılmasından yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu,

İfade edebiliriz.

Görüldüğü üzere; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamede ve Tip Sözleşmede söz konusu zorunluluk hükümleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiş olup, benzer düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamelerde, Tip Sözleşmelerde ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nde de yer almaktadır.

Bu itibarla, yapım işleri ile hizmet alımlarının denetim ve kontrol iş ve işlemlerinin 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

96. Doğrudan temin yönteminde sigorta uygulaması mümkün müdür?

Özet: *4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile bağlantılı mevzuatta yer alan sigorta uygulamasına ilişkin düzenlemelerin ihale kapsamı alımlar için geçerli olduğunu, hatta yapım işlerinde zorunluluk arz eden durumların bulunduğunu, buna karşın sigorta uygulamasının doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar için söz konusu olmadığını, sözleşme yapılmasının zorunlu olduğu ya da idarece takdir hakkı kullanılarak sözleşme yapılmasına karar verilen alımlarda işin niteliğine bağlı olarak sigortanın söz konusu olabileceğini ifade edebiliriz. Ancak sözleşme düzenlenmesinin zorunluluk arz ettiği ve alımın niteliğinin bunu gerektirdiği durumlarda sigorta yaptırılması uygun olacaktır. Yoksa mevzuatta doğrudan temin yöntemi için açık bir zorunluluk yoktur.*

İdarelerin ihale kapsamı mal, hizmet ve yapım işine ilişkin alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleşmekte, buna karşın ihalenin gerçekleşmesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına yönelik işlemlerde ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

4735 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin esaslar, ihale kapsamı alımlara istinaden düzenlenen sözleşmeler için geçerli olup, bu düzenlemelerin doğrudan temin kapsamı alımlar için doğrudan uygulanması mümkün değildir. Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü değildir ve bu sebeple ihale usullerinin tabi olduğu mevzuata da tabi olmak zorunda değildir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde düzenlenen doğrudan temin yönteminde, ihtiyaçların Kanun'un 18'inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'un 10'uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu usulde, şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar da idarelerin takdirindedir.

Ancak taraflar doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda sözleşme imzalamışsa ve sözleşme hükümleri içerisinde de belli koşullarda sözleşmenin devrine ilişkin düzenlemeler

varsa, bu hususta, sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi temel ilke olarak kabul edilmelidir.

Konuyla bağlantılı birçok Sayıştay Kararının incelenmesinden de alımın doğrudan temin yöntemi yapılması ve bu alıma ilişkin olarak sözleşme düzenlenmesi zorunlu ise bu sözleşmelerin taraflar için bağlayıcı olacağı belirtilmiştir.

Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmelikleri ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olması gerekli değildir, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabilecektir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile de hükme bağlandığı üzere, Kanun kapsamında yapılan sözleşmelerin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği gibi, Kanun'un yorum ve uygulanmasında bu prensibin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yine aynı Kanun hükmü gereğince, 4735 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağının hükme bağlanması ve söz konusu Kanun'la da (TBK) tarafların eşitliğinin ilke edinilmesi ve sözleşme hükümlerine aykırılığın da yaptırıma bağlanmasını, yapılan işlemlerde dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak ayrıca vurgulayabiliriz.

Yani doğrudan temin kapsamı alımlar için de geçerli olmak üzere, borçlu üstlendiği taahhüdü, sözleşme hükümlerine göre kararlaştırılan yer ve zamanda gereği gibi veya hiç yerine getirmemesi veya sözleşmeye aykırı şekilde bitirilmesi hâlinde yaptırım uygulanması söz konusudur.

İhale dokümanları, ne kadar doğru bir şekilde hazırlanmış olursa olsun bu sürecin anlamlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi, ancak sözleşme sonrası sürecin de idare tarafından etkin bir şekilde kontrolü ile mümkündür. Zira aksi bir durum olan hizmetin eksik gerçekleşmesi halinde ise, idare ihtiyaçlarının uygun şartlarla karşılanması gerektiği yönündeki 4734 sayılı Kanun'un "Temel ilkelere" ilişkin 5'inci maddesine aykırılık taşıması, buna bağlı olarak da kamu kaynağının verimsiz kullanılması gündeme gelmektedir.

İdare tarafından alıma konu edilen mal veya hizmetin sigorta yaptırılması her zaman söz konusu olabilmektedir. Ancak sigorta uygulaması her alım türü için aynı hukuki nitelikte değildir. Zira bazı alımlar için bu nitelikte bir işlem zorunlu iken, bazı alımlarda idarenin daha esnek hareket edebilmesi olanak dahilindedir.

Bu bağlamda, ihale mevzuatı açısından sigortanın hukuki altyapısı bağlamında yasal düzenlemeler olarak 4734 ve 4735 sayılı Yasalara öncelikle baktığımız zaman; 4734 sayılı Kanun'un "İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar" başlıklı 27'nci maddesinin; "İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.
v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar."

şeklinde hükme bağlandığı görülmüştür.

4735 sayılı Kanun'un "İş ve işyerinin sigortalanması" başlıklı 9'uncu maddesinin ise; "Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır." hükmüne amir olduğunu görmekteyiz.

Sigorta konusunda alım türleri açısından ilgili uygulama yönetmeliklerinde doğrudan bir hüküm bulunmamakla birlikte, anılan yönetmeliklerin ekleri arasında yer alan tip dokümanlarda bu konuda düzenlemelerin yer aldığını görmekteyiz. Bu bağlamda, alım türleri

arasında benzer ve farklılıklar bulunduğunu, ancak her alım türü için geçerli olmak üzere, teklif fiyatına dahil giderler arasına sigorta giderlerinin de bulunduğunu söyleyebiliriz.

Nitekim hizmet alımı ve yapım işleri açısından sigorta konusunda ilave düzenlemelerin bulunduğunu özellikle niteliğinden dolayı yapım işleri için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 9'uncu maddesinde yer aldığı üzere daha fazla zorunluluk arz eden durumların bulunduğunu görmekteyiz.

Örneğin; mal alımında, idare tarafından sigortanın varlığına yönelik düzenleme yapılması durumunda, yüklenicinin, sigorta poliçelerini teslim programına uygun olarak idareye vermesi zorunluluk arz etmektedir. Aksi halde yükleniciye ödeme yapılmaz.

Hizmet alımı ihalelerinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin düzenleme Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin 19'uncu maddesi ile tip idari şartnamelerin "Teklif fiyata dahil olan giderler" maddesi ve tip sözleşmenin 21'inci maddesinde yer almaktadır.

İstekliler tarafından ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken sigorta giderleri, tip idari şartnamelerin "Teklif fiyata dâhil olan giderler" maddesi kapsamında teklif fiyatına dâhil edilmesi gerekmektedir. İhale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasının ayrıca istenildiği durumlarda, sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmesi gerekmektedir.

Sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/iş yerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istenildiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş ve/iş yerlerinin sigortalanmasının istenilmediği kabul edilmek suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

İhale dokümanında iş ve/veya iş yerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilerek sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlendiği ihalelerde, isteklilerden ihale aşamasında sigortaya ilişkin herhangi bir belge (taahhütname, sigorta poliçesi vb.) sunmaları istenmeyecektir. Bu durumda, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından sigorta poliçesi sunulacağına ilişkin düzenlemenin teknik şartnamede yapılması gerekmektedir.

İş ve iş yerlerinin korunmasında hizmet alımlarına ait genel şartname ön plana çıkmakta olup, bahse konu düzenlemede ayrıntılı açıklamaların bulunduğunu görmekteyiz. Keza mezkûr Genel Şartnamenin "İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması" başlıklı 19'uncu maddesinde "İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği" öngörülmüştür.

Yine Genel Şartnameye göre; hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi gerektiği, düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yüklenicilerin yer alması gerektiği, kıymetlerin tam değer üzerinden sigorta ettirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Kaldı ki sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur. Yüklenicinin, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermesi zorunluluk arz etmektedir. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz. Hatta sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

Benzer şekilde, sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte Genel Şartnamede, sözleşmenin feshi veya işin tasfiyesi halinde bahse konu sigortaların, işin yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilmesi ve bu süreye ilişkin sigorta giderlerinin ilk yükleniciye ait olması söz konusudur.

Öte yandan aynı Genel Şartnamenin "Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar" başlıklı 20'nci maddesinde, konu bağlamında bazı düzenlemelerin bulunduğunu görmekteyiz. Söz

konusu maddeye göre, olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler sigorta kapsamında olsun veya olmasın yüklenici bu hasar ve zararlar için idareden hiçbir bedel isteyemeyeceği, ancak bu hasar ve zararlar nedeniyle meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli süre uzatımı verilmesi gerektiği öngörülmektedir.

Ayrıca, hizmet alımı ve yapım işlerinde ihalelere ait sözleşmelerin eki ve ayrılmaz parçası konumunda bulunan genel şartname hükümleri de süreçte önem arz etmektedir. Keza sözleşmeye bağlanan hizmet ve yapım işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Genel Şartnameler; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre sözleşmeye bağlanan hizmet ve yapım işlerini kapsamaktadır.

Önceki kısımda yer verdiğimiz üzere, iki ayrı doküman niteliğindeki bu genel şartnamelerde sürece ilişkin temel bilgiler yanında uygulanacak sigortanın kapsam ve niteliği ile idare ve yüklenicilerin sorumlulukları ortaya konulmaktadır.

Bunlara ilave olarak, yapım işleri açısından bazı ilave farklılıklar bulunduğunu, zira sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilip gerçekleştirildiğini, herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmadığının altını çizebiliriz.

Nitekim yapım işlerine ait sözleşme tasarısının "İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması" başlıklı (17'nci) maddesinde de bu kapsamda açıklamaların yer aldığını görmekteyiz. Zira söz konusu maddeye göre; yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin "Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar" ile "Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara" karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

Yapım işlerine ait Genel Şartnamenin "İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması" başlıklı 9'uncu maddesine göre; yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur.

Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı "inşaat sigortası (bütün riskler)", geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki inşaat sigortası (bütün riskler) Genel Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

Sigortaya esas alınacak bedeller ise, işin kendisi için sözleşme bedeli, her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve (veya) poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı ve(veya) cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur.

Sigorta poliçesinde; idare işveren sıfatıyla, yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla yer almalı, alt yüklenicilerin vereceği zararların da teminat kapsamı dahilinde olduğu belirtilmelidir.

Diğer yandan, işin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini

önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup, alınan bütün tedbirlere rağmen, yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak, bu konuda sigorta şirketlerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır.

Sigortalara ilişkin poliçelerin, idarenin yazılı izni dışında; genişletilmiş bakım devresi teminatı hariç, poliçenin geçici kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı, genişletilmiş bakım devresi teminatının ise kesin kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği hükmünü taşıması ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce idareye verilmesi gerekir.

Aksi halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez. Sigorta primlerinin ödendiğine ve sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğuna dair sigortacıdan alınacak bir belgenin her hak edişin tahakkuka bağlanmasından önce idareye sunulması zorunludur.

Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalarla sınırlandırılmamış olduğundan, inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının "Teminat dışında kalan haller" maddesinde belirtilen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için yüklenici idareden hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır. Yüklenici veya alt yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve iddiaların karşılanması yükümlülüğü de yükleniciye aittir.

Yüklenici, kendisinin veya alt yüklenicinin taksirinden, ihmalinden, ağır ihmalinden veya kusurlu herhangi bir hareketinden dolayı idareyi ve idare personelini sorumlu tutamaz. Ancak sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere iş, yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri idare tarafından karşılanır. Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için idare tarafından verilen talimata yüklenici uymak zorundadır.

Netice itibarıyla;

-4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile bağlantılı mevzuatta yer alan sigorta uygulamasına ilişkin düzenlemelerin ihale kapsamı alımlar için geçerli olduğunu, hatta yapım işlerinde zorunluluk arz eden durumların bulunduğunu,

-Buna karşın sigorta uygulamasının doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar için söz konusu olmadığını, sözleşme yapılmasının zorunlu olduğu ya da idarece takdir hakkı kullanılarak sözleşme yapılmasına karar verilen alımlarda işin niteliğine bağlı olarak sigortanın söz konusu olabileceğini,

-Doğrudan temin ihale yöntemi olarak kullanılmadığı için, düzenlenecek idari şartname ve sözleşme tasarısının, ilgili yönetmelikler ekinde yer alan tip şartname ve sözleşme tasarısına uygun olmasının gerekli olmadığını, ancak istenildiği takdirde bu metinlerden yararlanılabileceğini, doğrudan temin kapsamı alımlarda alıma ilişkin dokümanlarda sigorta faaliyetlerine ilişkin bir belirleme yapılabileceği gibi ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan genel şartnamelerin referans alınabileceğini ya da alım dokümanlarında bunlara atıf yapılmasının mümkün olduğunu,

İfade edebiliriz.

97. Doğrudan temin yönteminde sulh anlaşması yoluyla kamu idareleri alımlara ilişkin uyuşmazlıklarda yüklenici ile anlaşabilir mi?

Özet: *İdari başvuru yolları tüketilmeden dava açılması mümkün değildir. Her ne kadar doğrudan temin kapsamında yer alan alımlar ihale türleri dışında olsa da Anayasa'nın 125'inci maddesi çerçevesinde yargı yoluna başvurulması mümkündür. Ancak Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de; hukuk birimlerinin görevleri ve sorumlulukları arttırılmış ve söz konusu KHK'nın 8, 9, 10, 11 ve 12'nci maddeleri ile adli ve idari davalarda uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, kabul ve feragat ile vazgeçme yetkilerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda, gerek ihale kapsamı alımlarda ve gerekse doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda, tarafların hak ve menfaati çerçevesinde usul ekonomisine uygun olarak sözleşmelerde yer alan (ve almayan) konuları kapsayacak şekilde sulh anlaşması yapılabileceğini düşünmekteyiz. Ancak KHK'nın, "İdari uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli ve vazgeçme yetkileri" başlıklı 12'nci maddesine göre, idari işlemler dolayısıyla haklarının ihlal edildiğini iddia edenlerin, uğramış oldukları zararın sulh yoluyla giderilmesini dava açma süresi içinde isteyebilecekleri yönündeki hükmünün de dikkate alınması gerekir.*

İdarelerin ihale kapsamı mal, hizmet ve yapım işine ilişkin alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleşmekte, buna karşın ihalenin gerçekleşmesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına yönelik işlemlerde ise, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Doğrudan temin kapsamı alımlar ise, ihale usullerinin temel ilkelerinden sayılan kurallara uymaksızın, ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanun'da belirtilen yeterlik kriterlerini taşıma zorunluluğu aranmaksızın, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilen bir satın alma yöntemi olduğu ifade edilerek ihale surecinden tamamen ayrılmıştır. Ancak bu alım yönteminde de belli durumlarda sözleşme düzenlenmesi suretiyle tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi söz konusu olabilmektedir.

Hukuk devletinin en temel özelliklerinden biri olan idarenin hukuka bağlılığının gereği olarak, idarenin işlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi olması gerekmektedir. Söz konusu husus

Anayasa'nın 125'inci maddesinde açıkça düzenlenmiş olup, bu kapsamda idare tarafından yapılan işlem veya eylem hukuka aykırılık teşkil ediyorsa dava açılabilecektir.

Doğrudan temin alımı ile ilgili idari yargıda açılan davalar belli başlı niteliklere ilişkin olup, ayrı bir yargılama usulüne tabi olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, doğrudan temin ile ilgili idari işlem ve eylemler hakkında Kamu İhale Kurumunun inceleme yetkisi bulunmadığından, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gerçekleştirilen idari işlem ve eylemler için yargıya başvurulabilir. Böylelikle idari başvuru yollarından farklı olarak, doğrudan temin alımı ile ilgili idari yargıda açılan davalar, ayrı bir yargılama usulüne tabi değildir. Ancak ilgilinin davadan önce idareye başvurmasının daha uygun olacağını, keza bunun merci tecavüzü sorununun gündeme gelmesini engelleyeceği düşünülmektedir.

Ayrıca, süreçte yani sözleşmenin uygulanmasına yönelik işlemlerde, idare ile yükümlü çeşitli nedenlerle görüş aykırılığına düşmekte ve zaman zaman anlaşmazlıklar yargıya taşınmaktadır. Örneğin; yükümlünün sözleşmeye uygun davranmaması nedeniyle idare tarafından ceza tatbik edilmesi söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda, dava yoluna gidilmeden ihale kapsamı kamu alacağına ilişkin olarak belli koşullarda anlaşılıp anlaşılmayacağı hususu önem arz etmektedir.

Bu duruma, idare hukukunda uygulama alanı bulan 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mümkün olduğunu ifade edebiliriz.

Söz konusu KHK ile idare ile kişiler arasında yaşanan bir uyuşmazlığın yargıya taşınmadan idari aşamada sulh yoluyla çözümü öngörülmektedir. Söz konusu KHK ile hukuk birimlerine; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütme görev ve sorumluluğu verilmektedir. Verilen bu görevler kapsamında, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alınması ve uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verme de bulunmaktadır.

KHK'nın uygulanması açısından önemli diğer bir husus ise, "İlkeler" başlıklı 3'üncü maddesidir. Bir anlamda KHK'nın amacı diyebileceğimiz bu hususlar söz konusu maddede; *"..Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında; a) İdarelerin taraf oldukları*

uyuşmazlıkların, tarafların hak ve menfaatlerinin dengeli olarak değerlendirilerek, adil ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi,..esastır." şeklinde ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere; söz konusu KHK idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların adil ve hakkaniyete uygun çözümler üretilmesini hedeflemektedir. Ayrıca, "Davaların açılması" başlıklı KHK'nın 8'inci maddesinde bu hususa vurgu yapılmış ve merkez veya taşra birim amirince yapılan talep üzerine davayı açmakla yetkili ve görevli olanlarca, maddi ve hukuki sebeplerle dava açılmasında kamu menfaati bulunmadığı yönünde görüş belirtilmesi halinde, üst yöneticinin talimatına göre işlem yapılacağı şeklinde fayda görülmeyen davaların açılmaması da bir anlamda öngörülmektedir.

Sulh kavramı, KHK'da adli ve idari uyuşmazlıklar açısından farklı esaslara bağlanmıştır. Zira Adli uyuşmazlıklara ilişkin sulh, KHK'nın 9 ila 11'inci maddeleri arasında düzenlenmişken; İdari uyuşmazlıklara ilişkin sulha ise Yasa'nın 12'nci maddesinde yer verilmektedir.

"Adli uyuşmazlıklarda sulh" başlıklı KHK'nın 9'uncu maddesine baktığımızda söz konusu maddenin; "*İdarelerin adli yargıda dava açmadan veya icra takibine başlamadan önce karşı tarafı sulhe davet etmesi esastır. İdareler, kendi aleyhlerine dava açılacağını veya icra takibine başlanılacağını öğrenmeleri durumunda da karşı tarafı sulhe davet edebilirler. Sulhe davet, uyuşmazlığın tarafı olan gerçek veya tüzel kişilerce de yapılabilir..."* şeklinde hükme bağlandığını görmekteyiz.

Böylelikle; adli uyuşmazlıklarda idare aktif bir tutum içine girmekte ve dava açılmadan veya icra takibine başlamadan önce karşı tarafı sulha davet edilmesini öngören bir yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Adli uyuşmazlıklar için geçerli olan sulh müessesesi, idari uyuşmazlıklar konusunda da kendisini göstermektedir. Ancak KHK ile bir yöntem farklılığı öngörülmüştür. KHK'nın 12'nci maddesinde açıklandığı üzere, burada idarenin karşı tarafı doğrudan sulha davet etmesi gibi aktif bir tutum içine girmesi söz konusu değildir. Aksine bu davranış haklarının ihlal edildiğini söyleyen kişiye yüklenilmiştir.

Keza KHK'nın, "İdari uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli ve vazgeçme yetkileri" başlıklı 12'nci maddesine göre; "*(1) İdari işlemler dolayısıyla haklarının ihlal edildiğini iddia edenler idareye başvurarak, uğramış oldukları zararın sulh yoluyla giderilmesini dava açma süresi içinde isteyebilirler. İdari eylemler nedeniyle hakları ihlal edilenlerce, idari dava açmadan önce*

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan başvurular da sulh başvurusu olarak kabul edilir ve bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde incelenir.

(2) Sulh istemine ilişkin başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur. Başvuru sonuçlanmadan dava açılamaz.

(3) Sulh başvurularının altmış gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. Sulh başvurusu altmış gün içinde sonuçlandırılmamışsa istek reddedilmiş sayılır.

(4) Sulh başvurusu, belli bir konuyu ve somut bir talebi içermiyorsa, idari makam tarafından reddedilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak yapılan ve idare tarafından reddedilmeyen başvurular, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonuna gönderilir. Hak ihlaline neden olan birden fazla idarenin varlığı halinde, ortak hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonu oluşturulabilir.

(5) Sulh başvurularının incelenmesinde, başvurunun konusu, zarara yol açan olay ve nedenleri, zararın idari eylem veya işlemden doğup doğmadığı ve meydana geliş şekli, idarenin tazmin sorumluluğunun olup olmadığı, zararın miktarı ve ödenecek tazminat tutarı tespit edilir. Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonu tarafından, bilirkişi incelemesi dahil olmak üzere gerekli her türlü araştırma ve inceleme yapılır, olayla ilgili bilgisi bulunan kişiler dinlenebilir.

(6) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun inceleme sonunda hazırlayacağı rapor 11 inci madde uyarınca karar vermeye yetkili mercilere sunulur. Bu mercilerin sulh başvurusunu kabul etmesi halinde başvuru sahibine, hazırlanan sulh tutanağının imzalanması için en az onbeş günlük süre verilir. Davet yazısında, belirtilen tarihte gelmesi veya yetkili temsilcisini göndermesi gerektiği, aksi takdirde sulh tutanağını kabul etmemiş sayılacağı ve yargı yoluna başvurarak zararının tazmin edilmesini talep etme hakkının bulunduğu belirtilir.

(7) Tazminat miktarı ve ödeme şekli üzerinde idare ve istemde bulunanın sulh olmaları halinde buna ilişkin bir tutanak düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu tutanak ilam hükmündedir. Sulh olunan miktar idare bütçesinden ödenir. Vadeye bağlanmamış alacaklarda tutanağın imzalandığı tarihten itibaren iki aylık sürenin dolmasından, vadeye bağlanmış alacaklarda ise vadenin dolmasından önce tutanak icraya konulamaz.

(8) Sulh tutanağının kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması hallerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek bir örneği ilgiliye verilir.

(9) Sulh olunan konu ya da miktara ilişkin olarak dava yoluna başvurulamaz.

(10) Bu madde kapsamındaki idari uyuşmazlıkların sulhen halli ile idari davaların açılmasından, takibinden, davayı kabul ve feragatten, kanun yollarına başvurulmasından vazgeçilmesi, 11 inci maddede belirtilen esaslara ve tutarlara göre belirlenir."

Şeklinde hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, üst kısımda yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin taraf oldukları ihtilafların çözümlenmesi aşamasında idare bünyesinde oluşturulan hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 2012/3178 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 04.07.2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Komisyonunun görevi ise bahse konu Yönetmelikte yer aldığı üzere; *"659 sayılı KHK'nın 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamında idarelerin vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri 1.000.000 Türk Lirasından fazla olan;*

a) Herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın idare ile gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesine,
b) Sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesine,
c) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan taksit tekliflerine,
ç) Her türlü dava açılmasından ve icra takibine başlanılmasından veya yargı ve icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden ya da verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye,
d) Davaları kabul veya feragate,
e) Ceza uyuşmazlıklarında şikâyetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya,
ilişkin olarak yetkili makam ve mercilere görüş sunmak"

Şeklinde belirlenmiştir.

Bu bağlamda, idari işlem ve eylemler nedeniyle idareye yapılan sulh başvurularının komisyonca incelenmesinde; başvurunun konusu, zarara yol açan olay ve nedenleri, zararın idari eylem veya işlemden doğup doğmadığı ve meydana geliş şekli, idarenin tazmin sorumluluğunun olup olmadığı, zararın miktarı ve ödenecek tazminat tutarı tespit edilir.

Dolayısıyla sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda; sözleşme değişikliğinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebepler bulunup bulunmadığı veya kamu menfaati olup olmadığı hususları incelenir. Sözleşme değişikliği yapılması gereken hallerde ise, karar verecek makam veya merci, değişiklik sonucunda tanınacak bir hak ya da terk edilecek menfaatin değerine, idarelerden kaynaklanan nedenlerle sözleşmelerin sulhen tasfiye edilmek suretiyle sona erdirilmesinde ise karar verecek makam veya merci, yukarıda vurguladığımız rakamsal tutara göre belirlenir.

Komisyon incelemeleri tarafların sunmuş olduğu bilgi ve belgeler kapsamında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede yapılan inceleme sonucunda oluşturulan komisyon görüşü hazırlanan ve komisyona katılan üyeler tarafından birlikte imzalanan rapor, yetkili makam veya mercilere sunulur.

Tazminat miktarı ve ödeme şekli üzerinde idare ve istemde bulunanın sulh olmaları halinde buna ilişkin bir tutanak düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu tutanak ilam hükmündedir. Sulh olunan miktar idare bütçesinden ödenir. Vadeye bağlanmamış alacaklarda tutanağın imzalandığı tarihten itibaren iki aylık sürenin dolmasından, vadeye bağlanmış alacaklarda ise vadenin dolmasından önce tutanak icraya konulamaz. Sulh tutanağının kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması hallerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek bir örneği ilgiliye verilir.

Açıklandığı üzere, 659 sayılı KHK kapsamında da sulh olunan konu ya da miktara ilişkin olarak dava yoluna başvurulamamaktadır. Öte yandan, idari uyuşmazlıkların sulhen halli ile idari davaların açılmasından, takibinden, davayı kabul ve feragatten, kanun yollarına başvurulmasından vazgeçilmesinde KHK'nın 11'inci maddede belirtilen esas ve tutarlara göre hareket edilmesi gerekmektedir.

"Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri" başlıklı söz konusu 11'inci madde ise; "*(1) İdarelerin;*

...b) Gerçek veya tüzel kişilerle aralarındaki sözleşmelerde belirtilen sebeplerle yapılan her türlü sözleşme değişikliklerinin yapılmasında, bu hususlarla ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların sözleşme hükümleri çerçevesinde sulh yoluyla hallinde, hukuk birimlerinin uyuşmazlığın bu şekilde sonlandırılmasında maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati

bulunduğu yönündeki görüşü üzerine, buna dair onay ve anlaşmaları imzalamaya bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde üst yönetici yetkilidir. Bakan ya da üst yönetici bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle alt kademelere devredebilir..." şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu hüküm ise, söz konusu maddenin her türlü sözleşme değişikliğine izin verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Konunun diğer boyutu ise, ihale mevzuatını ilgilendirmektedir. 4735 sayılı Yasa'nın "Sözleşmede değişiklik yapılması" başlıklı 15'inci maddesine baktığımızda söz konusu maddenin;

"Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma veya teslim yeri.
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları." şeklinde hükme bağlandığını, bu durum ise, sözleşmede değişiklik yapılmasını Yasa'nın iki durum dışında değişikliğe izin vermediğini göstermektedir.

Diğer taraftan, 4735 sayılı Yasa'nın "İlkeler" başlıklı 4'üncü maddesinde; Bu (4735 sayılı) Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceği ve yine Kanun'da belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı ve ek sözleşme düzenlenemeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı maddede önemli bir hususun altı çizilmiştir. Zira söz konusu madde; "...Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur." şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı Kanun'un "Hüküm bulunmayan haller" başlıklı 36'ncı maddesi "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır." şeklinde düzenlenmiş olup, söz konusu Kanun maddesinden hareketle 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun "B. İbra" başlıklı 132. maddesinin; "Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa

bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir." hükmüne amir olduğunu görmekteyiz.

Diğer bir anlatımla, 4735 sayılı Kanun'da sözleşmenin ifa edilememesi ve buna bağlı olarak işin tasfiyesine yönelik çeşitli düzenlemeler içermesine rağmen tarafların karşılıklı olarak borcu sona erdirmesine yönelik açık bir düzenleme Kanun'da yer almamaktadır. Ancak yukarıda ifade ettiğimiz üzere, sözleşme uygulanmasına ilişkin süreç özel hukuk hükümlerine göre şekillenmektedir. Bu itibarla, 4735 sayılı Yasa'nın 36'ncı maddesi ışığında, koşulların oluşması halinde Borçlar Kanunu'na göre taraflar karşılıklı olarak sözleşmeyi sonlandırabileceği sonucu çıkmaktadır.

Ancak burada önem arz eden husus, gerek 4734 ve gerekse 4735 sayılı Kanun'da özel olarak düzenlenen bir hususun bulunması halinde kuşkusuz ilgili Kanunlara ait hükümlerin uygulanması gerektiğidir. Şayet bu hususta açık bir hüküm yoksa hukukun genel ilkeleri arasında yer aldığı üzere, özel kanun hükmü yoksa genel hükme gidilmesi gerekliliğinden hareketle Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğidir.

Özetle; Kamu İhale Mevzuatında açık bir şekilde sözleşmede değişiklik yapılmasının iki sınırlı durum dışında izin verilmediğini buna karşın söz konusu sözleşmelerin hukuki niteliğinden dolayı Borçlar Kanunu'ndan hareketle tarafların borcu sona erdirebileceğini genel olarak ifade edebiliriz.

659 sayılı KHK'nın, "İdari uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli ve vazgeçme yetkileri" başlıklı 12'nci maddesine göre; 11'inci maddede belirtilen esaslara göre hareket edileceği öngörülmüş, bahse konu 11'inci madde ise, gerçek veya tüzel kişilerle aralarındaki sözleşmelerde belirtilen sebeplerle yapılan her türlü sözleşme değişikliklerinin yapılması ile belirtilenler dışında, idarelerin, herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline izin vermektedir.

Böylelikle, KHK'nın söz konusu 12'nci maddesine göre de idari işlemler dolayısıyla haklarının ihlal edildiğini iddia edenler idareye başvurarak, uğramış oldukları zararın sulh yoluyla giderilmesini dava açma süresi içinde isteyebilecekleri, sulh istemine ilişkin başvurunun işlemeye başlamış olan dava açma süresini durduracağı, başvuru sonuçlanmadan dava

açılamayacağı gibi sulh olunan konu ya da miktara ilişkin olarak dava yoluna başvurulamayacağını ifade edebiliriz.

Dolayısıyla, yapılacak sulh anlaşmasında, tarafların hak ve menfaatlerinin adil ve hakkaniyete uygun olarak sulhen çözümlenmesi ve bütün davaların etkili, verimli, usul ekonomisine uygun olarak takibi temsil edilen idarelerin hak ve yararının korunması bakımından önem arz etmektedir.

Bu itibarla, her ne kadar 659 sayılı KHK, ayrım yapmaksızın sözleşmelerde (dolayısıyla ihalelere ilişkin sözleşmelerde) değişiklik yapılmasına olanak sağlarken, buna karşın, kamu ihale mevzuatında ihalelere ilişkin sözleşmede değişiklik yapılması konusunda iki durum dışında açık bir hükmün bulunmaması nedeniyle söz konusu değişikliğin pek mümkün olmadığını, ancak Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde ibra yoluyla istisnai olarak sözleşmenin sona erdirilebileceğini söyleyebiliriz.

Netice itibarıyla; 659 sayılı KHK çerçevesinde, ihale kapsamı alımlarda olduğu gibi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda da sulh yoluna başvurulmasının mümkün olduğunu, söz konusu KHK'da bunu engelleyen ya da aksi yönde bir düzenlemenin olmadığını söyleyebiliriz.

98. Doğrudan temin yönteminde dava ne zaman açılabilir?

Özet: *İhalelere yönelik şikayet mekanizması genel olarak ihale kapsamı alımları kapsamakta olup, önce idareye sonra KİK'e yönelik bir şikayet mekanizması söz konusudur. İdari başvuru yolları tüketilmeden dava açılması mümkün değildir. Her ne kadar doğrudan temin kapsamında yer alan alımlar ihale türleri kapsamı dışında olsa da Anayasa'nın 125'inci maddesi çerçevesinde yargı yoluna başvurulması mümkündür. Dava öncesi sürece ait bazı yargı kararlarına yansıdığı üzere, alımı gerçekleştiren idareye başvurarak hatanın düzeltilmesinin istenilmesi ve bunun sonucuna göre gerekirse dava konusu edilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri açısından daha uygun bir işlem olacaktır. Ancak doğrudan temin kapsamı alımlarda doğrudan dava açılmasını engelleyen yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca bu alım yönteminde, KİK'e yapılan şikayet niteliğindeki başvuruların anılan Kurum tarafından görev yönünden reddi söz konusu olmaktadır.*

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'te, ihale sürecine ait şikayetlere ait usul ve esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin önce idareye şikâyet, daha sonra Kamu İhale Kurumuna (KİK) itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri bir sistem öngörülmüştür. Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak anılan Kanun'da düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'te de yer aldığı üzere, ihalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayettir. Şikayet başvuruları, elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet ile) KİK'e yapılır.

Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurularda, başvuru

süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.

İstekliler, ihalelere yönelik şikâyet başvurularını, ihale süreci ile sınırlı olarak yapılabilmektedir. Keza ihale sonrası sürecin şikâyet konusu edilmesi mümkün olmayıp, bunlarla ilgili doğrudan yargı makamlarına başvuru yapılması gerekmektedir. Sözleşme sonrası süreç dava konusu olabilmektedir.

1982 tarihli Anayasa'nın 125'inci maddesinde yer aldığı üzere, idare tarafından yapılan işlem veya eylemin yargı denetimine tabi olması sebebiyle, idarenin işlemi hukuka aykırılık teşkil ediyorsa dava açılabilecektir. İdari yargıda bir işlemin dava konusu yapılabilmesi için yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımından, bir veya birkaç unsurun hukuka aykırılık teşkil etmesi gerekmektedir.

Ancak 4734 sayılı Yasa çerçevesinde şikayet mekanizması esas olarak ihale kapsamı alımlar için öngörülmüş olup, buna ilişkin dokümanlarda ihale sürecinden bahsedilmektedir. Doğrudan teminde ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan bir ihale sürecinden bahsedilemez. Kanun'un anılan 53'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda idarelerce tesis edilen işlemler itirazen şikâyete konu edilemez.

Dolayısıyla, doğrudan temin ile ilgili idari işlem ve eylemler hakkında Kamu İhale Kurumunun inceleme yetkisi bulunmadığından, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gerçekleştirilen idari işlem ve eylemler için 2577 sayılı Kanun çerçevesinde yargıya başvurulur. Böylelikle idari başvuru yollarından farklı olarak, doğrudan temin kapsamı alımla ile ilgili olarak idari yargıda açılan davaların, ayrı bir yargılama usulüne tabi olmadığı söylenebilir.

4734 ve 2577 sayılı Yasalar uyarınca, davadan önce idari mekanizmaların tüketilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, doğrudan temin kapsamı alım da olsa önceden idare başvuru yoluyla bu işlemin düzeltilmesinin talep edilmesi uygun olacaktır.

Nitekim KİK tarafından verilen bir Uyuşmazlık Kararında da; "… *İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşıldığından ve kapsamda yer almayan bu ihalede idarenin kararına karşın yetkili idare mahkemesine başvurulması gerektiğinden 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi*

bulunmamaktadır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun görev yönünden reddine ...” hususu yer almaktadır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kanun'un 57'nci maddesinde de, "Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihaî kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür." hükmüne yer verilmiştir.

Sözleşmenin imzalanmasına kadar olan işlemler için Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilirken, sözleşmenin imzalanmasından sonraki aşamalar için KİK'e başvurulamayacağı ve doğrudan yargı mercilerine başvurulması gerekmektedir.

Bu bağlamda, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler, usulüne uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler. Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Aksi takdirde yargı mercilerince "idari merci tecavüzü" (2577 s. İdari Yargılama Usulü Kanunu) nedeniyle, "dilekçenin görevli idare merciine tevdiine" karar vermelidir. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir.

Doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarda ilişkin olarak Danıştayın ilgili dairesince verilen bir Kararda da; 4734 sayılı Kanun'un 54, 55 ve 56. maddelerinde öngörülen usul izlenmeden, başka bir anlatımla öncelikle idareye başvurulmadan ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılmadan açılan davada; ihale işlemine karşı şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında bulunulduktan sonra Kurulca verilen kararın dava konusu edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (İYUK) 14'üncü maddesinde, açılan davada idarî merci tecavüzü bulunup bulunmadığının ilk inceleme sırasında inceleneceği; 15'inci maddesinde de idarî merci tecavüzü halinde, dilekçelerin görevli idarî mercie tevdiine karar verileceği hükme bağlanmıştır. Böylelikle idari başvuru yollarından farklı olarak, doğrudan temin alımı ile ilgili idari yargıda açılan davalar belli başlı niteliklere ilişkin olup, ayrı bir yargılama usulüne tabi olmadığı görülmektedir.

Ancak 4734 sayılı Yasa çerçevesinde şikayet mekanizması esas olarak ihale kapsamı alımlar için öngörülmüş olup, buna ilişkin dokümanlarda ihale sürecinden bahsedilmektedir. Doğrudan teminde ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan bir ihale sürecinden bahsedilemez.

İstisna kapsamı alımlara ilişkin olarak da, idarelerin istisna kapsamındaki ihale işlemlerinin ya da uygulamalarının hukuka aykırı olduğunu düşünen ilgililerin genel idari başvuru yoluna gitmesi gerekmektedir. İlgililer, istisna kapsamındaki ihale işlemlerine yönelik olarak, İYUK'un 11'inci maddesine dayanarak idareye başvurabileceği gibi doğrudan doğruya idari yargıda iptal davası da açabilecektir.

Farklı bir mahkeme kararında, 4734 sayılı Kanun'un hükmü uyarınca ihalenin iptali istemiyle doğrudan dava açılması mümkün olmadığından, uyuşmazlık konusu ihalede daha düşük teklif verdikleri halde ihalenin başka firma üzerinde bırakılmasının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla ihalenin iptali istemiyle açılan davada 4734 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık bulunmadığı dile getirilmiştir.

İhale kararları idari bir işlemdir ve hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, Anayasa'nın 125'inci maddesinde yer aldığı üzere, "idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açık olduğu" dikkate alınarak doğrudan temin kapsamı alımların dava konusu edilebilmesi gerekir.

Doğrudan teminde ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan bir ihale sürecinden bahsedilemez. Dolayısıyla, Kanun'un yukarıda anılan 53'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda idarelerce tesis edilen işlemler itirazen şikâyete konu edilemez.

Doğrudan temin ile ilgili idari işlem ve eylemler hakkında Kamu İhale Kurumunun inceleme yetkisi bulunmadığından, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda gerçekleştirilen idari işlem ve eylemler için 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde idari yargıya başvurulması mümkündür.

Hukuk devletinin en temel özelliklerinden biri olan idarenin hukuka bağlılığı ilkesi gereği, idareler tarafından yapılan bütün işlem ve eylemlerin hukuka uygun olarak yapıldığı kabul edilir. İdarenin her ne kadar bazı işlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi olması hususu Anayasa'nın 125'inci maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Bu kapsamda idare tarafından yapılan işlem veya eylem hukuka aykırılık teşkil ediyorsa dava açılabilecektir.

İdari yargıda bir işlemin dava konusu yapılabilmesi için yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımından, bir veya birkaç unsurun hukuka aykırılık teşkil etmesi gerekmektedir.

Netice itibarıyla; doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımların, 4734 sayılı Kanun uyarınca, ihale usulleri arasında sayılmaması bu alım türleri için öngörülen usul olan şikayet (idareye) ve itirazen şikayet (KİK) yollarının tüketilmesinden sonra yargıya başvurulması mümkün değildir. Bu sebeple idari işlemlere karşı doğrudan yargıya başvurması mümkün görülmekle birlikte, bazı yargı kararlarına yansıdığı üzere, öncelikle idareye sonrasında yargıya başvurulmasının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yer alan olası idari merci tecavüzü riskini ortadan kaldıracağı için daha uygun olacağı düşünülmektedir.

99. KBS boyutuyla taşınır ve bağlantılı harcama kapsamı işlemler örnek uygulamalar çerçevesinde nasıl gerçekleştirilmektedir?

Özet: *Doğrudan temin yöntemi alımlar, ihale kapsamına ilişkin kriterlere bağlı olmadan alım yapılmasına olanak sağlamaktadır. Alımın niteliği dikkate alınarak idareye geniş bir esneklik sağlanmıştır. Bu bağlamda genel kural olarak, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına ilişkin yasal çerçevede, idare ihtiyaçlarının, piyasa fiyat araştırması yapmak suretiyle uygun koşullarda karşılanması söz konusudur. Harcama sürecinin, gerek harcama talimatı hazırlanması ve gerekse taşınır işlemleri boyutuyla KBS'yi de ilgilendiren boyutu bulunmaktadır. Zira KBS, içerisinde birçok sistemi barındıran bir yazılımdır. Bu yazılımdaki sistemler muhasebe birimleriyle birlikte çalışır. Şöyle ki, KBS üzerinde yapılan bir işlem muhasebe birimini ilgilendiriyor ve muhasebe kaydı gerektiriyorsa, muhasebe sistemine gönderilir ve burada muhasebeleştirilir. KBS içerisinde taşınırların (TKYS) izlenmesi için de modüller bulunmaktadır. KBS ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanması hedeflenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) hazırlanan Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu ile Bütçe Hazırlama Rehberi'nin (Analitik Bütçe Sınıflandırması kapsamındaki açıklamalarının) de süreçte göz önünde bulundurulması gerekmektedir.*

Harcama sürecinin gerek harcama talimatı hazırlanması ve gerekse taşınır işlemleri boyutuyla KBS'yi de ilgilendiren boyutu bulunmaktadır. Zira KBS, içerisinde birçok sistemi barındıran bir yazılımdır. Bu yazılımdaki sistemler muhasebe birimleriyle birlikte çalışır. Şöyle ki KBS üzerinde yapılan bir işlem muhasebe birimini ilgilendiriyor ve muhasebe kaydı gerektiriyorsa, muhasebe sistemine gönderilir ve burada muhasebeleştirilir. KBS içerisinde taşınırların (TKYS) izlenmesi için de modüller bulunmaktadır. KBS ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedeflenmiştir. Bu kısımda Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) hazırlanan Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu da göz önünde bulundurulmak suretiyle açıklamalarda bulunulmaktadır.

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) KBS içerisinde yer alan uygulamalardan biridir. İdarelerce tüm taşınır işlemleri bu uygulama kapsamında yerine getirilmektedir. Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) arasında entegrasyon sağlanarak taşınır işlemlerine ilişkin harcama ve muhasebeleştirme süreçleri, elektronik olarak gerçekleştirilebilme olanağına kavuşmuştur.

*Bu çerçevede, **Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)** içerisinde önemli bir değişiklik söz konusu olmayıp, Entegrasyon, onaylı Taşınır İşlem Fişlerinde (TİF) yer alan veriler baz alınarak, maddi ve maddi olmayan tüm varlık işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde gerekli belge olarak tasarlanan Varlık İşlem Fişlerinin (VİF) oluşturulması ve süreçte bir sonraki sisteme elektronik iletimiyle sağlanmaktadır. Bu bağlamda, TKYS'ye Onaylı Taşınır İşlem Fişleri alt menüsünde butonlar bulunmaktadır.*

*Bu butonlar ile seçilen her bir onaylı TİF'e ilişkin VİF belgesini oluşturarak güvenli tekil bir numarayla ilgisine göre harcama veya muhasebe sistemine gönderilmesini sağlar. Aynı şekilde, **VİF Durum Sorgula butonu** ile de seçili her bir onaylı TİF'in sürecin hangi aşamasında olduğunu dair sorgulama yapılır. Sorgu sonucunda "Muhasebe (Fiş Durumu)" sütunu güncellenir.*

*TKYS'nin BKMYBS'yle entegre olması iki ayrı sistemin iletişimi şeklinde olduğundan, üzerinde işlem yapılan yahut kontrol edilmek istenen TİF'ler için TKYS'de yer alan **VİF Durum Sorgula** butonunun kullanılması mümkündür.*

Diğer taraftan, Mali Yönetim Sistemi (MYS), "Harcama Talimatı Onay Belgesi" ile "Ödeme Emri Belgesi"nin e-belge standartlarına uygun olarak elektronik ortamda hazırlamasına ve harcama işlemlerini yürütebilmesine imkân tanıyan bilişim sistemidir. Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında entegrasyonu sağlayan MYS, vergi borcu sorgu, ödeme belgesi, aboneliğe bağlı ödemeler ve e-yolluk uygulamalarını kapsamaktadır. Personel ödemeleri dışında kalan su, elektrik, doğalgaz, telefon ödemeleri gibi aboneliğe bağlı ödemeler, her türlü mal ve hizmet alımı ödemeleri, tarifeye bağlı ödemeler, ilama bağlı borç ödemeleri kısacası bir harcama biriminde 4/A ve 4/B personel ödemeleri dışındaki bütün ödemeler ve 4/C personel ödemeleri ve geçici personel ödemeleri Mali Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden hazırlanarak muhasebe birimine gönderilir.

Mali Yönetim Sistemi (MYS), *MYS'de Varlık Yönetimi menüsü altında 'VİF Listesi'ne ulaşıldığında ilgili harcama biriminde TKYS'den oluşturularak gönderilen Satın Alma ve Değer Artırımı TİF'lerine ait VİF'ler ekranda listelenmektedir. VİF Listesinde istenilen VİF seçilerek* ***Görüntüle*** *butonu yardımıyla VİF görüntülenebilir. Aynı fatura ile alımı gerçekleşen taşınırlar tek bir VİF belgesinde yer alarak tek bir ödeme emri belgesi oluşturulmasına zemin hazırlanmaktadır.*

VİF'ler, ancak ***Mal ve Hizmet Alımı*** *harcama türü altındaki* ***Taşınır Mal Alımı*** *ile* ***Diğer Mal Alımı*** *alt türleri veya* ***Temsil ve Tanıtma Gideri*** *harcama türü seçilerek oluşturulan harcama talimatlarıyla ilişkilendirilebilir. Harcama talimatıyla ilişkilendirilen bir VİF için kullanıcı, Durum sütununda yer alan harcama no linkine tıklayarak harcama talimatına ulaşır ve ödeme emri oluşturma aşamasını başlatabilir.*

Ödeme emri detay bilgilerinde, hak sahibinin (öeb'nin ilgilisinin) VKN/TCKN verisi, ödeme kalem türleri ve tutarlar otomatik olarak oluşturulmakta ve değiştirilmesine olanak tanınmamaktadır. Bu hususlar haricinde MYS'de oluşturulan diğer ödeme emirlerinden farklı bir kontrol veya işleyiş söz konusu değildir. Aynı faturada yer alıp, mevzuatı gereği taşınırın maliyetine eklenemeyen kalemler mevcut ise, yeni detay eklenmek suretiyle aynı ödeme emrinde taşınır haricinde de ödeme kalemi oluşturulabilmektedir.

Aşağıda ise Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan elde edilen bazı ekran görüntüleri ve bu hususta yapılan açıklamalara yer verilmekte olup, anılan Başkanlıkta görevli Şef Abdullah YILDIRIM bu soru başlığının yazılmasına katkı sağlamıştır.

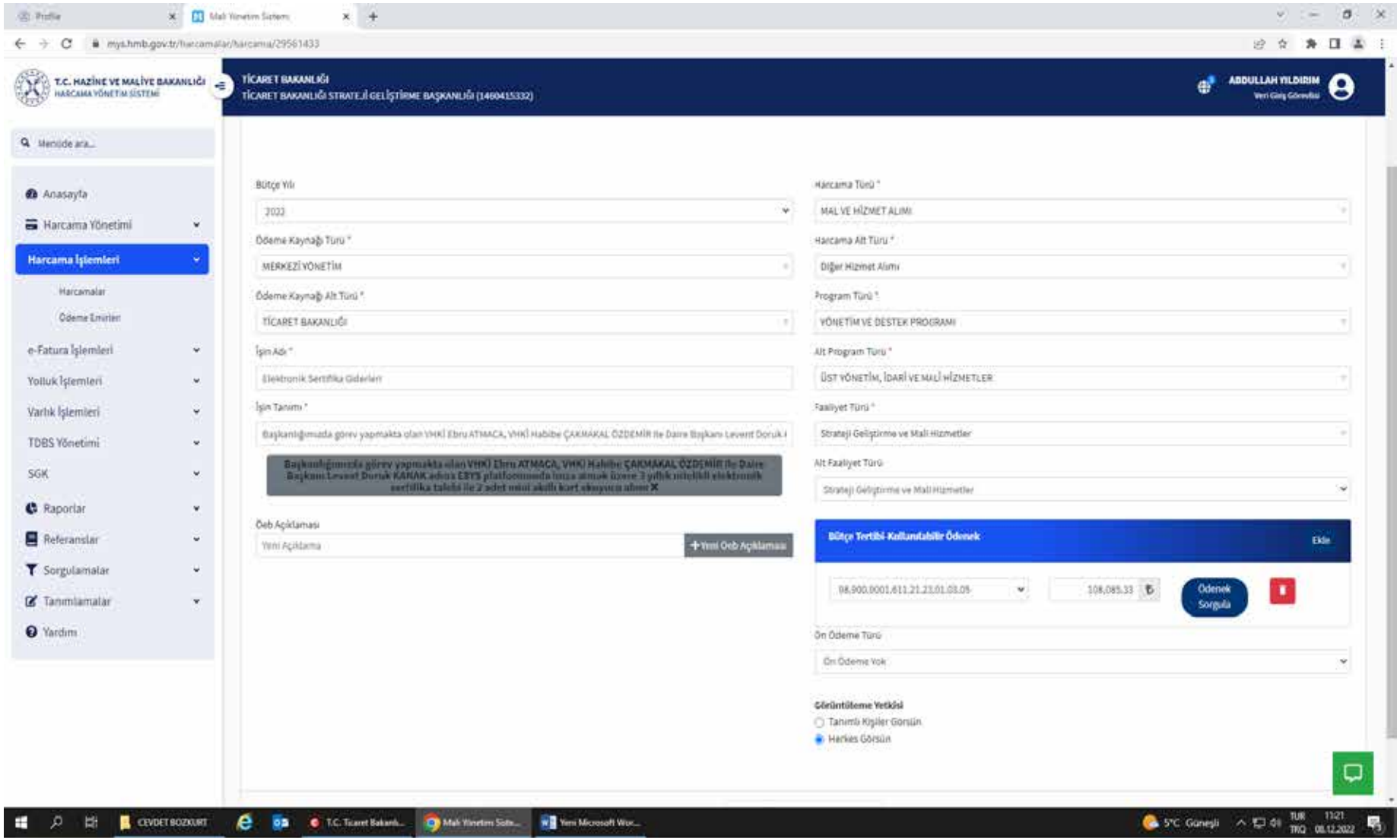
A. HİZMET ALIMLARINDAN YAPILACAK ÖDEMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Strateji Geliştirme Başkanlığında görev yapmakta olan personel adına TÜBİTAK Bilgem Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika süre uzatımı (3 yıllık) işlemleri yapılmış, ilgili sertifikalar oluşturulup kurye ile elden teslim edilmiştir. Sertifikalara ait kanıtlayıcı belge niteliğinde olan fatura oluşturularak anılan Başkanlığa posta yolu ile iletilmiştir.

Bu kapsamda; ilgili faturanın MYS platformu üzerinden tahakkuk ettirilmesi işlemlerinde aşağıdaki adımlara dikkate edilmiştir.

HARCAMA TALİMATININ OLUŞTURULMASI;

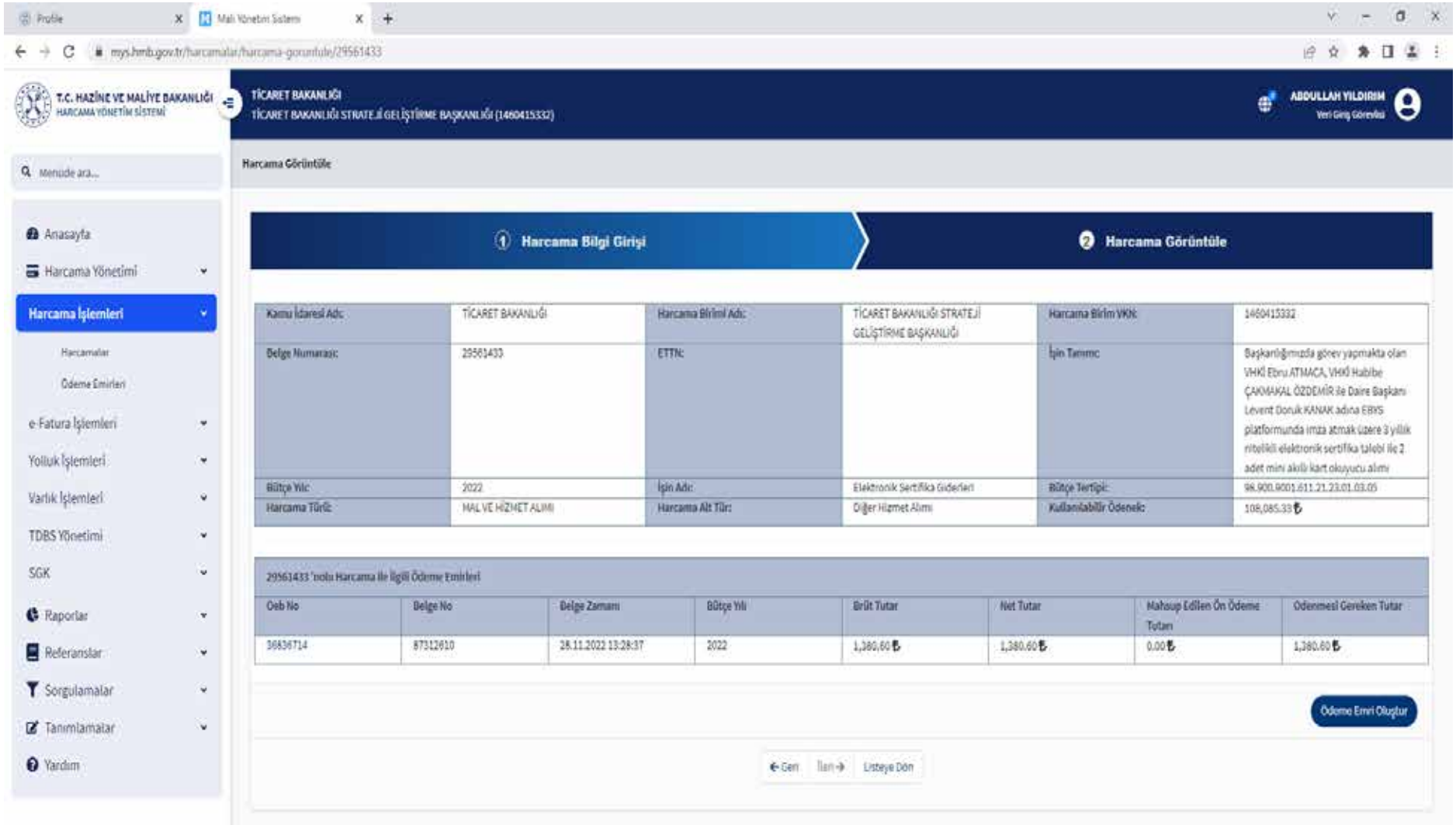
1-) Bir giderin gerçekleştirilmesi için öncelikli unsur harcama talimatının oluşturulmasıdır. MYS Veri Giriş Görevlisi tarafından ilgili harcama türü ve alt türü seçimlerinin yapılması ile süreç başlar. Yapılan işin niteliği gereği olarak, mal ve hizmet alımları sekmesi seçilmiştir. Burada dikkat edilecek husus, harcama alt türü kodunun doğru olarak seçilmesidir. Eğer; hizmet alımları kodu seçilirse, ödeme emirleri bölümüne gelindiğinde elektronik sertifika giderleri bütçe tertibi bulanamaz. Elektronik Sertifika Giderleri tertibinin görüntülenebilmesi için harcamalar bölümünde "Diğer Hizmet Alımları" sekmesinin seçilmesi gerekmektedir. Ödeme emirleri bölümüne geçildiğinde elektronik sertifika giderleri adı altında bütçe tertibi görüntülenecektir. Burada amaç, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan bütçe tertiplerinin açıklamalarına uygun hareket etmek ve yeknesaklığı sağlamaktır.


T.C. MAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ
TİCARET BAKANLIĞI
TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (1460415332)
ABDULLAH YILDIRIM
Menüde ara...
Anasayfa
Harcama Yönetimi
Harcama İşlemleri
Harcamalar
Ödeme Emirleri
e-Fatura İşlemleri
Yolluk İşlemleri
Varlık İşlemleri
TDBS Yönetimi
SGK
Raporlar
Referanslar
Sorgulamalar
Tanımlamalar
Yardım
Bütçe Yılı
2022
Harcama Türü *
MAL VE HİZMET ALIMI
Ödeme Kaynağı Türü *
MERKEZİ YÖNETİM
Harcama Alt Türü *
Diğer Hizmet Alımı
Ödeme Kaynağı Alt Türü *
TİCARET BAKANLIĞI
Program Türü *
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İşin Adı *
Elektronik Sertifika Giderleri
Alt Program Türü *
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
İşin Tanımı *
Faaliyet Türü *
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Alt Faaliyet Türü
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Öneb Açıklaması
Yeni Açıklama
+Yeni Öneb Açıklaması
Bütçe Tertibi Kullanılabilir Ödenek
Ekle
Ödenek Sorgula
Ön Ödeme Türü
Ön Ödeme Yok
Görüntüleme Yetkisi
Tanımlı Kişiler Görsün
Herkes Görsün
CEVDET BOZKURT
5°C Güneşli

2-) MANUEL HARCAMA ONAYI ALINMASI;

İlgili harcama talimatı oluşturulurken, ödeneklerin kontrol edilmesi önemlidir. Yeterli ödeneği bulunmayan tertiplerden harcama yapılamaz. Ancak; bu durum ödeme emri safhasına geçildiği anda karşımıza çıkan bir risktir. Örnek olayda; harcama talimatında 03.5 Hizmet Alımları bütçe tertibi seçilmiş ve ödenek sorgula butonuna basılarak mevcut kullanılabilir ödenek miktarı kontrol edilmiştir. Kullanılabilir ödenek miktarının eşiti ya da altı ödemelerde herhangi bir risk bulunmamaktadır. Ancak; fatura tutarının kullanılabilir ödenek tutarının üzerinde olması durumunda harcama yapılamayacaktır. Bu durum; harcama talimatı bölümünde görünmez. Zira yaklaşık maliyet tutarı veri girişi, bu arayüz bölümünde görüntülenmemektedir.

Sonrasında ise, 2. adım olan harcama görüntüleme bölümünde, yapılan harcamanın harcama yetkilisi onayına sunulması söz konusudur. Normal şartlar altında harcama talimatlarının gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayına sunularak oluşturulması gerekir. Ancak, Diğer Hizmet Alımları harcama alt türünden yapılan harcamalarda harcama talimatı herhangi bir onaya tabii olmaksızın Ödeme Emri oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Harcama yetkilisinin onayı alınmadan ödeme emri düzenlenemeyeceğinden manuel olarak harcama talimatı düzenlenmesi zorunludur. Örnek uygulamada; harcama talimatı ödeme emri oluşturma aşamasına kadar getirilmiş ve harcama talimatı manuel oluşturulmuştur.


T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ
TİCARET BAKANLIĞI
TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (1460415332)
ABDULLAH YILDIRIM
Veri Giriş Görevlisi
Menüde ara...
Anasayfa
Harcama Yönetimi
Harcama İşlemleri
Harcamalar
Ödeme Emirleri
e-Fatura İşlemleri
Yolluk İşlemleri
Varlık İşlemleri
TDBS Yönetimi
SGK
Raporlar
Referanslar
Sorgulamalar
Tanımlamalar
Yardım
Harcama Görüntüle
1 Harcama Bilgi Girişi
2 Harcama Görüntüle
Kamu İdaresi Adı:
TİCARET BAKANLIĞI
Harcama Birimi Adı:
TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Harcama Birim VKN:
1460415332
Belge Numarası:
29561433
ETTN:
İşin Tanımı:
Başkanlığımızda görev yapmakta olan VHKİ Ebru ATMACA, VHKİ Habibe ÇAKMAKAL ÖZDEMİR ile Daire Başkanı Levent Doruk KANAK adına EBYS platformunda imza atmak üzere 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika talebi ile 2 adet mini akıllı kart okuyucu alımı
Bütçe Yılı:
2022
İşin Adı:
Elektronik Sertifika Giderleri
Bütçe Tertibi:
99.900.9001.611.21.23.01.03.05
Harcama Türü:
MAL VE HİZMET ALIMI
Harcama Alt Türü:
Diğer Hizmet Alımı
Kullanılabilir Ödenek:
108,085.33₺
29561433 'nolu Harcama ile İlgili Ödeme Emirleri
Oeb No
Belge No
Belge Zamanı
Bütçe Yılı
Brüt Tutar
Net Tutar
Mahsup Edilen Ön Ödeme Tutarı
Ödenmesi Gereken Tutar
36836714
87312610
28.11.2022 13:28:37
2022
1,380.60₺
1,380.60₺
0.00₺
1,380.60₺
Ödeme Emri Oluştur
Geri
İleri
Listeye Dön

TİCARET BAKANLIĞI

HARCAMA TALİMATI

Sayı:	Tarih: / /2022
Harcama talebinde bulunan birim:	Strateji Geliştirme Başkanlığı

YAPILACAK HARCAMANIN	
Gerekçesi ve hukuki dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/B Maddesi
Konusu/nev'i / niteliği	Elektronik Sertifika Gideri
Miktarı	1 Adet Nitelikli Elektronik Sertifika Gideri
Gerçekleştirme süresi	1 Ay
Gerçekleştirme usulü	Tek Kaynaktan Temin
Tutarı veya belirlenmişse yaklaşık bedeli	1.380,60 TL(KDV Dahil)
Kullanılabilir ödenek tutarı	91.364,73 TL
Ödeneğin bütçe tertibi	98.900.9001.611.21.23.01.03.05
Gerçekleştirme görevlileri	

Başkanlığımızda kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde evrak imzalamayı sağlayan Elektronik Sertifikaların Başkanlığımız personeli Mali Hizmetler Uzmanı Erdem KARATAŞ adına 3 yıl süre ile uzatılması

ÖDEME EMRİNE BAĞLAMA İŞLEMLERİ;

Harcama talimatı gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine manuel olarak onaylattırıldıktan sonra tek kaynaktan temin formunun düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik sertifikalar hakkında (mülga) Başbakanlık Makamının yayınlamış olduğu, 2006/13 sayılı Genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik sertifika ihtiyacının TÜBİTAK tarafından karşılanması gerektiği öngörülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesi kapsamında ihtiyacın karşılanmış olması nedeniyle, Tek Kaynaktan Temin Formunun bu kapsamda düzenlenmesine dikkate edilmeli, harcama talimatı belge içeriklerinde de bu verilere yer verilmelidir.

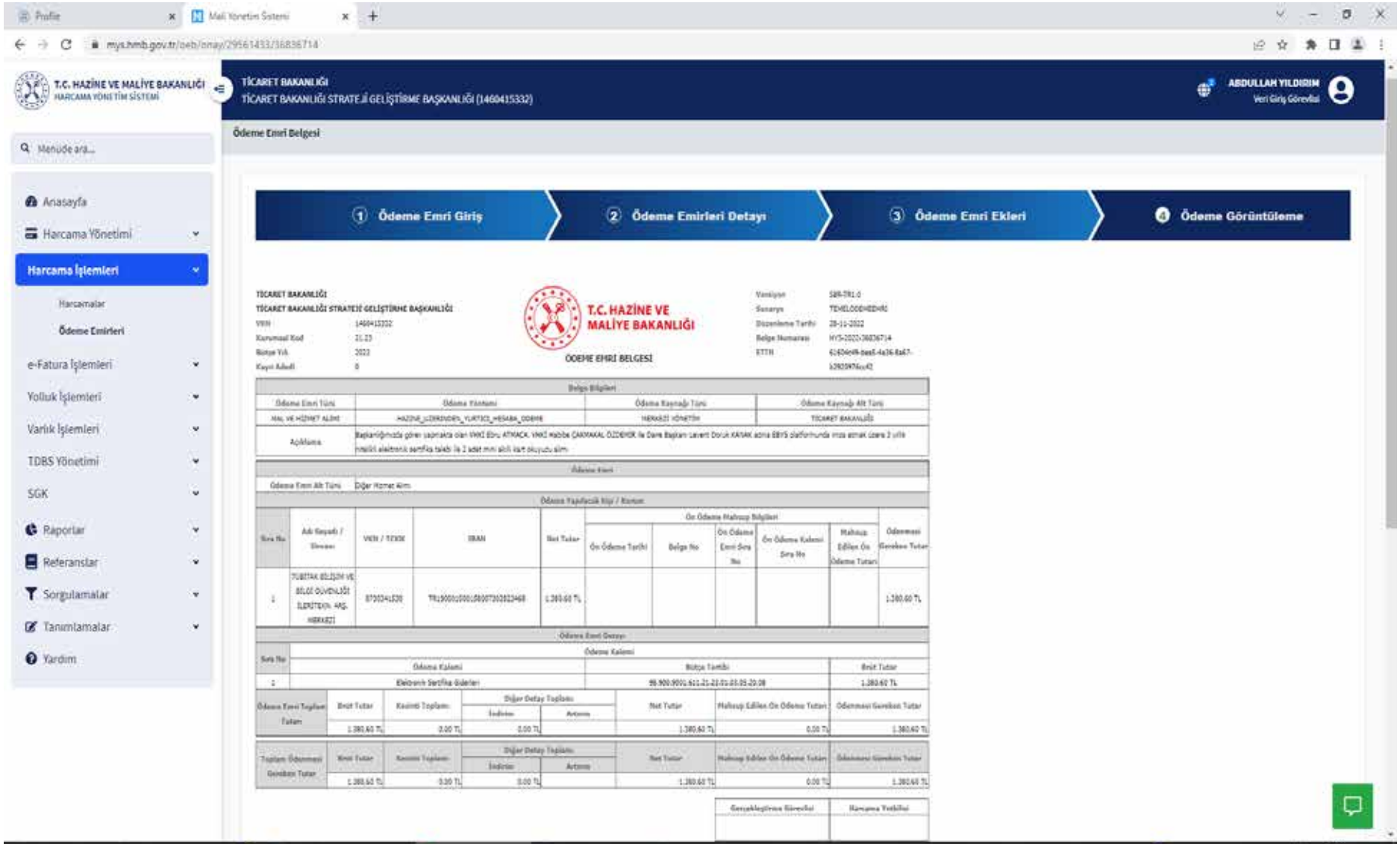
ÖDEME EMRİ AÇISINDAN;

Ödeme emri oluştur butonuna tıklanır.

Ödeme emri bölümünde seçilen harcama türü ve alt türüne uygun olacak şekilde ödeme yapılacak kişi/kurum seçilir. Gerekli TCKN/VKN bilgileri girildikten sonra ödeme kalemi bilgileri girilmelidir. Burada dikkate edilecek husus yapılacak giderin fatura muhteviyatı ile paralel olacak şekilde seçilmesidir. Bütçe tertibi seçilirken, Elektronik Sertifika Giderleri Ödeme Kalemine tıklanır. Mali Yönetim Sisteminde Bütçe tertibi her idare için otomatik olarak gelmektedir.

İlgili kurumun Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabii olmaması nedeniyle yapılacak tahakkuk işlemi vergi kesintisine tabii değildir. Yapılacak işlemler brüt tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayına sunulur. Onaylanan Ödeme Emri Belgesi harcama yetkilisi tarafından muhasebe birimine gönderilir.

Dikkat edilecek bir diğer husus ise; seçilen ödeme kalemine ait bütçe tertibinde ödenek bulunup bulunmamasıdır. Mali Yönetim Sisteminde veri girişi yapan personel tarafından ödenek miktarının üzerinde bir işlem yapılmaya çalışıldığında "ilgili tertipte yeterli ödenek bulunmamaktadır" uyarısı vermektedir. Yapılacak işlemde sistemsel bir hata olması nedeniyle ödenek üstü işleme izin verilmesi durumunda, tahakkuk işlemini gerçekleştirecek olan saymanlık müdürlüğü tarafından kullanılan BKMYBS programında da "ilgili tertipte yeterli ödenek bulunmamaktadır" uyarısı vererek işlemin iadesi ya da iptali sağlanmaktadır. Her iki durumda da harcama işlemleri ödenek yetersizliği nedeniyle tamamlanamamaktadır.


T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ
TİCARET BAKANLIĞI
TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (1460415332)
ABDULLAH YILDIRIM
Veri Giriş Görevlisi
Ödeme Emri Belgesi
Menüde ara...
Anasayfa
Harcama Yönetimi
Harcama İşlemleri
Harcamalar
Ödeme Emirleri
e-Fatura İşlemleri
Yolluk İşlemleri
Varlık İşlemleri
TDBS Yönetimi
SGK
Raporlar
Referanslar
Sorgulamalar
Tanımlamalar
Yardım
1 Ödeme Emri Giriş
2 Ödeme Emirleri Detayı
3 Ödeme Emri Ekleri
4 Ödeme Görüntüleme
TİCARET BAKANLIĞI
TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
ÖDEME EMRİ BELGESİ

Ayrıca; tahakkuk aşamasında, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirtilen belgelerin aranması zorunludur.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen Hizmet Alımına ilişkin işlemde;

-Harcama Talimatı
-Tek Kaynaktan Temin Formu
-Fatura
-Elektronik sertifikaların ilgili kişilere teslim edildiğine dair tutanak
-liste

ilgili ödeme emrine eklenerek muhasebe birimine bildirilir.

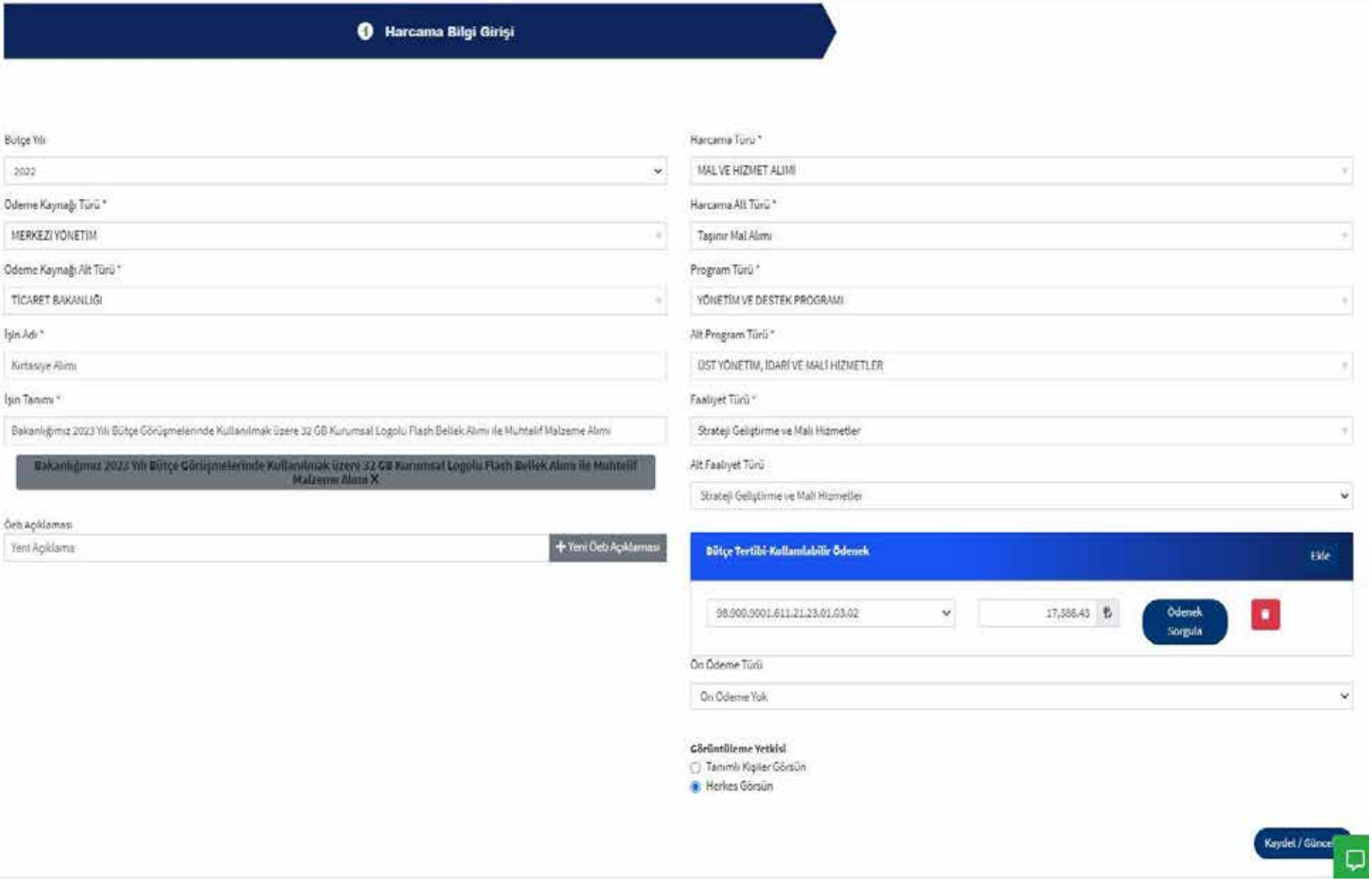
B. TAŞINIRLI MYS UYGULAMALASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İdarelerin harcama birimi düzeyinde yapmış oldukları tahakkuk işlemlerinde Mali Yönetim Sistemi (MYS) programı kullanılmakta olup, taşınır işlem fişi düzenlenen harcamalarda idarenin hata yapma imkânı yüksek düzeydedir. Bu nedenle; riski minimum düzeye indirmek, yıl sonu işlemlerinde yeknesaklığı sağlamak amacıyla aşağıdaki adımlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1-) HARCAMA TALİMATI OLUŞTURURKEN DOĞRU HARCAMA ALT TÜRÜNÜN SEÇİLMEMESİ

İdareler harcama işlemlerine ait oluşturacakları, Mali Yönetim Sistemi Harcama Talimatı işlemlerinde Harcama alt türünü doğru seçmelidir. Seçimi yapılacak harcama alt türünün taşınır işlem fişine tabii olup olmadığına dikkat edilmelidir. Eğer; tahakkuk işlemi taşınır işlem fişi oluşturularak yapılacak bir işlem ise taşınır mal alımı bölümünden, değil ise diğer mal alımı bölümünden seçim yapılması ödeme emri bölümünde seçilecek bütçe tertipleri açısından önem arz etmektedir.

Örnek olayda; Strateji Geliştirme Başkanlığına ait kırtasiye malzemesi alımı planlanmış, firmalar tarafından verilen tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde ortalama maliyet esasına göre yaklaşık maliyet cetveli oluşturulmuştur. Akabinde harcama onayının alınması için MYS platformuna veri giriş görevlisi giriş yaparak ilgili verileri girmeye başlamıştır. Alımı yapılan harcama türünün mal olması nedeniyle "mal ve hizmet alımı" sekmesi seçilmiştir. Burada harcama alt türünün doğru seçilmesi önemlidir. Taşınır işlem fişine haiz olan harcamalarda; harcama alt türü kodunun hatalı seçilmesi nedeniyle ödeme emri aşamasına gelindiğinde taşınır işlem fişi kodunda yer alan verilere ulaşılamayacaktır.


1 Harcama Bilgi Girişi
Bütçe Yılı
2022
Ödeme Kaynağı Türü *
MERKEZİ YÖNETİM
Ödeme Kaynağı Alt Türü *
TİCARET BAKANLIĞI
İşin Adı *
Kırtasiye Alımı
İşin Tanımı *
Bakanlığımız 2023 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Kullanılmak üzere 32 GB Kurumsal Logolu Flash Bellek Alımı ile Muhtelif Malzeme Alımı
Bakanlığımız 2023 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Kullanılmak üzere 32 GB Kurumsal Logolu Flash Bellek Alımı ile Muhtelif Malzeme Alımı X
Ödeneğ Açıklaması
Yeni Açıklama
+ Yeni Ödeneğ Açıklaması
Harcama Türü *
MAL VE HİZMET ALIMI
Harcama Alt Türü *
Taşınır Mal Alımı
Program Türü *
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Türü *
DST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Faaliyet Türü *
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Alt Faaliyet Türü
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Bütçe Tertibi-Kullanılabilir Ödenek
Ekle
98.000.9001.611.21.23.01.03.02
17,386.43 ₺
Ödenek Sorgula
Ön Ödeme Türü
Ön Ödeme Yok
Görüntüleme Yetkisi
Tanımlı Kişiler Görsün
Herkes Görsün
Kaydet / Güncel

BÜTÇE TERTİBİ-KULLANILABİLİR ÖDENEK KONTROLÜ

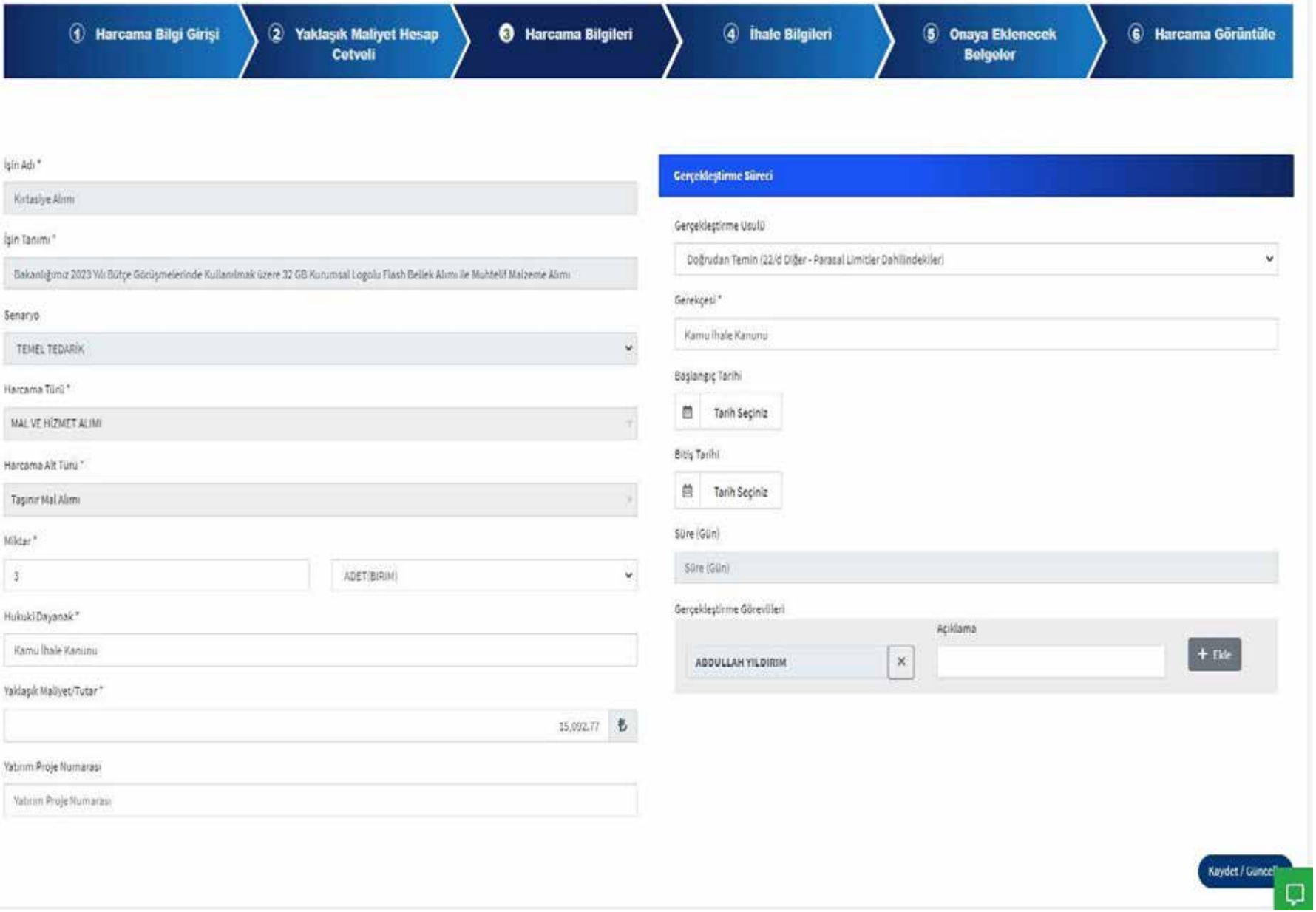
Ödeneği olmayan ya da yeterli düzeyde ödeneğe sahip olmayan bütçe tertiplerinden harcama yapılamaz. Bu nedenle ödenek sorgulama bölümünde "03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları" bütçe tertibi seçilerek bütçe tertibinde ne kadar ödenek olduğu sorgulanır. Yapılacak harcama tutarının, kullanılabilir ödenek tutarına eşit ya da kullanılabilir ödenek tutarının altında olması gerekir. Kullanılabilir ödenek tutarının üstünde yapılacak harcamalarda ödeme emri bölümü sekmesinde "ilgili tertipte yeterli ödenek bulunmamaktadır" uyarısı sistem tarafından verilmektedir.

Sistem tarafından hata verilmeyen durumlarda ödeme emri muhasebe birimine gönderilse dahi saymanlık müdürlüğü tarafından kullanılan BKMYBS programı ara yüzün de de "ilgili tertipte yeterli ödenek bulunmamaktadır" uyarısı verilerek işlemin iadesi ya da iptali sağlanır.

2-) GERÇEKLEŞTİRME USULÜNÜN DOĞRU SEÇİLMEMESİ

Veri giriş yetkilisince yapılacak tahakkuk işlemlerinde gerçekleştirme usulünün doğru seçilmemesi saymanlık müdürlüğü tarafından reddiyat işlemi ile sonuçlanmaktadır.

Örnek uygulamamızda Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan 2022 yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Tebliği uyarınca doğrudan temin limitleri dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi ile bağlantılı olan parasal sınırlar ve oranlar başlıklı gerçekleştirme usulü seçilmiştir. Ancak, söz konusu işlem tek kaynaktan temin işlemi gibi istisnai bir işlem olsaydı ve 22/d maddesi seçilseydi işlem muhasebe birimi tarafından iade edilecekti.


1 Harcama Bilgi Girişi
2 Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
3 Harcama Bilgileri
4 İhale Bilgileri
5 Onaya Eklenecek Belgeler
6 Harcama Görüntüle
İşin Adı *
Kırtasiye Alımı
İşin Tanımı *
Bakanlığımız 2023 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Kullanılmak üzere 32 GB Kurumsal Logolu Flash Bellek Alımı ile Muhtelif Malzeme Alımı
Senaryo
TEMEL TEDARİK
Harcama Türü *
MAL VE HİZMET ALIMI
Harcama Alt Türü *
Taşınır Mal Alımı
Miktar *
3
ADET(BİRİM)
Hukuki Dayanak *
Kamu İhale Kanunu
Yaklaşık Maliyet/Tutar *
15,092.77
Yatırım Proje Numarası
Yatırım Proje Numarası
Gerçekleştirme Süreci
Gerçekleştirme Usulü
Doğrudan Temin (22/d Diğer - Parasal Limitler Dahilindekiler)
Gerekçesi *
Kamu İhale Kanunu
Başlangıç Tarihi
Tarih Seçiniz
Bitiş Tarihi
Tarih Seçiniz
Süre (Gün)
Süre (Gün)
Gerçekleştirme Görevlileri
Açıklama
ABDULLAH YILDIRIM
+ Ekle
Kaydet / Güncel

3-) TAŞINIR İŞLEM FİŞİNE UYGUN ÖDEME EMRİ BELGESİNİN DÜZENLENMEMESİ

KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi üzerinden oluşturulan taşınır işlem fişi ile MYS veri tabanı birbiri ile entegreli kurulmuştur. Taşınır işlem fişinin 2.düzey detay kodu ile ödeme emrinin ödeme emri kod bölümünün aynı olması gerekmektedir. Taşınır işlem fişinde yer alan 2.düzey detay kodunun dikkate alınmaması neticesinde yapılan ödemeler, saymanlık müdürlüğü tarafından kullanılan BKMYBS sistemlerinde genel kod düzeyinde görünmektedir. Bu nedenle; idarenin yapmış olduğu ödeme işlemi hatalı olup, taşınır kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında eşitsizliğe neden olmaktadır. Durum tespiti; idarenin yıl sonu geçici mizanlarını saymanlık müdürlüklerinden talep ettiklerinde taşınır kayıtları ile muhasebe kayıtlarındaki uyumsuzluk olarak göze çarpmaktadır. Neticede; muhasebe birimi kayıtları esas alındığından Harcama Birimlerince düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin hatalı olduğu belirtilmekte ve manuel olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Örnek olayda; ödeme emri kesilmeden önce taşınır kayıt ve yönetim sistemi üzerinden taşınır işlem fişi giriş sekmesi tıklanarak giriş işlemleri gerçekleştirilmiş ve ilgili taşınır işlem fişi varlık işlemleri menüsüne aktarılmak üzere muhasebe birimine gönderilmiştir.

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

FİŞ SIRA NO	2022/16	**TAHAKKUK NO**		**TARİH**	28/11/2022

İL VE İLÇENİN	**ADI**	Merkez	**KODU**	00
HARCAMA BİRİMİNİN	**ADI**	Strateji Geliştirme Başkanlığı	**KODU**	31.1.0.23.923 (21.23-1460415332)
MUHASEBE BİRİMİNİN	**ADI**	Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü	**KODU**	32

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞININ	**TARİHİ**	28/10/2022	**SAYISI**	01
DAYANAĞI BELGENİN	**TARİHİ**	28/10/2021	**SAYISI**	GIB2022000000062

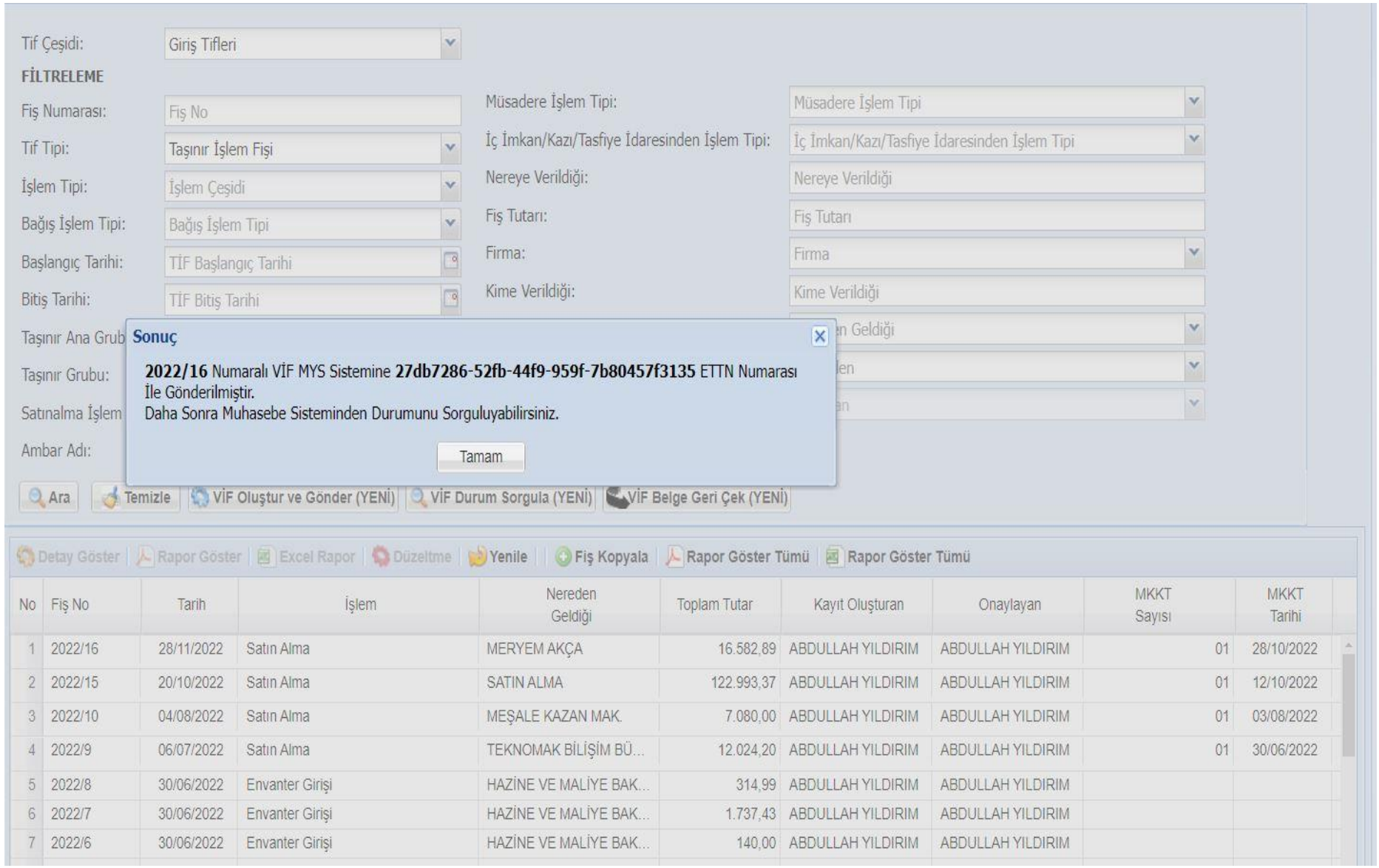
İŞLEM ÇEŞİDİ	**NEREDEN GELDİĞİ**	**KİME VERİLDİĞİ**	**NEREYE VERİLDİĞİ**
Satın Alma(Kurum Bütçesi)	MERYEM AKÇA MERYEM AKÇA		

BİRİMLER ARASI TAŞINIR HAREKETLERİNDE

GÖNDERİLEN HARCAMA	**ADI**		**KODU**	—
GÖNDERİLEN TAŞINIR AMBARI	**ADI**		**KODU**	
MUHASEBE BİRİMİNİN	**ADI**		**KODU**	

TAŞINIRIN

SIRA NO	KODU	SİCİL NO	ADI	AMBAR KODU	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYAT	MİKTARI	TUTARI
1	150.1.8.1.5-65		FLAŞ DİSKLER (32 GB FLASH BELLEK SANDİSK 32 GB FLASH BELLEK)	31102392301	ADET	81.06600000	130	10,538.58
	150.01.08	**Bilişim Malzemeleri**						**10,538.58**
2	150.13.4.1.1.2-7		FARELER (FARELER .MARKASIZ MOUSE)	31102392301	ADET	231.63400000	21	4,864.31
3	150.13.4.1.1.99-9		DİĞER BİLGİSAYAR VERİ GİRİŞ CİHAZLARI (SAMSUNG 1TB HARİCİ DİSK)	31102392301	ADET	1,180.00000000	1	1,180.00
	150.13.04	**Büro Makinecleri Grubu Yedek Parçaları**						**6,044.31**
			GENEL TOPLAM					**16,582.89**
			TİF KURUŞ FARKI..					**0.0**



No	Fiş No	Tarih	İşlem	Nereden Geldiği	Toplam Tutar	Kayıt Oluşturan	Onaylayan	MKKT Sayısı	MKKT Tarihi
1	2022/16	28/11/2022	Satın Alma	MERYEM AKÇA	16.582,89	ABDULLAH YILDIRIM	ABDULLAH YILDIRIM	01	28/10/2022
2	2022/15	20/10/2022	Satın Alma	SATIN ALMA	122.993,37	ABDULLAH YILDIRIM	ABDULLAH YILDIRIM	01	12/10/2022
3	2022/10	04/08/2022	Satın Alma	MEŞALE KAZAN MAK.	7.080,00	ABDULLAH YILDIRIM	ABDULLAH YILDIRIM	01	03/08/2022
4	2022/9	06/07/2022	Satın Alma	TEKNOMAK BİLİŞİM BÜ...	12.024,20	ABDULLAH YILDIRIM	ABDULLAH YILDIRIM	01	30/06/2022
5	2022/8	30/06/2022	Envanter Girişi	HAZİNE VE MALİYE BAK...	314,99	ABDULLAH YILDIRIM	ABDULLAH YILDIRIM		
6	2022/7	30/06/2022	Envanter Girişi	HAZİNE VE MALİYE BAK...	1.737,43	ABDULLAH YILDIRIM	ABDULLAH YILDIRIM		
7	2022/6	30/06/2022	Envanter Girişi	HAZİNE VE MALİYE BAK...	140,00	ABDULLAH YILDIRIM	ABDULLAH YILDIRIM		

4-)VARLIK İŞLEM FİŞİ OLUŞTURMA VE MUHASEBE BİRİMİNE İLETİLMESİ

Söz konusu taşınır işlem fişi saymanlık müdürlüğüne gönderildiğinde TKYS programında 34 haneli bir ETTN numarası düzenlemiştir. Düzenlenen ETTN numarası taşınır işlem fişinin MYS ile entegre olan varlık işlemleri bölümüne iletmiştir. Yapılacak işlem; taşınır işlem fişine uygun bir ödeme emri belgesi düzenlemektir.

Ödeme emri belgesi düzenleme kısmında; ödeme emri belgesinde yer alan ödeme emri kaleminin bütçe tertiplerinin taşınır işlem fişine uygun düzenlenmemesidir.

Örnek uygulamada; 150 ilk madde ve malzemeler grubunda yer alan ve 2.düzey detay kodu 150.01.08 olan bilişim malzemesi alımı için harcama alt türüne uygun ödeme kalemi olarak bilişim malzemeleri kalemi seçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Analitik Bütçe Rehberinde yer alan bilgiler ışığında uygun bütçe tertibinin seçilmesi gerekmektedir. Anılan Rehberde, bilişim malzemesinin 03.2 mal ve malzeme alımları bütçe tertibinde yer aldığı, 03.02.10.01 dörtlü düzey detay kodu ile de flash bellek alımlarının kırtasiye alımları tertibinin içerik kısmında vurgulandığı dikkate alınmalıdır.

Ödeme emirlerinin taşınır işlem fişi ile Analitik Bütçe Rehberinde yer alan sınıflandırmalar çerçevesinde yapılmasının, hata ve riskleri azaltacağı düşünülmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI
TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
VKN 1460415332
Kurumsal Kod 21.23
Bütçe Yılı 2022
Kayıt Adedi 0

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

ÖDEME EMRİ BELGESİ

Versiyon SBR-TR1.0
Senaryo TEMELODEMEEMRI
Düzenleme Tarihi 28-11-2022
Belge Numarası HYS-2022-36861932
ETTN

Belge Bilgileri			
Ödeme Emri Türü	Ödeme Yöntemi	Ödeme Kaynağı Türü	Ödeme Kaynağı Alt Türü
MAL VE HİZMET ALIMI	HAZINE_UZERINDEN_YURTICI_HESABA_ODEME	MERKEZİ YÖNETİM	TİCARET BAKANLIĞI
Açıklama	Bakanlığımız 2023 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Kullanılmak üzere 32 GB Kurumsal Logolu Flash Bellek Alımı ile Muhtelif Malzeme Alımı		

Ödeme Emri	
Ödeme Emri Alt Türü	Taşınır Mal Alımı

Ödeme Yapılacak Kişi / Kurum

Sıra No	Adı Soyadı / Unvanı	VKN / TCKN	IBAN	Net Tutar	Ön Ödeme Mahsup Bilgileri					Ödenmesi Gereken Tutar
					Ön Ödeme Tarihi	Belge No	Ön Ödeme Emri Sıra No	Ön Ödeme Kalemi Sıra No	Mahsup Edilen Ön Ödeme Tutarı	
1	MERYEM AKÇA	35545525688	TR740004600311888000101210	16.449,66 TL						16.449,66 TL

Ödeme Emri Detayı

Sıra No	Ödeme Kalemi			Kesinti							
	Ödeme Kalemi	Bütçe Tertibi	Brüt Tutar	Kesinti Türü	Kesinti Alt Türü	Kesinti Yapılan Kişi Kurum		Dosya No	Hesaba Esas Tutar	Kesinti Oranı	Tutar
						Adı Soyadı / Ünvanı	VKN / TCKN				
1	Bilişim Malzemeleri	98.900.9001.611.21.23.01.03.02.10.01	10.538,58 TL								
2	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	98.900.9001.611.21.23.01.03.02.09.90	6.044,31 TL								
3				Vergi	Damga Vergisi - Resmi Dairelerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler (Avans Dahil) Nedeniyle Düzenlenen Makbuz ve İbra Senetleri ile Bu Mahiyetteki Kağıtlar				14.053,30 TL	0.00948	133,23 TL

Ödeme Emri Toplam Tutarı	Brüt Tutar	Kesinti Toplamı	Diğer Detay Toplamı		Net Tutar	Mahsup Edilen Ön Ödeme Tutarı	Ödenmesi Gereken Tutar
			İndirim	Artırım			
	16.582,89 TL	133,23 TL	0,00 TL		16.449,66 TL	0,00 TL	16.449,66 TL

Toplam Ödenmesi Gereken Tutar	Brüt Tutar	Kesinti Toplamı	Diğer Detay Toplamı		Net Tutar	Mahsup Edilen Ön Ödeme Tutarı	Ödenmesi Gereken Tutar
			İndirim	Artırım			
	16.582,89 TL	133,23 TL	0,00 TL		16.449,66 TL	0,00 TL	16.449,66 TL

Ek Belgeler			
Doküman Türü	Doküman Tarihi	Doküman Numarası	Açıklama
HARCAMA_TALIMATI	28-11-2022	21690367	ettn:4edddf9e-c4b9-492d-a77a-a13e8f773bda

Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi

Muhasebe birimine gönderilen ödeme emri ile taşınır işlem fişi birbirleri ile uyumlu olduğundan 14 numaralı harcama yönetimi hesap cetvellerinde de işlem hatası gözükmeyecektir.

Ayrıca, ödeme sürecinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde yazılı olan belgelerin aranması zorunludur. Söz konusu belgeler ise şunlardır;

1-) Yaklaşık Maliyet Cetveli
2-) Harcama Talimatı Veya Onay Belgesi
3-) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
4-) Fatura
5-) Vergi Borcu Yoktur Yazısı
6-) Muayene Ve Kabul Komisyonu Tutanağı
7-) Taşınır İşlem Fişi

100. Doğrudan temin yönteminde EKAP üzerinden işlem yapılmakta mıdır?

Özet: *Elektronik alanda yaşanan gelişmelere bağlı olarak ihale kapsamı alımların büyük ölçüde elektronik ortama aktarılması ve EKAP üzerinden işlemlerin yürütülmesine rağmen, doğrudan temin kapsamı alımların EKAP üzerinden yürütülmesi isteğe bağlıdır. Ayrıca sistem de şu an itibarıyla yeterli seviyede değildir. Yani mevcut durum itibarıyla zorunluluk ve yaptırım yoktur. Dolayısıyla Kanun, İhale Uygulama Yönetmelikleri ve bu bağlamda Elektronik İhale Yönetmeliği hükümlerinin bütünüyle doğrudan temin yönteminde uygulanması hukuki ve teknik nedenlerle olası değildir. Ancak 16/11/2022 tarihli, 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli kanunlarda olduğu gibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda da değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihaleler ile Kanun'dan istisna edilen ve doğrudan teminle yapılan alımlarda, ayrıca tüm alım ve ihalelere ilişkin sözleşme süreçlerinde her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatın Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılabileceğine ve bu kapsamda EKAP üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile yapılması zorunlu işlemleri belirlemeye KİK'in yetkili olduğu ifade edilmiştir.*

Elektronik alanda yaşanan gelişmelere bağlı olarak ihalelerinin büyük ölçüde elektronik ortama aktarılması ve EKAP üzerinden işlemlerin yürütülmesine rağmen, doğrudan temin kapsamı alımlarda belli ölçüde yansıtılsa bile EKAP üzerinden işlemlerin yürütülmesi isteğe bağlıdır. Yani mevcut durum itibarıyla zorunluluk ve yaptırım yoktur. Dolayısıyla Kanun, İhale Uygulama Yönetmelikleri ve bu bağlamda Elektronik İhale Yönetmeliği'nin hükümlerinin bütünüyle uygulanması hukuki ve teknik nedenlerle olası değildir.

Diğer taraftan, 16/11/2022 tarihli, 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli kanunlarda olduğu gibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda da değişiklik yapılmış olup, 7421 sayılı Kanun'un 12'nci maddesi; *"4734 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.*

Bu Kanunun 13 üncü maddesi saklı kalmak üzere bu Kanunda veya diğer kanunlarla bu Kanundan istisna edilenler ile doğrudan teminle yapılanlar da dâhil olmak üzere, her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin alım, ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin olarak;

yaklaşık maliyetin ve dokümanların hazırlanması, ilanların yayımlanması, tekliflerin veya yeterlik başvurularının sunulması ve değerlendirilmesi, ihalelerin sonuçlandırılması, sözleşmelerin imzalanması, sonuç bildirimi, hakedişlerin düzenlenmesi gibi her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatlar ile şikayet ve itirazen şikayet başvuruları kısmen veya tamamen Kurum tarafından kurulan ve işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilebilir.
Kurum, EKAP'ın kurulması ve işletilmesine, birinci fıkra kapsamında yapılacak işlemlere, alım, ihale ve sözleşme süreçlerinde elektronik araçların kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile EKAP üzerinden yapılması zorunlu işlemleri belirlemeye yetkilidir."

Şeklinde hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kanun maddesinin gerekçesinde ise; kaydedilen teknolojik gelişmeler ışığında EKAP üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemlerin, kapsamının genişletilmesi ve EKAP'ın 4734 sayılı Kanun'dan istisna edilen ihaleler, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlar ve sözleşme süreçlerinde de etkin bir şekilde kullanılabilmesinin amaçlandığı hususu yer almaktadır.

Aynı hususta Kamu İhale Kurumu; 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihaleler ile Kanun'dan istisna edilen ve doğrudan teminle yapılan alımlarda, ayrıca tüm alım ve ihalelere ilişkin sözleşme süreçlerinde her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatın Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılabileceğine ve bu kapsamda EKAP üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile yapılması zorunlu işlemleri belirlemeye Kurumun yetkili olduğuna yönelik düzenleme yapıldığı ifade edilerek, bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu alımlarına katılım sağlayan kişilerin alım, ihale ve sözleşme süreçlerinde kullanacakları yeni hizmetlerin EKAP üzerinde geliştirilmesine devam edileceği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Kamu İhale Kurumunca yayınlanan doküman ve veriler esas alınarak EKAP üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait ön plana çıkan işlemlere aşağıda yer verilmektedir.

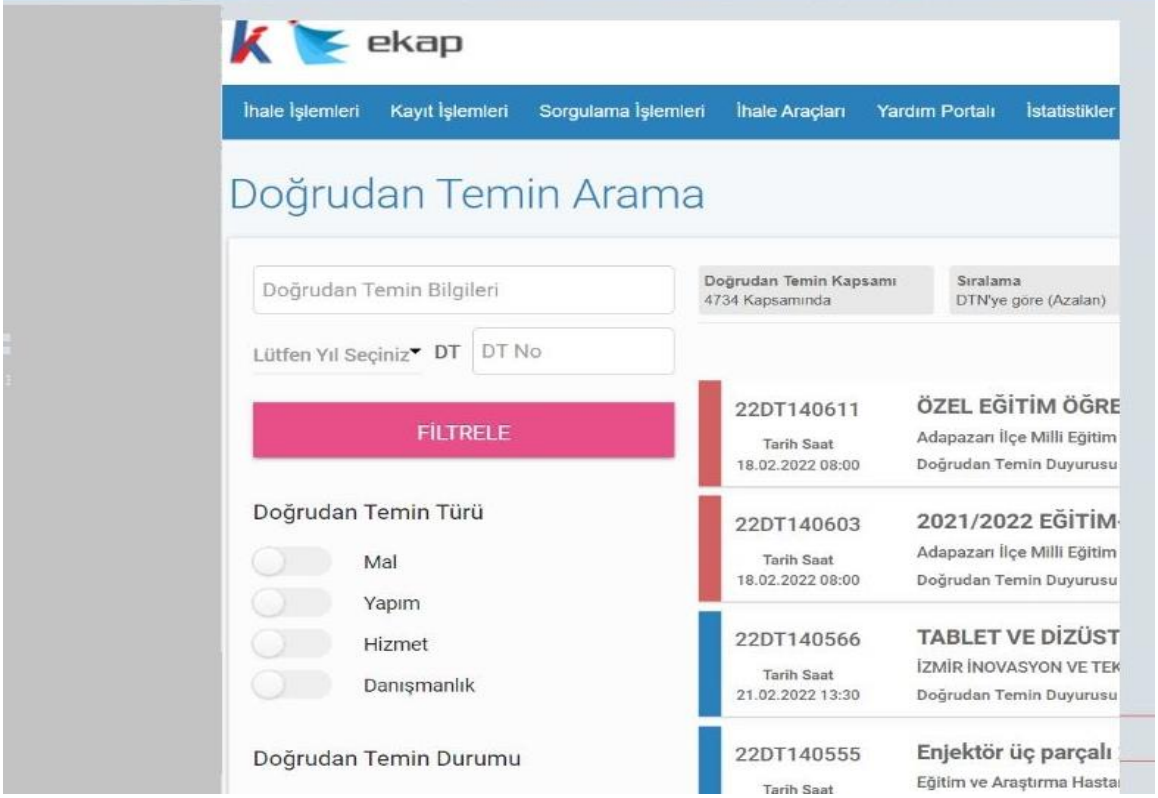
Doğrudan Temin Alımlarının İlanı

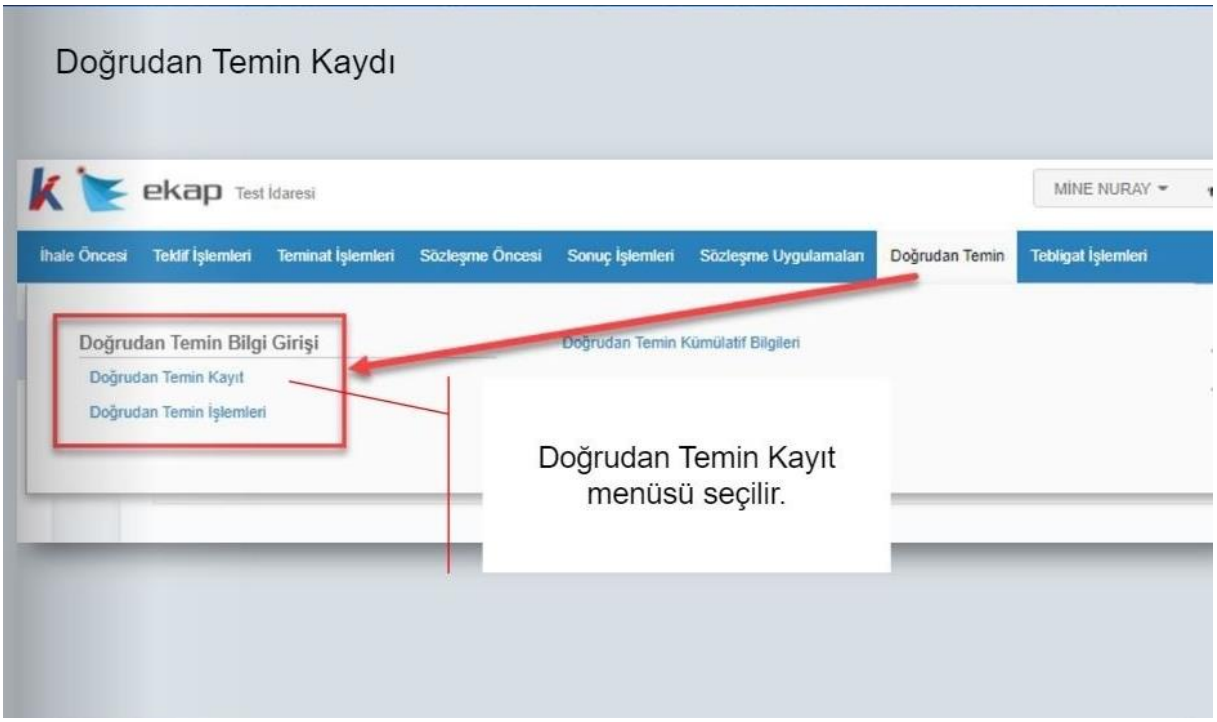
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesi kapsamında yapılacak doğrudan teminler ile istisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin alım öncesi EKAP üzerinden duyurulabilmesine yönelik uygulama 1 Şubat 2022 itibariyle devreye alınmıştır.

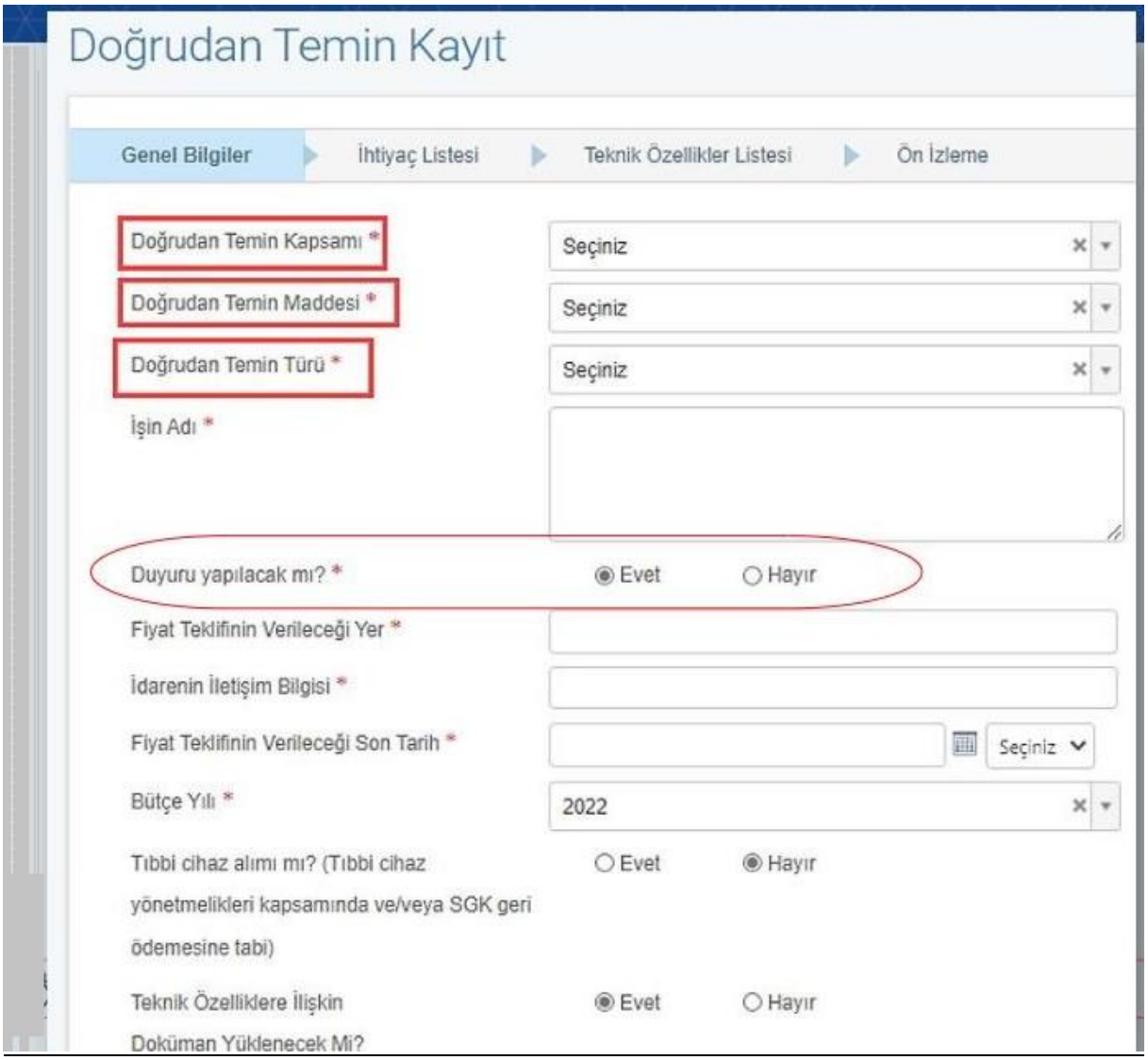
Bu kapsamda; doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların, alım öncesi ilgililere duyurulması, varsa alıma ilişkin dokümanlara duyuru ile birlikte erişilmesi ve duyuruya çıkan alımların farklı kriterlerle aranmasına yönelik geliştirmeler tamamlanmış ve Doğrudan Temin Arama Sayfası ekap.kik.gov.tr adresinde "İhale İşlemleri" menüsü altında erişime açılmıştır. Geliştirme ile alımlara duyuru imkânı getirilmesinin yanı sıra, alıma ilişkin bilgilerin EKAP'a kayıt edilmesi ve sonuç bilgisinin gönderilmesine ilişkin işlemler de sadeleştirilmiştir.

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların duyurulması idarelerin takdirinde olup söz konusu alımlar duyuru yapılmaksızın da neticelendirilebilecektir.

Doğrudan Temin Alımlarının İlanı



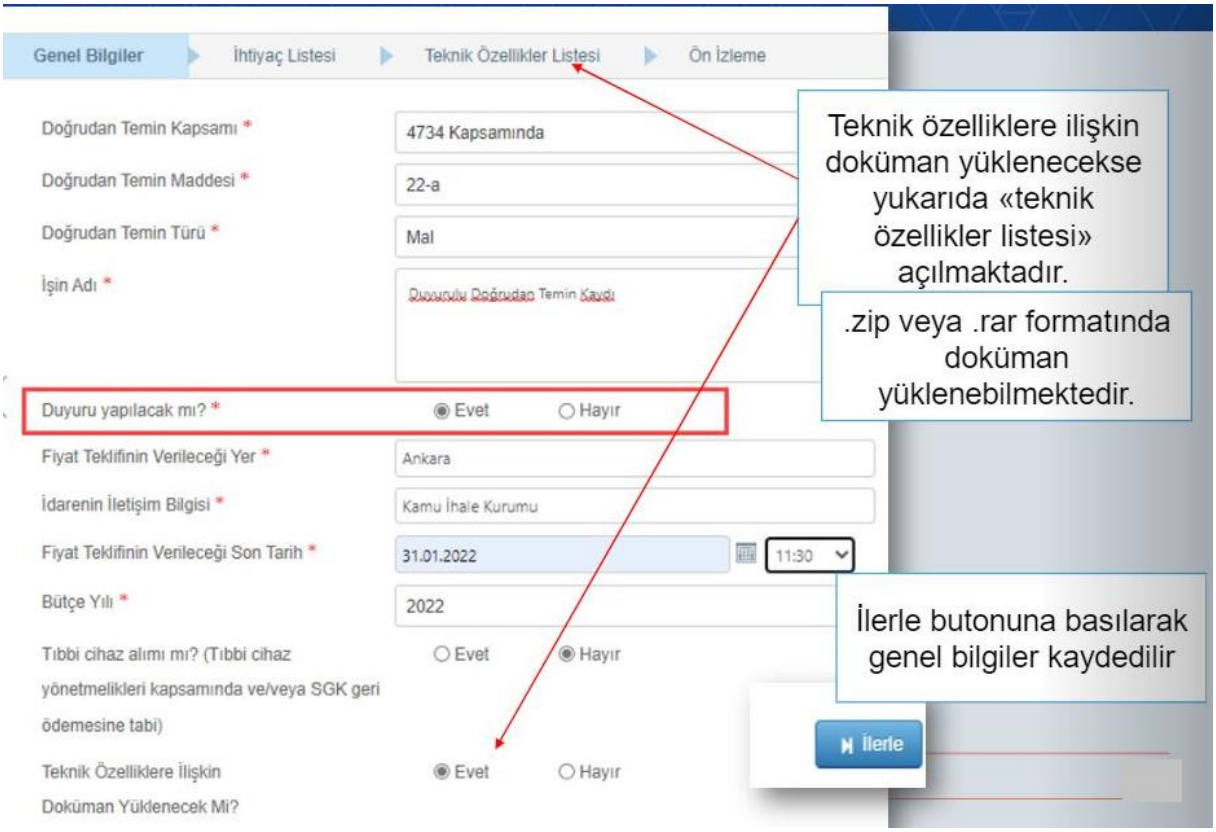

Doğrudan Temin Kaydı
ekap Test İdaresi
MİNE NURAY
İhale Öncesi
Teklif İşlemleri
Teminat İşlemleri
Sözleşme Öncesi
Sonuç İşlemleri
Sözleşme Uygulamaları
Doğrudan Temin
Tebligat İşlemleri
Doğrudan Temin Bilgi Girişi
Doğrudan Temin Kayıt
Doğrudan Temin İşlemleri
Doğrudan Temin Kümülatif Bilgileri
Doğrudan Temin Kayıt menüsü seçilir.


Doğrudan Temin Kayıt
Genel Bilgiler
İhtiyaç Listesi
Teknik Özellikler Listesi
Ön İzleme
Doğrudan Temin Kapsamı *
Seçiniz
Doğrudan Temin Maddesi *
Seçiniz
Doğrudan Temin Türü *
Seçiniz
İşin Adı *
Duyuru yapılacak mı? *
Evet
Hayır
Fiyat Teklifinin Verileceği Yer *
İdarenin İletişim Bilgisi *
Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarih *
Seçiniz
Bütçe Yılı *
2022
Tıbbi cihaz alımı mı? (Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi)
Evet
Hayır
Teknik Özelliklere İlişkin Doküman Yüklenecek Mi?
Evet
Hayır

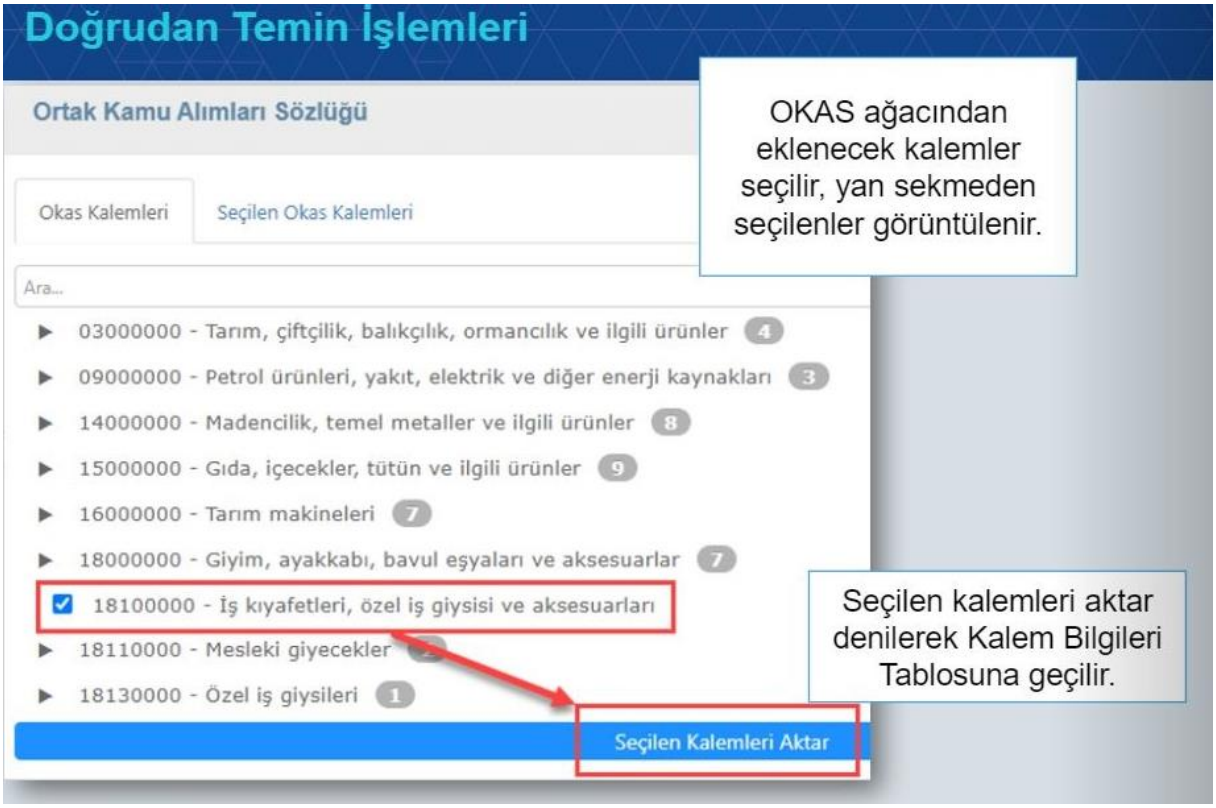
Doğrudan Temin 2 farklı şekilde kaydedilebilmektedir. Bunlar;

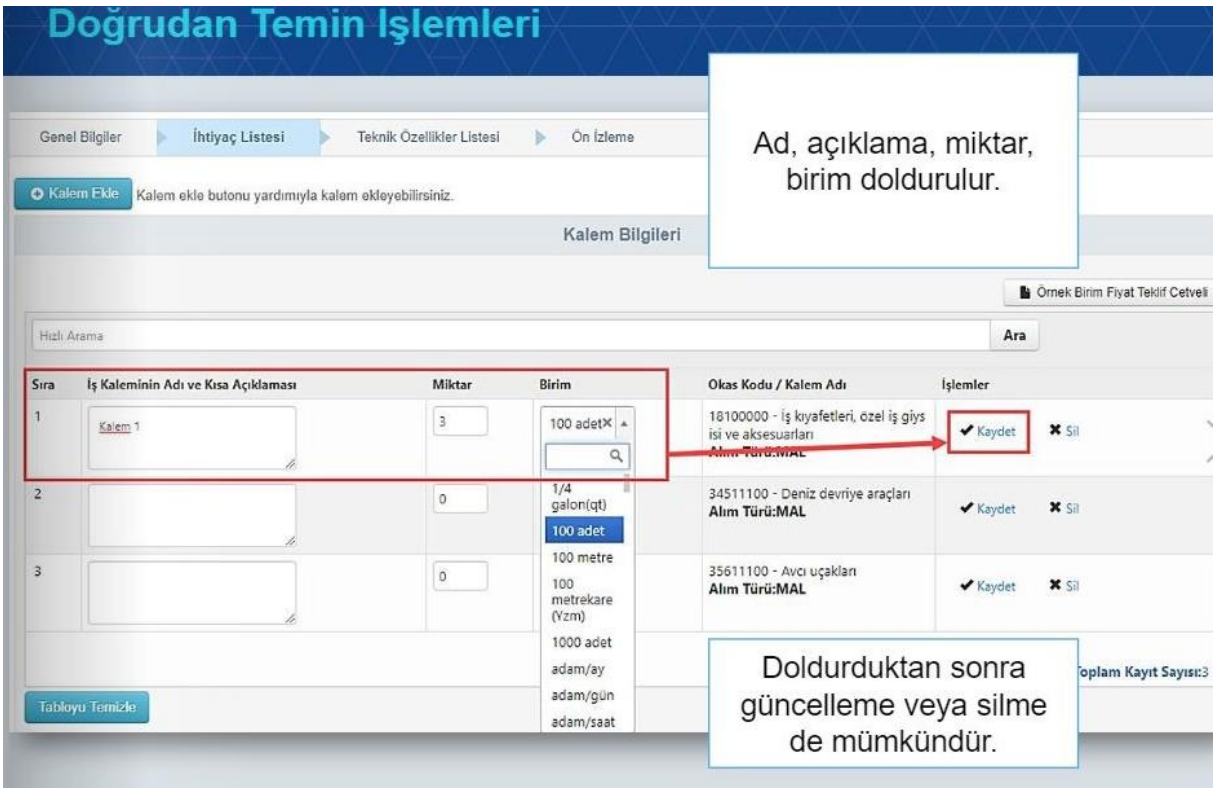
- Duyurulu Doğrudan Temin
  süreç tamamlanmamış ve teklif alınması planlanan doğrudan temin
- Duyurusuz Doğrudan Temin
  alımı tamamlanmış ve teklif alınmayacak doğrudan temin için.

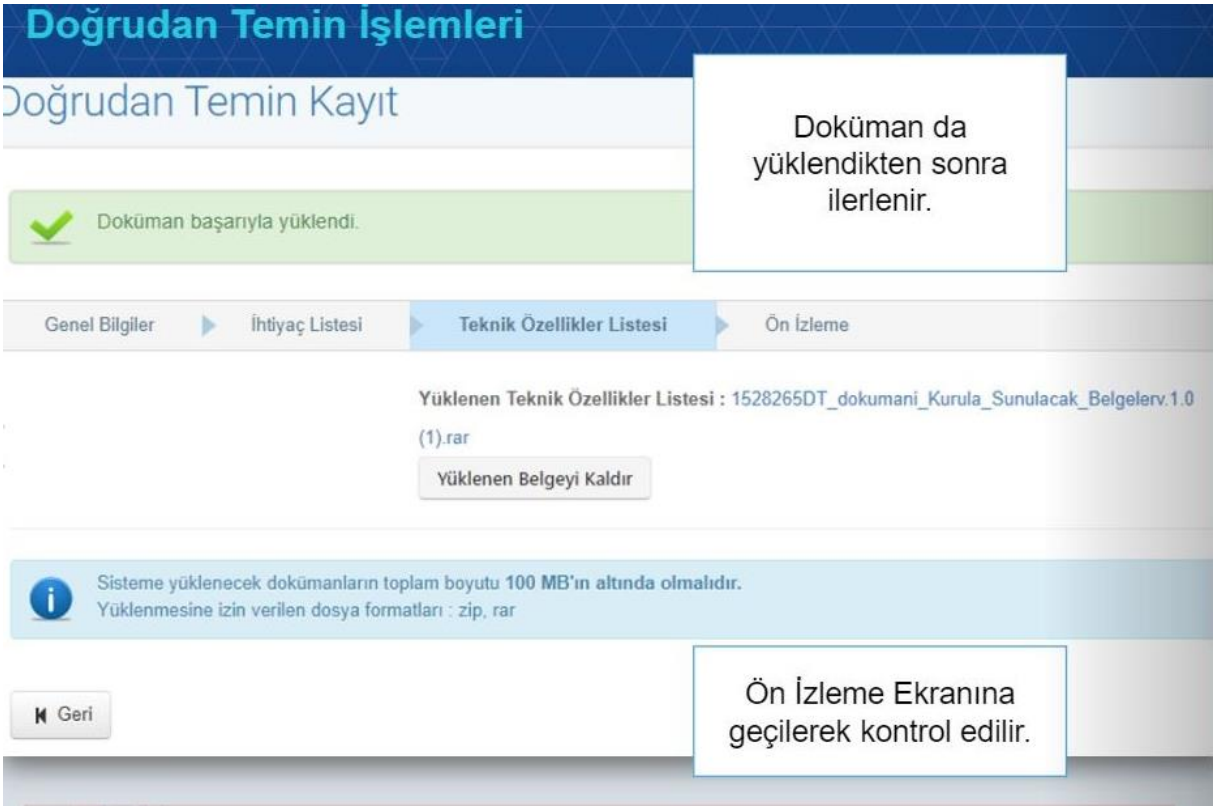
Kamu İhale Genel Tebliği md 30.9.2
«Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar "Doğrudan Temin Kayıt Formu" doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınır.»

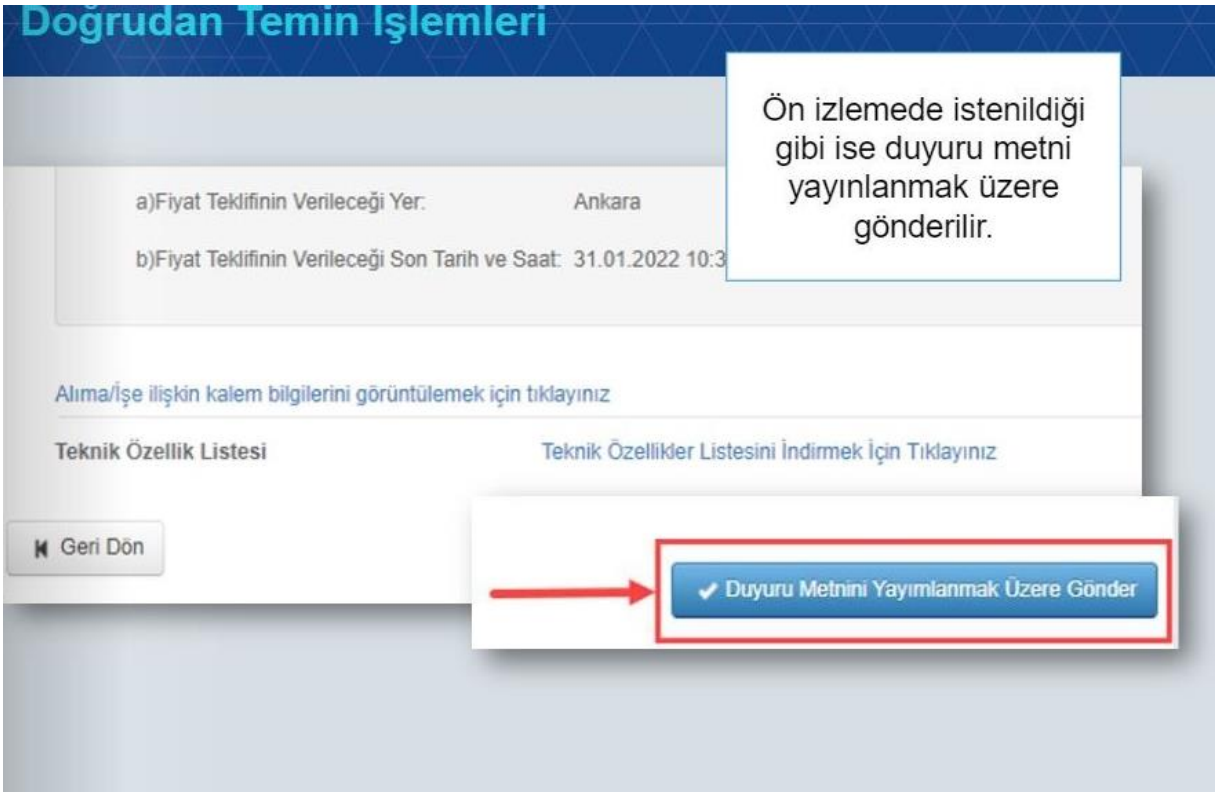


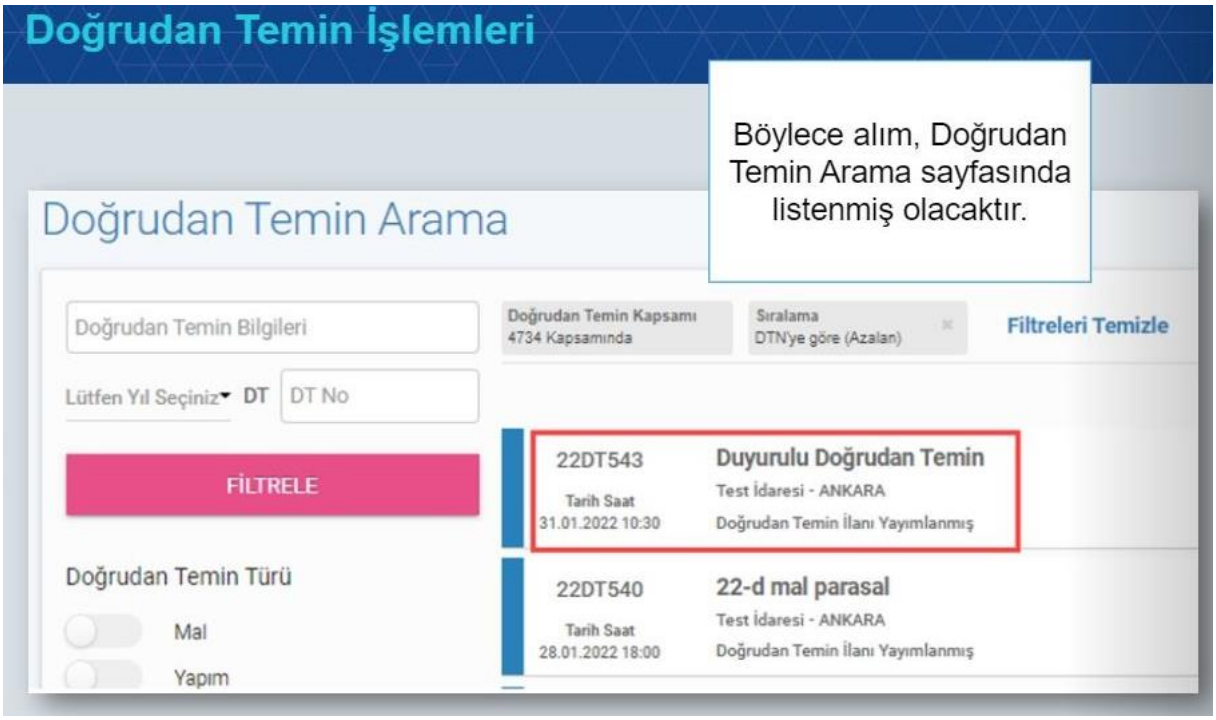

Doğrudan Temin İşlemleri
DTN 22DT504
Doğrudan Temin Kapsamı 4734 Kapsamında
Doğrudan Temin Maddesi 22-a
Doğrudan Temin Türü Mal
İşin Adı Duyurulu Do
Duyuru Yapılacak Mı? Evet
Fiyat Teklifin Verileceği Yer Ankara
İdarenin İletişim Bilgisi Kamu İhale K
Son Teklif Tarihi 31.01.2022 11
Bütçe Yılı 2022
Tıbbi Cihaz Alımı mı? Hayır
Teknik Özelliklere İlişkin Doküman Yüklenecek Mi? Evet
Doğrudan Temin Kayıt
Genel Bilgiler
İhtiyaç Listesi
Teknik Özellikler Listesi
Kalem Ekle
Kalem ekle butonu yardımıyla kalem ekleyebilirsiniz.
Geri
Genel bilgiler kaydedildikten sonra değişiklik yapılamaz.
Kalem ekle butonuna basılarak kalem bilgileri girilir.

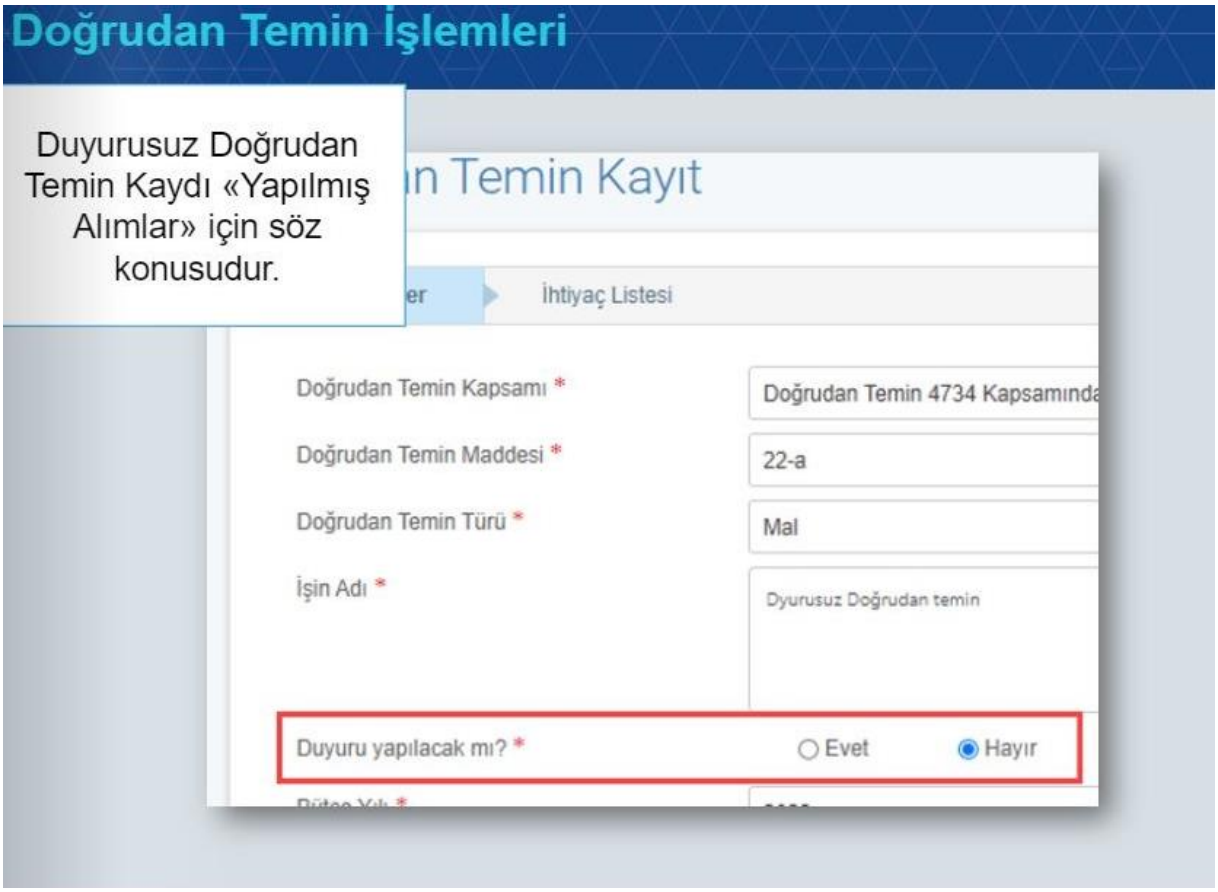

Doğrudan Temin İşlemleri
Ortak Kamu Alımları Sözlüğü
Okas Kalemleri
Seçilen Okas Kalemleri
Ara...
03000000 - Tarım, çiftçilik, balıkçılık, ormancılık ve ilgili ürünler 4
09000000 - Petrol ürünleri, yakıt, elektrik ve diğer enerji kaynakları 3
14000000 - Madencilik, temel metaller ve ilgili ürünler 8
15000000 - Gıda, içecekler, tütün ve ilgili ürünler 9
16000000 - Tarım makineleri 7
18000000 - Giyim, ayakkabı, bavul eşyaları ve aksesuarlar 7
18100000 - İş kıyafetleri, özel iş giysisi ve aksesuarları
18110000 - Mesleki giyecekler
18130000 - Özel iş giysileri 1
Seçilen Kalemleri Aktar
OKAS ağacından eklenecek kalemler seçilir, yan sekmeden seçilenler görüntülenir.
Seçilen kalemleri aktar denilerek Kalem Bilgileri Tablosuna geçilir.

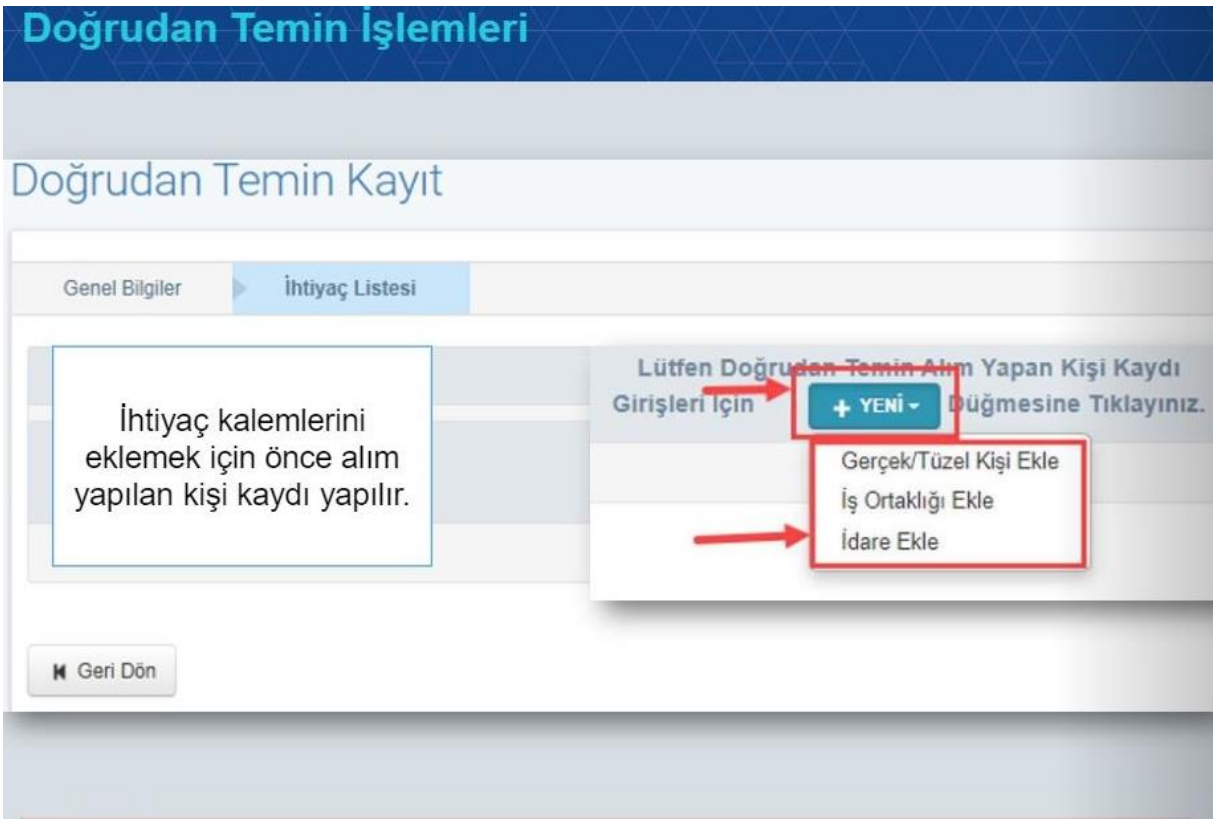

Doğrudan Temin İşlemleri
Genel Bilgiler
İhtiyaç Listesi
Teknik Özellikler Listesi
Ön İzleme
Kalem Ekle
Kalem ekle butonu yardımıyla kalem ekleyebilirsiniz.
Kalem Bilgileri
Örnek Birim Fiyat Teklif Cetveli
Hızlı Arama
Ara
Sıra
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Miktar
Birim
Okas Kodu / Kalem Adı
İşlemler
Kalem 1
100 adet
18100000 - İş kıyafetleri, özel iş giysisi ve aksesuarları
Alım Türü:MAL
Kaydet
Sil
1/4 galon(qt)
100 adet
100 metre
100 metrekare (Yzm)
1000 adet
adam/ay
adam/gün
adam/saat
34511100 - Deniz devriye araçları
Alım Türü:MAL
35611100 - Avcı uçakları
Alım Türü:MAL
Tabloyu Temizle
Ad, açıklama, miktar, birim doldurulur.
Doldurduktan sonra güncelleme veya silme de mümkündür.

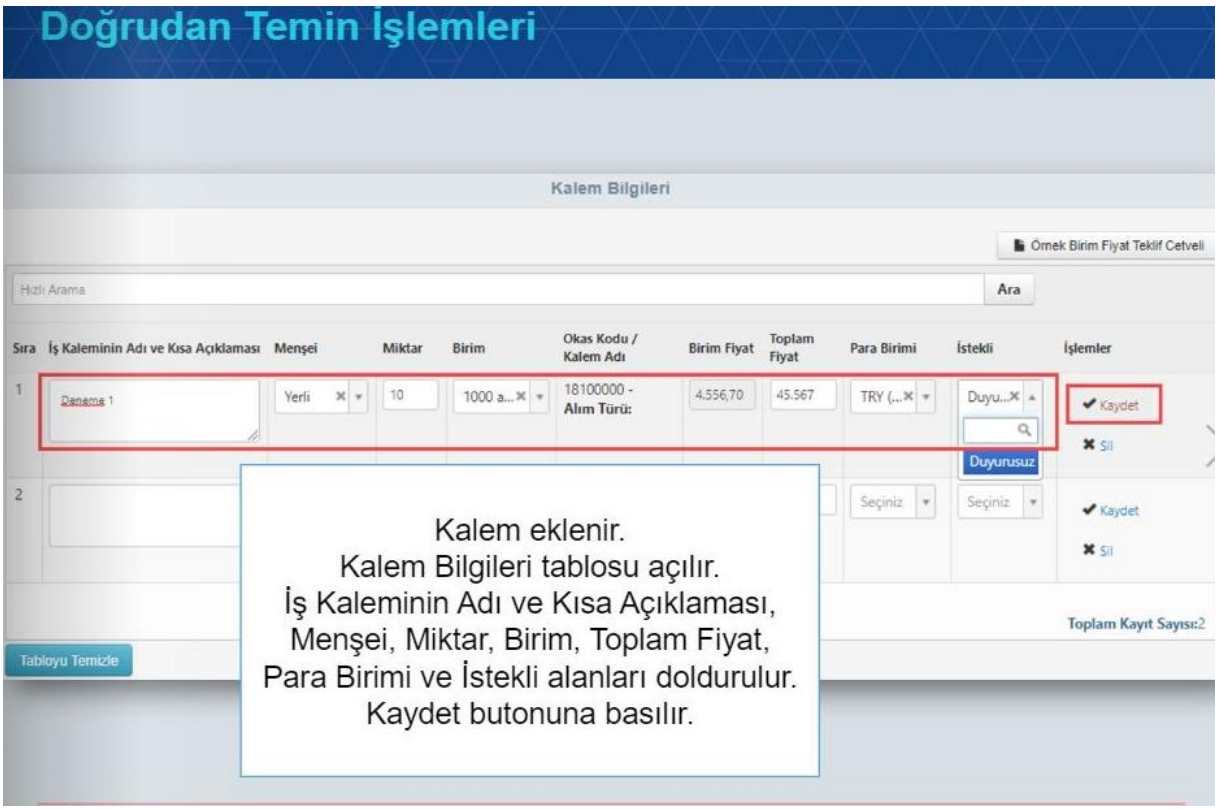

Doğrudan Temin İşlemleri
Doğrudan Temin Kayıt
Doküman başarıyla yüklendi.
Doküman da yüklendikten sonra ilerlenir.
Genel Bilgiler
İhtiyaç Listesi
Teknik Özellikler Listesi
Ön İzleme
Yüklenen Teknik Özellikler Listesi : 1528265DT_dokumani_Kurula_Sunulacak_Belgelerv.1.0 (1).rar
Yüklenen Belgeyi Kaldır
Sisteme yüklenecek dokümanların toplam boyutu 100 MB'ın altında olmalıdır.
Yüklenmesine izin verilen dosya formatları : zip, rar
Geri
Ön İzleme Ekranına geçilerek kontrol edilir.

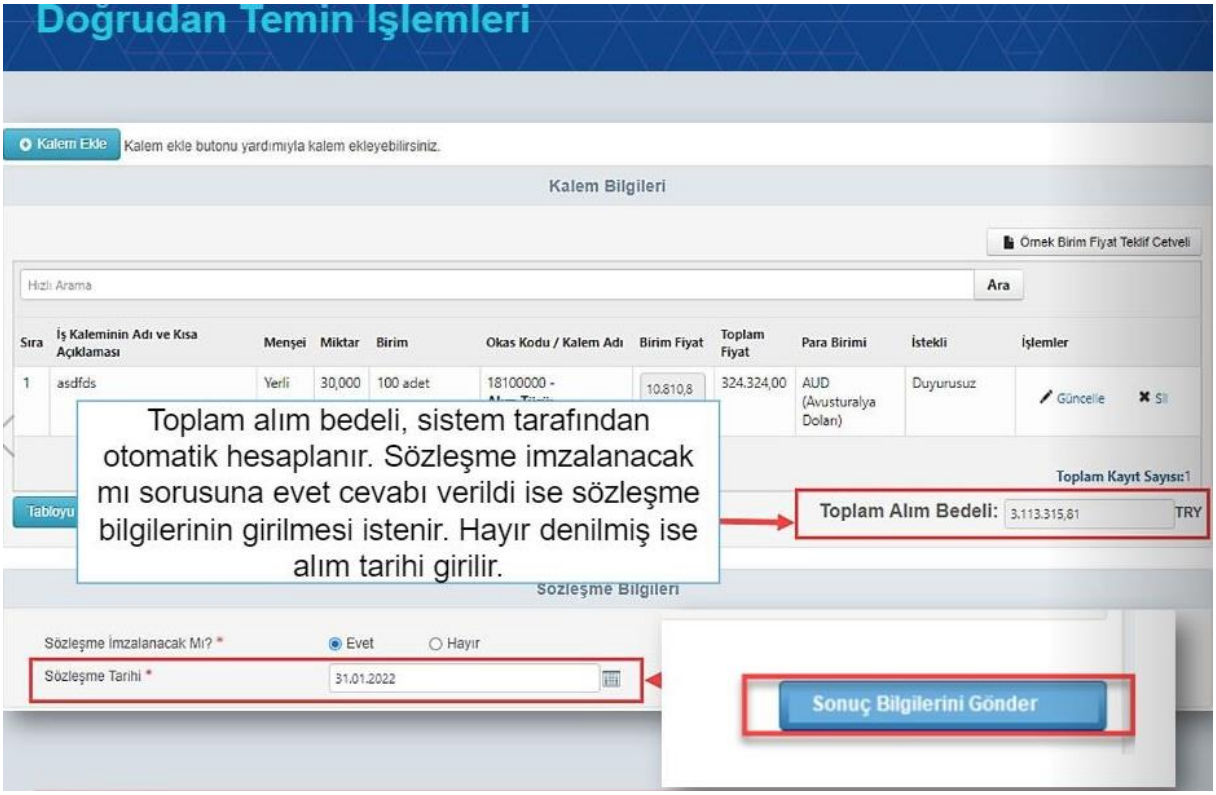

Doğrudan Temin İşlemleri
Ön izlemede istenildiği gibi ise duyuru metni yayınlanmak üzere gönderilir.
a)Fiyat Teklifinin Verileceği Yer: Ankara
b)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarih ve Saat: 31.01.2022 10:3
Alıma/İşe ilişkin kalem bilgilerini görüntülemek için tıklayınız
Teknik Özellik Listesi
Teknik Özellikler Listesini İndirmek İçin Tıklayınız
Geri Dön
Duyuru Metnini Yayımlanmak Üzere Gönder


Doğrudan Temin İşlemleri
Böylece alım, Doğrudan Temin Arama sayfasında listenmiş olacaktır.
Doğrudan Temin Arama
Doğrudan Temin Bilgileri
Doğrudan Temin Kapsamı
4734 Kapsamında
Sıralama
DTN'ye göre (Azalan)
Filtreleri Temizle
Lütfen Yıl Seçiniz
DT
DT No
FİLTRELE
Doğrudan Temin Türü
Mal
Yapım
22DT543
Tarih Saat
31.01.2022 10:30
Duyurulu Doğrudan Temin
Test İdaresi - ANKARA
Doğrudan Temin İlanı Yayımlanmış
22DT540
Tarih Saat
28.01.2022 18:00
22-d mal parasal
Test İdaresi - ANKARA
Doğrudan Temin İlanı Yayımlanmış

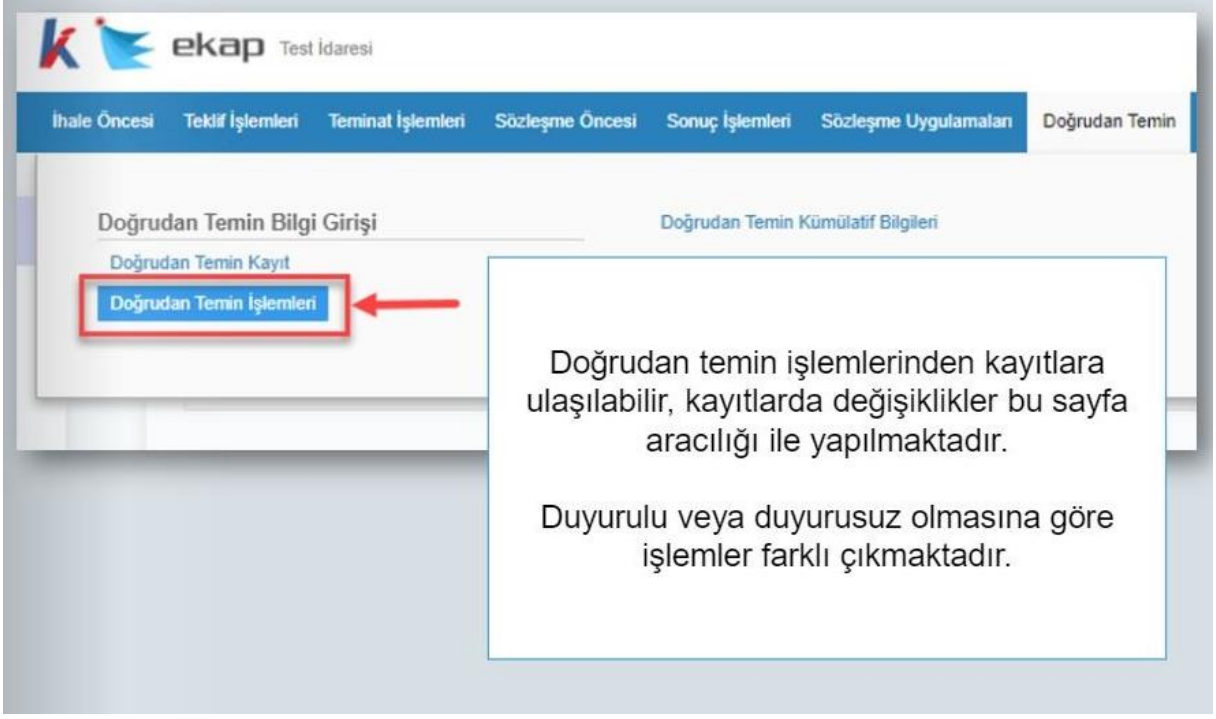

Doğrudan Temin İşlemleri
Duyurusuz Doğrudan Temin Kaydı «Yapılmış Alımlar» için söz konusudur.
Temin Kayıt
İhtiyaç Listesi
Doğrudan Temin Kapsamı *
Doğrudan Temin 4734 Kapsamında
Doğrudan Temin Maddesi *
22-a
Doğrudan Temin Türü *
Mal
İşin Adı *
Dyurusuz Doğrudan temin
Duyuru yapılacak mı? *
Evet
Hayır


Doğrudan Temin İşlemleri
Doğrudan Temin Kayıt
Genel Bilgiler
İhtiyaç Listesi
İhtiyaç kalemlerini eklemek için önce alım yapılan kişi kaydı yapılır.
Lütfen Doğrudan Temin Alım Yapan Kişi Kaydı Girişleri İçin
YENİ
Düğmesine Tıklayınız.
Gerçek/Tüzel Kişi Ekle
İş Ortaklığı Ekle
İdare Ekle
Geri Dön


Doğrudan Temin İşlemleri
Kalem Bilgileri
Örnek Birim Fiyat Teklif Cetveli
Hızlı Arama
Ara
Sıra
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Menşei
Miktar
Birim
Okas Kodu / Kalem Adı
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
Para Birimi
İstekli
İşlemler
Kaydet
Sil
Duyurusuz
Seçiniz
Toplam Kayıt Sayısı:2
Tabloyu Temizle
Kalem eklenir.
Kalem Bilgileri tablosu açılır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması,
Menşei, Miktar, Birim, Toplam Fiyat,
Para Birimi ve İstekli alanları doldurulur.
Kaydet butonuna basılır.


Doğrudan Temin İşlemleri
Kalem Ekle
Kalem ekle butonu yardımıyla kalem ekleyebilirsiniz.
Kalem Bilgileri
Örnek Birim Fiyat Teklif Cetveli
Hızlı Arama
Ara
Sıra
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Menşei
Miktar
Birim
Okas Kodu / Kalem Adı
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
Para Birimi
İstekli
İşlemler
1
asdfds
Yerli
30,000
100 adet
10.810,8
324.324,00
AUD (Avusturalya Doları)
Duyurusuz
Güncelle
Sil
Toplam Kayıt Sayısı:1
Tabloyu
Toplam Alım Bedeli: 3.113.315,81 TRY
Toplam alım bedeli, sistem tarafından otomatik hesaplanır. Sözleşme imzalanacak mı sorusuna evet cevabı verildi ise sözleşme bilgilerinin girilmesi istenir. Hayır denilmiş ise alım tarihi girilir.
Sözleşme Bilgileri
Sözleşme İmzalanacak Mı? *
Evet
Hayır
Sözleşme Tarihi *
31.01.2022
Sonuç Bilgilerini Gönder

Doğrudan Temin İşlemleri



Doğrudan temin işlemlerinden kayıtlara ulaşılabilir, kayıtlarda değişiklikler bu sayfa aracılığı ile yapılmaktadır.

Duyurulu veya duyurusuz olmasına göre işlemler farklı çıkmaktadır.

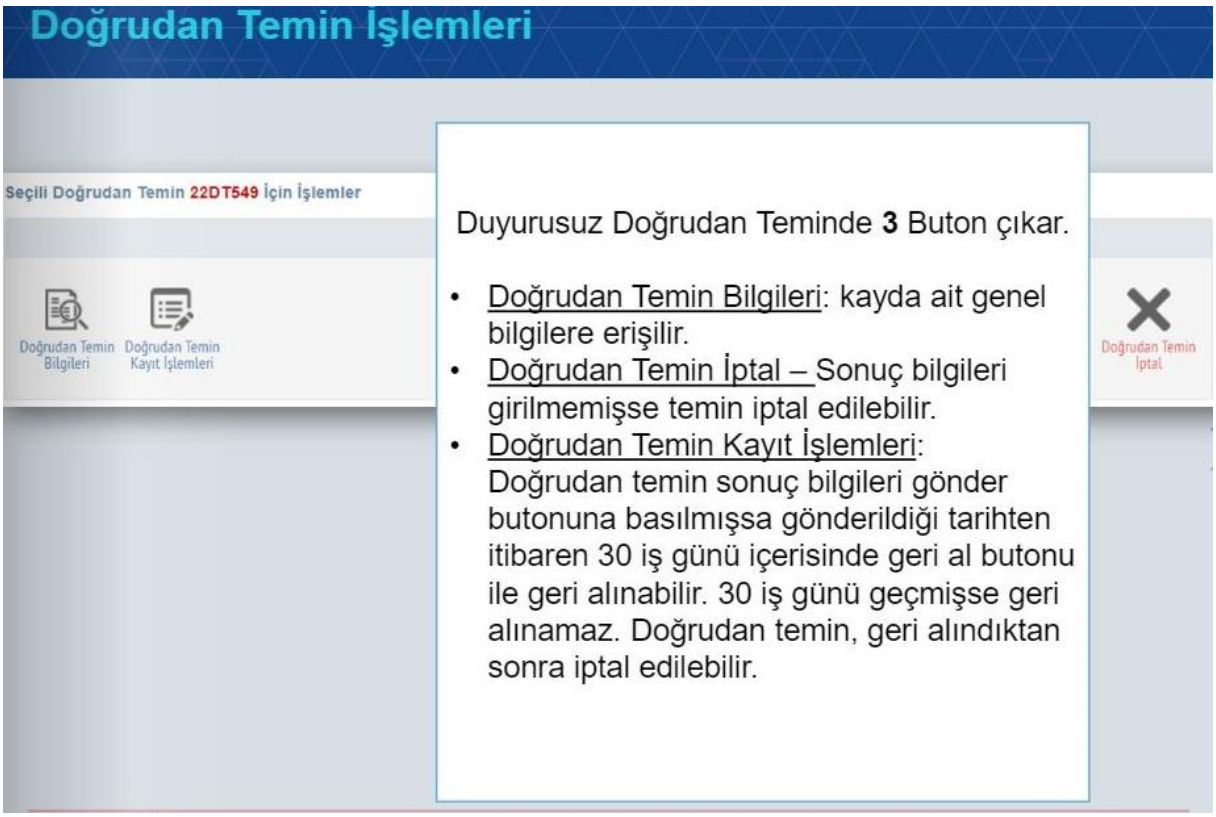
Doğrudan Temin İşlemleri



Duyurulu Doğrudan Teminde **4** Buton çıkar.

- Doğrudan Temin Bilgileri: kayda ait genel bilgilere erişilir.
- Teknik Özelliklere İlişkin Doküman İndir
- Doğrudan Temin İptal – Sonuç bilgileri girilmemişse temin iptal edilebilir.
- Sonuç Bilgilerini Kaydet: ilan edilmiş doğrudan temine ilişkin gerçekleşmeler kaydedilir. Kişi bilgileri girilir, kalem bilgileri güncellenerek alıma ilişkin bilgiler işlenir.

- Doğrudan temin sonuç bilgileri gönder butonuna basılmışsa gönderildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde geri al butonu ile geri alınabilir. 30 iş günü geçmişse geri alınamaz. Doğrudan temin, geri alındıktan sonra iptal edilebilir.


Doğrudan Temin İşlemleri
Seçili Doğrudan Temin 22DT549 İçin İşlemler
Doğrudan Temin Bilgileri
Doğrudan Temin Kayıt İşlemleri
Doğrudan Temin İptal
Duyurusuz Doğrudan Teminde 3 Buton çıkar.
• Doğrudan Temin Bilgileri: kayda ait genel bilgilere erişilir.
• Doğrudan Temin İptal – Sonuç bilgileri girilmemişse temin iptal edilebilir.
• Doğrudan Temin Kayıt İşlemleri: Doğrudan temin sonuç bilgileri gönder butonuna basılmışsa gönderildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde geri al butonu ile geri alınabilir. 30 iş günü geçmişse geri alınamaz. Doğrudan temin, geri alındıktan sonra iptal edilebilir.

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 -Bu Yönetmelik, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ilgili mevzuatları çerçevesinde yapacakları harcamalarında ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan şekil ve türleri bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik**,** 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri : 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini, (II) sayılı cetvelde sayılan özel bütçe kapsamındaki idareleri ve (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumları,

Ödeme belgesi: İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek numaralı Ödeme Emri Belgesini; ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem Fişini,

Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

Onay belgesi: İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım konusu işin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

Fatura: İş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden;

a)Faturayı,
b) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini,
c) Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan bu Yönetmelik eki 1 örnek numaralı Harcama Pusulasını,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi uyarınca düzenlenen muhasebe yetkilisi mutemetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri taşıyan alındıyı,
e)Yurtdışında yapılan iş ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde ise, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri,

Piyasa fiyat araştırması tutanağı: Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaralı tutanağı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kullanılacak Belgeler

Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler
Madde 5 - (Değişik fıkra:RG-5/11/2016-29879) Ödeme belgesi iki nüsha olarak Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Kanıtlayıcı belgeler ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır, ödeme belgesinin ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır.
Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. Kesin veya ön ödeme şeklinde yapılacak kamu harcamalarında ödeme belgesi olarak bağlanacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Kesin ödemelerde;
Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek numaralı Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.
b) Ön ödemelerde;
1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;
-Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,
-Gereken hallerde kredi izin yazısı;
2)Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda;
-Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,
-Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği,
-Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı,
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem Fişine
kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.
Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının bağlanması esastır. Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri bağlanmak suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir.
Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak

harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz .
(Ek fıkra:RG-5/11/2016-29879) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlere ilişkin belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasları, şekil hükümlerinden bağımsız olmak üzere belirlemeye yetkilidir.
Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Taahhüt dosyası
Madde 6 -İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı (Örnek:2) veya söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form, sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir. Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin (Değişik ibare:RG-5/11/2016-29879) birinci nüshasına bağlanır. Ancak, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan belgelerden taahhüt dosyası dışındaki belgeler bağlanır. taahhüt dosyasının onaylı sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklanır.

Hakediş raporu
Madde 7 –İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir.
a) Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3) : Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.
b) Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4) : Bu rapor, hizmet işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Hizmet türüne ve işin özelliğine göre yalnızca ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Yapılacak Kişiler

Ödemenin kimlere yapılacağı
Madde 8 –Ödeme; gerçek kişilerde alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine; alacaklının ölümü halinde varislere; tüzel kişilerde ise kanuni temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere; kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma yapılır.
Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:
a)Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğuna ilişkin noterce düzenlenmiş vekaletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği.
b) Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve çocukların (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numaraları; mahkemece tayin edilmiş velilere yapılacak ödemelerde mahkeme ilamı.
c) Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı.
d) Varislere yapılacak ödemelerde, veraset ilamı.
e) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, (Mülga ibare:RG-29/7/2021-31552)

ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge; bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmiş vekaletname.
f) Kayyımlara yapılacak ödemelerde, kayyım tayinine ilişkin mahkeme ilamı.
g) Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere alındı karşılığı yapılacak ödemelerde, dairesince verilmiş, ilgilinin tatbiki imzasını içeren yetki belgesi.
h) Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesi.
ı) Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının, harcama yetkililerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenmesinde Mutemet Görevlendirme Yazısı (Örnek : 5).
j) Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacakları ile kamu personeli olmayan kişilerin hizmetleri karşılığı gerçekleşen yolluk, ders ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti ve benzeri alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde, her ödemeyle ilgili Şahsi Mutemet Dilekçesi (Örnek: 6).
k) Kimliğinin saklı kalmasını isteyen muhbirlere mutemetleri aracılığıyla yapılacak ödemelerde, ilgili dairenin görevlendirme yazısı.
l) Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi (Hak sahipleri tarafından düzenlenen fatura üzerinde alacaklının banka hesap numarasının yer alması halinde ayrıca yazılı talepleri aranmaz).
Yukarıda sayılan belgelerden, (a), (b), (c), (d), (e), ve (f) bentlerinde belirtilenler Vekaletname/İlam Kayıt Defterine (Örnek :7) kaydedilerek muhasebe biriminde açılacak dosyada saklanır. İlgilinin durumu, her ödemeden önce kontrol edildikten sonra ödeme yapılır. Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere dairesince verilmiş yetki belgesi dışında, ödeme yapılacak kişileri belirleyen diğer belgeler ödeme belgesinin (Değişik ibare:RG-5/11/2016-29879) birinci nüshasına eklenir.
Bünyesinde tedavi kurumu bulunan kamu idarelerinin muhasebe birimlerince, tedavi bedeli karşılığı tahsil edilen paralardan iadesi gereken tutarların çeşitli nedenlerle hastaya ödenememesi halinde ödeme, tedavi bedelinin tahsili sırasında düzenlenen alındıda hasta dışında kimliği belirtilen diğer kişilere yapılır. Bu durumda ayrıca vekaletname aranmaz. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır.
Hazinenin veya diğer kamu idarelerinin aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak karşı taraf lehine hükme bağlanan mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin ibraz olunan ilamda adı yazılı taraf vekillerine ödenmesinde de vekaletname aranmaz.
Vekaletten veya temsilden azledilenler, azledenler tarafından muhasebe birimine yazılı olarak bildirilir. Vekalet veya temsilden azletme yazıları geldiğinde, Vekaletname/İlam Kayıt defterinin “açıklama” sütununa bu husus kaydedilerek, vekaletnamenin üzerine vekaletten azil yazısının tarih ve numarası yazılır.
Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının mutemetlere ödenmesine ilişkin görevlendirme yazıları**,** malî yılın ilk ayında ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir. Mutemet değişikliği halinde yeni mutemet ayrı bir görevlendirme yazısı ile muhasebe birimine bildirilir. Görevlendirme yazıları, muhasebe biriminde açılacak dosyalarda saklanır.

II KISIM
Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Personel Giderleri

Aylıklar
Madde 9 - Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu veya Yurtdışı Aylık Bordrosu (Örnek: 8 veya 8/A) ve Personel Bildirimi (Örnek: 9) ile duruma göre ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesine aşağıda belirtilen belgeler bağlanır.
a) İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı.

b) Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildirimi (Örnek:10); askeri personelin naklen atamalarında (10/A) örnek numaralı Ayrılış ve Katılış Bildirimi.
c) Terfilerde, terfi onayı (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.).
d) Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı.
e) Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı.
f) Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının ödenmesinde, harcama talimatı.
g) Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe başlama yazısı.
h) İkinci görev ödemelerinde, ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı.
ı) Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda, işe başlama yazısı.
Malî yılın ilk ayına ait ödemelerde, personelin kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösteren insan kaynakları birimince onaylı listenin ödeme belgesine bağlanması gerekir. Diğer aylarda ise durumunda değişiklik olanların listesi ödeme belgesine bağlanır.
(Değişik fıkra:RG-11/10/2017-30207) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muhtelif okullarından mezun olanların atama onayları, ikinci aya ait ödeme belgesine bağlanır.

Zam, tazminat ve benzeri ödemeler
Madde 10 - Kamu görevlilerine mevzuatları gereği yapılacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde aşağıda belirtilen belgeler ödeme belgesine bağlanır.
a) Yabancı dil tazminatı verilebilmesi için, yabancı dil sınav sonuç belgesi; gördükleri öğrenim nedeniyle yabancı dil bilgisinin tespitine gerek görülmeyenlerde ise insan kaynakları biriminin yazısı.
b)28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca yapılacak ödemede, ilgilinin uçuş ekibi kapsamında olduğuna ilişkin yetkili makamın onayı; uçuş ekibi dışında olup aynı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlere tazminat ödenmesinde, görevlendirme yazısı; yıpranma tazminatının ödenmesinde, bakan onayı; şehitlik tazminatının ödenmesinde, yetkili makamın onayı; sakatlık tazminatının ödenmesinde, yetkili makamın onayı ve sakatlık derecesini gösterir rapor.
c) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 18/1/1993 tarihli ve 21469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca yaralanma, sakatlanma veya ölüm halinde nakdi tazminat ödenmesinde, yetkili makamlarca onanmış nakdi tazminat komisyon kararı.
d)13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca sıkıyönetim hizmet zammının ödenmesinde, görevlendirme onayı ile Sıkıyönetim Hizmet Zammı Bordrosu (Örnek : 11).
e)14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile aktif istihbarat görevlilerine verilen ek tazminatların ödenmesinde, Başbakan onayı.
f)28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca ödenecek tazminatlarda, Uçuş, Dalış ve Atlayış Hizmetleri Tazminatı Bordrosu (Örnek : 12).
g)Yukarıdaki bentlerde sayılanların dışında özel mevzuatları gereğince yapılacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde, ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı.
Yukarıda (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yabancı dil sınav sonuç belgesi, onay, yazı ve raporun her malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.
Aylıklarla birlikte ödenen tazminatlar Aylık Bordrosunda; aylıklarla ödenmeyen tazminatlar ise özel bordrosunda veya Çeşitli Ödemeler Bordrosunda (Örnek : 13) gösterilir.
İş riski, iş güçlüğü, malî sorumluluk tazminatı ve eleman teminindeki güçlük zammı ile özel hizmet tazminatlarına ilişkin ana cetvel ve dağılım listelerinin, mali hizmetler birimince onaylandığı ayı izleyen aya ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Başbakan ve bakan ödenekleri
Madde 11-9/10/1984 tarihli ve 3055 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun gereğince ödenmesi gereken başbakan ve bakanların temsil ödenekleri ile aylıklarla birlikte ödenmesi gereken diğer ödenekler Aylık Bordrosu (Örnek : 8) ile ödenir.

Sosyal yardımlar
Madde 12-Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Evlenme yardımı: Aile yardımı bildirimi (Örnek No: 14) ödeme belgesine bağlanır.
b) Aile yardımı : Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek : 14) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin (Değişik ibare:RG-5/11/2016-29879) birinci nüshasına eklenir.
c) Doğum yardımı : Doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır.
d) Ölüm yardımı : Ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır. Normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir.
e) Tayın bedeli :22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca tayın bedellerinin ödenmesinde, tayın bedelinin ilgili aya ait tutarının tespitini gösteren yazı.
f) Giyecek yardımı : Nakden verilmesi gereken giyecek yardımı veya dikiş bedeli ödemelerinde;
- İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı,
- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13),
- Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı,
ödeme belgesine bağlanır.

Ek çalışma karşılıkları
Madde 13 - Ek ders ve fazla çalışma ücretleri ile huzur hakkı ve toplantı ücretleri, konferans ücretleri ve diğer ek çalışma ücretlerinin ödenmesinde, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13) ile birlikte duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.
a) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde;
- Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15),
- Aylık karşılığı okutulacak dersin adı ve haftalık ders saati ile ek branş derslerinin adını ve haftalık ders saatini gösteren onay,
- Haftalık ders dağılım çizelgesi, ücretli ders saatlerinde değişiklik yapılması halinde ise değişikliğe ilişkin onay ve haftalık ders dağılım çizelgesi,
b) Eleman yetiştirilmek üzere açılan mesleki okullarda, eğitim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendirilenlerin ders ücretlerinin ödenmesinde;
- Görevlendirme onayı,
- Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15),
c) 10/11/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde;
- Yükseköğretim Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15/A),
- Her öğretim döneminin ilk ayında ders yükü dağılımını gösteren onay ve akademik takvim (Programda değişiklik halinde onay yeniden alınır.),
d) Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde;

- Saat başına ödenecek fazla çalışma ücretini gösterir onay,
- Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge,
e) Komisyon ve kurul üyelerinin huzur hakkı ve toplantı ücretlerinin ödenmesinde;
- İlgili mevzuatında belirtilmeyenler için ödenecek miktarın tespitine ilişkin yetkili makamın onay veya yazısı,
- Üyelerin ad-soyadlarını ve katıldıkları toplantı sayısını gösterir yetkili makamca onaylı liste,
f) Konferans ücretlerinin ödenmesinde;
- Verilecek konferansın sayısını ve her bir konferans için verilecek ücreti gösterir Harcama talimatı,
- Konferansın verildiğine ilişkin ilgili dairenin yazısı,
ödeme belgesine bağlanır.
Yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen onay ve akademik takvimin, her öğretim yılının ilk ders ücretine ilişkin ödeme belgesine; (d) ve (e) bentlerinde belirtilen onay veya yazının ise malî yılın ilk ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Ödül ve ikramiyeler
Madde 14 – Kamu personeline verilecek ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13) ile birlikte, aşağıda belirtilen belgeler aranır. Ancak 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerin ödenmesinde, Kaçak Eşya Müsadir İkramiyeleri Cetveli (Örnek: 16) düzenleneceğinden Çeşitli Ödemeler Bordrosu aranmaz.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca emsallerine göre başarılı görev yapan devlet memurlarına verilecek ödüllerde;
Bağlı veya ilgili bakan onayı; ilave olarak birer aylık daha ödül verilmesi gereken hallerde Başbakan onayı,
b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 7 Ağustos 1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği uyarınca verilecek ödüllerde;
Değerlendirme kurullarınca hazırlanan ve ödül ödeneğini idare eden makamın onayını içeren liste, değerlendirme kurullarından geçirilmeden ödül verilmesi halinde yetkili makamın onayı,
c) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerden;
1- Kaçak eşya ikramiyelerinin ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Değer tespit tutanağı,
- Kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği,
- Kaçak Eşya Müsadir İkramiyeleri Cetveli (Örnek: 16),
-Muhbirli yakalamalarda ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini belirten yazı,
2- Kaçak silah-mühimmat ikramiyelerinin ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Değer tespit tutanağı,
-Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiyelerinin ödenmesinde kamu davasının açıldığına ilişkin cumhuriyet savcılığı yazısı; ikinci dönem ikramiyelerinin ödenmesinde, kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği,
- Sahipsiz olarak yakalananlarda, kesinleşmiş zor alım kararının onaylı örneği,
- Kaçak Eşya Müsadir İkramiyeleri Cetveli (Örnek: 16),
-Muhbirli yakalamalarda ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini belirten yazı,
3- Uyuşturucu madde ikramiyelerinin ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Ekspertiz raporu,
-Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiyelerinin ödenmesinde kamu davasının açıldığına ilişkin cumhuriyet savcılığı yazısı; ikinci dönem ikramiyelerinin ödenmesinde, kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği,
- Sahipsiz olarak yakalananlarda, kesinleşmiş zor alım kararı veya onaylı örneği,

- Kaçak Eşya Müsadir İkramiyeleri Cetveli (Örnek: 16),
-Muhbirli yakalamalarda ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini belirten yazı,
d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca ödenecek mükafatlarda;
-İçişleri Bakanı onayını taşıyan seçim komisyonu kararı,
e) 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu uyarınca verilecek ikramiye ve prim ödemelerinde;

1- Suni tohumlama ikramiyelerinin ödenmesinde, ilgili bakanlığın onayını taşıyan merkez komisyonu kararı,
2- Suni tohumlama primlerinde;
- İlgili bakanlığın onayını taşıyan merkez komisyonu kararı,
- Prim miktarını gösterir cetvel,
f) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerde;
- Harcama talimatı,
- Bulunan varlığın takdir edilen bedelini gösteren yazı veya tutanak,
g) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca verilecek ikramiyelerde;
- Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan onayı,
- Hükmedilen para cezasının tahsil edildiğine ilişkin alındı,
h) 8/9/1971 tarihli ve 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ödüllerde;
- Ödül komisyonu kararı,
- İçişleri Bakanı onayı,
ı) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığının görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara verilecek ödüllerin ödenmesinde;
- Değerlendirme kurulu kararı,
- Mükafat veya ödülün miktarını belirleyen Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlığın müşterek kararı,
j) 25/6/1927 tarihli ve 1156 sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun uyarınca verilecek ikramiyelerde;
-İhbarın doğruluğunu ve verilecek ikramiye miktarını gösteren harcama talimatı,
k) 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun uyarınca;
1- Menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde;
- Maliye Bakanı onayı,
- İhbar edilen malların veya bunların intifa hakkının Hazineye ait olduğunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı veya tapu senedinin onaylı örneği,
- İhbar konusu malların rayiç değerlerini gösteren belge,
2- Daimi vergilerle ilgili ihbar konusu vergi ve cezaların kesin tahakkuk ve tahsilinde verilecek ikramiyelerde;
- Maliye Bakanı onayı,
-İhbar Sonucu Tespiti ve İkramiye Hesap Çizelgesi (Örnek : 17),
l) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Düzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca verilecek ödüllerde;
-Genelkurmay Başkanın yazısı,
m) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile teknik direktör ve antrenörlerine verilecek ödüllerde;
-Mevzuatında belirtilen hallere göre ilgili bakanın veya genel müdürün onayı,

n) Kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği teşvik ödülü, hizmet armağanı, taltif ikramiyesi ve benzeri adlarla personeline vereceği diğer ödüllerin ödenmesinde;
-İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı,
ödeme belgesine bağlanır.
Yukarıdaki bentlerde sayılan mevzuat gereğince kamu personeli olmayan kimselere verilecek ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde de bu madde hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli personel ücretleri
Madde 15– Sözleşmeli olarak istihdam edilen personel ücretlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
- Yurtiçinde, Aylık Bordrosu (Örnek:8) ve Personel Bildirimi (Örnek:9); dış temsilciliklerde istihdam edilen gerek Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, gerekse yabancı uyruklu sözleşmeli personel ücretlerinin ödenmesinde ise Yurtdışı Sözleşmeli Personel Ücret Bordrosu (Örnek: 18),
- İşe başlama yazısı,
- Sözleşme,
ödeme belgesine bağlanır.
Sözleşmeli personele, sözleşmelerine göre ödenecek tazminat, sosyal yardım, ek çalışma ve diğer ödemelerde, ödemenin çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır.
Sözleşme ve işe başlama yazısının ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

İşçi ücretleri
Madde 16 –22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ücret ve ücretle birlikte her ay yapılacak ödemelerde ödemenin türüne göre aşağıdaki belgeler aranır.
a) Ücret ödemelerinde;
- Personel Bildirimi (Örnek : 9),
- İlk işe başlama, yer değiştirme ve terfilerde, İşçi Hareketleri Onayı (Örnek : 20),
- İşçi Ücret Bordrosu (Örnek : 19),
ödeme belgesine bağlanır.
İşçilerin fazla çalışma, ulusal bayram ve hafta tatili, genel tatil ile yıllık izin ücretlerinin ödenmesinde, ayrıca buna ilişkin onayın da aranması gerekir.
b) Evlenme, doğum ve ölüm yardımı ödemelerinde;
Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen belgeler ödeme belgesine bağlanır.
c) Giyecek yardımı ödemelerinde;
-Nakden yapılacak ödemelerde Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek:13), ödeme belgesine bağlanır.
d) Kıdem tazminatı ödemelerinde;
- Harcama talimatı,
- Hizmet cetveli,
- Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge,
- Askerlik borçlanması varsa buna ilişkin belge,
-Daha önce çalıştığı yerlerden ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadığını gösterir belge,
-Emekliye ayrılanlarda, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak emekliliği hakettiğine ilişkin belge,
ödeme belgesine bağlanır.
e) İhbar tazminatı ödemelerinde;
- Harcama talimatı,
- Hizmet cetveli,
- İhbar tazminatının hesaplanmasını gösteren belge,
ödeme belgesine bağlanır.
Sendikalarla yapılan toplu sözleşmenin onaylı iki nüshası, yapılacak ödemelere esas olmak üzere dönem başında muhasebe birimine verilir. (Değişik cümle:RG-5/11/2016-29879) Toplu sözleşmenin bir nüshası ödeme emri belgesinin birinci nüshasına eklenir.

Geçici personel giderleri

Madde 17 –Geçici personel giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.

a) 30 iş gününü aşmayan sürelerde ve vize alınmaksızın çalıştırılacak işçilerin ücretlerinin ödenmesinde;

- Harcama talimatı,
- İşçi Ücret Bordrosu (Örnek : 19),

ödeme belgesine bağlanır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/c maddesi veya özel mevzuatları gereğince sayım, propaganda, anket, canlı modellik ve benzeri geçici hizmetlerde istihdam edilen kısmi zamanlı çalışanların ücretleri ile aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenmesinde;

- Harcama talimatı,
- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),
- Gereken hallerde puantaj cetveli,

ödeme belgesine bağlanır.

c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca sigorta primlerinin ödenmesinde;

- Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi,
- Aday çırak, çırak veya öğrencilerin onaylı listesi,

ödeme belgesine bağlanır.

Er ve erbaş harçlıkları ve tayın bedelleri

Madde 18- Er ve erbaş harçlıkları ve tayın bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.

a) Er ve erbaş (Mülga ibare:RG-5/11/2016-29879) (...) harçlıklarının ödenmesinde, Er ve Erbaş Harçlıkları Özet Bordrosu (Örnek: 21),

b) Jandarma er ve erbaşlarının harçlıkları ve tayın bedellerinin avans olarak (Değişik ibare:RG-5/11/2016-29879) ödenmesi halinde, er ve erbaşların sayısı ile harçlık ve tayın bedeli tutarını gösteren yazı,

c) Söz konusu avansların mahsubunda ve kazandan iaşesi mümkün olmayan diğer er ve erbaşların harçlık ve tayın bedelleri ile ordu hemşire, ebe ve hastabakıcılarının tayın bedellerinin ödenmesinde;

- Er ve Erbaş Harçlıkları Dağıtım Bordrosu/Er,Erbaş ile Ordu Hemşire, Ebe ve Hastabakıcı Tayın Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek : 22),
- İlgili aya ait tayın bedeli tespitine ilişkin yazı,

d) Dinlenme ve hava değişimi alan er ve erbaşların tayın bedellerinin ödenmesinde;

- Tayın bedelinin miktarının tespitine ilişkin yazı,
-Sağlık kurulu raporu,

ödeme belgesine bağlanır.

Dinlenme ve hava değişimi alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporlarının zamanında düzenlenmemesi halinde hekim raporu veya hasta taburcu belgesi ödeme belgesine bağlanır. Ancak, daha sonra düzenlenen sağlık kurulu raporu, istenildiğinde ibraz edilmek üzere gideri gerçekleştiren harcama biriminde muhafaza edilir.

Öğrenim giderleri

Madde 19 - Öğrencilere yapılacak çeşitli giderlerin ödenmesinde aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Askeri öğrencilerin harçlıklarının ödenmesinde, Askeri Öğrenci Harçlıkları Bordrosu (Örnek : 23),

b) Dinlenme ve hava değişimi alan askeri öğrencilerin tayın bedellerinin ödenmesinde;

-Tayın bedelinin miktarının tespitine ilişkin yazı,
- Sağlık kurulu raporu,

Dinlenme ve hava değişimi alan askeri öğrencilerin sağlık kurulu raporlarının zamanında düzenlenmemesi halinde hekim raporu veya hasta taburcu belgesi ödeme belgesine bağlanır. Ancak, daha sonra düzenlenen sağlık kurulu raporu, istenildiğinde ibraz edilmek üzere gideri gerçekleştiren harcama biriminde muhafaza edilir.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun, 15/6/1989 tarihli ve 3580 sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun ve diğer mevzuat hükümleri gereğince ilgili bakanlık veya kurum bütçesinden ödenecek burs, harçlık, harç veya diğer sosyal yardımların ödenmesinde;
-Öğrenci Giderleri Bordrosu (Örnek : 24),
d)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve katkı kredisi ile burs giderlerinin ödenmesinde ;
-Harcama talimatı,
-Burs ve öğrenim kredilerinin ödenmesinde, banka şubeleri itibarıyla düzenlenecek ve öğrenci başına ödenecek kredi miktarı ile öğrenci sayısını ve ödenecek toplam kredi tutarını gösteren, burs ve kredi hizmetlerini yürüten birimce onaylı liste; katkı kredilerinin ödenmesinde, her bir üniversiteye ödenecek toplam katkı miktarını gösteren, kredi hizmetlerini yürüten birimce onaylı liste,
e) Öğrenciler tarafından yapılan kitap, kırtasiye ve benzeri giderler ile harç tutarlarının kendilerine ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Fatura, (Kitap ve kırtasiye giderlerine ilişkin fatura muhteviyatının öğrenim için zorunlu olduğunun ilgili okul idaresince onanması gerekir.)
f) 11/7/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu ve 30/10/1983 tarihli ve 18206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği uyarınca, parasız yatılı öğrencilerin Devletçe karşılanacak pansiyon ücretlerinin pansiyon hesabına aktarılmasında;
- Öğrencilerin adları ile her birine ait ücret miktarını gösterir okul idaresince düzenlenen onaylı cetvel,
g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve diğer kanun hükümlerine tabi personel çocuklarının pansiyon ücretlerinden indirilen ve Devletçe karşılanması gereken miktarların ödenmesinde;
- Öğrencilerin ad ve soyadlarını, velilerinin memuriyet unvanlarını, her biri için yapılan indirim oranını ve taksit miktarlarını gösteren okul idaresince onaylı liste,
h) Yapılan anlaşmalar gereği yurtiçi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin burslarının ödenmesinde;
- Verilecek burs tutarını ve diğer ödemelerin miktarını gösteren onay,
- Malî yılın ilk ödemesinde, yapılan anlaşmanın onaylı bir örneği,
- Yabancı Uyruklu Öğrenciler Burs Giderleri Bordrosu (Örnek : 25),
ı) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurtdışında lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrencilere aylık, yolluk ve diğer ödemelerde;
- Harcama talimatı,
-Yurtdışı Öğrenci Giderleri Bordrosu (Örnek : 25/A),
- Gönderilen kişinin ilgili ülkeye varış tarihini belirten belge,
ödeme belgesine bağlanır.
Belgelendirilmesi gereken diğer ödemelerde, harcama talimatı ile birlikte harcamaya ilişkin fatura, sigorta poliçesi veya diğer belgelerin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.Gereken hallerde bakan onayı da aranır.
Yurtdışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların tercümelerinin, eğitim müşavirliği veya ataşeliğinin veya dış temsilciliğin onayını taşıması gerekir.
Öğrencilere burs, harçlık veya aylık gibi belirli dönemlerde yapılan ödemelerde buna ilişkin onayların, malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tedavi ve Cenaze Giderleri

Tedavi giderleri
Madde 20 – (Değişik:RG-22/7/2009-27296)
Eczanelere, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ve personele yapılacak ilaç ve ilaç mahiyetinde olmayan ve tedavi amacıyla kullanılan çeşitli protez ve ortez, cihaz ve malzeme bedelleri ile hizmet giderlerinin ödenmesinde aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Eczanelere yapılacak ödemelerde;
- Hastanın şevkine ilişkin belge,
- 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği kapsamında karekodlu ilaçlara ait reçete, kapsam dışındaki ilaçlar için ise ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının yapıştırılmış olduğu reçete,
- Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste,
- Fatura
ödeme belgesine bağlanır.
Güvenli elektronik imzalı reçeteleme uygulamasına geçilen yerlerde kanıtlayıcı belge olarak ayrıca reçete aranmaz. Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez. Ancak, kişiye verilen ilaçlar arasında karekodlu ilaç bulunması halinde karekodlu ilaçlar için liste düzenlenmesi ve bu listenin harcama birimi tarafından onaylanması zorunludur.
Eczane ile her mali yılda yapılan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince açılacak dosyada saklanır.
b) Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde;
- Hastanın sevkine ilişkin belge,
- Tıbbi malzemeye ilişkin reçete ile Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği kapsamında karekodlu ilaçlara ait reçete, kapsam dışındaki ilaçlar için ise ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının yapıştırılmış olduğu reçete,
- Fatura
ödeme belgesine bağlanır.
Güvenli elektronik imzalı reçeteleme uygulamasına geçilen yerlerde kanıtlayıcı belge olarak ayrıca reçete aranmaz.
Yurtdışından getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturanın temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas alınır. Bunlar da yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.
c) Sağlık Bakanlığınca onaylanan şahsi reçeteler kapsamında ihtiyaç duyulan ilaçların Türk Eczacılar Birliği tarafından ithal edilerek kişiye teslim edilmesi halinde, ilaç bedellerinin Türk Eczacılar Birliğine ödenmesinde;
- Hastanın sevkine ilişkin belge,
- Reçete,
- Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste,
- Fatura
ödeme belgesine bağlanır.
Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.
d) Resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde;
- Hastanın sevkine ilişkin belge,
- Fatura,
- Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz)
ödeme belgesine bağlanır.

Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir liste de aranır.
Yurtdışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunların tercümelerinin misyon şefliğinin veya ihtisas biriminin onayını taşıması gerekir.
Mevzuatı gereğince hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde raporun da ödeme belgesine bağlanması gerekir.
Subay, askerî memur ve astsubaylarla bunların emeklilerinin ve aile efradının tedavi giderlerinin ödenmesinde, 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin sağlık işleri bölümünde belirtilen belgeler aranır.
Personelin tedavi hizmetlerinden yararlanan aile fertlerinin tedavi giderlerinin ödenmesinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen hasta sevkine ilişkin belge aranmaz.

Cenaze giderleri
Madde 21- Cenaze giderlerinin ödenmesinde;
a) Cenaze, sağlık kurum ve kuruluşu veya belediyece kaldırıldığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya belediyece düzenlenen fatura,
b) Cenaze, personelin bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir personel veya ailesi ya da yakınları tarafından kaldırıldığı takdirde, yapılan masraflara ilişkin fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi,
ödeme belgesine bağlanır.
Cenazenin başka bir yere nakli gerektiği takdirde, nakil ve defin giderleri yukarıdaki esaslara göre ödenir.
Yurtdışında ölenlerden cenazeleri yurda getirilenlerin, yurtdışında yapılan giderlerine ait belgelerin tercümelerinin ve mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliği veya ihtisas birimi tarafından onaylanması gerekir.
Subay, askeri memur ve astsubaylarla bunların emeklilerinin ve aile efradının cenaze giderlerinin ödenmesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin sağlık işleri bölümünde belirtilen belgeler aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yolluklar

Yurtiçi geçici görev yolluğu
Madde 22 - Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.
a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;
- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),
-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,
ödeme belgesine bağlanır.
b) Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;
- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 27),
- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,
- Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu,
ödeme belgesine bağlanır.

Yurtiçi sürekli görev yolluğu
Madde 23 –Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;
- Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,

- Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),
- Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli,
ödeme belgesine bağlanır.
Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır.

Yolluk karşılığı verilen tazminatlar
Madde 24 - Yolluk karşılığı verilen tazminatlar ile seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapanların tazminatlarının ödenmesinde;
- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),
- Mali hizmetler birimince onaylı, seyyar görev dağılım listesi,
b) Fiilen arazi üzerinde çalışanların tazminatlarının ödenmesinde;
- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),
c) Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde;
- İlgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay,
- Taşıt işleten kuruma ait fatura,
- Mali hizmetler birimince onaylı, seyahat kartı verilecek personel listesi,
ödeme belgesine bağlanır.
Seyyar görev dağılım listesi ile seyahat kartı verilecek personel listesinin mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Yurtdışı geçici görev yolluğu
Madde 25-Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde;
- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
- Yurtiçi **/** Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),
- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura,
ödeme belgesine bağlanır.
Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Yurtdışı sürekli görev yolluğu
Madde 26- Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;
- Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,
- Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),
ödeme belgesine bağlanır.

Yolluklara ilişkin diğer hükümler
Madde 27- Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde;
a)Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun,
b)Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince

imzalanan belgenin,
c)Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin,
d) Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının; sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayının,
e) Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin,
f) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak belgenin,
g) Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin,
h) Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin,
i) Yurtiçi veya yurtdışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulunduğu yer dışındaki bir tedavi kurumuna sevk edildiğine veya yurtdışında tedavisinin gerekli olduğuna ilişkin belgenin (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli olduğu hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.), ödeme belgesine bağlanması gerekir.
Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek : 29) düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri

Bey'iye aidatı ödemeleri
Madde 28- Bayilere yapılacak bey'iye aidatı (satış aidatı) ödemelerinde, satılmak üzere verilen değerli kağıtlara ilişkin alındıların tarihi, sayısı ve tutarlarını gösteren, muhasebe birimince onaylı liste ödeme belgesine bağlanır.

Mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç ödemeleri
Madde 29 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/11/2016-29879)
Mahkeme harç ve giderleri, icra harçları ile ilama bağlı borçların ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.
a) Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde;
- Mahkeme, icra dairesi veya noterce düzenlenen alındı,
- Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Başka yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalarda davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için bu liste daire amirince onaylanır.),
- Ödemenin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile ilişkili olarak elektronik ortamda gerçekleşmesi halinde; ödemeyi yapan idare, başvuru yapılan mahkeme veya icra dairesi, dosya no, yapılan ödemenin çeşidi ve tutarı bilgilerini içeren UYAP Bilişim Sisteminden veya UYAP Bilişim Sisteminin altyapısının kurulu olduğu yurt içinde yerleşik bankadan alınacak onaylı liste,
b) İlama bağlı borçlar, mahkeme ve icra harçları ile davacıya veya vekiline yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde;
- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,
-Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,
- Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı ve sulhname veya hakem kararı,

c) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 325 inci maddesi uyarınca yapılacak ödemelerde birinci fıkranın (a) bendinde istenen belgelere ilave olarak mahkeme kararı,
d) Hazineyi temsile yetkili görevlilere yapılacak yol tazminatı ödemelerinde;
- Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),
- (Ek:RG-11/10/2017-30207) Keşif işlemlerinde keşif zaptı, haciz işlemlerinde haciz tutanağı,
ödeme belgesine bağlanır.

Terör ve terörle mücadeleden doğan zarar ödemeleri
Madde 30 –17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca sulhen karşılanacak zararların nakden ödenmesinde;
-Ödenecek zararın miktarını belirleyen ve zarar tespit komisyonu başkanı ile alacaklı veya temsilcisi tarafından imzalanan sulhname,
-Valinin onayı veya gereken hallerde İçişleri Bakanının onayı,
ödeme belgesine bağlanır.

Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmet giderleri
Madde 31- Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmet giderleri 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen kararname esaslarına göre gerçekleştirilir.

Sigortalılara yapılacak tazminat ödemeleri
Madde 32 –Doğal Afet Sigortaları Kurumunca sigortalılara yapılacak tazminat ödemelerinde;
-Tapu senedinin onaylı örneği,
-Hasar tespitine ilişkin uzman raporu,
-Harcama talimatı,
ödeme belgesine bağlanır.

Vergi, resim , harç ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler
Madde 33 – İş veya mal veya hizmet satınalınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan; taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları ve benzeri giderler ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde;
- Harcama talimatı,
- Alındı,
ödeme belgesine bağlanır.

Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretleri
Madde 34-Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretlerinin ödenmesinde;
- Bakanlar Kurulu Kararı, mahkeme kararı, muhakkik kararı veya yetkili organların kararı,
- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13),
ödeme belgesine bağlanır.

Tarifeye bağlı ödemeler
Madde 35-Komisyon ücretleri ve kovuşturma giderleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki ilan, sigorta ile gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.
a) Komisyon ücretlerinin ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Fatura (Banka komisyon ücretlerinde dekont),
b) Kovuşturma giderlerinin ödenmesinde;

- Mahkeme kararı veya yetkili organların kararı,
- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13),
c) İlan giderlerinin ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Fatura,
-İlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla (gazete, radyo, televizyon ve benzeri araçlar) yapıldığına ilişkin yazı veya tutanak,
d) Sigorta giderlerinin ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Sigorta poliçesi veya zeyilname,
e)Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Fatura,
ödeme belgesine bağlanır.

Kurs ve toplantılara katılma giderleri
Madde 36- Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde;
- Görevlendirme yazısı,
- Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge,
- Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge,
ödeme belgesine bağlanır.
Yurtiçinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen dil kursları için idarece karşılanması gereken ders ücretlerinin ödenmesinde, görevlendirme yazısı yerine ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı aranır.
Görevlendirme yazısı veya yetkili makam onayının malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Seçim giderleri
Madde 37- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca, seçim kurulları başkan ve üyeleri ile görevlendirilecek memur, hizmetli, siyasi parti temsilcisi ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara görev mahalli içerisindeki çalışmaları için ödenecek ücretlerde;
- Harcama talimatı,
- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),
ödeme belgesine bağlanır.
Söz konusu Kanun uyarınca yapılacak satınalmalarda, Yönetmeliğin satınalmalara ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır.

Fahri konsolosluklar aidat ve giderleri
Madde 38- 9/12/1933 tarihli ve 2349 sayılı Kanun uyarınca fahri konsolosluklar aidat ve giderlerinin ödenmesinde;
- Aidatın hesabını ve yapılan harcamaların ayrıntısını gösteren fahri konsolosça düzenlenip bağlı bulunulan büyükelçilikçe tercüme ettirilen ve onaylanan liste,
- Dışişleri Bakanlığının onayı,
ödeme belgesine bağlanır.

Telif ve tercüme ücretleri
Madde 39- Telif ve tercüme giderlerinin ödenmesinde, harcamanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.
a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

hükümleri uyarınca yapılacak ödemeler:
1- Telif, işlenme (tercüme dahil) ve benzeri ücret ödemelerinde;
-Yetkili makamca onaylanmış ilgili yayın kurulu kararı,
- Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi (Örnek: 32),
- Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33 veya 33/A),
- Fatura,
2- İnceleme, redaksiyon, tashih veya koordinatörlük işlerinde görevlendirilecek kurum dışından ve memur olmayan uzmanlara yapılacak ücret ödemelerinde;
-Eserin inceleme, tashih, redaksiyon veya koordinatörlük hizmetine gerek görüldüğüne ve verilecek ücretin tespitine ilişkin yetkili makamın onayı,
- Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek:33),
- Fatura,
3- Yayın kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemelerinde;
- Harcama talimatı,
- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13),
4- Yarışma suretiyle sağlanacak eserlerle ilgili ödüllerin ödenmesinde;
- Yetkili makamın onayını taşıyan yayın kurulu kararı,
b) Kuruluşların özel yayın yönetmelikleri uyarınca yapılacak ödemelerde;
- Yayın komisyonu kararı,
- Sözleşme,
- Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33),
- Fatura,
c) Yazma ve Arap Harfli Basma Eserler ile Şer'i Sicillerin Künyelerinin Tespiti, Yabancı Dil ve Türkçe Eserlerin Katalog Fişlerinin Çıkartılması ve Şer'i Sicilleri Türkçeleştirme Ücret Yönetmeliği uyarınca yapılacak ödemelerde;
- Harcama talimatı,
- Sözü edilen Yönetmelik eki ücret ödeme fişi,
- Fatura,
d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak tercüme ücreti ödemelerinde;
- Taahhüt dosyası,
- Fatura,
- Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),
ödeme belgesine bağlanır.

Avukatlık hizmet bedelleri
Madde 40– (Değişik:RG-5/11/2016-29879)
Avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre hakkında dava açılan kişiler için tutulan avukat ücretlerinin ödenmesinde;
- İlgili makamın onayını taşıyan özel komisyon kararı,
- Fatura,
ödeme belgesine bağlanır.
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretleri ve diğer masraflarının ödenmesinde;
- İlgilinin beraat ettiğine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı,
- Dava ile ilgili yapılan masraflara ait fatura,
ödeme belgesine bağlanır.

c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca, terörle mücadelede görev alanlar için tutulan avukatlara yapılacak ücret ödemelerinde;
- İlgili makamın onayını taşıyan özel komisyon kararı,
- Fatura,
- Davacı personel için yapılacak ödemelerde ilgili Bakanın onayı,
ödeme belgesine bağlanır.
d) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca satın alınan avukatlık hizmet bedellerinin ödenmesinde; Yönetmeliğin "Çeşitli hizmet alımları" başlıklı 46 ncı maddesinde belirtilen belgeler ile 24/12/2012 tarihli ve 2012/4096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen hallerde ayrıca ilgili Bakan onayı aranır.
Avukatlık hizmet bedellerinin ve öngörülen diğer masrafların ödenmesinde, ilgili mevzuatı uyarınca farklı belgeler istenmesi halinde bu belgeler ödeme belgesine bağlanır.

Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderleri
Madde 41- Proje yarışma ödülleri ile proje teşvik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Yarışma konusu olan proje ödüllerinin ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Ödül kazananları belirleyen jüri tutanağı,
-Ödüller önceden belirlenmemiş ise verilecek ödüllerin (derece ve mansiyonlar) tutarını gösterir tespit tutanağı,
- Fatura,
ödeme belgesine bağlanır.
b) İlgili mevzuatı gereğince yapılacak proje teşvik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde;
-Harcama talimatı, ilgili mevzuatında belirtilen hallerde üst yöneticinin onayı ,
-Sözleşme,
-Yetkili komisyonun kabul onayı,
-Fatura,
ödeme belgesine bağlanır.
Proje teşvik ve destekleme giderlerinden ihale mevzuatına göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile seyahat giderlerinin ödenmesinde, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır.

Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderleri
Madde 42- Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası,
- Fatura,
- Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),
ödeme belgesine bağlanır.

Ulaştırma ve haberleşme giderleri
Madde 43- Ulaştırma ve haberleşme giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.
a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki telefon, teleks, telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde;
-Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura,
ödeme belgesine bağlanır.

b) Tekel niteliğinde olmayan veya ihale mevzuatına göre temin edilen telefon, teleks, telefaks ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının her türlü hat kullanım ve abone giderlerinin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası,
- Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura,
ödeme belgesine bağlanır.
c) Bir bağlantıyla ulaşılan (telefon, kablo, internet vb.) televizyon ve benzeri araçların abone giderleri ile bilgisayar haberleşmesi ve haber ajansları abonelik giderleri gibi bilgiye abonelik giderlerinin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası,
- Fatura,
ödeme belgesine bağlanır.

Taşıma giderleri
Madde 44 -Taşıma giderlerinin ödenmesinde, taşımanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.
a) İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası,
- Fatura,
- Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),
ödeme belgesine bağlanır.
Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen belgelere ilaveten taşıma senedinin (konşimento) aslı ile bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce yürütülen işlemlerde teslim kağıdının (ordino) onaylı bir örneğinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Bilgisayar sistemi bulunan idarelerde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim kağıdı hükmündedir.
b) Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde;
- Onay belgesi,
- Fatura,
ödeme belgesine bağlanır.
c) Erlerin serbest celp ve sevklerinde, gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtaları ile yapacakları seyahatlerle ilgili taşıma ve yiyecek bedellerinin ödenmesinde;
- Sevk Erleri Taşıma Ücreti ve Yiyecek Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek: 34),
ödeme belgesine bağlanır.

Kiralar
Madde 45 - Kira bedellerinin ödenmesinde, kiralamanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.
a) Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası,
- Fatura,
ödeme belgesine bağlanır.
b) Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde;
-Taahhüt dosyası,
- Fatura,
-Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),
ödeme belgesine bağlanır.

Çeşitli hizmet alımları
Madde 46-İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılan bakım, onarım, danışmanlık, araştırma ve geliştirme, muhasebe, anket, temizlik, tarımsal mücadele, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, yemek

hazırlama ve dağıtım, toplantı, kurs, koruma ve güvenlik, sigorta, etüt ve proje, harita ve kadastro, plân, imar uygulama, basım ve yayım, fotoğraf, film alımları, bilgisayar hizmet alımları (gayrimaddi hak olarak alınan yazılım ve donanımlar hariç) ve benzeri hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası,
- Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname),
- Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),
ödeme belgesine bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Temsil ve Tanıtma Giderleri

Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri
Madde 47- Temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır.
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon,
- Mihmandar Hesap Cetveli (Örnek: 35),
ödeme belgesine bağlanır.
Ziyafete ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde alınacak harcama talimatında, davetli ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapacağı harcamaların neleri kapsayacağı belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM
Mal, Malzeme ve Gayrimaddi Hak Alım Giderleri

Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım giderleri
Madde 48 - Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası,
- Fatura,
- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı,
-Taşınır işlem fişi,
ödeme belgesine bağlanır.
Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi tüketim malzemeleri ile test ve tetkik tüketim malzemelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (f) bendine göre alınması halinde, alımın acil bir durum sebebiyle gerçekleştirildiğine ve stoklanmasının mümkün bulunmadığına ilişkin belge de ödeme belgesine bağlanır.
Yurtdışından yapılacak alımlarda yukarıdaki belgelere ilaveten;
- Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildiğine ilişkin belge,
- Taşıma senedi (konşimento),
ödeme belgesine bağlanır.
Yurtdışından yapılan satınalmalarda ödenen vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örneği aranır.
Alımı bir merkezden yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır.

Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderleri

Madde 49- Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde;
-Fatura,
b) Tekel niteliğinde olmayan ve ihale mevzuatına göre temin edilen elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası,
- Fatura,
ödeme belgesine bağlanır.
Farklı bütçeli dairelerin aynı binayı ortaklaşa kullanmaları halinde elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketimler yalnız bir ölçü aletiyle ölçülüyor ise fatura yerine, fatura sureti ile her daireye isabet eden tüketim bedeli tutarını gösterir belgenin ve sözleşmenin ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Sanat eseri alımları
Madde 50-Sanat eseri alım giderlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereğince, müzelere alınacak taşınır kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;
-Harcama talimatı,
-Fatura,
-Değerlendirme komisyonu kararı,
- Taşınır işlem fişi,
b) Devlet resim ve heykel sergilerinde, usulüne uygun olarak kurulan seçici kurul tarafından seçilerek alınması kararlaştırılan resim, tablo ve heykel bedellerinin ödenmesinde;
- Harcama talimatı,
- Seçici kurul kararı,
- Fatura,
- Taşınır işlem fişi,
c) Sanatçılardan, kurum veya kuruluşlardan satın alınacak her türlü resim, tablo ve heykel bedellerinin ödenmesinde;
- İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı,
- Fatura,
- Taşınır işlem fişi,
ödeme belgesine bağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Mal Alımları, Kamulaştırma ve Devletleştirme Bedelleri, Onarım Giderleri

Taşınmaz mal alım bedelleri
Madde 51- Taşınmaz mal alım bedellerinin ödenmesinde aranılacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak alımlarda;
- Taahhüt dosyası,
- Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örneği,
b) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca teferruğ yoluyla elde edilen taşınmaz bedellerinin ödenmesinde;
- Teferruğa karar veren makamın yazısı,
- Satış komisyonu kararı,
- Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının onaylı örneği,
ödeme belgesine bağlanır.

Kamulaştırma bedelleri
Madde 52- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde;
a) Satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırmalarda;
- Kamulaştırma kararı,
- Kıymet takdir komisyonu kararı,
- Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaşma komisyonu tarafından imzalanmış tutanak,
- Taşınmazın idare adına ferağının verildiğine ilişkin resmi senedin onaylı örneği,
b) Satın alma usulünün uygulanmadığı kamulaştırmalarda;
- Kamulaştırma kararı,
- Kıymet takdir komisyonu kararı,
- Bedelde taraflarca mahkemede anlaşmaya varıldığı durumlarda, idarenin anlaşma yapıldığına ilişkin yazısı,
- Tarafların bedelde anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından tespit edilen kamulaştırma bedelinin (bedeli taksitle ödenmek üzere yapılan kamulaştırmalarda ilk taksitin) hak sahibi veya zilyedi adına bankaya yatırılması veya ileride belli olacak veya hak sahipliğini ispat edecek kişi adına bankada bloke edilmesi hususunda idareye süre verildiğine ilişkin mahkeme talimatı,
ödeme belgesine bağlanır.

Devletleştirme karşılıkları
Madde 53- 1/12/1984 tarihli ve 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca devletleştirme karşılıklarının ödenmesinde;
- Devletleştirme kararı,
- Değer tespiti ve takdir komisyonu kararı,
ödeme belgesine bağlanır.

Yapı, tesis ve onarım giderleri
Madde 54- (Değişik: RG-16/11/2013-28823)
Yapı, tesis ve onarım giderlerinin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası,
- Fatura,
- Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3)
ödeme belgesine bağlanır.
Ancak, mevzuatı uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleriyle ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde doğrudan yaptırılan işlerde;
- İlgili mevzuatın yetkili kıldığı makam onayı,
- Fatura,
- Protokol,
- Ödeme Takip Cetveli (Örnek: 3/A)
ödeme belgesine bağlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Borçlanma Maliyet Giderleri

Faiz, iskonto ve diğer borçlanma giderleri
Madde 55–Kamu borçlanmalarına ilişkin faiz, iskonto ve diğer borçlanma giderlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Devlet iç borçları faiz, iskonto ve diğer borçlanma giderlerinin ödenmesinde;

1- İtfa planı gereğince yapılan giderlerin ödenmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan ödeme planı, ve/veya ilgili birimce hazırlanan onaylı cetvel,
2-İtfa planı dışında erken ödeme veya senet değişimlerinde ;
-Bakan onayı,
-Yapılan ödemenin ayrıntısını gösteren, ilgili birimce onaylı cetvel,
3- Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan borçlanma giderlerinin ödenmesinde, yapılan ödemenin ayrıntısını gösteren ilgili birimce onaylı cetvel,
b) Devlet dış borçları faiz iskonto ve diğer borçlanma giderlerinin ödenmesinde;
1- Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan anlaşmalarla yapılan borçlanmalarda;
- Bakanlar Kurulu Kararı,
- Anlaşma metninde belirlenen şartlara göre düzenlenen ödeme planı veya kreditör ödeme bildirimi,
2- Tahvil ihracı yoluyla yapılan dış borçlanmalarda;
- Borcun niteliğine göre, tahvil ihracı suretiyle yapılan dış borçlanmaya ilişkin bilgileri içeren bildirim formu veya kreditör ödeme bildirimi,
ödeme belgesine bağlanır.
Bakanlar Kurulu Kararı ilk ödemeye ilişkin ödeme belgesine bağlanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Görev Zararı, Hazine Yardımı ve Diğer Transfer Harcamaları

Görev zararları ve hazine yardımları
Madde 56 – Görev zararları ile hazine yardımlarının ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Hazine Müsteşarlığınca;
1-Kurum ve kuruluşların görev zararları için yapılacak ödemelerde;
- Harcama talimatı
- Kesinleşmiş görev zararını gösterir, ilgili birimce onaylı cetvel; avans olarak yapılacak ödemelerde, kuruluşa tahsis edilen ödenek ile kullanılan ve arta kalan ödenek miktarını gösteren ilgili birimce onaylı cetvel,
2-Hazine yardımı olarak yapılacak ödemelerde;
- Harcama talimatı,
- İlgili idareye tahsis edilen ödenek ile kullanılan ve arta kalan ödenek miktarını gösteren ilgili birimce onaylı cetvel,
ödeme belgesine bağlanır.
b) Sosyal güvenlik kurumlarına kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda verilen bu görevin ifası sonucu oluşan bedelin Hazinece karşılanması için yapılacak ödemelerde;
- Harcama talimatı,
-Ödenecek miktarın hesaplanmasını gösteren, ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca düzenlenmiş belge,
ödeme belgesine bağlanır.

Katılma payı, sermaye teşkilleri, yardım, pay ve benzeri ödemeler
Madde 57 – Katılma payı, sermaye teşkilleri, yardım, pay, hane halkına yapılan transferler ve benzeri ödemelerde aşağıdaki belgeler aranır.
a) Kurumlara katılma payları, sermaye teşkilleri, iktisadi transfer ve yardımlar ile malî transferlere ilişkin ödemelerde;
- İlgili mevzuatın yetkili kıldığı makam onayı veya Bakanlar Kurulu Kararı,
- Anlaşmaya bağlı ödemelerde, sözleşme veya protokol,
b) Kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek payların ödenmesinde; gelirin ait olduğu kamu idaresi üst yöneticisinin onayı, genel bütçe gelirlerinden ilgili mevzuatı gereğince diğer kamu idarelerine verilecek payların ödenmesinde Maliye Bakanının onayı,

c)Yurtlarda barınan öğrencilere kupon karşılığı verilen yemek yardımlarına ilişkin işletmelere yapılacak ödemelerde;
-Harcama talimatı,
-Öğrenci sayısı, gün sayısı ve tutarları gösterir yetkili makamca onaylı liste,
-Fatura,
d)Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerine ödenen burs, harçlık ve benzeri giderlerin dışında kalan diğer giderlerinin ödenmesinde;
-Harcama talimatı,
-Fatura,
ödeme belgesine bağlanır.

Siyasi parti, dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküllere yapılacak ödemeler

Madde 58- Siyasi parti, dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküller ile kamu kurum ve kuruluşlarının yemek servislerine yardım mahiyetinde yapılacak ödemelerde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Siyasi partilere yapılacak ödemelerde;
- Bakan onayı,
- Ödenecek yardımın tutarını gösterir hesap pusulası,
b) Dernek, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküller ile kamu idarelerinin yemek servislerine yardım mahiyetinde yapılacak ödemelerde, ödemeyi yapacak kamu idaresi üst yöneticisinin onayı (özel mevzuatında bakan onayı aranması gereken hallerde ilgili bakan onayı),
ödeme belgesine bağlanır.

ONUNCU BÖLÜM
Diğer Giderler

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü ve ek 10 uncu maddeleri kapsamındaki alımlar ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar (Değişik başlık:RG-11/10/2017-30207)

Madde 59 - Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak alım bedelleri ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımların ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ürün alım bedellerinin ödenmesinde;
- Onay belgesi,
- Fatura,
-Düzenlenmesi gereken hallerde sözleşme,
-Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
- Taşınır işlem fişi,
ödeme emri belgesine bağlanır.
Aynı fıkra uyarınca, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak hizmet alım bedellerinin ödenmesinde; Onay Belgesi, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13) ve düzenlenmesi gereken hallerde fatura aranır.
Alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde Onay Belgesi ve yapılmış ise sözleşme ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.
b) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b), (d), (f), (i) ve (j) fıkralarında belirtilen alımlara ilişkin giderlerin ödenmesinde, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla; bu Yönetmeliğin mal ve hizmet alımları ile yapım giderlerinin ödenmesinde aranılacak kanıtlayıcı belgelere ilişkin ilgili madde hükümleri uygulanır.

c) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendine göre uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin giderlerin tahakkuk veya ödenmesinde, gider türleri itibarıyla Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin ödeme belgesine bağlanması esastır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanların idarelerince onaylı Türkçe tercümeleri fatura aslı ile birlikte ödeme belgesine bağlanır, diğer belgelerin asılları ise idarelerinde saklanır.
Sağlanan dış finansmanla yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak düzenlenen taahhüt dosyasına onay belgesi yerine harcama talimatı ile birlikte;
- Şartnameler (teknik şartname hariç),
- İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,
- Kredi anlaşmasında öngörülmüş ise kreditör onay belgesi,
- Teminata ilişkin alındının onaylı örneği,
- Karara ilişkin damga vergisi alındısı,
- Ayrıca, kullanılan dış finansmanın bütçeleştirildiğine ilişkin Dış Proje Kredileri Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen bildirim formları,
bağlanır.
Taahhüt dosyasının verileceği ve gönderileceği yerler ile nüsha sayıları hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.
Uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmet bedellerinin ödenmesinde Yönetmeliğin "Çeşitli Hizmet Alımları" başlıklı 46 ncı maddesinde belirtilen belgeler aranır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanların idarelerince onaylı Türkçe tercümeleri fatura aslı ile birlikte ödeme belgesine bağlanır, diğer belgelerin asılları ise idarelerinde saklanır.
d) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) fıkrasında sayılan kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alım giderlerinin ödenmesinde;
- Onay belgesi,
- Kamu ihale mevzuatında belirtilen parasal limiti aşan mal ve hizmet alımlarında alım komisyonu kararı,
- Düzenlenmesi gereken hallerde protokol,
- Fatura,
- Hizmet alımlarında Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek:4),
- Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
- Mal ve malzeme alımlarında taşınır işlem fişi,
ödeme belgesine bağlanır.
Mal ve hizmet bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, onay belgesi ile protokole bağlanması gereken alımlarda protokol ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.
e) Devlet Malzeme Ofisinden ve idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlarda;
- Onay Belgesi,
- Fatura,
-Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
- Taşınır işlem fişi,
ödeme belgesine bağlanır.
Mal ve malzeme alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, onay belgesi ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.
f) (Ek:RG-11/10/2017-30207) Kamu İhale Kanununun ek 10 uncu maddesine göre, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet

alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;
- Onay Belgesi,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Fatura,
- Gereken hallerde taşınır işlem fişi, muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
ödeme belgesine bağlanır.
İnternet erişimine dayalı dijital eğitim içeriklerine ulaşılmasını sağlayan Fatih Projesi Bileşenleri Hizmet Alımları giderlerinin ödenmesinde;
- Onay Belgesi,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Fatura,
- Varsa sözleşmede belirtilen belgeler,
ödeme belgesine bağlanır.
Alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde Onay Belgesi ve yapılmış ise sözleşme ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.

Dış temsilciliklerce yapılan harcamalar
Madde 60- Dış temsilciliklere gönderilen avanslar ile açılan kredilerden bütçenin her bir tertibinden yapılan harcamalarda dönemler itibarıyla bir Mahsup Bildirimi (Örnek: 36) düzenlenir.
Bu bildirime;
- Bütçenin her bir tertibi için düzenlenen Fatura ve Alındılar Tercüme ve Müfredat Cetveli (Örnek:37),
- Döviz satış belgesi,
- Konsolosluk hasılatından kullanılan avanslar için Dışişleri Bakanlığının emri,
bağlanır.
Mahsup Bildirimi (Örnek: 36) ve ekleri ile duruma göre taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır.

Ödünç verme ve yardım
Madde 61- Yabancı ülkelerde güç veya muhtaç duruma düştükleri Dışişleri Bakanlığınca tespit olunan ve yurda dönmeleri gereken Türk vatandaşlarının, dönüş ve yolda yiyecek giderleri için;
a) Geri alınmak üzere ödünç olarak verilen paraların ödenmesinde;
- Senet (Örnek: 38),
b) Yardım olarak verilen paraların ödenmesinde;
- İlgilinin muhtaç olduğunu belirten ve parayı aldığına ilişkin imzasını içeren konsoloslukça düzenlenmiş tutanak,
ödeme belgesine bağlanır.

Zimmetten doğan borç ödemeleri
Madde 62 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/11/2016-29879)
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesinden doğan borç ödemelerinde;
- Soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcılığı yazısı,
- Paranın icra dairesine yatırıldığına ilişkin belge,
ödeme belgesine bağlanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar

Madde 63 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde;

- Onay Belgesi ,
- Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Fatura,
- Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
-Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi,

ödeme belgesine bağlanır.

Söz konusu alım bedellerinin ödenmesinde aranılacak belgelere ilişkin diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yurtdışından yapılacak tüketim malı, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde birinci fıkrada belirtilen belgelere ilaveten;

- Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildiğine ilişkin belge,
- Taşıma senedi (konşimento),

ödeme belgesine bağlanır.

Yurtdışından yapılan satınalmalarda ödenen vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örneği aranır.

Alımı bir merkezden yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır.

b) Tercüme ücreti ödemeleri ile elektrik, su, doğalgaz ve ulaştırma, haberleşme giderlerinin ödenmesinde muayene ve kabul işleminin yapıldığına ilişkin belge aranmaz.

c) Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, birinci fıkrada belirtilen belgelere ilaveten;

-Taşıma senedinin (konşimento) aslı,

-Bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce yürütülen işlemlerde teslim kağıdının (ordino) onaylı bir örneği,

ödeme belgesine bağlanır.

Bilgisayar sistemi bulunan idarelerde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim kağıdı hükmündedir.

Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı ve düzenlenmiş ise sözleşme dışındaki belgeler aranır.

Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler

Madde 64- Kamu ihale mevzuatına göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bedellerinin ödenmesinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan belgelerden başka, duruma göre aşağıda belirtilen belgeler de ödeme belgesine bağlanır. Söz konusu belgelerin onaylı birer nüshaları muhasebe biriminde saklanan taahhüt dosyalarına eklenmek üzere ayrıca alınır.

a) Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

b) Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

c) Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,

d) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

Vize veya uygun görüş alınması gereken hallerde aranacak belgeler

Madde 65- Kamu idarelerinin yapacakları harcamalarında, ilgili mevzuatında vize veya uygun görüş alınmasının belirtildiği hallerde, duruma göre vize yazısı veya cetveller ile uygun görüş yazıları ilk

ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.
Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen alımların ödenmesinde, uygun görülmediğine ilişkin görüş yazısının da ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Taşınır işlem fişine ilişkin istisnai hükümler
Madde 66- (Değişik:RG-11/10/2017-30207)
28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır işlem fişi düzenlenmesi öngörülmeyen hallerde bu belge aranmaz.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak taşınır alımlarında, taşınır girişlerinde düzenlenecek belgenin ödeme belgesine bağlanması hususunda, 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Olağanüstü hallerde ve yeni bir giderin ortaya çıkması halinde yapılacak düzenlemeler
Madde 67-Bakanlık;
a) Savaş hali ile idari ve askeri sebeplerle tahliye durumunda veya olağanüstü diğer hallerde yapılması zorunlu olan ivedi giderlerin ödenmesinde,
b) Mevzuat değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin bu Yönetmelikte değişiklik yapılıncaya kadar ödenmesinde,
ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir.
Doğal afetler nedeniyle alınacak tedbirler ile yapılacak yardımlara ilişkin harcamalar 25/9/2005 tarihli ve 25947 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Afet Harcamaları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Geçici Madde 1- Taşınır Mal Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar bu Yönetmelikte geçen taşınır işlem fişi yerine, Ayniyat Talimatnamesi ekinde yer alan ayniyat tesellüm makbuzu veya idarelerin özel mevzuatlarında bu makbuz yerine kullanılması öngörülen belge düzenlenir.
Geçici Madde 2- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin taşınır mal işlemlerinde Ordu Mal Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 – (Ek: RG-16/11/2013-28823)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işler için avans olarak verilen tutarların mahsubunda; ödeme belgesine makam onayı, fatura ve protokolün idarece onaylı bir örneği bağlanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 68- 14/10/1991 tarihli ve 21021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 69- Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 70 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TUTANAĞI

İdarenin Adı :……..……..……..……..……..……..……..……..……..…

Yapılan İş / Mal / Hizmetin Adı, Niteliği :……..……..……..……..……..……..……..……..……..…

Alım ve Yetkilendirilen Görevlilere İlişkin
Onay Belgesi /Görevlendirme Onayı Tarih ve No.su :……..……..……..……..……..……..……..……..……..…

	Mal / Hizmet / Yapım İşi	Kişi / Firmalar ve Fiyat Teklifleri			
		1 inci	2 nci	3 üncü	4 üncü .....
1	(Birinci Kalem Mal/Hizmet /Yapım İşi)				
2	(İkinci Kalem Mal/Hizmet /Yapım İşi)				
3					
4					

	Mal / Hizmet / Yapım İşi	Uygun Görülen Kişi / Firma / Firmalar		
		Adı	Adresi	Teklif Ettiği Fiyat
1	(Birinci Kalem Mal/Hizmet /Yapım İşi)			
2	(İkinci Kalem Mal/Hizmet /Yapım İşi)			
3				
4				

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesi uyarınca doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlara ilişkin yapılan piyasa araştırmasında firmalarca/kişilerce teklif edilen fiyatlar tarafımca/ tarafımızca değerlendirilerek yukarıda adı ve adresleri belirtilen kişi / firma / firmalardan alım yapılması uygun görülmüştür. ../ .... / ...

Piyasa Fiyat Araştırması Görevlisi / Görevlileri

		.....	
Adı Soyadı	:.....	....	.....
		.....	
Unvanı	:.....	....	.....
		.....	
İmzası	:.....	....	.....

* Piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi / firma, yer sayısına ihale yetkilisi karar verebilecektir.

* Piyasa fiyat araştırması için görevlendirilecek personelin sayısına ihale yetkilisi karar verebilecektir.

M.Y.H.B.Y. Örnek No:2

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

1. Giriş

(1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Bundan böyle "Yönetmelik" olarak anılacaktır.) 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 1/1/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

(2) Yönetmeliğin uygulanmasında kamu idarelerinde oluşan tereddütlerin giderilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

2. Harcama talimatı, ihale onay belgesi ve onay belgesi

(1) 5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu ihale mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır. Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgelerdir.

(2) Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir.

(3) Buna göre;

a) Kamu ihale mevzuatı gereğince ihale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili uygulama yönetmeliklerinin ekinde standart form olarak belirlenen ihale onay belgesi[1],

b) Kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapılacak veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde onay belgesi[2],

c) İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, kıdem tazminatı, huzur ücreti, konferans ücreti, kaçak olarak yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ile diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde ise Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan harcama talimatı (Ek-1),

ödeme belgesine bağlanır.

(4) Ayrıca, sınai, teknolojik, malî ve benzeri zorunluluklar nedeniyle yaklaşık maliyetin tespit edilemediği haller dışında, yaklaşık maliyet hesap cetveli veya yaklaşık bedelin tespitine ilişkin belgeler de yukarıda belirtilen ihale onay belgesi veya onay belgesi ile birlikte ödeme belgesine bağlanacaktır.

(5) Mevzuatı gereğince, Yönetmelikte bazı giderlerin (şehitlik tazminatı, yabancı dil tazminatı, 657 sayılı Kanun gereğince devlet memurlarına verilecek ödüller, kurs ve toplantılara katılma giderleri, siyasi partilere yapılacak ödemeler gibi.) ödenmesinde "başbakan", "ilgili bakan", "üst yönetici", "atamaya yetkili amir" ve benzeri yetkililerden alınan onay veya yazının ödeme belgesine bağlanması hususuna yer verilmiştir. Anılan makamlardan alınan onay ve yazılar da harcama talimatında belirtilmesi gereken bilgilere yer verilerek düzenlenir. Bu durumda söz konusu ödemelerin yapılmasında ayrıca harcama talimatı aranmaz.

3. Fatura

(1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan "Faturaya" ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

a) Fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile düzenlenme şekilleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229-237 nci maddelerinde açıklanmıştır. Söz konusu maddeler gereğince fatura yerine geçen belgeler olarak kabul edilen belgelerden perakende satış vesikası ile ödeme kaydedici cihazlara (yazar kasa) ait satış fişinde mal veya hizmeti alan ya da mal veya hizmetin teslim edildiği kişi veya idarenin adına ilişkin bilgilere yer verilmediğinden, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılan fatura tanımında söz konusu belgeler sayılmamıştır. Ancak, personelin bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir personel veya ailesi ya da yakınları tarafından kaldırılan cenazeye ilişkin giderler ile belediye hudutları dışında taksi ile yapılan seyahat giderleri ve yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması için görevlendirilen personel veya mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi fatura yerine kabul edilebilecektir.

Akaryakıt istasyonlarından yapılan akaryakıt alımlarında, Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığının 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 68 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğindeki

açıklamalar çerçevesinde akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen fişler "fatura yerine geçen belge" olarak kabul edilecektir. Ancak, aynı Tebliğde yapılan açıklamalara göre fatura düzenlenmesi gereken hallerde "fatura"nın aranması zorunludur.
Ayrıca, kanunen fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan yapılan alımlarda, idarelerce Yönetmelik eki 1 örnek numaralı Harcama Pusulası düzenlenerek ödeme belgesi ekine bağlanır. Fatura düzenlemek zorunda olmayan kamu idarelerinden yapılan alımlarda ise her ne adla düzenlenmiş olursa olsun, yapılan alım karşılığında 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirlenen asgarî bilgileri taşıyan alındı, ödeme belgesi ekine bağlanacaktır.
Diğer taraftan, yurtdışından veya yurtdışında yapılan alım bedellerinin ödenmesinde, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen fatura veya benzeri belgelerin, birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen misyon şefi, ataşe, eğitim müşavirliği, ihtisas birimi yöneticisi ve benzeri yetkililerce onaylanmış tercümeleri ile birlikte ödeme belgesi ekine bağlanması gerekir.
Alım şekli veya tutarı ne olursa olsun, düzenlenen faturanın ihale komisyonu veya mevzuatları gereğince bu maksatla görevlendirilmiş kurullarca onaylanması gerekmez.
b) Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince, ödeme belgesine kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretlerinin bağlanması gerekmektedir. Ancak, kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatının bulunduğu ülkenin mevzuatı gereğince asılları vergi iadesinde kullanılan faturalara ilişkin giderlerin ödenmesinde, ilgili dış temsilciliğin veya yurtdışı teşkilatının yetkilisi tarafından onaylanan fatura örneklerine göre işlem yapılması uygun görülmüştür.
Ayrıca, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, aşağıda belirtilen esaslara göre düzenlenen faturanın onaylı suretleri ödeme belgesine bağlanmak suretiyle ödeme yapılması uygun görülmüştür.
1) Kamu idareleri tarafından düzenlenen ve kaybolduğu anlaşılan faturalar, bunları düzenleyen idarelerde bulunan dip koçanındaki nüshasına uygun olarak suretleri çıkarılır ve ilgili kamu idarelerinin yetkililerince onaylanır.
2) Özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybolması halinde; aksine bir düzenleme yapılmadığı sürece tutarı Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ ekinde yer alan tabloda gösterilen tutara kadar olanlar için, harcama birimine ibraz edilen dipkoçanındaki nüshasına uygun olarak suretleri çıkarılır ve harcama yetkilisince veya harcama yetkilisinin belirleyeceği görevli tarafından onaylanır. Ayrıca, dipkoçanının arkasına suretinin çıkarıldığına ilişkin şerh düşülerek onaylanır. Belirtilen tutarı geçen faturaların kaybolması halinde ise noterce onaylanan suretleri ödeme belgesine bağlanır.
3) Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmî mühür ile onay tarihini taşıması gerekir. Ayrıca, onaylı fatura örneklerine dayanılarak yapılacak giderlere ilişkin ödeme belgesi düzenlenmeden önce, borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığı ve fatura bedelinin ödenmesi için daha önce ödeme belgesi düzenlenip düzenlenmediği araştırılır. Söz konusu faturalar, muhasebe kayıt ve işlemleri elektronik ortamda yapılan kamu idarelerinin muhasebe yetkililerince de ödemeden önce sistemden sorgulanır.

4. Ödeme belgeleri
(1) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderlerin kesin olarak ödenmesinde ve ön ödemelerin mahsubunda; 30 Aralık 2006 tarihli ve 26392 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki (1/A, 1/B) örnek numaralı Ödeme Emri Belgesi, bu idarelerin bütçe içi veya bütçe dışı avans veya kredi şeklinde yapacakları ön ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem Fişi ödeme belgesi olarak düzenlenecektir.
(2) Ödeme belgeleri harcama yetkililerince belirlenen gerçekleştirme görevlisi tarafından düzenlenir ve ekine giderin çeşidine veya ön ödemenin şekline göre Yönetmelikte belirlenmiş olan gerçekleştirme belgeleri bağlanır.

5. Ortak veri tabanı bilgilerine dayanılarak yapılacak ödemeler
(1) 5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir" hükümlerine yer verilmiştir.
Ayrıca, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayan belge bağlanmaz." denilmiş olup, madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirleneceği öngörülmüştür.
(2) Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ödemeleri Bakanlığımız Muhasebat

Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimlerince yapılan harcama birimlerinde istihdam edilen memurların aylıklarının say2000i sisteminde oluşturulan merkezi veri tabanındaki bilgilerden yararlanmak suretiyle ödenmesinde Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) düzenlenen usul ve esaslara uyulacaktır.

6. Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler

(1) Kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderler için ilgili mevzuatında düzenlenmesi, aranması ve alınması öngörülen belgelerin düzenlenmesi, aranması ve alınması zorunludur. Kamu ihale mevzuatına göre hazırlanan ihale işlem dosyasında, ihale sürecinde düzenlenen tüm belgeler bulunur. Taahhüt dosyasında ise yalnızca ödeme belgesine bağlanması öngörülen belgelere yer verilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuatına göre istenen belgelerden Yönetmelikte ve bu Tebliğde sayılmayanlar ödeme belgesine bağlanmayacak, iç ve dış denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerinde muhafaza edilecektir.

(2) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve diğer ilgili maddeleri gereğince, taahhüt dosyasında bulunması öngörülen belgeler ile Bakanlığımızca taahhüt dosyasında bulunması gerekli görülen diğer belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) İhale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde,

-İhale onay belgesi,
-İhale komisyonu kararı,
-Sözleşme,
-İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,
-Kesin teminatın alındığına ilişkin alındının örneği,
-Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı,
-Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge,
-Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,
-Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,
-Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı,
-Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi dışındaki bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda;

-Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi,
-Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, komisyon kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı; 22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form,
-Yukarıdaki (a) bendinde sayılanlardan düzenlenmesi gereken diğer belgeler.

c) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendine göre uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, gider türleri itibarıyla Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin ödeme belgesine bağlanması esastır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanların idarelerince onaylı Türkçe tercümeleri fatura aslı ile birlikte ödeme belgesine bağlanır, diğer belgelerin asılları ise iç ve dış denetim sırasında ilgililere ibraz edilmek üzere harcama birimlerince saklanır.

Sağlanan dış finansmanla yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak düzenlenen taahhüt dosyasına onay belgesi yerine harcama talimatı ile birlikte;

-Şartnameler (teknik şartname hariç),
-İlanın yapıldığına ilişkin tutanak,
-Kredi anlaşmasında öngörülmüş ise kreditör onay belgesi,
-Kesin teminata ilişkin alındının onaylı örneği,
-Damga vergisi alındısı,
-Ayrıca, kullanılan dış finansmanın bütçeleştirildiğine ilişkin 11/07/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Proje Kredileri Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen bildirim formları,

bağlanır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtildiği şekilde hazırlanan taahhüt dosyasının aslı, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanır. Taahhüt olunan işin bedelinin bir defadan fazla ödeme belgesi düzenlenmek suretiyle tahakkuk ettirilerek ödenmesinin söz konusu olduğu hallerde, taahhüt dosyasının harcama yetkilisi veya harcama yetkilisinin belirleyeceği görevli tarafından Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak onaylanmış bir nüshası da ayrıca muhasebe birimine gönderilir.

7. Ödeme yapılacak kişiler

(1) Yönetmeliğin ödemenin kimlere yapılacağına ilişkin maddesinde açıklanması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesi hükmü gereğince avukatlar belgeleri onaylama yetkisine sahip olduklarından, bunlara vekaletname ile yapılacak ödemelerde, noterce düzenlenmiş vekaletnamelerin avukat tarafından onaylanmış örnekleri kabul edilecektir.

b) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge, bunların tayin ettikleri vekile yapılacak ödemelerde ise sadece noterce düzenlenmiş vekaletname aranacaktır.

Uygulamada, noterlerce düzenlenen imza sirkülerinde aynı zamanda ilgili kişi veya kişilerin tüzel kişiliği "temsil ve ilzam"a yetkili oldukları belirtilmesine rağmen, ayrıca yetki belgesi istenildiği, yetki belgesi istenilen kişinin noterde bir başkasına vekalet vererek alacağın vekile ödenmesinin sağlandığı Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmaktadır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket tüzel kişiliğini ortaklara ve üçüncü şahıslara karşı temsil salahiyet ve yetkisi anonim şirketlerde idare meclislerine, diğerlerinde ise şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm olmadıkça ortakların çoğunluğu ile ortaklardan birine veya birkaçına verilebilmektedir. Şirketi temsile salahiyetli olan kimse, şirketin gayesine dahil olan her nevi iş ve hukuki muameleleri şirket namına yapmak ve şirket tüzel kişiliğinin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi sınırlandıran her şart, hüsnüniyetle hareket eden üçüncü şahıslara karşı hükümsüzdür. Bu nedenle, noterde düzenlenen imza sirkülerine ilişkin belgede ilgili kişi veya kişilerin, tüzel kişiliği birlikte veya münferiden "temsil ve ilzam"a yetkili olduklarının belirtilmiş olması halinde, bu kişi veya kişilere yapılacak ödemelerde ayrıca, tahsile yetkili olduğuna dair belge istenilmesine gerek bulunmamaktadır.

8. Ödül ve ikramiyeler

(1) 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun uyarınca kamu personeli olmayan kişilere yapılacak ikramiye ödemelerinde Maliye Bakanı onayı yerine harcama yetkilisinden alınan harcama talimatının ödeme emri belgesine bağlanması uygun görülmüştür. Anılan Kanuna göre kamu personeline yapılacak ikramiye ödemelerinde ise Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtildiği gibi Maliye Bakanı onayının aranacağı tabidir.

9. Tedavi giderlerinde aranılacak belgeler

a) Tedavi giderlerinin ödenmesinde aranacak belgeler arasında sayılan hastanın sevkine ilişkin belge ihtiyaca göre bir, iki ya da üç nüsha olarak düzenlenir. Zorunlu durumlarda Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde onaylanmış fotokopileri de kabul edilir. Ayrıca, cezaevlerindeki mahkum ve tutuklular ile kamu idarelerine ait esirgeme kurumlarında veya sığınma evlerinde ya da terkedilmiş olmaları nedeniyle karakollarda barındırılan çocuk ve yetişkinlerin tedavileri için düzenlenen tutanak ve resmî yazılar hastanın sevkine ilişkin belge yerine kabul edilir.

b) Yönetmeliğin 20 nci maddesinde eczanelere yapılacak ödemeler ile personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının yapıştırılmış olduğu reçetenin ödeme belgesine bağlanması öngörülmüştür. İlaç kutuları üzerinde hem fiyat kupürü hem de barkod diyagramının bulunması halinde her ikisinin de reçeteye yapıştırılması gerekmektedir. Barkod diyagramı yoksa, fiyat kupürünün reçeteye yapıştırılması yeterli olacaktır. Ayrıca, personele ilişkin ilaç ihtiyaçları T.C. Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sistemi üzerinden kontrol edilerek karşılanan harcama birimlerince eczanelere yapılacak ödemelerde, eczanelerce reçete kontrol sisteminden alınan java döküm listesinin bir nüshasının ödeme belgesine bağlanması gerekmektedir.

10.Yolluk giderlerinin ödenmesinde aranılacak belgeler

(1) Yolluk giderlerinin ödenmesinde Yönetmeliğin 22-27 nci maddelerinde belirtilen belgelerin ödeme belgesine bağlanacağı hükmüne yer verilmiş olup diğer hususlar aşağıda açıklanmıştır.

a) Yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde tutarı açıkça yazılan söz konusu giderlerin kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belge ödeme belgesine bağlanır.

b) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde belediye hudutları dışına taksi ile yapılan seyahatlerde, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmiştir.

Belediye hudutları dışına özel otomobil ile yapılan seyahatlerde ise;

- İşin gereği veya zorunluluk nedeniyle mutat taşıt dışında bir taşıtla yapılması gereken seyahatlerde, zorunlu hallere ilişkin yetkili makamdan alınmış onay veya rapor ile yetkili mercilerden alınan taksi rayiç belgesi,
- Mutat taşıt aracının işlemediği yerlere yapılan seyahatlerde, yetkili mercilerden alınan ve mutat taşıt

aracının işlemediğini belirten taksi rayiç belgesi,
Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen diğer kanıtlayıcı belgelerle birlikte ödeme belgesine bağlanacaktır.Söz konusu taksi rayiç belgesindeki rayiç tutarı, hiçbir zaman ticari taksiler için verilecek rayici geçemez.
Özel otomobil ile birden fazla kişinin seyahat etmesi halinde ise, otomobil sahibi dışındaki görevliler taksi rayiç belgesi yerine, kişi başına ödedikleri ücreti gösteren ve özel otomobil sahibinin imzasını taşıyan Yönetmelik eki 1 örnek numaralı harcama pusulasını düzenleyeceklerdir.
Belediye hudutları içinde taksi veya özel otomobil ile yapılan seyahatlerde taksi rayiç belgesi, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi aranmaz.
c) İlgililerce yolculuk sırasında ödenen ve yolluk bildirimlerinde gösterilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin ödenmesinde geçiş ücretine ilişkin belge veya bilet aranmaz.

11.Elektronik sayaçlara yükletilen doğalgaz ve su bedellerinin ödenmesinde aranacak belgeler
(1) Elektronik sayaçlara yükletilen kredi tutarında tüketilen doğalgaz ve su bedelleri için, idarelerin ayrıntılı harcama planları ve serbest bırakılan ödenekler dahilinde, ilgili kuruluşa kredi şeklinde ön ödeme yapılır. Yapılacak ön ödemelerde Harcama Talimatı (Ek-1), gereken hallerde kredi izin yazısı ödeme belgesine bağlanır.
(2) Kredinin mahsubunda ödeme belgesine, fatura ve ön ödemenin yapılması sırasında düzenlenen Harcama Talimatının (Ek-1) bir nüshası bağlanır.

12. Avukatlara yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde aranacak belgeler
(1) Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, idare aleyhine sonuçlanan davalar ve ilama bağlı borçlar nedeniyle karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde; ödemenin doğrudan avukata yapılması halinde serbest meslek makbuzu ilgili maddede sayılan diğer belgelerle birlikte ödeme belgesine bağlanacak, ödemenin doğrudan icra dairesine yapılması halinde ise serbest meslek makbuzu aranmayacaktır.

13.Taşıma Giderleri
(1) Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde, onay belgesi ile faturanın ödeme belgesine bağlanacağı hükmüne yer verilmiştir.
(2) Ancak, kamu idarelerinin makam ve diğer hizmetlerinde kullanılan araçlarının otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin olarak otomatik geçiş veya kartlı geçiş sistemine abonelik bedelleri için onay belgesi düzenlenmek suretiyle ön ödeme yapılır. Ön ödemenin mahsubunda da ödeme belgesine fatura yerine aboneliğe ilişkin banka dekontu ile ön ödemenin yapılması sırasında düzenlenen onay belgesinin bir nüshası bağlanır.
(3) Yolcu ve yük taşımasına ilişkin olarak otoyol ve köprülerden münferit geçişlerde ise fatura yerine, geçişi yapan görevlilerce düzenlenen geçiş tarihi, sayısı, tutarını gösteren ve görevlendirme veya geçişlerden bilgisi olan amir tarafından imzalanan bildirim ödeme belgesine bağlanır.

14.Taşınır işlem fişi
(1) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddesinde taşınır işlem fişinin düzenlenmeyeceği belirtilen taşınır alımlarında ödeme emri belgesine taşınır işlem fişi bağlanmayacaktır.

15. Diğer hususlar
(1)Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Boş kamu konutlarına ait ısınma giderleri ile diğer ortak giderlerin, kamu idarelerince ödenmesinde;
-Giderlerin karşılanmasına ilişkin karar defterinin ilgili sayfasının kamu konutu yöneticisi tarafından onaylanmış örnekleri,
-Her daireye isabet eden ısınma giderinin hesabını gösteren cetvel,
-Isınma gideri ile diğer ortak giderler için yönetici tarafından düzenlenen tahsilat makbuzu,
ödeme emri belgesine bağlanır.
b) Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı da gösterilir. Ayrıca, 25/A örnek numaralı Yurtdışı Öğrenci Giderleri Bordrosunun "Aylık ödenek (yabancı para)" sütunu ile "Diğer ödemeler" sütunundaki YTL ibaresi çıkarılarak tutarlar yabancı para cinsinden gösterilecektir.
c) Yönetmelik eki bordro ve benzeri belgeler üzerinde birim amiri için ayrılan bölüm, harcama yetkililerince aksine bir görevlendirme yapılmadığı sürece;
1) Personelin aylık, ücret ve diğer özlük haklarının ödenmesinde, ilgili harcama biriminin insan kaynakları yetkililerince,
2) Diğer giderlerde ise giderle ilgili hizmetin yapıldığından bilgisi olan yetkililerce,

imzalanacaktır.
d) Yönetmelik eki belgeler, aynı bilgileri kapsamak koşuluyla, ebadına ve şekil şartına bağlı kalmaksızın basılı olarak veya elektronik ortamda düzenlenebilir.

16. Kaldırılan düzenlemeler ve yürürlük
(1) 28/9/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2006/1 no.lu Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.

---

1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Yapım İşleri / Mal Alımı / Hizmet Alımı / Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ekinde bulunan standart (İhale Onay Belgesi) formları.
2 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamalarına ilişkin çeşitli mevzuatta açıklandığı şekilde düzenlenen onay belgesi.

HARCAMA TALİMATI

Tarih:
Sayı: .....//20..
Harcama talebinde bulunan birim:

...MAKAMINA

YAPILACAK HARCAMANIN	
Gerekçesi ve hukuki dayanağı	
Konusu/nev'i / niteliği	
Miktarı	
Gerçekleştirme süresi	
Gerçekleştirme usulü	
Tutarı veya belirlenmişse yaklaşık bedeli	
Kullanılabilir ödenek tutarı	
Ödeneğin bütçe tertibi	
Gerçekleştirme görevlileri	

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda belirtilen harcamanın yaptırılması/harcamanın yaptırılması için harcama yetkilisi mutemedi .....'na .....YTL .avans verilmesi, hususu olurlarınıza arz olunur. Teklif Eden Yetkilinin İmzası :..... Adı Soyadı :..... Unvanı :.....	O L U R ..../ ... /.... Harcama Yetkilisi* İmzası :..... Adı Soyadı :..... Unvanı :.....

*Bu sütun, yönetim kurulu, komisyon veya komite kararlarıyla yapılan harcamalarda kurul, komisyon, komite üyelerinin imzalarını kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

KAYNAKÇA

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Kamu İhale Genel Tebliği

KİK Doğrudan Temin Son Kullanıcı Kılavuzu

KİK Elektronik Kamu Alımları Platformu Doğrudan Temin Kullanıcı Kılavuzu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satınalma Rehberi, Ankara, 2018.

ALTUNKÜLÇE, M. Rasih ve SAĞIR, Yücel, Tüm Yönleriyle Doğrudan Temin, TBB, Ankara:2020

DEMİREL, Salim ve ARAPGİRLİ, Murat, Doğrudan Temin El Kitabı, TBB, Ankara:2012

DEMİREL, Salim ARAPGİRLİ, Murat ALTINTAŞ, Hüseyin: Sorularla Doğrudan Temin, Ankara Yayınevi, Ankara 2014.

ŞENER, Ramazan, "Kamu İdarelerinde Doğrudan Temin Yöntemi", http://www.muhasebeciyizbiz.com/kamu-idarelerinde-dogrudan-temin yontemi.html.

AZAK, H.İbrahim, "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin ve Uygulanması", İller ve Belediyeler Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 2010, sayı: 750, 751, 752, s. 46-59.

İNAN, Atilla: İhale Hukuku Ders Notları, Ankara 2011.

BÜYÜKBAŞ, Ercan ve ORMANOĞLU, Burhan, "İhale Kararları ve Damga Vergisi", İller ve Belediyeler Dergisi, Temmuz 2011, Sayı: 759, s.50-59.

BÜYÜKBAŞ, Ercan **"**Doğrudan Temin; Uygulamalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri**",** Mali Hukuk Dergisi, Kasım-Aralık 2011, sayı: 156.

KÜÇÜKÇAKIRLAR, Işıl, "4734 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a) ve (b) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Yapılan Alımlar**,** Yayımlanmamış Kamu İhale Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara, 2010.

FİDAN, M.Erol ve BAT, Bilal, "Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Olası Hata ve Hile Riskleri: Bir Kamu Kurumu Örneği", Şeyh Edibali Üniversitesi, Bilecek, 2021

ÜSTÜN, Ümit Süleyman ve ÇALIŞ, Hande Sena, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Doğrudan Temin Usulü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 27, S. 1, 2019, s. 11-36.

SARITAŞ, Hatice, " İhaleye Fesat Karıştırma Ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları", Sayıştay Dergisi, Ankara, Sayı:73, 51-67.

https://www.mevzuat.gov.tr

https://www.hmb.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

https://www.ihale.gov.tr

https://www.resmigazete.gov.tr

https://mevzuatsal.com

https://www.malihakem.com

https://ihalesorucevap.com

https://www.tbb.gov.tr

https://www.mud.org.tr

https://www.kidder.org.tr